

eBook
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

DIREITO PENAL

Autores:
Samer Agi e Michelle Tonon

Organizado por CP Iuris
ISBN 978-85-5805-020-3

DIREITO PENAL

1ª edição

**Brasília
CP Iuris
2020**

SOBRE OS AUTORES

SAMER AGI. Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Foi Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Autor do livro *Comentários à Nova Lei de Abuso de Autoridade* e coautor do livro *Os 23 pontos da sentença penal*. Mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa.

MICHELLE TONON. Bacharel em Direito pela Universidade de Brasília - UnB (2005). Foi aprovada, ainda durante a faculdade, no concurso para técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça. Atuou, de 2005 a 2007, como assessora de Subprocuradores-Gerais da República na PGR. Ingressou na Defensoria Pública do Distrito Federal em 2008, com atuação predominante na área criminal e Tribunal do Júri. Possui pós-graduação *lato sensu* em Direito, Estado e Constituição pela Jurplac/Faciplac (2009). É coautora das obras "Série Defensoria Pública. Teses jurídicas dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Direito Penal e Processual Penal. Coordenação da ADEP-DF", "Manual de mediação judicial", "Estudos de arbitragem, mediação e negociação. Volumes 2 e 3", "O novo Direito Administrativo brasileiro - o Estado, as agências e o terceiro setor" e "O novo Direito Administrativo - o público e o privado em debate."

Introdução à obra.....	35
Capítulo 1 — Lições preliminares de direito penal	36
1. Criminologia e política criminal	36
2. Função do direito penal.....	37
3. Classificações do direito penal	38
3.1. Direito penal substantivo e direito penal adjetivo	38
3.2. Direito penal objetivo e direito penal subjetivo.....	38
3.3. Direito penal de emergência e direito penal simbólico	38
3.4. Direito penal promocional/político/demagogo	39
3.5. Direito penal de intervenção	39
3.6. Direito penal como proteção de contextos da vida em sociedade	39
3.7. Direito penal garantista	40
3.8. Direito penal secularizado	41
3.9. Direito penal subterrâneo e direito penal paralelo.....	41
3.10. Direito penal quântico	41
3.11. A escola de Kiel – Direito penal da Alemanha nacional-socialista	42
3.12. O direito penal comunista	42
4. Privatização do direito penal	42
5. Velocidades do direito penal	43
6. Espiritualização, dinamização ou desmaterialização do bem jurídico	43
7. Garantismo hiperbólico monocular.....	44
8. Ecocídio	44
Capítulo 2 — Evolução histórica	45
1. Período da Vingança	45
2. Período iluminista.....	45
3. Período das Escolas Penais	45

4. Direito penal brasileiro.....	46
Capítulo 3 — Fontes do direito penal	47
1. Doutrina clássica.....	47
2. Doutrina moderna	47
3. Costume	48
4. Características da lei penal	48
5. Classificação da lei penal	49
Capítulo 4 — Interpretação da lei penal.....	50
1. Quanto à origem (ou ao sujeito que interpreta)	50
2. Quanto ao modo	50
3. Quanto ao resultado	50
4. Formas de interpretar a lei penal.....	51
4.1. Interpretação extensiva.....	51
4.2. Interpretação analógica.....	51
5. Analogia	51
Capítulo 5 — Teoria geral da norma penal.....	53
1. Princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos	53
2. Princípio da intervenção mínima	53
3. Princípio da insignificância	53
4. Princípio da adequação social.....	55
5. Princípio da exteriorização ou da materialização do fato	56
6. Princípio da legalidade	56
7. Princípio da ofensividade ou lesividade	57
7.1. Princípio da alteridade.....	58
8. Princípio da responsabilidade pessoal	58

9. Princípio da responsabilidade subjetiva	59
10. Princípio da culpabilidade.....	59
11. Princípio da presunção de inocência (não culpabilidade)	59
12. Princípio da pessoalidade	59
13. Princípio da vedação do <i>bis in idem</i>	60
14. Princípio da confiança	60
Capítulo 6 — Eficácia da lei penal no tempo	61
1. Introdução	61
2. Tempo do crime	61
3. Sucessão de leis penais	61
3.1. <i>Novatio legis</i> incriminadora.....	61
3.2. <i>Novatio legis in pejus</i>	61
3.3. <i>Abolitio criminis</i>	62
3.4. <i>Novatio legis in melius</i>	62
3.5. Lei penal benéfica em período de <i>vacatio legis</i>	62
3.6. Combinação de leis penais (<i>lex tertia</i>).....	63
3.7. Continuidade típico-normativa.....	63
3.8. Leis temporárias e excepcionais.....	63
3.9. Retroatividade da jurisprudência	63
3.10. Retroatividade da lei penal no caso de norma penal em branco.....	64
3.11. Lei intermediária mais benéfica	64
Capítulo 7 — Lei penal no espaço.....	66
1. Introdução e princípios.....	66
2. Teorias da lei penal no espaço	66
3. Território nacional	66
4. Embaixadas	67
5. Passagem inocente	67

6. Lugar do crime	67
7. Extraterritorialidade.....	67
7.1. Extraterritorialidade incondicionada.....	67
7.2. Extraterritorialidade condicionada.....	68
7.3. Extraterritorialidade hipercondicionada	69
8. Competência para extraterritorialidade	69
9. Pena cumprida no estrangeiro.....	69
Capítulo 8 — Eficácia da lei penal em relação às pessoas	70
1. Imunidade diplomática	70
2. Agente consular	70
3. Imunidades parlamentares.....	70
3.1. Imunidades absolutas (substancial, material ou indenidade).....	70
3.2. Imunidades relativas (formal ou processual)	71
3.2.1. Imunidade relativa ao foro	71
3.2.2. Imunidade relativa à prisão (incoercibilidade dos congressistas).....	71
3.2.3. Imunidade relativa ao processo	72
3.2.4. Imunidade relativa à condição de testemunha	72
3.2.5. Imunidade relativa ao estado de sítio	72
3.3. Parlamentar licenciado.....	73
3.4. Imunidades dos deputados estaduais	73
3.5. Imunidades dos vereadores	73
Capítulo 9 — Disposições gerais.....	74
1. Eficácia da sentença estrangeira	74
2. Contagem de prazo	74
3. Frações não computáveis da pena	74
4. Conflito aparente de normas	74
4.1. Princípio da especialidade	75
4.2. Princípio da subsidiariedade.....	75
4.3. Princípio da consunção.....	75

Capítulo 10 — Teoria geral do crime: Introdução	77
1. Conceito de infração penal	77
2. Diferença entre crime e contravenção	77
3. Sujeito ativo do crime	78
3.1. Responsabilização penal da pessoa jurídica	78
3.2. Responsabilização penal da pessoa jurídica dissolvida	79
3.3. Responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público	79
3.4. Crime comum, crime próprio e crime de mão própria.....	80
4. Sujeito passivo do crime.....	80
4.1. Espécies de sujeito passivo.....	80
4.2. Classificação do sujeito passivo	80
4.3. Crime contra o morto	80
4.4. Simultaneidade de sujeição ativa e passiva	81
5. Objeto jurídico do crime e objeto material.....	81
5.1. Objeto material.....	81
5.2. Objeto jurídico	81
6. Classificação dos crimes	81
6.1. Classificação quanto ao resultado	82
6.2. Classificação quanto ao sujeito	82
6.3. Classificação quanto ao ânimo do agente	82
6.4. Classificação quanto ao momento de consumação	82
6.5. Crime consumado ou tentado	83
6.6. Crime de dano ou crime de perigo	83
6.7. Crime simples, complexo, qualificado e privilegiado	83
6.8. Crime plurissubjetivo ou unissubjetivo	84
6.9. Crime omissivo ou comissivo.....	84
6.10. Crime unissubsistente ou plurissubsistente	85
6.11. Crime habitual	85
6.12. Crime exaurido	85
6.13. Crime de ação única ou crime de ação múltipla	85
6.14. Crime falho e quase-crime.....	86

6.15. Crime de atentado	86
6.16. Crime de resultado cortado e crime mutilado de dois atos	86
6.17. Delito de tendência interna transcendente	86
6.18. Crime de acumulação	87
6.19. Crime de rua ou crime de colarinho azul.....	87
6.20. Crime de olvido.....	87
6.21. Quanto à existência autônoma do crime	87
6.22. Quanto à necessidade de exame de corpo de delito como prova	88
6.23. Quanto ao vínculo existente entre os crimes.....	88
6.24. Quanto à liberdade para iniciar a ação penal.....	88
6.25. Outras classificações.....	88
7. Substratos do crime	90
Capítulo 11 — Teoria geral do crime: Fato típico.....	91
1. Conceito e elementos do fato típico	91
2. Conduta.....	91
2.1. Teorias da conduta	91
2.1.1. Teoria causalista (natural)	91
2.1.2. Teoria neokantista (neoclássica)	92
2.1.3. Teoria finalista	92
2.1.4. Teoria social da ação	93
2.1.5. Teorias funcionalistas	93
a) Funcionalismo moderado (teleológico).....	93
b) Funcionalismo radical (sistêmico)	93
2.1.6. Teoria adotada pelo Código Penal.....	94
2.1.7. Teoria da ação significativa	94
2.2. Elementos da conduta	95
2.3. Causas de exclusão da conduta	95
2.4. Formas de conduta	95
2.4.1. Conduta dolosa.....	95
a) Fase interna	97
b) Fase externa	97
2.4.2. conduta culposa	98

2.4.3. Conduta preterdolosa.....	100
2.5. Erros de tipo	100
2.5.1. Diferença entre erro de tipo e erro de proibição	101
2.5.2. Erro de tipo essencial	101
2.5.3. Erro de tipo accidental	101
2.6. Classificação dos crimes quanto ao modo de execução.....	104
3. Resultado	105
4. Nexo causal	106
4.1. Conceito e teorias.....	106
4.2. Concausas	106
4.2.1. Concausas absolutamente independentes	106
4.2.2. Concausas relativamente independentes	107
4.3. Teoria da imputação objetiva.....	108
4.3.1. Criação ou incremento de um risco juridicamente proibido.....	109
4.3.2. Realização do risco proibido no resultado	109
4.3.3. Resultado dentro do alcance do tipo	109
4.4. Causalidade nos crimes omissivos.....	109
5. Tipicidade penal.....	110
5.1. Tipicidade formal.....	110
5.2. Elementos do tipo penal.....	110
5.3. Tipo penal congruente e incongruente	111
5.4. Tipo simples e tipo misto.....	111
Capítulo 12 — Teoria geral do crime: Ilicitude	112
1. Conceito	112
2. Teorias que explicam a relação entre fato típico e ilicitude.....	112
3. Causas excludentes da ilicitude (descriminantes)	113
3.1. Estado de necessidade	113
3.1.1. Conceito.....	113
3.1.2. Requisitos do estado de necessidade.....	113
3.1.3. Estado de necessidade em crime habitual e em crime permanente	114
3.1.4. Estado de necessidade contra estado de necessidade	114

3.1.5. Estado de necessidade e erro na execução	115
3.2. Legítima defesa.....	115
3.2.1. Conceito – art. 25, CP	115
3.2.2. Requisitos da legítima defesa.....	115
3.2.3. Legítima defesa e erro na execução	116
3.2.4. Legítima defesa recíproca.....	116
3.2.5. Legítima defesa sucessiva.....	116
3.2.6. Legítima defesa real contra legítima defesa putativa	117
3.2.7. Legítima defesa putativa recíproca	117
3.3. Estrito cumprimento do dever legal.....	117
3.3.1. Conceito.....	117
3.3.2. Requisitos	117
3.4. Exercício regular de um direito	117
3.4.1. Conceito.....	117
3.4.2. Requisitos	117
3.5. Ofendículos.....	118
3.5.1. Conceito.....	118
3.5.2. Natureza jurídica	118
3.6. Causas supralegais de exclusão da ilicitude	118
3.6.1. Requisitos do consentimento como causa excludente da ilicitude	118
3.6.2. Integridade física é bem jurídico disponível?	118
3.6.3. Consentimento do ofendido nos crimes culposos	119
3.7. Excesso na justificante.....	119
3.8. Discriminante putativa	120
3.8.1. Erro quanto à existência da discriminante	120
3.8.2. Erro quanto aos pressupostos fáticos (discriminante putativa por erro de tipo).....	120
Capítulo 13 — Teoria geral do crime: Culpabilidade.....	122
1. Conceito	122
2. Teorias da culpabilidade.....	122
2.1. Teoria psicológica da culpabilidade.....	122
2.2. Teoria psicológica-normativa	122
2.3. Teoria normativa pura (extremada)	122

3. Culpabilidade	123
4. Culpabilidade às avessas.....	123
5. Culpabilidade do autor ou culpabilidade do fato	123
6. Elementos da culpabilidade.....	124
6.1. Imputabilidade.....	124
6.1.1. Conceito e elementos de imputabilidade	124
6.1.2. Critérios da imputabilidade	124
6.1.3. Inimputabilidade em razão da capacidade mental do agente	124
6.1.4. Inimputabilidade em razão da idade.....	125
6.1.5. Inimputabilidade em razão da embriaguez.....	125
a) Embriaguez não accidental	125
b) Embriaguez accidental	126
6.1.6. Imputabilidade do índio não integrado.....	126
6.1.7. Emoção e paixão.....	126
6.2. Potencial consciência da ilicitude	127
6.2.1. Conceito.....	127
6.2.2. Erro de proibição	127
6.2.3. Espécies de erro de proibição	127
6.3. Exigibilidade de conduta diversa	128
6.3.1. Conceito.....	128
6.3.2. Coação moral irresistível	128
6.3.3. Obediência hierárquica	128
6.3.4. Dirimentes supralegais	128
Capítulo 14 — Teoria geral do crime: Punibilidade.....	130
1. Conceito	130
2. Causas extintivas da punibilidade	130
2.1. Morte do agente.....	130
2.2. Anistia, graça e indulto	131
2.2.1. Anistia	131
2.2.2. Graça e indulto	131
2.2.3. Anistia, graça e indulto e os crimes hediondos	132

2.3. <i>Abolitio criminis</i>	132
2.4. Decadência	132
2.5. Perempção	133
2.6. Prescrição	133
2.6.1. Diferença entre decadência e prescrição	133
2.6.2. Hipóteses de imprescritibilidade	133
2.6.3. Espécies de prescrição	133
a) Prescrição da pretensão punitiva em abstrato	134
b) Prescrição da pretensão punitiva superveniente (ou intercorrente)	136
c) Prescrição da pretensão punitiva retroativa	136
d) Prescrição da pretensão punitiva virtual (antecipada ou em perspectiva ou prognose)	137
e) Prescrição da pretensão executória	137
2.6.4. Prescrição para atos infracionais	138
2.6.5. Prescrição da pena de multa	138
2.6.6. Redução dos prazos prescricionais	139
2.6.7. Prescrição e medida de segurança	139
2.7. Renúncia ao direito de agir	139
2.8. Perdão do ofendido	139
2.9. Retratação do agressor	140
2.10. Perdão judicial	140
Capítulo 15 — Teoria geral do crime: <i>Iter criminis</i>	141
1. Conceito	141
2. Fases	141
3. Teorias que tratam do momento em que o ato preparatório passa a ser ato executório	141
4. Tentativa	142
4.1. Conceito	142
4.2. Punição da tentativa	142
4.3. Critério para punição	142
4.4. Elementos da tentativa	142
4.5. Espécies de tentativa	143
4.6. Infrações penais que não admitem tentativa	143

5. Desistência voluntária e arrependimento eficaz	144
5.1. Conceito	144
5.2. Natureza jurídica	144
5.3. Análise dos institutos.....	144
5.4. Arrependimento posterior	145
5.5. Crime impossível.....	146
 Capítulo 16 — Teoria geral do crime: Concurso de pessoas	147
1. Conceito	147
2. Requisitos	147
3. Teorias.....	147
4. Formas de praticar o crime quanto ao sujeito	148
4.1. Autoria (<i>animus auctoris</i>)	148
4.2. Autoria mediata	148
4.3. Autoria colateral	149
4.4. Multidão delinquente.....	149
5. Coautoria.....	149
6. Participação (<i>animus socii</i>).....	150
6.1. Espécies de partícipe	150
6.2. Teorias da punição do partícipe	150
6.3. Participação em cadeia e participação sucessiva	150
7. Concurso de pessoas em crimes culposos	151
8. Concurso de pessoas em crimes omissivos	151
9. Participação de menor importância	151
10. Participação dolosamente distinta	151
11. Comunicabilidade das circunstâncias, condições e elementares.....	152
12. Participação impunível	152
 Capítulo 17 — Teoria geral da pena: Conceitos e fundamentos	153
1. Conceitos e fundamentos	153

2. Finalidades (ou funções) da pena.....	153
2.1. Teorias da pena	153
3. Finalidade da pena no Brasil.....	154
4. Justiça restaurativa	155
5. Princípios informadores da pena	155
6. Penas proibidas no Brasil	156
6.1. Pena de morte	156
6.2. Pena de caráter perpétuo.....	156
6.3. Pena de trabalhos forçados.....	156
6.3. Pena de banimento	156
6.4. Penas cruéis	156
7. Penas permitidas no Brasil	157
7.1. Privação da liberdade	157
7.2. Restritivas de direito.....	157
7.3. Pena de multa.....	157
Capítulo 18 — Teoria geral da pena: Aplicação da pena	158
1. Fixação da pena privativa de liberdade	158
1.1. Conceito.....	158
1.2. Sistema trifásico (Sistema Nelson Hungria).....	158
1.2.1. Primeira fase: circunstâncias judiciais	158
a) Culpabilidade	158
b) Antecedentes	159
c) Conduta social.....	160
d) Personalidade do agente.....	160
e) Motivos do crime.....	161
f) Circunstâncias do crime	161
g) Consequências do crime	161
h) Comportamento da vítima	161
1.2.2. Segunda fase: agravantes e atenuantes.....	161
a) Preponderância	161
b) Agravantes.....	162

c) Atenuantes.....	165
1.2.3. Terceira fase: causas de aumento e de diminuição da pena	168
a) Concurso (homogêneo) entre causas de aumento	168
b) Concurso (homogêneo) entre causas de diminuição.....	169
c) Concurso entre causas de aumento e de diminuição.....	169
1.3. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.....	169
1.3.1. Regime fechado	170
1.3.2. Regime semiaberto.....	171
1.3.3. Regime aberto	171
1.4. Espécies de pena privativa de liberdade.....	172
1.4.1. Pena de reclusão.....	172
1.4.2. Pena de detenção	172
1.4.3. Pena de prisão simples	173
1.4.4. Regime especial para cumprimento de pena de prisão pela mulher.....	173
1.5. Fixação do regime inicial de cumprimento de pena e detração	173
1.6. Penas e medidas alternativas à prisão	174
1.6.1. Penas restritivas de direito.....	174
a) Espécies de penas restritivas de direito	174
b) Características das penas restritivas de direitos	175
c) Requisitos das penas restritivas de direitos	176
d) Penas restritivas de direitos X delitos de ameaça, lesão corporal leve e constrangimento ilegal.....	176
e) Penas restritivas de direitos x delitos de roubo impróprio	176
f) Penas restritivas de direitos x crimes militares.....	177
g) Penas restritivas de direitos x regras da substituição	177
h) Penas restritivas de direitos x conversão	177
1.7. Suspensão condicional da pena.....	180
1.7.1. Conceito.....	180
1.7.2. Sistemas do <i>sursis</i>	180
a) Espécies, requisitos e condições	181
b) Revogação do <i>sursis</i>	182
c) Cassação do <i>sursis</i>	183
d) Prorrogação do <i>sursis</i>	184
e) Extinção do <i>sursis</i>	184

f) Sursis sucessivos	184
g) Sursis simultâneos	184
h) Sursis para estrangeiro	184
1.8. Livramento condicional	185
1.8.1. Conceito	185
1.8.2. Requisitos	185
a) Requisitos objetivos.....	185
b) Requisitos subjetivos.....	185
1.8.3. Condições para o livramento condicional	186
1.8.4. Concessão e execução do livramento condicional	186
1.8.5. Revogação do livramento condicional.....	186
a) Revogação obrigatória.....	186
b) Revogação facultativa	187
1.8.6. Prorrogação do livramento condicional	187
1.8.7. Extinção da pena	188
Capítulo 19 — Teoria geral da pena: Concurso de crimes	189
1. Introdução	189
1.1. Conceito.....	189
1.2. Sistemas de aplicação da pena	189
2. Concurso material	189
2.1. Conceito.....	189
2.2. Requisitos	189
2.3. Condenação a pena de reclusão e de detenção	190
2.4. Condenação a pena privativa de liberdade e restritiva de direitos.....	190
2.5. Concurso material e penas restritivas de direitos.....	190
2.6. Espécies de concurso material	190
2.7. Regras de fixação de pena no concurso material.....	190
2.8. Concurso material e concessão de fiança depois da Lei 12.403/2011	190
2.9. Concurso material e suspensão condicional do processo	191
2.10. Concurso material e prescrição	191
3. Concurso formal (ou ideal) de crimes.....	191
3.1. Conceito.....	191

3.2. Requisitos do concurso formal	191
3.3. Espécies de concurso formal	191
3.4. Regras de fixação da pena	192
3.4.1. Concurso formal próprio	192
3.4.2. Concurso formal impróprio	192
4. Crime continuado ou continuidade delitiva.....	192
4.1. Conceito.....	192
4.2. Espécies de crime continuado	193
4.2.1. Crime continuado genérico	193
4.2.2. Crime continuado específico	194
4.3. Súmula 711 do STF	194
4.4. Súmula 723 do STF	194
4.5. Aplicação cumulativa de concurso formal e continuidade delitiva.....	194
4.6. Continuidade delitiva e homicídio doloso	195
4.7. Crime continuado e multa	195
5. Questões complementares.....	195
5.1. Concurso de crimes e Juizados Especiais Criminais.....	195
5.2. Concurso de crimes e Lei 12.403/11	195
Capítulo 20 — Teoria geral da pena: Medidas de segurança.....	196
1. Introdução	196
2. Finalidades	196
3. Espécies de medida de segurança	196
4. Pressupostos da medida de segurança.....	196
5. Duração da medida de segurança	197
6. Perícia médica.....	197
7. Desinternação ou liberação condicional.....	197
8. Reinternação do agente	198
9. Conversão da pena em medida de segurança.....	198
10. Extinção da punibilidade e medida de segurança	198

11. Medida de segurança preventiva	199
Capítulo 21 — Teoria geral da pena: Efeitos da condenação.....	200
1. Introdução	200
2. Efeitos extrapenais.....	200
2.1. Efeitos extrapenais genéricos.....	200
2.2. Efeitos extrapenais específicos.....	200
3. Efeitos da condenação na legislação extravagante	203
3.1. Lei de Tortura	203
3.2. Lei de Organização Criminosa.....	203
3.3. Lei de Lavagem	203
3.4. Lei de Racismo (Lei 7.716/89).....	203
3.5. Lei de Falência	204
Capítulo 22 — Teoria geral da pena: Reabilitação	205
1. Conceito	205
2. Efeitos	205
3. Requisitos da reabilitação	205
4. Revogação da reabilitação.....	205
5. Competência.....	206
6. Recurso.....	206
7. Pluralidade de condenações	206
8. Reabilitação x reincidência	206
Capítulo 23 — Ação penal	207
1. Conceito	207
2. Características	207
3. Condições da ação.....	207
3.1. Condições genéricas	207
3.2. Condições específicas	207

4. Classificação da ação penal.....	208
4.1. Ação penal pública incondicionada	208
4.2. Ação penal pública condicionada	208
4.2.1. Representação do ofendido	208
4.3. Ação penal de iniciativa privada	209
4.3.1. Ação penal exclusivamente privada	210
4.3.2. Ação penal privada personalíssima	211
4.3.3. Ação penal privada subsidiária da pública	211
5. Institutos que ensejam a extinção da punibilidade nos crimes perseguidos mediante ação penal privada.....	211
6. Ação penal nos crimes contra a honra.....	212
Capítulo 24 — Dos Crimes Contra a Pessoa: Dos crimes contra a vida.....	213
1. Art. 121. Homicídio	213
1.2. Homicídio Privilegiado	214
1.3. Homicídio Privilegiado-Qualificado ou Híbrido	215
1.4. Homicídio Qualificado	216
1.5. Homicídio Culposos.....	222
Questões	223
Comentários	223
2. Art. 122. Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio ou a Automutilação (Redação dada pela Lei Nº 13.968/19).....	224
3. Art. 123. Infanticídio	226
4. Arts. 124 a 128. Aborto	226
Questões	229
Capítulo 25 — Dos Crimes Contra a Pessoa: Das lesões corporais.....	230
1. Art. 129. Lesão Corporal	230
1.1. Considerações iniciais.....	230
1.2. Substituição de pena	233
1.3. Aumento de pena (lesão corporal culposa majorada)	234

1.4. Perdão judicial	234
1.5. Violência doméstica.....	234
Capítulo 26 — Dos Crimes Contra a Pessoa: Da Periclitção da Vida e da Saúde	236
1. Art. 130. Perigo de Contágio Venéreo	236
2. Art. 131. Perigo de Contágio de Moléstia Grave	237
3. Art. 132. Perigo para a Vida ou Saúde de outrem	237
4. Art. 133. Abandono de Incapaz.....	238
5. Art. 134. Exposição ou Abandono de Recém-Nascido	239
6. Art. 135. Omissão de Socorro	239
7. Art. 135-A. Condicionamento de Atendimento Médico-Hospitalar Emergencial	240
8. Art. 136. Maus-Tratos	241
Capítulo 27 — Dos Crimes Contra a Pessoa: Da Rixa	243
1. Art. 137. Rixa	243
1.1. Qualificadora	243
Capítulo 28 — Dos Crimes Contra a Pessoa: Dos Crimes Contra a Honra	245
1. Classificação da honra	245
2. Art. 138. Calúnia	245
3. Art. 139. Difamação	246
3.1. Exceção da notoriedade	246
4. Art. 140. Injúria.....	247
Questões	249
Capítulo 29 — Dos Crimes Contra a Pessoa: Crimes Contra a Liberdade Individual.....	250
1. Art. 146. Constrangimento Ilegal	250
2. Art. 147. Ameaça	250
3. Art. 148. Sequestro e Cárcere Privado.....	251

4. Art. 149. Redução a Condição Análoga à de Escravo	252
5. Art. 149-A. Tráfico de Pessoas	253
6. Dos Crimes Contra a Inviolabilidade do Domicílio.....	254
6.1. Art. 150. Violação de Domicílio	254
7. Dos Crimes Contra a Inviolabilidade de Correspondência	255
7.1. Art. 151. Violação de Correspondência	255
7.1.1. Consumação e tentativa	256
7.2. Art. 152. Correspondência Comercial.....	257
8. Dos Crimes Contra a Inviolabilidade dos Segredos.....	257
8.1. Art. 153. Divulgação de Segredos	257
8.2. Art. 154. Violação de Segredo Profissional.....	258
8.3. Art. 154-A. Invasão de Dispositivo Informático	258
Capítulo 30 — Dos Crimes Contra o Patrimônio: Do Furto	260
1. Art. 155. Furto	260
1.2. Princípio da insignificância ou bagatela (causa de exclusão da tipicidade)	260
1.3. Requisitos para o reconhecimento da insignificância no caso concreto.....	261
1.4. Teorias acerca da consumação dos crimes de furto e roubo.....	262
1.5. Repouso noturno	262
1.6. Furto privilegiado.....	263
1.7. Furto privilegiado-qualificado (híbrido).....	263
1.8. Furto qualificado.....	264
1.8. Art. 156. Furto de Coisa Comum	268
Questões	268
Capítulo 31 — Dos Crimes Contra o Patrimônio: Do Roubo e Da Extorsão	269
1. Consumação do roubo próprio	270
2. Roubo circunstanciado, agravado ou majorado (roubo próprio ou impróprio)	270
3. Pluralidade de causas de aumento de pena	273
4. Roubo qualificado pelo resultado	274

4.1. Latrocínio (art. 157, §3º, inc. II)	274
Questões	275
5. Art. 158. Extorsão	276
Questões	277
6. Art. 159. Extorsão Mediante Sequestro.....	277
7. Art. 160. Extorsão Indireta.....	278
Capítulo 32 — Dos Crimes Contra o Patrimônio: Da Usurpação	279
1. Art. 161. Alteração de Limites.....	279
2. Art. 162. Supressão ou Alteração de Marca em Animais	280
Capítulo 33 — Dos Crimes Contra o Patrimônio: Do Dano	281
1. Documentos públicos podem ser objeto material do crime de dano?	281
2. Figuras qualificadas do dano. Art. 163, parágrafo único, incisos I a IV	282
3. Dano à cela ou instalação de presídio com finalidade de fuga.....	283
4. Art. 164. Introdução ou Abandono de Animais em Propriedade Alheia	283
5. Art. 165. Dano em Coisa de Valor Artístico, Arqueológico ou Histórico	283
6. Art. 166. Alteração de Local Especialmente Protegido	283
7. Art. 167. Ação Penal.....	283
Capítulo 34 — Dos Crimes Contra o Patrimônio: Da Apropriação Indébita	284
1. Art. 168. Apropriação Indébita	284
2. Art. 168-A. Apropriação Indébita Previdenciária	284
3. Art. 169. Apropriação de Coisa Havia por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza.....	286
4. Art. 170. Apropriação Indébita Privilegiada	286
Capítulo 35 — Dos Crimes Contra o Patrimônio: Do Estelionato e Outras Fraudes	288
1. Art. 171. Estelionato.....	288

1.1. Reparação do dano e estelionato.....	290
2. Art. 172. Duplicata Simulada	291
3. Art. 173. Abuso de Incapazes.....	291
4. Art. 174. Induzimento à Especulação	292
5. Art. 175. Fraude no Comércio	292
6. Art. 176. Outras fraudes	293
7. Art. 177. Fraudes e Abusos na Fundação ou Administração de Sociedade por Ações	293
8. Art. 178. Emissão Irregular de Conhecimento de Depósito ou <i>Warrant</i>	294
9. Art. 179. Fraude à Execução	294
Capítulo 36 — Dos Crimes Contra o Patrimônio: Da Receptação	296
1. Art. 180-A. Receptação de Animal	297
Capítulo 37 — Dos Crimes Contra o Patrimônio: Disposições Gerais.....	299
Questões.....	299
Capítulo 38 — Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial.....	301
1. Art. 184. Violação de Direito Autoral	301
2. Art. 185. Usurpação de Nome ou Pseudônimo Alheio.....	302
3. Art. 186. Ação Penal.....	303
Capítulo 39 — Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial: Dos Crimes Contra o Privilégio de Invenção	304
Capítulo 40 — Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial: Dos Crimes Contra as Marcas de Indústria e Comércio.....	304
Capítulo 41 — Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial: Dos Crimes de Concorrência Desleal	304
Capítulo 42 — Dos Crimes Contra a Organização do Trabalho	305
1. Art. 197. Atentado Contra a Liberdade de Trabalho.....	305
2. Art. 198. Atentado Contra a Liberdade de Contrato de Trabalho e Boicotagem Violenta	305

3. Art. 199. Atentado Contra a Liberdade de Associação	306
4. Art. 200. Paralisação de Trabalho, Seguida de Violência ou Perturbação da Ordem	306
5. Art. 201. Paralisação de Trabalho de Interesse Coletivo.....	307
6. Art. 202. Invasão de Estabelecimento Industrial, Comercial ou Agrícola. Sabotagem.	307
7. Art. 203. Frustração de Direito Assegurado por Lei Trabalhista	307
8. Art. 204. Frustração de Lei Sobre a Nacionalização do Trabalho	308
9. Art. 205. Exercício de Atividade com Infração de Decisão Administrativa	308
10. Art. 206. Aliciamento para o Fim de Emigração	308
11. Art. 207. Aliciamento de Trabalhadores de um Local para Outro do Território Nacional	309
Capítulo 43 — Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso e Contra o Respeito aos Mortos: Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso.....	310
1. Art. 208. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo	310
2. Art. 209. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária	310
3. Art. 210. Violação de sepultura.....	310
4. Art. 211. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver.....	311
5. Art. 212. Vilipêndio a cadáver.....	311
Capítulo 44 — Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual.....	312
1. Art. 213. Estupro	312
2. Art. 214. Atentado violento ao pudor	313
3. Art. 215. Violação sexual mediante fraude	313
4. Art. 215-A. Importunação sexual	314
5. Art. 216. Atentado ao pudor mediante fraude	315
6. Art. 216-A. Assédio sexual	315
Capítulo 45 — Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: Da Exposição da Intimidade Sexual	317

1. Art. 216-B. Registro não autorizado da intimidade sexual.....	317
Capítulo 46 — Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável.....	319
1. Art. 217. Sedução	319
2. Art. 217-A. Estupro de vulnerável	319
3. Art. 218. Corrupção de menores	320
4. Art. 218-A. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente	321
5. Art. 218-B. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.....	322
6. Art. 218-C. Divulgação de cena de estupro e de estupro de vulnerável, de sexo ou pornografia	323
Capítulo 47 — Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: Do Rapto	325
Capítulo 48 — Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: Disposições Gerais	325
1. Art. 225. Ação Penal.....	325
2. Art. 226. Aumento de pena	325
Questões	326
Gabarito	327
Capítulo 49 — Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoa para o Fim de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual	328
1. Art. 227. Mediação para servir a lascívia de outrem	328
2. Art. 228. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual	329
3. Art. 229. Casa de prostituição.....	330
4. Art. 230. Rufianismo	331
5. Arts. 231 e 231-A. Tráfico internacional e interno para fim de exploração sexual	332
6. Art. 232-A. Promoção de migração ilegal	332
Capítulo 50 — Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: Do Ultraje Público ao Pudor	333
1. Art. 233. Ato obsceno.....	333

2. Art. 234. Escrito ou objeto obsceno	333
Capítulo 51 — Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: Disposições Gerais.....	335
1. Art. 234-A. Aumento de pena	335
Capítulo 52 — Dos Crimes Contra a Família: Dos Crimes Contra o Casamento.....	336
1. Art. 235. Bigamia	336
2. Art. 236. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento.....	337
3. Art. 237. Conhecimento prévio de impedimento	338
4. Art. 238. Simulação de autoridade para celebração de casamento.....	338
5. Art. 239. Simulação de casamento	338
6. Art. 240. Adultério	339
Capítulo 53 — Dos Crimes Contra a Família: Dos Crimes Contra o Estado de Filiação	340
1. Art. 241. Registro de nascimento inexistente	340
2. Art. 242. Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido.....	340
3. Art. 243. Sonegação de estado de filiação	341
Capítulo 54 — Dos Crimes Contra a Família: Dos Crimes Contra a Assistência Familiar.....	342
1. Art. 244. Abandono material	342
2. Art. 245. Entrega de filho menor a pessoa inidônea.....	342
3. Art. 246. Abandono intelectual.....	343
4. Art. 247. Abandono moral	344
Capítulo 55 — Dos Crimes Contra a Família: Dos Crimes Contra o Pátrio Poder, Tutela ou Curatela ...	346
1. Art. 248. Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes.....	346
2. Art. 249. Subtração de incapazes	346
Capítulo 56 — Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública: Dos Crimes de Perigo Comum.....	348

1. Art. 250. Incêndio.....	348
2. Art. 251. Explosão	349
3. Art. 252. Uso de gás tóxico ou asfixiante.....	350
4. Art. 253. Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante.....	351
5. Art. 254. Inundação.....	351
6. Art. 255. Perigo de inundação.....	351
7. Art. 256. Desabamento ou desmoronamento.....	352
8. Art. 257. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento	352
9. Art. 258. Formas qualificadas de crime de perigo comum	353
10. Art. 259. Difusão de doença ou praga	353
 Capítulo 57 — Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública: Dos Crimes Contra a Segurança dos Meios de Comunicação e Transporte e Outros Serviços Públicos.....	 354
1. Art. 260. Perigo de desastre ferroviário	354
2. Art. 261. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo.....	355
3. Art. 262. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte.....	356
4. Art. 263. Forma qualificada.....	356
5. Art. 264. Arremesso de projétil.....	356
6. Art. 265. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.....	357
7. Art. 266. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública	358
 Capítulo 58 — Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública: Dos Crimes Contra a Saúde Pública	 359
1. Art. 267. Epidemia	359
2. Art. 268. Infração de medida sanitária preventiva	359
3. Art. 269. Omissão de notificação de doença.....	360

4. Art. 270. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal	361
5. Art. 271. Corrupção ou poluição de água potável	361
6. Art. 272. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios	362
7. Art. 273. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais	363
8. Art. 274. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida.....	365
9. Art. 275. Invólucro ou recipiente com falsa indicação	365
10. Art. 276. Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores	366
11. Art. 277. Substância destinada à falsificação	366
12. Art. 278. Outras substâncias nocivas à saúde pública	367
13. Art. 279. Substância avariada	367
14. Art. 280. Medicamento em desacordo com receita médica.....	367
15. Art. 281. Comércio, posse ou uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica	368
16. Art. 282. Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica	368
17. Art. 283. CHARLATANISMO.....	369
18. Art. 284. Curandeirismo	370
19. Art. 285. Forma qualificada	370
Capítulo 59 — Dos Crimes Contra a Paz Pública	372
1. Art. 286. Incitação ao crime	372
2. Art. 287. Apologia de crime ou criminoso.....	373
3. Art. 288. Associação criminosa	373
4. Art. 288-A. Constituição de milícia privada.....	375
Capítulo 60 — Dos Crimes Contra a Fé Pública.....	377

1. Art. 289. Moeda falsa	377
2. Art. 290. Crimes assimilados ao de moeda falsa	378
3. Art. 291. Petrechos para falsificação de moeda	379
4. Art. 292. Emissão de título ao portador sem permissão legal	379
5. Art. 293. Falsificação de papéis públicos	379
6. Art. 294. Petrechos de falsificação	381
7. Art. 295. Forma majorada.....	382
Capítulo 61 — Dos crimes contra a fé pública: Da Falsidade Documental.....	383
1. Art. 296. Falsificação do selo ou sinal público.....	383
2. Art. 297. Falsificação de documento público	383
3. Art. 298. Falsificação de documento particular.....	384
4. Art. 299. Falsidade ideológica	385
5. Art. 300. Falso reconhecimento de firma ou letra.....	386
6. Art. 301. Certidão ou atestado ideologicamente falso	386
7. Art. 302. Falsidade de atestado médico	387
8. Art. 303. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica	388
9. Art. 304. Uso de documento falso.....	388
10. Art. 305. Supressão de documento	390
Capítulo 62 — Dos Crimes Contra a Fé Pública: De Outras Falsidades	391
1. Art. 306. Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins.....	391
2. Falsa Identidade.....	391
2.1. Art. 307.	391
2.2. Art. 308.	392
3. Fraude de lei sobre estrangeiro	392

3.1. Art. 309.....	392
3.2. Art. 310.....	393
4. Art. 311. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.....	393
5. Art. 311-A. Fraudes em certames de interesse público	394
Capítulo 63 — Dos Crimes Contra a Administração Pública	396
Capítulo 64 — Dos Crimes Contra a Administração Pública: Dos Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração em Geral	398
1. Art. 312. Peculato	398
1.2. Modalidades de peculato	398
Questões	399
Gabarito	399
2. Art. 313. Peculato mediante erro de outrem	400
3. Art. 313-A. Inserção de dados falsos em sistema de informações.....	400
4. Art. 313-B. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações.....	400
5. Art. 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento	401
6. Art. 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas	401
7. Art. 316. Concussão.....	402
8. Art. 316, § 1º. Excesso de exação	403
9. Art. 317. Corrupção passiva	403
9.1. Classificação da corrupção passiva.....	404
10. Art. 318. Facilitação de contrabando ou descaminho.....	405
11. Art. 319. Prevaricação	405
12. Art. 319-A. Prevaricação imprópria ou nos presídios	406
13. Art. 320. Condescendência criminosas.....	406
14. Art. 321. Advocacia administrativa	406

15. Art. 322. Violência arbitrária.....	407
16. Art. 323. Abandono de função	407
17. Art. 324. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado	408
18. Art. 325. Violação de sigilo funcional	408
19. Art. 326. Violação do sigilo de proposta de concorrência	409
20. Art. 327. Funcionário público.....	409
Questões	409
 Capítulo 65 — Dos Crimes Contra a Administração Pública: Dos Crimes Praticados por Particular contra a Administração em geral	
1. Art. 328. Usurpação de função pública.....	410
2. Art. 329. Resistência.....	410
3. Art. 330. Desobediência	411
4. Art. 331. Desacato.....	411
5. Art. 332. Tráfico de influência.....	412
6. Art. 333. Corrupção ativa.....	412
7. Art. 334. Descaminho	413
8. Art. 334-A. Contrabando	415
9. Art. 335. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência.....	416
10. Art. 336. Inutilização de edital ou de sinal	416
11. Art. 337. Subtração ou inutilização de livro ou documento	417
12. Art. 337-A. Sonegação de contribuição previdenciária	417
 Capítulo 66 — Dos Crimes Contra a Administração Pública: Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Pública Estrangeira	
1. Art. 337-B. Corrupção ativa em transação comercial internacional	419
2. Art. 337-C. Tráfico de influência em transação comercial internacional.....	419

Capítulo 67 — Dos Crimes Contra a Administração Pública: Dos Crimes Contra a Administração da Justiça.....	421
1. Art. 338. Reingresso de estrangeiro expulso.....	421
2. Art. 339. Denúnciação caluniosa	421
3. Art. 340. Comunicação falsa de crime ou de contravenção	422
4. Art. 341. Autoacusação falsa	423
5. Art. 342. Falso testemunho ou falsa perícia.....	423
6. Art. 343. Corrupção ativa de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete	424
7. Art. 344. Coação no curso do processo.....	425
8. Art. 345. Exercício arbitrário das próprias razões.....	425
9. Art. 346. Subtração, supressão ou danificação de coisa própria no legítimo poder de terceiro....	426
10. Art. 347. Fraude processual	426
11. Art. 348. Favorecimento pessoal.....	427
12. Art. 349. Favorecimento real	427
12.1. Art. 349-A.....	428
13. Art. 350. Exercício arbitrário ou abuso de poder.....	428
14. Art. 351. Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança.....	428
15. Art. 352. Evasão mediante violência contra a pessoa.....	429
16. Art. 353. Arrebatamento de preso	429
17. Art. 354. Motim de presos	429
18. Art. 355. Patrocínio infiel.....	429
19. Art. 356. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório	430
20. Art. 357. Exploração de prestígio	430
21. Art. 358. Violência ou fraude em arrematação judicial	430
22. Art. 359. Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito.....	431

Questões	431
Capítulo 68 — Dos Crimes Contra a Administração Pública: Dos Crimes Contra as Finanças Públicas .	432
1. Art. 359-A. Contratação de operação de crédito.....	432
2. Art. 359-B. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar	432
3. Art. 359-C. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura.....	432
4. Art. 359-D. Ordenação de despesa não autorizada	433
5. Art. 359-E. Prestação de garantia graciosa	433
6. Art. 359-F. Não cancelamento de restos a pagar.....	434
7. Art. 359-G. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura ..	434
8. Art. 359-H. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado.....	434
Referências Bibliográficas	435

INTRODUÇÃO À OBRA

A presente obra busca tratar da parte geral do Direito Penal de forma suficiente para o enfrentamento de todas as fases de concursos de carreiras jurídicas, como os concursos para ingresso na magistratura, no ministério pública, na defensoria pública e no cargo de delegado de polícia.

O livro nasceu das aulas do professor Samer Agi, cujo esqueleto é extraído da obra Manual de Direito Penal – parte geral – de Rogério Sanches Cunha (bibliografia indicada aos alunos dos cursos regulares), somada aos ensinamentos dos professores Nélon Hungria, Aníbal Bruno, Heleno Cláudio Fragoso e Aloysio de Carvalho Filho, em suas obras “Comentários ao Código Penal”.

Por diversas vezes, faremos referência à obra do professor Rogério Sanches, cuja didática inspirou-nos na elaboração da sequência deste e-book.

CAPÍTULO 1 — LIÇÕES PRELIMINARES DE DIREITO PENAL

O direito é um elemento cultural, que revela os valores reinantes em uma sociedade em um determinado espaço de tempo. Em verdade, o direito permite, e até mesmo estimula, a realização em concreto de tais valores. Portanto, antes mesmo de se positivar o comportamento desejável e o indesejável (criminoso), a sociedade já tem como antijurídica determinada conduta. O direito reproduz o anseio social e, em seguida, o supera.

O processo de endoculturação começa com as crianças. As manifestações do homem não são fruto de sua isolada consciência e experiência. Pensar é, também, expressão do condicionamento histórico-social do homem.

Qual é o conceito de direito penal? A resposta não é única e, como adverte Rogério Sanches Cunha, dependerá do aspecto em destaque, do enfoque do estudioso.

Sob o **aspecto formal (estático)**, o direito penal consiste em um conjunto de normas jurídicas que qualificam comportamentos humanos comissivos ou omissivos como delitos, preveem situações excludentes da ilicitude de tais comportamentos, ou excludentes da culpabilidade de seu autor, cominam sanções e tratam dos mais diversos temas ligados ao fenômeno delitivo.

Sob o **aspecto material**, o direito penal cuida de comportamentos considerados reprováveis, porque são violadores de bens jurídicos que o ordenamento jurídico, na esfera penal, decidiu tutelar, ou seja, violadores de bens indispensáveis à conservação e ao progresso do organismo social. Aqui, vale destacar que o direito penal não tutela todos os bens jurídicos, mas tão somente os reputados mais importantes à sociedade. Ainda vale ressaltar que mesmo os bens jurídicos tutelados pelo direito penal não merecem sua proteção em qualquer situação antijurídica. Explico. O direito penal tutela, por exemplo, o patrimônio. Entre os diversos bens jurídicos passíveis de tutela, o direito criminal escolheu esse (caráter fragmentário do direito penal). Porém, não são todas as violações ao patrimônio que merecem a guarida desse ramo do direito. Quando há uma colisão entre veículos, se um dos condutores foi imprudente, houve a violação do patrimônio do inocente e há um responsável por isso. Mas a responsabilização, aqui, se dá apenas na esfera cível. O direito penal não é chamado a intervir, porque outro ramo do direito mostra-se suficiente. Tem-se, assim, aplicação do princípio da intervenção mínima do direito penal (direito penal como *ultima ratio*): o direito penal só deve intervir quando os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes.

Sob o **aspecto sociológico (ou dinâmico)**, o direito penal é instrumento de controle social, buscando assegurar a necessária disciplina para que a convivência dos membros da sociedade seja harmônica.

1. CRIMINOLOGIA E POLÍTICA CRIMINAL

Na ciência penal, podemos estudar criminologia e política criminal. É importante diferenciá-las do Direito Penal.

A ciência penal estuda a delinquência como um fato social. Em toda sociedade, há crime. Portanto, a partir desta constatação desenvolvem-se dois campos de estudo interligados:

- **Criminologia:** ciência que estuda o crime, o criminoso, a vítima, e o controle social. As escolas da criminologia dedicam-se ao estudo do crime, ora como fato natural (história natural do delito), ora como entidade jurídica abstrata (escola clássica), ora como prática decorrente de anomalia individual ou produto do ambiente. Ainda, a evolução da criminologia passa pela crítica ao sistema penal como (re)produtor de criminosos e mecanismo de rotulação e dominação social. As constatações da criminologia, em grande medida fruto de trabalho empírico, devem subsidiar o desenvolvimento da política criminal. Destacam-se as escolas clássica, positiva e crítica. O estudo da criminologia não é objeto de nossa presente obra. Mas, apenas para se ter ideia da complexidade de seu estudo, destacamos pensamentos da escola positiva. Para os positivistas a função do direito é descobrir, através da análise dos fatos



empiricamente verificáveis, as leis que regem as condutas humanas. Se para Lombroso, as características morfológicas de um ser humano seriam suficientes para defini-lo como criminoso, não se pode afirmar o mesmo para a definição de delito, variável de época para época. Garofalo defenderá a necessidade de se desenvolver um conceito atemporal de delito, aplicável a qualquer sociedade e momento da história. Para Garofalo há uma antijuridicidade natural ou universal e outra local, social. A primeira ofende os sentimentos de piedade, o que faz com que o ato seja considerado delituoso em qualquer momento da história. A segunda ofende sentimentos de justiça, probidade e antijuridicidade vulgar, que estão sujeitos a variações de educação, ambiente e moral. O delito, portanto, é um conceito natural, e não jurídico. Cabe ao naturalista dizer o que é delito. Ferri defende o caráter sociológico do crime. Assim como o corpo reage a uma infração (comer muito causa indigestão), o corpo social reage a um ato ofensivo. A pena, portanto, não tem caráter retributivo, mas é um meio de defesa social, fundado na periculosidade apresentada pelo agente, um meio de prevenção especial. Os positivistas entendem que o crime é causado por fatores psíquicos, físicos e sociais. Portanto, há um determinismo biológico e/ou social na construção do delinquente e na formação de sua periculosidade, constatada na prática da infração penal. A reação penal é uma forma de defesa social.

- **Política criminal:** é o vetor que orienta a produção do direito penal (norma). O que queremos criminalizar, que condutas desejamos evitar, para que queremos punir e quando, então, devemos deixar de punir? A política criminal possui uma finalidade, trabalhando com estratégias e mecanismos de controle social da criminalidade. A criminologia deve orientar a elaboração da política criminal, que, por sua vez, deve orientar o legislador na elaboração das leis penais. Possui a característica de vanguarda, porque a mudança da política criminal, por exemplo, conduz à reforma das leis.

2. FUNÇÃO DO DIREITO PENAL

O estudo do funcionalismo penal exige resposta à seguinte pergunta: qual é a função do direito penal? Qual é a finalidade do direito penal?

O movimento do **funcionalismo penal** busca descobrir a real função do direito penal. Nesse campo, existem duas correntes que se destacam:

- Funcionalismo teleológico (moderado);
- Funcionalismo sistêmico (radical).

O funcionalismo teleológico (moderado) tem como expoente **Claus Roxin**, o qual preceitua que a finalidade do direito penal é **proteger bens jurídicos**, de modo que, não havendo bem jurídico a ser protegido, não há que se falar em intervenção do direito penal. É chamado de funcionalismo teleológico porque busca encontrar a finalidade do direito penal e, também, reconstruir o ordenamento jurídico penal a partir dessa finalidade.

O funcionalismo sistêmico, por sua vez, é de criação de **Günther Jakobs**. Jakobs dirá que a função do direito penal é assegurar a vigência do sistema, garantindo o império da norma. Para ele, não é possível afirmar que o direito penal tem por finalidade proteger bens jurídicos, porque, quando sua intervenção só se dá quando o bem jurídico já foi violado ou ameaçado de violação por meio de ato executório (crimes consumados ou tentados). Em verdade, o autor de um crime é punido para que se demonstre que o sistema continua em vigor, que a norma deve ser obedecida. É um funcionalismo sistêmico, pois o direito penal existe em razão do sistema e para assegurar sua higidez. É um funcionalismo radical, porque, a cada descumprimento, tem-se uma punição. A função do direito penal é, portanto, assegurar o respeito à norma. Se, ao cometer um crime, o autor nega a existência da norma (negação), sua punição significa negação do comportamento antijurídico. Portanto, a pena é a negação da negação (Hegel).

Para Günther Jakobs, o indivíduo que, reiterada e deliberadamente, se comporta como um violador da lei penal, não deve ser tratado como um cidadão, devendo, sim, ser visto como um **inimigo da**



sociedade, e tratado como um inimigo. O **Direito Penal do Inimigo**, a ser estudado mais a frente, nasce da ideia de que o direito penal deve tratar de maneira diferenciada aqueles que se mostram infiéis ao sistema. Assim, é preciso que haja uma repressão mais forte àqueles que perderam o status de cidadão, porque decidiram, reiteradamente, desobedecer à norma e ao sistema imposto (rompimento do contrato social – base rousseauiana).

3. CLASSIFICAÇÕES DO DIREITO PENAL

São várias as classificações do direito penal.

3.1. DIREITO PENAL SUBSTANTIVO E DIREITO PENAL ADJETIVO

- **Direito penal substantivo:** é o direito penal material, propriamente dito, que consta, classicamente, no Código Penal. Define o crime e anuncia a pena. Mas também há direito penal substantivo em legislações especiais, como na Lei de Drogas (11.343/06) e na Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19). Observação: é comum encontrarmos, nas legislações extravagantes, normas de direito penal substantivo e de direito penal adjetivo (processo penal). É o que ocorre nos dois exemplos citados;
- **Direito penal adjetivo:** é o direito processual penal, previsto, em regra, no Código de Processo Penal. Cuida do processo e do procedimento.

Essa classificação perdeu a importância, em virtude de o direito processual ter passado a ser considerado ramo autônomo do Direito, e não mais um braço do direito penal.

3.2. DIREITO PENAL OBJETIVO E DIREITO PENAL SUBJETIVO

- **Direito penal objetivo:** é o conjunto de leis penais em vigor no país. Constitui-se das normas penais incriminadoras e não incriminadoras;
- **Direito penal subjetivo:** é o direito de punir, pertencente ao Estado (*ius puniendi*). O direito punitivo estatal não é ilimitado. As limitações ao *ius puniendi* encontram-se explicitadas no texto constitucional e reproduzidas na legislação infraconstitucional (princípio da legalidade). O direito penal deve respeitar direitos e garantias fundamentais, não atingindo o núcleo duro de tais direitos, sob pena de violação à própria dignidade humana. Vale destacar que a privação da liberdade (pena clássica) deve se dar nos limites legais e em estabelecimentos prisionais que cumpram as exigências estabelecidas pela Lei de Execução Penal (Lei 7.2010/84). Quanto ao espaço, o direito penal objetivo será aplicado apenas aos fatos praticados no território nacional, via de regra (princípio da territorialidade). No que toca ao tempo, o Estado só poderá exercer o seu direito de punir por certo prazo. Após o esgotamento do prazo legal para dar fim à perseguição penal, perderá o Estado esse direito (prescrição, que é causa extintiva da punibilidade).

3.3. DIREITO PENAL DE EMERGÊNCIA E DIREITO PENAL SIMBÓLICO

- **Direito penal de emergência:** é o direito penal criado a partir de uma situação atípica. O legislador cria normas de repressão porque há uma anormalidade social que exige uma resposta legal extraordinária. Certamente, a opinião pública e determinados setores da sociedade exercem, em tais circunstâncias, pressão para produção de normas excepcionais. Busca-se, com a produção legislativa, devolver ao seio da sociedade uma sensação de tranquilidade. A criação de norma que recrudesce o tratamento já existente é legislação de



emergência. Todavia, vale ressaltar, que o direito penal de emergência é campo fértil para um direito penal meramente simbólico.

- **Direito penal simbólico:** é o direito penal que vai ao encontro aos anseios populares, pois o legislador atua pensando na opinião pública para devolver à sociedade uma **ilusória** sensação de tranquilidade. Não se tem, em verdade, a norma cumprindo sua função (prevenção de crimes exercida pela lei - função inibitória), razão pela qual o direito penal será apenas simbólico. Se a criação da lei penal não afeta a realidade, o Direito Penal acaba cumprindo apenas uma função simbólica, nasce sem qualquer eficácia social.

3.4. DIREITO PENAL PROMOCIONAL/POLÍTICO/DEMAGOGO

O direito penal promocional é uma distorção do direito penal. É um **direito penal político**, eis que visa a promoção do próprio Estado. Acaba sendo um **direito penal demagogo**, tendo em vista que engana e cria a ideia de que o direito penal pode promover a alteração da sociedade.

Utiliza o Direito penal como instrumento de transformação social. Na verdade, as políticas públicas tem que ser instrumento para transformação social. O Estado, visando a consecução dos seus objetivos políticos, emprega leis penais desconsiderando o princípio da intervenção mínima. Tem por finalidade usar o direito penal para a transformação social. Exemplo: criando contravenção penal de mendicância (revogada) para acabar com os mendigos ao invés de melhorar políticas públicas.

Até 2009, a mendicância era uma contravenção penal. E não era a “criminalização” do fato de o indivíduo ser mendigo que faria com que ele deixasse a sua condição. Afora isso, havia uma discussão sobre a configuração de um direito penal do autor, que pune o indivíduo pelo que ele é, não pelo que ele fez.

3.5. DIREITO PENAL DE INTERVENÇÃO

Windfried Hassemer trata sobre o direito de intervenção. O autor traz que o direito penal não deve ser alargado, **devendo se preocupar apenas com os bens jurídicos individuais**, tais como a vida, o patrimônio, a propriedade etc., bem como com infrações penais que causem perigo concreto.

Não somente, se a **infração penal visa proteger bem jurídico difuso, coletivo ou de natureza abstrata**, ela não deveria ser considerada uma infração penal, razão pela qual **deveria ser tutelada pela administração pública, sem risco de privação da liberdade do infrator**. Este seria o direito de intervenção.

O direito de intervenção (ou interventivo) estaria acima do direito administrativo, do ponto de vista de resposta estatal, mas abaixo do direito penal.

A crítica que se faz é que não se sabe como seria a legitimidade e como atuaria o direito de intervenção e como se separaria o direito de intervenção do direito penal e do direito administrativo.

3.6. DIREITO PENAL COMO PROTEÇÃO DE CONTEXTOS DA VIDA EM SOCIEDADE

Trata-se de uma **ideia oposta à de Hassemer**.

Segundo Günter Stratenwerth, na verdade, **a proteção de bens estritamente individuais deve ter um foco secundário no direito penal**. Isso porque, para ele, o **direito penal deve focar nos interesses difusos e da coletividade**, eis que estes são os mais importantes para a sociedade, como, por exemplo, quando há a tipificação de crimes ambientais.

O Direito Penal deve focar nos interesses difusos e da coletividade, havendo aqui a substituição do bem jurídico pela tutela direta de relações ou contextos de vida. E por isso o nome “*direito penal como proteção de contextos da vida em sociedade*”.

Consistiria, como se vê, em um **direito de gestão punitiva dos riscos gerais**. A preocupação é diferente do que Hassemer enfatizou.



3.7. DIREITO PENAL GARANTISTA

O direito penal garantista tem como expoente **Luigi Ferrajoli**.

A Constituição traz garantias fundamentais, as quais se subdividem em duas categorias:

- **Garantias primárias:** a Constituição traz os limites impostos aos exercícios de qualquer poder. Diz: “não será feito”.
- **Garantias secundárias:** se o limite estabelecido pela garantia primária não for observado, haverá de levantar a garantia secundária, a qual é uma forma de reparação subsequente a essa violação da garantia primária. Diz: “se o que era para não ser feito for feito, então pode acionar esse instrumento de proteção”.

Por exemplo, é garantia primária de que não haverá penas de caráter perpétuo. Essa garantia não é observada pelo legislador, o qual cria o crime e comina a pena com pena privativa de liberdade de caráter perpétuo. Neste caso, há uma garantia secundária na própria Constituição, a qual se dará por meio do controle de constitucionalidade, julgando o ato nulo.

Ferrajoli terá como base da sua teoria garantista penal os **10 axiomas ou implicações deônticas**:

- **Nulla poena sine crimine (Não há pena sem crime):** não pode alguém ser penalizado se não cometeu crime. É o princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito.
- **Nullum crimen sine lege (Não há crime sem lei):** não há crime sem que haja lei, refletindo o princípio da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito.
- **Nulla lex (poenalis) sine necessitate (Não há lei penal sem necessidade):** é reflexo do princípio da necessidade ou da economia do direito penal, ambos decorrentes do princípio da intervenção mínima.
- **Nulla necessitas sine injuria (Não há necessidade sem ofensa a bem jurídico):** decorre do princípio da lesividade ou ofensividade do evento. Significa dizer que os tipos penais devem descrever condutas que ofendam bens jurídicos de terceiros.
- **Nulla injuria sine actione (Não há ofensa ao bem jurídico sem ação):** não há materialidade, sendo necessário que seja exteriorizada a ação. É o princípio da materialidade ou da exterioridade da ação.
- **Nulla actio sine culpa (Não há ação sem culpa):** o indivíduo deve ter cometido uma ação, mas com dolo ou culpa. Trata-se de corolário do princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal.
- **Nulla culpa sine judicio (Não há culpa sem processo):** o indivíduo deve ser submetido a um processo, não podendo ser considerado culpado sem processo. É decorrência do princípio da jurisdiicionalidade no sentido lato ou estrito.
- **Nulla judicium sine accustone (Não há processo sem acusação):** para se instaurar um processo, é necessidade que alguém instaure o processo. Trata-se de uma garantia, fruto do princípio acusatório ou da separação ente o juiz e a acusação.
- **Nulla accusatio sine probatione (Não há acusação sem prova):** o ônus da prova é de quem acusa. É aplicação do princípio do ônus da prova ou da verificação.
- **Nulla probatio sine defensione (Não há prova sem defesa):** a prova não existe sem que a defesa tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre ela. Trata-se do princípio da defesa ou da falseabilidade.

Percebe-se, então, que os axiomas de Ferrajoli estão todos ligados: não há pena sem crime e não há crime sem lei; não há lei sem necessidade e não há necessidade se não houver ofensa, de modo que não há ofensa se não houver ação. Ação é a exteriorização, eu não puno o pensamento, preciso que haja uma ação. E não há ação sem culpa, a responsabilidade penal é subjetiva e não se considerar alguém culpado sem o devido processo legal. O processo legal só existe se houver uma acusação (princípio acusatório) e ninguém pode acusar sem provas, de modo que não há que se falar em provas se a defesa não pode se manifestar a respeito daquilo.



Por isso que na fase pré-processual se fala em elementos informativos que vão se confirmar ou não em sede processual.

3.8. DIREITO PENAL SECULARIZADO

A ideia do Direito Penal secularizado é separar o direito penal da Igreja.

O **direito penal secularizado**, de acordo com Luigi Ferrajoli, é a ideia de que inexistente uma conexão entre o direito e a moral. O direito penal não tem a missão de reproduzir os elementos da moral ou de outro sistema metajurídico de valores éticos-políticos, como os dogmas religiosos. Essa secularização (laicização) é a **ruptura entre a cultura eclesástica e as doutrinas filosóficas, especialmente entre a moral do clero e a forma de produção da ciência**. Por isso, o Estado não deve se imiscuir coercitivamente na vida moral dos cidadãos, nem tampouco promover coativamente sua moralidade, mas apenas tutelar sua segurança, impedindo que se lesem uns aos outros. Com o princípio da secularização busca-se preservar a pessoa numa esfera em que é ilícito proibir, julgar e punir a esfera do pensamento, das ideias. Ex.: Ordenações Afonsinas, fundada nos dogmas religiosos.

3.9. DIREITO PENAL SUBTERRÂNEO E DIREITO PENAL PARALELO

Na verdade, essa classificação de Zaffaroni se refere aos sistemas penais paralelos e subterrâneos.

- **Direito penal paralelo:** tenho um direito penal que é paralelo ao direito penal oficial. Ao lado da atuação do Estado, por não ser essa atuação suficiente, surgem outros mecanismos de direito penal. É como se no âmbito particular surgisse um direito penal paralelo extraestatal. O sistema penal formal do Estado não exerce grande parte do poder punitivo, de forma que outras agências acabam se apropriando desse espaço e passam a exercer o poder punitivo paralelamente ao Estado. Ex.: médicos aprisionando doentes mentais.
- **Direito penal subterrâneo:** é um direito penal do “andar de baixo”. Dentro da própria estrutura do Estado, mas no “andar de baixo”, é construída uma estrutura de direito penal. Diante da constatação do sistema que está positivado (o sistema que é visto, que está “no térreo, no andar de cima”) não é eficiente, no “andar de baixo”, são organizadas formas de exercer o poder punitivo. Ocorre quando as instituições oficiais atuam com poder punitivo ilegal, acarretando abuso de poder. Os próprios agentes do Estado passam a atuar ilegalmente. Ex.: desaparecimentos de indivíduos pela polícia; extorsões mediante sequestro etc.

3.10. DIREITO PENAL QUÂNTICO

O direito penal quântico consiste no direito penal que **não se contenta com a mera relação de causalidade** (*relação física de causa e efeito*), mas também com elementos indeterminados, como o chamado nexa normativo e a chamada tipicidade material, a serem aferidos pelos operadores do direito diante da análise do caso.

Para se imputar a alguém um resultado, não basta que o sujeito tenha praticado uma conduta que tenha levado àquele resultado e que ele tenha a vontade de praticar aquela conduta. Não basta sequer a causalidade subjetiva ou psíquica, é preciso que antes de observar tudo isso, se observe que critérios objetivos me permitam imputar àquele sujeito a prática daquela conduta, por isso o nome teoria da imputação objetiva. Para que eu impute um crime à alguém é preciso que esse alguém tenha criado ou incrementado um risco juridicamente proibido, que haja a realização desse risco no resultado e que o resultado esteja dentro do alcance do tipo.

Esses três parâmetros são parâmetros objetivos para que eu possa imputar a alguém a prática de um crime. Vai exigir então a própria ideia de um nexa normativo.

O direito penal quântico limita quando exige critérios objetivos para se imputar a alguém a prática de um crime, nem sempre quando tiver uma causalidade física se imputará a alguém um crime. Outro



critério que se admite no direito penal quântico é a tipicidade material, que diz que se não houver a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, o direito penal não deve intervir. Não basta a causalidade física, é preciso que se analise se o bem jurídico tutelado foi efetivamente lesado ou não.

Dessa maneira, pode-se caracterizar o Direito Penal Quântico pela existência de uma imprecisão no direito que se afasta da dogmática penal e se aproxima da política criminal. Com isso, há uma nítida exigência da tipicidade material, **afastando da esfera penal condutas socialmente aceitas e que não tragam uma carga mínima de lesão ao bem jurídico** (sendo que o direito penal quântico se agarra também na teoria da imputação objetiva).

3.11. A ESCOLA DE KIEL – DIREITO PENAL DA ALEMANHA NACIONAL-SOCIALISTA

As concepções de direito, especialmente, de direito penal na Alemanha nacional-socialista reproduzem a ideia de formação de um povo de uma só raça, a germânica, com um só sentimento.

A partir dessa ideia, a lei é parte do direito, mas não limita sua atuação. Atrás de cada tipo penal, há um tipo de autor que o legislador quer punir. Portanto, se alguém adota um comportamento que fere o sentimento social, pode o juiz se vale do tipo penal que se mostre mais próximo de tal comportamento antijurídico para punir o agente. Permite-se, portanto, a aplicação da analogia incriminadora. O papel do juiz passa a ser demasiadamente criativo na função de punir e preceitos como da legalidade cedem ante a busca da construção de uma sociedade completamente harmônica, o que só seria possível com uma única raça, pura.

3.12. O DIREITO PENAL COMUNISTA

Tem-se, aqui, a clara ideia de que o direito não é um instrumento de transformação social, mas de manutenção da realidade em que uma classe exerce domínio sobre outro. O direito penal é despedido de qualquer intenção reformatória.

Quando, então, passamos ao direito penal soviético, em sua ditadura do proletariado, o direito penal passa a servir aos interesses da revolução. Tem-se, então, a possibilidade de emprego de analogia para incriminar condutas que, a despeito de não estarem descritas em tipo penal autônomo, mostram-se contrárias à sociedade socialista, à coletividade. Isso, porque tais condutas evidenciam a periculosidade social do fato e, especialmente, a periculosidade social do autor.

Em 1958, a possibilidade de emprego de analogia incriminadora no direito penal soviético é descartada, mas ainda persiste a importância da periculosidade social como critério para definição do crime. A ausência de periculosidade social da ação (ausência de risco à sociedade soviética e à ditadura do proletariado) exclui a ilicitude da conduta.

4. PRIVATIZAÇÃO DO DIREITO PENAL

A privatização do direito penal é uma expressão que destaca a **crescente participação da vítima**, ou da importância dada à vítima, no âmbito criminal.

A ideia é fazer com que a vítima retorne à situação que ostentava antes da prática do crime. Daí a ideia da justiça restaurativa e da pena cumprindo uma terceira função, chamada terceira via da pena: a pena não é mais para retribuir apenas o mal causado, nem para prevenir a nova prática de infrações pelo apenado ou pela sociedade, que ao ver o sujeito sendo penalizado desiste de praticar crimes, mas também serve para restaurar a situação que a vítima tinha antes do crime.

Trata-se do destaque dado às vítimas nos últimos anos, como ocorre com a Lei dos Juizados Especiais Criminais, quando é possível a composição civil, ou que seja declarada extinta a punibilidade em razão do cumprimento da transação penal ou da suspensão condicional do processo (sursis processual), ou até mesmo o sursis penal (suspensão condicional da pena).



Para todos estes institutos, haverá a extinção da punibilidade, desde que tenha havido a reparação dos danos à vítima. Há, como se vê, uma maximização da importância dada à vítima.

Outro exemplo é a Lei 11.719/08, que consagrou a hipótese em que o juiz criminal deve se manifestar, no momento da sentença condenatória, a fim de fixar o mínimo indenizatório à vítima.

Por conta de tudo isso, há um campo fértil para a **teoria da justiça restaurativa**.

Essa justiça restaurativa cria a chamada **terceira via da função da pena**, pois a função da pena, tradicionalmente, seria a retribuição ao mal causado (*ao mal do crime, o mal da pena*) e a prevenção, que é fazer com que o indivíduo não volte a praticar crimes (prevenção especial) e fazer com que outros indivíduos, vendo aquele ser punido, optem por não cometer crimes (prevenção geral). Estas seriam as duas vias da função da pena: retribuição e prevenção.

Todavia, a partir do momento em que se busca a reparação da vítima por meio de indenização no âmbito criminal, bem como institutos despenalizadores diretamente ligados à vítima, passa-se a ter uma terceira função da pena, denominada de **terceira via**, exteriorizada pela **reparação do dano causado**.

5. VELOCIDADES DO DIREITO PENAL

Jesús-María Silva Sánchez cria as chamadas velocidades do direito penal:

- **Direito penal de 1ª velocidade:** enfatiza infrações penais mais graves, as quais podem ser punidas com penas privativas de liberdade. Porém, para ser fixadas, é preciso que se observem todas as garantias do indivíduo que está sendo acusado. Todos os direitos e garantias fundamentais estão sendo observados, mas, ao final, pode ser que o sujeito seja condenado a uma pena privativa de liberdade. Ex.: crime de homicídio.
- **Direito penal de 2ª velocidade:** temos um direito penal mais célere, porque há uma flexibilização de direitos e garantias fundamentais, pois se quer ter maior celeridade na punição. Esta velocidade se destina a infrações penais menos graves, eis que se aplicam penas não privativas de liberdade, como as penas alternativas. Ex.: Leis dos Juizados Especiais.
- **Direito penal de 3ª velocidade:** há uma flexibilização de direitos e garantias fundamentais, porém há infrações penais mais graves, podendo, inclusive, cominar pena privativa de liberdade. É uma mistura da 1ª velocidade com a 2ª velocidade. Há um recrudescimento do tratamento do indivíduo em prejuízo de garantias processuais. Ex.: Lei dos Crimes Hediondos. É aqui que se encontra o Direito Penal do Inimigo.

Observação: Fala-se, atualmente, em uma quarta velocidade do Direito Penal, não tratada por Silva Sanchez. A 4ª velocidade do Direito Penal está ligada ao Direito Internacional, sendo aplicável, especialmente, a Chefes de Estado que, como tais, violaram tratados internacionais de direitos humanos. Eles serão julgados conforme normas de Direito Internacional, sendo, em regra, o Tribunal Penal Internacional competente para processar e julgar o feito. Dada a reprovabilidade do comportamento de tais líderes, defende-se uma diminuição de garantias individuais penais e processuais penais em seu desfavor.

6. ESPIRITUALIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO OU DESMATERIALIZAÇÃO DO BEM JURÍDICO

A tipificação de crimes sempre esteve relacionada à proteção de bens jurídicos inerentes ao indivíduo, sejam estes bens lesados (crimes de dano) ou expostos a efetivo perigo (crimes de perigo concreto). Havia, portanto, uma materialização dos bens jurídicos.

A medida que tem crescido essa criminalização de condutas ofensivas a bens de caráter difuso e coletivo, passa a ter dificuldade de individualizar qual bem foi violado com aquela conduta criminosa. Assim, há uma liquefação, desmaterialização do direito penal.

Neste cerne, a espiritualização do bem jurídico foi uma expressão criada pela doutrina para criticar a **tipificação de condutas que visam tutelar bens jurídicos de interesse transindividual, com o fim de combater condutas difusas e perigosas, que, se não evitadas, acabariam resultando em danos às pessoas**.



Exemplificando esta nova tendência, punem-se crimes ambientais porque a proteção do meio ambiente traz benefícios às pessoas em geral, e um meio ambiente desequilibrado é prejudicial à vida e à saúde dos seres humanos, ainda que reflexamente.

Parcela da doutrina critica a inadequada expansão da tutela penal na proteção de bens jurídicos de caráter difuso ou coletivo. Argumenta-se que tais bens são formulados de modo vago e impreciso, ensejando a denominada desmaterialização, espiritualização, ou liquefação do bem jurídico.

7. GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR

Garantismo é a visão do direito constitucional aplicada no direito penal e direito processual penal. Trata-se de expressão cunhada pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli.

Para muitos, **o garantismo serviria apenas para beneficiar o réu, forma de proteção de seus direitos fundamentais e individuais**. Desse modo, surge o chamado garantismo hiperbólico monocular.

É hiperbólico porque é aplicado de uma forma ampliada, desproporcional e **é monocular porque só enxerga os direitos fundamentais do réu** (só um lado do processo). Esse garantismo hiperbólico monocular contrapõe-se ao garantismo penal integral, que visa resguardar os direitos fundamentais não só dos réus, mas também das vítimas.

Um exemplo seria a lei de Lavagem de Capitais, com alteração dada pela lei 12.683/12. O rol de crimes antecedentes que outrora era taxativo foi revogado. Permitiu-se, dessa forma, a aplicação da lei supra acerca de qualquer infração penal (crime ou contravenção) antecedente. Nesse sentido, caso fosse aplicado o garantismo hiperbólico monocular (tese adotada pelas defensorias públicas), o crime ou contravenção antecedente que não constasse do rol taxativo da antiga lei 9.613/98 (lei de lavagem de capitais), não poderia ser, agora, utilizado para punição pela lei de lavagem.

8. ECOCÍDIO

O Tribunal Penal Internacional decidiu, no final de 2016, reconhecer o ecocídio como **crime contra a humanidade**.

O termo designa a **destruição em larga escala do meio ambiente**. O novo delito, de âmbito mundial, vem ganhando adeptos na seara do Direito Penal Internacional e entre advogados e especialistas interessados em criminalizar as agressões contra o meio ambiente.

Com o novo dispositivo, **em caso de ecocídio comprovado, as vítimas terão a possibilidade de entrar com um recurso internacional para obrigar os autores do crime, sejam empresas ou chefes de Estado e autoridades, a pagar por danos morais ou econômicos**.

A responsabilidade direta e penas de prisão podem ser emitidas, no caso de países signatários do TPI, mas a sentença que caracteriza o ecocídio deve ser votada por, no mínimo, um terço dos seus membros.

O Brasil é signatário do Tratado de Roma, que aceita a jurisdição do TPI.



CAPÍTULO 2 — EVOLUÇÃO HISTÓRICA

1. PERÍODO DA VINGANÇA

Em relação à evolução histórica do direito penal, devemos passar pelas seguintes fases:

- **Fase da vingança divina:** é a ideia de que haveria uma punição perpetrada por entidades divinas. Quando o indivíduo cometesse uma infração, ele era penalizado pela tribo para que a divindade não punisse todos os membros daquela comunidade.
- **Fase da vingança privada:** um sujeito defende seu direito em face do outro. É a chamada *homo homini lupus*, ou seja, o homem é o lobo do próprio homem. Posteriormente, há evolução dessa fase com a Lei de Talião, que seria olho por olho, dente por dente, surgindo daí a proporcionalidade.
- **Fase da vingança pública:** o direito de punir passa a ser do Estado.

2. PERÍODO ILUMINISTA

A partir do século XVIII, em que se vive no mundo o chamado Iluminismo. Neste movimento, busca-se a racionalidade e o desenvolvimento humano, e, a partir do iluminismo, buscou-se a finalidade da norma que tem caráter sancionador.

O que se procura é prevenção? Ou ressocialização? Ou retribuição? Durante o iluminismo é que se buscou o caráter das normas de caráter sancionador, de modo que o direito penal até então aplicado seria contraproducente.

A partir disso, surgiu a obra que marcou a história do direito penal, escrita por **Cesare Beccaria** (Marquês de Beccaria), conhecida como “**Dos Delitos e das Penas**”.

A conclusão de Beccaria foi a seguinte: “**Para que cada pena não seja uma violência, de um ou de muitos, contra um cidadão, esta pena deve ser essencialmente pública, rápida, necessária e a mínima possível nas circunstâncias dadas, observada a proporcionalidade aos delitos, e ditadas tais penas pelas leis**”. Ou seja, quem pune deve ser o Estado. Deverá ser rápida para que se tenha a resposta ao ilícito. Necessidade é a proporcionalidade. A ideia de *ultima ratio* deve ser vista como a mínima pena nas circunstâncias dadas. Como se vê, até mesmo a legalidade Beccaria se referia.

3. PERÍODO DAS ESCOLAS PENAIIS

Após o período iluminista, surgem as escolas penais, duas delas ganhando destaque.

- **Escola clássica**
- **Escola positiva**

A Escola Clássica, destacada por **Francesco Carrara**, dizia que:

- **crime era um ente jurídico**, eis que consiste na violação de um direito (razão por que atinge a esfera jurídica). Talvez essa seja a grande crítica a Escola Clássica, pois ela não se preocupa em entender a origem do crime. Para a Escola Clássica, crime é uma entidade jurídica, é a violação do direito (porque o direito previu que aquela conduta era proibida) e, portanto, quem descumpra a norma, descumpra porque quer, age com livre arbítrio e por isso se pune o delinquente.
- **delinquente** é um ser livre, que pratica um delito por vontade própria, alheia à moral.
- **função da pena** é prevenir a prática de novos crimes e a necessidade ética.

A Escola Clássica tem como base os ensinamentos de Beccaria, pois há uma relação com o absolutismo, tendo a ideia de que se o indivíduo praticou o crime deve ser penalizado, pois o sujeito é livre para suas escolhas.



No entanto, para Enrico Ferri, os ensinamentos da Escola Clássica não resolveram e nem poderiam resolvê-los, pois não se preocupam em resolver a origem do crime e, quando não se quer entender de onde surgiu a doença, não se pode dizer qual o remédio adequado. Daí surge a ideia da Escola Positiva, que é uma escola empírica e que vai trabalhar com estatísticas.

A Escola Positiva tem como expoente **Cesare Lombroso**.

- **crime** decorre de fatores naturais e sociais. Existe a figura de um criminoso nato e existe a figura de um sujeito que nasceu em um ambiente criminógeno, que faz com que as pessoas se tornem criminosas.
- **delinquente** não é dotado de livre arbítrio, pois, do ponto de vista biológico ou psíquico, seria portador de uma anormalidade. Existiria um criminoso nato, nascido com essas características;
- **finalidade da pena** é prevenir crimes, mas deverá ser indeterminada, a ser fixada a partir do caso concreto, tendo em vista que estamos diante de um criminoso nato. A pena deve ter um caráter terapêutico (tratar o criminoso).

Escola positiva possui caráter determinista, pois traz a ideia do criminoso nato, cunhada por Lombroso.

4. DIREITO PENAL BRASILEIRO

Quando o Brasil foi colônia, vigoravam as Ordenações Afonsinas, sendo as mesmas normas que vigiam em Portugal. Estas normas tinham caráter religioso.

Em 1514, estas Ordenações Afonsinas foram revogadas pelas Ordenações Manuelinas, as quais, posteriormente, foram substituídas por uma compilação feita por Nunes Leão, criando o **Código Sebastião**.

Esta compilação, mais tarde, dá lugar às **Ordenações Filipinas**. Nessas ordenações, continuam as ideias de direito confundido com religião e moral. Por isso, havia uma preocupação do ordenamento jurídico em punir benzedores, feiticeiros, hereges e bruxas, aplicando-se penas com caráter cruel e desumanas, de forma que fosse infundido temor nas pessoas da sociedade.

No entanto, o Brasil se torna independente em 1822, vindo, logo em seguida, a Constituição de 1824, seguida do **Código Criminal do Império**. Tratava-se de um código penal **humanitário**, trazendo, inclusive, o princípio da individualização da pena. Para se ter ideia, considerando seu contexto social, a **pena de morte ficou limitada aos crimes cometidos por escravos**.

Em 1890, posteriormente ao início da República, sanciona-se o **Código Criminal da República**. A **Constituição de 1891 vedou a pena de morte e a pena de prisão de caráter perpétuo**. O Código Republicano **permitia as penas de prisão, banimento e suspensão de direitos**, mas o banimento seria de **natureza temporária**, pois era vedado pela Constituição de 1891 que a pena tivesse caráter perpétuo.

Em 1932, vem uma **Consolidação das Leis Penais**, realizada pelo Desembargador Vicente Piragibe, recebendo o nome de **Consolidação de Piragibe**.

Em 1942, **entra em vigor o Código Penal atual**, sendo sua parte geral reformulada pela Lei 7.209/84.



CAPÍTULO 3 — FONTES DO DIREITO PENAL

As fontes do direito penal podem ser divididas em:

- **Fonte material**
- **Fonte formal**

1. DOUTRINA CLÁSSICA

Segundo a doutrina tradicional, **fonte material** é o órgão criador do direito penal. No Brasil, quem cria o direito penal é a **União**, que tem **competência privativa**, conforme art. 22, I, CF.

A Constituição permite que os Estados legislem sobre direito penal, nos casos específicos, desde que haja uma autorização dada por lei complementar, conforme o § único do art. 22, CF.

Ainda, segundo esta corrente tradicional, a fonte formal do direito penal traz os instrumentos pelos quais se exterioriza o direito penal. A **fonte formal imediata** do direito é a **lei**. Como fonte formal mediata, haveria os **princípios gerais do direito** e os **costumes**.

2. DOUTRINA MODERNA

Todavia, Rogério Sanches traz a fonte formal do direito penal à luz da **doutrina moderna**:

- **Fontes formais imediatas:** lei, CF, tratados e convenções internacionais de direitos humanos, jurisprudência, princípios e a norma penal em branco.
- **Fonte formal mediata:** é apenas a doutrina.
- **Fonte informal:** costumes.

A **lei** é única fonte imediata capaz de criar infrações penais e cominar sanções. Única fonte incriminadora.

A **Constituição Federal** é fonte formal imediata, mas não pode criar infrações penais ou cominar sanções, em razão de seu processo rígido e moroso de alteração, incompatível com o dinamismo que deve envolver processo legislativo no direito penal. Muito embora a CF não possa criar crime e nem cominar pena, ela pode orientar o legislador na sua função (de criar crime e cominar pena), são os chamados mandados constitucionais de criminalização. Ex.: art. 5 XLII, CF – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (patamares mínimos). É a lei, no entanto, quem cria o crime de racismo e comina a sua pena. A CF como fonte formal imediata fica evidente quando, por exemplo, traz a imprescritibilidade e a inafiançabilidade do racismo, constituindo-se num mandato constitucional de criminalização.

Os **tratados e convenções internacionais de direitos humanos** também são fontes formais imediatas, ainda que não possam criar crimes e cominar penas. Isto é percebido na própria decisão do STF, quando reputou inadmissível a utilização do conceito de organização criminosa trazido pela Convenção de Palermo.

As normas dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos podem ingressar no nosso ordenamento jurídico por duas formas: o TIDH que foi ratificado com quórum de emenda constitucional tem status de norma constitucional. Já o TIDH que foi ratificado com quórum comum está abaixo da CF, mas acima da lei ordinária, tem status supralegal.

Atenção: respeitável corrente doutrinária se posiciona no sentido de que os tratados, versando sobre direitos humanos (e somente eles), uma vez subscritos pelo Brasil, se incorporam automaticamente e possuem (sempre) caráter constitucional, a teor do dispositivo 1º e 2º, art. 5º, da CF.

No entanto, as normas dos tratados e convenções internacionais jamais poderão criar crime ou cominar pena para o direito interno. Só pode criar crime ou cominar pena para o direito internacional. Assim, antes do advento das Leis 12.696/12 e 12.850/13 (que definiram, sucessivamente, organização criminosa), o STF manifestou-se pela inadmissibilidade da utilização do conceito de organização criminosa



dado pela Convenção de Palermo, trancando a ação penal que deu origem à impetração, em face da atipicidade da conduta (HC nº 96007).

A **jurisprudência** é fonte formal imediata, pois trata de normas de direito penal. Isto está ainda mais evidente com as denominadas **súmulas vinculantes**. Basta ler a súmula vinculante 24 que diz ser o crime contra ordem tributária atípico antes que ocorra o lançamento definitivo do tributo.

Os **princípios**, para a doutrina clássica, aparecem como fonte formal mediata. Para a doutrina moderna, devem ser rotulados como fonte formal imediata não incriminadora. Não raras vezes réus são absolvidos ou condenados baseados em princípios. Assim, os princípios também são, hoje, fontes formais imediatas, tendo em vista a grande relevância que tem se dado a eles. Os princípios possuem densidade normativa, ou seja, são normas. Por exemplo, quando pensamos no princípio da insignificância, lembremos que há casos em que o indivíduo furta uma fruta, sem que haja lesão efetiva ao bem jurídico da vítima, o que ensejaria na atipicidade da conduta.

O mesmo ocorre com relação à **norma penal em branco**, pois, neste caso, o próprio complemento é uma fonte formal imediata.

A doutrina moderna diz que **só a doutrina é fonte formal mediata**, pois traz interpretações e análises de como as normas devem ser interpretadas.

Há, ainda, na corrente moderna, posição no sentido de que **os costume são fontes informais do direito penal**.

3. COSTUME

Costume é um comportamento uniforme e constante, sendo este o **elemento objetivo**. Seria um hábito qualificado pela convicção da obrigatoriedade, formando um **elemento subjetivo**. Em suma:

- Elemento objetivo: comportamento uniforme;
- Elemento subjetivo: convicção de obrigatoriedade.

Rogério Sanches afirma que **costumes não criam infrações penais**, pois não há crime sem lei e, portanto, quem cria o crime é a lei (reserva legal).

Costumes também **não extinguem nem revogam infrações penais**, ainda que a sociedade não mais considere aquela conduta criminosa. Exemplo disso é o jogo do bicho, o qual continua sendo contravenção penal. Esta é a corrente prevalente, mas há mais duas correntes:

- 1ªC: corrente abolicionista entende que costumes revogam infrações penais, material e formalmente.
- 2ªC: um fato que deixa de ser considerado como infração penal para a sociedade não pode revogar formalmente, mas apenas de forma material, não devendo a lei ser aplicada pelo magistrado.
- 3ªC: entende que somente lei revoga lei, pois enquanto estiver em vigor possui plena eficácia. Esta corrente possui guarida na LINDB, que diz: “Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”. Esta é a corrente adotada pelo STF e pela doutrina majoritária.

4. CARACTERÍSTICAS DA LEI PENAL

A lei penal possui algumas características:

- **Exclusividade:** somente a lei define infrações e comina sanções;
- **Imperatividade:** a lei penal é imposta a todos;
- **Generalidade:** a lei penal é de acatamento geral, ainda que sejam inimputáveis os seus destinatários;
- **Impessoalidade:** a lei penal se dirige a todos abstratamente. A lei penal trata de fatos, e não de pessoas.



5. CLASSIFICAÇÃO DA LEI PENAL

A doutrina traz, basicamente, duas classificações:

- **Lei penal incriminadora:** é a lei que define crimes e comina sanções, trazendo o preceito primário (conduta) e o preceito secundário (sanção).
- **Lei penal não incriminadora:** a doutrina subdivide:
 - **Permissiva (justificante e exculpante):** a lei permite que se pratique a conduta, sendo lícita a conduta do sujeito. Ex.: matar em legítima defesa (permissiva justificante), então a norma do art. 25 do CP é uma norma penal permissiva. Poderá ser permissiva exculpante, que pode agir acobertado por uma excludente de ilicitude ou por uma excludente de culpabilidade, excluindo a culpabilidade, quando ocorrer, por exemplo, a embriaguez accidental completa.
 - **Explicativa (interpretativa):** a lei explica o conteúdo da norma. Ex.: peculato trata de um crime cometido por funcionário público, vindo o art. 327 e explicando esta norma (norma explicativa).
 - **Complementar:** ocorre quando delimita a aplicação das leis incriminadoras, quando e onde eu aplico a lei penal. O art. 5º do CP trata da aplicação da lei penal no território brasileiro, delimitando as normas penais incriminadoras.
 - **De extensão (integrativa):** viabiliza a tipicidade de alguns fatos. Trata-se da denominada adequação típica mediata. Sem essa norma penal, as condutas seriam tidas por atípicas. Ex.: norma que trata da tentativa (art. 14, II, CP) e a norma que trata da participação (art. 29, CP).

CAPÍTULO 4 — INTERPRETAÇÃO DA LEI PENAL

Interpretar significa buscar o significado. O ato de interpretar é necessariamente feito por um sujeito que, empregando determinado modo, chega a um resultado.

Há várias classificações da interpretação da lei penal. A interpretação é estudada quanto ao sujeito, ao modo e ao resultado.

1. QUANTO À ORIGEM (OU AO SUJEITO QUE INTERPRETA)

- **Autêntica:** feita pelo legislador, aquela fornecida pela própria lei, a lei interpreta a si mesma;
- **Doutrinária:** feita pelo estudioso;
- **Jurisprudencial:** realizada pelos Tribunais.

2. QUANTO AO MODO

- **Gramatical:** busca-se o sentido literal das palavras;
- **Teleológica:** busca-se a finalidade ou intenção, objetivo da lei. O intérprete pesquisa a intenção objetivada na lei, busca saber em que contexto essa norma foi produzida;
- **Histórica:** busca-se o fundamento de criação da norma;
- **Sistemático:** busca-se analisar o sistema em que a norma está inserida. Interpretação em conjunto com a legislação em vigor e com os princípios gerais do direito. É uma interpretação rica
- **Progressiva:** busca-se o significado legal de acordo com a ciência que está progredindo.
- **Lógica:** busca-se utilizar métodos indutivos, dedutivos de dialética, tentando encontrar o sentido da lei, a partir da razão.

3. QUANTO AO RESULTADO

- **Declarativa:** o resultado que se alcança é o que está escrito no texto; é aquela em que a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer, nada suprimindo e nada adicionando;
- **Restritiva:** é preciso reduzir o alcance das palavras da lei. Legislador disse mais do que queria, preciso restringir a aplicação da norma;
- **Extensiva:** legislador disse menos do que queria, sendo necessário ampliar o alcance das palavras. Amplia-se o alcance das palavras da lei para que corresponda a vontade do texto.

Admite-se interpretação extensiva contra o réu?

Socorrendo-se do princípio *in dubio pro reo*, não admite interpretação extensiva contra o réu (na dúvida, o juiz deve interpretar em seu benefício). O Estatuto de Roma, que criou o TPI, no seu art. 22, § 2º alerta que, na dúvida, o juiz deve interpretar a norma de forma a favorecer a pessoa objeto do inquérito, acusada ou condenada.

O STJ tem precedente que diz que o princípio da legalidade estrita impede a interpretação extensiva em desfavor do réu, mas essa tese não prevalece mais. O próprio STJ e o STF admitem e aplicam interpretação extensiva em desfavor do réu. A Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), diz que a lei 9.099/95 (Lei do Juizados Especiais) não se aplica aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os Tribunais Superiores dizem que, na verdade, a Lei 9.099/95 não se aplica aos crimes e às contravenções penais, porque na verdade a Lei Maria da Penha quis falar em delito, que engloba crimes e contravenções penais. Dou a “crimes” interpretação extensiva, já que a lei disse menos do que queria. E essa é uma interpretação extensiva feita em desfavor do réu.

Não podemos confundir interpretação extensiva com interpretação analógica.



Interpretação analógica (*intra legem*) – dentro da própria lei. O Código, atento ao princípio da legalidade, detalha todas as situações que quer e, posteriormente, permite que aquilo que a elas seja semelhante, passe também a ser abrangido no dispositivo. Estamos diante de exemplos seguidos de fórmula genérica de encerramento. O legislador, ao formular a lei, dá exemplos e, sabendo que não pode abranger todas as hipóteses, encerra de forma genérica para que o juiz, encontrando situação semelhante, interprete de forma analógica. Ex.: art. 121, § 2º, I, III e IV, CP.

A interpretação analógica não se confunde com analogia! Analogia não é forma de interpretação, mas de integração.

Rogério Sanches traz ainda a interpretação *sui generis*, que é aquela em que é dividida em:

- **interpretação *sui generis* exofórica:** o significado da norma não está no ordenamento jurídico, pois não se encontra na lei. Por exemplo, o art. 20 do CP não traz o significado da palavra “tipo”, razão pela qual deve ser buscado na doutrina.
- **interpretação *sui generis* endofórica:** ocorre quando o texto normativo interpretado procura o significado em outros textos do próprio ordenamento, ainda que não seja da própria lei. É isso que ocorre quando estamos diante de uma norma penal em branco. Por exemplo, a Lei de Drogas não define o que é “droga”, mas dentro do ordenamento eu encontro uma norma positivada (portaria da ANVISA), que vai me dizer o que é norma.

A **interpretação conforme a Constituição** é aquela em que o intérprete busca, dentre várias interpretações possíveis, aquela que se coaduna com a Constituição.

4. FORMAS DE INTERPRETAR A LEI PENAL

4.1. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA

Segundo o art. 22 do Estatuto de Roma, não é possível interpretação extensiva em prejuízo do réu, pois, em caso de ambiguidade, a norma deve ser interpretada em favor da pessoa investigada ou acusada. **O STJ também já disse que o princípio da estrita legalidade impede a interpretação extensiva.**

Zaffaroni e Pierangeli, por outro lado, entendem que, **em casos excepcionais, é possível interpretação extensiva em prejuízo do réu**, quando sua aplicação restrita resultar em notória irracionalidade. Isso é chamado de escândalo interpretativo. Diz que em regra, de fato, não cabe interpretação extensiva contra o réu, salvo quando interpretação diversa resultar num escândalo por sua notória irracionalidade. Quando falo em notória irracionalidade falo em princípio da proibição da proteção deficiente.

4.2. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA

Na interpretação analógica, o legislador, propositadamente, traz uma série de situações que pretende regular e, no fim, permite que aquilo que seja semelhante às aquelas situações também seja abrangido pela norma. Ex.: homicídio pode ser qualificado mediante paga, promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. É o juiz quem dirá o que é o motivo torpe.

Há uma fórmula casuística, seguida de uma fórmula genérica. O que se tem é o encerramento genérico que permite que seja enquadrado outras situações naquela descrição.

5. ANALOGIA

Analogia não é forma de interpretar a norma, mas **modo de integrar** a lei penal. A integração da lei penal se faz por meio da analogia.

Parte-se do pressuposto de que não há lei para aplicar ao caso concreto. Não havendo lei, aplica-se a norma que regule o caso semelhante: “onde há mesma razão deve haver a mesma decisão”.



Sabe-se que, por conta da reserva legal, está **vedada a analogia in malam partem**. A doutrina é **pacífica para que a analogia seja praticada in bonam partem**.

Ademais, para que a analogia seja aplicada, deverá haver uma **lacuna legal**, e não um silêncio intencional do legislador, além de **resultar em algo favorável ao réu**.

A analogia pressupõe lacuna, falta de lei. É necessário integrar essa lacuna. Parte-se do pressuposto de que não existe uma lei a ser aplicada ao caso concreto, motivo pelo qual é preciso socorrer-se de previsão legal empregada à outra situação similar.

É possível analogia no direito penal? Sim. Os pressupostos são:

a) Certeza de que sua aplicação será favorável ao réu – somente *in bonam partem*.

b) Existência de uma efetiva lacuna a ser preenchida, isto é, omissão involuntária do legislador. Se o legislador propositalmente, se for um silêncio for eloquente, não quis que uma determinada lei se aplique a um fato, ainda que seja para favorecer o réu, não será aplicada a analogia. Ex.: art. 181, I, CP. Não se fala em companheiro/união estável, fala somente em cônjuge. O CP é de 1940, e não se falava sobre União Estável à época. É uma omissão involuntária do legislador.

Ex.: art. 155, §2º, CP. Forma privilegiada do furto. Mas há silêncio do legislador na forma privilegiada ao roubo. O legislador não quis colocar a forma privilegiada no roubo.

A analogia poderá ser:

- **analogia legis:** o operador entende que não há uma norma regulando o tema, mas há uma norma regulando tema semelhante. Com isso, integra-se a norma àquela lacuna.
- **analogia iuris:** o operador entende que não há uma norma regulando o tema, mas poderá se utilizar de um princípio geral do direito, que regula caso semelhante, e integrá-lo àquela lacuna.



CAPÍTULO 5 — TEORIA GERAL DA NORMA PENAL

É preciso tratar dos princípios gerais do direito penal.

1. PRINCÍPIO DA EXCLUSIVA PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS

Segundo Luiz Régis Prado, **bem jurídico é um ente material ou imaterial essencial para coexistência e desenvolvimento do homem em sociedade**. E por ser essencial, é juridicamente e penalmente protegido. O caráter essencial do bem jurídico, a vida em sociedade do homem, justifica a sua proteção na esfera penal.

Portanto, a criação de tipos penais deve ser pautada pela proibição de comportamentos que exponham a risco ou lesionem estes bens jurídicos, valores essenciais para o ser humano.

E isso vai pautar a atuação do legislador, quando proibir condutas e criar crimes, pois deverá analisar se tais condutas vão expor a perigo valores essenciais do ser humano.

2. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA

O direito penal só deve ser aplicado quando for estritamente necessário, de forma que a atuação do direito penal fica condicionada à insuficiência das demais esferas do controle social.

Só pode o direito penal atuar nos casos em que houver uma relevante lesão ou perigo de lesão relevante a um bem juridicamente tutelado. Este é o **caráter fragmentário** do direito penal, sendo, portanto, a *ultima ratio*.

3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Como desdobramento do princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade, surge o denominado princípio da insignificância.

Ainda que o legislador crie tipos incriminadores, é possível que no caso concreto a lesão ao bem jurídico seja irrelevante. E é nesses casos que estaremos diante do **crime de bagatela**.

No caso do princípio da insignificância, **há subsunção do fato à norma**, configurando a tipicidade formal. Todavia, **não há tipicidade material**.

Zaffaroni estabelece que não basta que a conduta traga a tipicidade formal, é necessário que haja **tipicidade conglobante**, a qual englobaria, além da tipicidade material, a antinormatividade (que essa conduta não seja fomentada nem mesmo obrigada pelo Estado).

Ou seja, para haver tipicidade seriam necessárias:

- **Tipicidade formal;**
- **Tipicidade conglobante: tipicidade material + antinormatividade.**

No caso do princípio da insignificância, **não há tipicidade material**.

Do ponto de vista da interpretação, o princípio da insignificância seria uma restrição dada ao tipo penal. Ou seja, o tipo penal, neste caso, não é aplicado. E, por conta disso, a conduta seria **atípica**.

Informativo 913-STF (05/09/2018) – Dizer o Direito

Em regra, o reconhecimento do princípio da insignificância gera a absolvição do réu pela atipicidade material. Em outras palavras, o agente não responde por nada.

Em um caso concreto, contudo, o STF reconheceu o princípio da insignificância, mas, como o réu era reincidente, em vez de absolvê-lo, o Tribunal utilizou esse reconhecimento para conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afastando o óbice do art. 44, II, do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II – o réu não for reincidente em crime doloso;

Situação concreta: Antônio foi denunciado por tentar furtar quatro frascos de xampu de um



supermercado, bens avaliados em R\$ 31,20. O réu foi condenado pelo art. 155 c/c art. 14, II, do CP a uma pena de 8 meses de reclusão. Foi aplicado o regime inicial semiaberto e negada a substituição por pena restritiva de direitos em virtude de ele ser reincidente (já possuía uma condenação anterior por furto), ataindo a vedação do art. 44, II, do CP.

Em razão da reincidência, o STF entendeu que não era o caso de absolver o condenado, mas, em compensação, determinou que a pena privativa de liberdade fosse substituída por restritiva de direitos, afastando a proibição do art. 44, II, do CP.

STF. 1ª Turma. HC 137217/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/8/2018 (Info 913).

Os Tribunais Superiores fixaram 4 requisitos para aplicação do princípio da insignificância (**OPRI**):

- Mínima ofensividade da conduta;
- Ausência de periculosidade social da ação;
- Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
- Inexpressividade da lesão jurídica causada.

O STF, analisando casos de aplicação ou não do princípio da insignificância, vai chegar à conclusão de que **o criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado como se tivesse praticado condutas irrelevantes**. Quando estes pequenos crimes são analisados em conjunto, é possível perceber que o sujeito fez da infração penal um meio de vida, **não podendo ser beneficiado pelo princípio da insignificância**.

O STJ vai além, dizendo que **a reiteração delitiva impede o reconhecimento do princípio da insignificância**, eis que demonstra a periculosidade do agente, por meio do alto grau de reprovabilidade do comportamento.

Vale lembrar que já houve a aplicação do princípio da insignificância quando a reincidência não se deu em relação ao mesmo bem jurídico tutelado. Ex.: o sujeito já havia sido condenado pela prática de uma lesão corporal leve, com sentença já transitada em julgado e cometeu um furto de R\$ 16,00 e como os bens jurídicos eram distintos (integridade física e patrimônio), nada impediria a aplicação do princípio da insignificância.

O STJ, em determinado caso, admitiu a aplicação do princípio da insignificância, mas a Sexta Turma decidiu da seguinte forma: *“Ainda que se trate de acusado reincidente, ou portador de antecedentes, deve ser aplicado o princípio da insignificância, no caso em que a conduta esteja restrita à subtração de 11 latas de leite em pó, avaliadas em R\$ 66,00, pertencentes ao estabelecimento comercial”*.

Como se vê, a aplicação é casuística. No entanto, **via de regra, quem reitera na prática delitiva não é beneficiado**.

O STF e o STJ vão considerar a lesão insignificante ou não, **partindo da análise da capacidade financeira da vítima**, eis que uma coisa é subtrair R\$ 100,00 de um sujeito desempregado e outra é subtrair do Abílio Diniz. Ou seja, **caso a pessoa tenha poucas condições financeiras, poderá o agente ter negada a aplicação do princípio da insignificância, eis que, com relação à vítima, o quantum não seria insignificante**. **Informativo 911-STF (23/08/2018) – Dizer o Direito**

Em regra, a habitualidade delitiva específica (ou seja, o fato de o réu já responder a outra ação penal pelo mesmo delito) é um parâmetro (critério) que afasta o princípio da insignificância mesmo em se tratando de bem de reduzido valor.

Excepcionalmente, no entanto, as peculiaridades do caso concreto podem justificar o afastamento dessa regra e a aplicação do princípio, com base na ideia da proporcionalidade.

É o caso, por exemplo, do furto de um galo, quatro galinhas caipiras, uma galinha garnizé e três quilos de feijão, bens avaliados em pouco mais de cem reais. O valor dos bens é inexpressivo e não houve emprego de violência. Enfim, é caso de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

Mesmo que conste em desfavor do réu outra ação penal instaurada por igual conduta, ainda em



trâmite, a hipótese é de típico crime famélico.

A excepcionalidade também se justifica por se tratar de hipossuficiente. Não é razoável que o Direito Penal e todo o aparelho do Estado-polícia e do Estado-juiz movimente-se no sentido de atribuir relevância a estas situações.

STF. 2ª Turma. HC 141440 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/8/2018 (Info 911).

Informativo 938-STF (03/05/2019) – Dizer o Direito

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 23/4/2019 (Info 938).

Segundo o STF, nos casos de **evasão de divisas** praticada mediante operação do tipo “dólar-cabo” (nas quais são efetuados pagamentos em reais no Brasil, com o objetivo de disponibilizar, por meio de quem recebe tal pagamento, o respectivo montante em moeda estrangeira no exterior), **não é possível utilizar o valor de R\$ 10 mil como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância** (REsp 1.535.956-RS, 9/3/2016. Informativo n. 578).

Segundo o TSE, **não é possível a aplicação do princípio da insignificância em crimes eleitorais** (REsp11887-18/RN).

Por outro lado, o STF já entendeu que é **possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime consistente na conduta de Prefeito que utilizou máquinas e caminhões da Prefeitura para realizar terraplanagem no terreno de sua residência**.

A doutrina moderna distinguiu o princípio da insignificância do princípio da bagatela imprópria (irrelevância penal do fato):

- **Princípio da bagatela própria:** há insignificância da conduta perpetrada, sendo materialmente atípica;
- **Princípio da bagatela imprópria:** há uma irrelevância da pena, ainda que o fato seja relevante. O fato é material e formalmente típico, ilícito e culpável, mas não haverá a aplicação da pena, pois ela se torna desnecessária, não cumprindo a sua função. Ex.: homicídio culposo quando o sujeito mata o filho, ou quando o sujeito que cometeu o crime fica tetraplégico.

4. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

Rogério Sanches ainda distingue o princípio da insignificância do princípio da adequação social. Este princípio foi idealizado por Häns Welzel. Segundo o **princípio da adequação social**, ainda que uma conduta seja formalmente e materialmente típica, não poderá ser considerada típica, **caso ela seja socialmente adequada**.

Aqui há duas funções básicas, pois reduz a abrangência do tipo penal. Se o fato está em desacordo com a norma, mas **de acordo com o interesse social**, a conduta deverá ser tida como atípica. A segunda, **remete o princípio da adequação social ao legislador**. Isso porque, se esta conduta está de acordo com a sociedade, o legislador não pode criminalizar esta conduta, orientando o parlamentar a como proceder na definição dos bens jurídicos a serem tutelados.

Cezar Roberto Bitencourt faz uma crítica ao princípio da adequação social, afirmando que este critério é impreciso. E continua: “princípio sempre inseguro e relativo”. Isso explicaria o porquê de os mais



destacados penalistas internacionais não aceitarem o princípio da adequação nem como caso de exclusão da tipicidade nem mesmo como causa de justificação da pena.

5. PRINCÍPIO DA EXTERIORIZAÇÃO OU DA MATERIALIZAÇÃO DO FATO

Vem do axioma: *Nulla injuria sine actione*. Ou seja, não há ofensa ao bem jurídico sem ação.

Trata-se do direito penal do fato, pois não há como punir o pensamento do autor. É preciso que haja a exteriorização ou materialização do fato.

Não se admite incriminações de sujeito pela sua personalidade. Isso porque o direito penal não é do autor, e sim do fato, havendo materialização do fato.

6. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O art. 1º do CP diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

A partir daí é possível perceber a ótica do direito penal sob três fundamentos:

- **Fundamento político:** vincula o Poder Executivo e Poder Judiciário, proibindo o exercício arbitrário de um poder punitivo.
- **Fundamento democrático:** é o povo que elege o representante que vai definir o que é crime.
- **Fundamento jurídico:** a lei deve existir antes de se punir alguém, pois a lei cria um efeito intimidativo.

A doutrina amplia o alcance do CP e da CF, devendo ser lido crime como infração penal e pena como sanção penal, de forma a incluir a contravenção penal e a medida de segurança, respectivamente.

A doutrina também vai desmembrar o princípio da legalidade em outros 6 princípios:

- **Não há crime nem pena sem lei:** Com relação ao **princípio da reserva legal**, esta decorrência advém do trecho “não há crime sem lei...nem pena sem prévia *cominação legal*”. A lei deve ser em sentido estrito. Medida provisória não pode definir infração penal nem cominar pena, mas **pode versar sobre direito penal não incriminador**, segundo o STF. Por isso, as MP's do Estatuto do Desarmamento tornaram o fato atípico durante um período. É inadmissível que lei delegada verse sobre direito penal, pois a CF determina que é vedado que lei delegada verse sobre direitos individuais. Quando falamos de norma penal, falamos de direitos individuais.
- **Não há crime nem pena sem lei anterior;** ideia da anterioridade.
- **Não há crime nem pena sem lei escrita:** Exclui-se a possibilidade de o direito consuetudinário promover a agravamento da pena ou ser utilizado como fundamentação para se considerar a existência ou não de crime. Costume não cria e nem extingue norma penal.
- **Não há crime nem pena sem lei estrita:** é a proibição de analogia para tipo incriminador e para agravar a pena. O STF não admitiu o furto de energia elétrica nos casos em que há furto de sinal de TV a cabo, pois não seria possível fazer analogia *in malam partem*.
- **Não há crime nem pena sem lei certa:** é o princípio da taxatividade. É dirigido ao legislador, devendo os tipos penais ter clareza. O legislador não pode simplesmente criar um tipo penal de que seja crime um “comportamento incorreto no trânsito”, pois esse conceito é um conceito vago.
- **Não há crime nem pena sem lei necessária:** também advém do princípio da intervenção mínima do direito penal.

A legalidade deve ser analisada sob dois aspectos:

- **Legalidade formal:** é a obediência aos trâmites processuais, denominado de devido processo legislativo em que se cria a lei.
- **Legalidade material:** é imprescindível que a lei criada a partir desse processo legislativo seja compatível com a Constituição.

A lei penal pode ser classificada como:



- **Lei completa:** não depende de complemento, seja valorativo (pelo juiz) ou normativo (por outra norma). Ex.: “matar alguém”, é uma lei completa.
- **Lei incompleta:** depende de complemento valorativo ou normativo.
 - **Tipo penal aberto:** a norma depende de um complemento valorativo, dado pelo juiz. Ex.: crimes culposos, pois é o juiz se decide que houve imprudência.
 - **Norma penal em branco:** há a necessidade de um complemento normativo. Portanto, é preciso que outra norma promova esse complemento. O preceito primário não é completo, razão pela qual a doutrina subdivide essa norma penal em branco em:
 - **Própria (em sentido estrito, heterogênea):** o complemento normativo advém de uma norma diversa do legislador. Ex.: Portaria complementa o crime de tráfico de drogas.
 - **Imprópria (em sentido amplo, homogênea):** o complemento normativo emana do próprio legislador:
 - **Homovitelina:** o complemento emana do mesmo diploma legal. Ex.: peculato é complementado pelo conceito de funcionário público do art. 327, ambos do Código Penal;
 - **Heterovitelina:** o complemento emana de instância legislativa diversa. Ex.: o CP, quando fala em contrair casamento com impedimento, não fala o que seja impedimento, de maneira que deverá se complementar com o conceito previsto no Código Civil.

Atenção! Rogério Greco vai dizer que a norma penal em branco imprópria pode ser homovitelina ou heterovitelina, conforme emane ou não do mesmo ramo do direito. Portanto, se o complemento emana do ramo de direito penal, a norma penal será homovitelina. De outro lado, se a norma-complemento está em outro ramo do direito civil, então a norma penal será heterovitelina.

A doutrina também fala em **norma penal em branco ao revés**, sendo aquela em que o complemento não vem no preceito primário, e sim no preceito secundário (sanção). É o caso dos crimes de genocídio, razão pela qual, por se tratar de pena, necessariamente será complementada por meio de lei.

A norma penal em branco também pode ser denominada de **norma penal em branco ao quadrado**, sendo aquela que a norma penal requer um complemento, mas este complemento também exige a integração por outra norma. Ex.: art. 38 da Lei 9.605, estabelecendo que é crime destruir ou danificar floresta de preservação permanente. Todavia, a floresta de preservação permanente está prevista no Código Florestal. Ocorre que será floresta de preservação permanente a assim declarada pelo chefe do Poder Executivo. Então, quem vai dizer é o chefe do poder executivo.

A norma penal em branco pode ser de instâncias federativas diversas. Por exemplo, a lei de crimes ambientais pode criminalizar uma conduta de alguém que altere a estrutura da edificação, em desacordo com o ato administrativo ou com uma lei, podendo esta ser municipal, estadual ou federal. O que se entende é que, como regra, estas disposições são constitucionais, salvo se muito abertas, perdendo a taxatividade e violando a competência privativa da União.

Norma penal em branco é passível de complemento internacional, ou por uma norma de direito internacional.

Teoria geral da norma penal (continuação). Eficácia da lei penal no tempo. Eficácia da lei penal no espaço. Eficácia da lei penal em relação às pessoas. Disposições finais.

7. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE OU LESIVIDADE

O princípio da ofensividade está ligado ao axioma da *nulla necessitas sine injuria*¹ (não há necessidade sem ofensa ao bem jurídico).

¹Máxima de Luigi Ferrajoli.



Para este princípio, é necessário que haja uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado para que haja crime.

Parte da doutrina defende, com base neste princípio, a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Isso porque, no caso, não haveria lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico. Os crimes de perigo abstrato possuem uma **presunção absoluta do perigo**.

Os Tribunais Superiores admitem delitos de perigo abstrato como constitucionais. Ex.: posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento)². A posse ilegal de arma de fogo desmuniçada já seria suficiente para configurar o crime.

Outro exemplo, em que o STF entende possível o crime de perigo abstrato, é a embriaguez ao volante.

São vedações decorrentes do princípio da lesividade:

- Vedação à criminalização de pensamentos e cogitações (**direito à perversão**) – o pensamento é impunível, uma vez que não há alteridade, não há lesão ao outro.
- Vedação à criminalização de condutas que não tenham caráter transcendental (**vedação à criminalização da autolesão**) – só é possível criminalizar determinada conduta se esta atingir bem jurídico de outrem.

PERGUNTA: Pratica crime o sujeito que se auto lesiona com o intuito de receber indenização da seguradora? Sim, mas o bem jurídico ofendido não é a sua integridade física, mas sim o patrimônio da seguradora que o sujeito, de forma ardil, viola. Pratica, portanto, estelionato.

- Vedação à criminalização de meros estados existenciais (**criminalização da pessoa pelo que ela é**) – não se pode criminalizar a pessoa pelo o que ela é, mas pelo o que ela faz. É por essa razão que não se admite a contravenção penal da mendicância, visto que o Direito Penal não pode ser utilizado como forma de produção de política pública. Em outras palavras, o sujeito não deixará de ser mendigo por existir contravenção penal prevendo que *ser mendigo é uma infração penal*.

7.1. PRINCÍPIO DA ALTERIDADE

É um subprincípio do princípio da lesividade. Este princípio indica que a conduta deve necessariamente atingir, ou ameaçar atingir, bem jurídico de terceiro.

A conduta deve ser transcendental para ser criminalizada. Por isso, o direito penal não pune a autolesão.

8. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL

Só se pune alguém por aquilo que ele fez. É vedado que a pena atinja quem não praticou o fato. A pena não passará na pessoa do condenado.

Tendo em vista que a **responsabilidade é pessoal**, é indispensável que a denúncia traga, de forma pormenorizada, a conduta de cada um dos envolvidos em caso de concurso de pessoas. Ressalte-se que esta previsão é relativa, uma vez que em muitos casos é praticamente impossível individualizar com precisão a conduta de cada agente envolvido.

A partir de então, em síntese, têm-se dois desdobramentos:

- É preciso que a denúncia seja individualizada, narrando, ao menos minimamente, o que os acusados fizeram.

²Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.



- Exige-se que, na sentença, seja feita a individualização da pena, pois cada um merece uma pena certa.

9. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA

Sem a presença de culpa em sentido amplo, que inclui dolo e culpa, não há responsabilidade penal.

O ordenamento **não admite** a chamada responsabilidade penal objetiva. Para que o sujeito seja responsabilizado criminalmente é preciso que tem agido com culpa em sentido amplo.

No caso de embriaguez completa, desde que não acidental (voluntária ou culposa), o sujeito será responsabilizado com base na teoria da *actio libera in causa* (a ação é livre na causa); o estado mental do agente será analisado no momento imediatamente anterior ao início da ingestão da bebida alcoólica.

10. PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE

O princípio da culpabilidade é um postulado que **limita o direito de punir do Estado**. É preciso que o sujeito seja culpável para ser punível.

Ou seja, é preciso, para ser punido, que o sujeito (elementos da culpabilidade):

- Seja imputável;
- Tenha potencial consciência da ilicitude de sua conduta;
- Pudessem ter uma conduta diversa (exigibilidade de conduta diversa).

O princípio da culpabilidade exige que estejam presentes tais elementos para haver a punição do indivíduo.

Obs.: A punibilidade não faz parte do conceito analítico de crime.

11. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (NÃO CULPABILIDADE)

Dispõe a CF, em seu art. 5º, LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

A partir dessa ideia, é possível extrair três ideias do Estatuto de Roma:

- A pena privativa de liberdade só é admissível após a condenação em caráter definitivo (trânsito em julgado);

Obs.: O Supremo reafirmou entendimento no sentido de que o início do cumprimento da pena só pode ocorrer após o trânsito em julgado da condenação. Destaque-se que, no período de fevereiro de 2016 a novembro de 2019, a partir do HC 126.292, o STF havia entendido que o início do cumprimento da pena após confirmação da condenação em segunda instância não violaria o princípio do estado de inocência. No entanto, atualmente, resta reafirmado o entendimento da Corte de se exigir o trânsito em julgado da sentença condenatória.³

- Quem deve comprovar a responsabilidade penal do réu é o órgão acusatório (Ministério Público) – ao final do processo, se restar dúvida, o sujeito deve ser absolvido, já que ele é presumidamente inocente;
- Eventual dúvida, deve ser interpretada a favor do réu (*in dubio pro reo*).

12. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE

Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, conforme art. 5º, XLV, CF.

Este princípio está ligado ao princípio da responsabilidade penal subjetiva, responsabilidade penal pessoal, da culpabilidade etc.

³Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, de relatoria do Min. Marco Aurélio Mello.



13. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO *BIS IN IDEM*

Este princípio **não encontra consagração expressa na Constituição**, mas está previsto no Estatuto de Roma, em seu artigo 20.

Para o Estatuto de Roma, nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime mencionado no artigo 5º, relativamente ao qual já tenha sido condenada ou absolvida pelo Tribunal.

O princípio da vedação do *bis in idem* **não é de caráter absoluto**. Há uma exceção nos arts. 7º e 8º do Código Penal, que são os casos de extraterritorialidade da lei penal brasileira. O artigo 8º do CP diz que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo **mesmo crime**, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Logo, é possível que o sujeito tenha sido processado e condenado duas vezes pelo mesmo fato.

No direito brasileiro, **a sentença condenatória transitada em julgado evita que se instaure novo processo contra o réu condenado, em razão do mesmo fato**, quer para impingir ao sentenciado acusação mais gravosa, quer para aplicar-lhe pena mais elevada.

Obs.: A doutrina sustenta que **a proibição de imposição de mais de uma consequência jurídico-repressiva pela prática dos mesmos fatos ocorre, ainda, quando o comportamento definido espaço-temporalmente imputado ao acusado não foi trazido por inteiro para apreciação do juízo**. Isso porque o objeto do processo é informado pelo princípio da consunção, pelo qual, tudo aquilo que poderia ter sido imputado ao acusado, em referência a dada situação histórica e não o foi, jamais poderá vir a sê-lo novamente.⁴

14. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA

O princípio da confiança, nem sempre citado pela doutrina, aduz que **todos possuem o direito de atuar acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a vida em sociedade**. Assim, quando alguém ultrapassa um sinal verde e acaba colidindo lateralmente com outro veículo que avançou o sinal vermelho, aquele que ultrapassou o sinal verde agiu amparado pelo princípio da confiança, não tendo culpa, já que dirigia na expectativa de que os demais respeitariam as regras de sinalização.

⁴STF. Plenário. HC 86606/MS. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03/08/2007.



CAPÍTULO 6 — EFICÁCIA DA LEI PENAL NO TEMPO

1. INTRODUÇÃO

É possível que a lei penal se movimente no tempo. A esse movimento dá-se o nome de **extra-atividade**.

Se a lei penal é aplicada a fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor, temos a **retroatividade da lei penal**. Sendo aplicada a fatos posteriores a sua revogação, o caso é de **ultratatividade da lei penal**.

2. TEMPO DO CRIME

Considera-se praticado o crime **no momento da ação ou omissão**, ainda que outro seja o momento do resultado: **teoria da atividade** (art. 4º, CP).

Isso tem implicações, principalmente, quando o sujeito é inimputável no momento da ação, e maior de 18 anos, no momento do resultado. Nesta situação, será punido com base no ECA.

3. SUCESSÃO DE LEIS PENAIS

O art. 5º, XL, da CF estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

Portanto, percebemos que a regra é a irretroatividade da lei penal e a exceção é a retroatividade da lei penal benéfica.

3.1. NOVATIO LEGIS INCRIMINADORA

Se a conduta anteriormente era atípica, mas com a vigência da nova lei passa a ser uma conduta criminosa, tem-se **novatio legis incriminadora** (teoria da ação significativa). A lei penal, neste caso, não retroagirá.

3.2. NOVATIO LEGIS IN PEJUS

A nova lei trata de um comportamento que já era considerado criminoso, mas o tratamento atual dado pela lei a este comportamento é um tratamento mais rigoroso.

Se a conduta já era criminalizada, mas uma lei recrudesce o tratamento estatal em relação àquela conduta, receberá o nome de **novatio legis in pejus**. A lei nova que, de qualquer modo, prejudique o réu, também será irretroativa.

Cabe fazer uma observação com relação à Súmula 711 do STF, a qual diz que **a lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência**.

- **Crime permanente** é aquele cuja consumação se protraí no tempo pela vontade do agente. Ex.: crime de sequestro.
- **Crime continuado**, que é uma ficção jurídica, consista na prática de vários crimes da mesma espécie, sob as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, de forma que um crime será considerado continuação do outro, sendo todos tratados como crime único. Neste caso, se uma lei mais prejudicial entrar em vigência, e o indivíduo continuar cometendo crimes da mesma natureza e condições abarcadas pelo instituto do crime continuado, **a lei penal mais grave incidirá na cadeia de todos os crimes cometidos, ainda que anteriores à vigência da nova lei penal, desde que não tenha cessado a continuidade**.



Aplica-se, portanto, a pena do crime mais grave e, considerando o número de infrações praticadas, exaspera-se a pena (≠ concurso formal).

3.3. ABOLITIO CRIMINIS

É possível que a conduta criminosa seja suprimida do ordenamento jurídico por meio de uma lei penal, tornando-se um indiferente penal. Apresenta-se, consequentemente, como uma lei penal benéfica que irá retroagir, alcançado, inclusive, situações definitivamente julgadas.

Neste caso, a lei penal será denominada de **abolitio criminis**. Este é inclusive o teor do art. 2º do CP, estabelecendo que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, **cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais** da sentença condenatória. Portanto, serão interrompidos os efeitos penais, ou seja, **poderá a vítima cobrar as indenizações do réu**, pois a *abolitio criminis* não retira o caráter ilícito da conduta, mas, tão somente, a ilicitude penal.

Os efeitos extrapenais persistem, visto que o fato de uma conduta deixar de ser considerada um ilícito penal não significa que ela tenha deixado de ser um ilícito civil e, portanto, a obrigação de indenizar a vítima por eventual prejuízo causado persiste.

Por isso, **é assentado que os efeitos extrapenais não são alcançados** pela *abolitio criminis*.

Para Flávio Monteiro de Barros, a natureza jurídica da *abolitio criminis* é de causa extintiva da tipicidade. Mas em primeira fase não devemos seguir esta posição. Isso porque **o Código Penal estabelece que a abolitio criminis é causa extintiva da punibilidade (art. 107, CP)**.

3.4. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS

É possível que uma nova lei venha a beneficiar o réu, sendo uma **lex mitior**. O art. 2º, parágrafo único, do CP estabelece que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Trata-se de uma nova lei que passa a conferir um tratamento mais brando àquela conduta criminosa. Isto é, a conduta continua sendo considerada criminosa, mas recebe tratamento mais ameno.

Trata-se da **retroatividade da lei penal benéfica**, incidindo ainda que o sujeito tenha sido condenado definitivamente.

Após o trânsito em julgado da sentença, o juiz competente para aplicar a *novatio legis in mellius* é o **juízo da execução**, conforme entendimento sumulado do STF (Súmula 611).

Todavia, Rogério Sanches atenta ao fato de que a súmula está incompleta, pois **é possível que a análise da lei mais benéfica seja feita pelo juízo competente para apreciar a revisão criminal**. Isso ocorre quando houver necessidade de exercício de um **juízo de valor**. É o caso que exige maior complexidade.

Será competente o juízo da execução quando a aplicação da *novatio legis in mellius* exigir apenas uma operação matemática.

3.5. LEI PENAL BENÉFICA EM PERÍODO DE VACATIO LEGIS

PERGUNTA: Lei penal mais benéfica pode ser aplicada, ainda que de forma retroativa e em período de *vacatio legis*? Não, visto que ainda não entrou em vigor. Ressalte-se que é só com a entrada em vigor que uma lei passa a ter aptidão para produzir efeitos jurídicos.

No caso de lei penal benéfica em período de *vacatio legis*, a discussão desemboca em duas correntes:

1ªC: Alberto Silva Franco diz que é possível a aplicação, mesmo que esteja a lei em *vacatio legis*.

2ªC: A lei penal durante a *vacatio legis* não tem eficácia jurídica, razão pela qual **não pode beneficiar o réu. É a corrente majoritária**.



3.6. COMBINAÇÃO DE LEIS PENAIS (*LEX TERTIA*)

No caso de combinação de leis penais, **o STF não admite a criação de uma terceira lei**, em que o magistrado se utiliza de pontos positivos de duas leis e os aplica ao caso concreto.

Se fosse possível, o Judiciário estaria agindo como legislador positivo, o que não é permitido. O juiz deve aplicar INTEGRALMENTE a lei A ou a lei B.

Por essa razão, não se admite a combinação de leis penais no tempo, **devendo a benignidade entre a lei posterior e a lei anterior ser aferida considerando-as separadamente**.

Assevera a doutrina que se houver dúvida sobre qual lei se mostra mais benéfica, a análise cabe ao réu, representado por seu advogado.

3.7. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA

Este princípio não se confunde com a *abolitio criminis*.

No caso da abolitio, há uma supressão formal e material da conduta criminosa, fazendo com que esta não mais seja considerada criminosa.

No princípio da continuidade normativo-típico, há a supressão formal, mas não material do crime. Esse princípio se aplica nos casos em que uma norma penal é revogada, mas sua conduta continua sendo criminosa no ordenamento.

Ex.: Lei 12.015/2009 – o crime de atentado violento ao pudor (art. 214) teve sua conduta migrada para o delito de estupro (art. 213). Houve a supressão formal, mas não a material.

3.8. LEIS TEMPORÁRIAS E EXCEPCIONAIS

As leis temporárias e excepcionais são leis que possuem uma duração. Estas leis já nascem com previsão de revogação.

A lei temporária e a excepcional, mesmo que encerrado o período de sua duração, serão aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência, razão pela qual têm o efeito da **ultratividade**.

A **lei temporária** tem um prazo determinado, certo. Exemplo: Lei 12.663/12, que busca proteger o patrimônio material e imaterial da FIFA, tendo vigência até 31/12/2014. Encerrado o prazo, não há mais aqueles crimes, mas, se alguém cometeu crime durante o prazo em que vigia a lei, responderá por eles.

A **lei excepcional** é editada em função de algum acontecimento excepcional, como por exemplo uma calamidade. Percebe-se, por exemplo, que quando o estado de emergência cessar também cessará a lei, porém continua a ser aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência.

Tais leis possuem duas características essenciais:

- **autorrevogabilidade:** a lei penal temporária traz o prazo certo da sua revogação, enquanto a lei penal excepcional não traz o momento de revogação, cessando no momento em que cessar a situação ensejadora.
- **ultratividade:** alcançam fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação.

Vale lembrar que, como regra, não há *abolitio criminis* e nem mesmo *lex mitior* para os fatos delitivos praticados durante a vigência das leis temporárias e excepcionais, **salvo se houver determinação expressa em lei nesse sentido**.

3.9. RETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA

Entendimento que prevalece: a extra-atividade, ultratividade ou retroatividade da jurisprudência não é admitida. Só se admite a extra-atividade a lei.

DICA: Para a primeira fase do concurso adote que o entendimento que a JURISPRUDÊNCIA NÃO RETROAGE PARA BENEFICIAR O RÉU.



Todavia, à luz dos ensinamentos do professor Rogério Sanches, chamemos a atenção ao fato de que **não se pode negar a possibilidade de retroatividade benéfica de jurisprudência de efeito vinculante**, a qual se dá através de súmula vinculante do STF, bem como quando há controle concentrado de constitucionalidade. Nesses casos, a decisão será *erga omnes*. Para primeiras fases, devemos marcar que jurisprudência não retroage, ainda que para beneficiar o réu.

3.10. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL NO CASO DE NORMA PENAL EM BRANCO

Norma penal em branco é aquela que é incompleta, dependente de um complemento normativo.

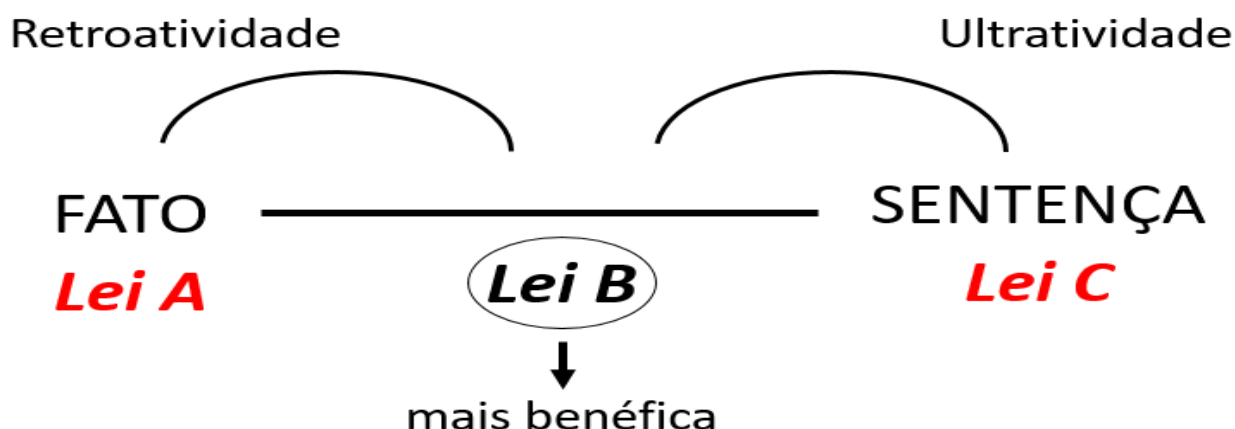
O STF vai dizer que a alteração de um complemento da **norma penal em branco homogênea (norma penal em branco imprópria / em sentido amplo)**, por ser complementada pela própria lei (homovitelina ou heterovitelina), deverá retroagir para beneficiar o réu.

Todavia, no caso de uma alteração de uma **norma penal em branco heterogênea (norma penal em branco própria / em sentido estrito)**, cujo complemento se dá através de uma norma de hierarquia diferente da lei (normalmente uma Portaria ou Resolução), a retroatividade da lei penal dependerá do caráter do complemento:

- **quando a legislação complementar é revestida de caráter excepcional**, como é o caso de portarias que fazem tabelamento de preços, tal qual os crimes contra a ordem econômica. Nesta hipótese, se não foi obedecido o tabelamento daquele ano ou mês, mas posteriormente houve a correção da tabela para um patamar superior, **não haverá a retroatividade da lei penal**. Isso porque não produz a descriminalização, visto que o complemento é dotado de caráter excepcional.
- **quando a legislação não se reveste de excepcionalidade**, como é o caso da retirada do cloreto de etila da lista da Portaria da Anvisa que complementa a Lei de Drogas, **haverá a retroatividade da lei penal**, razão pela qual, neste caso, a alteração do complemento produz a descriminalização da conduta. Isso porque não há caráter excepcional da Portaria que não seja droga.

3.11. LEI INTERMEDIÁRIA MAIS BENÉFICA

Supondo que João tenha cometido um crime sob a vigência da Lei A. Esta lei pune a conduta de João com 4 anos de reclusão. Após, durante o processo, vem a Lei B, estabelecendo que a pena de João passa a ser de 2 anos. Por fim, quando do julgamento, surge uma nova Lei C, determinando que a pena seja de 3 anos.



Analisando as três leis, a melhor é a Lei B. Todavia, esta é intermediária, eis que não estava presente no momento do fato, tampouco no momento da sentença.

O entendimento da doutrina e do STF é de que esta lei é dotada de **duplo-efeito**:

- **retroatividade**: retroage para alcançar o fato;
- **ultratatividade**: possui força para alcançar a sentença ou o julgamento.

Prevalece a **norma mais favorável** que tenha tido vigência entre a data do fato e a data da sentença.



CAPÍTULO 7 — LEI PENAL NO ESPAÇO

1. INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS

Quando falamos em lei penal no espaço, há um verdadeiro conflito de jurisdição internacional. Neste caso, há princípios que levam à solução de um conflito aparente:

- **Princípio da territorialidade:** a lei penal do local do crime é a que será aplicada, não importando a nacionalidade do agente, da vítima ou do bem jurídico.
- **Princípio de nacionalidade ativa (personalidade ativa):** aplica-se a lei do país pertencente ao agente do crime (sujeito ativo), sem importar a nacionalidade da vítima, local do crime ou bem jurídico violado.
- **Princípio da nacionalidade passiva (personalidade passiva):** aplica-se a lei do país pertencente à vítima do crime, sem importar a nacionalidade do agente (sujeito ativo), local do crime ou bem jurídico violado.
- **Princípio da defesa real:** é a aplicação da lei penal da nacionalidade da coisa, do bem jurídico lesado.
- **Princípio da justiça penal universal (justiça penal cosmopolita):** é o princípio que exige que se faça justiça, sem se importar onde. O agente fica sujeito ao país em que for encontrado.
- **Princípio do pavilhão (substituição ou bandeira):** aplica-se a lei nacional aos crimes cometidos em aeronaves ou embarcações privadas, quando praticados no estrangeiros, mas aí não sejam julgados. **ADOTADO PELO CP.**

2. TEORIAS DA LEI PENAL NO ESPAÇO

Segundo o art. 5º, aplica-se a lei brasileira, **sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.** Ou seja, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos no território nacional, mas não haverá prejuízos a tratados celebrados com o Brasil. Esta teoria adotada é denominada de **territorialidade mitigada.**

Isto é, permite-se, eventualmente, a aplicação da lei estrangeira a fato praticado no território brasileiro, sendo isto denominado de **intraterritorialidade.** Exemplo disso é a imunidade diplomática.

Por outro lado, também é possível que se aplique a lei penal brasileira a fato praticado no estrangeiro, a isto se dando o nome de **extraterritorialidade.**

3. TERRITÓRIO NACIONAL

Para efeitos penais, segundo o art. 5º, o §1º do CP, consideram-se como extensão do território nacional as **embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem.**

Também é extensão do território nacional as **aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar** (princípio do pavilhão ou da bandeira).

O §2º diz que **é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se as aeronaves em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, ou então as embarcações em porto ou mar territorial do Brasil.**



4. EMBAIXADAS

Apesar de as Embaixadas serem invioláveis, **não constituem extensão do território dos países que representam**. A embaixada está dentro do território nacional, a aplicação da lei brasileira pode ser afastada em razão da existência de Convenção Internacional que conceda imunidade diplomática, mas ainda assim a embaixada é parte do território nacional.

Ex.: A embaixada da Holanda no Brasil é considerada território brasileiro, razão pela qual, a depender de quem pratique o crime lá dentro, haverá incidência da lei penal brasileira, salvo se houver convenções, tratados e regras de direito internacional em sentido contrário.

5. PASSAGEM INOCENTE

O direito de passagem inocente consiste na **não incidência da lei penal brasileira** no caso em que ocorra um crime dentro de um navio ou aeronave que se encontra **de passagem** no território nacional.

Neste caso, não haverá aplicação da lei penal brasileira, pois não há intenção de atracar no território nacional.

6. LUGAR DO CRIME

Segundo o art. 6º do CP, considera-se praticado o crime **no lugar em que ocorreu a ação ou omissão** (teoria da atividade), no todo ou em parte, bem como **onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado** (teoria do resultado).

Como se vê, foi adotada a **teoria mista ou da ubiquidade**.

Obs.: O art. 70 do Código de Processo Penal adota a teoria do resultado para fins de fixação de competência.

O professor Rogério Sanches apresenta três classificações de crimes:

- **Crimes à distância (crime de espaço máximo):** é aquele crime que percorre dois territórios de estados soberanos. Poderá gerar um conflito de jurisdição.
- **Crimes em trânsito:** é o crime que percorre mais de dois países soberanos, também podendo gerar um conflito internacional de jurisdição.
- **Crimes plurilocais:** são os crimes que percorrem dois ou mais territórios dentro de um mesmo país. Neste caso, pode existir um conflito interno de competência.

DICA: Crimes à Distância percorrem Dois estados soberanos. Crimes em Trânsito percorrem Três ou mais estados soberanos.

7. EXTRATERRITORIALIDADE

É a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira a fatos ocorridos no estrangeiro.

O Código Penal, em seu art. 7º, estabelece quais crimes ficam sujeitos à lei brasileira, embora estes crimes tenham sido cometidos no estrangeiro.

7.1. EXTRATERRITORIALIDADE INCONDICIONADA

Inciso I: haverá **extraterritorialidade incondicionada**, ou seja, o agente será punido segundo a lei brasileira, **ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro**, no seguintes crimes:

- crimes contra a **vida** ou a **liberdade** do Presidente da República;
- crimes contra o **patrimônio** ou a **fé pública** da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;



- crimes contra a **administração pública, por quem está a seu serviço;**
 - crimes de **genocídio**, quando o **agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;**
- A extraterritorialidade incondicionada é uma **exceção ao princípio do *ne bis in idem***.

7.2. EXTRATERRITORIALIDADE CONDICIONADA

Inciso II: estabelece a **extraterritorialidade condicionada** para os crimes:

- que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
- praticados por brasileiro;
- praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Trata-se de aplicação do princípio da bandeira ou pavilhão.

Todavia, para que haja a extraterritorialidade condicionada e seja aplicada a lei penal brasileira, deverá haver o cumprimento das seguintes **condições**:

- **Entrar o agente no território nacional:** trata-se de uma condição de procedibilidade, pois somente haverá processo se o agente ingressar no território nacional.
- **Ser o fato punível também no país em que foi praticado:** Se o agente consumiu droga em determinado local permitido, então o fato não será punível no local em que foi praticado. Trata-se de uma condição objetiva de punibilidade.
- **Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição:** as condições estão previstas no art. 82 da Lei 13.445/17 (Lei de Migração)⁵; a pena privativa de liberdade deve ser não inferior a dois anos.
- **não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena:** percebe-se que já um maior respeito ao *ne bis in idem*;
- **não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, segundo a lei mais favorável, não estar extinta a punibilidade:** se o indivíduo tiver sido perdoado, não mais poderá ser punido no Brasil, assim como se tiver sido absolvido ou extinta a punibilidade.

⁵Lei 13.445/17 (Lei de Migração) - Art. 82. Não se concederá a extradição quando:

I - o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato;

II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;

III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;

IV - a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos;

V - o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;

VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;

VII - o fato constituir crime político ou de opinião;

VIII - o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; ou

IX - o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, ou de asilo territorial.

§ 1º A previsão constante do inciso VII do caput não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal.

§ 2º Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração.

§ 3º Para determinação da incidência do disposto no inciso I, será observada, nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição.

§ 4º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo.

§ 5º Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses previstas na Constituição Federal.

7.3. EXTRATERRITORIALIDADE HIPERCONDICIONADA

A extraterritorialidade hipercondicionada exige, além de todas as condições da extraterritorialidade condicionada, que o crime **cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil**, nesse caso, para haver aplicação da lei brasileira, é necessário que:

- não tenha sido pedida ou negada a extradição;
- haja uma requisição do Ministro da Justiça.

8. COMPETÊNCIA PARA EXTRATERRITORIALIDADE

No caso da extraterritorialidade, **a competência será da Justiça Estadual** para julgar o indivíduo que praticou o crime fora do território nacional, mas que está sujeito à aplicação da lei brasileira.

No entanto, se estiverem presente alguma (ou algumas) das hipóteses do **art. 109 da Constituição Federal, que atrairá a competência da Justiça Federal**, porém a regra é da Justiça Estadual.

O art. 88 do CPP estabelece que no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, **será competente o juízo da capital do Estado onde houver por último residido o acusado**.

Todavia, caso o **acusado nunca tiver residido no Brasil**, será competente o **juízo da Capital da República**.

9. PENA CUMPRIDA NO ESTRANGEIRO

Nesse caso, seria, inicialmente, o caso de extraterritorialidade, mas a pena foi cumprida no estrangeiro.

Por essa razão, o Código Penal prevê que se a pena foi cumprida no estrangeiro atenuará a pena imposta no Brasil, **se ela for diversa da pena**.

Ex.: No estrangeiro a pena para o crime é de prestação de serviços à comunidade, mas no Brasil é pena privativa de liberdade. Neste caso, atenuará a pena imposta no Brasil, não podendo ser a mesma que seria se ele não tivesse cumprido a penalidade no exterior.

Por outro lado, se a **pena for idêntica**, ou seja, ambas as penas são privativas de liberdade.

Ex.: Sendo o indivíduo no Brasil condenado a 4 anos, mas no estrangeiro foi condenado a 3 anos, nesta hipótese, a pena privativa de liberdade é computada, pois são idênticas. Desse modo, se cumpriu os 3 anos no estrangeiro, faltará apenas 1 ano para cumprir a pena no Brasil.



CAPÍTULO 8 — EFICÁCIA DA LEI PENAL EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS

1. IMUNIDADE DIPLOMÁTICA

As imunidades diplomáticas são **prerrogativas**, e não privilégios. Trata-se de prerrogativa em razão do cargo exercido, de natureza pública.

Possuem imunidades diplomáticas:

- Chefes de estado e Chefes de governo, bem como seus familiares e membros da comitiva;
- Embaixador e sua família;
- Funcionários do corpo diplomático e sua família;
- Funcionários de organização internacional, quando estes estiverem em serviço;

A Convenção de Viena vai além, **assegurando ao agente diplomático a imunidade de jurisdição penal do estado acreditado** (aquele que recebe o agente diplomático), ou seja, ele não pode ser punido pelas leis do estado acreditado (em que ele está), pois está representando o seu país, que no caso é o estado acreditante (aquele que envia o agente diplomático).

PERGUNTA: O diplomata não deve obediência à lei penal brasileira?

Sim, ele deve. Isso porque a lei penal possui caráter geral (generalidade) e imperatividade, pois a todos ela é imposta. Sendo assim, o diplomata deve obedecer à lei, pois se a desobedecer, apesar de não ser submetido às consequências do direito penal brasileiro, poderá ficar sob a eficácia da lei do Estado a que pertence (acreditante). Nesse caso da imunidade diplomática, **haverá o fenômeno da intraterritorialidade, pois será aplicada a lei do país acreditante aqui no Brasil.**

O agente diplomático **não pode ser objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão**, conforme Decreto 6.435/65. Esta inviolabilidade se estende à sua residência, documentos, correspondências, ou seja, aos seus bens em geral.

A natureza jurídica da imunidade diplomática é de **causa pessoal de isenção de pena**. Esta imunidade se aplica a qualquer crime, **e não apenas aos atos praticados no exercício da função**. O embaixador, por exemplo, não ficará submetido a qualquer dessas reprimendas.

2. AGENTE CONSULAR

Não se pode confundir o agente diplomático com o agente consular.

O agente consular tem a função meramente administrativa, **não desfrutando de imunidade diplomática**. Apesar disso, **o cônsul possui uma imunidade restrita aos atos de ofício, ou seja, é uma imunidade funcional relativa.**

3. IMUNIDADES PARLAMENTARES

As imunidades parlamentares poderão ser classificadas em:

- Imunidades absolutas (substancial, material ou indenidade)
- Imunidades relativas (formal ou processual)

3.1. IMUNIDADES ABSOLUTAS (SUBSTANCIAL, MATERIAL OU INDENIDADE)

Segundo o art. 53, caput, CF, os Deputados e Senadores são invioláveis, **civil e penalmente**, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

Percebemos que há uma inviolabilidade pelas palavras, opiniões e votos. Trata-se da **liberdade da fala**.



O STF entendeu que **para haver a incidência da imunidade absoluta, é preciso que haja uma conexão entre as palavras e opiniões do parlamentar e o exercício de suas funções**. Não havendo essa conexão, não há imunidade parlamentar substancial.

Todavia, se o parlamentar estiver **nas dependências do Parlamento, presume-se absolutamente que há essa conexão**, razão pela qual sua imunidade estaria assegurada, tal como decidiu o STF⁶.

3.2. IMUNIDADES RELATIVAS (FORMAL OU PROCESSUAL)

A imunidade parlamentar relativa está prevista no art. 53, §§1º a 8º, da CF.

- Imunidade relativa ao foro;
- Imunidade relativa à prisão (incoercibilidade dos congressistas);
- Imunidade relativa ao processo
- Imunidade relativa à condição de testemunha
- Imunidade relativa ao estado de sítio

3.2.1. IMUNIDADE RELATIVA AO FORO

Deputados e Senadores, **desde a expedição do diploma**, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Não se trata de privilégio, mas sim um **foro por prerrogativa de função**.

Obs.: O Supremo conferiu uma interpretação restritiva – o foro por prerrogativa de função para deputados e senadores só existe em relação a crimes praticados **no exercício da função e em razão dela**.⁷

3.2.2. IMUNIDADE RELATIVA À PRISÃO (INCOERCIBILIDADE DOS CONGRESSISTAS)

A imunidade relativa à prisão visa proteger os parlamentares para que não sofram coerções pelas suas atuações e opiniões. Trata-se da denominada **incoercibilidade dos congressistas**.

Por conta disso, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de **24 horas** à Casa respectiva, para que, pelo voto da **maioria de seus membros**, resolva sobre a prisão. Trata-se de uma **decisão política**, podendo a Casa liberá-lo ou mantê-lo preso.

No caso do Senador Delcídio do Amaral, o STF entendeu que o Senador estava obstruindo a Justiça (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13), e que este delito possui caráter permanente, estando, por isso, em situação de flagrante. Ademais, no caso em apreço, não cabia fiança, sendo inafiançável, razão pela qual estariam presentes os requisitos para prisão cautelar.

Com relação à **pensão alimentícia**, há uma divergência sobre a possibilidade de prisão ou não do parlamentar:

1ª Corrente: Uadi Lammego Bulos entende que é possível a prisão do parlamentar devedor de alimentos.

2ª Corrente: Gilmar Mendes entende que não é cabível, eis que a imunidade abarca qualquer ato de privação da liberdade, impedindo também as prisões de natureza extrapenal, como a do devedor de alimentos.

⁶STF. RE 606451 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/03/2011. (Os atos praticados em local distinto, escapam da proteção absoluta da imunidade, que abarca apenas as manifestações que guardem pertinência, como nexo de causalidade, com o desempenho das funções do mandato parlamentar).

⁷STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018. (As normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. Assim, por exemplo, se o crime foi praticado antes de o indivíduo ser diplomado como Deputado Federal, não se justifica a competência do STF, devendo ele ser julgado pela 1ª instância mesmo ocupando o cargo de parlamentar federal. Além disso, mesmo que o crime tenha sido cometido após a investidura no mandato, se o delito não apresentar relação direta com as funções exercidas, também não haverá foro privilegiado).



3ª Corrente: Rogério Sanches diz que a depender da espécie de alimentos, poderá ou não haver a prisão. Se os alimentos forem provisórios, em uma tutela de urgência, não caberia prisão. Todavia, se os alimentos tiverem caráter definitivo, então seria possível a prisão do parlamentar pelo descumprimento inescusável e voluntário da obrigação alimentícia.

O tema não é pacífico. Para o professor Samer Agi, bastaria que parte do subsídio do parlamentar fosse destinado ao adimplimento da dívida alimentícia.

3.2.3. IMUNIDADE RELATIVA AO PROCESSO

A imunidade relativa se estende ao processo, mais precisamente a **processos relativos a crimes cometidos após a diplomação por congressistas**. Repita-se: APÓS a diplomação.

No caso de crimes praticados após a diplomação por congressista, sendo recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, neste caso, permite-se que a Casa Legislativa respectiva suste, a pedido de qualquer partido político que nela tenha representação, o andamento da ação penal, através do voto ostensivo e nominal da maioria absoluta de seus membros (art. 53, §3º da CF).

Veja, **esta imunidade não impede a instauração do processo**, pois o STF dispensa a autorização.

Esta suspensão processual deve ser apreciada dentro do **prazo de 45 dias** pela Casa respectiva. Caso ocorra a sustação, o processo não seguirá enquanto o parlamentar seguir no mandato, ficando **suspenso o processo e, conseqüentemente, o lapso prescricional**.

ATENÇÃO: a imunidade parlamentar em sentido formal, que é a ideia de sustar o processo a partir de um partido político com representação no Congresso Nacional, **não se estende aos inquéritos policiais**, razão pela qual, se houver a respectiva instauração da investigação, não há que se falar em suspensão a pedido de qualquer partido político.

Ademais, como se trata de parlamentar, o STF entende que a **iniciativa para instauração de inquérito policial deve ser requerida pelo Procurador-Geral da República**, com a autorização do STF, de modo que, a partir de então, restará supervisionada pelo Supremo Tribunal Federal.

3.2.4. IMUNIDADE RELATIVA À CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA

Com relação à imunidade relativa à condição de testemunha, esta não se trata de parlamentar acusado ou investigado, e sim na sua verdadeira condição de testemunha.

Os parlamentares **são obrigados a testemunhar, salvo em duas hipóteses excepcionais**, previstas na CF:

- não são obrigados a prestar testemunhos sobre informações recebidas ou prestadas **em razão do exercício do mandato**;
- não são obrigados a prestar **sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações**.

Portanto, nestes casos, há uma relação íntima com a atribuição do cargo.

De acordo com o art. 221 do CPP, os parlamentares possuem a **prerrogativa de serem inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz**, ou seja, os parlamentares têm o dever de prestar testemunho, salvo naquelas hipóteses constitucionais, mas deverão ajustar previamente a inquirição.

Atente-se que **a condição de testemunha não se aplica ao parlamentar investigado ou acusado**.

3.2.5. IMUNIDADE RELATIVA AO ESTADO DE SÍTIO

Mesmo que tenha sido decretado o estado de sítio, **as imunidades parlamentares persistem**. É possível que estas imunidades sejam **suspensas pela decisão de 2/3 dos parlamentares da Casa respectiva**, nos casos de **atos praticados fora do recinto** do Congresso Nacional, e que **sejam incompatíveis** com a execução da medida.



3.3. PARLAMENTAR LICENCIADO

Segundo STF, o **parlamentar licenciado não tem imunidade**. Todavia, **permanece apenas o foro por prerrogativa de função** para ser julgado perante a Corte Suprema.

3.4. IMUNIDADES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS

A CF, em seu art. 27, §1º, **estende as imunidades dos parlamentares federais aos deputados estaduais**. Portanto, eles possuem a mesma imunidade em razão do princípio da simetria.

3.5. IMUNIDADES DOS VEREADORES

O art. 29, VIII, da CF, estabelece que os vereadores possuem **inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município**. Isto é, possuem apenas imunidades absolutas (materiais).

Ademais, vereadores **não possuem foro por prerrogativa de função**, salvo se previsto na Constituição Estadual.

Por esta razão, aplica-se o disposto na **súmula vinculante 45**, estabelecendo que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual.

O foro por prerrogativa de função do prefeito está na Constituição Federal, devendo ser julgado originariamente no Tribunal de Justiça. O STF amplia essa competência para tribunais de 2º Grau, a depender da espécie de crime cometido (TRF, TRE ou TJ). Todavia, o vereador não possui foro previsto na CF, razão pela qual se houver a prática de homicídio doloso, será julgado pelo Tribunal do Júri, ainda que previsto o foro na Constituição Estadual.



CAPÍTULO 9 — DISPOSIÇÕES GERAIS

1. EFICÁCIA DA SENTENÇA ESTRANGEIRA

A sentença criminal proveniente de estado soberano estrangeiro desde a EC 45/04 deve ser **homologada** no Brasil pelo **Superior Tribunal de Justiça**. Ao fazer a homologação **não aprecia o mérito**, fazendo apenas um exame formal (**juízo de prelibação**).

Após a homologação, se a parte quiser que o agente repare o dano, restitua a reparação ou que ocorra qualquer efeito civil, neste caso, é necessário que a parte interessada promova a ação, pois haverá sempre a necessidade de requerimento por parte do interessado.

E se a homologação for pertinente à **medida de segurança**, será **imprescindível que exista tratado de extradição com o país de cuja autoridade emanou a decisão**. Se não houver este tratado, é necessário que haja uma requisição do ministro da justiça que suprirá a necessidade do tratado entre os países.

Esta homologação **não é imprescindível para que ela produza todos os seus efeitos**. Damásio de Jesus explica que hipóteses em que não é necessária a homologação, quando, por exemplo, no caso da **reincidência**, bastando que o sujeito tenha uma sentença penal condenatória, ainda que proferida no estrangeiro. Há ainda outros casos, como o **sursis** e **livramento condicional**, hipóteses em que o reconhecimento independerá de homologação da sentença penal condenatória.

2. CONTAGEM DE PRAZO

Com relação à contagem de prazo, Rogério Sanches estabelece a diferença de:

- **prazos processuais penais:** o CPP estabelece que não é computado o dia do início, mas é incluído o dia do vencimento. Se cair em feriado ou dia não útil, prorrogar-se-á para o primeiro dia útil imediatamente posterior.
- **prazos penais:** há aqui uma improrrogabilidade dos prazos, de forma que será incluído o dia do começo e excluído o dia do final.

3. FRAÇÕES NÃO COMPUTÁVEIS DA PENA

Dispõe o art. 11 do CP que são desprezadas, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de reais (cruzeiro).

O CP estabelece, ainda, que a pena será exasperada em 1/3, por exemplo.

Ex.: Quando há uma causa de aumento de pena, essa pena poderá ficar em 8 anos, 7 meses, 12 dias e 4 horas, esta fração de dia (4 horas) é excluída pelo Código Penal. A pena de multa poderá ficar em R\$ 3.500,87, sendo que estas frações de reais serão excluídas.

4. CONFLITO APARENTE DE NORMAS

Quando falamos de conflito aparente de normas, não falamos em sucessão de leis penais no tempo. **Para que falemos no conflito aparente de normas, é necessário que haja duas leis penais em vigor ao mesmo tempo.**

Para resolver o conflito aparente de norma, é necessário se valer dos seguintes princípios:

- princípio da especialidade;
- princípio da subsidiariedade;
- princípio da consunção;
- princípio da alternatividade.



4.1. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

O princípio da especialidade estabelece que a lei especial prevalece sobre a geral. No conflito de lei penal geral e lei penal especial, aplica-se esta última. A lei é especial em razão de conter todos os elementos da lei geral, além de conter elementos especializantes.

Ex.: Quem comete um infanticídio mata alguém, mas há elementos como “logo após o parto” e o “estado puerperal” que são elementos especializantes, distinguindo-se do homicídio.

Atente-se que **não há relevância se o crime é mais gravoso ou menos gravoso**. O infanticídio possui pena mais branda do que o homicídio.

4.2. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

Na subsidiariedade, uma lei define o fato como criminoso e outra lei também define o fato como criminoso. Porém, a abrangência da outra lei é maior. Em verdade, o que se percebe nesta relação entre norma subsidiária e norma principal, é de que **há uma relação de maior e de menor gravidade**.

Não é relação de norma e espécie. Trata-se de uma relação de menor gravidade e maior gravidade.

A norma subsidiária só se aplica quando não houver subsunção do fato à norma mais grave, que é a norma principal, devendo ser aplicada a norma subsidiária.

A subsidiariedade poderá ser:

- **subsidiariedade expressa:** ocorre quando o próprio tipo penal traz a fórmula “se não houver crime mais grave”.
- **subsidiariedade tácita:** ocorre quando o tipo penal não traz a fórmula, mas é possível perceber o caráter de subsidiariedade da norma.

4.3. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Na consunção, há uma absorção de um delito por outro.

Não há uma relação de espécie e gênero, tampouco um menos grave para o mais grave.

No princípio da consunção **não necessariamente será aplicada a pena do crime mais grave**. É o caso, por exemplo, do agente que falsifica documento (com pena de reclusão de 2 a 6 anos) e posteriormente utiliza-o para a prática de estelionato (com pena de reclusão de 1 a 5 anos). Neste caso, haverá aplicação da **Súmula 17 do STJ**, a qual estabelece que, **quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido** (o crime de estelionato é menos grave do que o de falsificação de documento).

No ano de 2016, o STJ entendeu que, se o agente cria farmácia de fachada para vender produtos falsificados destinados a fins terapêuticos ou medicinais, ele deverá responder pelo delito do art. 273 do CP (e não por este crime em concurso com tráfico de drogas), ainda que fique demonstrado que ele também mantinha em depósito e vendia alguns medicamentos e substâncias consideradas psicotrópicas no Brasil por estarem na Portaria SVS/MS nº 344/1998. Assim, **mesmo tendo sido encontradas algumas substâncias que podem ser classificadas como droga, o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 ficará absorvido pelo delito do art. 273 do CP, que possui maior abrangência. Aplica-se aqui o princípio da consunção**.

Segundo decidiu o STJ⁸, “não se mostra plausível dizer que houve a prática de dois crimes distintos e em concurso material quando, em um mesmo cenário fático, se observa que a intenção criminosa era dirigida para uma única finalidade, perceptível, com clareza.”

Casos de consunção:

CRIME PROGRESSIVO x PROGRESSÃO CRIMINOSA

⁸STJ. RE no REsp 1537773/SC. Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/12/2016.



O que caracteriza o princípio da consunção é o fato de que uma lei atinge parte de um todo de outro crime. E **quando atinge o todo, mesmo que uma parte não seja crime, deverá aplicar a parte do crime que é o todo.**

No **crime progressivo**, o sujeito já tem uma finalidade grave, mas para alcançá-la o sujeito pratica crime menos grave.

Ex.: João quer matar José. João pega uma faca e dá uma facada em José, tendo aqui uma lesão corporal. Após, dá uma segunda facada e, na terceira, José morre. Perceba que para alcançar o resultado de um crime, neste caso mais grave, o agente passa necessariamente por um crime menos grave. Há aqui um **crime progressivo**.

Todavia, o agente, desde o início, tinha o dolo de matar. É isto que diferencia a progressão criminosa do crime progressivo (lesão é uma parte do homicídio).

Na **progressão criminosa**, o sujeito substitui o dolo inicial, pois, primeiramente, o sujeito queria lesionar. Após lesionar, quer matar, havendo uma mudança do dolo. Há uma substituição do dolo, dando causa a um resultado mais grave. Por essa razão, considera-se que o indivíduo praticou apenas um crime, qual seja, o crime mais grave.

É ainda caso de consunção os chamados *ante factum* impunível e *post factum* impunível:

- ***ante factum* impunível:** é o que ocorre antes e não será punível. São fatos anteriores que estão na linha de desdobramento na ofensa mais grave.

Ex.: João quer furtar a televisão de José. Para isso, viola o domicílio e leva a televisão. Neste caso, a violação de domicílio é uma etapa do furto, mas não será de todo furto. Por essa razão, não há falar em progressão criminosa e crime progressivo. Não há aqui substituição impunível.

- ***post factum* impunível:** consiste basicamente no exaurimento do crime principal.

Ex.: O sujeito já cometeu a lesão, pegando o objeto que subtraiu e o destrói. Após ter cometido o crime, ele o exaure. O sujeito que furtou a televisão de José e o coloca fogo nela não praticará um furto e um dano, mas apenas um furto, pois a destruição posterior é *post factum* impunível.



CAPÍTULO 10 — TEORIA GERAL DO CRIME: INTRODUÇÃO

1. CONCEITO DE INFRAÇÃO PENAL

- **Enfoque formal:** infração penal consiste na prática de uma conduta descrita em uma norma penal incriminadora; em outras palavras, é aquilo que está rotulado em uma norma penal incriminadora com ameaça de pena.
- **Enfoque material:** infração penal é o comportamento humano, causador de uma lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pelo Estado.
- **Enfoque analítico:** infração penal é o fato típico, ilícito e culpável (teoria tripartite).

2. DIFERENÇA ENTRE CRIME E CONTRAÇÃO

No Brasil, infração penal é gênero, tendo como espécies o crime e a contravenção penal.

Entre crime e contravenção penal não há diferença ontológica; o professor Nelson Hungria assevera que contravenção penal não mais é do que um crime anão.

No entanto, do ponto de vista axiológico há diferença acerca da valoração que se faz da infração; crimes são infrações penais mais graves e contravenções penais são menos graves

São diferenças entre crime e infração penal:

- **quanto à pena privativa de liberdade imposta:** o CP dispõe em sua Lei de Introdução que se considera crime quando a pena privativa de liberdade é de reclusão ou de detenção, ainda quando alternativamente à pena de multa. A contravenção penal é apenada com prisão simples, multa, ou prisão simples e/ou multa.
- **quanto à espécie de ação penal:** as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada (que é a regra), enquanto os crimes podem ser de ação penal pública incondicionada, condicionadas à representação ou requisição e de ação penal privada;
- **quanto à tentativa:** as contravenções penais não admitem tentativa, pois não são puníveis (art. 4º, Lei de Contravenções Penais). Os crimes admitem, como regra.
- **quanto à extraterritorialidade da lei brasileira:** somente se admite a extraterritorialidade quando houver a prática de crime, não cabendo este instituto com relação às contravenções (art. 2º, LCP).
- **quanto à competência para processar e julgar:** os crimes podem ser da competência da Justiça Federal, Estadual ou Eleitoral. Em relação às contravenções, estas serão sempre de competência da Justiça Estadual (por exemplo, ainda que seja cometida contra o patrimônio da União), salvo se quem a cometeu a contravenção tiver foro por prerrogativa de função.
- **quanto aos limites da pena:** no crime, a execução não pode exceder a 40 anos (Lei 13.964/19). Nas contravenções, o limite para cumprimento de pena é de 5 anos.
- **quanto ao período de prova (sursis):** nos crimes, o período de prova será, como regra, de 2 a 4 anos, porém se for o sursis etário ou humanitário poderá ser de 4 a 6 anos. No caso de contravenção, o período de prova será de 1 a 3 anos, somente.
- **quanto ao cabimento de prisão temporária e preventiva:** crime admite prisão temporária e prisão preventiva, porém contravenção não admite, pois não está dentro das hipóteses do art. 313 do CPP, nem no rol previsto para a prisão temporária (Lei 7.960/89).
- **quanto à possibilidade de confisco:** a lei prevê que é possível confisco de bens que sejam produtos de crimes, não havendo previsão neste sentido para as contravenções.
- **quanto à ignorância da lei:** no tocante às contravenções penais, no caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena poderá deixar de ser aplicada pelo magistrado (hipótese de perdão judicial). Todavia, no caso dos crimes, o Código Penal



estabelece que, quando há crime, o desconhecimento da lei é inescusável, funcionando, no máximo, como atenuante da pena.

3. SUJEITO ATIVO DO CRIME

Sujeito ativo do crime é qualquer pessoa que pratica uma infração penal, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica.

Para ser sujeito ativo, a **pessoa física** deverá ser **maior de 18 anos e capaz**.

3.1. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA JURÍDICA

No tocante à pessoa jurídica, existe uma discussão, porém **prevalece que a pessoa jurídica poderá cometer crime**, conforme o art. 225, §3º, da CF (as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas **ou jurídicas**, a sanções **penais** e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados).

A Lei 9.605/95 (Lei dos Crimes Ambientais) regulamenta essa matéria, ao dispor que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas **penalmente** conforme o disposto nesta Lei, desde que:

- a infração seja cometida por decisão de quem detinha poderes para tanto dentro da Pessoa Jurídica, ou seja, o seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado;

+

- a infração se dê no interesse ou benefício da sua entidade.

Com relação à pessoa jurídica, há algumas **correntes que divergem** sobre a possibilidade de punição:

1ª Corrente: pessoa jurídica não pode praticar crime. A empresa é uma ficção jurídica, sendo desprovida de consciência e vontade, não havendo que se falar em dolo.

2ª Corrente: entende que apenas pessoa física pode praticar crimes, mas, em se tratando de crimes ambientais, e havendo uma relação objetiva entre o autor do fato e a empresa (exemplo: quem cometeu o crime foi o seu representante legal), admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Neste caso, ela não comete o crime, mas poderá ser responsabilizada se houver esta relação objetiva entre o autor do ilícito e a pessoa jurídica.

3ª Corrente: entende que a pessoa jurídica é ente autônomo, distinto dos seus membros, e dotada de vontade própria, razão pela qual pode cometer crimes ambientais. Essa doutrina não ignora que a responsabilização da PJ está associada a uma pessoa física, pois esta age com elementos subjetivo: dolo e culpa. **ADOTADA!**

Todavia, o **STF decidiu que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, independe da responsabilidade penal da pessoa física**. Sendo assim, STF⁹ e STJ¹⁰ não adotam a teoria da dupla imputação, visto que afronta o art. 225, §3º, CF, pois acaba condicionando a punição da pessoa jurídica à punição da pessoa física, e isso não está previsto na CF ou legislação ordinária.

Por essa razão, é possível que os responsáveis pela empresa sejam absolvidos por inexigibilidade de conduta diversa, excluindo-se assim a culpabilidade dos agentes, mas a pessoa jurídica seja punida pelo ilícito.

⁹RE 548181, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013.

¹⁰RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015, DJe 13/8/2015.



3.2. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA JURÍDICA DISSOLVIDA

O que acontece se foi constatado um crime praticado por pessoa jurídica e, durante a apuração criminal ou processo criminal, essa pessoa jurídica foi dissolvida?

Aqui, há uma celeuma. Rogério Sanches: **não há óbice para continuidade** da apuração se a pessoa jurídica é dissolvida durante o processo criminal. **O que vai obstar a punição da pessoa jurídica é a sua liquidação.** Isso porque o art. 51 do Código Civil diz que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para o fim de liquidação até que essa se conclua. Portanto, até a liquidação ela subsistirá.

3.3. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Trata-se de outra controvérsia, havendo uma corrente dizendo que pode haver, mas outra corrente se posiciona no sentido da sua impossibilidade:

1ª Corrente: A corrente que entende pela impossibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público utiliza como argumento o fato de que **o Estado não pode ser delinquente**. Isso porque a finalidade do Estado é cumprir as leis, e, se não há o cumprimento, é porque a pessoa que estava na sua direção desviou-se da vontade do Estado. O outro argumento pela impossibilidade é o fato de que **o titular do ius puniendi é o próprio Estado**, não podendo ele aplicar pena a si mesmo. E o último fundamento é que, na verdade, **a reprimenda de uma punição penal ao Estado seria um ônus contra a própria sociedade**.

2ª Corrente: entende pela possibilidade da responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público. A uma, porque a CF e a Lei 9.605/95 não obstam a punição da pessoa jurídica de direito público, o argumento é que, em primeiro lugar, as normas que disciplinam **a responsabilidade penal da pessoa jurídica não excepcionam as pessoas jurídicas de direito público** e, portanto, se a lei não impõe barreiras, não cabe ao intérprete fazê-lo. A duas, porque o Estado, muitas vezes, se lança em atividades, por meio de pessoas jurídicas, inclusive para atuar na disputa do mercado com o setor privado, não havendo empecilhos para que essas pessoas venham a delinquir.

Para ser penalizada a pessoa jurídica de direito público, é necessário que sejam feitas algumas adequações às penas que ela pode receber. Os art. 21, 22 e 23 da Lei 9.605/95 tratam das sanções a que ficam sujeitas as pessoas jurídicas infratoras.

Algumas dessas sanções não poderiam ser aplicadas às pessoas jurídicas de direito público, como é o caso do art. 21, estabelecendo que as penas aplicáveis à pessoa jurídica seriam a multa, penas restritivas de direitos e a prestação de serviços à comunidade.

O art. 22 vai explicitar quais são estas **penas restritivas de direito**:

- suspensão parcial ou total de atividades;
- interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
- proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

Já o art. 23 vem especificar em que consiste a **prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica**:

- custeio de programas e de projetos ambientais;
- execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
- manutenção de espaços públicos;
- contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

No caso de um município cometer conduta que se enquadre como crime ambiental, se entendermos que a pessoa jurídica de direito público pode ser responsabilizada penalmente, **algumas penas serão incompatíveis, tais como as penas restritivas de direito**. Isso porque as atividades não podem ser suspensas, tampouco interditados os estabelecimentos, além de não ser possível proibir a contratação com o Poder Público.



Por outro lado, a **pena de multa** e a **prestação de serviços à comunidade** seriam, em tese, plenamente aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público.

Em suma, conclui-se que a **Lei 9.605/95 não obsta que a pessoa jurídica de direito público seja responsabilizada penalmente**. Este é o entendimento de Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado.

PROVA: as questões objetivas ainda se posicionam no sentido de inadmissibilidade da punição.

3.4. CRIME COMUM, CRIME PRÓPRIO E CRIME DE MÃO PRÓPRIA

O delito pode ser classificado como:

- **crime comum:** qualquer pessoa pode praticá-lo, não exigindo uma qualidade especial do agente. Admite coautoria. **Ex.:** furto, homicídio.
- **crime próprio:** exige-se uma qualidade pessoal do agente. Admite coautoria, ainda que ao coautor não ostente a qualidade especial, desde que saiba que seu comparsa ostenta (comunicação de circunstância e condição pessoal, que são elementares do tipo). **Ex.:** peculato.
- **crime de mão própria:** além da qualidade pessoal do agente, é necessário que o próprio agente execute o delito, de forma que somente ele poderá praticar o crime na condição de autor. **Ex.:** falso testemunho ou falsa perícia. No crime de mão própria, **admite-se participação**, mas coautoria não, excepcionalmente ocorreria na hipótese de dois peritos combinarem em assinar laudo falso.

4. SUJEITO PASSIVO DO CRIME

O sujeito passivo é a vítima do crime, quem sofre as consequências da infração penal, admitindo-se que seja qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, incluindo os entes sem personalidade jurídica.

Quando o crime for cometido contra esses entes sem personalidade jurídica, neste caso, o nome doutrinário será **crime vago**. **Ex.:** crimes contra a família, coletividade, etc.

4.1. ESPÉCIES DE SUJEITO PASSIVO

O sujeito passivo pode ser subdividido em:

- **sujeito passivo constante ou mediato:** será sempre o Estado, em razão da violação de uma norma estatal.
- **sujeito passivo imediato (casuístico, material ou eventual):** é o titular do interesse juridicamente protegido e que foi violado naquela situação em apreço.

4.2. CLASSIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

- **sujeito passivo próprio:** dependerá de uma exigência de uma qualidade especial do sujeito passivo. **Ex.:** infanticídio – recém-nascido.
- **sujeito passivo comum:** a vítima do crime pode ser qualquer pessoa.

Sendo o sujeito ativo e passivo comuns, o delito será classificado como **crime bi-comum**. Por outro lado, se ambos os sujeitos forem próprios, **o crime será bi-próprio**.

4.3. CRIME CONTRA O MORTO

PERGUNTA: Sendo o crime cometido contra os mortos, como a calúnia, quem será o sujeito passivo?

O morto não é titular de direitos. Se o delito é contra o respeito aos mortos, o sujeito passivo será a coletividade. Sendo uma calúnia contra o morto, o sujeito passivo será a sua família.



4.4. SIMULTANEIDADE DE SUJEIÇÃO ATIVA E PASSIVA

PERGUNTA: É possível que o indivíduo seja sujeito ativo e passivo do crime ao mesmo tempo?

Em regra, não será possível. Nem mesmo no caso de autolesão para obtenção de benefício de seguro será admissível. Neste caso, o sujeito passivo é a seguradora, pois é o seu patrimônio que é violado.

Na autoacusação falsa, a vítima é o Estado, e não a parte que faz essa autoacusação.

Contudo, na **rixa** há uma divergência. Isso porque, na rixa, os rixosos são sujeitos ativos nas condutas que realizam e sujeitos passivos quando sofrem as consequências dos outros participantes. Não é que ele é sujeito passivo e ativo ao mesmo tempo, e sim sujeito ativo das condutas que pratica e passivo das condutas praticadas contra ele.

Todavia, ainda no caso da rixa, **Rogério Greco entende que o crime de rixa seria uma exceção em que haveria uma pessoa sendo sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo.**

5. OBJETO JURÍDICO DO CRIME E OBJETO MATERIAL

5.1. OBJETO MATERIAL

É o resultado naturalístico alcançado pela infração penal, **é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta.** **Ex.:** no furto de um carro, o objeto material é o carro (objeto jurídico: o patrimônio). No homicídio de José, o objeto material é José (objeto jurídico: a vida).

PERGUNTA: Existe crime sem objeto material?

Sim, é o caso dos **crimes de mera conduta**. Nos **crimes omissivos puros ou próprios**, também não haveria objeto material. **Ex.:** porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003).

Por outro lado, **nos crimes materiais sempre há objeto material**. Isso porque a lei descreve uma conduta e um resultado naturalístico, o qual será indispensável para a consumação do delito.

5.2. OBJETO JURÍDICO

Todo crime tem objeto jurídico. Objeto jurídico é o **interesse tutelado pela norma**, é o bem jurídico em si. **Ex.:** no porte ilegal de arma de fogo o objeto jurídico é a incolumidade pública.

O crime pode ofender um bem jurídico (**crime mono-ofensivo**), mas também poderá ofender mais de um bem jurídico (**crime pluriofensivo**). **Ex.:** no furto, o bem jurídico violado é o patrimônio; no roubo, viola-se a liberdade e o patrimônio.

Anselm Von Feuerbach dizia que delito deveria ser concebido como uma violação a uma liberdade individual e não como mera violação à norma. Não obstante as críticas a elas direcionadas, as ideias de Feuerbach foram fundamentais para a posterior construção do conceito de bem jurídico, por J. M. F. Birnbaum.

Para Birnbaum, **o Direito Penal estaria materialmente limitado a intervir nas liberdades individuais apenas para pretender tutelar um determinado bem, individual ou coletivo, de relevante interesse para o indivíduo ou para a sociedade, respectivamente.**

Abandona-se, assim, a ideia de violação ao direito como legitimação à resposta penal, proposta por Feuerbach, numa transposição de bases normativas para bases naturalistas, daí porque alguns se referem a Birnbaum como um jus racionalista naturalista.

ATENÇÃO: nem todo o crime possui objeto material, porém, **todo o crime possui objeto jurídico**. Não é possível haver crime sem objeto jurídico, mesmo os crimes de mera conduta.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES

Estas classificações costumam cair em prova.



6.1. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO RESULTADO

A classificação que trata dos crimes materiais, formais e de mera conduta se refere ao **resultado naturalístico**:

- **crime material**: a norma descreve a conduta e o resultado naturalístico (modificação no mundo exterior), sendo imprescindível a ocorrência do resultado para a consumação do delito.
Ex.: homicídio.
- **crime formal (crime de consumação antecipada)**: o tipo descreve um resultado, mas a sua ocorrência é desnecessária para ocorrer a consumação, caso ocorra, ter-se-á mero exaurimento. **Ex.:** extorsão mediante sequestro, em que a vantagem indevida é mero exaurimento (este fator repercutirá na dosimetria da pena).
- **crime de mera conduta**: é aquele em que a norma descreve a conduta e não descreve o resultado naturalístico. O crime de mera conduta não possui objeto material, sendo o mero comportamento proibido.
Ex.: porte ilegal de arma de fogo (art. 12, Lei 10.826/2003).

6.2. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SUJEITO

O crime pode ser classificado como:

- **crime comum**: qualquer um pode cometer.
- **crime próprio**: exige uma qualidade especial do agente.
- **crime de mão própria**: exige a qualidade especial do agente e sua atuação pessoal.

6.3. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO ÂNIMO DO AGENTE

O crime pode ser classificado como:

- **crime doloso**: ocorre quando o agente quer o resultado (**dolo direto – teoria da vontade**) ou assume o risco de produzi-lo (**dolo eventual – teoria do assentimento**).
- **crime culposo**: ocorre quando o agente não quer o resultado, mas este é previsível, de modo que o agente age sem o dever objetivo de cuidado e causa o resultado. Neste caso, provocou o resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
- **crime preterdoloso**: é aquele que possui o dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Inicia a conduta dolosamente, mas o resultado mais grave é culposo. **Ex.:** lesão corporal seguida de morte.

6.4. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO

O crime pode ser classificado como:

- **crime instantâneo**: quando a consumação se dá em momento determinado. **Ex.:** roubo, que se dá com a inversão da posse do bem.
- **crime permanente**: é aquele cuja consumação se protraí no tempo. **Ex.:** extorsão mediante sequestro.
- **crime instantâneo de efeitos permanentes**: é aquele em que a consumação se dá em momento determinado, mas o efeito causado é irreversível. **Ex.:** homicídio, o sujeito mata e o sujeito não mais retorna; embaraço à investigação de organização criminosa (Lei 12.850/13); crime de dano, quando, por exemplo, o indivíduo coloca fogo em um quadro de Picasso.



6.5. CRIME CONSUMADO OU TENTADO

O crime pode ser classificado como:

- **crime consumado:** é o crime que preencheu todos os elementos do tipo. Não se confunde com o crime exaurido, em que após a consumação é praticado um novo ato. O exaurimento é relevante para fins de aplicação da pena.
- **crime tentado:** não se tem o preenchimento de todos os requisitos legais, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6.6. CRIME DE DANO OU CRIME DE PERIGO

O crime pode ser classificado como:

- **crime de dano:** há uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.
- **crime de perigo:** não há uma efetiva lesão ao bem jurídico, pois ele somente é colocado em risco. É possível ainda a sua subdivisão:
 - **crime de perigo concreto:** exige a demonstração de que o bem jurídico foi colocado em risco. **Ex.:** exposição da vida e da saúde de outrem a perigo (art. 132, do CP).
 - **crime de perigo abstrato ou presumido:** a própria lei presume absolutamente que aquela conduta é perigosa, dispensando a prova do perigo. **Ex.:** porte ilegal de arma de fogo.

6.7. CRIME SIMPLES, COMPLEXO, QUALIFICADO E PRIVILEGIADO

O crime pode ser classificado como:

- **crime simples:** é formado pelo tipo penal. É objetivamente aferido, bastando a leitura do *caput* da lei penal incriminadora.
- **crime complexo:** na descrição do crime, há a fusão de pelo menos dois tipos penais. Exemplo: o roubo é a soma do furto com o constrangimento ilegal.
- **crime ultra complexo:** tipo penal complexo + uma causa de aumento de pena ou de uma qualificadora.
Ex.: roubo praticado com emprego de arma de fogo. Neste caso, como o indivíduo porta a arma de fogo ilegalmente, poderia configurar o tipo autônomo do Estatuto do Desarmamento. Mas, no caso do crime de roubo, o que se tem é uma causa de aumento, aplicando-se o princípio da especialidade, respondendo por roubo, majorado pelo emprego da arma. Para evitar *bis in idem*, se o indivíduo utilizou a arma apenas para o crime de roubo, não responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Este é o entendimento do STJ e foi objeto de recente atuação legislativa.¹¹
- **crime qualificado:** é um crime que deriva do tipo penal básico ou complexo, derivando do *caput*, como regra. A qualificadora fixa novos patamares mínimo e máximo de pena.
- **crime privilegiado:** a reprimenda é abrandada. A lei considera que, em certas circunstâncias, a gravidade da conduta é menor, razão pela qual há um tipo penal com patamares menores do que o tipo penal básico.

¹¹ A Lei 13.654/2018 alterou o art. 157, do Código Penal, que passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 157 § 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;



6.8. CRIME PLURISSUBJETIVO OU UNISSUBJETIVO

O crime pode ser classificado como:

- **crime plurissubjetivo:** é o crime em que há uma pluralidade de sujeitos. É um **crime de concurso necessário**. **Ex.:** associação criminosa; promover ou integrar organização criminosa.

Neste caso, poderá ser de:

- **condutas paralelas:** quando todos pretendem alcançar um fim único. **Ex.:** associação criminosa (art. 288, CP).
 - **condutas divergentes:** quando os sujeitos dirigem suas ações uns contra os outros. **Ex.:** rixa (art. 137, CP).
 - **condutas bilaterais:** ocorre quando a conduta de um agente se encontra com a conduta de outro agente. **Ex.:** bigamia (art. 235, CP).
- **crime unissubjetivo:** ocorre quando não há exigência da pluralidade de sujeitos, basta uma única pessoa. Ressalte-se que é possível a prática do crime em concurso de pessoas. São os chamados **crimes de concurso eventual**. **Ex.:** homicídio, que pode ser praticado por uma ou várias pessoas.

6.9. CRIME OMISSIVO OU COMISSIVO

O crime pode ser classificado como:

- **Crime comissivo:** é a realização do crime por meio de uma **ação**. O indivíduo viola uma norma penal proibitiva. **Ex.:** é proibido matar e o indivíduo mata.
- **Crime omissivo:** o sujeito não faz o que devia ser feito; há a violação de um tipo mandamental. **Ex.:** a norma manda o indivíduo socorrer e ele não socorre. O crime omissivo se subdivide em:
 - **Crime omissivo próprio:** é um não fazer que caracteriza o crime omissivo próprio, somado à situação em que o indivíduo devia e podia agir. A norma mandamental do crime omissivo decorre do próprio tipo penal. **Ex.:** omissão de socorro (art. 135, CP).
É possível a participação por ação em crime omissivo próprio, ocorrendo quando o agente influencia (participação moral por induzimento) o autor a deixar de prover alimentos a vítima (art. 244, CP).
 - **Crime omissivo impróprio (impuro ou comissivo por omissão):** tem-se, em verdade, um crime comissivo, praticado por omissão; o sujeito tem o dever jurídico de evitar o resultado, é o chamado GARANTE (art. 13, § 2º, CP); a omissão decorre de uma cláusula geral, de um dever de agir que está descrito. Neste caso, não há uma descrição do tipo penal incriminador, de forma que o tipo descreve inclusive uma conduta comissiva, e não omissiva.
Ex.: mãe que, querendo matar o filho, deixa de amamentá-lo, levando-o à morte. Nesta situação, a mãe praticou o crime na forma omissiva, denominando-se de crime omissivo impróprio, impuro ou comissivo por omissão.
Admite-se a participação por ação em crime omissivo impróprio. Isso ocorre quando o agente induz (participação moral por induzimento) a mãe a matar o próprio filho por inanição (art. 13, § 2º, alínea 'a', c/c art. 29, ambos do CP).
 - **Crime omissivo por comissão:** é aquele crime em que a pessoa atua para que outras se omitam em relação à situação em que deveriam agir; a pessoa deveria agir, mas ela é impedida por alguém.
Ex.: médico tem a obrigação legal de atender a pessoa em situação de emergência. Todavia, um desafeto do paciente tranca o médico na sala e impede que ele atue para salvar a pessoa. Neste caso, morrendo o sujeito, o médico não terá agido, havendo o



crime de homicídio do desafeto por meio omissivo por comissão. O médico não responde.

ATENÇÃO: crime omissivo, via de regra, não se admite a tentativa; não há que falar em resultado naturalístico. Mas se o crime é omissivo por comissão, é plenamente possível a tentativa, bastando pensar na hipótese em que o médico consegue quebrar a porta, sair e atender o paciente. Neste caso, o desafeto tentou matar a vítima trancando o médico na sala.

Há ainda o crime de conduta mista, em que há uma ação comissão seguida de uma omissão.

Ex.: apropriação de coisa achada (art. 169, II, CP). Primeiro, o indivíduo acha a coisa (ação). Em seguida, ele não devolve a coisa à autoridade competente passados 15 dias (omissão).

6.10. CRIME UNISSUBSISTENTE OU PLURISSUBSISTENTE

O crime pode ser classificado como:

- **crime unissubsistente:** é o crime cometido por apenas uma conduta. Não se admite o fracionamento da conduta. Neste caso, **não haverá tentativa**.
Ex.: injúria verbal, pois, sendo escrita, poderá haver a interceptação da carta e configurar tentativa.
- **crime plurissubsistente:** a conduta poderá ser fracionada, e, se pode ser fracionada, **é possível a tentativa**. **Ex.:** homicídio, furto, roubo etc.

6.11. CRIME HABITUAL

O crime habitual é aquele em que se exige uma **reiteração de atos** para fins de consumação.

Ex.: art. 229 do CP, que tipifica a manutenção de estabelecimento em que ocorra a exploração sexual. Não basta a exploração sexual, devendo haver a manutenção do estabelecimento, o que preceitua a habitualidade; exercício ilegal da medicina.

6.12. CRIME EXAURIDO

Crime exaurido é aquele que já se consumou, mas ocorreu o resultado agravador; contempla os atos posteriores à consumação. **Ex.:** obtenção do resgate (delito de resultado cortado) no crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, CP); o pagamento do resgate é considerado mero exaurimento.

6.13. CRIME DE AÇÃO ÚNICA OU CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA

- **crime de ação única:** há apenas uma conduta descrita como possível. **Ex.:** no furto, só é descrita a subtração, ainda que possa ser fracionada a conduta.
- **crime de ação múltipla (tipo penal misto):** ocorre quando há diversas formas de conduta descrita pelo tipo penal. **Ex.:** tráfico de drogas (vender, trazer consigo, ter em depósito, oferecer a venda, etc.).
 - **tipo penal misto alternativo:** a prática de uma ou mais condutas implicará, no mesmo contexto fático, crime único. **Ex.:** quem traz consigo e, em seguida, vende a droga, pratica um crime de tráfico; estupro.
 - tipo penal misto cumulativo:** as condutas praticadas são consideradas autonomamente, ainda que descritas no mesmo tipo penal, de forma que se o sujeito incorrer em mais de um verbo, irá responder por tantos crimes quantos forem os núcleos praticados. **Ex.:** art. 242 do CP – Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido).



ATENÇÃO: A Lei 12.015/2009 alterou o CP, passando o crime de estupro a abarcar a conduta que antes era de atentado violento ao pudor. É estupro a prática de constrangimento a uma conjunção carnal, bem como de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

O sujeito que, no mesmo contexto, constrange a mulher à conjunção carnal e a sexo oral, pratica um ou dois delitos?

A priori, estabeleceu-se o entendimento de que se tratava de tipo penal misto cumulativo. Posteriormente, sedimentou-se o entendimento de que trata-se de tipo penal misto alternativo, havendo, portanto, **crime único**. Houve uma *novatio legis in melius*.

6.14. CRIME FALHO E QUASE-CRIME

- **crime falho:** é sinônimo de **tentativa perfeita, tentativa acabada**. O sujeito praticou todos os atos da execução, mas não conseguiu consumir o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
- **quase-crime:** não há crime, o que há é um crime impossível, por impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio.

6.15. CRIME DE ATENTADO

No crime de atentado, a lei atribui responsabilidade penal ao crime tentado idêntica ao crime consumado. **Ex.:** evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou pessoa submetida a medida de segurança por meio de violência à pessoa; pune-se a evasão e a tentativa de evasão da mesma forma.

6.16. CRIME DE RESULTADO CORTADO E CRIME MUTILADO DE DOIS ATOS

Nos chamados delitos de intenção, o agente tem o intento. A doutrina vai chamar isso de delito de tendência interna transcendente, pois há um especial fim de agir, subdividindo-se em:

- **crime de resultado cortado (ou de resultado separado):** o sujeito pratica o ato, chega à consumação do seu delito, mas quer que outro ato seja praticado. Ocorre que este segundo ato não é praticado por ele. Por isso, o resultado que ele deseja, que é dispensado da consumação, não depende do agente, pois está fora de sua atuação.
Ex.: extorsão mediante sequestro (art. 159, CP). O sujeito promove o sequestro, e por meio da extorsão exige a vantagem indevida (1º ato). Todavia, quem paga o resgate é um terceiro (2º ato), não cabendo ao agente a realização deste segundo ato, razão pela qual o delito já se consuma com o 1º ato.
- **crime mutilado de dois atos:** o sujeito também consuma o crime no 1º ato, mas o 2º ato, que também é dispensado para consumação do crime, depende de uma ação do agente, estando em sua esfera de decisão.
Ex.: crime de petrechos para falsificação de moedas. O sujeito possui os petrechos para promover a falsificação, razão pela qual já está consumado o delito. Se ele vai falsificar ou não moeda ou colocá-la em circulação, não interessa, pois o delito já está consumado. Como se vê, este 2º ato depende somente do agente, havendo, em virtude disso, dois atos. É mutilado em razão da consumação do delito com a prática do 1º ato, mas de 2 atos do próprio agente.

6.17. DELITO DE TENDÊNCIA INTERNA TRANSCENDENTE

O delito de tendência interna transcendente é o chamado **delito de intenção**. Neste crime, o sujeito ativo quer alcançar o resultado (delito de resultado cortado), o segundo ato não depende do agente, e, no mutilado de dois atos, o segundo ato depende do agente. Mas em ambos os casos, o



resultado (2º ato), seja por um terceiro ou pelo próprio agente, é dispensado para haver a consumação do crime.

Ou seja, o delito de intenção é composto:

- por um dolo;
- por um elemento subjetivo especial, que é a finalidade transcendente ou especial fim de agir.¹²

6.18. CRIME DE ACUMULAÇÃO

No crime de acumulação, o legislador, ao criar alguns tipos penais, busca **proteger interesses supraindividuais**.

Nos crimes contra o meio ambiente, uma conduta considerada isoladamente pode configurar uma repressão desproporcional.

Ex.: é proibido pescar em determinado período em certa localidade. Se alguém for encontrado pescando dez peixes, nos parece desproporcional que este indivíduo tenha cometido um crime. Contudo, nos chamados delitos cumulativos, é necessário entender que, se diversas pessoas começarem a pescar peixes, haverá um desequilíbrio ambiental significativo na região. Com isso, o delito de acumulação traz ao intérprete a necessidade de analisar o fato sob esta vertente, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.¹³

STF e STJ entendem ser possível a aplicação do princípio da insignificância, mas com a devida cautela, haja vista se tratar de direito fundamental de terceira geração.

6.19. CRIME DE RUA OU CRIME DE COLARINHO AZUL

Os **crimes de colarinho branco** são os crimes cometidos na órbita econômica, como a lavagem de dinheiro, praticado por quem, normalmente, teria condições de viver adequadamente sem o cometimento de crimes.

Os **crimes de rua ou crimes de colarinho azul**, fazendo um contraponto aos crimes de colarinho branco, são aqueles praticados por pessoas economicamente menos favorecidas, em situações de vulnerabilidade. O nome é uma alusão aos operários norte-americanos do final do século XX, denominados *blue collars*.

6.20. CRIME DE OLVIDO

Crime de olvido é sinônimo de **crimes de esquecimento**, é o crime cometido porque o sujeito esqueceu de praticar uma conduta. São crimes omissivos impróprios, ou crimes de espúrio, ou crimes comissivos por omissão, de natureza culposa (por imprudência, negligência ou imperícia), é a culpa inconsciente ou sem previsão, o agente não prevê o resultado que era previsível no caso concreto.

Ex.: Pai que esquece o filho recém-nascido dentro do carro, causando-lhe a morte.

6.21. QUANTO À EXISTÊNCIA AUTÔNOMA DO CRIME

- **crimes principais:** aqueles que possuem existência autônoma, independendo da prática de crime anterior. **Ex.:** estupro (art. 213, CP).
- **crimes acessórios, de fusão ou parasitários:** dependem da prática de crime anterior para a sua existência. **Ex.:** receptação (art. 180, CP) e lavagem de capitais (Lei 9.613/1998).

¹³HC 137652. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/08/2017.



6.22. QUANTO À NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMO PROVA

- **crime transeunte ou de fato transitório:** são aqueles que não deixam vestígios materiais. **Ex.:** injúria verbal, ameaça, calúnia, desacato. Nesse caso, não se realiza perícia.
- **crime não transeunte ou de fato permanente:** deixam vestígios materiais. **Ex.:** homicídio. Nesse caso, a falta de exame de corpo de delito é imprescindível, acarretando a nulidade da ação penal.

6.23. QUANTO AO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE OS CRIMES

- **crimes independentes:** não apresentam nenhuma ligação com outros delitos.
- **crimes conexos:** ocorre uma ligação dos delitos entre si. Essa conexão pode ser penal ou processual. A conexão penal, que nos interessa, divide-se em:
 - **conexão teleológica ou ideológica:** o crime é praticado para assegurar a execução de outro delito.
 - **conexão consequencial ou causal:** o crime é praticado na sequência de outro, para assegurar a impunidade, ocultação ou vantagem de outro delito.
 - **conexão ocasional:** o crime é praticado como consequência da ocasião, proporcionada pela prática do crime antecedente. **Ex.:** estupro praticado após o roubo. Trata-se de criação doutrinária, sem amparo legal.

Observe que as duas primeiras (teleológica e consequencial) possuem previsão legal no art. 61, servindo como agravantes dos crimes, salvo no caso de homicídio em que servirão como qualificadoras.

6.24. QUANTO À LIBERDADE PARA INICIAR A AÇÃO PENAL

- **Crimes incondicionados:** a instauração da persecução penal é livre, podendo o Estado iniciá-la sem nenhuma autorização. Não havendo menção expressa a respeito, aplica-se a regra geral de crime incondicionado, ou seja, **a ação penal será pública incondicionada.**
- **Crimes condicionados:** a inauguração da persecução penal depende de representação da vítima ou do CADI (cônjuge, ascendente, descendente ou irmão) ou de requisição do Ministro da Justiça; trata-se de uma condição objetiva de procedibilidade. A legislação expressamente indica essa hipótese.

6.25. OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

- **crime gratuito:** é o crime praticado **sem motivo conhecido**. Não se confunde com motivo fútil, pois neste há motivação, porém, desproporcional ao crime praticado.
- **crime de ímpeto:** é o cometido **sem premeditação**, como decorrência da reação emocional repentina.
- **crime de circulação:** é o praticado em **veículo automotor**, a título de dolo ou culpa.
- **crime de opinião ou de palavra:** cometido com **excesso abusivo na manifestação do pensamento**, seja pela forma escrita ou verbal.
- **crime multitudinário:** é aquele **praticado pela multidão, em tumulto**. A lei não define o que seria multidão, assim, analisa-se o caso concreto. No direito canônico, exigiam-se, no mínimo, 40 pessoas.
- **crime internacional:** aquele que **o Brasil, por tratado ou convenção** devidamente incorporado ao ordenamento pátrio, **se comprometeu a punir**. **Ex.:** art. 231, CP (tráfico de pessoas).
- **crime de mera suspeita, sem ação ou mera posição:** o agente não realiza a conduta, mas é **punido pela suspeita** despertada em seu modo de agir. **Não encontrou amparo em nossa**



doutrina porque não há efetivamente uma ação, o que violaria o direito penal do fato (o sujeito seria punido pelo o que ele é e não pelo o que fez). De forma temerária, exemplifica-se a contravenção penal do art. 25 (posse de instrumento usual na prática de furto).

- **crime inominado:** é aquele que **ofende regra ética ou cultural** consagrada pelo Direito Penal, embora **não definido como infração penal**. Não é aceito por ferir o princípio da reserva legal.

crime profissional: é o crime habitual cometido com finalidade lucrativa. **Ex.:** rufianismo (art. 230,CP).

- **crime subsidiário:** é o que somente se verifica **se o fato não constituir crime mais grave**. **Ex.:** crime de dano (art. 163, CP). Nelson Hungria o chama de “**soldado de reserva**”.
- **crime de ação astuciosa:** é o praticado por meio de **fraude, engodo**. **Ex.:** estelionato (art. 171, CP).
- **crime putativo, imaginário ou erroneamente suposto:** aquele onde o agente acredita ter realmente praticado um crime, mas, na verdade, houve um **indiferente penal**. Trata-se de um não-crime por **erro** de tipo, erro de proibição ou por obra de agente provocador.
- **crime remetido:** é o que se verifica quando o **tipo penal faz referência a outro crime**, que passa a integrá-lo. **Ex.:** fazer uso de documento falso (art. 304, CP).
- **crime de responsabilidade:** dividem-se em **próprios** (crimes comuns ou especiais) e **impróprios** (infrações administrativas), que redundam em **sanções políticas**.
- **crime obstáculo:** é aquele que retrata **atos preparatórios**, mas que foram tipificados como crimes autônomos pelo legislador. **Ex.:** associação criminosa (art. 288, CP).
- **crime de impressão:** são aqueles que provocam determinado estado de ânimo, **de impressão na vítima**. Subdividem-se em:
 - **crimes de inteligência:** praticados mediante o engano;
 - **crimes de vontade:** recaem na vontade da vítima quanto à sua autodeterminação;
 - **crimes de sentimento:** incidem nas faculdades emocionais da vítima.
- **crimes militares:** são os tipificados pelo Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/1969). Subdividem-se em:
 - **próprios:** exclusivamente militares, ex.: deserção.
 - **impróprios:** previstos tanto no CPM quanto no CP, ex.: furto.
 - **crimes militares em tempo de paz:** previstos no art. 9º do CPM.
 - **crimes militares em tempo de guerra:** previstos no art. 10 do CPM.
- **crimes falimentares:** são os tipificados pela Lei de falências (Lei 11.101/2005).
- **crimes funcionais ou delicta in officio:** são aqueles que o tipo penal exige seja o autor funcionário público. Dividem-se em:
 - **próprios:** cuja condição funcional é indispensável para a tipicidade do ato;
 - **impróprios:** se ausente a qualificação funcional, desclassifica-se para outro delito. **Ex.:** Peculato furto
- **crimes funcionais típicos e atípicos:** o STF entende que somente os crimes funcionais típicos (sejam eles próprios ou impróprios) seriam processados por meio do procedimento especial de apuração da responsabilidade dos funcionários públicos (existência de defesa prévia). Dividem-se em:
 - **típicos:** são aqueles nos quais o tipo penal exige que a conduta seja praticada por funcionário público. **Ex.:** prevaricação. São os crimes previstos nos arts. 312 a 326 do CP e no art. 3º da Lei 8.137/90.
 - **atípicos:** praticados por funcionário público em razão de suas funções, mas que poderiam ter sido praticados por um particular.
Ex.: art. 90 da Lei de Licitações:

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem,



vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

7. SUBSTRATOS DO CRIME

No conceito analítico de crime, prevalece o conceito tripartite: crime é **fato típico, ilícito e culpável**.



CAPÍTULO 11 — TEORIA GERAL DO CRIME: FATO TÍPICO

1. CONCEITO E ELEMENTOS DO FATO TÍPICO

O fato típico é uma **ação ou omissão humana que se adequa a um modelo descrito em uma norma penal incriminadora**. Há uma subsunção de um fato a uma norma penal incriminadora.

São elementos do fato típico:

- conduta
- resultado
- nexa causal
- tipicidade

2. CONDOTA

O conceito de conduta varia conforme a teoria adotada.

2.1. TEORIAS DA CONDOTA

- teoria causalista;
- teoria neokantista;
- teoria finalista.

2.1.1. TEORIA CAUSALISTA (NATURAL)

Para a teoria causalista, conduta é um movimento corporal voluntário que modifica o mundo exterior, passível de ser percebida pelos sentidos. Não se analisa culpa ou dolo. Foi idealizada por Von Liszt, Belling e Radbruch.

Quando falam em movimento, explicam o crime comissivo, mas falham no crime omissivo.

A vontade é composta por um **aspecto externo** (movimento corporal do agente) e um **aspecto interno** (vontade de fazer ou não fazer), porém a vontade do sujeito não está relacionada à sua finalidade, a qual será analisada apenas na culpabilidade. Por isso, na teoria causalista, o dolo será analisado na culpabilidade, e não no fato típico como elemento da conduta.

Será percebido que a teoria causalista é obrigatoriamente tripartite, eis que o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Do contrário, haveria responsabilização objetiva.

A culpabilidade para os causalistas é composta por dois elementos:

- imputabilidade;
- culpabilidade dolosa/culposa (espécies)

A antijuridicidade ou ilicitude, para os causalistas, só é analisada formalmente, bastando que esteja ou não presente uma causa excludente.

São críticas feitas pela doutrina em relação ao causalismo:

- não explicação dos crimes omissivos e crimes de mera conduta, pois o resultado naturalístico deveria ser perceptível pelos sentidos.
- deixar para analisar o dolo e a culpa na culpabilidade, inviabiliza a possibilidade de distinguir a finalidade do agente, ou seja, dificulta a análise do crime cometido. Exemplo disso é o caso da lesão corporal grave ou tentativa de homicídio diante de um caso concreto.
- não há conduta humana desprovida de finalidade.

Além disso, nesta teoria, o **tipo normal** é aquele que contém elementos objetivos, enquanto o **tipo anormal** contém, além dos objetivos, elementos subjetivos e normativos.



2.1.2. TEORIA NEOKANTISTA (NEOCLÁSSICA)

Tem base causalista, idealizada por Edmund Mezger.

Segundo esta teoria, a conduta é elemento do fato típico, mas passa a abranger não só a ação, como também a omissão. Isto é, **a conduta passa a ser um comportamento humano voluntário**.

Com isso, admite-se a valoração no tipo penal, passando a não mais ser composto apenas por elementos objetivos, mas também por elementos subjetivos e normativos. A existência de tais elementos do tipo penal passa a ser considerada como normal.

No âmbito da antijuricidade há uma modificação, passando a ter um aspecto material. Ou seja, para os neokantistas, **se não há lesão ao bem, não há antijuricidade**.

Na culpabilidade, a teoria neokantista desenvolve a **teoria psicológico-normativa**, ou seja, o dolo e a culpa continuam na culpabilidade, mas não mais como espécies, e sim como elementos, ao lado da imputabilidade e da exigibilidade de conduta diversa:

- imputabilidade;
- exigibilidade de conduta diversa;
- dolo ou culpa

Dolo deixa de ser apenas a vontade de fazer, passando a ser também a vontade de fazer somado à consciência **atual** da ilicitude do que se faz. Veja, o dolo, por conta disso, será um **dolo normativo**, não sendo um dolo natural.

A culpabilidade não é mais apenas compreendida como um vínculo entre o agente e o resultado, mas sim como um juízo de censurabilidade, de reprovação, da conduta.

2.1.3. TEORIA FINALISTA

Hans Welzel vai desenvolver a teoria finalista. Segundo este autor, a conduta é um comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim.

O crime é realmente **fato típico, ilícito e culpável**, apesar de haver doutrina no Brasil aderindo a teoria bipartite, funcionando o crime como fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade o pressuposto de aplicação da pena.

A grande mudança da teoria finalista está na culpabilidade, pois os elementos de dolo ou culpa deixam a culpabilidade, migrando para o fato típico.

Portanto, o dolo passa a ser composto pela **consciência** (elemento cognitivo) e pela **vontade** (elemento volitivo).

EXEMPLO: João atravessa um viaduto a 50 km/h quando uma pessoa se atira. João atropela o indivíduo, que morre. A via permitia 80 km/h. Neste caso, João não pratica fato típico, eis que não houve dolo e culpa, não se podendo falar em homicídio, ainda que tenha havido o efeito morte.

O dolo, na teoria finalista, perde o seu elemento normativo (consciência atual da ilicitude), deixando de ser um dolo normativo para ser um **dolo natural**, que é, na verdade, essa vontade e consciência de praticar o ato. Trata-se do *dolus bonus*, que se contrapõe ao *dolus malus*, que é o dolo normativo.

Os finalistas, por retirarem o elemento psicológico da culpabilidade, adotarão a **teoria normativa pura da culpabilidade**. A culpabilidade passa a ser apenas um juízo de reprovação, possuindo os seguintes elementos:

- imputabilidade;
- potencial consciência da ilicitude
- exigibilidade de conduta diversa

Há uma crítica que se faz ao finalismo, porque, quando se diz que a ação do homem é dirigida a um fim, sendo necessário analisar este fim para saber qual foi o fato típico, é muito difícil explicar o delito culposos, pois, neste crime, o resultado alcançado não é o desejado, não havendo esta finalidade. A conduta culposa, normalmente, é orientada por um fim lícito, mas **a reprovação não recai sobre a finalidade, e sim**



sobre os meios que o sujeito elegeu para alcançar aquele fim. A imputação do crime culposos recai sobre os meios e não sobre a finalidade.

2.1.4. TEORIA SOCIAL DA AÇÃO

Essa teoria, desenvolvida por Johannes Wessels e Jescheck, não tinha como ideia substituir as demais, mas, tão somente, acrescentar a tendência social da ação.

Para esta teoria, **a conduta é um comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim socialmente reprovável.**

A crítica que recai sobre esta teoria é o fato de que não há no ordenamento jurídico uma previsão sobre o que seria fim social. Esta vagueza não transmite segurança jurídica.

2.1.5. TEORIAS FUNCIONALISTAS

PERGUNTA: Qual é a função do direito penal e qual a sua finalidade?

Duas principais correntes se destacam:

- funcionalismo moderado (teleológico);
- funcionalismo radical (sistêmico).

A) FUNCIONALISMO MODERADO (TELEOLÓGICO)

Para Claus Roxin, o funcionalismo moderado busca resgatar a função do direito penal, que, para ele, se destina à **proteção de bens jurídicos**. Se não há bem jurídico a ser tutelado, não deve haver a intervenção do direito penal.

O fato típico deve atuar de forma a tipificar fatos relevantes do ponto de vista material. A teoria do delito deve ser reconstruída a partir da política criminal. Ou seja, o funcionalismo é teleológico, a fim de se proteger os fatos realmente relevantes.

Conduta: **comportamento humano voluntário, causador de uma relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.**

Claus Roxin vai dizer que o crime é composto por três substratos:

- tipicidade;
- ilicitude;
- responsabilidade (reprovabilidade).

A culpabilidade funcionaria como limite funcional da pena (**culpabilidade funcional**).

A responsabilidade, como terceiro elemento do substrato do crime, seria composta por 4 elementos:

- imputabilidade;
- potencial consciência da ilicitude;
- exigibilidade de conduta diversa;
- necessidade da pena.

Como se vê, se a pena não atingir o seu fim, não haverá responsabilidade do agente e consequentemente não haveria crime. Eis o critério teleológico.

No Brasil, **não foi adotado** o conceito de conduta do funcionalismo teleológico.

B) FUNCIONALISMO RADICAL (SISTÊMICO)

Segundo Günther Jakobs, se a norma é frustrada pelo agente, é imprescindível que ele seja sancionado. Isso porque o sistema está em vigor, e **a função do direito penal é assegurar a higidez do sistema**, ainda que indivíduos o violem.



Conduta, portanto, é um **comportamento humano voluntário, causador de um resultado evitável que ocasiona a violação do sistema.**

Jakobs vai dizer que **culpabilidade faz parte do substrato** do crime. Ademais, a culpabilidade seria formada pelos elementos tradicionais:

- imputabilidade;
- potencial consciência da ilicitude;
- exigibilidade de conduta diversa.

Perceba que a ideia do funcionalismo sistêmico, que é a proteção do sistema, permitirá a exumação do direito penal do inimigo, pois, desde Thomas Hobbes e São Tomás de Aquino, há a preocupação de combater esse indivíduo que decide desobedecer às normas vigentes.

Jakobs entende que o indivíduo que recorrentemente se utiliza de violações constantes da norma penal deve receber um **sistema próprio de tratamento**, devendo ser tratado com mais rigor, pois o indivíduo abriu mão de ser cidadão, razão pela qual deve recair sobre ele o **direito penal do inimigo**. Ou seja, **esse inimigo não é cidadão**, perdendo o tratamento fundado nas garantias e direitos individuais, tendo em vista que seu comportamento compromete o tratamento do sistema em relação aos demais cidadãos. Esta teoria se funda na teoria do contrato social de Rousseau.

As principais **características do direito penal do inimigo** são:

- **antecipação da punibilidade com a tipificação de atos preparatórios.** Ex.: associação criminosa;
- **crimes de mera conduta e de perigo abstrato.** Aqui há a flexibilização do princípio da ofensividade. O perigo da conduta é absolutamente presumido pela norma. Ex.: porte ilegal de arma de fogo;
- **descrição vaga de crimes e de penas.** Há uma flexibilização do princípio da legalidade;
- **preponderância do direito penal do autor.** A preocupação é com o inimigo da sociedade, e não com o que ele fez ou faz. É uma contraposição ao direito penal do fato, sendo uma flexibilização do princípio da exteriorização do fato, pois retira os olhos do fato e se direciona ao autor;
- **surgem as chamadas leis de luta e de combate.** É preciso criar leis rigorosas para combater o inimigo, gerando uma falsa sensação de tranquilidade;
- **recrudescimento da execução penal.** É a dificuldade para progressão de regime, como ocorre nos casos de crimes hediondos, os quais necessitam de 2/5 e 3/5 de cumprimento da pena;
- **restrições de direitos e garantias fundamentais.** É característica clássica de direito penal de 3ª velocidade (professora Jesus Maria Silvia Sanchez), que flexibiliza garantias e aplica pena privativa de liberdade.

2.1.6. TEORIA ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL

O CP adota a teoria finalista. O CP Militar adota a teoria causalista, e coloca dolo e culpa como elementos da culpabilidade (art. 33, CPM).

2.1.7. TEORIA DA AÇÃO SIGNIFICATIVA

A teoria da ação significativa **propõe uma nova análise do conceito de conduta**. Para esta teoria, haverá uma ação a partir do significado que se dá aquilo que as pessoas fazem, e não simplesmente uma ação com base naquilo que as pessoas fazem.

Havendo uma conduta, poderá ela até mesmo ter uma aparência de ação, e, a partir desse momento, será necessário buscar o seu significado.

Segundo a teoria da ação significativa, **a ação só existe em razão da norma**. Então, quando dizemos que matar alguém é homicídio, significa dizer que *matar alguém* só é homicídio porque uma norma



precedeu esta conduta. Por conta disso, **só existe ação em razão da norma, isto é, se não houvesse ação, não haveria significado para aquela ação.**

EXEMPLO: crimes cibernéticos não tinham significado, eis que não eram crimes, sendo indiferentes penais. Hoje, no entanto, possuem significado de crime. Com isso, a norma criou o significado para ação. Daí a ideia de que só existe ação com a instituição de normas. Ou seja, a norma define o que nós entendemos socialmente como uma ação. **A partir da norma é que teremos uma ação.** A subtração de coisa alheia móvel só tem significado porque uma norma diz que é crime e que isto configura o furto.

2.2. ELEMENTOS DA CONDUTA

A conduta tem como elementos:

- **comportamento voluntário psiquicamente dirigido a um fim**
- **exteriorização da vontade**

A partir desses elementos, se não houve qualquer deles, não haverá conduta e, por essa razão, não haverá crime.

2.3. CAUSAS DE EXCLUSÃO DA CONDUTA

São causas de exclusão da conduta:

- **caso fortuito ou força maior:** a doutrina diverge, mas são conceituados como eventos imprevisíveis ou impossíveis de se evitar ou de se impedir.
- **estado de inconsciência completa:** trata-se de uma involuntariedade do agente;
- **movimentos reflexos:** também é o caso de involuntariedade do agente, que ocorrerá quando o sujeito age por meio de reações automáticas. **Não se confunde com as ações em curto-circuito,** pois nestas hipóteses o agente age impulsivamente, dotado de dolo e vontade, sabendo o que faz.
- **coação física irresistível:** neste caso, não haverá conduta, pois foi empregado contra o sujeito a *vis absoluta*, sendo impossibilitado de exercer seus movimentos.

2.4. FORMAS DE CONDUTA

- **dolosa**
- **culposa**
- **preterdolosa**

Também poderá ser:

- **comissiva por ação**
- **comissiva por omissão**

2.4.1. CONDUTA DOLOSA

A conduta dolosa é praticada quando o agente **quis o resultado** ou **assumiu o risco de produzir o resultado**. A consciência é dirigida a realizar ou a aceitar a realização de uma conduta prevista no tipo penal incriminador.

Com relação ao dolo, há basicamente **três teorias**, mas já houve provas pedindo as demais:

- **Teoria da vontade:** dolo é a vontade consciente de praticar a infração penal. Para essa teoria, o dolo pressupõe a consciência (elemento intelectual), mas esta não basta, sendo imprescindível a vontade do agente em produzir o resultado (elemento volitivo). É a vontade de praticar a conduta e alcançar o resultado (dolo direto). É classificada como uma **teoria volitiva**.



- **Teoria da representação (teoria da possibilidade):** dolo está presente sempre que o agente tem a previsão do resultado como possível, e ainda assim continua a sua conduta. Basta, portanto, a presença do elemento intelectual (consciência) para sua caracterização. Para essa teoria, **a culpa é sempre inconsciente**, porque, sendo reconhecida a certeza, possibilidade ou probabilidade do resultado, haveria dolo, não sendo necessário analisar se o agente assumiu ou não sua produção do resultado. É, pois, uma **teoria intelectiva**.
- **Teoria do assentimento (teoria do consentimento ou teoria aprovação):** o agente tem a previsão do resultado como possível e ainda assim prossegue na sua conduta, assumindo o risco de produzir o resultado. Ou seja, **o dolo exige que o agente consinta em causar o resultado**, além de o considerar como possível. Para aplicação dessa teoria, Frank sugeriu a fórmula hipotética seguinte: diante da realização do tipo objetivo, o agente pensa: *“seja assim ou de outro modo, ocorra este ou outro resultado, em todo caso eu atuo”*. É uma **teoria volitiva**.
- **Teoria da probabilidade (teoria da cognição):** de acordo com esta teoria, distingue-se o dolo eventual segundo a probabilidade da realização do resultado representado pelo agente. Esta teoria traz dificuldades em conhecer o real elemento volitivo do agente. Haverá dolo eventual quando o agente prevê como provável o resultado, e não apenas como possível, admitindo ou não o resultado. Se a produção do resultado for pouco provável, haverá culpa consciente.
Ex.: “A” atira a longa distância em “B”, com o intuito de testar a eficácia do tiro da arma. Se “A” “B”, e, ainda assim, disparar e ocorrer o evento, significa que consentiu com o resultado, realizando o tipo com dolo eventual.
- **Teoria da evitabilidade:** segundo Juarez Cirino, a teoria da não-comprovada vontade de evitação do resultado (teoria da objetivação da vontade de evitação do resultado), desenvolvida por Armin Kaufmann em bases finalistas, coloca o dolo eventual e a imprudência consciente na dependência da ativação de contrafactores para evitar o resultado representado como possível: imprudência consciente se o autor ativa contrafactores, dolo eventual se não ativa contrafactores para evitação do resultado. Ou seja, **a teoria da evitabilidade, cognitiva, pressupõe a representação do resultado como possível, o que bastará para a caracterização do dolo eventual**. Contudo, se o agente busca evitar o resultado através da ativação de contrafactores, agindo concretamente, existirá culpa consciente.
- **Teoria do risco:** a existência do dolo depende do conhecimento pelo agente do risco indevido (tipificado) na realização de um comportamento ilícito. Teoria pertencente ao grupo das intelectivas.
- **Teoria do perigo a descoberto:** fundamenta-se apenas no tipo objetivo. Perigo descoberto vem a ser a situação na qual a ocorrência do resultado lesivo subordina-se à sorte ou ao acaso. Cirino afirma que essa teoria retira o elemento volitivo do conteúdo do dolo – *a principal característica da teoria da representação* – e fundamenta a distinção entre dolo eventual e imprudência consciente com base na natureza do perigo: o perigo desprotegido, caracterizado pela dependência de meros fatores de sorte-azar, configura dolo eventual, ainda que o autor confie na ausência do resultado, como jogar roleta russa (com risco de resultado na proporção de 1:5). É uma teoria intelectiva.
- **Teoria da indiferença ou do sentimento:** estabelece a distinção entre dolo eventual e culpa consciente por meio da disposição de ânimo ou da atitude subjetiva do agente ante a representação do resultado. Baseia-se na postura de indiferença diante da produção do resultado (dolo eventual), ou do alto grau de indiferença por parte do agente para com o bem jurídico ou a sua lesão. É uma teoria considerada **volitiva**.

O Código Penal adota a teoria da vontade para o dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual. Não se adota a teoria da representação para o dolo.

Em relação às **espécies**, o dolo pode ser:

- **dolo natural:** é o composto pelo elemento cognitivo e volitivo. É o adotado pela teoria finalista.



- **dolo normativo (híbrido):** traz a consciência atual da ilicitude (elemento normativo) juntamente com os elementos cognitivo e volitivo. Este dolo era integrante da culpabilidade, tornando-a psicológica-normativa. Adotado pela teoria neoclássica.
- **dolo direto:** agente prevê o resultado e atua para que este resultado seja alcançado;
- **dolo indireto:** o agente não busca um resultado certo e determinado. Há aqui duas formas de manifestação:
 - **dolo eventual:** sujeito age com indiferença penal, pois, com a sua conduta, assume o risco de produzir o resultado;
 - **dolo alternativo:** está presente quando há uma pluralidade de resultados e o sujeito dirige a sua conduta para alcançar qualquer uma delas, tendo a mesma intensidade de vontade entre elas. O indivíduo quer ferir ou matar. Neste caso, o agente será punido sempre pelo crime mais grave, respondendo em caso de ferimento por tentativa de homicídio.
- **dolo geral (erro sucessivo):** ocorre quando o agente, supondo que já tivesse alcançado o resultado com a sua primeira ação, pratica uma nova ação que efetivamente leva ao resultado almejado. **Ex.:** O sujeito atira na vítima e, pensando já estar morta, joga-a no rio, a qual vem a morrer por afogamento. Neste caso, o indivíduo responderá por homicídio.
- **dolo direto de 1º grau:** é o dolo direto, destinado a cometer uma conduta criminosa. **Ex.:** João quer matar José, e mata por meio de um disparo.
- **dolo direto de 2º grau:** há um dolo de consequências necessárias para alcançar um determinado resultado. Trata-se de um dolo de efeitos colaterais, eis que a sua conduta dirigida a atingir um resultado está diretamente ligada a outro resultado, vindo a atingir outros bens jurídicos. **Ex.:** João quer matar um presidente de um banco. Para tanto, João insere uma bomba no veículo da vítima, mas esta é conduzida por um motorista. Diante disso, João tem o dolo direto de 1º grau contra a vítima e dolo direto de 2º grau contra o motorista.
- **dolo direto de 3º grau:** é a consequência da consequência necessária. **Ex.:** No caso do presidente do banco, João sabe que a motorista do veículo estava grávida. Mesmo assim, comete o crime por meio do uso de uma bomba. Com essa conduta, João possui dolo direto de 1º grau contra o presidente do banco, dolo direto de 2º grau contra a motorista e dolo direto de 3º grau em face do feto.

A conduta dolosa pode ser dividida em duas fases:

- **fase interna**
- **fase externa**

A) FASE INTERNA

É a **fase do pensamento e da cogitação**. Esta fase é composta por:

- **representação ou antecipação do resultado.**
- **após, se desenvolve pelos meios eleitos para que aquela conduta seja praticada.**
- **avaliação dos efeitos colaterais decorrentes da conduta.**

Esta fase não é punível, eis que o pensamento é impunível.

B) FASE EXTERNA

Nesta fase, o sujeito ativo põe em prática aquilo que deliberou, surgindo somente aqui a relevância penal.



2.4.2. CONDOTA CULPOSA

Está previsto no art. 18, II, do CP. Segundo o dispositivo, a conduta voluntária, que realiza um evento ilícito não voluntário, mas que era previsível, pode implicar crime culposos.

O sujeito pratica uma conduta (conduta voluntária), mas não quer atingir o resultado (resultado involuntário). No entanto, se o resultado era previsível, e ele não previu, haverá **culpa inconsciente**. Por outro lado, sendo o resultado previsível e o agente previu, porém acreditou sinceramente que o resultado não ocorreria, haverá **culpa consciente**.

Nesses casos, para haver crime culposos, será necessário que o indivíduo não tenha tomado as cautelas nos **moldes do homem-médio** e, portanto, é preciso que tenha havido a **quebra de um dever objetivo de cuidado**, exteriorizado pela imprudência, negligência ou imperícia.

A culpa é tratada como um elemento normativo da conduta, estando inserida no fato típico.

Os **elementos estruturais do crime culposos** são:

- conduta humana voluntária;
- resultado involuntário;
- nexos de causalidade;
- tipicidade;
- violação de um dever objetivo de cuidado (homem-médio);
- previsibilidade objetiva;

São **modalidades** de culpa:

- **imprudência**: é uma forma positiva da culpa. Trata-se da culpa no agir. **FALTA DE CUIDADO + AÇÃO. Ex.:** Correr a 200km/h em uma via residencial.
- **negligência**: é a ausência de precaução. É negativa. É a omissão ou um não fazer aquilo que deveria ter feito. **FALTA DE CUIDADO + OMISSÃO. Ex.:** Sujeito que não fez a revisão do carro.
- **imperícia**: é falta de aptidão técnica para o exercício da arte ou da profissão. Na imperícia, o sujeito não tem aptidão técnica, não se confundido com o erro profissional, eis que, neste caso, o sujeito domina a arte e a profissão, mas a medicina não é uma ciência, razão pela qual, mesmo assim, o indivíduo pode morrer. No caso de erro profissional, não há que se falar em imperícia;

Obs.1: Ainda que o sujeito atue violando uma regra, não significa que ele praticou um crime culposos, sendo apenas um indício de que tenha agido culposamente. Pode ser que aquela infração ocorresse ainda que o indivíduo não tivesse quebrado o seu dever objetivo de cuidado. E, se isto ocorrer, não há que se falar em responsabilização culposos.

Por exemplo, o indivíduo pular de um viaduto, e um motorista passar por cima a 120 km/h, na via em que o máximo seria 80 km/h, vindo este a matar o indivíduo. A princípio, houve uma quebra do dever objetivo de cuidado. Contudo, é preciso analisar se, caso o motorista estivesse a 80 km/h, a morte poderia ter sido evitada, comprovadamente feito por perícia. Do contrário, não haverá responsabilização.

Por conta da necessidade de ocorrência do resultado naturalístico, como regra, os crimes culposos são classificados como **crimes materiais**.

No entanto, existem **exceções**, como é o caso do art. 38 da Lei de Drogas, que estabelece ser crime culposos a conduta de prescrever drogas sem que delas necessite o paciente. Este crime se consuma com a mera prescrição feita pelo médico ou dentista, ou seja, é um **crime de mera conduta**. Se o indivíduo usar a droga será mero exaurimento.

Obs.2: Em regra, os delitos culposos são **tipos penais abertos** que exigem uma valoração feita pelo magistrado. O código penal estabelece que **não se pune a conduta culposos, salvo se houver expressa disposição em lei neste sentido**.

São espécies de culpa:

- **culpa consciente**: o sujeito prevê o resultado previsível (resultado previsto), mas acredita sinceramente que ele não vá ocorrer, pois confia em sua habilidade.
- **culpa inconsciente**: o sujeito não prevê o resultado previsível.



- **culpa própria:** é o caso em que o indivíduo não quer o resultado, mas acaba dando causa por imprudência, negligência ou imperícia.
- **culpa imprópria (culpa por equiparação ou por assimilação):** o agente, por um erro evitável, imagina que se encontra numa situação de fato que, se existisse, levaria à ilicitude do seu comportamento. João vê um vulto dentro de casa e dispara, pensando ser um bandido, mas, na verdade, era sua filha retornando da festa que estaria proibida de frequentar. Neste caso, João matou porque quis, mas achou que agia em legítima defesa. Por conta disso, e em razão de política criminal, o ordenamento denominou esta situação de **descriminante putativa**, fazendo com que o sujeito, que agiu dolosamente, responda pelo crime culposo, se houver previsão legal. Na hipótese, não haveria isenção de pena, pois o erro seria evitável. Na hipótese de erro inevitável, o sujeito seria isento de pena, ainda que a discriminação seja putativa. Ademais, em razão de o indivíduo cometer a conduta, em verdade, de forma dolosa, caberá tentativa, caso sua conduta não tenha sido consumada, hipótese de excepcional possibilidade da denominada tentativa de crime culposo. Ou seja, **culpa imprópria admite a tentativa**.

São **questões divergentes** que a doutrina e a jurisprudência debatem:

- **crime de racha:** o STJ estabelece que no crime de racha há dolo eventual, caso atinja alguém. Por outro lado, houve uma alteração legislativa, estabelecendo uma nova redação para o art. 308 do CTB. Esta lei acrescentou dois parágrafos, um para a lesão corporal grave e outro para a morte decorrentes do crime de racha. Nessas hipóteses, o delito será qualificado. Todavia, o dispositivo destaca que as penas são aplicadas apenas se as circunstâncias indicarem que o indivíduo não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, o indivíduo teria agido com culpa. Todavia, **o STJ entende que, se há um resultado lesivo no crime de racha, o dolo é eventual**. Ocorre que, hoje, pela lei, se houver a lesão grave ou a morte, o delito passará para um patamar mais elevado, por conta da qualificação, mas neste caso a qualificadora será pela culpa, e não pelo dolo eventual. Em suma, pelo STJ é dolo eventual, mas pela leitura da lei a ocorrência de lesão corporal grave ou a morte no racha qualifica o delito, desde que o sujeito não tenha querido o resultado nem assumido o risco de produzi-lo.
- **atropelamento por conta da embriaguez:** os Tribunais Superiores, majoritariamente, entendem que o crime cometido na condução de veículo automotor sob o efeito de álcool é crime culposo por **culpa consciente**, e não dolo eventual, pois o indivíduo confia nas suas habilidades para não cometer o resultado previsto.
- **compensação de culpas:** não cabe compensação de culpas no direito penal. O máximo que poderá ocorrer é que se, houver culpa concorrente da vítima, haverá uma atenuação da pena, pois o art. 59 do CP coloca entre as circunstâncias judiciais o comportamento da vítima. Isto é, se o comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito, a pena-base poderá ser fixada no mínimo legal.
- **concorrência de culpas:** dá-se quando dois ou mais agentes culposamente contribuem para a eclosão de um resultado naturalístico. Todos respondem pelo evento danoso, por conta da *conditio sine qua non*. Perceba que dois agentes contribuirão para um resultado, mas não há entre eles o liame psicológico. Ou seja, não há concurso de pessoas.

São hipóteses de **exclusão da culpa**:

- **caso fortuito e força maior:** eventos imprevisíveis e impossíveis de se evitar ou de se impedir excluem a culpa.
- **princípio da confiança:** o indivíduo que pratica condutas de acordo com as regras do ordenamento jurídico e da sociedade presume que as demais pessoas também sigam estas regras. Isto é, aquele que segue o dever objetivo de cuidado de acordo com as normas, não poderá violar estes deveres objetivos de cuidado, não respondendo pelo eventual resultado lesivo que tenha causado voluntariamente.
- **erro profissional:** poderá ser gerado por uma falibilidade dos métodos científicos. O agente é apto a realizar o procedimento, porém naquela situação não se mostrou suficiente. Nesta



situação, não há que se falar em falha humana, ou em imperícia. Isso porque o indivíduo sabe o que está fazendo. Por exemplo, o médico pensa que ministrando um remédio ao paciente ele irá se curar, porém não se curou e morreu. Na época, não dava para saber que se tivesse ministrado o outro remédio o indivíduo estaria curado. Não havia evolução da medicina na época para aferir isso.

- **risco tolerado:** o comportamento humano e a própria vida em sociedade implica risco. E, na verdade, se não tolerarmos certos risco, não haverá como conviver em sociedade. Mesmo para a evolução da ciência, é necessário que se admita testes em humanos, por exemplo, ainda que haja riscos.

2.4.3. CONDUTA PRETERDOLOSA

No crime preterdoloso, há uma figura criminosa **híbrida**, pois há **dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente**. O sujeito dolosamente pratica uma conduta criminosa, mas ele dá causa ao resultado agravador de maneira culposa.

O exemplo clássico é homicídio preterdoloso, que na verdade consubstancia-se no crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, CP). Outro exemplo é o do aborto qualificado, em que ocorre a morte da gestante (art. 127, CP).

Os elementos do crime preterdoloso são:

- conduta dolosa
- resultado mais grave, causado culposamente, mas previsível
- nexos causal entre a conduta dolosa e o resultado culposos
- tipicidade

Se o sujeito pratica crime preterdoloso, neste caso, para fins de reincidência, **o indivíduo será considerado reincidente em crime doloso**. Isso porque ele já tinha o dolo de praticar o crime menos grave, tendo atingido inclusive esta finalidade. Todavia, ele ultrapassa essa finalidade, atingindo um resultado culposos ainda mais grave. Esta conduta é ainda pior do que a conduta inicialmente praticada dolosamente. Ou seja, não poderá o indivíduo ser tratado de modo mais benéfico do que seria se não tivesse cometido o resultado culposamente agravador.

O fato do sujeito ser reincidente em crime doloso tem repercussão, por exemplo, não caberá a suspensão condicional da pena. Isto é, devido a configuração do crime preterdoloso como crime doloso para fins de reincidência, haverá certas consequências, como o sursis, pois o art. 77 do CP exige que o indivíduo que esteja sendo beneficiado com a suspensão condicional da pena não seja reincidente em crime doloso.

2.5. ERROS DE TIPO¹⁴

O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime **exclui o dolo e a culpa**, se invencível (escusável, desculpável, inevitável).

Sendo vencível (inescusável, injustificável, evitável), **exclui apenas o dolo, mas persiste a conduta culposa**, se previsto em lei, conforme aduz o art. 20, CP. Um dos elementos do crime culposos é também a tipicidade.

EXEMPLOS: Quando a agente toma coisa alheia como própria; relaciona-se sexualmente com vítima menor de 14 anos, supondo-a maior; contrai casamento com pessoa já casada, desconhecendo o matrimônio anterior; apossa-se de coisa alheia, acreditando tratar-se de *res nullius*; atira em alguém imaginando ser um

¹⁴É aquele que recai sobre as elementares, circunstâncias ou qualquer dado que se agregue à determinada figura típica, ou ainda aquele, incidente sobre os “pressupostos de fato de uma causa de justificação ou dados secundários da norma penal incriminadora. (GREGO, Rogério. *Curso de Direito Penal Parte Geral*. 19ª ed. Impetus. 2017).



animal; ideia de agir por desconhecer sua qualidade de garantidor; tem relações sexuais com alguém supondo-se curado de doença venérea.

2.5.1. DIFERENÇA ENTRE ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO

No **erro de tipo**, o sujeito tem uma má compreensão da realidade. Há um **erro sobre a circunstância fática**. É isso que diferencia o erro de tipo do erro de proibição. No erro de tipo, mesmo sabendo que o crime de furto se configura com a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, o indivíduo pega uma carteira enganado, achando que era o seu. Neste caso, o indivíduo não teve dolo, ou seja, não houve conduta, pois foi desprovida de dolo, e não há punição culposa, pois não existe furto culposos. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Ou seja, neste caso, o fato foi atípico.

No **erro de proibição**, o sujeito sabe o que está fazendo, conhecendo a realidade, porém desconhece a ilicitude da conduta por ele praticada. O indivíduo sabe o que faz, mas não sabe que a sua conduta é proibida pelo ordenamento.

EXEMPLOS: (i) Sujeito mantém relação sexual com uma adolescente de 13 anos, e ele sabe que ela possui 13 anos, mas como a moça e família consentem, pensa o sujeito não estar cometendo estupro. (ii) O indivíduo, ao se deparar com uma carteira no chão, apanha para si, pensando que “achado não é roubado”, pois, para ele, não haveria uma conduta ilícita, em razão de não imaginar a existência do crime de apropriação de coisa achada.

O indivíduo sabe o que está fazendo, pois sabe que o dinheiro não era seu, porém não imaginava que a conduta seria proibida pelo ordenamento jurídico.

Os erros de tipo podem ser **classificados** como:

- erro de tipo essencial
- erro de tipo accidental

2.5.2. ERRO DE TIPO ESSENCIAL

No erro de tipo essencial, o erro recai sobre os **dados principais do tipo penal**.

O erro de tipo essencial pode ser:

- **inevitável (justificável, escusável, desculpável):** exclui o dolo e a culpa. O sujeito não responde por qualquer crime.
- **evitável (injustificável, inescusável, indesculpável):** exclui o dolo, mas o sujeito pode ser punido a título de culpa.

No erro de tipo essencial, para verificar se o erro foi inevitável ou evitável, a doutrina aduz que é necessário se utilizar do **homem-médio**. Doutrina mais moderna entende que as circunstâncias do caso concreto, bem como o grau de instrução do agente, devem ser considerados a fim de se concluir se seria evitável ou não tal erro de tipo.

2.5.3. ERRO DE TIPO ACIDENTAL

O erro de tipo accidental é o erro que **recai sobre dados secundários ou periféricos do tipo penal**. Neste caso, há um intento criminoso manifesto, devendo ser dividido em:

- **erro sobre o objeto (*error in objecto*)**
- **erro quanto a pessoa (*error in persona*)**
- **erro na execução**
- **resultado diverso do pretendido (*aberratio criminis ou aberratio delicti*)**
- **erro sobre o nexa causal**

Erro sobre o objeto (*error in objecto*):



O erro sobre o objeto **não encontra previsão legal**. O agente confunde a coisa (objeto material). Por exemplo, o indivíduo quer furtar um relógio Rolex, mas subtrai um relógio falsificado ou de baixo valor. A consequência é que o sujeito é punido pela conduta perpetrada. **A doutrina considera que deve ser levado em consideração o objeto material efetivamente atingido**. Por essa razão, é possível inclusive aplicar o princípio da insignificância, a depender do objeto material e do crime.

Rogério Sanches defende que deve ser considerado aquilo que seja mais benéfico ao réu. Isto é, se o indivíduo queria furtar um relógio Rolex, mas subtrai um relógio dourado, deve ser considerado o bem mais benéfico ao réu, eis que inexistente previsão legal sobre ao assunto.

Erro quanto a pessoa (error in persona):

O art. 20, §3º, do CP estabelece que o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado **não isenta de pena**. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime (vítima virtual). O CP preceitua que, no erro in persona, não se considera a pessoa efetivamente atingida, e sim a vítima que o agente pretendia atingir.

EXEMPLOS: (i) O agente quer matar José, saca a arma e mata João, pensando ser José, visto que estes são irmãos gêmeos (univitelinos). O erro se deu quanto à compreensão da pessoa atingida, e não de pontaria. Considera-se, portanto, a vítima que o agente queria atingir (vítima virtual).

(ii) No caso de uma mãe que, em estado puerperal, entra no berçário e mata uma criança pensando que era seu filho, não cometerá homicídio, e sim infanticídio, eis que se considera a vítima virtual (vítima que buscava atingir). A teoria que fundamenta a vítima virtual é denominada de **teoria da equivalência**.

Erro na execução (aberratio ictus):

Ocorre quando o indivíduo representa efetivamente quem se quer atingir, porém, por erro de pontaria ou acidente, outra pessoa é atingida. É denominado de **aberratio ictus**.

Segundo o art. 73, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, em vez de atingir a pessoa que pretendia ofender, atingir pessoa diversa, responderá como se tivesse praticado o crime contra aquela (**vítima virtual**), atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do **concurso formal** (art. 70 do CP) – homicídio doloso consumado (vítima virtual) e lesão corporal culposa (vítima pretendida).

Perceba que no erro de execução, o agente representa a vítima que deseja ofender, mas, por erro na execução, atinge pessoa diversa da pretendida. Neste caso, aplica-se a **teoria da equivalência**. Aqui, a doutrina diverge quando há duplo resultado.

EXEMPLO: João, querendo matar Maria, atira e fere Maria, mas mata Carla, por erro de pontaria.

1ª corrente: deverá o indivíduo ser responsabilizado por tentativa de homicídio em face de Maria e homicídio culposos em face de Carla, em concurso formal. (T.H. + H.C.)

2ª corrente: o indivíduo deverá responder, em concurso formal, pelo crime de homicídio doloso consumado, como se efetivamente tivesse matado Maria, e pela lesão corporal culposa, como se tivesse lesionado a amiga de Maria (Carla). (H.D. + L.C.C.)

Não há uma previsão legal dirimindo esta controvérsia, razão pela qual o magistrado deverá fazer um juízo com base naquilo que seja mais benéfico ao réu.

Resultado diverso do pretendido (aberratio criminis ou aberratio delicti):

No resultado diverso do pretendido, o indivíduo atinge bem jurídico distinto daquele que pretendia atingir.

O art. 74 do CP estabelece que quando, por acidente ou erro na execução do crime, vier resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposos, porém, se ocorrer também o resultado pretendido, aplica-se a regra do concurso formal (art. 70).

O indivíduo quer cometer um crime de dano e, para tanto, arremessa uma pedra em uma casa. O indivíduo erra o carro e acerta numa senhora de 80 anos, lesionando-a. Neste caso, o indivíduo comete lesão corporal culposa. Se, todavia, o indivíduo, além de acertar a senhora, atingir o imóvel pretendido, responderá pelo crime de dano e pelo homicídio culposos em **concurso formal**.

Rogério Sanches estabelece que, **quando o resultado pretendido for mais grave do que o resultado culposamente praticado, não poderá ser aplicado o art. 74**. Por exemplo, a Lei de Crimes



Ambientais, em seu art. 49, parágrafo único (Lei 9.605/98), tipifica o crime culposo de destruir ou danificar plantas de ornamentação de logradouros públicos. Via de regra, dano culposo não é crime, mas esta lei criou esta figura. Com base nessa tipificação, Sanches diz que não dá para aplicar o art. 74 quando o resultado efetivamente alcançado for de crime menos gravoso do que o pretendido.

EXEMPLO: João joga uma pedra com a intenção de matar José. José desvia e João danifica uma planta de ornamentação de logradouros públicos culposamente. O dano culposo, neste caso, não absorverá a tentativa de homicídio, sendo inaplicável o art. 74. Do contrário, haveria uma teratologia.

Erro sobre o nexa causal:

Neste caso, também não há previsão legal. O resultado almejado pelo sujeito é produzido. João quer matar José, **mas somente consegue matá-lo com nexa causal diverso do previsto**. Este erro se divide em duas espécies:

- **em sentido estrito:** o agente provoca o resultado com apenas um ato. Todavia, este resultado é alcançado por outro nexa causal.

Ex.: João decide matar José. Sabendo que José não sabe nadar, João o arremessa no rio. Durante a queda, José bate a cabeça numa pedra e morre. Neste caso, houve homicídio, pois, ainda que João não tenha matado José por afogamento, atingiu sua finalidade. Houve um erro em sentido estrito. Sendo assim, João responderá por homicídio. João deu causa ao resultado com uma única ação, mas o nexa causal foi distinto do planejado.

- **dolo geral (*aberratio causae*):** ocorre quando o agente alcança o resultado pretendido, mas com uma pluralidade de atos.

Ex.: João atira em José. Pensando que José estava morto, João o joga no rio. Feita a perícia, constatou-se que José morreu por afogamento. Portanto, houve dois atos praticados por João. No caso, o dolo inicial se generaliza no desdobramento fático, ao contrário de responder por tentativa de homicídio e homicídio culposo, o dolo geral fará com que o sujeito responda apenas pelo homicídio doloso consumado. Trata-se da aplicação do **princípio unitário**.

→ **Diferença entre erro de tipo essencial e delito putativo por erro de tipo (delito de alucinação)**

Erro de tipo essencial é o erro quanto às circunstâncias fáticas que recai sobre elementar do tipo; é a prática do crime sem ter consciência da realidade. Nesta hipótese, o indivíduo não quer cometer o crime. **Ex.:** José leva a carteira de João, pensando ser sua.

Delito putativo por erro de tipo acontece quando o sujeito quer realizar um crime, mas, na verdade, o fato é atípico. O crime só existe na cabeça do agente. **Ex.:** João sai com uma menina, pensando que ela tem 13 anos de idade, o que configuraria um estupro de vulnerável. No entanto, após a apuração, verifica-se que ela tem 15 anos de idade. Apesar de ele ter pensado que seria um estupro de vulnerável, o fato é atípico.

→ **Competência do erro de tipo**

No caso de erro de tipo, a competência **é fixada com base na vítima efetivamente atingida**, e não sobre aquela em que o indivíduo tinha a intenção de cometer o delito.

Segundo o STF, **deverá ser considerada a vítima efetivamente atingida**, e não aquela que ele pretendida atingir, pois, em matéria processual, não há o tratamento específico previsto no Código Penal. **Ex.:** no caso de *error in persona*, em que o agente quer matar uma mulher, mas acaba matando um policial rodoviário federal, no exercício de suas funções.

→ **Erro de subsunção e erro de proibição**

O erro de subsunção retrata uma situação jurídica que para o direito penal será irrelevante. O sujeito responderá penalmente pelo fato praticado. O que se mostra indiferente é que o indivíduo comete um **equivoco no tocante à valoração jurídica**. Há uma interpretação errônea do autor do fato sobre o tipo penal que julga praticar. **O sujeito sabe que sua conduta é ilícita, tendo potencial consciência da ilicitude**.

Ex.: jurado pede mil reais para votar a favor do réu. Neste caso, ele sabe que está praticando um ilícito, porém desconhece que sua conduta, em razão do seu enquadramento como funcionário público para fins penais, configura crime contra a administração pública.



No **erro de proibição**, o sujeito não sabe que sua conduta é ilícita, como é o caso de um senhor de 70 anos que pesca na sua cidade, durante o período de pesca proibida. Ele sabe que está pescando, porém desconhece que o fato é considerado ilícito.

→ **Erro provocado por terceiro**

Em regra, o erro provocado por terceira gera a punição do agente provocador do erro, denominado **autor mediato**. O agente provocado, chamado de autor imediato, em regra, não responde pelo crime, salvo se tiver agido dolosa ou culposamente.

EXEMPLO: médico que determina que a enfermeira aplique uma injeção. Todavia, naquela injeção, há veneno, levando o enfermo à morte. Neste caso, o médico responde pelo crime de homicídio, como autor mediato, e a enfermeira não comete crime, pois o erro foi provocado por terceiro (o médico). Se a enfermeira tomou conhecimento de que a injeção continha veneno e, mesmo assim, a aplicou, também responderá pelo crime doloso. Se percebeu que a substância não era remédio, mas não conferiu do que se tratava, responderá pelo crime culposos.

2.6. CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO

O crime pode ser:

- comissivo (violação de um mandamento proibitivo)
- omissivo (violação de um tipo mandamental)
- conduta mista

No **crime comissivo** há um fazer do agente, **violando um mandamento proibitivo**. O art. 121 do CP diz que é crime matar alguém. Se o sujeito matar alguém, violará um tipo proibitivo.

Já no **crime omissivo**, o sujeito não faz o que ele deveria fazer, **violando um tipo mandamental**. Na omissão de socorro (art. 135), a norma diz “socorra”, e o indivíduo não socorre. Nesta situação, o indivíduo viola a norma mandamental.

A norma mandamental pode decorrer de:

- **próprio tipo:** é denominado de **crime omissivo próprio ou puro**. Este dever é dirigido a todos, de modo que qualquer um poderá incidir no crime do art. 135 do CP, por exemplo;
- **cláusula geral:** é o denominado **crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão**. Neste caso, não há a simples abstenção de um comportamento exigido pela lei, e sim a adoção da teoria normativa. Aqui, há um não fazer penalmente relevante, mesmo o tipo descrevendo uma conduta comissiva, como é o caso do art. 121. Para que o indivíduo pratique um crime comissivo de maneira omissiva, é necessário que o agente tenha o **dever jurídico de evitar o resultado** (garante). O art. 13, §2º, cria este dever, de forma que a omissão configura o próprio tipo penal doloso, cometido pelo agente ao não evitar a ocorrência do resultado.

Ex.: É o caso da mãe que deixa de amamentar seu filho para vê-lo morrer de inanição (fome). A mãe possuía um dever jurídico de evitar o resultado. Cabe ressaltar que o **dever de agir** não é suficiente para imputar ao agente a conduta delituosa, é imprescindível que o indivíduo também **tivesse a possibilidade de agir para evitar o resultado**.

Como se vê, são dois os pressupostos para que haja incidência no crime comissivo por omissão, devendo o agente, diante do caso concreto:

- dever de agir;
- possibilidade de agir.

O art. 13, §2º, do CP é claro neste sentido, ao estabelecer que a omissão é penalmente relevante quando o omitente **devia e podia agir** para evitar o resultado.

O dever de agir incumbe a quem:

- **Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância (dever legal);** aqui está a obrigação dos pais em relação aos filhos, sendo denominado poder familiar.
- **De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado (garante):** neste caso, há uma assunção voluntária do encargo, como é o caso em que a babá se comprometeu de cuidar



das crianças. Se houver alguma conduta criminosa comissiva, e ela deixou de agir, sendo certo que podia e devia agir, a fim de evitar o resultado, responderá pelo crime comissivo por omissão. Rogério Sanches também afirma que relações da vida cotidiana também podem gerar este dever, como ocorre quando um indivíduo bebe e o outro não, mas a mãe de um deles liga para o indivíduo que não estaria alcoolizado e ele garante que levará o bêbado para casa. Neste caso, o indivíduo assumiu o encargo voluntariamente. Também é aqui que mora a responsabilização dos indivíduos no que tange às relações contratuais.

- **Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado:** neste caso, quem criou o risco não pode ser considerado sem o dever jurídico de agir.

Crimes de conduta mista são aqueles em que o tipo penal traz, primeiramente, uma ação seguida de uma omissão.

A norma exige do sujeito ativo dois comportamentos:

- **comissão no antecedente**
- **omissão no consequente**

É o caso da apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, inciso II, CP), a qual ocorre quando o agente acha coisa alheia perdida e dela se apropria(**conduta comissiva**), total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente(**conduta omissiva**), no prazo de quinze dias.

Neste caso, está configurada uma ação seguida de uma omissão, sendo um **crime de conduta mista**. Há, portanto, uma comissão no antecedente e uma omissão no consequente.

3. RESULTADO

Da conduta comissiva ou omissiva poderão surgir dois resultados:

- **resultado naturalístico:** é a modificação no mundo exterior provocado pela conduta;
- **resultado normativo:** é a violação da norma protetora do bem jurídico tutelado. **Todo crime possui um resultado jurídico.**

Em se tratando de resultado naturalístico, é possível afirmar que há crimes sem resultado naturalístico, como é o caso dos **crimes de mera conduta** (ex.: ato obsceno – art. 233, CP), mas também há crimes que não exigem a ocorrência do resultado naturalístico para sua consumação, ainda que previsto, sendo o caso dos **crimes formais**(ex.: extorsão mediante sequestro – 157, CP) . Há ainda os crimes que exigem a ocorrência do resultado naturalístico para sua consumação, como ocorre nos **crimes materiais**(ex.: homicídio).

No caso do resultado normativo (jurídico), há apenas a lesão ao bem jurídico, ou mesmo um perigo de lesão ao bem jurídico. Considerando que é o atingimento do bem jurídico que caracteriza o resultado, é possível entender que **todo crime possui um resultado jurídico**. Veja, não há crime sem resultado normativo.

Quando tratamos dos elementos do fato típico (conduta, nexa causal, resultado e tipicidade), a doutrina diverge sobre qual seria a espécie de resultado.

1ª Corrente: a corrente tradicional estabelece que se trata de resultado naturalístico, razão pela qual os crimes de mera conduta e os formais teriam o preenchimento de seus fatos típicos com apenas a conduta e a tipicidade, não sendo necessário nexa causal e resultado.

2ª Corrente: a corrente mais moderna entende que **a teoria do fato típico se refere ao resultado normativo**, pois estaria ali descrita a lesão (ou perigo de lesão) ao bem jurídico tutelado, de modo que todos os crimes teriam resultado jurídico previsto no fato típico (LFG e Rogério Sanches).



4. NEXO CAUSAL

4.1. CONCEITO E TEORIAS

Nexo de causalidade é o **vínculo que existe entre a conduta e o resultado**.

O art. 13, caput, do CP estabelece que o resultado, de que depende a existência do crime, **somente é imputável a quem lhe deu causa**. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Analisando o dispositivo acima, é possível compreender que, para fins de causa, o CP adotou a **teoria da equivalência dos antecedentes causais (*conditio sine qua non*)**

Para saber se certa conduta foi ou não causa do crime, é necessário adotar a **teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais (Método de Thyén)**. Neste caso, deverá o aplicador do direito suprimir determinada ação ou omissão e verificar se o resultado teria ocorrido, ou, ao menos, se teria ocorrido daquela forma. Caso se conclua que o fato não teria ocorrido da mesma forma, a ação ou omissão será considerada como causa do crime.

EXEMPLO: João toma banho e coloca uma camisa amarela. Sai de casa e coloca a arma no bolso. Liga e marca um jantar com José. José senta e inicia o jantar. No final, João saca a arma e dá um tiro em José, matando-o. Neste caso, a arma foi causa do crime. A ligação foi causa. A camisa amarela não é causa, pois se ele estivesse de camisa azul, o crime teria ocorrido da mesma forma.

Teoria da equivalência dos antecedentes causais + Teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais = causalidade objetiva do resultado (causalidade efetiva do resultado)

A junção da teoria da equivalência dos antecedentes causais e a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais denomina-se **causalidade objetiva do resultado** (causalidade efetiva do resultado). Esta causalidade objetiva é apenas uma mera relação de causa e efeito, razão pela qual a crítica diz que a causalidade objetiva do resultado leva ao **regresso ao infinito**.

Para evitar o regresso ao infinito, é preciso que o aplicador se utilize da **causalidade subjetiva (psíquica)**, de forma que devemos analisar se o agente, anteriormente, agiu de forma dolosa ou culposa.

4.2. CONCAUSAS

Concausa é uma causa que está junto de outra causa. A partir do momento em que se sabe o que pode figurar como causa de um crime, é possível que se note, no caso concreto, que há mais de uma causa concorrendo para o resultado, e esta concorrência de causas é denominada de concausas.

Existem concausas que são **absolutamente independentes** e **relativamente independentes**.

4.2.1. CONCAUSAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES

Nas concausas absolutamente independentes, a causa efetiva do resultado não se origina, direta ou indiretamente, do comportamento concorrente. Veja que a causa absolutamente independente **não tem qualquer relação com a outra causa**.

O sujeito quer cometer um crime, pratica a conduta, mas o resultado não decorreu dessa conduta, mas ocorre por outra causa, absolutamente independente. Quer esta causa seja antecedente, concomitante ou superveniente, quem praticou a primeira conduta responderá por crime tentando.

A causa absolutamente independente pode ser:

- **Superveniente:** Ex.: Maria decide matar o marido José. Para tanto, decide fazer uma sopa e colocar veneno. O marido toma a sopa. No momento em que o marido está assistindo televisão e antes de o veneno começar a fazer efeito, entra um indivíduo na residência e mata o marido



de Maria. O marido vem a óbito por motivo dos disparos, e não pelo motivo do veneno. Maria responderá por tentativa de homicídio, eis que, quando ela ministrou o veneno, o objeto material (marido) tinha vida, não havendo que se falar em crime impossível. Veja, ela não conseguiu matar o marido por circunstâncias alheias à sua vontade. A causa absolutamente independente da primeira causa é superveniente, pois o bandido só ingressou na residência após a conduta de Maria.

- **Preexistente:** Ex.: Maria decide matar o marido. Para tanto, decide fazer uma sopa e colocar veneno. O marido toma a sopa. No momento em que o marido está assistindo televisão, o veneno começa a fazer efeito, mas, antes que ele morra, entra um indivíduo na residência e atira no marido de Maria. O bandido vai embora. Posteriormente, constata-se que o marido de Maria morreu em razão do veneno, e não em razão dos disparos. Maria responderá pelo homicídio consumado, enquanto o bandido responderá por latrocínio tentado.
- **Concomitante:** Ex.: quando o bandido dá um tiro em José, no mesmo instante, cai um lustre na cabeça de José, que morre por traumatismo craniano. Neste caso, o bandido responderá por tentativa de homicídio.

A conclusão é de que, **no caso de concausas absolutamente independentes, não importa a espécie, o comportamento paralelo será punível como se fosse tentado.** Mas o outro que efetivamente causar o resultado, responderá pelo resultado, salvo no caso do lustre, que não haverá crime.

4.2.2. CONCAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES

As concausas poderão ser relativamente independentes, hipótese em que haverá uma **conjugação de causas que irão levar ao resultado final.**

As concausas, nesta situação, se fossem analisadas individualmente consideradas, não levariam ao resultado final. Todavia, se conjugarmos as duas causas, será plenamente possível o resultado.

As concausas relativamente independentes poderão ser:

- **Preexistente:** a causa efetiva é anterior à causa concorrente, **o sujeito responderá pelo crime consumado.** Ex.: João é portador de hemofilia. José deseja matar João e, por saber que ele é hemofílico, dá uma facada na vítima. Posteriormente, é constatado que João não teria sido morto por conta da facada, que foi no braço, porém, em razão da hemofilia, a vítima morreu. Neste caso, José responderá por homicídio consumado, eis que o agente tinha o intento de matar, alcançando a morte de João. Há aqui uma concausa preexistente relativamente independente (hemofilia).
- **Concomitante:** a causa efetiva ocorre simultaneamente à outra causa, **o sujeito responderá pelo crime consumado.** Ex.: Neste caso, João, com intenção de matar José, efetua um disparo contra a vítima. No entanto, João não atinge José, mas, por ter 90 anos, a vítima morre de infarto com o susto causado pela atitude do agente. João responderá pelo homicídio consumado, eis que tinha o dolo de matar, efetuou o disparo para matar, e conseguiu matar, ainda que tenha sido por uma causa relativamente independente, que foi o susto de José.
- **Superveniente:** no caso de causa superveniente relativamente independente, a causa efetiva do resultado ocorre após a causa concorrente, há uma cisão no nexo causal, um rompimento de fato. **O sujeito responderá pelos atos até então praticados.**

O exemplo clássico é aquele em que João efetua um disparo contra José, porém este é socorrido com vida e levado por uma ambulância ao hospital. No trajeto para o hospital, a ambulância colide com um ônibus, levando a vítima à morte. Esta causa é superveniente, pois ocorreu após os disparos, e é relativamente independente, visto que, se não tivesse sofrido o tiro, a vítima não estaria na ambulância. Além disso, é uma causa que, **por si só,** produziu o resultado. Nesta hipótese, o CP (§1º do art. 13) diz que **a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.**



Portanto, o indivíduo que efetuou os disparos responderá por tentativa de homicídio, e não por homicídio consumado. Isso porque, o que há aqui é uma causa relativamente independente que produziu por si só o resultado. O art. 13, §1º, do CP adotou a **teoria da causalidade adequada (condição qualificada ou condição individualizadora)**, considerando como causa a circunstância que, além de ser um antecedente indispensável, leva a produção de um resultado dentro daquilo que é esperado. Ou seja, o sujeito realiza uma atividade adequada à concretização do resultado. Quem age para matar, não quer matar por um acidente do veículo que conduz a vítima para o hospital. Isto não está dentro do desdobramento esperado, dentro daquilo que é possível ocorrer.

Por outro lado, **quando o fato superveniente está dentro do desdobramento normal da causa realizada pelo agente, o sujeito vai responder pelo crime**. Por exemplo, no caso em que João dispara contra José e, ao chegar no hospital, recebe tratamento médico, o qual se mostrou insuficiente em razão de um erro médico, neste caso, João responderá pelo homicídio consumado, podendo até mesmo o médico responder por homicídio culposo. Todavia, João responde pelo homicídio doloso consumado, eis que um erro médico no momento da cirurgia é algo que está dentro do desdobramento normal.

Como dito, no caso da ambulância, o evento sai da linha de desdobramento causal, sendo um evento imprevisível. Neste caso, o agente não responderá pelo resultado consumado, mas apenas pelos atos até então praticados, no caso a tentativa de homicídio.

Em suma, é adotado pelo Código Penal:

- **Teoria da equivalência dos antecedentes causais em conjugação com a teoria da eliminação hipotética**, que é denominada de teoria da causalidade objetiva, a qual deve ser somada à teoria da **causalidade subjetiva** (causalidade psíquica), sendo essa um freio para o regresso ao infinito.
- **Teoria da causalidade adequada**, a qual ocorre quando se analisa a concausa relativamente independente superveniente. Quando a concausa relativamente independente superveniente, por si só, produzir o resultado, excluir-se-á a imputação, eis que aquela conduta inaugural não é adequada ao resultado como se deu.

4.3. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA

Esta teoria busca delimitar a imputação do resultado ao agente. O agente não responde objetivamente pelo delito, mas a análise é objetiva para imputar o resultado ao agente. Esta teoria considera, além do critério físico, os **nexos normativos** para o momento em que se atribui um resultado a uma conduta.

Antes, se valorava a ação do sujeito para verificar se a conduta do indivíduo se dirigiu para determinado fim. A teoria da imputação objetiva vai além, criando uma faceta **objetiva** da finalidade, ou seja, a teoria busca identificar se houve a criação de um **risco juridicamente proibido pelo agente**.

Em suma, o desvalor do resultado está ligado à **criação ou incremento de um risco juridicamente proibido**. Após, é necessário verificar se o **resultado foi alcançado por meio da criação ou incremento desse risco**. E, por último, é indispensável que o **resultado esteja dentro do alcance do tipo penal**.

Caso os três elementos estejam presentes, haverá o **nexo normativo**. Esta análise do nexo normativo **antecede** a análise subjetiva da conduta do agente, não se falando em dolo ou culpa neste momento.

Portanto, a análise da teoria da imputação objetiva passa pelos seguintes critérios normativos:

- **criação ou incremento de um risco juridicamente proibido**
- **realização do risco proibido no resultado**
- **resultado dentro do alcance do tipo**



4.3.1. CRIAÇÃO OU INCREMENTO DE UM RISCO JURIDICAMENTE PROIBIDO

Quando um indivíduo, desejando que o colega morra, o presenteia com uma passagem de Rio Grande do Sul/RS para Ouro Preto/MG, com a finalidade de que o colega passe por determinada estrada com alto índice de acidentes e lá possa morrer, e o resultado ocorre, não há crime. Neste caso, o indivíduo criou um risco ao colega, porém o risco de pegar estrada é permitido.

Se fôssemos pensar na teoria da equivalência dos antecedentes causais, o indivíduo deu causa (causalidade objetiva) dolosamente (causalidade subjetiva).

Todavia, por meio da teoria da imputação objetiva, não pode o resultado ser imputado ao indivíduo que doou as passagens, pois o risco que ele criou foi permitido.

Nos crimes de trânsito, por exemplo, o fabricante fez o carro, criando um risco permitido.

4.3.2. REALIZAÇÃO DO RISCO PROIBIDO NO RESULTADO

A ocorrência do resultado deve ser atribuída ao risco ou ao incremento criado. É necessário entender se o perigo criado foi gerado daquela conduta, de maneira que não será considerado como causa se o comportamento do agente não estiver na linha de desdobramento natural da ação praticada pelo agente.

EXEMPLO: No erro médico de uma cirurgia de um indivíduo que levou um tiro no peito, haverá a imputação do resultado ao agente que promoveu o disparo, ainda que tenha havido o erro médico, pois, neste caso, o médico buscava reduzir um risco criado pelo homicida. Nada impede que, a depender do caso, o médico responda por homicídio culposo. Contudo, a conduta do homicida criou um risco proibido (efetuar disparo), de forma que as complicações decorrentes da cirurgia realizada pelo médico são um risco que pode alcançar o resultado, havendo um desdobramento natural.

4.3.3. RESULTADO DENTRO DO ALCANCE DO TIPO

O perigo gerado pelo agente deve estar dentro do alcance do tipo penal. Imaginemos que um sujeito dá um tiro em seu desafeto e, no caminho, a ambulância se choca com outro ônibus, levando a vítima à morte em razão do acidente. Neste caso, o resultado está fora do alcance do tipo. Quando o indivíduo atirou, queria matar e, ainda que a morte se desse no hospital, a vítima teria morrido em razão do disparo.

No entanto, no caso da ambulância, caso o indivíduo morra em razão do acidente, o resultado estará fora do alcance do tipo, eis que o indivíduo queria matar alguém com tiro, e não por acidente. O objetivo do art. 121 do CP não é prevenir acidentes fatais. Esses acidentes fatais não estão na linha de domínio direto e indireto do autor, estando fora do alcance do tipo.

4.4. CAUSALIDADE NOS CRIMES OMISSIVOS

Mirabete diz que “do nada, nada surge”. Portanto, para ele quem não faz nada não comete nada.

Por isso, para que haja a causalidade nos crimes omissivos, é necessário que o aplicador do direito se utilize de um **nexo normativo**.

Trata-se do **nexo de evitação**. Ou seja, deve-se empregar um juízo hipotético e pensar se o resultado teria ocorrido caso a mãe tivesse dado alimento ao filho. Em se verificando que o resultado teria sido evitado com a alimentação, a mãe será responsável pelo crime, estando previsto o nexo de evitação

EXEMPLO: Quando o pai deixa de alimentar o filho, a criança morre de inanição. Neste caso, há um dever jurídico criado pela norma para que o pai dê alimento ao filho. O pai tem a obrigação de evitar o resultado morte.



5. TIPICIDADE PENAL

Para a doutrina tradicional, tipicidade é a subsunção do fato à norma. Neste caso, se o indivíduo subtrair um clipe, haverá crime de furto. Essa ideia não mais se sustenta na íntegra, uma vez que é apenas das facetas da tipicidade.

A doutrina moderna preceitua que não basta a subsunção do fato à norma, sendo necessário que haja **lesão ou perigo de lesão, de forma relevante, ao bem jurídico tutelado**. Portanto, quem subtrai uma caneta Bic pratica fato atípico (atipicidade material).

Corrente moderna diz que a tipicidade penal é formada por:

- tipicidade formal
- tipicidade material

Zaffaroni, todavia, preceitua que o ordenamento deve atuar de forma conglobante. Para ele, a tipicidade se subdivide em:

- tipicidade formal (subsunção do fato à norma)
- **tipicidade conglobante** (tipicidade material + antinormatividade)

A antinormatividade é a contrariedade ao ordenamento jurídico como um todo, visando evitar incoerência do fato. Para ele, não se pode considerar uma conduta ilícita penalmente se outra norma estatal é determinada ou fomentada pelo Estado.

Neste caso, para Zaffaroni, a excludente de ilicitude do estrito cumprimento dever legal que fundamenta a atuação do oficial de justiça, quando promove a penhora de bens (subtraindo coisa alheia móvel), deveria ser analisada sob o âmbito da excludente do fato típico, eis que estaria desprovida de antinormatividade. Não havendo antinormatividade, por essa conduta ser determinada pelo Estado, não poderia haver tipicidade conglobante, razão pela qual não haveria que se falar em tipicidade penal e, consequentemente, em crime.

Para a doutrina que acolhe a teoria da tipicidade conglobante, os casos de **estrito cumprimento do dever legal** e o **exercício regular de um direito fomentado** não poderão ser considerados como excludentes da ilicitude, mas sim excludentes da tipicidade penal, tornando tais condutas **atípicas**.

5.1. TIPICIDADE FORMAL

Há duas espécies de tipicidade formal:

- **subsunção direta ou adequação típica imediata:** não há dependência de qualquer dispositivo complementar para adequar o fato à norma. **Ex.:** João atira e mata José. Neste caso o fato de matar alguém se enquadra diretamente no art. 121 do CP.
- **subsunção indireta ou adequação típica mediata:** há uma conjugação do tipo penal com a norma de extensão, também denominada de **norma de adequação típica mediata**. **Ex.:** João tenta matar José. Neste fato, não há subsunção direta ao art. 121, CP. Neste caso, devemos utilizar o art. 121 do CP e conjugá-lo com o art. 14, II, do CP. Da mesma forma, quem espera do lado de fora da casa o comparsa subtrair a televisão, não subtrai o objeto, mas neste caso responderá pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas em razão do art. 29 do CP. A própria norma de extensão do garante (art. 13, II, CP) também é de subsunção indireta.

5.2. ELEMENTOS DO TIPO PENAL

Basicamente, temos como elementos do tipo penal:

- **Elementos subjetivos:** estão ligados ao especial fim de agir do indivíduo. A doutrina diz que existem:



- **positivos:** são elementos subjetivos que animam o agente. **Ex.:** no tráfico para uso compartilhado, o indivíduo deve vender droga com o objetivo de consumir juntamente com a pessoa.
- **negativos:** elementos subjetivos que não devem animar o agente. **Ex.:** no tráfico para uso compartilhado, o indivíduo deve vender droga sem o objetivo de lucrar.
- **Elementos objetivos:**
 - **descritivos:** descrevem aspectos materiais da conduta como o tempo, circunstância, forma de execução.
 - **normativos (valorativos):** há um juízo de valor para sua compreensão. **Ex.:** no ato obsceno, é necessário o juiz valorar sobre o que é essa obscenidade.
 - **científico:** não são meramente elementos normativos, mas demandam o conhecimento técnico de determinado conceito. **Ex.:** para saber se houve utilização inadequada de embrião humano, é necessário saber o que é tecnicamente um embrião.

A doutrina ainda classifica os elementos do tipo como modais, que de certa forma se confundem com os elementos descritivos.

Elementos modais são elementos relacionados às circunstâncias de tempo, local, modo de execução etc. **Ex.:** No roubo impróprio, há o emprego da violência logo depois de subtrair a coisa. Este “logo depois” seria o elemento modal, pois traz uma circunstância de tempo, devendo ser logo depois. Está relacionado ao tempo, local, modo de execução.

5.3. TIPO PENAL CONGRUENTE E INCONGRUENTE

O tipo penal pode ser classificado como:

- **Congruente (simétrico):** há uma simetria entre os elementos objetivos e os elementos subjetivos. **Ex.:** matar alguém.
- **Incongruente (assimétrico):** aqui há uma assimetria entre os elementos objetivos e subjetivos. **Ex.:** No crime tentado, João tem subjetivamente o dolo de matar, mas objetivamente ele não alcança, havendo uma assimetria. No crime preterdoloso, há o inverso, o sujeito quer apenas lesionar (elemento subjetivo), mas acaba matando (elemento objetivo), ou seja, não há uma congruência.

5.4. TIPO SIMPLES E TIPO MISTO

O tipo penal pode ser:

- **Tipo simples:** o crime contém apenas um núcleo. **Ex.:** subtrair coisa alheia móvel, para sim ou para outrem.
- **Tipo misto (de conduta mista ou de conteúdo variado):** há mais de um núcleo no tipo penal. **Ex.:** tráfico de drogas. Pode ser subdividido em:
 - **Tipo misto alternativo:** a prática de mais de um núcleo do tipo será crime único, desde que no mesmo contexto fático. Para o STJ, a conjunção carnal e outro ato libidinoso, sob violência ou grave ameaça, praticados no mesmo contexto fático, configuram **crime único** de estupro.
 - **Tipo misto cumulativo:** quando há a prática de mais de um núcleo do tipo, haverá concurso material de crimes.

CAPÍTULO 12 — TEORIA GERAL DO CRIME: ILICITUDE

1. CONCEITO

Illicitude é uma **conduta contrária ao ordenamento jurídico**. É o segundo elemento do crime, sendo conhecida como antijuridicidade.

2. TEORIAS QUE EXPLICAM A RELAÇÃO ENTRE FATO TÍPICO E ILICITUDE

A ilicitude será verificada a partir de um juízo negativo, pois não havendo causa excludente de ilicitude, o crime é considerado ilícito.

A partir daí, é possível verificar a existência de 4 teorias que tratam sobre essa relação:

- **Teoria da autonomia (absoluta independência):** tipicidade não tem a ver com ilicitude. O fato pode ser típico e não ser ilícito. Não há qualquer relação entre os substratos.
- **Teoria da indiciarietade (*ratio cognoscendi*):** a existência de um fato típico gera a presunção relativa de que o fato é também ilícito. Há um caráter indiciário da ilicitude. Ou seja, há uma certa relação de dependência da ilicitude em relação ao fato típico. Cabe à defesa fazer prova que o fato típico foi praticado sob o manto de uma excludente de ilicitude. **É a teoria adotada pelo Direito Penal.** O fato típico desperta indícios de ilicitude.

Obs.: Essa teoria foi mitigada com a reforma do CPP. O art. 386, do CPP passou a afirmar que se o juiz tiver fundada dúvida sobre a existência de uma excludente de ilicitude, o juiz deverá absolver o indivíduo, aplicando-se o *in dubio pro reo*. Sendo assim, a defesa não precisa provar categoricamente que o sujeito agiu acobertado por uma excludente de ilicitude, basta que ela produza prova suficiente e capaz de deixar alguma dúvida no magistrado. Há uma mitigação da teoria da relatividade do ônus probatório. **Há uma mitigação da teoria da relatividade do ônus probatório.** **Ex.:** João lesionou Pedro, mas afirma que só o fez porque estava em legítima defesa. Pedro não prova o contrário, deixando a cargo das provas constantes nos autos. João, por sua vez, traz uma prova que coloca o juiz em dúvida, não sendo absolutamente convincente se o sujeito teria agido em legítima defesa. Diante disso, **o juiz deverá absolver o réu, pois presente a fundada dúvida.**

- **Teoria da absoluta dependência (*ratio essendi*):** esta teoria diz que há o **tipo total do injusto**, ou seja, a ilicitude faz parte da própria tipicidade, é a essência da tipicidade. Se o fato não é ilícito, não será considerado típico.
- **Teoria dos elementos negativos do tipo:** para esta teoria, o tipo penal é composto por elementos positivos e elementos negativos. Os positivos são explícitos, enquanto os elementos negativos estão implícitos.

Ex.: tipo penal diz “matar alguém”, sendo este o elemento positivo. No entanto, também contém os elementos negativos implícitos, o que significa que o tipo penal deve ser lido da seguinte forma “matar alguém é crime, salvo se praticado acobertado por uma excludente da ilicitude”. Para que o comportamento do agente seja típico, não podem estar configurados os elementos negativos. Há aqui uma absoluta relação de dependência entre o fato típico e a ilicitude.

Como dito, o **Brasil adotou a teoria da indiciarietade (*ratio cognoscendi*)**. A importância disso é que, uma vez demonstrado que o sujeito praticou o fato típico, caberá à defesa demonstrar que o réu praticou uma conduta amparada por uma causa excludente da ilicitude, pois há presunção de ilicitude da conduta.



3. CAUSAS EXCLUDENTES DA ILICITUDE (DESCRIMINANTES)

As causas excludentes da ilicitude estão descritas no art. 23 do CP:

- estado de necessidade
- legítima defesa
- estrito cumprimento do dever legal
- exercício regular do direito

Não se trata de causas exaustivas, pois o próprio CP traz a hipótese de **aborto justificado** (art. 128, CP).

Inclusive, há causas de justificação supraleais (sem previsão legal), como é o consentimento do ofendido (em se tratando de bem disponível, próprio, vítima capaz).

Ilicitude (continuação). Culpabilidade.

3.1. ESTADO DE NECESSIDADE

3.1.1. CONCEITO

O art. 24 do CP estabelece que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de **perigo atual**, que não provocou por sua **vontade**, nem podia de outro modo **evitar**, direito **próprio** ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, **não era razoável** exigir-se.

3.1.2. REQUISITOS DO ESTADO DE NECESSIDADE

Perceba é possível verificar os requisitos do estado de necessidade:

- **Perigo atual:** há uma discussão se o perigo iminente seria elemento possível do estado de necessidade. O entendimento que prevalece é no sentido de que o perigo atual abrange o perigo iminente, tendo em vista que perigo é a probabilidade de dano¹⁵. Quanto à existência do perigo, o estado de necessidade pode se classificar em (i) estado de necessidade real, em que há efetivamente o perigo, e em (ii) estado de necessidade putativo, situação em que o perigo é imaginário.
- **Perigo não causado voluntariamente pelo agente:** o agente não pode ser o causador voluntário da situação de perigo. Esta voluntariedade, segundo a doutrina majoritária, se refere àquele que causou dolosamente o perigo. Se o causador atuou culposamente, este indivíduo poderá agir em estado de necessidade. A despeito do professor Mirabete, que possui entendimento diverso (corrente minoritária).
- **Salvar direito próprio ou alheio:** para incidir na excludente, também é necessário que o indivíduo aja para salvar direito próprio ou alheio. Sendo o direito próprio a ser salvo, haverá estado de necessidade próprio, porém, se salvar direito alheio, haverá estado de necessidade de terceiro.
- **Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo:** o art. 24, §1º, CP, assevera que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Este dever legal, para a maioria da doutrina, é um dever jurídico, deve ser considerado em sentido amplo, não podendo alegar o estado de necessidade quem tem o dever jurídico de enfrentar o perigo, podendo, inclusive, nascer este dever de uma relação contratual. **Ex.:** um salva-vidas tem o dever jurídico de tentar salvar quem está se afogando no mar. O segurança da boate não pode alegar estado de necessidade e não enfrentar uma situação de briga no estabelecimento. No caso do World Trade Center, devido aos desabamentos, os bombeiros saíram do prédio. Nesta

¹⁵Para provas de 1ª fase deve-se adotar a expressão **atual**.



situação, não poderiam alegar estado de necessidade em razão do dever jurídico que possuíam, porém poderiam alegar a inexigibilidade de conduta diversa, afastando-se a culpabilidade.

- **Inevitabilidade do comportamento lesivo:** a lei diz que o indivíduo sacrifica o direito alheio, pois não há outro modo de agir. O comportamento do agente deve ser absolutamente inevitável. Se é possível a fuga, o indivíduo deve fugir. Ou seja, se a saída é possível, havendo outro modo de evitar a lesão, deverá o indivíduo adotar o modo menos lesivo. Quanto a quem sofre a ofensa, poderá haver a classificação em:
 - **Estado de necessidade defensivo:** quando o bem jurídico violado é do causador da situação de perigo.
 - **Estado de necessidade agressivo:** quando o sacrifício se dá em relação a bem pertencente a terceiro, que não causou a situação de perigo.
Neste caso, subsiste o dever de indenizar. Na **esfera cível**, se a lesão se deu em face de quem gerou o perigo (e. n. defensivo), não há o dever de indenizar o indivíduo. Por outro lado, se o causador da lesão atingir o terceiro, que não causou o perigo, deverá indenizá-lo, sem prejuízo da ação de regresso contra o indivíduo causador do perigo.
- **Inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado:** aqui há uma ponderação entre o bem salvo e o bem sacrificado. A partir dessa ideia se desenvolvem duas teorias:
 - **Teoria diferenciadora:** é necessário fazer uma diferenciação, isto é, se o bem jurídico sacrificado tiver um valor menor ou igual ao bem jurídico protegido, haverá estado de necessidade como excludente da ilicitude, denominado de **estado de necessidade justificante**. Por outro lado, se o bem sacrificado tiver o valor **maior** do que o bem protegido, a doutrina denominará esta situação de **estado de necessidade exculpante**, ou seja, há a exclusão da culpabilidade. **NÃO É ADOTADA**.
 - **Teoria unitária:** não há estado de necessidade exculpante, mas apenas o estado de necessidade como excludente da ilicitude. Sendo o bem sacrificado mais valioso do que o bem protegido, deverá o indivíduo responder pelo crime, mas há uma causa obrigatória de redução de pena de 1/3 a 2/3, conforme o §2º do art. 24 estabelece. O dispositivo diz que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. **TEORIA ADOTADA**.
- **Conhecimento da situação justificante:** é o requisito subjetivo, determinando que o sujeito saiba que está agindo em estado de necessidade.

3.1.3. ESTADO DE NECESSIDADE EM CRIME HABITUAL E EM CRIME PERMANENTE

Rogério Sanches reputa o questionamento acerca da possibilidade de se falar em estado de necessidade diante de um crime habitual ou de um crime permanente. A conclusão que ele chega é a de que, como a lei exige perigo atual, inevitabilidade do comportamento lesivo e não razoabilidade de sacrifício do direito ameaçado (art. 24, CP), não há como aplicar esses requisitos legais nos casos de crime permanente e crime habitual.

Isso, porque, no crime habitual, por exemplo, o sujeito não poderia exercer a medicina irregularmente em razão de um perigo atual. Todavia, **poderá, eventualmente, o indivíduo se valer de uma inexigibilidade de conduta diversa**, que é uma causa excludente da culpabilidade, **não havendo falar em estado de necessidade em crime habitual ou permanente**.

3.1.4. ESTADO DE NECESSIDADE CONTRA ESTADO DE NECESSIDADE

É **possível** falar-se em estado de necessidade contra estado de necessidade, bastando lembrar do caso dos naufrágos em que, havendo uma tábua de salvação, ambos possuem o interesse jurídico de evitar o perigo atual, podendo matar a outra pessoa para salvar o seu bem jurídico, a vida.

A doutrina denomina esta espécie de **estado de necessidade recíproco**.



3.1.5. ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO NA EXECUÇÃO

Trata-se de erro de pontaria. Supondo que o indivíduo esteja de frente com o cachorro do vizinho, não havendo como fugir. Neste caso, se o indivíduo estivesse com uma arma e matasse o cachorro, incidiria em estado de necessidade. Contudo, um dos disparos atravessa o cachorro e atinge a perna de uma criança, causando lesões.

A repercussão jurídica disso deve ser feita a partir do **erro na execução**. Isso porque o indivíduo queria apenas matar o cachorro, e não a criança. Neste caso, deverá ser considerada apenas a **vítima pretendida**, que era o cachorro, por meio do estado de necessidade. Por esta razão, **o disparo que atingiu a criança não configurará crime, salvo se agiu culposamente**.

3.2. LEGÍTIMA DEFESA

3.2.1. CONCEITO – ART. 25, CP

A lei estabelece que quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, justifica a sua conduta pela legítima defesa.

3.2.2. REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA

- **Uso moderado dos meios necessários:** é preciso que o indivíduo aja com proporcionalidade, isto é, deve ser utilizado o meio menos lesivo à disposição do agredido. Meio necessário é aquele menos lesivo à disposição de quem vai repelir a injusta agressão, mas que seja capaz de repelir o ataque. **A atuação moderada é uma utilização sem excessos e que demonstre que houve emprego suficiente daquilo que se exige para cessar a agressão.** Nélson Hungria destaca que, na verdade, para dizer se foi moderado ou não, não é possível utilizar de uma balança de farmácia, devendo-se analisar se foi mais ou menos proporcional.
- **Agressão injusta:** agressão é uma ação ou omissão humana, a injustiça deve ser contrária ao direito e ao ordenamento jurídico. Se houver a agressão injusta, o agredido poderá revidar a agressão, não se exigindo a fuga do local (*commodus discessus*), diferentemente do estado de necessidade. A injustiça da agressão justifica o rebate do agredido. **Ex.:** o ataque do cachorro pode gerar legítima defesa, caso o dono do cachorro tenha instigado-o a atacar a pessoa. Se não há essa determinação do dono, que o utiliza como instrumento de ataque, o caso poderá configurar estado de necessidade.

A legítima defesa **independe da consciência do agressor**, ou seja, o inimputável, por exemplo, pode ser agressor injusto e haver uma legítima defesa contra este indivíduo. O provocador da injusta agressão poderá agir em legítima defesa, como no caso em que o indivíduo encontra a mulher e o amante na cama. Neste caso, aquele sujeito que será agredido pelo agressor provocou a situação, mas poderá se utilizar da legítima defesa.

Há duas hipóteses em que o provocador da agressão não pode invocar a legítima defesa: i) a hipótese em si já se mostra uma provocação. Por exemplo, João dá um soco na cara de Pedro. Pedro não poderá pegar uma arma e sustentar que agiu em legítima defesa; ii) a hipótese em que o próprio indivíduo provoca a agressão injusta com o intuito de levantar a legítima defesa. O indivíduo tem por finalidade criar a ação de legítima defesa para justificar a morte do agressor. É o caso em que o indivíduo, querendo matar o marido de sua amante, vai até a casa, fazendo com que ele compareça à residência e encontre os dois na cama, de modo que antes de o marido sacar a arma, o amante mata o traído. Esta provocação só foi um pretexto para que o provocador agisse em legítima defesa, razão pela qual não será admissível a excludente.



A legítima defesa quanto à existência dessa injusta agressão, pode ser: real (agressão real) ou putativa (agressão imaginária).

- **Agressão atual ou iminente:** não se admite a legítima defesa contra agressão passada (vingança) e nem contra agressão futura (mera suposição).

PERGUNTA: O que é a **legítima defesa postergada**? Se o sujeito acabou de ser roubado, mas quando o ladrão vai correr, a vítima vai atrás dele e reage, empurrando o agente e conseguindo o bem de volta. Neste caso, a vítima agrediu o agente em momento posterior, quando a agressão já não era mais iminente e nem mesmo atual. A partir dessa situação, deve-se fazer uma leitura elástica do termo atual. **Entende-se que se esta reação, logo depois da ocorrência do ilícito, é atual, o sujeito ainda age em legítima defesa, pois ele ataca logo em seguida.** Esta é a decisão mais justa, porém é necessário que seja logo após a agressão injusta. Rogério Sanches questiona se é possível a legítima defesa no crime de rixa? Em regra, não, pois as agressões são todas injustas, não havendo que se falar em legítima defesa. Porém, é possível que um dos sujeitos envolvidos extrapole a agressão do conflito pactuado com os demais, admitindo-se que os outros se utilizem da legítima defesa.

- **Proteção de direito próprio ou de outrem:** se agir para defender direito próprio, haverá a legítima defesa própria, sendo o direito de outrem, haverá a legítima defesa de terceiro (*ex persona*). Não se impõe a observância da proporcionalidade entre o bem jurídico injustamente atacado e aquele que foi atingido pelo exercício da legítima defesa. Por exemplo, sujeito está sendo furtado, mas poderá inclusive ceifar a vida do agente. Neste caso, há a relação de vida *versus* patrimônio, podendo ser admitida a legítima defesa.
- **Conhecimento da situação de fato justificante:** é o requisito subjetivo.

A legítima defesa pode ser invocada para repelir injusta agressão de alguém que se encontra acobertado por uma excludente de culpabilidade. Isso porque a excludente de culpabilidade não altera o caráter injusto da conduta (o fato continua sendo típico e ilícito), o que permite a atuação em legítima defesa.

Ex.: O sujeito coloca arma na cabeça do filho do gerente do banco e determina que o gerente adentre o banco e fure cem mil reais. O gerente age mediante coação moral irresistível.

3.2.3. LEGÍTIMA DEFESA E ERRO NA EXECUÇÃO

Havendo erro na execução ocasionado pela legítima defesa, a vítima que foi acertada por erro na execução será considerada como se o indivíduo tivesse acertado o agente criminoso (vítima virtual), de modo que não estaria configurado o crime.

3.2.4. LEGÍTIMA DEFESA RECÍPROCA

Diferentemente do estado de necessidade, **não é possível** legítima defesa contra legítima defesa (recíproca), pois não é possível que duas pessoas ajam uma contra outra em legítima defesa. Para que haja legítima defesa, uma das agressões deve ser injusta. Porém, se duas legítimas defesas são idôneas, não há agressão injusta, não havendo fundamento para a legítima defesa.

3.2.5. LEGÍTIMA DEFESA SUCESSIVA

É o caso em que um sujeito, em legítima defesa, agride outro que havia provocado a agressão injusta, porém **age com excesso**, dando aporte à legítima defesa sucessiva. Portanto, é possível legítima defesa sucessiva.

O sujeito agredido repele a agressão injusta e se excede. Se o sujeito se excede, a agressão passa a ser injusta, isto é, aquele que era inicialmente o agressor passa a ser o agredido, podendo agir em legítima defesa.



3.2.6. LEGÍTIMA DEFESA REAL CONTRA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

Ex.: João, desafeto de José, vai pegar uma carteira de cigarro no bolso, mas José pensa que João sacará uma arma, momento em que José atira em João. Pedro estaria agindo em legítima defesa putativa. Todavia, neste momento, João, tendo recebido disparos contra si, pega a sua arma e revida disparos contra José. Nesta situação, João estaria agindo legítima defesa real contra a legítima defesa putativa de José.

3.2.7. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA RECÍPROCA

É possível que ambos os indivíduos queiram sacar uma carteira de cigarro ou um bilhete, quando João pensa que José sacará uma arma e vice-versa. Neste momento, José saca sua arma e João também saca a sua.

Portanto, é possível que haja uma legítima defesa putativa de uma legítima defesa putativa.

3.3. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL

3.3.1. CONCEITO

O indivíduo age em estrito cumprimento de um dever legal, ou seja, a lei obriga o agente a atuar. O dever legal que fundamenta essa discriminante decorre da lei, mas de **lei em sentido amplo**. Em outras palavras, a conduta do agente estará abarcada por qualquer diploma normativo, com algum grau de abstração. **Ex.:** decreto, regulamento, portaria, etc.

Obs.: Para Zaffaroni, o estrito cumprimento do dever legal não é excludente de ilicitude, mas sim excludente de tipicidade, pois a tipicidade penal para ele deve ser formal e conglobante (tipicidade material + antinormatividade).

3.3.2. REQUISITOS

Além da lei em sentido amplo, a doutrina costuma exigir que esteja presente o **elemento subjetivo**, ou seja, é necessário que o indivíduo tenha a consciência de que está agindo no estrito cumprimento do dever legal.

3.4. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO

3.4.1. CONCEITO

Trata-se de condutas que são facultadas ao cidadão comum, desde que de forma regular. São condutas autorizadas pela lei, como é o caso da prisão em flagrante por particular. **Ex.:** Se o particular segura uma pessoa que acabou de cometer crime, ainda que o indivíduo esteja privando o agente da sua liberdade, estará ele agindo no exercício regular de um direito. E, portanto, não há crime.

Frise-se, o exercício deve ser regular, pois o exercício irregular do direito é ato ilícito.

3.4.2. REQUISITOS

É requisito para que haja o exercício regular de um direito que o exercício seja **proporcional** ou indispensável.

Ademais, é necessário que o indivíduo tenha o **conhecimento** de que age no exercício regular de um direito.



3.5. OFENDÍCULOS

3.5.1. CONCEITO

É o aparato pré-ordenado para defesa do patrimônio. **Ex.:** cacos de vidros nos muros ou pontas de lanças no portão.

3.5.2. NATUREZA JURÍDICA

A doutrina majoritária diz que, enquanto o ofendículo não é acionado, o indivíduo age em **exercício regular de um direito**. Porém, quando é acionado o aparato protetor, a fim de repelir a injusta agressão, o indivíduo agirá em **legítima defesa preordenada**.

3.6. CAUSAS SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE

Há causas supralegais de exclusão da ilicitude, como é o caso do **consentimento do ofendido**.

O consentimento do ofendido não caracterizará sempre uma excludente da ilicitude, podendo ser:

- **Indiferente penal;**
- **Excludente da tipicidade** (quando o dissentimento for elementar do crime, como é o caso do estupro. Neste caso, como o dissentimento é elementar, e caso haja o consentimento, não haverá o crime, não sendo causa supralegal).
- **Excludente da ilicitude**

3.6.1. REQUISITOS DO CONSENTIMENTO COMO CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE

Para que haja a excludente da ilicitude como causa supralegal, é necessário que:

- **O consentimento não seja elementar do crime;**
- **A vítima seja capaz**
- **O consentimento seja válido:** quem consente deve ter, naquele momento, liberdade e consciência para emitir sua vontade;
- **O bem seja disponível:** não é possível que haja o consentimento para bem indisponível. Esta é a grande razão para que eutanásia seja considerada crime, pois a vida é indisponível.
- **Bem próprio:** só se pode consentir se o bem não for de terceiro;
- **Prévio ou simultâneo à lesão ao bem jurídico:** se o consentimento for posterior à lesão, não haverá excludente de ilicitude, ainda que possa haver outras repercussões penais, como é o caso do perdão do ofendido na ação penal privada ou na ação penal pública condicionada à representação, bem como da renúncia, decadência.
- **Consentimento expresso?** A doutrina tradicional ainda diz que o consentimento deve ser expresso, porém a doutrina moderna discorda, dizendo que é admissível o consentimento tácito;
- **Conhecimento da situação de fato que autoriza a justificante:** portanto, é necessário que o agente saiba que está agindo com o consentimento do ofendido.

3.6.2. INTEGRIDADE FÍSICA É BEM JURÍDICO DISPONÍVEL?

A doutrina diverge. A corrente moderna entende que a integridade física é **bem disponível**, pois se fundamenta na Lei 9.099/95, que fez com que a ação penal para os crimes de lesão leve e culposa, os quais eram crimes de ação pública incondicionada, passasse a ser pública condicionada à representação do ofendido.



Portanto, a vítima pode dispor, exercendo ou não o direito, não sendo processado o autor da lesão. Isso subsidia a integridade física como bem disponível.

Todavia, **para que haja a disponibilidade da integridade física**, é necessário observar os seguintes requisitos:

- **lesão corporal de natureza leve;**
- **consentimento não contrário à moral e aos bons costumes, o que exige um juízo de valor.**

3.6.3. CONSENTIMENTO DO OFENDIDO NOS CRIMES CULPOSOS

É possível que haja o consentimento do ofendido nos crimes culposos?

Segundo Rogério Sanches, sim. **Ex.:** o condutor de uma motocicleta propõe a um amigo uma volta de motocicleta, cheia de manobras radicais e perigosas. O amigo aceita a oferta. Um dos indivíduos vai na garupa do outro a fim de promover diversas manobras. Uma hora a motocicleta cai, fazendo com que o amigo sofra lesões corporais leves. Nesse caso, podemos dizer que o bem é disponível. O sujeito consentiu a partir de o momento em que subiu na garupa, sabendo que iria realizar manobras.

Como se vê, o caso fundamenta a excludente supralegal do consentimento do ofendido para o crime de lesão corporal culposa.

3.7. EXCESSO NA JUSTIFICANTE

O art. 23 do CP estabelece que o agente, em qualquer das hipóteses em que agir acobertado por uma excludente da ilicitude, **responderá pelo excesso doloso ou culposo**.

A expressão excesso pressupõe que tenha havido algum momento em que não havia sido excedido o limite. Pressupõe uma situação inaugural de legalidade, seguida de um momento em que se extrapolou a legalidade, cometendo-se excesso.

Segundo a doutrina, o excesso poderá ser:

- **Excesso doloso:** o sujeito se propõe a ultrapassar os limites da justificante. **Ex.:** sujeito, acobertado por uma excludente de ilicitude por um tapa na cara injusto, resolve matar o agressor. É o excesso proposital.
- **Excesso culposo:** o sujeito reage à uma agressão injusta e, ao se defender, extrapola os limites da legítima defesa sem que esta fosse a sua intenção. O indivíduo não observa os cuidados sobre os limites.
- **Excesso acidental:** do ponto de vista penal, é irrelevante, pois não decorre de um fato realizado pelo sujeito, e sim de um caso fortuito ou força maior. **Ex.:** Supondo que o agente esteja repelindo agressão e, neste ato, o agressor, nervoso com aquela situação, por ter tomado um soco, sofre parada cardíaca, um infarto, razão de sua morte. Neste caso, o sujeito não responderá pelo excesso, pois não houve dolo ou culpa, e o Código Penal diz justamente que o sujeito só responderá se agir com excesso doloso ou culposo. O excesso acidental não pode implicar responsabilidade penal de quem agiu.
- **Excesso exculpante:** o sujeito está em um estado anímico que lhe retira a capacidade de atuar racionalmente. Neste caso, o indivíduo não agiu dentro da excludente da ilicitude, porém somente poderia responder se tivesse agido culposamente. Todavia, na situação, sua culpabilidade é afastada, por inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o indivíduo está fora de si. **Ex.:** sujeito, ao retornar para casa, verifica que sua filha de 9 anos de idade está sendo estuprada por um idoso de 75 anos de idade. O sujeito, vendo o idoso estuprar sua filha, agride o idoso, retirando-o de cima de sua filha. No entanto, o pai está em um estado de ânimo tão alterado, e portanto fora de si, que continua a agressão contra o idoso, matando-o. É possível encontrar, nesse caso, apesar de ultrapassados os limites da legítima defesa, uma excludente da culpabilidade.



3.8. DESCRIMINANTE PUTATIVA

Descriminante: aquilo que não é crime; putativa: está somente na cabeça do indivíduo. É a causa excludente da ilicitude imaginária. Neste caso, há dois tipos de erros putativos:

- **Erro de tipo:** o erro recai sobre as circunstâncias fáticas, ou seja, o agente erra sobre os pressupostos da realidade. Exclui o dolo. Se evitável, afasta o dolo, mas o sujeito responde pelo crime culposos; se inevitável, exclui dolo e culpa (*vide Aula 04*).
Ex.: José pega a carteira de João achando que é a sua, coloca-a no bolso e vai embora. José está acobertado por um erro de tipo.
- **Erro de proibição (indireto):** o agente erra sobre a existência de uma norma penal proibitiva. O sujeito fica isento de pena, se inevitável, ocorrendo a exclusão da culpabilidade; se evitável, o sujeito terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3.
Ex.: Sujeito que tem 18 anos e que mantém relação sexual com a sua namorada de 13 anos, mas que desconhece estar cometendo o crime de estupro de vulnerável, porque a adolescente e a família consentem.

3.8.1. ERRO QUANTO À EXISTÊNCIA DA DESCRIMINANTE

Apesar de o sujeito conhecer a situação de fato, não sabe que o comportamento é ilícito. Por conta disso, o indivíduo, ao tomar um soco injustamente, resolve revidar com um tiro, achando que estaria amparado pela legítima defesa. O indivíduo sabe o que está fazendo, bem como tem o conhecimento da circunstância fática, mas **o equívoco do sujeito é sobre a existência de uma discriminante putativa**.

3.8.2. ERRO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS (DESCRIMINANTE PUTATIVA POR ERRO DE TIPO)

Neste caso, **o indivíduo tem uma errada compreensão da norma, não sabe o que está acontecendo na realidade, imaginando situação de fato que, na realidade, não existe**. Isso pode ocorrer quando alguém saca a carteira do bolso, mas o outro indivíduo pensa que se trata de arma, hipótese em que reage, agindo em legítima defesa putativa. O erro é quanto à situação de fato.

O equívoco do agente neste caso deve ser tratado como um erro de tipo ou de proibição?

1ª Corrente: para a teoria extremada da culpabilidade, o erro sobre os pressupostos fáticos nas causas justificantes deve ser considerado como erro de proibição. O fundamento está no fato de que o art. 20, §1º, CP, quando o erro é inevitável, o agente está isento de pena, ou seja, a isenção é da pena, havendo crime.

Crítica: o CP, em outras passagens, fala em isenção de pena quando, na verdade, não existe crime. Este argumento da teoria extremada da culpabilidade não se sustenta, portanto, esta teoria NÃO É A ADOPTADA.

2ª Corrente: a teoria limitada da culpabilidade, que é a prevalente, estabelece que, no caso em que a discriminante putativa se dá em razão dos pressupostos fáticos, há erro de tipo. Isso porque, se ele for inevitável, excluirá o dolo e a culpa, apesar de a lei dizer que o agente é isento de pena, eis que esta é apenas uma consequência. Se o agente não age com dolo ou com culpa, não pode ser penalizado. Tanto é que essa é a ideia que o próprio CP ao dizer que, se o erro for evitável, o indivíduo responderá a título de crime culposos, consequência do erro de tipo, e do erro de proibição. O erro de tipo repercute na conduta do sujeito se ela for dolosa ou culposa. Esta é denominada culpa imprópria. Imprópria porque o sujeito mata dolosamente, mas acredita estar em legítima defesa. Em razão de política criminal, pune-se o sujeito a título culposos, em vez de responsabilização dolosa.

Lembre-se: a culpa imprópria admite tentativa, pois é um delito intencional. **Ex.:** o sujeito mata porque quer matar, se não alcançar o resultado morte, terá sido por circunstâncias alheias à sua vontade.



3ª Corrente: a teoria extremada sui generis estabelece que o art. 20, §1º, do CP, é uma figura híbrida, eis que haveria uma fusão das duas teorias. Dessa forma, quando o erro é inevitável adota-se a teoria extremada da culpabilidade, ou seja, o sujeito é isento de pena. Por outro lado, quando o erro é evitável, adota-se a teoria limitada da culpabilidade, eis que o sujeito é punido por um crime culposos.

Prevalece a teoria limitada da culpabilidade, sendo um erro de tipo.

CAPÍTULO 13 — TEORIA GERAL DO CRIME: CULPABILIDADE

1. CONCEITO

É o terceiro substrato do conceito analítico do crime. **Culpabilidade é um juízo de reprovação. Este juízo recai sobre a conduta típica e ilícita que o agente realizou** (teoria tripartite).

Para quem adota o conceito bipartite do crime, a culpabilidade não seria substrato do crime, mas seria um pressuposto de aplicação da pena. No entanto, para a maioria da doutrina é o terceiro substrato do crime.

A culpabilidade reprova a conduta do autor que cometeu um fato típico e ilícito. **A reprovação advém da possibilidade que o autor teria de atuar conforme o direito**, porém optou livremente por se comportar de maneira contrária ao ordenamento. A partir dessa ideia, que justifica a reprovabilidade do comportamento do autor, é que serão extraídos os elementos da culpabilidade.

2. TEORIAS DA CULPABILIDADE

É necessário entender as teorias adotadas pela doutrina:

- **teoria psicológica da culpabilidade**
- **teoria psicológica-normativa**
- **teoria normativa pura**

2.1. TEORIA PSICOLÓGICA DA CULPABILIDADE

A culpabilidade consiste na **relação psíquica entre autor e resultado**. A culpabilidade se confunde com o dolo e com a culpa. A culpabilidade possui como espécies a culpabilidade-dolo e a culpabilidade-culpa.

Para esta teoria, o **dolo seria normativo**, isto é, o sujeito tem consciência da ilicitude de sua conduta.

No caso dessa teoria psicológica da culpabilidade, **a imputabilidade é mero pressuposto da culpabilidade, não sendo um elemento**.

2.2. TEORIA PSICOLÓGICA-NORMATIVA

A teoria psicológica-normativa entende que a culpabilidade possui um caráter psicológico, sendo dolo e culpa elementos da culpabilidade, e não mais espécies. Para essa teoria, juntamente como o **dolo (normativo – em que o sujeito tem consciência atual da ilicitude) e a culpa**, também é necessário que haja **imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa**.

Há um avanço em relação à teoria psicológica. O dolo na teoria psicológica-normativa ainda é **normativo**, estando dentro da culpabilidade.

2.3. TEORIA NORMATIVA PURA (EXTREMADA)

A teoria normativa pura da culpabilidade, inspirada no finalismo de Hans Welzel, vai dizer que a culpabilidade é composta dos seguintes elementos:

- imputabilidade
- exigibilidade de conduta diversa
- potencial consciência da ilicitude

O dolo e a culpa migram para o fato típico, tornando o dolo natural.



Perceba que, agora, a culpabilidade é normativa, pois não há qualquer elemento psicológico na culpabilidade. Dolo e culpa estão no fato típico.

A teoria adotada no Brasil é a teoria limitada da culpabilidade.

Essa teoria tem as mesmas premissas da teoria normativa pura (extremada), porém há uma ressalva quanto às descriminantes putativas sobre os pressupostos fáticos. Isso porque a teoria limitada da culpabilidade vai dizer que é erro de tipo, razão pela qual a doutrina adota a teoria limitada.

3. COCULPABILIDADE

A teoria da coculpabilidade estabelece que o Estado tem parcela de responsabilidade nos fatos realizados por criminosos que não tiveram acesso à escola, saúde, à oportunidade, tendo trilhado o caminho do crime.

Para essa teoria, o Estado deve também ser responsabilizado pelos agentes estarem cometendo delitos por conta da desigualdade social.

O CP não adota expressamente a teoria da coculpabilidade, mas é possível aplicá-la por meio do art. 66 do CP, que diz a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

4. COCULPABILIDADE ÀS AVESSAS

Atente-se à coculpabilidade às avessas.

Se a coculpabilidade significa um menor grau de reprovabilidade do comportamento daquele sujeito que não teve oportunidade, a coculpabilidade às avessas vai significar uma maior reprovabilidade do comportamento do sujeito que teve todas as oportunidades de seguir pelo caminho da licitude.

E, portanto, a coculpabilidade às avessas adota uma postura crítica quanto à seletividade do direito penal. Ela vai dizer que o direito penal do jeito que está resta equivocado, pois há abrandamento no tocante aos delitos praticados por pessoas com alto poder econômico social. **Ex.:** abrandamento é o pagamento do crédito tributário que extingue a punibilidade.

Outra crítica que ela faz é no sentido de que o sistema é feito de maneira a se mostrar mais gravoso para as pessoas com menores condições. Basta olhar para a Lei de Contravenções Penais e compreender que vadiagem e mendicância são atos cometidos por aqueles que são marginalizados e não possuem condições de prover o seu próprio sustento (trata-se de punição ao sujeito pelo que ele é, e não pelo o que ele faz).

A partir daí, começam a ser tipificadas condutas de pessoas que não tiveram acesso ao ensino, saúde e educação de qualidade. Por isso, há uma coculpabilidade às avessas ao indivíduo que, a par de todas as oportunidades, decidiu ingressar no mundo do crime.

A maior reprovabilidade da coculpabilidade às avessas **não possui previsão legal**. Além disso, não é possível sua aplicação, eis que **não se admite analogia in malam partem no Direito Penal**.

Todavia, o magistrado, quando da dosimetria da pena, poderá considerar um maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, nas circunstâncias do art. 59 do CP, devendo haver algo específico para que a pena seja fixada acima do mínimo legal. Mas, em nenhum momento, poderá considerar a coculpabilidade às avessas como agravante.

5. CULPABILIDADE DO AUTOR OU CULPABILIDADE DO FATO

A doutrina alemã levanta uma questão: a culpabilidade é do autor ou a culpabilidade é do fato?

Prevalece, na doutrina, que **o direito penal brasileiro adotou a culpabilidade do fato**. Apesar de o objeto da censura ser o agente, ele é censurado pelo que ele fez, e não pelo que ele é. E, portanto, a culpabilidade é do fato.



6. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE

São elementos da culpabilidade:

- imputabilidade
- exigibilidade de conduta diversa
- potencial consciência da ilicitude

6.1. IMPUTABILIDADE

6.1.1. CONCEITO E ELEMENTOS DE IMPUTABILIDADE

Imputabilidade é a capacidade de imputação de o sujeito ser responsabilizado pelos seus atos.

São dois os elementos que devem estar presentes para que o sujeito tenha imputabilidade:

- **Elemento intelectual:** o sujeito deve ter higidez psíquica, consciência do caráter ilícito do fato;
- **Elemento volitivo:** tendo consciência, o sujeito tem vontade de praticar o fato, dominando a sua vontade.

Ou seja, ele compreende o caráter ilícito do fato e é capaz de dominar a sua vontade de acordo com esse entendimento.

6.1.2. CRITÉRIOS DA IMPUTABILIDADE

São **critérios para aferição** da imputabilidade:

- **Crítério biológico:** leva-se em conta apenas o **desenvolvimento mental** e a **idade** do agente. Se o sujeito é doente mental, ele é inimputável, bastando isso. Adotado para o menor de 18 anos, considerando-se que este possui desenvolvimento mental incompleto e, portanto, é inimputável.
- **Crítério psicológico:** considera-se apenas **se o agente ao tempo da conduta tinha capacidade de entendimento e de autodeterminação**. Deve-se analisar se, ao tempo da conduta, o agente tinha capacidade para entender a ilicitude do fato e determinar o seu comportamento de acordo com esse entendimento. Não adotado.
- **Crítério biopsicológico:** para este critério, considera-se inimputável aquele que, **em razão da sua condição mental** (doente mental, ou desenvolvimento mental incompleto), era, ao tempo da conduta, **inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento**. Portanto, não basta que o agente tenha a doença mental, é necessário que essa doença mental tenha sido capaz de comprometer o seu entendimento ou o seu comportamento a partir desse entendimento.

No Brasil adota-se o critério conforme a causa da **inimputabilidade**.

6.1.3. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA CAPACIDADE MENTAL DO AGENTE

O art. 26 do CP estabelece que a incapacidade de imputação é percebida por aquele agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, percebe-se que o **critério adotado foi o biopsicológico**, devendo o agente ter a doença e não poder se determinar ou entender o caráter ilícito do fato.

Doente mental pode ser considerado imputável, desde que não haja o comprometimento sobre entender o caráter ilícito do fato e de se comportar de acordo com esse entendimento. Por isso é que o sujeito, mesmo que acometido por doença mental, se praticar o crime num momento de lucidez, será imputável.



O **inimputável**, salvo se menor de idade, será denunciado, processado, mas **não será condenado**, será processado e absolvido imprópriamente. Supondo-se que o agente tenha cometido o fato análogo ao crime, neste caso, o agente receberá uma sanção penal, denominada medida de segurança com natureza de tratamento. Esta é a denominada **absolvição imprópria**.

Já o **semi-imputável**, por outro lado, segundo o art. 26, parágrafo único, do CP, estabelece que se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, **não era inteiramente capaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, este sujeito será condenado, mas a **sua pena será reduzida de 1/3 a 2/3**.

Ou seja, o semi-imputável terá sua pena reduzida, porém, **é possível que o magistrado perceba que, para ele, é mais indicado que se submeta a uma medida de segurança**. Veja, o juiz poderá modificar a redução da pena por uma medida de segurança, mas, ainda assim, a sentença continuará sendo condenatória.

Atenção: somente deve ser pena **ou** medida de segurança, e não pena **e** medida de segurança. **Nós adotamos o sistema vicariante ou unitário**. O Brasil não mais adota o sistema do duplo binário.

6.1.4. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA IDADE

O art. 27 do CP estabelece que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

Se o indivíduo é menor de 18 anos, ficam desprezados os critérios que levam em conta a capacidade de o agente compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Adota-se o **critério biológico**. Há uma presunção absoluta de que o desenvolvimento mental é incompleto neste caso.

O sujeito alcança a maioridade no **primeiro minuto do dia em que faz aniversário**.

6.1.5. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ

A inimputabilidade pode se dar em razão da embriaguez.

Embriaguez é uma intoxicação causada pelo álcool ou uma substância que tenha efeitos análogos ao álcool.

A embriaguez pode ser classificada como:

- **embriaguez não acidental**
- **embriaguez acidental**

A) EMBRIAGUEZ NÃO ACIDENTAL

A embriaguez não foi um acidente, mas causada voluntariamente ou culposamente:

- **embriaguez voluntária**: é aquela que se dá quando o sujeito tem a intenção de se embriagar;
- **embriaguez culposa**: é aquela em que o indivíduo se embriaga por negligência ou imprudência.

O sujeito começa a beber e não tem o cuidado necessário, passando a ficar embriagado.

A embriaguez voluntária e a culposa podem ser completas ou incompletas:

- **embriaguez completa**: retira do sujeito a capacidade de entendimento e de autodeterminação.
- **embriaguez incompleta**: neste caso, não retira a capacidade, mas diminui a capacidade de entendimento e de autodeterminação.

A embriaguez não acidental (voluntária ou culposa) **jamaís exclui a imputabilidade**, ainda que seja completa, mesmo que retire a capacidade de autodeterminação e entendimento. Isso porque, nessa hipótese, o Código Penal adota a **teoria *actio libera in causa*** (a ação era livre na causa).



B) EMBRIAGUEZ ACIDENTAL

Trata-se da embriaguez causada por conta de um **caso fortuito ou força maior**. **Ex.:** quando alguma substância é colocada na bebida do sujeito, sem o seu conhecimento, levando-o à embriaguez causada dos fatores externos à sua vontade.

Poderá ser:

- **embriaguez completa:** neste caso, haverá isenção de pena, conforme art. 28, §1º, CP;
- **embriaguez incompleta:** se apenas diminuir a capacidade de entendimento, não haverá a isenção de pena, mas a pena do agente será reduzida de 1/3 a 2/3 (art. 28, §2º, CP).

A embriaguez pode ainda ser classificada como:

- **embriaguez patológica:** é uma doença, ou seja, o sujeito pode ser considerado inimputável ou semi-imputável, mas em razão da doença.
- **embriaguez preordenada:** visa conferir coragem ao indivíduo para praticar o crime; o sujeito ingere bebida com a finalidade de cometer o delito. Neste caso, o art. 61, II, "I", do CP estabelece que a embriaguez preordenada é uma agravante do crime.

A embriaguez será punida, mesmo nos casos em que ela é completa.

O fundamento disso é a **teoria da *actio libera in causa***. Essa teoria estabelece que o ato revestido de inconsciência, que é aquele que se dá quando a embriaguez está completa, decorre de um ato anterior consciente.

Ato anterior: é o momento da ingestão da bebida alcoólica, pois o agente era livre na sua vontade. Portanto, deve o aplicador do direito transferir para o momento anterior à conduta delitiva, ou seja, para o momento da decisão de ingerir a bebida alcoólica, a análise sobre a existência de imputabilidade e voluntariedade, se o sujeito quis ou não se embriagar.

Percebe-se que o dolo e a culpa somente serão analisados no momento originário da ingestão da bebida alcoólica. Ou seja, não há responsabilidade penal objetiva, ao contrário do que a minoria da doutrina estabelece.

Isso porque, se o sujeito decidiu beber, e bebeu prevendo o resultado, como é o caso em que o indivíduo bebe para matar outra pessoa, ele responderá pelo crime. O mesmo ocorre se o sujeito estiver bebendo e prever que, se continuar bebendo, poderá matar uma pessoa, mas ignora tal condição, assumindo o risco do resultado (dolo eventual).

Por outro lado, se o sujeito decidiu beber, e o resultado era previsível, mas o sujeito não previu, haverá culpa inconsciente. De outra forma, se o sujeito decidiu beber, o resultado era previsível, o sujeito previu, mas sinceramente não acreditou que poderia gerar o resultado, haverá culpa consciente.

Pergunta: Se, ao tempo em que o agente decidiu beber, a conduta posterior fosse imprevisível, o sujeito teria cometido crime? NÃO. O dolo e a culpa somente serão analisados no momento originário da ingestão da bebida alcoólica. Trata-se de **fato atípico**, pois o direito penal não admite a responsabilidade penal objetiva.

6.1.6. IMPUTABILIDADE DO ÍNDIO NÃO INTEGRADO

Rogério Sanches lembra que a **condição do índio não integrado não gera presunção de incapacidade penal**. É possível que se analise, a partir do caso concreto, que o indivíduo não tinha potencial consciência da ilicitude ou que não lhe era exigível uma conduta diversa. Todavia, não se pode estabelecer a priori que ele seja inimputável por ser índio.

6.1.7. EMOÇÃO E PAIXÃO

A emoção e a paixão não isentam de pena, não excluem a responsabilidade do réu.

Emoção é um súbito sentimento, ocorrido na hora. Paixão é um sentimento crônico e duradouro.



A emoção poderá funcionar como uma **atenuante** ou mesmo como uma **causa de diminuição de pena**, como no homicídio privilegiado.

A paixão, no entanto, se funcionar como uma patologia, poderá significar que o sujeito seja semi-imputável, ou mesmo inimputável.

Todavia, via de regra, emoção e paixão **não** excluem a responsabilidade penal.

6.2. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE

6.2.1. CONCEITO

A potencial consciência da ilicitude afere se o sujeito possui condições de compreender que a sua conduta é reprovável.

É, como regra, a **análise daquele que desconhece a lei**, mas tem a consciência de que seu comportamento é ilícito, ainda que desconheça o dispositivo legal. Essa possibilidade de compreender é a potencial consciência da ilicitude.

Essa valoração feita na esfera do sujeito que não é operador do direito é denominada de **valoração paralela na esfera do profano**. O juiz promove uma valoração paralela, fora da sua própria, diante do profano, ou seja, diante daquele que não conhece o direito (leigo). Esse é o critério usado para aferir se a pessoa possui potencial consciência da ilicitude. A valoração paralela na esfera do profano exige apenas que o indivíduo tenha condições de conhecer o caráter ilícito do fato que pratica, conhecendo a antissocialidade, imoralidade ou lesividade da conduta.

6.2.2. ERRO DE PROIBIÇÃO

No erro de proibição, há uma **causa que exclui a potencial consciência da ilicitude** ou, ao menos, que tenha a possibilidade de excluir.

O art. 21 do CP diz que o desconhecimento da lei é inescusável. Todavia, o erro sobre a ilicitude do fato (não saber que o fato é ilícito), sendo este erro inevitável, isenta de pena. Por outro lado, se este erro for evitável, **haverá redução da pena de 1/6 a 1/3**.

O erro de proibição é o desconhecimento de que a conduta realizada é proibida pelo ordenamento jurídico.

Para aferir se o erro é inescusável ou escusável, a doutrina estabelece que se deve analisar as características pessoais do agente, como a idade, grau de instrução etc.

6.2.3. ESPÉCIES DE ERRO DE PROIBIÇÃO

O erro de proibição é dividido em espécies:

- **Erro de proibição direto:** o sujeito se equivoca **quanto à existência de uma norma proibitiva, ou ignora a existência do tipo incriminador**, ou não conhece completamente o seu conteúdo. **Ex.:** sujeito maior que pratica relação sexual com sua namorada de 13 anos que consente; marido que estupra a mulher sabendo que ela não quer praticar relação sexual, aquele pensa estar acobertando por um exercício regular do direito; holandês, habituado a consumir maconha no seu país de origem, acredita ser possível utilizar a mesma droga no Brasil, equivocando-se quanto ao caráter proibido da sua conduta; o sujeito que pesca em período em que a pesca é proibida.
- **Erro de proibição indireto:** o agente sabe que a conduta é típica, mas supõe presente uma norma permissiva, ora supondo existir uma causa excludente da ilicitude, ora supondo estar agindo nos limites da discriminante. O sujeito viola uma norma permissiva, pois ele acredita que está agindo acobertado por uma norma permissiva, mas na verdade não está observando



esta norma. Há uma descriminante putativa por erro de proibição. O sujeito sabe o que está fazendo, mas age com uma conduta permissiva ou por uma causa excludente da ilicitude, a qual, na verdade, inexistente. Ex.: sujeito descobre que a mulher está lhe traindo, chega em casa e acredita que está amparado pela legítima defesa da honra.

6.3. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

6.3.1. CONCEITO

Exigibilidade de conduta diversa é a possibilidade de agir de acordo com o ordenamento jurídico, contrária àquela que o agente tomou.

Segundo o art. 22, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

6.3.2. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

A coação irresistível é uma excludente da culpabilidade.

São **elementos** da coação moral irresistível:

- **coação moral:** a coação é moral, pois se a coação for física, haverá exclusão da tipicidade, pois não haverá mais conduta;
- **coação irresistível:** se a coação for resistível, o coacto responde pelo crime do coator, mas com uma atenuante, enquanto o coator responderá com uma agravante.

Nesse caso, o coator responderá pelo delito, pois é o autor mediato. Ademais, o coator responderá pelo crime que coagiu em concurso material com o crime de tortura. Isso porque a lei de tortura diz que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa (art. 1º, I, “b”, Lei 9.455/97).

O coator responde pelo ato que o coagido praticou, bem como com o crime de tortura em concurso material.

6.3.3. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA

No caso da obediência hierárquica, os requisitos são:

- **Ordem de um superior hierárquico de uma relação pública:** no caso de subordinação doméstica, eclesástica, não há este excludente de culpabilidade, podendo até configurar uma inexigibilidade de conduta diversa, mas via de regra não há.
- **Não pode ser manifestamente ilegal:** esta ordem não pode ser manifestamente ilegal. Do contrário, o subordinado também responderá pelo crime, com a presença da atenuante, e o expedidor da ordem uma agravante. Neste caso, completos os requisitos, só o expedidor da ordem que irá responder pelo crime.
- **Estrita obediência à ordem:** se o subordinado se excede na ordem, ele responderá. Do contrário, apenas o autor da ordem responderá, funcionando como autor mediato.

6.3.4. DIRIMENTES SUPRALEGAIS

As dirimentes supralegais são as condutas inexigíveis, sendo exemplos:

- **Cláusula de consciência:** o sujeito que, por motivo de crença ou consciência, pratica um fato previsto como crime, desde que não viole direito fundamental, age com a cláusula de consciência, sendo uma cláusula suprallegal, que é inexigibilidade de conduta diversa. **Ex.:** o pai



que é testemunha de Jeová veda a transfusão de sangue ao filho. No entanto, esta conduta somente será válida se o filho sobreviver. Caso não sobreviva, o pai deverá responder, pois, neste caso, há o conflito entre liberdade de crença versus vida.

- **Desobediência civil:** desobediência é um ato de insubordinação, o qual possui a finalidade de transformar a ordem estabelecida, demonstrando a injustiça e promover o reconhecimento do *status a quo*. Primeiro, é necessário que o sujeito esteja desobedecendo com base num direito fundamental que ele tenha, e que o dano causado em razão dessa desobediência não seja relevante.

Ex.: invasão do MST. É direito de propriedade é direito fundamental, mas a ação do MST não poderá causar dano relevante, pois, se causar, não poderá dizer que se trata de causa excludente da culpabilidade.



CAPÍTULO 14 — TEORIA GERAL DO CRIME: PUNIBILIDADE

1. CONCEITO

Punibilidade é a possibilidade de punir alguém. Pode-se dizer que é o direito de o Estado aplicar uma sanção penal em alguém, desde que haja previsão em uma norma penal incriminadora.

Isso quer dizer que punibilidade **não integra do conceito analítico de crime**.

2. CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE

Inicialmente, nasce o direito de punir do Estado, que, por uma das causas previstas no art. 107, irá se extinguir (causas extintivas da punibilidade):

- morte do agente;
- anistia, graça ou indulto;
- retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
- prescrição, decadência ou perempção;
- renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;
- retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;
- perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Trata-se de um rol meramente **exemplificativo**. Afora as causas legais de extinção da punibilidade, é possível que haja causas supraleais de extinção da punibilidade.

Exemplo: A súmula 554 do STF estabelece que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, **após o recebimento da denúncia**, não obsta a continuação da ação penal. Isso significa dizer que **o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos antes do recebimento da denúncia obsta a ação penal**. É uma **causa supraleal de extinção da punibilidade**.

Diferenças das causas extintivas da punibilidade de causas de exclusão da punibilidade e das condições objetivas de punibilidade:

- **Causa extintiva da punibilidade** significa que o direito de punir do Estado convalida por alguma causa especificada em lei ou de forma supraleal. **Ex.:** na ação penal privada, o sujeito tem 6 meses para oferecer queixa-crime. Caso não ofereça, haverá decadência.
- **Causa de exclusão da punibilidade:** o direito de punir sequer nasce, jamais surge. É sinônimo de escusa absolutória. **Ex.:** furto praticado filho contra o pai de 50 anos de idade. Para o direito penal, o direito de punir não surge em momento algum.
- **Condições objetivas de punibilidade:** existe o direito de punir, porém não pode ser exercido até que uma condição se implemente. Trata-se de um evento futuro e incerto, que pode ou não ocorrer. A condição precisa ser implementada para que seja possível punir aquele sujeito. **Ex.:** nos crimes falimentares, a decretação da falência é uma condição objetiva de punibilidade; quando o crime é cometido no estrangeiro, para que seja punível no Brasil, será necessário que o fato também seja punível no estrangeiro.

2.1. MORTE DO AGENTE

A morte do agente extingue a punibilidade, pois é o fim da personalidade jurídica.

Com a morte, **desaparecem os efeitos penais principais e acessórios** (primários e secundários).

Os **efeitos civis (extrapenais) podem permanecer**, e os herdeiros poderão responder nos limites da herança. **Ex.:** Reparação de danos.

Segundo o art. 62 do CPP, a morte é comprovada por meio da **certidão de óbito**. Esta certidão original deve ser juntada aos autos.



Mirabete, Sanches e os Tribunais Superiores entendem que a decisão que transitou em julgado declarando extinta a punibilidade será considerada **inexistente**, de forma que o sujeito poderá ser punido pelo crime que em tese cometeu. É a que prevalece.

No entanto, para Damásio de Jesus e Fernando Capez, se a **certidão de óbito é falsa** e houve o trânsito em julgado da sentença declaratória de extinção da punibilidade, somente cabe ao Estado punir o indivíduo por uso de documento falso.

Já a **morte da vítima, como regra, não extingue a punibilidade do réu**, salvo no caso de ação penal privada personalíssima, caso do crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento (art. 236, CP).

2.2. ANISTIA, GRAÇA E INDULTO

São formas de renúncia do Estado ao seu direito de punir.

2.2.1. ANISTIA

A anistia se dá por **meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional**, por razões de clemência, sociais e políticas. A anistia apaga os **efeitos penais**, mas os **extrapenais persistem**, isto é, o sujeito não é mais considerado reincidente, não tem mais pena para cumprir, mas a obrigação de indenizar persiste.

A anistia se classifica em:

- **anistia própria:** ocorre antes da condenação.
- **anistia imprópria:** ocorre depois a condenação.
- **anistia irrestrita:** todos são beneficiados.
- **anistia restrita:** atingem certas pessoas que se enquadram em certas condições.
- **anistia condicionada:** a lei impõe requisito para anistiar, não se trata de uma simples questão pessoal. **Ex.:** obrigação de reparar o dano.
- **anistia incondicionada:** não impõe qualquer requisito para anistiar.
- **anistia comum:** incide sobre crimes comuns.
- **anistia especial:** incide sobre crimes políticos.

2.2.2. GRAÇA E INDULTO

São formas de renúncia do direito de punir do Estado.

Graça e indulto são concedidos **pelo presidente da república por decreto presidencial**. Todavia, o presidente poderá delegar aos Ministros de Estado, Procurador-Geral da República e ao Advogado Geral da União.

Tanto o indulto quanto a graça apagam apenas os **efeitos executórios da condenação**, ou seja, o sujeito para de cumprir pena. Porém, subsistirá o crime, a condenação, e os **efeitos penais secundários, como a reincidência. Os efeitos extrapenais também são mantidos**.

De acordo com a Súmula 631-STJ, aprovada no dia 24/04/2019, *o indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais*.

Portanto, o indulto e a graça impedem apenas os efeitos executórios da pena.

Diferenças entre graça e indulto:

- **Graça:** é individual e depende de provocação do interessado ao Presidente da República.
- **Indulto:** benefício coletivo que não depende de provocação do interessado. **Ex.:** indulto natalino. Segundo o STJ, o benefício da comutação de penas previsto no Decreto de indulto natalino deve ser negado quando o apenado tiver praticado falta disciplinar de natureza grave



nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto de concede o indulto, mesmo que a respectiva decisão homologatória tenha sido proferida posteriormente. Assim, **não terá direito de comutação de pena, o apenado que praticar falta grave no lapso de 12 meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial, desde que homologada a falta, ainda que a decisão seja posterior ao Decreto.**

Classificam-se o indulto e a anistia em:

- **plenos:** extinguem totalmente a pena;
- **parciais:** há comutação da pena, diminuindo a pena;
- **condicionados:** impõem condições para o indivíduo ser beneficiado. **Ex.:** ressarcimento do dano.
- **incondicionados:** não impõe qualquer requisito.

2.2.3. ANISTIA, GRAÇA E INDULTO E OS CRIMES HEDIONDOS

A CF veda a anistia e graça aos crimes hediondos e aos crimes equiparados a hediondos. No entanto, a lei 8.072/90 diz que **os crimes hediondos e equiparados são insuscetíveis de anistia, graça e indulto.**

O STF já decidiu que ampliação feita pela Lei 8.072/90 é constitucional. Posicionamento razoável, uma vez que o indulto nada mais é do que uma graça coletiva.

2.3. ABOLITIO CRIMINIS

Abolitio criminis é o fato que deixa de ser considerado criminoso.

Haverá a **cessação dos efeitos penais (principais e acessórios)**, mas não quer dizer que não seja mais ilícito civil. **Ex.:** adultério deixou de ser crime, mas ainda é uma violação ao dever de fidelidade do casamento.

2.4. DECADÊNCIA

Decadência é a perda do direito de ação pela consumação do tempo.

O sujeito, nesse tempo, deveria ter oferecido queixa-crime ou apresentado representação, mas como não o fez, foi extinta a punibilidade.

O prazo para oferecimento da queixa-crime e da representação é de **6 meses, a contar do dia em que a vítima tomou conhecimento de quem foi o autor** do fato criminoso.

Obs.: Existem crimes de **ação penal privada subsidiária da pública**, nos quais, a vítima terá 6 meses para oferecer a queixa, que são contados a partir do esgotamento do prazo do Ministério Público (tendo o *parquet* quedado-se inerte, a vítima passa a poder propor a ação penal, sendo este o caso de legitimidade concorrente). **Não oferecida a queixa, não haverá extinção da punibilidade.** Ressalte-se que na ação penal privada subsidiária da pública, a decadência não gera a extinção da punibilidade.

Havendo **coautoria**, a ação penal pública condicionada à representação terá o prazo de 6 meses, **a contar do conhecimento do nome de um dos autores.**

Caso a **vítima seja menor de 18 anos, não haverá o termo inicial da contagem do prazo.** Neste caso, o exercício do direito de ação será realizado pelo representante da vítima, salvo se houver um conflito de interesses. Em outras palavras, até os 18 anos, a vítima é representada pelo seu representante legal. Caso o representante não ingresse com a representação, a vítima poderá representar a partir do momento em que completar 18 anos, correndo a partir desse momento o prazo de 6 meses.



2.5. PEREMPÇÃO

Perempção é uma sanção processual ao sujeito que se mostra inerte e desidioso.

A perempção incide **somente sobre as ações penais privadas**, ou seja, somente recairá sobre a ação penal privada exclusiva ou sobre a ação penal privada personalíssima.

Não é em todas as ações penais privadas que irá haver perempção. Isso porque na **ação penal privada subsidiária da pública não haverá a perempção**. Neste caso, o MP retomará a titularidade da ação.

São **hipóteses** de perempção:

- querelante deixar de promover o andamento do processo **durante 30 dias seguidos**, salvo se houver motivo justo. **Ex.:** audiência marcada para dois meses, o querelante não terá que fazer nada durante os 60 dias;
- falecimento do querelante, ou sobrevivendo sua incapacidade, e ninguém comparecer para dar seguimento ao processo, **dentro do prazo de 60 dias**;
- **querelante deixar de comparecer, injustificadamente**, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou **deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais**;
- quando o **querelante pessoa jurídica se extinguir sem deixar sucessor**.
- **recurso da defesa e o querelante não apresentar contrarrazões recursais**: não está prevista em lei, mas na jurisprudência.

Em havendo dois querelantes, caso um deles seja desidioso, haverá apenas perempção para um dos querelantes, não sendo o outro prejudicado.

2.6. PRESCRIÇÃO

É a perda da pretensão punitiva ou da pretensão executória. Essa perda ocorre em razão de o titular (Estado) ter perdido o direito de punir ou de executar.

A prescrição deve ser conhecida de ofício pelo magistrado.

2.6.1. DIFERENÇA ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Decadência: atinge o direito de ação e ocorre em ação penal privada ou em ação penal pública condicionada a representação.

Prescrição: atinge o direito de punir ou o direito de executar uma punição e poderá ocorrer em qualquer ação, seja pública ou privada.

2.6.2. HIPÓTESES DE IMPRESCRITIBILIDADE

A CF consagra alguns crimes imprescritíveis:

- racismo (Lei 7.716/89)
- ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou contra o estado democrático de direito

Não pode o legislador ordinário ou constituinte derivado reformador criar novas hipóteses de imprescritibilidades. Até porque seria um direito fundamental do indivíduo de que os crimes fossem prescritíveis, isto é, o Estado deve agir dentro do tempo razoável. Isso é o que garante segurança jurídica.

2.6.3. ESPÉCIES DE PRESCRIÇÃO

A prescrição poderá ser:

- **prescrição da pretensão punitiva**: antes do trânsito em julgado. Extingue o direito de punir.



- **prescrição da pretensão executória:** após o trânsito em julgado. Extingue o direito de executar. Os efeitos penais secundários continuam vigentes. Ex.: reincidência.

A prescrição da pretensão punitiva poderá se dividir em:

- prescrição propriamente dita em abstrato
- prescrição superveniente
- prescrição retroativa
- prescrição virtual ou antecipada

No entanto, os Tribunais Superiores não admitem a prescrição virtual ou antecipada, conforme dispõe a Súmula 438, do STJ.

A) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO

– *Lapso temporal da prescrição*

Para descobrir o lapso temporal, é necessário **pegar a pena máxima cominada ao delito** e verificar o rol do art. 109 do CP, que estabelece que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, verifica-se:

- em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano.
- em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2anos;
- em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4anos;
- em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8anos;
- em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12anos;
- em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12 anos;

– ***Causas de aumento e de diminuição, qualificadoras, agravantes e atenuantes para fins de prescrição***

Para verificar a pena máxima, é necessário analisar as penas máximas das qualificadoras e considerar as causas de diminuição e aumento de pena. Para o caso de diminuição, deve-se levar em conta a menor diminuição, e, para o caso de aumento, o maior aumento. Trata-se de aplicação da **teoria da pior das hipóteses**.

Não se levam em conta as atenuantes e agravantes, bem como as circunstâncias judiciais, pois não têm o condão de aumentar ou diminuir o máximo da pena.

ATENÇÃO 1: as atenuantes da menoridade e da senilidade são relevantes **para a prescrição da pretensão punitiva** quando o agente for **menor de 21 anos, na data do fato**, ou **maior de 70 anos, na data da sentença**, eis que, neste caso, segundo o art. 115 do CP, **os prazos de prescrição serão reduzidos pela metade**.

ATENÇÃO 2: no caso de agravante da reincidência, o prazo prescricional da pretensão punitiva não é alterado, mas a prescrição da pretensão executória tem o seu *quantum* aumentado em 1/3.

– *Começo do prazo prescricional*

A partir do momento em que acabou a atividade criminosa (art. 111 do CP).

Ou seja, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, **começa a correr**:

- **do dia em que o crime se consumou;**
- no caso de tentativa, **do dia em que cessou a atividade criminosa;**
- nos crimes permanentes, **do dia em que cessou a permanência;**
- nos casos de bigamia e de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, **da data em que o fato se tornou conhecido:** isso porque, nesses crimes, se fosse contada a prescrição do dia que consumou a infração, não haveria punição. Nesses casos, será pela data em que o fato se tornou conhecido.
- nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, **da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.**



Nos casos de crime habitual, o prazo prescricional começará a ser contado a partir da prática do **último ato delitivo**.

– **Causas suspensivas da prescrição**

Durante a ocorrência daquela causa, ficará suspensa o curso do prazo prescricional. Após, a prescrição retomará o seu curso, considerando o período que anteriormente já havia transcorrido.

É diferente da causa interruptiva, na qual, o prazo prescricional para e recomeça do zero.

São **causas de suspensão** da prescrição, em que, antes de passar em julgado a sentença final, **não** correrá:

- **enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime:** trata-se da questão prejudicial externa facultativa para existência do crime no processo penal. **Ex.:** no crime de bigamia, resta suspenso o processo penal, enquanto não for julgado o processo de anulação do casamento no cível.
- **enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.**
- **na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e**
- **enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.**

Existem outras causas de suspensão da prescrição não previstas no CP, como é o caso da suspensão de processo contra parlamentar. Os congressistas, quando processados, podem ter a prescrição suspensa. Caso o STF receba a denúncia, a Corte deverá comunicar a Casa respectiva. Nesse caso, o congressista poderá ter o seu processo suspenso, caso haja requerimento de suspensão formulado por partido político com representação no Congresso Nacional e haja a aprovação da maioria absoluta da Casa. **Esta suspensão do processo implica suspensão do prazo prescricional.** Trata-se de uma questão de prosseguibilidade, isto é, para que o processo prossiga é necessário comunicar a Casa Legislativa.

– **Causas interruptivas da prescrição**

No caso da **interrupção da prescrição**, como dito, o prazo voltará a correr do início. As causas interruptivas estão previstas no art. 117 do CP:

- pelo recebimento da denúncia ou da queixa
- pela pronúncia
- pela decisão confirmatória da pronúncia
- pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
- pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
- pela reincidência

Exemplo disso é o **recebimento da denúncia ou da queixa-crime**, que interromperá o prazo prescricional. Caso haja decisão inicial rejeitando a inicial, não terá havido a interrupção do prazo. Se o MP recorrer e o Tribunal reformar a decisão de rejeição da inicial, a interrupção do prazo prescricional **ocorrerá na data dessa decisão do Tribunal**, que implica no recebimento da denúncia.

O STJ entende, de forma pacífica que quando o recebimento da denúncia se der por **autoridade absolutamente incompetente** em razão da prerrogativa de foro do acusado, esse ato **não tem o condão de interromper a prescrição**. Se a autoridade for relativamente independente, é plenamente possível essa interrupção.

No caso de **concurso de crimes**, a extinção de punibilidade incidirá em relação a **cada um isoladamente**.

A **decisão de pronúncia** é a que remete o réu ao Tribunal do Júri, por haver indícios de autoria e materialidade do crime. Essa decisão também **interrompe a prescrição, e não apenas do crime doloso contra a vida, mas também do crime conexo**, que é objeto do mesmo processo. **Ex.:** sujeito matou com um menor em coautoria. O sujeito cometeu o crime de homicídio e corrupção de menores.

A **decisão confirmatória da pronúncia** também é causa de interrupção da prescrição. Dá-se com a confirmação da decisão pelo Tribunal.

A sentença condenatória interrompe a prescrição, mas a discussão reside no acórdão condenatório recorrível. Prevalece o entendimento de que o acórdão condenatório que interrompe a prescrição **é aquele**



acórdão em que reforma uma sentença absolutória. Por essa razão, o STJ decidiu que **o acórdão confirmatório da condenação, ainda que modifique a pena fixada, não interrompe o curso do prazo prescricional.**

Obs.: Caso a sentença seja condenatória em relação a um crime e absolutória em relação a outro e o Tribunal reforme a decisão, condenando por ambas as infrações, ocorrerá a interrupção da prescrição novamente. Lembrando que a interrupção em relação a um crime estende-se ao outro, o que terá ocorrido na primeira e na segunda instância na situação hipotética.

No entanto, o próprio Código Penal afirma que essa interrupção depende da **publicação** da sentença ou do acórdão condenatório. Segundo o CPP, **considera-se publicada a sentença quando o escrivão procede à juntada da sentença aos autos, ou no caso de sentença proferida em audiência, e acórdão proferido em sessão, a publicação se dá na audiência ou na sessão de julgamento.** Ressalte-se que a sentença confirmatória da condenação pelo Tribunal **não tem o condão de interromper a prescrição.**

A interrupção da prescrição **não se dá em relação a apenas um autor**, e sim em relação a todos os autores do crime. **Ex.:** se houver 3 réus, cada vez que for recebida a denúncia contra cada um deles haverá a interrupção do prazo prescricional em relação a todos os demais.

Em relação aos crimes conexos, que sejam objetos do mesmo processo, também **haverá a extensão da interrupção da prescrição em relação a todos eles**, independentemente da causa interruptiva que tenha sido ocasionada. **Ex.:** crime doloso contra a vida e corrupção de menores – a decisão de pronúncia interrompe a prescrição de ambos.

B) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE (OU INTERCORRENTE)

Tem-se aqui a alteração do paradigma para a contabilização do prazo prescricional. Por exemplo, um juiz fixa uma pena em 4 anos, sendo que a sanção para o crime poderia ser de até 10 anos (ex.: crime de roubo). Quando essa decisão transita em julgado para a acusação, significa que a pena não pode mais ser majorada. A partir de então, percebe-se a pena máxima que o sujeito poderá receber, visto que não se admite *reformatio in pejus* no caso de recurso exclusivo da defesa. Neste momento, há um diferente paradigma para o prazo prescricional.

Segundo o art. 110, §1º, a prescrição, depois da sentença condenatória com **trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso**, é regulada pela pena aplicada.

Portanto, são requisitos para essa prescrição:

- sentença ou acórdão condenatório
- havido trânsito em julgado para a acusação
- a partir deste momento, essa pena passa a ser o paradigma

O **termo inicial** da contagem do prazo prescricional é a data **publicação da sentença ou acórdão condenatório** até a data do trânsito em julgado final.

A análise prescricional se dá a partir da sentença ou acórdão condenatório para frente, por isso prescrição da pretensão punitiva superveniente.

C) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

A prescrição da pretensão punitiva retroativa levará em conta a pena em concreto, assim como a superveniente.

A pena máxima será a partir do trânsito em julgado para a acusação, devendo, nesse caso, o julgador olhar para trás, ou seja, a prescrição retroativa deverá se voltar a partir da data da publicação da sentença ou acórdão condenatório até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Se entre a **data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório** tiver passado lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto na pena fixada, então terá havido a prescrição da pretensão punitiva retroativa.



D) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL (ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA OU PROGNOSE)

Não há previsão legal.

A prescrição virtual leva em conta o conhecimento do fato, bem como das circunstâncias que seriam levadas em conta quando o juiz fosse graduar a pena e chegando-se a uma provável condenação. Toma-se por base essa pena virtualmente considerada e faz-se a averiguação de possível prescrição. Assim, não haveria interesse em dar-se andamento em ação penal que, de antemão, pudesse se encerrar com a extinção da punibilidade.

Trata-se, em verdade, de uma perda de interesse de agir do Estado.

Os Tribunais Superiores **não admitem a prescrição virtual**.

O STJ editou a súmula 438, estabelecendo que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

E) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

A prescrição da pretensão executória é a prescrição da **pena em concreto**.

Houve pena fixada e o trânsito em julgado. Neste caso, deve-se analisar os prazos do art. 109 do CP e descobrir quanto tempo há para o sujeito começar a ter sua pena executada.

Caso o condenado seja **reincidente**, os prazos do art. 109 deverão **sofrer um aumento de 1/3**.

Se houver o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a pena estará extinta, mas os **efeitos penais secundários** continuam vigentes. Na verdade, ficarão mantidos os efeitos de reincidência, por exemplo, e os **efeitos extrapenais**, como é o caso da reparação do dano.

Essa prescrição **somente encerra os efeitos penais principais**, ou seja, a execução da pena.

– **Termo inicial da prescrição da pretensão executória**

Apesar de a redação legal ser bastante criticada pela doutrina e jurisprudência, o termo inicial da prescrição da pretensão executória está disposto no art. 112 do CP.

Segundo o dispositivo, no caso da prescrição da pretensão executória, a prescrição **começa a correr**:

- **do dia em que houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação;**
- **do dia em que houver a revogação da suspensão condicional da pena (*sursis*) ou o livramento condicional;**
- **do dia em que houver a interrupção da execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.**

Do dia em que for revogado o *sursis* ou do dia em que for revogado o livramento condicional começará a correr o prazo da prescricional da pretensão executória. Vale lembrar que, **durante o *sursis* ou o livramento condicional, não correm os prazos prescricionais**.

Nos casos de evasão de cárcere e revogação do livramento condicional, haverá o início da contagem do prazo prescricional da pretensão executiva. Caso não haja a recaptura do condenado e ultrapasse o prazo prescricional, haverá a prescrição da pretensão executória.

Nesse caso, o prazo para cumprimento que regula a prescrição da pretensão executória **deverá ter por base o *quantum* de pena que ainda resta cumprir**, e não a pena da condenação. Isso também serve para o livramento condicional, nos casos em que o sujeito se evade tendo cumprido boa parte da pena em cárcere.

ATENÇÃO: no caso da suspensão condicional da pena, não haverá essa aplicação, visto que o condenado não começou a cumprir a pena. Diante disso, deve-se levar em conta o *quantum* fixado na sentença.

– **Causas de suspensão da prescrição da pretensão executória**



O art. 116, parágrafo único, do CP diz que, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, **a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado estiver preso por outro motivo**, ou seja, o sujeito está cumprindo pena por um crime e, durante esse prazo, foi condenado por outro crime. Enquanto estiver cumprindo pena pelo primeiro crime, não correrá a prescrição executória em relação ao segundo crime.

Trata-se de causa de suspensão.

– **Causas de interrupção da prescrição da pretensão executória**

Segundo o art. 117, o curso da prescrição é interrompido:

- pelo início ou continuação do cumprimento da pena
- pela reincidência

2.6.4. PRESCRIÇÃO PARA ATOS INFRACIONAIS

Em regra, corre prescrição para crimes. A Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) não prevê o rol de prazos prescricionais.

No entanto, segundo a jurisprudência, a prescrição para atos infracionais terá os mesmos prazos do art. 109 do CP, visto que a Súmula 338 do STJ estabelece que a prescrição penal é aplicada às medidas socioeducativas.

Vale lembrar: **o prazo prescricional é reduzido pela metade, pois o condenado era menor de 21 anos na data do fato**. Nesse caso, os prazos previstos no art. 109 do CP deverão ser reduzidos pela metade.

2.6.5. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA

A prescrição da pena de multa encontra previsão no art. 144 do CP, havendo, basicamente, duas regras:

- se pena de multa tiver sido **fixada isoladamente** ou **tiver previsão isolada**, a prescrição ocorrerá em 2 anos;
- se a pena de multa tiver sido cominada alternativamente ou cumulativamente com a pena privativa de liberdade ou tiver sido fixada cumulativamente à pena privativa de liberdade, o prazo prescricional ocorrerá no mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

A maioria da doutrina entende que, mesmo com a Lei 9.268/96 (que realizou alteração no sentido de que a pena de multa passou a ser dívida de valor, a ser executada pela Procuradoria), esses são os prazos prescricionais da pena de multa, a despeito da aplicação da Lei de Execução Fiscal quanto às causas interruptivas e suspensivas da prescrição em relação à pena de multa. O prazo prescricional continua sendo o do art. 144 do CP

Vale destacar!

Está superada a Súmula 521 do STJ (A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública). O Plenário do STF definiu que o Ministério Público é o principal legitimado para executar a cobrança das multas pecuniárias fixadas em sentenças penais condenatórias. Por ter natureza de sanção penal, a competência da Fazenda Pública para executar essas multas se limita aos casos de inércia do MP. ADI 3150 e 12ª Questão de Ordem apresentada na AP 470. Dezembro 2018.

Ainda, merece citação a nova redação do artigo 51 do CP (Redação dada pela Lei 13.964/19 – Pacote Anticrime): **Art. 51**. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa **será executada perante o juiz da execução penal** e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.



2.6.6. REDUÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS

Conforme já exposto, se o sujeito era menor de 21 anos, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença, os prazos de prescrição serão **reduzidos pela metade**.

2.6.7. PRESCRIÇÃO E MEDIDA DE SEGURANÇA

Para o STJ a prescrição da medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria é regulada pela pena máxima abstratamente prevista para o delito.

Este é inclusive o entendimento da Súmula 527 do STJ, que diz que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Sendo este o teto do *quantum* da medida de segurança, este deve ser paradigma para o cálculo do prazo prescricional.

Para o STF, a prescrição da medida de segurança não poderá ser superior a 30 anos.

2.7. RENÚNCIA AO DIREITO DE AGIR

É mais uma das causas extintivas da punibilidade. **A renúncia é um ato unilateral do indivíduo**, pois ele não quer agir. Consequentemente, caso o indivíduo não exerça o seu direito de agir, não há como o Estado exercer o direito de punir.

O Estado não confere ao particular o seu direito de punir. Na ação penal privada, o Estado confere ao particular o direito de perseguir ou não a punição estatal.

Se o sujeito renuncia, esta renúncia implica impossibilidade de o Estado exercer o direito de punir.

Todavia, a Lei 9.099/95 vai estabelecer que, **se houver um acordo homologado entre o agente e o ofendido, também haverá renúncia ao direito de representação**.

A renúncia é do direito de agir, ou seja, ela ocorre **antes** do direito de agir.

Esta renúncia será da seguinte forma:

- **renúncia tácita:** o sujeito pratica um ato incompatível com o desejo de exercer a queixa-crime.
- **renúncia expressa:** o sujeito expressamente afirma que não quer agir.

Sendo dois os autores do crime, e caso o ofendido renuncie em relação a um deles, essa renúncia se estenderá ao outro, por meio do **princípio da indivisibilidade**.

Por outro lado, caso haja duas vítimas e um autor, e uma delas resolva renunciar ao direito de ação contra o autor, a renúncia de uma não compromete o direito de ação da outra vítima.

2.8. PERDÃO DO OFENDIDO

O princípio prevalente em relação ao perdão do ofendido é o **princípio da disponibilidade**, isto é, o sujeito **poderá desistir da ação penal**.

Caso o ofendido perdoe o réu, o que somente poderá ocorrer após o oferecimento da queixa-crime, **será necessário que o perdão seja aceito**, pois é um ato bilateral, diferente da renúncia.

O perdão poderá ser aceito de forma:

- **judicial:** nos autos do processo.
- **extrajudicial:** fora dos autos, por escritura pública.
- **expressa:** o sujeito afirma que perdoou.
- **tácita:** prática de ato incompatível com o desejo de prosseguir na ação penal. Ex.: ofendido convida o réu para ser seu padrinho de casamento.

O perdão **não é ato unilateral**, e sim **ato bilateral**, pois é preciso que haja a concordância do réu. No silêncio, presume-se que o perdão foi aceito.



O perdão do ofendido poderá ser oferecido **até o trânsito em julgado**. Após, não é mais possível perdoar.

Se o perdão for concedido a um dos autores do delito, **haverá extensão aos demais**, por conta do princípio da indivisibilidade. Caso haja dois ofendidos e um deles perdoe o réu, o outro ofendido não será obrigado a perdoar.

2.9. RETRATAÇÃO DO AGRESSOR

Retratação é retirar aquilo que foi dito. É **dispensável a concordância do ofendido**, só sendo possível nos casos previstos em lei.

Segundo o CP, calúnia e difamação admitem retratação, visto que atingem a honra objetiva. Portanto, **injúria não admite retratação**, por se tratar de ofensa à honra subjetiva.

Na calúnia e na difamação, é possível que, **antes da sentença**, o sujeito se retrate, hipótese em que o indivíduo **ficará isento de pena** (causa extintiva da punibilidade).

No caso do **falso testemunho e da falsa perícia**, há ainda uma outra hipótese em que a lei prevê uma retratação, hipótese em que o **fato não será punido se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retratar**. Em outras palavras, o indivíduo que comete falso testemunho e falsa perícia não poderá se retratar no processo em que responde por esse crime, **mas somente no processo em que cometeu esses crimes**.

2.10. PERDÃO JUDICIAL

Perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade, visto que não há interesse em punir do Estado. É aplicada pelo juiz. Há um desvalor da ação e um desvalor do resultado, mas a sanção penal é desnecessária.

Preenchidos os requisitos legais para a aplicação do perdão judicial, o indivíduo passa a ter um direito público subjetivo de não ter a pena imposta contra ele.

A natureza dessa sentença não pode ser condenatória; a Súmula 18 do STJ aduz que a sentença concessiva do perdão judicial é **declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório**.

EXEMPLO: Sujeito que comete homicídio culposo na direção de veículo automotor, cuja vítima é a esposa.
- A lei de contravenções penais traz outra hipótese de perdão judicial. Segundo a LCP, os casos em que o sujeito tem a errada ignorância sobre a compreensão da lei, e sendo esta escusável, **poderá não ser aplicada a pena respectiva**.

A lei de organização criminosa (Lei n. 12.850/13) traz a hipótese em que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o **perdão judicial** daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que preenchidos os requisitos legais.

Com relação ao perdão judicial, há quem o chame de **princípio da bagatela imprópria** ou **princípio bagatelar impróprio**, pois há aqui um desvalor da ação, um desvalor do resultado, mas não há interesse em aplicar a pena.

Cabe ressaltar ainda que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê o perdão judicial para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Todavia, **é possível aplicar a regra constante no Código Penal aos crimes cometidos na direção de veículos automotores**.

CAPÍTULO 15 — TEORIA GERAL DO CRIME: *ITER CRIMINIS*

1. CONCEITO

Iter criminis é o caminho/itinerário do crime. É o conjunto de fases que vão se suceder no caminho do delito.

2. FASES

São fases do crime, segundo a doutrina:

- **cogitação:** é a ideia do crime que surge na cabeça do agente. É sempre impunível.
- **atos preparatórios:** o sujeito cria condições para realização da conduta delituosa idealizada. O agente começa a preparar terreno para cometer o crime. Essa fase preparatória, em regra, não é punível. Serão quando previstos como delitos autônomos. **Ex.:** sujeito compra uma arma para matar desafeto (porte ilegal de arma de fogo).
- **atos executórios:** ocorre quando o sujeito coloca em prática o seu plano. Em regra, é a partir dessa fase que passa a ser punível a sua conduta. O ato executório deve ter idoneidade, ou seja, deve ser capaz de conduzir o sujeito ativo ao resultado desejado.
- **consumação:** é a última etapa. Ocorre quando o agente realiza todos os elementos do tipo penal. É a subsunção do fato à norma.

Obs.: Atualmente, o direito penal de 3ª velocidade traz a tipificação de crimes de perigo abstrato, havendo uma maior criminalização de atos preparatórios como crimes autônomos. **Ex.:** sujeito foi na feira e comprou uma arma sem porte. Cometerá o crime de porte ilegal de arma de fogo. O sujeito que se reúne com outros indivíduos para cometer crimes comete o delito de associação criminosa.

3. TEORIAS QUE TRATAM DO MOMENTO EM QUE O ATO PREPARATÓRIO PASSA A SER ATO EXECUTÓRIO

Existem 3 teorias que tratam do assunto:

- **Teoria da hostilidade ao bem jurídico:** esta teoria afirma que ato executório começa quando o bem jurídico é colocado em risco. Quando o agente decide furtar uma casa e fica de olho, aguardando a vítima sair de casa, este sujeito já pratica ato executório, pois o bem jurídico já está em risco.
- **Teoria objetivo-formal:** para essa teoria, ato executório é aquele em que há a prática do núcleo do tipo. Haveria ato executório a partir do momento em que o agente começasse a efetuar a subtração, por exemplo.
- **Teoria objetivo-material:** para esta teoria, o ato executório se inicia imediatamente anterior à prática do núcleo do tipo. Se o furto exige subtração, para essa teoria, a execução começaria a partir do momento em que o indivíduo pulasse o muro da casa para efetuar a subtração.
- **Teoria objetivo-individual:** para essa teoria, o ato executório começa com o ato imediatamente anterior ao início da prática do núcleo do tipo, mas é necessário levar em conta o plano concreto do autor para chegar a essa conclusão. O STJ já adotou esta teoria.



4. TENTATIVA

4.1. CONCEITO

Tentativa se dá quando o sujeito inicia a execução, mas não chega à consumação, por circunstâncias alheias à sua vontade.

4.2. PUNIÇÃO DA TENTATIVA

Para punir a conduta tentada, não basta olhar para o tipo penal, devendo se promover uma **adequação típica mediata**, com base no art. 14, inciso II do CP. Ou seja, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, **diminuída de 1/3 a 2/3**.

Há aqui uma incongruência entre o elemento objetivo e o elemento subjetivo. **Ex.:** Art. 121, CP – subjetivamente, o indivíduo quer matar e mata, mas objetivamente, o indivíduo não consegue matar.

Existem crimes tentados que são punidos com a mesma pena do crime consumado, sendo tais crimes denominados de **crimes de atentado**. Exemplo disso é o art. 352 do CP, que diz ser crime a conduta de **evadir-se** ou **tentar evadir-se** o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa.

Em relação à punição da tentativa, existem três teorias da punição da tentativa:

- **teoria subjetiva (voluntarística):** subjetivamente, o sujeito consumou o crime. Por isso, quem pratica o crime tentado deve receber a mesma pena do que aquele que pratica o crime consumado.
- **teoria sintomática:** a razão de punir o agente é com base na periculosidade do indivíduo. Por isso, esse sujeito deverá ser punido como quem consumou o crime, pois apresenta igual periculosidade.
- **teoria objetiva (realística):** objetivamente, não está acabado o crime. Por isso, quem comete o crime tentado deve ter pena menos rigorosa do que aquele que comete o crime consumado.

O CP adota, via de regra, a teoria objetiva. Mas, nos crimes de atentado, o CP adota a teoria subjetiva.

Cabe destacar que **existem crimes em que o legislador pune apenas a modalidade tentada**, sem prever o delito na modalidade consumada. Por exemplo, o crime do art. 11 da Lei 7.170 estabelece que é crime tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Se o sujeito conseguir, não haverá o crime, pois terá fundado um novo país.

4.3. CRITÉRIO PARA PUNIÇÃO

Para o juiz aferir o critério para punição do crime tentado, o magistrado deverá levar em conta a proximidade da consumação. Isto é, quanto mais próximo o indivíduo chegou à consumação, maior será a reprimenda. Nesse caso, o indivíduo terá uma redução de 1/3, por exemplo.

4.4. ELEMENTOS DA TENTATIVA

São elementos da tentativa:

- início da execução
- não consumação
- circunstâncias alheias à vontade do agente, que tinha um dolo de consumir o delito



4.5. ESPÉCIES DE TENTATIVA

A tentativa, quanto ao *iter criminis* percorrido, pode ser:

- **tentativa imperfeita (inacabada):** o sujeito não praticou todos os atos executórios. A execução é interrompida.
- **tentativa perfeita (acabada):** o sujeito praticou todos os atos executórios, mas não conseguiu alcançar o seu intento.

Quanto ao resultado produzido na vítima, poderá ser:

- **tentativa branca (incruenta):** a vítima não sofre lesão.
- **tentativa vermelha (cruenta):** a vítima é atingida pelo agente.

Quanto à possibilidade de alcançar o resultado, poderá ser:

- **tentativa idônea:** admite punição, com a redução da pena de 1/3 a 2/3, pois o resultado era passível de ser alcançado.
- **tentativa inidônea:** trata-se de crime impossível, motivo pelo qual não poderá ser punida a conduta do agente, por impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio.

A doutrina trata, ainda, da denominada **tentativa supersticiosa (ou irreal)**. Nessa tentativa, o sujeito acredita que está numa situação de crime tentado, mas na prática não é realizável, porque a conduta por ele praticada nunca chegará à consumação da infração penal. **Ex.:** sujeito que mentaliza que o seu inimigo sofrerá uma lesão e, por mais que a lesão seja mentalizada, esta não ocorre. Na cabeça do sujeito ocorreu uma tentativa de lesão corporal, mas essa tentativa é meramente supersticiosa.

Essa tentativa é apenas uma crença na eficácia de um meio que nunca poderia conduzir ao resultado lesivo. É diferente do crime impossível, em que o agente pega uma arma quebrada. A arma poderia causar um crime caso estivesse operando. No entanto, no caso, por estar quebrada, conduziu à impossibilidade absoluta do meio escolhido pelo agente.

4.6. INFRAÇÕES PENAIS QUE NÃO ADMITEM TENTATIVA

Existem infrações penais que não admitem tentativa:

- **crimes culposos:** isso porque é da tentativa não alcançar a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso de crimes culposos, o resultado não é desejado, ao contrário da tentativa, em que o resultado é querido pelo agente, mas não é alcançado. Atente-se que, na culpa imprópria, o resultado é desejado pelo agente, hipótese em que somente não responderá o agente pelo crime doloso por política criminal e por conta da discriminante putativa. No caso de culpa imprópria, poderá haver tentativa de crime culposos.
- **crime preterdoloso:** em regra, é incompatível com a modalidade tentada. LFG afirma que é possível quando a frustração se dá em razão da conduta dolosa, mas a conduta culposa acontece. **Ex.:** médico que tenta provocar aborto na mulher. O aborto não acontece, mas a mulher morre em razão das manobras abortivas. É uma tentativa de aborto qualificado pelo resultado morte culposa.
- **crimes unissubsistentes:** não admitem tentativas, pois são praticados por um único ato. **Ex.:** crimes omissivos puros.
- **contravenções penais:** o art. 4º da Lei de Contravenções Penais não pune as contravenções penais tentadas.
- **crimes habituais:** apesar da divergência doutrinária, prevalece que nos crimes habituais ou há a reiteração dos atos, consumando o crime, ou os atos não são reiterados e não há crime habitual.
- **crimes condicionados ao implemento de um resultado:** de forma que, se não houver o resultado, não há que se falar em crime, não havendo punição da tentativa. **Ex.:** Quem induz



alguém a se suicidar não responde pelo crime se a vítima não sofre lesão corporal grave ou não morre. Nesse caso, o crime está condicionado ao implemento de um resultado.

PERGUNTA: É possível tentativa se o sujeito agiu com dolo eventual? **Prevalece o entendimento de que é possível**, apesar da dificuldade de verificação prática.

5. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ

5.1. CONCEITO

Esses dois casos são denominados de **tentativa abandonada**.

Diferença entre tais institutos e a tentativa. Na tentativa, o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na tentativa abandonada, o resultado não ocorre pela vontade do agente, que impede a consumação do delito.

Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, **o sujeito só responderá pelos atos até então praticados**.

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são incompatíveis com o crime culposos, eis que neste o resultado é involuntário. Na desistência voluntária e o arrependimento eficaz, no começo, o indivíduo quer chegar ao resultado, mas, após, o indivíduo abandona seu intento, enquanto no crime culposos o indivíduo nunca quis o resultado.

5.2. NATUREZA JURÍDICA

Existe discussão doutrinária sobre a natureza jurídica, porém prevalece o entendimento de que se trata de **causa exclusão da tipicidade**.

Outros autores defendem que seria uma causa extintiva da punibilidade, pois o indivíduo desistiu de prosseguir ou impediu que o resultado ocorresse, apesar de ter praticado todos os atos executórios.

Quando há exclusão da tipicidade, **beneficia-se inclusive o partícipe**, ao contrário do que seria se houvesse causa extintiva da punibilidade.

5.3. ANÁLISE DOS INSTITUTOS

Na desistência voluntária, o indivíduo não termina os atos executórios, podendo prosseguir, mas não quer.

Tanto na desistência voluntária como no o arrependimento eficaz, existe a chamada **ponte de ouro**, razão pela qual, se o indivíduo estiver no caminho do ilícito, poderá tomar o caminho de ouro, da licitude.

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz **não precisam ser espontâneos, devendo apenas ser voluntários**. Isto é, não precisa que a ideia parta do agente.

A desistência voluntária se dá durante os atos executórios e o arrependimento eficaz após o esgotamento dos atos executórios, mas antes que o resultado naturalístico ocorra.

No arrependimento eficaz, o indivíduo esgota os atos executórios, só fazendo sentido no caso de **crimes materiais**, pois é preciso que o sujeito impeça esse resultado naturalístico possível. Se não há resultado naturalístico e o sujeito praticou todos os atos de execução, o crime já está consumado, não havendo que se falar em arrependimento.

A doutrina denomina **tentativa qualificada** a remanência de conduta delituosa, por conta da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. O próprio art. 15 do CP assevera isso quando estabelece que o sujeito **só responde pelos atos já praticados**.



5.4. ARREPENDIMENTO POSTERIOR

O art. 16 do CP estabelece que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a **pena será reduzida de 1/3 a 2/3**.

São requisitos para o arrependimento posterior:

- **crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa:** admite violência contra a coisa.
- **reparação do dano ou devolução da coisa**
- **até o recebimento da denúncia ou queixa**
- **ato voluntário, não necessariamente espontâneo**

Aqui há a denominada **ponte de prata**, pois não se trata de causa excludente da tipicidade, porque o crime persiste, o que se tem é apenas uma causa de diminuição da pena.

O arrependimento posterior **vale para todos os crimes com que ele seja compatível**, sem distinção, inclusive contra a Administração Pública. Assim, é errado pensar que o arrependimento posterior aplica-se apenas para os crimes contra o patrimônio.

Entende-se majoritariamente que os **crimes culposos admitem o arrependimento posterior**.

O STJ entende que **não se aplica o instituto do arrependimento posterior para o homicídio culposo na direção de veículo automotor** (art. 302 do CTB) mesmo que tenha havido composição civil entre o autor do crime a família da vítima. Para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena **é indispensável que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais**. O arrependimento posterior exige a reparação do dano e isso é impossível no caso do homicídio. O delito do art. 302 do CTB tutela a vida. Não se pode reconhecer o arrependimento posterior porque é impossível a reparação do dano cometido contra o bem jurídico "vida". Além disso, a vítima não poderá aproveitar a composição financeira realizada entre a sua família e o autor do crime. Sendo assim, inviável o reconhecimento do arrependimento posterior na hipótese de homicídio culposo na direção de veículo automotor (Informativo 590).

Predomina que **é possível se falar em arrependimento posterior em casos de violência imprópria**, pois o sujeito apenas retira a capacidade de resistência da vítima, o que não impediria a aplicação do instituto. O fundamento para aplicação é de que o CP não veda expressamente, quando o código quer criminalizar a violência imprópria, ele o faz expressamente.

A reparação do dano deverá ser **integral**. Somente podemos falar em reparação parcial, nos casos em que a vítima concordar com isso.

A diminuição da pena irá variar de 1/3 a 2/3 a depender da **celeridade com que essa reparação se der**.

Informativo 645-STJ (26/04/2019) – Dizer o Direito

No caso de furto de energia elétrica mediante fraude, o adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade.

O furto de energia elétrica não pode receber o mesmo tratamento dado ao inadimplemento tributário, de modo que o pagamento do débito antes do recebimento da denúncia não configura causa extintiva de punibilidade, mas causa de redução de pena relativa ao arrependimento posterior (art. 16 do CP). Isso porque nos crimes contra a ordem tributária, o legislador (Leis nº 9.249/1995 e nº 10.684/2003), ao consagrar a possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, adota política que visa a garantir a higidez do patrimônio público, somente. A sanção penal é invocada pela norma tributária como forma de fortalecer a ideia de cumprimento da obrigação fiscal.

Já nos crimes patrimoniais, como o furto de energia elétrica, existe previsão legal específica de causa de diminuição da pena para os casos de pagamento da "dívida" antes do recebimento da denúncia. Em tais hipóteses, o Código Penal, em seu art. 16, prevê o instituto do arrependimento posterior, que em nada afeta a pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da



pena.

Outrossim, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público, no caso de fornecimento de energia elétrica, prestado por concessionária, é de tarifa ou preço público, não possuindo caráter tributário. Não há como se atribuir o efeito pretendido aos diversos institutos legais, considerando que o disposto no art. 34 da Lei nº 9.249/1995 e no art. 9º da Lei nº 10.684/2003 fazem referência expressa e, por isso, taxativa, aos tributos e contribuições sociais, não dizendo respeito às tarifas ou preços públicos. STJ. 3ª Seção. RHC 101.299-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. Ac. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/03/2019 (Info 645).

Existem hipóteses em que a reparação do dano é ainda mais benéfica ao acusado do que as previstas no art. 16, do CP. Vejamos:

- **peculato culposo:** a reparação do dano é causa extintiva da punibilidade, caso essa reparação se dê até a sentença irrecorrível (trânsito em julgado). Caso seja posterior ao trânsito, aí o art. 312, §3º, diz que a pena será reduzida pela metade.
- **pagamento de cheque sem fundos antes do recebimento da denúncia:** obsta o prosseguimento da ação penal, sendo causa extintiva da punibilidade. É uma causa supralegal.
- **pagamento do débito tributário (Lei 10.684/03):** também é uma causa extintiva da punibilidade.
- **crimes de menor potencial ofensivo:** a composição civil dos danos pode gerar a extinção da punibilidade.

PERGUNTA: A reparação do dano comunica-se ao corréu, coautor ou partícipe? A reparação do dano é uma circunstância objetiva, devendo se estender aos corréus.

5.5. CRIME IMPOSSÍVEL

Crime impossível é o **quase-crime, crime oco, tentativa inidônea**.

O art. 17 do CP estabelece que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é **impossível** consumar-se o crime.

Existem teorias tratando do crime impossível:

- **teoria sintomática:** o sujeito é punido em razão da sua periculosidade.
- **teoria subjetiva:** analisa que subjetivamente o crime está consumado, não conseguindo o agente consumá-lo objetivamente. Nesse caso, deverá ser punido o crime impossível assim como é punido o crime tentado.
- **teoria objetiva:** a execução deve ser idônea, pois se ela não for, não se poderá punir o sujeito da mesma forma (**adotada**). Essa teoria se subdivide em duas:
 - **teoria objetiva pura:** se não for idônea a execução, não poderá o sujeito ser punido. Não há tentativa, ainda que essa inidoneidade seja relativa.
 - **teoria objetiva temperada (intermediária):** para que o sujeito seja punido, a inidoneidade deve ser relativa. Se a inidoneidade é absoluta, não há punição, pois o crime será impossível.

São espécies de crime impossível:

- **ineficácia absoluta do meio:** é o meio escolhido pelo sujeito. **Ex.:** quem pega uma arma quebrada para atirar, não vai alcançar o intento criminoso.
- **impropriedade absoluta do objeto:** o objeto material não serve para a consumação do delito. **Ex.:** matar quem já está morto. Praticar aborto em quem não está grávida.
- **delito putativo por obra do agente provocador:** é o caso do flagrante preparado. Nessa situação, o sujeito instiga o agente a praticar o crime, mas adota medidas para que o crime jamais se consuma.



CAPÍTULO 16 — TEORIA GERAL DO CRIME: CONCURSO DE PESSOAS

1. CONCEITO

Concurso de pessoas é uma reunião de pessoas para realização de um crime. Essas pessoas devem atuar de maneira relevante e possuir identidade de propósito (liame subjetivo). Não havendo identidade de propósito, há autoria colateral e não concurso de pessoas.

Masson entende que, nos crimes unissubjetivos ou de concurso eventual (crime que pode ser cometido por uma única pessoa ou, eventualmente, por duas, três ou quatro, como é o caso do homicídio, roubo, furto, estupro) é necessário que os coautores e partícipes sejam culpáveis ou dotados de culpabilidade. Já nos crimes plurissubjetivos (exigem mais de um sujeito) ou de concurso necessário, a culpabilidade dos coautores ou partícipes é dispensável. **Ex.:** rixa, associação criminosa, organização criminosa etc. A jurisprudência dispensa essa diferenciação e possibilita a punição pelo concurso de pessoas, ainda que se tenha coautor inimputável em crime unissubjetivo.

2. REQUISITOS

São requisitos do concurso de pessoas:

- **pluralidade de agentes ou de condutas;**
- **relevância causal das condutas:** significa que cada partícipe ou coautor tenha dado causa, de alguma forma, para o resultado; é vista a partir da teoria da equivalência combinada com a teoria da eliminação hipotética – imagina-se um desdobramento fático sem aquela conduta, isto é, se o desdobramento for o mesmo, a conduta não é causa, se for diferente então a conduta é causa, causa é tudo aquilo que sem aquilo o crime não teria ocorrido como ocorreu.
- **identidade de infração:** a ideia é de que os agentes queiram praticar o mesmo crime.
- **liame subjetivo:** os agentes devem estar conscientes da prática dos demais. É dispensado o prévio ajuste para a prática do crime.

3. TEORIAS

O ordenamento jurídico traz as seguintes teorias:

- **teoria monista:** todos os concorrentes, independentemente da distinção entre partícipes, autores ou coautores, praticam condutas concorrendo para a prática de um único crime, de modo que responderão por este crime. Disposta no art. 29, CP. Adotada pelo CP (em regra, mas há exceções).
- **teoria pluralista (teoria da cumplicidade-delito distinto ou autonomia da concorrência):** cada agente do crime comete um delito diferente, eis que cada agente possui um elemento e conduta específicos. **Ex.:** corrupção ativa (art. 333, CP) e corrupção passiva (art. 317, CP). O particular que corrompe o funcionário público pratica corrupção ativa, enquanto o funcionário corrompido pratica corrupção passiva.
- **teoria dualista:** faz uma diferenciação, estabelecendo que há um delito para os executores (autores e coautores) e outro delito para os partícipes.

O CP adotou a teoria monista, com base no art. 29, estabelecendo que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. O autor e o partícipe respondem pelo mesmo crime. No entanto, há exceções, em que se poderia pensar na teoria pluralista. O CP, em determinados pontos, adota a teoria pluralista, como é o caso da corrupção passiva e ativa.



4. FORMAS DE PRATICAR O CRIME QUANTO AO SUJEITO

4.1. AUTORIA (*ANIMUS AUCTORIS*)

Existem várias teorias para definir o que seja autor:

- **Teoria subjetiva ou unitária:** não faz diferenciação entre autor e partícipe. O autor é aquele que de alguma forma contribuiu para o resultado.
- **Teoria extensiva:** não distingue autor de partícipe, mas permite estabelecer graus de autoria. Todos são autores, mas, a depender do grau de culpabilidade, haverá punições diferentes para cada um deles. Há previsão de causas de diminuição, conforme o grau de atuação de cada autor do crime.
- **Teoria objetiva ou dualista:** faz distinção entre autor e partícipe. É a teoria adotada. Essa teoria se subdivide em:
 - **Teoria objetivo-formal:** autor é quem realiza o núcleo do tipo, enquanto partícipe é quem concorre dolosamente para o crime de qualquer forma sem praticar o núcleo do tipo. **Ex.:** autor é quem subtrai, partícipe é quem empresta o pé-de-cabra para viabilizar a subtração.
 - **Teoria objetivo-material:** autor é quem contribui objetivamente de forma mais eficaz, enquanto partícipe é o que concorre de forma menos relevante.
- **Teoria do domínio do fato:** autor é quem tem o domínio do fato, controlando finalisticamente o fato, decidindo a forma de execução, quando começa etc., enquanto o partícipe é quem colabora dolosamente, porém não tem o domínio do fato. Podemos afirmar, com base nisso, que aquele que por sua vontade executa o núcleo do tipo é o autor imediato. Já aquele que planeja a empreitada criminosa é o autor intelectual/mediato. **Só há aplicação da teoria do domínio do fato caso o crime seja doloso**, pois no crime culposos o agente não tem o domínio do fato, tanto não tem que dá causa a um resultado involuntário.

De acordo com a maioria da doutrina, **o CP adotou a teoria objetivo-formal**. Autor é quem pratica o núcleo do tipo e partícipe é quem contribui sem executar o núcleo.

4.2. AUTORIA MEDIATA

Na autoria imediata, é o próprio agente que executa o fato.

O autor mediato, por sua vez, não realiza o núcleo do tipo. Há autoria mediata quando o agente se utiliza de pessoa, **que atua sem dolo ou de forma não culpável**, como instrumento para a execução do fato. O domínio do fato pertence exclusivamente ao autor mediato, e não ao executor. O autor mediato domina a vontade alheia para cometer o delito. **Ex.:** médico indica a injeção letal para que a enfermeira aplique na vítima, sem que a enfermeira tenha conhecimento do intento criminoso. O médico é autor mediato; se a enfermeira percebe que é veneno e aplica propositadamente, também pratica o crime de homicídio; se ela tem dúvida se é ou não veneno, mas acredita sinceramente que não é, apesar da cor ser muito diferente da cor do remédio, ela pode incidir na prática de homicídio culposos.

Prevalece o entendimento de que **não se admite autoria mediata em crimes culposos**, também denominados de **crimes imprudentes**, pois a autoria mediata tem lugar quando alguém se vale de outrem como instrumento para atingir um resultado, mas, no caso do crime culposos, o resultado é involuntário.

No tocante aos **crimes próprios** ou **crimes de mão própria**¹⁶, a doutrina afirma que, em relação aos **crimes próprios** (aqueles que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo), como é o caso do peculato, que exige a condição de ser o agente funcionário público, **será possível a autoria mediata, desde que o**

¹⁶ A prova do MP-PR considerou correta a seguinte alternativa: “Não existe a possibilidade de autoria mediata nos delitos de mão própria e nos crimes próprios”.



autor mediato seja quem tenha a qualidade exigida pelo tipo penal, não podendo ser a pessoa-instrumento.

Já em relação aos **crimes de mão própria**, por não permitirem coautoria, o **entendimento majoritário é no sentido de que não se admite autoria mediata**, eis que a ação deve ser praticada diretamente pelo sujeito ativo. **Ex.:** Crime de falso testemunho ou falsa perícia (art. 342, CP).

A doutrina fala hoje em **autoria de escritório**, que é uma forma de autoria mediata. Trata-se de uma autoria em que um indivíduo emite uma ordem para que outro a cumpra. A ordem para o subordinado é de matar uma terceira pessoa, por exemplo. Quem mata é igualmente culpado, assim como aquele que emite a ordem. Perceba que quem emite a ordem possui uma posição de comando, enquanto o subalterno pode ser inclusive ser trocado. O autor de escritório é o autor mediato. Essa autoria mediata é característica de organizações criminosas hierarquizadas, havendo fungibilidade dos membros.

4.3. AUTORIA COLATERAL

Não há concurso de pessoas pela ausência de vínculo subjetivo, em outras palavras, um não sabe da conduta do outro.

A autoria colateral ocorre quando dois ou mais agentes, ignorando a atuação do outro, praticam determinada conduta visando ao mesmo resultado, que ocorre em razão do comportamento de apenas um deles. **Ex.:** João e José querem matar Antônio, esperam Antônio passar e, para isso, cada um se esconde atrás de uma árvore diferente; quando Antônio passa, ambos atiram; Antônio vem a óbito em razão do disparo de João e não de José. João responde por homicídio consumado e José por tentativa de homicídio.

Caso não se saiba quem foi o autor responsável pelo disparo fatal, por exemplo, haverá **autoria incerta**, razão pela qual **ambos deverão responder por tentativa de homicídio**, devido à máxima do *in dubio pro reo*.

Se, havendo duas pessoas querendo matar alguém, uma se utilizar de meio absolutamente ineficaz para atingir o resultado e a outra se valer de um meio eficaz, como veneno, caso não seja possível apontar qual das duas foi a que utilizou o meio eficaz, nenhuma delas será responsável pelo crime. Em outras palavras, no caso, ficou configurado que uma pessoa cometeu um crime impossível (ex.: usou talco para matar alguém) e a outra usou de um meio possível e matou de fato a vítima, mas não se sabe quem ministrou qual substância. Logo, pela aplicação do *in dubio pro reo*, nenhum dos agentes responde pelo crime. O caso não se confunde com o anterior, pois naquela as duas pessoas usavam de meio eficazes para atingir o resultado desejado.

4.4. MULTIDÃO DELINQUENTE

São os crimes multitudinários ocorridos por conta de um fato gerador dessas condutas. É o caso, por exemplo, dos indivíduos que subtraem caixas de cerveja do caminhão tombado – furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, CP).

Apesar de não haver prévio ajuste, **há liame subjetivo, havendo concurso de pessoas**, porém é difícil particularizar a conduta de cada um dos indivíduos. Sendo assim, **dispensa-se a individualização da conduta, bastando comprovar que o agente contribuiu para a ocorrência do resultado**.

O Código Penal, no art. 65, inciso III, prevê uma atenuante da pena, caso o indivíduo cometa um crime influenciado pela multidão. Mas essa atenuante é apenas para quem foi influenciado, pois quem provocou a multidão é punido pela agravante do art. 62, inciso I, CP, visto que dirigiu a atividade dos demais agentes.

5. COAUTORIA

Há dois ou mais autores, ligados subjetivamente, unidos para a prática de uma conduta criminosa, podendo esta ser tanto omissiva quanto comissiva.



Coautoria: dois ou mais autores. E portanto, se há um caso de coautoria, haverá concurso de agentes.

A coautoria pode ser parcial ou direta:

- **Coautoria parcial:** cada autor pratica um ato de execução diferente do outro. Juntos, alcançam o resultado pretendido. João e José decidem roubar Maria. João ameaça e José subtrai a bolsa.¹⁷
- **Coautoria direta:** todos praticam a mesma conduta. João e José colocam a arma na cabeça da Maria e subtraem seus pertences.

Nos crimes próprios é possível coautoria, ainda que o indivíduo não tenha a qualidade especial. **Ex.:** Para a prática de peculato é necessário ser funcionário público, mas **é possível** que haja coautoria ainda que o indivíduo não tenha a qualidade especial, **desde que o agente saiba que o comparsa ostenta essa qualidade.**

Prevalece que os crimes de mão própria não admitem coautoria.

Os crimes de mão própria exigem que o sujeito ativo pratique o próprio núcleo do tipo, razão pela qual **não admitem coautoria**, mas tão somente participação.

Há apenas uma **exceção** de coautoria em crimes de mão própria que é o caso do crime de falsa perícia. Nesse caso, **os dois peritos combinam de cometer o crime de falsa perícia** (art. 342, CP)

6. PARTICIPAÇÃO (*ANIMUS SOCCI*)

Participação: o sujeito realiza atos que contribuem para o crime, sem executar o núcleo do tipo (teoria objetivo-formal).

6.1. ESPÉCIES DE PARTICÍPE

São espécies de participação:

- **Participação moral:** o agente instiga ou induz. Instigar é alimentar a ideia já existente. Induzir é fazer nascer o pensamento no agente. A instigação e o induzimento devem atingir pessoa certa, pois se forem gerais, o crime poderá ser o de incitação ao crime (art. 286, CP).
- **Participação material:** o agente auxilia materialmente.

6.2. TEORIAS DA PUNIÇÃO DO PARTICÍPE

São **teorias** que analisam a punição do partícipe:

- **Teoria da acessoriedade mínima:** para punir o partícipe, basta que o autor pratique o fato típico.
- **Teoria da acessoriedade limitada:** para punir o partícipe, basta que o autor pratique o fato típico e ilícito. Esta é a que predomina na doutrina.
- **Teoria da acessoriedade máxima:** para punir o partícipe, é necessário que o autor pratique o fato típico, ilícito e que seja o autor culpável.
- **Teoria da hiperacessoriedade:** para punir o partícipe, é necessário que o autor pratique o fato típico, ilícito e que seja o autor culpável e punível.

6.3. PARTICIPAÇÃO EM CADEIA E PARTICIPAÇÃO SUCESSIVA

- **Participação em cadeia:** é o caso em que um agente instiga outro que induz um terceiro a cometer o crime.

¹⁷O emprego de arma de fogo majora a pena do crime de roubo em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018.



- **Participação sucessiva:** é o caso em que um indivíduo instiga uma pessoa e, paralelamente, há uma outra pessoa instigando também essa pessoa, sem que os instigadores tenham conhecimento um da atuação do outro. O mesmo agente é instigado por duas ou mais pessoas, sem que uma tome conhecimento da ação das outras.

7. CONCURSO DE PESSOAS EM CRIMES CULPOSOS

É **possível** a coautoria em crimes culposos, desde que dois ou mais indivíduos, com vínculo subjetivo, atuem de forma imprudente, negligente ou imperita, dando causa ao resultado involuntário, que seja previsível.

O liame subjetivo no crime culposo **não é para alcançar o resultado**, mas para praticar aquela conduta imprudente, negligente ou imperita. **Ex.:** Um indivíduo pede para que outro corra a mais de 150 km/h em uma rua residencial. Essa conduta acaba por lesionar gravemente uma mulher que estava transitando na via.

Há doutrina (minoritária) sustentando que nesse caso haveria participação. Todavia, em verdade, o liame subjetivo dos indivíduos envolve a própria conduta e, portanto, **não caberia participação em crime culposos, mas apenas coautoria**.

8. CONCURSO DE PESSOAS EM CRIMES OMISSIVOS

Admite-se coautoria em crimes omissivos próprios, apesar de divergente o entendimento. Mirabete diz que não é possível coautoria em crimes omissivos próprios, é posição minoritária.

Cezar Roberto Bitencourt entende que **é possível coautoria em crimes omissivos próprios, desde que exista vínculo subjetivo**. **Ex.:** João e Pedro assistem Maria se afogando. João vira para Pedro e diz: “deixa morrer”. Pedro responde: “vamos deixar”. Caso Maria morra, haverá coautoria, pois os dois concordaram em não socorrer a colega.

Também **é possível a participação em crimes omissivos próprios**. **Ex.:** o paciente vira para o médico e pede para que ele não cumpra a notificação compulsória de que o paciente é portador. O médico deixa de efetuar a notificação compulsória, baseado naquele apelo. O sujeito que pediu não omitiu, mas foi participe da omissão (art. 269, CP).

É possível a coautoria nos crimes omissivos impróprios(ou comissivos por omissão – que são aqueles crimes comissivos, mas cometidos por omissão por aquele que tinha o dever jurídico de evitar o resultado, que é o garante, previsto do art. 13, § 2º, CP), **desde que os garantes tenham de evitar o resultado, e de comum acordo não evitem o resultado**. **Ex.:** mãe e pai concordam em deixar o recém-nascido morrer.

9. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

O art. 29, §1º, CP, assevera que, se a participação for de menor importância, a pena poderá ser **diminuída de 1/6 a 1/3**. Isso se justifica em razão da pequena relevância causal que tem a conduta do agente.

O quantum de 1/6 a 1/3 considera a culpabilidade/censurabilidade do sujeito. Quanto maior a censurabilidade maior a pena.

10. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA

O art. 29, §2º, CP estabelece que, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; **essa pena será aumentada até metade**, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.



Os agentes podem ter dolos distintos. **Ex.:** indivíduos queriam furtar, mas ao ingressar na residência encontram uma pessoa em casa. Neste caso, um deles resolve roubar. João, dentro de casa, pratica roubo, enquanto José, fora de casa, imaginou participar de furto. José responde por furto qualificado e João pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Diante disso, querendo o agente praticar o crime menos grave, deverá responder por ele, caso o **imprevisível o resultado mais grave**. Por outro lado, deve-se aplicar a pena que do crime que o agente gostaria de ter praticado, **aumentada de metade, caso previsível o crime mais grave**.

11. COMUNICABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS, CONDIÇÕES E ELEMENTARES

Segundo o art. 30 do CP, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter **pessoal**, salvo quando elementares do crime.

Todos os tipos penais são integrados por suas elementares. Alguns também possuem circunstâncias.

O que for de caráter pessoal, circunstância ou condição, não se comunica. Só se comunica aquilo que for elementar.

- **circunstâncias:** são dados acessórios ao crime, dispensáveis para a configuração da figura penal básica, embora causem influência sobre a quantidade de pena. Podem ser objetivas e subjetivas:
 - **circunstâncias objetivas – Ex.:** furto mediante rompimento de obstáculo. Essa circunstância qualifica o crime de furto (elementar) e vai se comunicar.
 - **circunstâncias subjetivas:** não se comunicam como regra, salvo quando forem elementares, pois se referem ao agente. **Ex.:** quem mata o pai para receber herança comete homicídio qualificado pelo motivo torpe; o motivo torpe é uma circunstância do crime de homicídio, ligada ao crime, mas que se refere ao agente, sendo esta circunstância subjetiva, que não se comunica ao coautor.
- **condição:** é algo inerente ao indivíduo; a condição é inerente ao indivíduo, existindo independentemente da prática do crime. **Ex.:** reincidência, isto é, independente do crime, o sujeito vai ser reincidente. O mesmo ocorre em relação à condição da menoridade, eis que o indivíduo, por ser menor, não pratica crime, e sim ato infracional, não se comunicando com os demais agentes.
- **elementar:** são dados que constituem o tipo penal, ou seja, são os elementos constitutivos do crime. As elementares sempre se comunicam, sejam de caráter objetivo ou subjetivo. **Ex.:** a vítima é menor de 14 anos, e acaba por ser estuprada por dois indivíduos. Neste caso, o fato de ela ser menor de 14 é elementar para o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), sendo uma elementar que irá atingir os dois agentes, independentemente de suas condições.

As circunstâncias e condições de caráter objetivo se comunicam, desde que os demais indivíduos tenham o conhecimento. Ou seja, se ambos os indivíduos estiverem sabendo que o crime de furto foi cometido com rompimento de obstáculo, haverá furto qualificado. No entanto, caso um deles não tenha esse conhecimento, responderá apenas por furto simples.

12. PARTICIPAÇÃO IMPUNÍVEL

É a participação que não pune, salvo disposição em contrário.

Segundo o art. 31, do CP, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

Se o crime não chega ao menos ser tentado, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio não gera punição da participação, salvo se previstos como delitos penais autônomos.



CAPÍTULO 17 — TEORIA GERAL DA PENA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS

1. CONCEITOS E FUNDAMENTOS

Pena é uma sanção penal, uma resposta que o Estado dá para quem não observou uma norma penal.

A pena é a restrição ou privação de determinado bem jurídico do agente, para que seja responsável pelo que praticou.

2. FINALIDADES (OU FUNÇÕES) DA PENA

Para os **absolutistas**, pena é uma decorrência da delinquência, nasce da pena “ao mal do crime, o mal da pena”. Pena é a retribuição para o mal causado.

Para os **utilitaristas**, a pena é um instrumento de prevenção:

- **Prevenção geral:** a finalidade consiste em intimidar a sociedade.
 - **Prevenção geral negativa:** a pena é uma ameaça legal dirigida aos cidadãos para que se abstenham de cometer delitos. É uma coação psicológica.
 - **Prevenção geral positiva:** demonstração de que a lei ainda está vigente, criando uma sensação de confiança na sociedade.
- **Prevenção especial:** dirige-se ao criminoso.
 - **Prevenção especial negativa:** visa a carcerização ou inocuização do condenado quando outros meios menos lesivos não se mostrarem eficazes para sua ressocialização.
 - **Prevenção especial positiva:** a importância da pena está na ressocialização do condenado.

Há ainda a **teoria eclética**, em que a finalidade da pena assume estas duas finalidades: retribuição e prevenção geral e especial.

2.1. TEORIAS DA PENA

São várias as teorias da pena solicitadas em prova. Dentre elas, destacam-se:

- **Teoria agnóstica (Zaffaroni):**
Essa teoria tem como fundamento modelos ideais de estado de polícia e de estado de direito. Para a teoria agnóstica da pena existe uma grande dificuldade em acreditar que a pena possa cumprir, na grande maioria dos casos, as funções manifestas atribuídas a ela, expressas no discurso oficial. Para os seguidores dessa linha de pensamento, a pena está apenas cumprindo o papel degenerador da neutralização, já que empiricamente comprovada a impossibilidade de ressocialização do apenado. Não quer dizer que essa finalidade de ressocializar, reintegrar o condenado ao convívio social deva ser abandonada, mas deve ser revista e estruturada de uma maneira diferente. Para tanto, adverte-se que a reintegração social daquele que delinuiu não deve ser perseguida através da pena e sim apesar dela, vez que para efeitos de ressocialização o melhor criminoso é o que não existe.
- **Teoria dialética da pena (Zaffaroni):**
O discurso crítico da teoria dialética da pena demonstra a natureza real da retribuição penal nas sociedades modernas. Essa realidade não constitui um fenômeno de sobrevivência histórica da vingança, nem resquício metafísico de expiação ou de compensação de culpabilidade como as teorias preventivas apresentam. A teoria dialética mostra a emergência histórica da retribuição equivalente como fenômeno específico das sociedades capitalistas, pois a função de retribuição equivalente da pena corresponde aos fundamentos das sociedades fundadas na relação entre capital e trabalho assalariado. A partir daí se inicia uma tradição de pensamento



crítico em teoria jurídica e criminológica, na qual se inserem contribuições fundamentais da teoria marxista sobre crime e controle social.

Nessa tradição crítica, todo sistema de produção tende a descobrir a punição que corresponde às suas relações produtivas:

- a) se a força de trabalho é insuficiente para as necessidades do mercado, o sistema penal adota métodos punitivos de preservação da força de trabalho;
- b) se a força de trabalho excede as necessidades do mercado, o sistema penal adota métodos punitivos de destruição da força de trabalho. O sistema punitivo é um fenômeno social ligado ao processo de produção.

“Se a pena constitui retribuição equivalente do crime, medida pelo tempo de liberdade suprimida segundo a gravidade do crime realizado, determinada pela conjunção de desvalor da ação e de desvalor de resultado, então essa pena representa a forma de punição específica da sociedade capitalista e que deve perdurar enquanto existir a sociedade de produtores de mercadorias.”

- **Teoria retributiva (absoluta):**

Para a teoria retributiva, a finalidade da pena é **punir o autor de uma infração penal**. A retribuição se dá através de **um mal justo previsto no ordenamento jurídico em retribuição a um mal injusto praticado pelo criminoso**. A pena não é apenas um mal que se deve aplicar só porque antes houve outro mal, porque seria irracional querer um prejuízo simplesmente porque já existia um prejuízo anterior. **A imposição da pena implica no restabelecimento da ordem jurídica violada pelo delinquente.**

- **Teoria preventiva geral intimidatória (negativa):**

Direcionada à generalidade dos cidadãos. A pena pode ser concebida como forma acolhida de **intimidação das outras pessoas** através do sofrimento que com ela se inflige ao delinquente e que, ao fim, as conduzirá a não cometerem fatos criminais.

- **Teoria preventiva geral integradora (positiva):**

Direcionada à generalidade dos cidadãos. Fortalece a consciência jurídica dos cidadãos e sua confiança e fé no Direito. O Estado se serve da pena para **manter e reforçar a confiança da comunidade na validade e na força de vigência das suas normas** de tutela de bens jurídicos e, assim, no ordenamento jurídico-penal.

- **Teoria preventiva especial ressocializadora (positiva):**

Direcionada ao delinquente concreto. Busca a **ressocialização do delinquente**, através, da sua correção. Uma pena dirigida ao tratamento do próprio delinquente, com o propósito de incidir em sua personalidade, com efeito de evitar sua reincidência. A finalidade da pena-tratamento é a ressocialização.

- **Teoria preventiva especial inocuidadora (negativa):**

Direcionada ao delinquente concreto. tem como fim **neutralizar a possível nova ação delitiva**, daquele que delinuiu em momento anterior, através de sua "inocuidação" ou "intimidação". Busca evitar a reincidência através de técnicas, ao mesmo tempo, eficazes e discutíveis, tais como, a pena de morte, o isolamento etc.

3. FINALIDADE DA PENA NO BRASIL

No Brasil, a pena tem tríplice finalidade:

- **Retributiva**
- **Preventiva**
- **Reeducativa (ressocializadora)**



4. JUSTIÇA RESTAURATIVA

A justiça restaurativa tem como ideia restaurar a situação anterior ao crime, **recompondo os danos sofridos pela vítima**. Deve-se colocar os olhos sobre a vítima. **Ex.:** Lei 9.099/95, quando permite a composição civil dos danos.

Há um procedimento de consenso entre o autor do crime e a vítima, podendo envolver outros sujeitos da comunicada, a depender do caso. Não é apenas a retribuição do crime que é importante, tampouco a prevenção e a ressocialização, mas sim a **restauração do resultado anterior ao crime**. **Esta seria uma nova função da pena.**

5. PRINCÍPIOS INFORMADORES DA PENA

São princípios informadores da pena:

- **princípio da legalidade:** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, previsto na CF e no CP.
- **princípio da personalidade ou da intransmissibilidade:** a pena não passará da pessoa do condenado. É o princípio da intranscendência da pena, conforme art. 5º, XLV, CF.
- **princípio da individualização da pena:** a lei regulará a individualização da pena. Há uma preocupação de que a pena seja individualizada. Isto significa que a pena deve ser observada em vários momentos: 1º para o legislador; 2º para o juiz na dosimetria da pena; 3º para o juiz da execução da pena¹⁸.
- **princípio da proporcionalidade:** é um princípio implícito, decorrendo do devido processo legal. A ideia é de que esta noção penal deve ter razoabilidade na aplicação da pena. Deve-se considerar a personalidade do agente e os danos causados por ele, além de verificar as condições da vítima. Esse princípio da proporcionalidade se orienta pela proibição do excesso, bem como pela proibição da proteção deficiente. A proporcionalidade deve ser verificada pelo legislador e pelo magistrado.
- **princípio da inevitabilidade ou da inderrogabilidade da pena:** significa que se o sujeito cometer o crime, deverá obrigatoriamente cumprir a pena. A depender do caso, é possível aplicação do perdão judicial, hipótese em que não haverá interesse estatal.
- **princípio da dignidade da pessoa humana:** a dignidade da pessoa humana seria um postulado anterior ao princípio, sobre o qual os princípios são consagrados. A dignidade da pessoa humana não comporta ponderação, razão pela qual não é um direito fundamental, e sim um núcleo duro. Por conta disso, não haverá pena de morte, salvo guerra declarada, não haverá de trabalhos forçados, de caráter perpétuo, de banimento, cruéis etc.
- **princípio da vedação do bis in idem:** ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Não há previsão na CF, mas sim no Estatuto de Roma. Não tem caráter absoluto, pois é possível que o sujeito seja condenado e processado duas vezes pelo mesmo fato no caso de extraterritorialidade incondicionada. O STF já enfrentou um caso em que havia duas sentenças.

¹⁸O legislador individualizará a pena, por exemplo, quando prevê o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, cuja pena é de 2 a 8 anos; se há a utilização de explosivo ou de artefato análogo, a pena é de 4 a 10 anos. O próprio legislador traz os elementos individualizadores da pena: se o sujeito confessar, atenuar, se for reincidente, agrava, se tiver maus antecedentes, aplica-se a pena base em um patamar mais elevado, se a vítima contribuiu para a ocorrência do resultado, diminui a pena-base. Perceba que o legislador já inicia o processo de concretização do princípio da individualização da pena. O juízo da condenação, ao proferir sentença, observará essas circunstâncias e condições pessoais e individualizará a sanção. O princípio em comento também encontra guarida no juízo da execução, é possível, por exemplo, que João não trabalhe, que pratica falta grave, que não apresente bom comportamento carcerário, enquanto José trabalha, estuda, apresenta bom comportamento carcerário e, portanto, fará jus à remição da pena ou terá a execução da pena adequada à sua situação.



No caso, o Supremo reconheceu a nulidade da segunda sentença, **ainda que mais benéfica**, visto que o indivíduo não poderia ser processado e condenado duas vezes pelo mesmo fato.

6. PENAS PROIBIDAS NO BRASIL

6.1. PENA DE MORTE

Segundo o art. 5, XLVII, CF, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, em que haverá pena de fuzilamento para crimes militares.

Apesar da CF dizer que é vedada a pena de morte, a doutrina traz duas outras exceções:

- **abate de aeronave (art. 303, § 2º, CBA):** a lei permite que uma aeronave hostil, que esteja sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, e que não obedeça à ordem de pouso, hipótese em que poderá ser destruída, levando o piloto à morte. Não há previsão na CF desta ressalva, mas jamais foi julgado inconstitucional.
- **pessoa jurídica com atividades encerradas por violações ambientais (art. 24, Lei 9.605/98):** a pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

6.2. PENA DE CARÁTER PERPÉTUO

A vedação à pena de caráter perpétuo também pode ser vista pelo art. 75 o CP, o qual estabelece que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade **não pode ser superior a 40 anos**.

Atente-se que os 40 anos são de cumprimento da pena, podendo o indivíduo ser condenado a 120 anos.

Súmula 715 do STF: A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.

6.3. PENA DE TRABALHOS FORÇADOS

É vedado a pena de trabalhos que violam a dignidade da pessoa humana. Não é o trabalho do preso, pois isso favorece a dignidade humana.

6.3. PENA DE BANIMENTO

Banimento é a expulsão do nacional, a qual não é admitida.

6.4. PENAS CRUÉIS

Nesse caso, a pena cruel viola da dignidade da pessoa humana. É uma ordem ao Estado.

Por essa razão, não pode haver pena de castração física do estuprador, pois seria cruel.

Essa ordem é enviada ao legislador e ao Estado, o qual deverá assegurar condições mínimas para cumprimento da pena.

A pena, na maioria dos presídios do Brasil, viola a vedação à pena de caráter cruel (estado de coisas inconstitucional).



7. PENAS PERMITIDAS NO BRASIL

A CF estabelece, no art. 5º, XLVI, que são penas permitidas no Brasil:

- **privação ou restrição da liberdade**
- **perda de bens**
- **multa**
- **prestação social alternativa**
- **suspensão ou interdição de direitos**

Trata-se de um **rol exemplificativo**. A pena de advertência do art. 28 da Lei 11.343/06 não está prevista na CF.

7.1. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE

Poderá ser de reclusão, detenção ou prisão simples:

- **reclusão:** deve ser superior a 8 anos. Deve ter regime inicial fechado, semiaberto ou aberto (art. 33, CP);
- **detenção:** deve ter regime inicial semiaberto ou aberto. O regime fechado só em caráter de regressão por falta grave.
- **Prisão simples:** regime inicial semiaberto ou aberto. Não admite regime fechado mesmo em caráter de regressão.

7.2. RESTRITIVAS DE DIREITO

Essas penas podem ser:

- prestação pecuniária
- perda de bens e valores
- limitação de fim de semana
- prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas
- interdição temporária de direitos
- limitação de fim de semana

7.3. PENA DE MULTA

A pena de multa passou a ser considerada uma dívida de valor.



CAPÍTULO 18 — TEORIA GERAL DA PENA: APLICAÇÃO DA PENA

1. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

1.1. CONCEITO

Fixação da pena consiste em estabelecer a pena do condenado.

1.2. SISTEMA TRIFÁSICO (SISTEMA NÉLSON HUNGRIA)

Segundo o art. 68 do CP, a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Esse dispositivo consagra o **sistema trifásico**, também denominado de **sistema Néelson Hungria**:

- 1ª fase: circunstâncias judiciais do art. 59, CP;
- 2ª fase: agravantes e atenuantes;
- 3ª fase: causas de diminuição e aumento.

As qualificadoras não são consideradas, pois é a partir delas que se faz a dosimetria da pena.

O juiz calcula a pena privativa de liberdade. Em seguida, com base no art. 33, §2º, o juiz fixa o regime inicial da pena. Verifica a possibilidade de substituição da pena pelo art. 44. Se não for o caso, há possibilidade de suspensão da pena, com base no art. 77.

1.2.1. PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O art. 59 do CP traz 8 requisitos, sobre os quais o juiz deverá analisar:

- **culpabilidade**
- **antecedentes**
- **personalidade do agente**
- **conduta social**
- **motivos**
- **circunstâncias**
- **consequências do crime**
- **comportamento da vítima**

Obs.: No caso da Lei de Drogas, somam-se a esses os critérios de quantidade e qualidade da droga, nos termos do art. 42, da Lei 13.343/06.

O CP não diz qual é o critério de aumento que deverá haver para cada uma dessas circunstâncias.

Cabe ao juiz dizer. O juiz está atrelado ao mínimo e ao máximo fixado no preceito secundário do crime. O magistrado parte da pena mínima e vai valorando.

A lei também **não diz como deve ser feita a compensação entre as circunstâncias judiciais**, razão pela qual a doutrina afirma que deve ser feita uma **aplicação analógica do art. 67, CP**, que fala que nos casos de circunstâncias atenuante e agravantes, algumas prevalecerão.

Rogério Sanches sustenta que esta aplicação analógica não pode servir de prejuízo para o réu.

Em hipótese alguma pode o magistrado majorar a pena-base sem que haja fundamentação objetiva para justificar a exasperação.

A) CULPABILIDADE

Culpabilidade do agente significa a menor ou maior grau de censurabilidade do comportamento.



Segundo o STF, para fins de dosimetria da pena, **culpabilidade consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.**

Essa culpabilidade de que trata o art. 59 do CP não tem nada a ver com a culpabilidade como requisito do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e inexigibilidade de conduta diversa)

STF: no tráfico de drogas, o juiz não pode aumentar a pena-base sob o argumento de que a venda da droga ocorria dentro da própria casa do condenado, pois não enseja maior reprovabilidade da conduta.

STJ: o fato de o crime de corrupção passiva ter sido praticado por promotor de justiça no exercício da função poderá servir como circunstância desfavorável, pois há maior reprovabilidade da conduta. Da mesma forma ocorre com relação a essas espécies de crimes cometidos por policiais.

B) ANTECEDENTES

Antecedente é aquilo que o indivíduo **fez antes do crime**, não sendo aquilo que ele fez depois do crime.

Por exemplo, no dia 2 de janeiro de 2018, João cometeu um furto. Após, João foi processado. Durante o processo, João cometeu mais de 30 furtos. Não poderão esses 30 furtos serem valorados negativamente.

A Súmula 444 do STJ deixa claro que **inquéritos policiais em aberto e ações penais em curso não podem agravar a pena-base**, não servindo como antecedentes.

Da mesma forma, **atos infracionais não podem servir como maus antecedentes.**

Segundo o STJ (Inf. 576), atos infracionais não configuram crimes e, por isso, não é possível considerá-los como maus antecedentes nem como reincidência, até porque fatos ocorridos ainda na adolescência estão acobertados por sigilo e estão sujeitos a medidas judiciais exclusivamente voltadas à proteção do jovem.

Condenações definitivas por fatos praticados antes do fato que está sendo julgado podem servir como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado do fato pretérito tenha se dado posteriormente ao delito em apreço. Isto é, se o indivíduo não for reincidente, poderá ser considerado como circunstância judicial desfavorável. Por outro lado, **se o indivíduo for reincidente, somente poderá considerá-la uma única vez, ou nas circunstâncias judiciais ou na agravante**, sob pena de *bis in idem*. Sendo o agente **duplamente reincidente**, uma reincidência é possível utilizar para fins de agravante e a outra para circunstâncias judiciais (Súmula 244, STJ).

Segundo o STJ, a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, **pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.**

Após 5 anos do cumprimento de extinção da pena, **não poderá mais se considerar como reincidência, mas poderia ser considerado como maus antecedentes.** Este é o entendimento de Sanches e do STJ. No entanto, **o STF não admite sequer considerar como maus antecedentes, pois haveria uma condenação perpétua** (Min. Dias Toffoli).

Informativo 647 – STJ (24/05/2019) – Dizer o Direito

Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam



fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

STJ. 3ª Seção. EAREsp 1.311.636-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019 (Info 947).

C) CONDUTA SOCIAL

Conduta social é o modo como o agente se comporta em sociedade, no ambiente familiar, no trabalho, igreja, na comunidade, etc.

Com base nessa ideia, é possível falar em **testemunhas de beatificação**, as quais afirmam a boa conduta do agente.

Segundo o STF, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. Não se admite a “conduta social desfavorável”.

O fato de o réu ser usuário de drogas não pode ser considerado, por si só, como má-conduta social.

Informativo 639-STJ (01/02/2019) – Dizer o Direito

A circunstância judicial “conduta social”, prevista no art. 59 do Código Penal, representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos.

Os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São circunstâncias distintas, com regramentos próprios.

Assim, não se mostra correto o magistrado utilizar as condenações anteriores transitadas em julgado como “conduta social desfavorável”.

Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negar a conduta social.

STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825).

STJ. 5ª Turma. HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/12/2018.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639).

D) PERSONALIDADE DO AGENTE

É o retrato psíquico do delinquente.

Por essa razão, segundo o STJ, isto deve ser aferido objetivamente, ou seja, a simples menção à personalidade do infrator, desprovida de elementos concretos, não se presta à negatificação dessa circunstância. É necessário que um profissional ateste a situação do delinquente.

Informativo 639-STJ (01/02/2019) – Dizer o Direito

A existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime.

Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade do agente.

STJ. 5ª Turma. HC 466.746/PE, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 11/12/2018.



STJ. 6ª Turma. HC 472.654-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 (Info 643).

E) MOTIVOS DO CRIME

É aquilo que levou o indivíduo a praticar o crime.

Não pode valorar negativamente um motivo inerente ao crime, ou quando funciona como qualificadora. **Ex.:** no furto, a ideia de lucro fácil já é inerente ao crime.

A simples **falta de motivos não constitui fundamento idôneo** para o incremento da pena-base.

F) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

É a forma como o crime foi cometido nas circunstâncias de tempo, local, instrumentos etc.

G) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

É o resultado do delito decorrente daquela infração penal.

H) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

É a análise se a vítima provocou ou não o crime.

Não há compensação de culpas, mas, **se há uma culpa concorrente**, deverá ser valorada em favor do agente.

Se o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime, isso significa que essa circunstância é neutra, de forma que não pode ser utilizada para aumentar a pena imposta ao réu.

1.2.2. SEGUNDA FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase, haverá as agravantes e atenuantes.

O CP trata de agravantes e atenuantes, havendo uma preponderância entre algumas, mas não há fixação de quanto de exasperação, ficando a critério do magistrado.

A doutrina e a jurisprudência caminham no sentido de que o magistrado deve valorar em 1/6, entendendo a jurisprudência que o juiz deve observar o mínimo e o máximo do preceito secundário (Súmula 231, STJ).

A) PREPONDERÂNCIA

De acordo com o art. 67, no concurso de agravantes e atenuantes, **a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes.**

As **circunstâncias preponderantes** são aquelas que resultam:

- dos **motivos do crime**,
- da **personalidade do agente** e
- da **reincidência**.

Entre as circunstâncias preponderantes, a própria jurisprudência fixou critérios de prevalência.

- **atenuante que mais prepondera:** menoridade (menor de 21 anos) ou a senilidade (maior de 70 anos);
- **segunda que mais prepondera:** reincidência;
- **após:** agravantes e atenuantes subjetivas;
- **por último:** agravantes e atenuantes objetivas;



Na reincidência, **o STJ tem feito a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.**

Em relação às agravantes, é possível perceber que há um **rol taxativo**, eis que o direito penal não admite analogia *in malam partem*.

As agravantes, **via de regra, só vão incidir em crimes dolosos, mas há a exceção da reincidência.** Ou seja, o indivíduo que fica cometendo crimes culposos reincidentemente deverá sofrer essa agravante.

O art. 385 do CPP estabelece que **não é necessário que a denúncia venha descrevendo qual é a agravante ou a atenuante.** Ainda que não haja previsão na denúncia, é possível o magistrado reconhecer uma agravante ou uma atenuante na sentença.

B) AGRAVANTES

Segundo o art. 61 do CP, as circunstâncias que sempre agravam a pena, quando **não constituem ou qualificam o crime.** São agravantes:

- reincidência
- cometido o crime por motivo fútil ou torpe
- cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
- cometido o crime à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
- cometido o crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum
- cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge
- cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
- cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão
- cometido o crime contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
- cometido o crime quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade
- cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido
- cometido o crime em estado de embriaguez preordenada

→ Reincidência

Com relação à reincidência, o art. 63 do CP estabelece que se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado **por crime anterior.**

Para ser reincidente, o indivíduo, após ter sofrido uma sentença condenatória transitada em julgado, deverá ter cometido um novo crime.

Essa leitura deve ser feita em conjunto com o art. 7º da LCP, que diz que **há reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.**

Observe! Não será considerado reincidente:

- se o indivíduo tiver uma sentença transitada em julgado por um **crime cometido no Brasil ou no estrangeiro e cometer uma contravenção ou crime**, será ele **reincidente.**
- se o indivíduo tiver uma sentença transitada em julgado por uma **contravenção cometida no Brasil e cometer uma contravenção**, será ele **reincidente.**

Por outro lado:

- se o indivíduo tiver uma sentença transitada em julgado por uma **contravenção cometida no Brasil e cometer um crime**, **não será ele reincidente.**



- se o indivíduo tiver uma sentença transitada em julgada por uma **contravenção cometida no exterior e cometer um crime, não será ele reincidente.**
- se o indivíduo tiver uma sentença transitada em julgada anterior **por crime político, ou por crime militar próprio**, e depois **cometer um crime comum ou um crime militar impróprio**, também **não será considerado reincidente**;

Atente-se que, **no caso de crime militar próprio, ele só será considerado reincidente se cometer outro crime militar próprio.**

Obs.: não há necessidade de homologação da sentença penal estrangeira para que produza efeitos da reincidência no Brasil.

Se houver ***abolitio criminis*** ou **anistia no delito anterior**, o sujeito **não é considerado reincidente**, pois estas apagam os efeitos penais principais e acessórios, mantendo os efeitos extrapenais.

O Brasil adota o **sistema da temporariedade da reincidência**, razão pela qual ultrapassado o período depurador de **5 anos do cumprimento da pena**, o sujeito não será mais reincidente.

Se o indivíduo teve a **pena suspensa ou teve livramento condicional**, com a posterior declaração de extinção da pena, **esse período será considerado para fins de período depurador**. Ou seja, se o indivíduo ficou 2 anos em livramento condicional, tendo posteriormente a pena sido extinta, passados mais 3 anos, o sujeito terá completado o período depurador de 5 anos, situação em que, se praticar nova infração penal, não será considerado reincidente.

A reincidência pode ser:

- **reincidência genérica:** é aquela que o sujeito comete um crime e depois comete um crime de outra espécie.
- **reincidência específica:** o agente comete um crime da mesma espécie, após de ter tido uma sentença penal condenatória por um delito daquela espécie.

Há algumas **consequências para o reincidente específico**. **Ex.:** obsta a substituição da pena (art. 44, §3º, CP); fica obstado a concessão de livramento condicional nos crimes hediondos, quando o sujeito é reincidente específico em crimes desta natureza (o art. 83, V, CP).

A jurisprudência faz um temperamento em relação à reincidência geral e específica. **No caso de crimes hediondos, haverá reincidência específica quando o indivíduo cometeu um crime hediondo seja qual for e após cometeu outro crime hediondo de diferente espécie.** Portanto, se o indivíduo cometeu um crime homicídio qualificado e, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cometeu estupro de vulnerável, ainda assim será considerado reincidente específico.

A prova da reincidência se dá através de **certidão cartorária**, sendo certo que o STJ admite que se possa comprovar com a folha de **antecedentes criminais**.

Por fim, **a reincidência não pode ser considerada como agravante e maus antecedentes**, conforme a súmula 241 do STJ. Todavia, **caso o sujeito seja duplamente reincidente, poderá uma delas servir como circunstância judicial e a outra como agravante.**

→ **Motivo fútil ou torpe**

O motivo fútil é o motivo insignificante. Há uma desproporção entre a causa do crime e o crime cometido. **Ex.:** Ao agente é negado uma balinha que, por essa razão, mata o indivíduo (motivo fútil).

Vingança e ciúmes não serão sempre motivos fúteis, dependendo do caso concreto. Não necessariamente são motivos fúteis. **Ex.:** Quem mata o estuprador da filha, mata por vingança, não havendo motivo fútil. A depender, se o sujeito agir sob o domínio de violenta emocional e relevante valor moral, esta conduta poderá ser considerada, inclusive, como homicídio privilegiado.

Segundo o STJ, o **dolo eventual não é compatível com a agravante do motivo fútil**, já que o sujeito apenas assume o risco da ocorrência do resultado.

A qualificadora do motivo fútil não pode ser aplicada ao agente que participa de racha e causa a morte de terceiro não participante ao colidir com o carro deste, em virtude de direção imprudente (Inf. 583).

Obs.: Quando o motivo fútil for qualificadora, não funcionará como agravante. No caso do homicídio, ele funciona como qualificadora. Se o sujeito pratica um homicídio porque está participando de racha,

trazendo à tona a possibilidade de dolo eventual (o CTB foi alterado para considerar tal conduta como crime culposos), ainda que se considere que há dolo, o motivo fútil é afastado, vez que o sujeito não tinha a intenção. **O dolo eventual não é compatível com o motivo fútil.**

→ **Crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime**

Temos aqui um crime conexo a outro delito.

Há aqui duas hipóteses de conexão:

- **conexão teleológica:** crime é cometido para assegurar a execução de outro delito.
- **conexão consequencial:** o crime é cometido para assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime cometido no passado.

→ **Crime à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido**

O Código Penal traz uma série de hipóteses agravantes e as encerra de forma genérica, o que permite a adoção de uma interpretação analógica.

Segundo o STF, **o dolo eventual é incompatível com a agravante da traição, emboscada ou outro motivo que impossibilite a defesa da vítima.**

→ **Crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum**

Mais uma vez, a norma traz uma série, terminando com um encerramento genérico. A consequência é a possibilidade de interpretação analógica.

Meio cruel é um crime que causa um sofrimento desnecessário à vítima.

→ **Crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge**

As agravantes até então analisadas se aplicam a crimes dolosos, crimes culposos não permitirão, via de regra, a incidência dessas agravantes, salvo a reincidência.

O direito penal, naquilo que agrava a pena ou prejudica a situação do réu, não admite analogia.

Isto significa que **não se pode incluir o companheiro**, assim como o parentesco por afinidade, uma vez que ordenamento jurídico veda a analogia *in malam partem*.

Este parentesco se prova por meio documental.

→ **Crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica**

Geralmente, quando o sujeito o comete um crime na seara da Lei Maria da Penha, incide essa agravante, porque foi um crime cometido com violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06.

Quando a lei se refere ao abuso de autoridade, não significa que se trata de relações públicas, mas de **relações privadas**, é a autoridade que alguém exerce sobre outrem. Em outras palavras, é um excesso que ocorre quando há uma posição de superioridade do ofensor no relacionamento com o ofendido. **Ex.:** tutor e tutelado, curador e curatelado, do pai em relação ao filho, havendo um abuso nesta relação.

→ **Cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão**

Abuso de poder: aqui sim, há relação pública. Nesses casos, há um excesso do exercício de uma relação pública.

Com relação ao cargo, ofício, ministério ou profissão, há um excesso na relação privada. Nesse caso, há um abuso no exercício da função.

→ **Crime contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida**

Criança, segundo o ECA, é a pessoa com até 12 anos incompletos. A partir dessa idade, torna-se adolescente.

O Estatuto do Idoso estabelece que idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. No entanto, o CP diz que a agravante incide sobre o **maior de 60 anos**. Isso significa dizer que se o crime é cometido no dia em que a pessoa completa 60 anos, não poderá incidir essa agravante, pois ela teria 60 anos. Há opinião em sentido diverso.

Nesses casos, para incidir a agravante são necessários dois requisitos:



- **nexo entre a condição da vítima e o crime praticado:** a ideia é que a agravante incida em razão da maior vulnerabilidade da vítima.
- **consciência desta situação da vítima:** é necessário que o agente tenha conhecimento dessa condição, uma vez que não se admite responsabilidade penal objetiva.

→ **Crime quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade**

A vítima deve estar sob a imediata proteção da autoridade.

Ex.: No interior de alguma unidade federativa a população deseja atingir sujeito que estuprou várias crianças (só não o fazem porque aquele está na delegacia, sob a proteção da autoridade), se lograssem êxito nesse intento, incidiria a agravante.

O que é diferente do:

Resgate de preso na delegacia. Neste caso, só incidiria caso o preso fosse de uma facção e o resgate fosse por uma facção rival, hipótese em que o ofendido estaria sob a imediata proteção da autoridade. Nos resgates de preso na delegacia pela própria facção do preso, não haverá essa agravante, pois o ofendido não é o sujeito que foi resgatado, mas o Estado.

→ **Crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido**

Cabível a agravante porque o sujeito se vale de uma situação dramática pela qual passa a vítima para praticar a infração penal. Neste caso, há um maior grau de reprovabilidade.

→ **Crime em estado de embriaguez preordenada**

É a embriaguez feita para cometer o crime. Nesse caso, deve-se aplicar a teoria da *actio libera in causa*.

O sujeito se embriaga para praticar a infração penal. Se o sujeito estiver completamente embriagado, não haverá alteração na causa, pois a ação era livre.

→ **Agravantes cometidas por duas ou mais pessoas**

Segundo o art. 62, CP, a pena será ainda agravada em relação ao agente que:

- é o **líder da organização**: promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
- **coage ou induz outrem** à execução material do crime, é o caso do **autor mediato**;
- **instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível** em virtude de condição ou qualidade pessoal (autor mediato);
- executa o crime, ou nele participa, **mediante paga ou promessa de recompensa**, é o caso do delinquente mercenário.

Se a coação é resistível, o sujeito coator responde com a agravante e o coagido com a atenuante. Se irresistível, só o coator responde, o coagido terá extinta a sua punibilidade. Da mesma forma, se há uma ordem que não é manifestamente ilegal e nem proferida por superior hierárquico, haverá excludente de culpabilidade. Se o subordinado, diante de uma ordem, percebe que é ilegal, mas ainda assim pratica, seu superior hierárquico terá a pena agrava, quem obedeceu terá a pena atenuada.

Segundo o STJ, **é possível que a pena daquele condenado por homicídio, na condição de mandante, seja agravada em razão de promover ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes, sem que haja *bis in idem***(Inf. 580, STJ).

Também é **possível compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da promessa de recompensa**, segundo o STJ (Inf. 577). Tem-se, portanto, duas circunstâncias (uma atenuante ou agravante) de caráter subjetivo, que demonstram a personalidade do sujeito e que, portanto, devem preponderar. Nesse caso, como elas preponderam, elas se compensam.

C) ATENUANTES

As atenuantes, em regra, atenuam a pena.

Há algumas exceções em que as atenuantes não atenuam, e uma delas é o caso em que não incide a atenuante quando a circunstância já constitui ou privilegia o crime, como é o caso do homicídio



privilegiado em que a pessoa comete o crime por motivo de relevante valor moral ou social. Nesse caso, **o privilégio abrange a atenuante, hipótese em que a atenuante não deve ser aplicada**. Nesse sentido, é a posição da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Corolário desse entendimento é a faceta do princípio da proporcionalidade em razão do princípio da proibição deficiente.

Nos termos da Súmula 232 do STJ, a incidência de uma circunstância atenuante não pode ficar abaixo do mínimo legal.

A atenuante incide em todos os crimes: **doloso, culposo ou preterdoloso**.

São **circunstâncias atenuantes**:

- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença condenatória de 1º grau¹⁹;
- desconhecimento da lei;
- ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;
- ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;
- ter o agente cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
- ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;
- ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, **se não o provocou**.

→ Menoridade

Haverá atenuante se o agente **menor for 21 anos na época do fato**. A lei diz que o agente é imaturo, devendo ser considerada uma **circunstância preponderante**.

→ Senilidade

Haverá atenuante se o agente for **maior de 70 anos, na data da sentença**.

A data da sentença é a data de sentença de primeiro grau, salvo se esta for absolutória, hipótese em que, caso haja recurso, o **acórdão condenatório será considerado como marco para se aferir a idade do sujeito**.

→ Desconhecimento da lei

O desconhecimento da lei é inescusável, motivo pelo qual o sujeito responde pelo crime, salvo em contravenções penais, mas há uma atenuante.

Não se confunde com o erro de proibição, em que o sujeito desconhece a ilicitude de sua conduta, que é causa excludente da culpabilidade.

Pode o sujeito desconhecer a lei, mas, ainda assim, ter consciência de que sua conduta é ilícita.

→ Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral

Incidirá a atenuante, desde que não configure o privilégio.

Relevante valor moral é aquele presente na situação em que se manifesta o interesse individual no caso. Ex.: agente que mata o estuprador da filha.

No motivo de relevante valor social, o indivíduo age impellido por motivos sociais, como é o caso do indivíduo que mata o estuprador de cem meninas da cidade.

→ Ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano

A reparação do dano funciona como atenuante quando não for mais benéfica.

Exemplos:

¹⁹Far-se-á presente essa atenuante se a sentença for absolutória e o Tribunal reformá-la por recurso do MP para condenar. Neste caso, o acórdão condenatório que será considerado para fins de verificação se o sujeito era ou não maior de 70 anos.



A reparação do dano nos termos do art. 16 do CP pode configurar arrependimento posterior, que é causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3; se o sujeito repara integralmente o dano antes do recebimento da denúncia, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena será diminuída;

No peculato culposo, a reparação integral antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória extingue a punibilidade e após, diminui a pena na metade.

A composição civil dos danos no juizado especial (crimes de **menor potencial ofensivo**) extingue a punibilidade.

Outra hipótese em que **não se aplica essa atenuante é para o caso de pagamento de cheque sem fundos antes do recebimento da inicial**, situação que obsta a instauração da ação penal, de acordo com a súmula 554 do STF.

No caso de **pagamento de tributos, haverá a extinção da punibilidade.**

→ **Ter o agente cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima**

No caso de coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, tem-se uma agravante para quem deu a ordem e uma atenuante para quem obedeceu.

No caso da **influência** de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incidirá quando estivermos diante de homicídio privilegiado por essa causa, eis que, no homicídio privilegiado, o indivíduo estaria **sob o domínio** de violenta emoção.

→ **Ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime**

Trata-se da atenuante da confissão espontânea, sendo aquela não instigada ou induzida por ninguém.

Se a confissão for voluntária, mas não tendo sido espontânea, pois alguém o influenciou, caberá a atenuante denominada pelo art. 66 do CP.

A confissão pode ser:

- **Confissão simples:** o indivíduo apenas admite a prática do crime. Poderá ser:
 - **Total:** sujeito afirma todo o fato.
 - **Parcial:** sujeito confessa parte do fato. **Ex.:** furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mas confissão de furto simples.
- **Confissão qualificada:** o indivíduo admite a prática do crime, mas levanta a seu favor uma excludente de culpabilidade ou ilicitude.

Para o STF, **é plenamente possível aplicar a atenuante da confissão, quando a confissão qualificada foi valorada como meio de prova.** **Ex.:** sujeito que confessa o fato típico de ter roubado por estar em estado de necessidade ou mediante inexigibilidade de conduta diversa, excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Se o sujeito não confessa o fato típico, não fará jus à atenuante da confissão.

A Terceira Turma do STJ aprovou a Súmula 630 que assim dispõe: *A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.*

Se o agente confessa o crime no curso do inquérito, mas se retrata durante a ação penal, a confissão poderá ser usada como atenuante, desde que valorada como meio de prova.

STJ: a confissão revela a personalidade do indivíduo, razão pela qual possui caráter preponderante, sendo plenamente possível sua compensação com a reincidência.

STF (2014): a reincidência prepondera sobre a confissão espontânea.

STJ: a agravante da violência contra a mulher compensa com a atenuante da confissão espontânea.

→ **Ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou**

Se o sujeito provocou, haverá incidência da agravante, mas, se não o provocou, incidirá essa atenuante. Trata-se do **crime multitudinário**.

→ **Circunstância denominada**

Segundo o art. 66, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, **anterior ou posterior ao crime**, embora não prevista expressamente em lei.



A doutrina traz o exemplo da **coculpabilidade**, em que a sociedade teria contribuído pela prática de um crime, razão pela qual deveria incidir essa circunstância inominada. **Ex.:** o indivíduo nunca estudou, não teve acesso à saúde, moradia, era dependente químico desde a infância, etc. Estado esteve ausente durante este tempo, mas quando o sujeito comete crime, atua para aplicar-lhe reprimenda. Perceba que a sociedade tem parcela de culpa pela situação na qual chegou o sujeito.

Os professores LFG e Antonio Molina discordam da coculpabilidade, defendendo a aplicação da **teoria da vulnerabilidade**. Para os professores, atenuar a situação ou agravar a situação do indivíduo depende de sua maior ou menor vulnerabilidade. Quem conta com alta vulnerabilidade são aqueles que estão sujeitos ao direito penal por falta de instrução intelectual ou econômica, mais suscetíveis ao crime. Nesses casos, a culpabilidade do indivíduo estaria reduzida, por conta dessa hipervulnerabilidade, motivo pelo qual a pena deveria ser atenuada pela circunstância inominada. Por outro lado, LFG afirma que o sujeito que tem baixa vulnerabilidade, pois tem condição de pagar advogado, tem família, instrução, educação etc., deverá ter uma culpabilidade maior, também chamada de culpabilidade às avessas. Por essa razão, quem tem maior vulnerabilidade tem menor culpabilidade, enquanto o que tem menor vulnerabilidade tem maior culpabilidade.

1.2.3. TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA

O ponto de partida é a **pena intermediária**.

As causas de diminuição e de aumento são denominadas minorantes e majorantes.

Estabelecem o quantum de aumento ou diminuição, podendo levar a pena acima do máximo e abaixo do mínimo previsto em lei.

Não podem ser confundidas com as qualificadoras, pois estas alteram o intervalo da pena.

A) CONCURSO (HOMOGÊNEO) ENTRE CAUSAS DE AUMENTO

O concurso entre causas de aumento pode estar na parte geral e/ou na parte especial.

i. Concurso entre causas de aumento previstas na parte geral

Sendo causas de aumento previstas na **parte geral**, por exemplo duas causas, **haverá a aplicação das duas causas de aumento**. Aqui, deverá ser aplicado o **princípio da incidência isolada**. Ou seja, no concurso de causas de aumento da parte geral aplicam-se as duas, adotando esse princípio, visto que é mais benéfico ao réu.

Segundo o **princípio da incidência isolada**, o aumento recai sobre a pena precedente (intermediária), e não sobre a pena já aumentada.

Exemplo: João teve sua pena fixada em 4 anos de reclusão. Estão presentes duas causas de aumento, que determinam que a pena seja aumentada de metade. Neste caso, a primeira causa de aumento incide sobre 4 anos, devendo somar mais 2, totalizando 6 anos. Para aplicar a outra causa de aumento, deverá incidir sobre os 4 também, de modo que haverá a soma de mais 2 anos sobre os 4 anos iniciais, somando-se ainda os 2 anos da primeira causa, totalizando 8 anos.

Não se aplica o princípio da incidência cumulativa, a qual permite que as causas de aumento de pena incidam sobre as penas já aumentadas, pois isso seria desfavorável ao réu. Partindo do exemplo assim, somando-se 4 anos mais a metade, tem-se 6 anos acrescidos da metade, que totalizaria 9 anos.

ii. Concurso entre causas de aumento previstas na parte especial

No caso de concurso previsto na parte especial, o art. 68, parágrafo único, do CP, estabelece que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, **pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua**.

Portanto, não há necessidade de o juiz considerar as duas causas de aumento, podendo considerar apenas uma delas, desde que seja a que mais aumente.

Havendo concurso entre as causas de aumento da parte geral com a da parte especial, haverá a incidência das duas, aplicando-se o princípio da incidência isolada.



B) CONCURSO (HOMOGÊNEO) ENTRE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO

A regra é a mesma, mas o princípio é diferente.

Todavia, no caso de concurso entre causas de diminuição, deverá ser aplicado o **princípio da incidência cumulativa**. Ou seja, se aplicar uma causa de diminuição de pena, deverá incidir a outra causa de diminuição sobre o resultado da operação anterior.

É a pena já diminuída que passa a ser paradigma para o cálculo da próxima causa de diminuição da pena.

Exemplo: João foi condenado a 4 anos de reclusão, presentes duas causas de diminuição. Cada uma delas reduz a pena da metade: uma na parte geral e outra na especial. Se for utilizado do princípio da incidência cumulativa, a causa de diminuição reduzirá a pena de João a 2 anos. Posteriormente, esta pena deverá ser reduzida por metade, devido à outra minorante. Sendo assim, João será condenado a 1 ano.

i. Concurso entre causas de diminuição previsto na parte geral

Se houver duas causas de diminuição previstas na parte geral, aplicam-se as duas.

ii. Concurso entre causas de diminuição previstas na parte especial

Nos termos do art. 68, parágrafo único, havendo concurso entre duas causas de diminuição previstas na parte especial, deverá ser aplicada apenas uma causa de diminuição, desde que seja a que mais diminua.

iii. Concurso entre causas de diminuição previstas na parte geral e na parte especial

Havendo concurso entre causas de diminuição previstas na parte geral e na parte especial, aplicam-se as duas.

Obs.: A jurisprudência atesta a aplicação das limitações do art. 68, parágrafo único, do CP, referente causa de aumento de diminuição e aumento de pena, à legislação penal extravagante.

C) CONCURSO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO

No caso de concurso entre causas de aumento e de diminuição, deverão ser aplicadas as duas, formando um **concurso heterogêneo**.

Nesse caso, haverá a aplicação das duas causas com base no **princípio da incidência cumulativa**.

Ao chegar na pena definitiva, o juiz vai **desconsiderar as frações de dias**.

1.3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, deverá fixar o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. A isso se dá o nome de fixação do regime inicial. Os critérios para essa fixação estão previstos no art. 33 do Código Penal.

O juiz, quando vai fixar o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, deve observar quatro fatores:

- 1) o **tipo de pena** aplicada: se reclusão ou detenção;
- 2) o **quantum da pena** definitiva;
- 3) se o condenado é **reincidente ou não**;
- 4) as **circunstâncias judiciais** (art. 59, do CP).

São regimes iniciais de cumprimento da pena:

- regime fechado
- regime semiaberto
- regime aberto



1.3.1. REGIME FECHADO

A pena deve ser cumprida em penitenciária, devendo o condenado ser alojado em uma cela individual, com tamanho mínimo de 6m², com sanitário, salubre, aerada, com dormitório, aparelho sanitário e lavatório (arts. 87 e 88 da LEP).

O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena em regime fechado, a **exame criminológico**.

Este exame é importante para individualização da pena, passando a considerar as características daquele sujeito. Trata-se da aplicação desse princípio constitucional na fase de execução.

O preso fica sujeito a trabalho durante o dia e a isolamento durante o repouso noturno. O trabalho dentro do estabelecimento prisional é um **direito e um dever ao mesmo tempo**. Trata-se de um direito, pois **a cada 3 dias de trabalho abate 1 dia de pena**, denominado remição da pena.

O período de atividade laboral do apenado **que exceder o limite máximo da jornada de trabalho** (8 horas) deve ser contado para fins de remição, **computando-se 1 dia de trabalho a cada 6 horas extras realizadas**.

O trabalho em regime fechado **em regra ocorre dentro do estabelecimento prisional**. Todavia, o **trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas**, desde que haja autorização do juízo da execução ou do diretor do estabelecimento²⁰.

O condenado, para ter direito a trabalho externo, além de autorização da direção do estabelecimento, dependerá de **aptidão, disciplina e responsabilidade, e do cumprimento mínimo de 1/6 da pena**. Esta trabalho externo é quase inócuo nesta fase, pois, via de regra, o sujeito progride com o cumprimento de 1/6 da pena, de modo que não haveria como trabalhar externamente no regime fechado nesses casos, salvo se cometeu crime hediondo, eis, em tais delitos, exige-se uma fração maior para progressão.

Obs.: o preso **não está submetido às regras da CLT**, mas **deverá ser remunerado**. Apesar de não estar regulado pela CLT, tem a **garantia da previdência social**, nos termos do art. 39, do CP.

Admite-se a remição pelo estudo. A jurisprudência admite a remição inclusive pela leitura. A Súmula 341 do STJ assevera que a frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena **sob regime fechado ou semiaberto**.

Essa é a previsão da súmula, mas, em 2010, a Lei 12.245/10 alterou a redação do art. 83 da LEP, a fim de **autorizar a instalação de salas de aulas nos presídios**.

A Lei 12.433/11 é expressa ao dizer que **é possível a remição inclusive nos 3 regimes (fechado, aberto e semiaberto) e no livramento condicional se o sujeito está estudando**. Cada 12 horas de frequência no curso, distribuídas em pelo menos 3 dias, dão direito à remição de 1 dia de pena.

O tempo remido em função das horas de estudo **será acrescido de 1/3 caso o condenado consiga concluir o ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena**.

A remição pelo estudo pressupõe a frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, **independentemente da sua conclusão ou do aproveitamento satisfatório**.

É ainda **possível que seja cumulado o estudo com o trabalho**. O curso pode se dar de forma **presencial ou à distância**, desde que haja certificado.

Segundo o STJ, **não há remição da pena na hipótese em que o condenado deixa de trabalhar ou estudar em virtude da omissão do Estado** em fornecer tais atividades.

É possível a remição da pena **por meio da leitura**.

A decisão que reconhece a remição da pena, em virtude de dias trabalhados, **não faz coisa julgada nem constitui direito adquirido**.

²⁰Vide DECRETO 9.450 de 24 de JULHO DE 2018: Institui a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, voltada à ampliação e qualificação da oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo e à formação profissional das pessoas presas e egressas do sistema prisional.



Obs.: O ECA garante a convivência da criança ou do adolescente com o pai ou a mãe com a sua liberdade privada. Este acesso se dá por meio de visitas, as quais **não dependem de autorização judicial**.

1.3.2. REGIME SEMIABERTO

A pena será cumprida, no regime semiaberto, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, podendo o apenado ser **alojado em compartimento coletivo**.

Lembre-se que **no regime fechado o indivíduo fica em cela individual, enquanto no regime semiaberto é possível alojamento coletivo**. Isso porque é o início da preparação do indivíduo ao seu retorno à vida em sociedade.

O trabalho é admissível dentro do presídio durante o período diurno. **O trabalho externo também é admissível**, bem como a **frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior**. Este trabalho poderá ser em obras e serviços públicos, mas **também para a iniciativa privada**.

No caso da **iniciativa privada**, a jurisprudência exige **prévia autorização judicial**.

Admite-se a frequência a **cursos fora do estabelecimento**, podendo ser profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior, valendo como remição da pena.

STF: **se a pena-base foi fixada no mínimo legal** (circunstâncias judiciais favoráveis), **o juiz deverá estabelecer o regime inicial semiaberto para o condenado a pena superior a 4 e que não exceda a 8 anos, desde que não reincidente**. Aplica-se ao caso a Súmula 440 do STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

1.3.3. REGIME ABERTO

No caso do regime aberto, a ideia é começar a trabalhar com o sujeito, considerando a sua aptidão ao retorno da vida social.

Cabe ressaltar que **não há remição pelo trabalho no regime aberto**, pois trabalhar é **condição necessária** para que o apenado possa estar nesse regime.

O condenado vai sair do estabelecimento durante o dia, frequentando cursos ou exercer algum trabalho. **Durante a noite, o indivíduo volta para se recolher na casa de albergado**.

Tanto no período noturno como nos dias de folga o indivíduo fica na casa de albergado. Essa casa de albergado é um imóvel sem grades, não existindo obstáculos físicos à fuga.

Geralmente, não há casa de albergado ou não há vagas na casa de albergado existente. Nesses casos, **a lei permite que o sujeito cumpra pena em estabelecimento adequado**, conforme as condições pessoais do reeducando.

Também é possível que, na falta da casa de albergado, o sujeito **cumpra pena em prisão domiciliar**.

Nos termos da Súmula Vinculante 56, **a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso**, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Nos termos deste RE641.320/RS:

- **a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;**
- os juízes da execução penal **poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes**. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”, do CP);
- havendo **déficit de vagas**, deverá determinar-se:
 - **a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;**



- a **liberdade eletronicamente monitorada** ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
- o **cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado** que progride ao regime aberto;

Segundo a súmula 493 do STJ, é **inadmissível a fixação de pena substitutiva (artigo 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.**

A prisão domiciliar é uma espécie do gênero de regime aberto.

A prisão domiciliar é **cabível** quando (art. 117, da LEP):

- não há estabelecimento adequado ou casa de albergado
- o reeducando é maior de 70 anos
- o reeducando é portador de doença grave
- a reeducanda tem filho menor ou deficiente físico ou mental;
- a reeducanda é gestante

1.4. ESPÉCIES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

1.4.1. PENA DE RECLUSÃO

Basicamente, a pena de reclusão permite que ela seja cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto.

Em relação a esta pena, o CP diz que:

- **pena superior a 8 anos, o regime inicial será o fechado**, independente se o sujeito for primário ou reincidente.
- **pena superior a 4 anos e não superior a 8 anos, o regime inicial poderá ser semiaberto**, desde que o sujeito seja **primário**.
- **pena não superior a 4 anos de reclusão, o regime inicial poderá ser aberto**, desde que o condenado seja **primário**.
- **sendo reincidente, se a pena for maior que 4 anos e até 8 anos, o regime inicial será fechado.**
- **sendo reincidente, se a pena for de até 4 anos, é possível a fixação de regime inicial fechado ou semiaberto, com base na súmula 269 do STJ.**

Súmula 269, STJ: **é admissível a adoção do regime prisional semiaberto** aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, **desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.**

A opinião do julgador sobre a **gravidade abstrata** do crime **não é motivação idônea** para fixação de regime de cumprimento mais gravoso do que o previsto em lei. O regime de cumprimento de pena mais severo exige motivação idônea, que é a **gravidade em concreto do delito**. É o teor das súmulas 718 e 719 do STF.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

O art. 59, do CP, que trata das circunstâncias judiciais, é um critério que **orienta a fixação de regime**, razão pela qual **é possível fixar um regime mais gravoso do que o previsto em lei**. Isto é, **se a pena-base é fixada acima do mínimo legal em virtude de as circunstâncias judiciais da primeira fase de dosimetria da pena serem desfavoráveis, é possível que o juiz fixe regime inicial mais gravoso do que o abstratamente previsto de acordo com a quantidade de pena aplicada** (Inf. 775, STF).

1.4.2. PENA DE DETENÇÃO

Na pena de detenção, o regime inicial será semiaberto ou aberto. Não se admite regime inicial fechado, **ainda que o sujeito seja reincidente.**



É possível a aplicação de regime fechado ao condenado a pena de detenção, desde que haja regressão de regime, por descumprimento das regras da execução.

1.4.3. PENA DE PRISÃO SIMPLES

São penas cominadas às contravenções penais. A prisão simples pode ser em regime aberto ou semiaberto, mas **não se admite o regime fechado, ainda que se trate de regressão.**

1.4.4. REGIME ESPECIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA DE PRISÃO PELA MULHER

É necessário fazer uma leitura do art. 37 do CP combinado com o art. 5º da CF.

Segundo o dispositivo penal, **as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio**, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste Capítulo (título V – das penas, capítulo I – das espécies de pena). O art. 5º, LXVIII, diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com o sexo do apenado.

O inciso L do art. 5º diz que às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos **durante o período de amamentação.**

1.5. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Detração é o cômputo do tempo de prisão provisória cumprida antes do trânsito em julgado no tempo definitivamente fixado na sentença.

Poderá ser computada não só a **prisão provisória**, como também a **prisão administrativa e a internação**, no Brasil ou no estrangeiro.

A Lei 12.736/12 alterou o art. 387, §2º, do CPP, que passou a ter a seguinte redação: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

O juiz sentenciante é quem fixa o regime inicial, devendo considerar o tempo da prisão provisória.

Só é capaz de permitir um regime prisional menos gravoso do que aquele que caberia de acordo com a pena antes cômputo da detração, se:

- **coincidir o requisito temporal para a progressão (cumprimento de 1/6)**
- **é necessário considerar outros requisitos subjetivos, como é o caso de crimes contra a administração pública, que exigem a reparação do dano para a progressão de regime.**

Exemplo: João, primário, foi condenado a 9 anos de reclusão. João tem o seu regime fechado fixado. Todavia, ele já está preso há 1 ano e 1 mês. Quando é feita a detração, João terá de cumprir ainda 7 anos e 11 meses. Se pegarmos apenas 7 anos e 11 meses, o regime inicial cabível seria o semiaberto.

Com base nisso, seria possível, ao fixar o regime, descontar o período já cumprido provisoriamente para fixar regime menos gravoso?

NÃO. Isso porque quem foi condenado a 9 anos, deverá cumprir 1/6 para progredir. Ou seja, o indivíduo deverá cumprir ao menos 1 ano e 6 meses. Por não ter cumprido esse tempo de 1/6 da pena, somente após esse prazo é que poderá progredir. Por conta disso, o regime de João continuará sendo o regime fechado.

Por outro lado, caso João tivesse cumprido 1 ano e 7 meses, por exemplo, o juiz deveria fixar a pena, ao invés de 9 anos, em 7 anos e 5 meses, hipótese em que o **regime inicial será o semiaberto**, desde que presentes as condições necessárias para tanto.



1.6. PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO

1.6.1. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

A pena alternativa é um **direito público subjetivo do réu**, isto é, se ele cumprir as exigências legais, o magistrado é obrigado a promover a substituição da pena privativa. Por outro lado, o réu não pode abrir mão de tal direito e optar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade. Isso, porque o magistrado determina qual a melhor pena devida ao condenado, considerando as finalidades da pena, especialmente a finalidade preventiva.

A finalidade é impedir que alguém que tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade seja realmente a ela submetido, quando a pena restritiva for mais eficaz e, evidentemente, menos gravosa.

A) ESPÉCIES DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

São espécies de penas restritivas de direito:

- prestação pecuniária
- perda de bens e valores;
- limitação de fim de semana;
- prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
- interdição temporária de direitos;
- limitação de fim de semana.

Obs.: Rol exemplificativo. A Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, prevê outras modalidades.

→ Prestação pecuniária

Prestação pecuniária é a prestação em dinheiro **para a vítima, seus dependentes ou entidade pública**.

É fixada pelo juiz, com valor **mínimo de 1 salário-mínimo e máximo de 360 salários-mínimos**.

Se em uma ação de reparação na esfera cível a vítima já tiver recebido algo a título de prestação pecuniária, **esta indenização será compensada**. Caso os beneficiários não sejam coincidentes, não haverá dedução.

O art. 45, §2º, CP, aduz que **se o beneficiário concordar, a prestação pecuniária poderia consistir em prestação de outra natureza**.

Rogério Sanches faz uma crítica, no sentido de que tal possibilidade dá uma abertura que fragiliza a segurança jurídica e a legalidade, eis que a outra parte estaria dizendo qual seria a pena. Todavia, Samer Agi discorda e diz que isto favorece a justiça restaurativa.

→ Perda de bens e valores

A perda se dará **em favor do Fundo Penitenciário Nacional**, salvo se houver lei em sentido contrário.

Esta perda de bens e valores possui dois tetos, e **prevalecerá a perda do que for maior**, não o que for menor:

- perda do montante do prejuízo causado
- perda do proveito criminoso que experimentou

Ou seja, ou um ou outro será o que o indivíduo irá perder, o que for maior.

→ Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas

A prestação de serviços à comunidade **só é possível para condenações superiores a 6 meses de pena privativa de liberdade**.

Consiste a prestação de serviços à comunidade na execução de atividades à comunidade ou a entidades públicas. **Ex.:** escola pública, hospital público, orfanato, etc.

Esse serviço é prestado de maneira gratuita, não gerando vínculo empregatício.



O juiz deverá aplicar a pena de prestação de serviços de maneira a não prejudicar o trabalho do condenado, visto que é uma forma de favorecer a plena ressocialização.

Para cada **1 dia de condenação a pena privativa de liberdade, haverá 1 hora para prestação de serviços à comunidade.**

Se a pena privativa de liberdade for superior a 1 ano, **a lei permite que o reeducando cumpra a pena substitutiva em até metade do tempo da pena privativa de liberdade**, mas nunca inferior a metade.

Exemplo: João foi condenado a 2 anos a pena privativa. João deverá cumprir a prestação de serviços à comunidade em 2 anos, com uma hora por dia. **Como a condenação é superior a 1 ano, poderá ser reduzido pela metade.** Ou seja, poderá trabalhar 2 horas por dia e cumprir a pena em 1 ano, mas não menos do que isso.

É o juízo da execução que cuidará disso.

→ **Limitação de final de semana**

É a obrigação do indivíduo que foi condenado de permanecer aos sábados e domingos, **durante 5 horas diárias**, em casa de albergado ou estabelecimento adequado, em que serão ministrados cursos e palestras, ou mesmo atividades educativas.

No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, **poderá o juiz determinar o comparecimento obrigatório do agressor ao programa de recuperação e educação**, conforme art. 152, parágrafo único, da LEP.

→ **Interdição temporária de direitos**

Existem 5 hipóteses de interdição temporária de direitos:

- proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo;
- proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público;
- suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.
- proibição de frequentar determinados lugares.
- proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

As duas primeiras são **específicas** e só se aplicam aos sujeitos que praticaram crimes no exercício de cargo, função ou atividade **com violação** aos deveres inerentes ao cargo, função ou atividade.

A primeira hipótese exige que o sujeito **tenha se valido** da condição do exercício de cargo, função ou atividade pública, ou do mandato eletivo.

A segunda, deve também ter o sujeito **ter se valido** de sua profissão para a prática do crime.

A hipótese de suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo foi **revogada tacitamente pelo CTB**.

A proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos vale para aquele sujeito que pratica fraude em concurso público, durante um determinado espaço de tempo, eis que é vedada a pena de caráter perpétuo.

B) CARACTERÍSTICAS DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

O art. 44 do CP estabelece que as penas restritivas de direitos tem as seguintes características:

- **autonomia:** não se pode cumular penas privativas de liberdade com restritivas de direito.
- **substitutividade:** as penas restritivas substituem as penas privativas de liberdade quando presentes os requisitos legais. Primeiro, fixa-se a pena privativa, depois substitui-se.

As penas restritivas de direitos **terão a mesma duração das penas privativas de liberdade**, porém há exceções:

- **penas restritivas de caráter real:** as penas restritivas de direito de caráter real, como perda de bens e valores e a prestação pecuniárias, a partir do momento em que os bens são perdidos, ou em que há o pagamento, há a extinção da pena, em razão do cumprimento da pena.
- **pena privativa superior a 1 ano:** neste caso, é possível cumpri-la na metade do tempo.



- **estatuto do torcedor:** admite-se a pena de impedimento de comparecimento às proximidades do estádio. Esta pena restritiva de direito poderá ser superior à pena abstratamente prevista no preceito secundário do tipo penal.

C) REQUISITOS DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Segundo Rogério Sanches, é preciso separar a análise dos requisitos entre crimes dolosos e culposos:

- **crimes dolosos:** nesse caso, os requisitos são:
 - **a pena fixada não poderá ser superior a 4 anos** (art. 44)
 - **crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa:** na violência sobre a coisa, é possível. A violência deve ser real.
 - **não ser o condenado reincidente em crime doloso:** em verdade, a reincidência autoriza a conversão, quando não for específica e a medida se mostrar socialmente recomendável.
 - **seja indicada suficiente a substituição da pena:** princípio da suficiência da pena.
- **crimes culposos:** qualquer que seja a pena, é possível a substituição.

PERGUNTA: E no caso de crimes preterdolosos? No caso de **crimes preterdolosos, deverão ser considerados os requisitos do crime doloso.**

D) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS X DELITOS DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL LEVE E CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Na verdade, percebe-se que nos delitos de ameaça, lesão corporal leve e constrangimento ilegal são caracterizados por violência contra a pessoa ou por grave ameaça. Ou seja, pela simples leitura do art. 44, seria forçoso convir que não seria possível a aplicação das penas restritivas de direitos.

Porém, a **Lei 9.099/95** passou a considerar esses crimes como **infrações de menor potencial ofensivo, visto que a pena máxima não é superior a 2 anos, razão pela qual seria cabível a transação penal**, que é a aplicação imediata de multa ou penas restritivas de direitos.

Diálogo das fontes entre a Lei de Juizados e o Código Penal: é **possível concluir pela aplicação da pena restritiva de direitos aos delitos de ameaça, lesão corporal leve e constrangimento ilegal, desde que esses crimes não sejam cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher, no ambiente doméstico e familiar**. Isso porque esta aplicação das penas restritivas de direitos somente se faz necessária a partir do momento em que há a aplicação da Lei 9.099/95. Todavia, a Lei Maria da Penha veda a utilização da Lei 9.099/95, restando apenas a leitura do CP. Assim sendo, **não caberia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nesses casos.**

E) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS X DELITOS DE ROUBO IMPRÓPRIO

O crime de roubo pode ser praticado mediante violência física ou grave ameaça, não cabendo a substituição nesses casos, por óbvio.

A doutrina se debruça nos casos em que há o crime de roubo por meio de violência imprópria, reduzindo a capacidade da vítima. **A doutrina majoritária entende que no caso de violência imprópria é possível a aplicação das penas restritivas de direitos.**

Samer Agi entende que não pode, mas é minoritário.



F) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS X CRIMES MILITARES

O Código Penal Militar não prevê penas restritivas de direito. Todavia, **o STF entendeu que, em se tratando de crimes militares, seria impossível a aplicação de penas restritivas de direitos**, devido a uma omissão voluntária do legislador.

G) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS X REGRAS DA SUBSTITUIÇÃO

Se a pena privativa de liberdade **não for superior a 1 ano**, deverá o juiz substituir a pena por uma restritiva de direitos **ou** por multa.

Se a pena privativa de liberdade **for superior a 1 ano**, deverá o juiz substituí-la **por multa e por restritiva de direito ou** por **duas restritivas de direito**.

H) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS X CONVERSÃO

Deverá ser feito pelo caminho inverso.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se o sujeito não a cumpre, **deverá o juiz converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade**.

Esta medida é possível em razão da previsão legal, dizendo que em determinadas hipóteses a pena restritiva de direitos vai ser convertida em pena privativa de liberdade. O legislador visa dotar a pena restritiva de direitos de **coercitividade**.

São hipóteses de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade:

- **descumprimento injustificado da restrição:** sendo justificável, não há conversão.
- **sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por um outro crime:** nesse caso, o juiz da execução vai valorar se é necessária a conversão ou se é possível o condenado cumprir a pena privativa e a pena restritiva de liberdade. Ex.: indivíduo é condenado a pena privativa de liberdade pelo regime semiaberto, hipótese em que o indivíduo irá trabalhar durante o dia e voltará para dormir durante a noite. Nesse caso, poderá também o indivíduo ir trabalhar e depois cumprir a pena restritiva de liberdade no hospital. Todavia, **se não for possível o cumprimento da pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos, então esta última será convertida em pena privativa de liberdade**.
- **prática de falta grave**

Em havendo conversão, é preciso que o juiz leve em conta o período cumprido pela pena restritiva de direitos, **respeitado o limite mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão**.

Informativo 631-STJ (14/09/2018) – Dizer o Direito

Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos (ex: prestação pecuniária), o CP prevê, como consequência, a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Logo, o juiz não deve decretar o arresto dos bens do condenado como forma de cumprimento forçado da pena substitutiva. A possibilidade de reconversão da pena já é a medida que, por força normativa, atribui coercitividade à pena restritiva de direitos.

Ex: João foi condenado a pena de 3 anos de reclusão, tendo o juiz substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Uma delas foi o pagamento de prestação pecuniária no valor total de R\$ 100 mil, parceladamente em 36 prestações mensais. O Ministério Público afirmou que o prazo para cumprimento da prestação pecuniária é muito longo e que haveria o risco de o condenado não pagar. Diante disso, pediu ao juiz que decretasse o arresto dos bens do sentenciado. Este requerimento deverá ser indeferido.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.699.665-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07/08/2018 (Info 631).



→ **Pena de multa**

A pena de multa consiste na obrigação de pagar, nos termos do art. 51, do CP.

O sujeito é condenado a pagar **ao Fundo Penitenciário** um valor em dinheiro.

i. Aplicação da pena de multa

Esta multa deverá observar dois momentos, adotando-se o **sistema de dias-multa**:

- **características e circunstâncias do crime**
- **capacidade econômica e características do sentenciado**

Quando o juiz fixa o número de dias-multa, ele verifica as características do crime. Ou seja, **a fixação de dias-multa será de 10 a 360, com base nas circunstâncias do crime**. Para se alcançar esse número, o juiz deverá passar pelo **critério trifásico**.

Fixado o número de dias-multa, o juiz deverá analisar a **capacidade econômica** do condenado, a fim de definir o **valor de cada dia-multa**, devendo variar **entre 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos e 5 vezes** o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Se for insuficiente o valor do dia-multa de 5 vezes do salário mínimo à época dos fatos, por conta da condição econômica do sentenciado, poderá o juiz elevá-lo **até o triplo**. Ou seja, **poderá o sentenciado ser condenado a pagar 15 vezes o valor do salário mínimo por dias-multa**.

Supondo que o condenado foi condenado a 10 dias-multa e a 1/30 do valor de dias-multa, e supondo que o salário mínimo seja de 900 reais, sendo que 1/30 seria 30 reais. Como o indivíduo foi condenado a 10 dias-multa, deverá pagar 300 reais.

Essa multa é irrisória. Por conta disso, a doutrina predominante afirma que **mesmo a multa irrisória deverá ser cobrada obrigatoriamente em juízo, caso não haja o pagamento espontâneo. Ou seja, pouco importa o seu valor, pois multa, apesar de ser considerada dívida de valor, não deixa de ser pena**. E como pena, é inevitável, com base no princípio da inderrogabilidade da pena.

ii. Pagamento da pena de multa

O pagamento da pena de multa está disciplinado no código penal de uma forma e na LEP de outra forma.

De acordo com o CP, a multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.

Já a LEP estabelece que a multa deverá ser paga **no prazo de 10 dias**, contados da citação do condenado, precedida da extração da certidão de sentença condenatória e havendo requerimento do MP. O MP faz um requerimento com a certidão de sentença, e aí o condenado é citado para pagar a multa em 10 dias.

A LEP é mais favorável, razão pela qual deverá prevalecer.

O pagamento da pena de multa poderá ser **integral, parcelado** ou **por meio de desconto** do salário do condenado, desde que não viole à dignidade da pessoa humana e sua capacidade de subsistência.

iii. Não pagamento da pena de multa

Não havendo o pagamento da pena de multa, a jurisprudência já entendeu que **não é possível a conversão em pena privativa de liberdade**.

A multa não paga é **dívida de valor**, aplicando-se a ela as regras da execução fiscal, inclusive as regras interruptivas e suspensivas da prescrição.

Súmula 521, STJ: a legitimidade para execução fiscal pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública (súmula superada)

ATENÇÃO: Para o STJ, o MP, apesar de não poder executar a pena de multa, é legitimado para promover medida assecuratória da multa imposta na sentença penal, eis que esta não deixa de ser pena.
POSSICIONAMENTO ULTRAPASSADO.

ATUALIZAÇÃO:



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



Em julgamento realizado em 13 de dezembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, em virtude da natureza de sanção penal – não alterada pela Lei 9.268/96 –, a pena de multa deve ser executada pelo Ministério Público na própria Vara de Execuções Penais.

O tribunal apreciou conjuntamente uma questão de ordem na Ação Penal 470 e a ADI 3150. A ação direta de inconstitucionalidade havia sido ajuizada pelo Procurador-Geral da República para que o tribunal conferisse interpretação conforme ao art. 51 do Código Penal e estabelecesse a legitimidade do Ministério Público e a competência da Vara de Execuções Penais para a execução da pena de multa. Já na questão de ordem contestava-se decisão do ministro Barroso, que havia estabelecido, com base no art. 164 da LEP, a legitimidade do Ministério Público para executar multa imposta na AP 470, mas a União sustentava que a Lei 9.268/96 havia revogado tacitamente o disposto na Lei de Execução Penal, razão por que caberia à Procuradoria da Fazenda Nacional executar a sanção imposta naquela condenação.

Segundo o ministro Barroso – que foi acompanhado pela maioria –, a alteração promovida pela Lei 9.268/96 não alterou a natureza da pena de multa, que continuou a ser uma espécie de sanção penal, tanto que na própria AP 470 o STF impôs o pagamento da multa como condição para a progressão de regime. O art. 164 da LEP, portanto, continua em vigor e é claro ao estabelecer a legitimidade do Ministério Público, a quem cabe a fiscalização da execução penal.

STJ: **não obsta a declaração de extinção da pena**, o sujeito ter cumprido a pena privativa de liberdade, mas ainda estar inadimplente em relação à pena de multa.

A multa é pena, razão pela qual **não poderá passar da pessoa do condenado**.

Obs.1: Há uma **exceção ao Juizado Especial Criminal**, a pena de multa deverá ser executada no próprio JECRIM, eis que este tem competência, segundo a lei, para executar os seus próprios julgados.

Obs.2: Apesar das causas de suspensão e interrupção serem reguladas pelas normas que tratam da fazenda pública, **o prazo de prescrição da pena de multa continua sendo a de 2 anos**, caso seja isolada, **ou da pena privativa de liberdade**, caso seja cumulada com a pena.

iv. Pena de multa e progressão de regime

Em regra, se o condenado cumprir 1/6 da pena (requisito objetivo) e tiver bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), será admissível a progressão do regime semiaberto para o aberto.

O pagamento da multa não está previsto expressamente no art. 112, do CP, como um dos requisitos necessários para a progressão de regime.

Apesar disso, o STF entendeu que esse pagamento poderá ser exigido. Para o STF, **o juiz está autorizado a lançar mão de outros requisitos, não necessariamente enunciados no art. 112 da LEP, mas extraídos do ordenamento jurídico**, para avaliar a possibilidade de progressão no regime prisional, tendo como objetivo, sobretudo, o exame do merecimento do sentenciado.

Dessa forma, o STF entendeu que, em regra, **o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional**. A exceção reside no fato de que poderá haver progressão quando o sentenciado, mesmo sem ter pago, comprovar a absoluta impossibilidade econômica em quitar a multa, ainda que parceladamente.

Por tudo isso, o STF fixou a tese de que se o juiz autorizar o pagamento da pena de multa parceladamente, caso o apenado deixe de pagar injustificadamente tais parcelas, haverá a **regressão** de regime. **O inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão no regime prisional**.

O STJ já decidiu que a data-base para subsequente progressão de regime é aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. A decisão do Juízo das Execuções que defere a progressão de regime é **declaratória** (e não constitutiva).

Algumas vezes, o reeducando preenche os requisitos em uma data, mas a decisão acaba demorando meses para ser proferida. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão (Inf. 595).

v. Pena de multa e substituição da pena privativa por outra pena de multa



Presentes os requisitos legais, o magistrado pode substituir a pena de prisão por outra multa, cumulando esta multa substitutiva com a multa principal? Por exemplo, no crime de furto há uma pena de 1 a 4 anos e multa. Supondo que o juiz fixe em 1 ano e 10 dias-multa. Esta pena de 1 ano poderia também ser convertida em multa substitutiva e outra multa principal?

Segundo o STJ, por meio da súmula 171, cominadas cumulativamente, **em lei especial**, penas privativas de liberdade e pecuniária, **é defeso a substituição da prisão por multa**.

O STJ diz que se estiver em lei especial, prevendo pena privativa de liberdade e multa, não será possível substituir a pena privativa de liberdade por multa.

A partir dessa leitura, é possível concluir que **se houver a previsão de pena privativa de liberdade no Código Penal, seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma multa, mantendo a condenação principal da outra multa**.

vi. Pena de multa e Lei Maria da Penha

Lembrando que a Lei Maria da Penha veda a pena de cesta básica, ou outras de caráter pecuniário, bem como a substituição de pena que implique pagamento **isolado de multa**.

Ou seja, **poderá haver a substituição de pena**, como por exemplo a prestação de serviços à comunidade, mas não poderá haver penas de cestas básicas ou de caráter pecuniário, além de não poder haver o pagamento isolado de multa. Em outras palavras, **havendo a aplicação de multa cumulada com outras penas, será possível falar em multa**.

Outra exceção ocorre quando o **tipo penal prevê como única pena a pena de multa**.

Teoria geral da pena: aplicação da pena (continuação). Concurso de crimes. Medida de segurança.

1.7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

1.7.1. CONCEITO

A suspensão condicional da pena é um **instituto de política criminal**. A ideia é suspender a execução da pena privativa de liberdade, o condenado tem **suspensa a execução da pena**, ficando submetido a determinadas condições, a fim de conferir a ele a liberdade, sendo denominado este período de período de prova.

O magistrado é **obrigado a suspender** a pena se estiverem presentes os requisitos. Trata-se de um **direito público subjetivo**.

1.7.2. SISTEMAS DO SURSIS

Três sistemas:

- **Sistema anglo-americano (*probation system*)**: o réu fica submetido ao período de prova, após o reconhecimento de sua responsabilidade penal, mas sem que tenha sido imposta a ele determinada pena. Descumprindo as condições, o julgamento é retomado, a fim de estabelecer a pena privativa de liberdade. Não é contemplado no ordenamento jurídico brasileiro.
- **Sistema do *probation of first offender act***: é o adotado no âmbito dos juizados especiais criminais, quando a pena fixada não ultrapassa um ano. Estabelece que haverá a suspensão da ação penal, inclusive antes de se reconhecer a responsabilidade penal do réu. Há a imposição de determinadas condições, as quais, não sendo cumpridas, gerará a retomada do processo. É adotado para a suspensão condicional do processo. A suspensão é condicional, eis que o sujeito fica submetido a determinadas condições. Não cumprindo as condições, é possível a retomada do processo (e não do julgamento), no qual já foi oferecida a denúncia e recebida pelo magistrado anteriormente.



- **Sistema franco-belga:** é o sistema adotado no Código Penal. O sujeito é condenado e imposta uma pena privativa de liberdade, sendo que, em momento posterior, haverá a suspensão da pena, fixando o juiz certas condições, às quais o condenado deve se submeter. Caso não as observe, poderá cumprir a pena privativa de liberdade.

Portanto, o ordenamento brasileiro adota o sistema franco-belga para a suspensão condicional da pena e o sistema do *probation of first offender act* para a suspensão condicional do processo.

A) ESPÉCIES, REQUISITOS E CONDIÇÕES

O sursis tem basicamente 4 espécies:

- **sursis simples**
- **sursis especial**
- **sursis etário**
- **sursis humanitário**

i. Sursis simples e sursis especial

→ *Sursis simples*

O sursis simples está previsto no art. 77, combinado com o art. 78, § 1º, do CP.

O sursis simples exige que a pena privativa de liberdade **não seja superior a 2 anos**. Havendo concurso de crimes, haverá a soma deles. Neste caso, fica suspensa a pena, ficando o sujeito submetido ao **período de prova que varia de 2 a 4 anos, caso condenado por crime, ou de 1 a 3 anos, caso condenado por contravenção**.

O Supremo Tribunal Federal entende que o período de prova do sursis não tem natureza de pena e, com isso, **não pode ser considerado para fins de indulto**, que exige como condição o cumprimento de determinada fração da pena.

No sursis simples, no 1º ano do prazo, o condenado tem de **prestar serviços à comunidade** ou **terá limitados seus fins de semana**. Aplica-se quando o condenado **não reparou o dano injustificadamente** ou **quando as circunstâncias do art. 59 não são favoráveis**.

Para a aplicação do sursis simples, devem estar presentes os seguintes **requisitos**:

- **condenado não reincidente em crime doloso**: se a pena de multa foi a única aplicada em condenação por crime doloso anterior, não haverá óbice à concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77, §1º, do CP.
- **circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59, CP)**;
- **não indicada ou cabível pena restritiva de direitos (art. 44, CP)**.

ATENÇÃO: o sursis possui caráter subsidiário.

→ *Sursis especial*

O sursis especial somente se diferencia do sursis simples em razão do condenado ter **reparado o dano ou ter comprovado a impossibilidade de fazê-lo**.

A pena privativa de liberdade fixada **não poderá ser superior a 2 anos**, considerando o concurso de crimes. O **período de provas também variará entre 2 e 4 anos**.

Frise-se, diferentemente do sursis simples, o **sursis especial exige a reparação do dano ou comprovada impossibilidade de fazê-lo**.

Diante disso, o condenado ficará sujeito às seguintes condições **no 1º ano do período de prova**:

- **proibição de frequentar determinados lugares**
- **proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial**
- **comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades**.

Essas medidas **podem ser fixadas cumulativamente**. Veja que são condições menos rigorosas que as do sursis simples, pois o agente reparou o dano. Ou seja, no sursis especial, o condenado **não precisa**



prestar serviços à comunidade e não se submete à limitação de fim de semana no 1º ano do período de prova.

Como dito, aplica-se aos casos em que o condenado reparou o dano, salvo justificativa, e desde que as circunstâncias do art. 59, do CP, sejam favoráveis.

Os **requisitos do sursis especial** são os mesmos do sursis simples:

- **condenado não reincidente em crime doloso;**
- **circunstâncias judiciais favoráveis;**
- **não indicada ou cabível pena restritiva de direitos.**

ii. Sursis etário e sursis humanitário

→ **Sursis etário**

O sursis etário é conferido às **pessoas maiores de 70 anos**, idade essa diferente do Estatuto do Idoso, razão pela qual nem todo idoso será beneficiário.

Nesse caso, exige-se que **a pena não seja superior a 4 anos**, ficando o **período de prova entre 4 a 6 anos**.

Para a aplicação do sursis etário, devem estar presentes os seguintes requisitos:

- **condenado não reincidente em crime doloso;**
- **circunstâncias judiciais favoráveis;**
- **não indicada ou cabível pena restritiva de direitos**

As condições do sursis etário variam de acordo com o fato de **haver ou não o condenado reparado o dano**. Podem ser, portanto, as condições:

- **caso tenha reparado o dano:** fica sujeito às condições do sursis especial.
- **caso não tenha reparado o dano:** fica sujeito às condições do sursis simples.

→ **Sursis humanitário**

O sursis humanitário é conferido às **pessoas que razões de saúde justifiquem a suspensão**. Nesse caso, exige-se que **a pena não seja superior a 4 anos**, ficando o **período de prova entre 4 a 6 anos**. Ex.: tratamento incompatível com o regime prisional.

Para a aplicação do sursis humanitário, devem estar presentes os seguintes requisitos:

- **condenado não reincidente em crime doloso;**
- **circunstâncias judiciais favoráveis;**
- **não indicada ou cabível pena restritiva de direitos.**

As condições do sursis humanitário variam de acordo com o fato de haver ou não o condenado reparado o dano. Podem ser, portanto, as condições:

- **caso tenha reparado o dano:** fica sujeito às condições do sursis especial.
- **caso não tenha reparado o dano:** fica sujeito às condições do sursis simples.

iii. Sursis nas Lei de Crimes Ambientais

A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) cria uma outra hipótese de suspensão condicional da pena. Neste caso, **é possível o sursis quando a condenação não for superior a 3 anos**.

B) REVOGAÇÃO DO SURSIS

Se o sujeito descumprir as condições, o **sursis poderá ou será revogado**.

Segundo o STJ, **mesmo após o fim do período de prova é possível a revogação do sursis**, por fato (apto a causar a revogação) que tenha ocorrido durante o período de prova.

Existem hipótese de revogação obrigatória e revogação facultativa.

i. **Revogação obrigatória**

São hipóteses de revogação obrigatória:



- **Condenação irrecorrível por crime doloso:** O STF entende que essa causa é **automática** de revogação, ou seja, dispensa oitiva do beneficiário. Pouco importa ter sido o crime doloso cometido antes ou depois do início do período de prova.
- **Frustrar a execução da pena de multa, ou imotivadamente deixa de reparar o dano:** em relação à frustração da pena de multa, houve a revogação tácita do art. 81, II, pela Lei 9.268/1996, visto que passou a ser vedada a conversão da multa em pena privativa de liberdade. A reparação do dano é uma condição legal de todo e qualquer *sursis*. É condição direta do *sursis* especial e indireta das demais modalidades. De um modo ou de outro, o agente terá de reparar o dano. Reparado o dano antes da condenação definitiva, será cabível o *sursis* especial. Caso, injustificadamente, não repare o dano depois, o benefício será revogado. EXIGE PRÉVIA OITIVA.
- **Descumprir injustificadamente as condições do art. 78, §1º, do CP:** caso o beneficiário descumpra injustificadamente tais condições (prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana), o *sursis* será revogado. Esta modalidade de revogação exige a prévia oitiva do beneficiário pelo juiz. Repare, portanto, que somente a revogação prevista no art. 88, inciso I, do CP, é automática.

ii. Revogação facultativa

São hipóteses que o juiz pode ou não revogar o *sursis*:

- **Descumprimento de qualquer outra condição:** o condenado descumpriu as medidas do *sursis* especial como a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, ou o comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, ou até mesmo outras condições impostas pelo juiz.
- **Condenação definitiva do beneficiário por crime culposo ou contravenção penal a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos:** há sentença transitada em julgado por crime culposo ou contravenção a pena que não seja a de multa, ou seja, não caberá a revogação se a condenação for a pena de multa.

No caso de revogação facultativa, o juiz também poderá optar:

- pela revogação;
- por nova advertência;
- por prorrogar o período de prova até o máximo; ou
- por exacerbar as condições impostas: neste caso, fixa outras condições.

C) CASSAÇÃO DO SURSIS

Rogério Sanches afirma que é importante que se saiba distinguir revogação do *sursis* da cassação do *sursis*.

- **Revogação:** ocorre em momento **posterior** do usufruir do benefício pelo condenado, isto é, depois da audiência de advertência, podendo ser obrigatória ou facultativa. As hipóteses de revogação já foram estudadas (art. 81, do CP).
- **Cassação:** ocorre uma causa **anterior** ao início do cumprimento do *sursis*, que impede a fruição do benefício. As hipóteses de cassação do *sursis* são três:
 - **Não comparecimento injustificado na audiência admonitória:** antes da audiência admonitória, não há *sursis*. Portanto, se o sujeito não comparece à audiência, aquele *sursis* concedido na sentença é cassado, pois o condenado não chegou sequer a começar.
 - **Provimento de recurso da acusação contra a concessão do benefício;**
 - **Condenado recusa as condições.**

A cassação ocorre após a concessão do *sursis* na sentença condenatória, mas antes do início de sua fruição.



D) PRORROGAÇÃO DO SURSIS

Na prorrogação do sursis haverá a **extensão do período de prova**.

A prorrogação do período de prova poderá ser aplicada quando:

- **casos de revogação facultativa**
- **sujeito está sendo processado por outro crime ou contravenção**

Neste último caso, trata-se de **prorrogação automática até o julgamento definitivo pelo crime que está sendo processado**. Isto é, a simples existência de inquérito policial não acarreta a prorrogação, sendo indispensável o **recebimento de denúncia ou queixa** pelo outro crime ou pela contravenção; é necessário a existência de processo.

Durante a prorrogação, não subsistem as condições impostas originariamente. O beneficiário não ficará, por exemplo, durante todo o prazo de prorrogação, tendo de prestar serviços à comunidade ou tendo de comparecer em juízo.

E) EXTINÇÃO DO SURSIS

A extinção é o término do sursis pelo término do prazo. Neste caso, a pena privativa de liberdade está **extinta**.

F) SURSIS SUCESSIVOS

Sursis sucessivos: consiste em o réu obter um sursis após o cumprimento de outro sursis.

Ocorre quando o agente, depois de cumprir o *sursis* (ou durante o período de prova) recebe novo sursis. **É preciso que se trate de crime culposos ou contravenção penal**, já que o art. 77, inciso I, do CP, exige que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Por conta disso, **como não é reincidente em crime doloso, pode ser beneficiado novamente com o sursis sucessivo**.

G) SURSIS SIMULTÂNEOS

É também **possível** sursis simultâneos, dados ao mesmo tempo.

Ocorre quando, **durante o período de prova, o sujeito é condenado irrecorrivelmente por penas que autorizam a concessão do sursis**. Ex.: sujeito é condenado por um crime com pena não superior a 2 anos; neste caso, poderá ser agraciado com o sursis. Se o segundo crime é culposos ou se é uma contravenção penal, **haverá hipótese de revogação facultativa** (não há que se falar em revogação automática, eis que necessário que o segundo crime cometido, e agora em condenação definitiva, também seja doloso).

Em síntese, admitem-se *sursis* simultâneos, desde que, depois de aplicado o primeiro *sursis*, o segundo seja **antes da realização da audiência admonitória** do primeiro.

Exemplo: João é condenado por furto. O juiz aplicou o sursis. Durante o cumprimento do sursis, João é condenado por homicídio culposos. Não haverá a revogação automática do sursis, eis que crime culposos é hipótese de revogação facultativa, podendo, neste período, cumprir os dois sursis simultaneamente.

H) SURSIS PARA ESTRANGEIRO

Não há vedação legal de sursis para estrangeiro, prevalecendo o entendimento de que **é possível**.



1.8. LIVRAMENTO CONDICIONAL

1.8.1. CONCEITO

Livramento condicional significa colocar alguém em liberdade sob determinadas condições.

Formalmente, é uma medida penal que antecipa a liberdade de quem está condenado, desde que ele se submeta a determinadas limitações, funcionando como um instrumento de ressocialização.

Cumprido um determinado período de pena, há um direito subjetivo de ser colocado em liberdade, desde que cumpridas determinadas condições.

Portanto, o livramento condicional é **direito subjetivo do apenado**.

1.8.2. REQUISITOS

A) REQUISITOS OBJETIVOS

Para se falar em livramento condicional é necessário que haja o preenchimento dos seguintes **requisitos objetivos**:

- **Pena privativa de liberdade fixada na sentença igual ou superior a 2 anos**
- **Cumprimento de parcela da pena:**
 - **Regra:** mais de 1/3 da pena.
 - **Reincidente:** mais de 1/2 de pena.
 - **Condenado por crime hediondo, tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e terrorismo:** mais de 2/3 da pena, desde que não seja reincidente em delitos desse natureza, pois, nesse caso não será admitido o livramento condicional.
- **Reparação do dano causado, salvo se for impossível fazer.**

B) REQUISITOS SUBJETIVOS

Já os **requisitos subjetivos** para concessão do livramento condicional são:

- **Bom comportamento durante a execução da pena:** o livramento significa o retorno do indivíduo à vida em sociedade, sendo o bom comportamento um indicativo.
- **Não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inovação da Lei 13.964/19)**
- **Bom desempenho no trabalho**
- **Aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto:** não se exige que o reeducando tenha um emprego assegurado. Este requisito é um grande obstáculo para os estrangeiros em situação irregular, pois, neste caso, serão expulsos do país. Sendo assim, o indivíduo não terá aptidão para prover a subsistência, ficando vedado o livramento condicional.
- **Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é imprescindível que se constate que as condições pessoais fazem presumir que quando ele estiver livre não voltará a delinquir.** A forma mais comum é pelo exame criminológico. Não é obrigatório, mas não é vedado, podendo ser determinado pelo magistrado fundamentadamente. Este é o teor da súmula 439 do STJ.

Atenção:

Súmula 441 do STJ – “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.”

Súmula 534-STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”



Súmula 535-STJ: “A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.”

Segundo o STJ, a **não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura mero descumprimento de condição obrigatória que autoriza a aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, mesmo em tese, a prática de falta grave** (Inf. 595, STJ).

Não confundir:

- **Falta grave:** apenado que rompe a tornozeleira eletrônica ou mantém a bateria sem carga suficiente;
- **Não configura a prática de falta grave:** apenado que descumpre o perímetro estabelecido para tornozeleira eletrônica.

1.8.3. CONDIÇÕES PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL

O juiz especificará as condições a que fica subordinado o condenado:

- **Condições obrigatórias:**
 - **deverá ocupar e exercer uma atividade lícita dentro de um prazo razoável:** o prazo razoável depende do momento pelo qual passa o país.
 - **comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação:** esse comunicado não é necessariamente mensal, sendo o período fixado pelo magistrado.
 - **não mudar do território da comarca sem autorização judicial:** ou seja, pode mudar, mas tem que ter autorização.
- **Condições facultativa:** serão elencadas de acordo com o caso concreto:
 - **não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção:** veja, esta condição só existirá se o juiz fixá-la (art. 132, §2º, LEP).
 - **recolher-se à habitação em hora fixada;**
 - **não frequentar determinados lugares;**
 - **outras condições estabelecidas pelo juiz.**

1.8.4. CONCESSÃO E EXECUÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

É o **juízo da execução** que fixa o livramento condicional, tendo **início a partir da audiência admonitória**. É realizada **no estabelecimento** onde o sujeito está sendo cumprida a pena.

Concordando com as condições, é expedida uma **carta de livramento**, a qual possui duas finalidades:

- **cientificará o reeducando das condições a que se submeterá;**
- **funcionará como alvará de soltura.**

Caso o reeducando não observe essas condições, é possível a revogação do livramento.

1.8.5. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

A revogação poderá ser:

- obrigatória
- facultativa

A) REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA

A revogação **obrigatória** ocorrerá:



- **se o liberado vem a ser condenado por sentença transitada em julgado a uma pena privativa de liberdade por crime cometido durante o período de prova**. As consequências nesse caso são as seguintes:
 - o tempo de livramento condicional não é considerado pena cumprida;
 - não pode em relação a mesma pena obter um novo livramento condicional;
 - o restante da pena a ele fixado não pode somar-se a nova pena para efeito de concessão para novo livramento.

Ex.: o sujeito foi condenado a 6 anos de reclusão. Após o cumprimento de 4 anos, consegue o livramento condicional. Com 1 ano de período de prova, vem a ser novamente condenado a pena privativa de liberdade de 5 anos, em sentença irrecorrível, por crime cometido durante o período de prova. Da primeira pena (6 anos), havia cumprido 4 anos de prisão. O tempo de 1 ano correspondente ao período de prova não será computado, restando, assim, 2 anos de pena a ser cumprida (1ª condenação). Como a 2ª condenação foi por crime cometido durante o período de prova, as penas não se somam para efeito de nova concessão. Em relação ao restante da pena (1ª condenação) não caberá novo livramento condicional. No tocante à 2ª pena, poderá haver a concessão do livramento.
- **se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime anterior ao período de prova**: neste caso, o tempo de livramento condicional cumprido é considerado como período de pena cumprido, pois o sujeito não demonstrou que durante o período de prova não estaria apto a viver em sociedade, visto que o fato foi anterior. Consequências:
 - será possível um novo livramento condicional em relação à mesma pena;
 - o tempo de livramento cumprido será considerado como período de pena cumprido;
 - será permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas.

B) REVOGAÇÃO FACULTATIVA

A revogação facultativa ocorrerá:

- **se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença**
- **se o liberado for condenado por crime ou contravenção que não seja privativa de liberdade**

Diante dessa revogação facultativa, o juiz poderá:

- revogar o livramento condicional, ou
- alterar as condições a que fica submetido o condenado, ou ainda
- aplicar advertência

1.8.6. PRORROGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Nos termos do art. 89 do CP, o juiz **não pode declarar extinta a pena** enquanto não transitar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado **por crime cometido na vigência do livramento**.

Isso porque, se ele cometer um crime na vigência de um livramento condicional e for condenado definitivamente à pena privativa de liberdade, haverá **a revogação obrigatória e o tempo do livramento não será considerada tempo de pena cumprido**.

Se o indivíduo estiver sendo investigado em inquérito policial, não haverá a prorrogação do livramento condicional. **É necessário que ele esteja sendo processado**.

Em síntese, **ocorrerá a prorrogação do livramento condicional enquanto não transitar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento**.

ATENÇÃO! Súmula 617 do STJ: “A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.” Se o juízo da execução é comunicado sobre a instauração de processo penal por



crime cometido na vigência do livramento condicional pelo condenado, não suspender o livramento condicional e o período de prova se escoar, mister se fará a declaração de extinção da pena.

Rogério Greco afirma que o indivíduo que for condenado a 1 ano e 11 meses tem interesse recursal para pedir que sua pena seja majorada para 2 anos, a fim de ser beneficiário do livramento condicional, visto que este exige a pena superior a 2 anos.

1.8.7. EXTINÇÃO DA PENA

O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do MP, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação. **Se até seu término do período, o livramento condicional não for revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.**

A sentença é **declaratória de extinção da punibilidade.**

Segundo o STF, findo o período de prova, sem suspensão ou interrupção, o paciente tem direito à extinção da pena privativa de liberdade.



CAPÍTULO 19 — TEORIA GERAL DA PENA: CONCURSO DE CRIMES

1. INTRODUÇÃO

1.1. CONCEITO

Ocorre o concurso de crimes quando o agente, mediante uma ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes.

Há, basicamente, três espécies:

- concurso material
- concurso formal
- continuidade delitiva

1.2. SISTEMAS DE APLICAÇÃO DA PENA

- **Sistema do cúmulo material:** há a soma das penas dos crimes. É adotado para o concurso material, concurso formal impróprio (desígnios autônomos) e para as penas de multas.
- **Sistema da exasperação (agravação):** quando há o concurso de crimes, devemos olhar para a pena do crime mais grave e exasperá-la de acordo com o número de delitos praticados no contexto. É adotado para o concurso formal e para a continuidade delitiva.
- **Sistema da absorção:** a pena do delito mais grave absorve as demais. Não há previsão nos arts. 69, 70 e 71 do CP.
- **Sistema jurídico:** não há cumulação de penas. Aplica-se uma única pena, mas com severidade suficiente para atender a gravidade dos crimes praticados.
- **Sistema da responsabilidade única e da pena progressiva única:** não há cumulação de penas, mas deve-se aumentar a responsabilidade do agente à medida que aumenta o número de infrações.

2. CONCURSO MATERIAL

2.1. CONCEITO

Ocorre quando o agente, através de mais de uma ação ou mais de uma omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Neste caso, **as penas são somadas**.

Em tese, **todas as infrações admitem concurso de crimes** (crime consumado ou tentado, comissivo ou omissivo, doloso ou culposos; crime e contravenção etc.). **É possível que haja concurso entre um crime doloso e um culposos**. Exemplo: *aberratio ictus* em que o agente mata quem queria (homicídio doloso) e acaba ferindo terceiro sem vontade (lesão culposa).

2.2. REQUISITOS

São requisitos do concurso material:

- pluralidade de condutas
- pluralidade de crimes.



2.3. CONDENAÇÃO A PENA DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO

Estes crimes **podem ser idênticos ou diferentes**, não sendo necessária a identidade criminosa. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, **executa-se primeiro a pena de reclusão**. Ex.: Dispositivo da sentença – Portanto, fica João da Silva definitivamente condenado a 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e a 2 anos de detenção em regime inicial aberto.

2.4. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 69, §1º do CP, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, **não suspensa**, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição da pena por restritivas de direito. Assim, **somente caberá restritiva de direitos ao crime “Y” se a pena privativa do crime “X” for suspensa**.

Em suma, imposta pena privativa de liberdade não suspensa para um dos crimes, ao outro não caberá a substituição por restritiva de direitos

2.5. CONCURSO MATERIAL E PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

É possível que duas penas restritivas de direito sejam aplicadas simultaneamente. Nesse caso, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

O cumprimento **será, portanto, simultâneo, se as penas forem compatíveis**, ou **sucessivo, se não compatíveis**.

2.6. ESPÉCIES DE CONCURSO MATERIAL

O concurso material pode ser:

- **homogêneo**: ocorre quando os **crimes são da mesma espécie**. Ex.: dois furtos.
- **heterogêneo**: ocorre quando os crimes **não são da mesma espécie**. Ex.: roubo e estupro.

2.7. REGRAS DE FIXAÇÃO DE PENA NO CONCURSO MATERIAL

As penas são aplicadas individualmente, isto é, cada crime tem sua pena aplicada de forma isolada. Em seguida, as penas devem ser cumuladas, somadas (**sistema da cumulação**). O juiz primeiro individualiza as penas de cada um dos crimes (critério trifásico – art. 68, CP), somando todas as penas ao final.

2.8. CONCURSO MATERIAL E CONCESSÃO DE FIANÇA DEPOIS DA LEI 12.403/2011

Como regra, a fiança é cabível independente do *quantum* da pena, mas sim de acordo com o tipo de crime, se inafiançável ou não (hediondos e equiparados, racismo e ação de grupos armados contra a ordem democrática e o estado de direito).

Obs.: Em crimes cuja pena máxima abstratamente cominada seja de **até quatro anos**, a fiança pode ser concedida pela autoridade policial quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. **Acima de 4 anos** de pena máxima em abstrato, a fiança somente pode ser concedida pela autoridade judicial.

Para saber se a pena máxima está ou não acima dos quatro anos, **deve-se considerar o concurso de crimes**.



2.9. CONCURSO MATERIAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A suspensão condicional do processo somente é admissível quando, no concurso material, a somatória das penas mínimas abstratamente previstas nos crimes **não ultrapassar um ano**, pressuposto do art. 89 da Lei 9.099/1995 (posições do STF e do STJ).

2.10. CONCURSO MATERIAL E PRESCRIÇÃO

Como visto anteriormente, no concurso material de crimes, cada crime tem uma prescrição autônoma (art. 119 do CP). **No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.**

As penas, portanto, não são somadas para se aquilatar o prazo prescricional.

3. CONCURSO FORMAL (OU IDEAL) DE CRIMES

3.1. CONCEITO

Ocorre quando o sujeito, através de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Neste caso, pega-se a pena mais grave (se diversas), ou uma das penas (se iguais), devendo-se **exasperá-la de 1/6 até a 1/2.**

Para isso, o patamar da exasperação **levará em conta o número de crimes praticados.**

3.2. REQUISITOS DO CONCURSO FORMAL

São requisitos do concurso formal de crimes:

- **conduta única, ainda que dividida em vários atos**
- **pluralidade de crimes**

Atente-se que nada impede que esta ação única do concurso formal seja fracionada em diversos atos. É o que a doutrina chama de **ação única desdobrada**.

Isso porque a conduta única não importa, obrigatoriamente, em ato único, podendo haver conduta fracionada em vários atos. **Ex.:** sujeito armado que entra em ônibus e rouba a bolsa de duas senhoras comete dois crimes, mas em concurso formal. Isto é, a ação foi uma ação, ainda que desdobrada em vários atos.

STF: há uma só conduta fracionada em vários atos (ou seja, a ação sobre cada passageiro é uma fração de uma só conduta).

3.3. ESPÉCIES DE CONCURSO FORMAL

- **concurso formal homogêneo:** os crimes são da **mesma espécie** (mesmo tipo penal).
- **concurso formal heterogêneo:** os crimes são de **espécies diversas** (não estão no mesmo tipo penal).
- **concurso formal próprio (perfeito):** ocorre quando, apesar de provocar dois ou mais resultados, não há desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes. **Ex.:** João, querendo matar José, acaba matando também culposamente Maria. Responderá em concurso formal próprio por homicídio doloso e culposo.
- **concurso formal impróprio (imperfeito):** há desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes. **Ex.:** João, querendo matar José e Maria, coloca-os em um quarto trancados e incendeia



o cômodo. Houve uma única conduta, mas com desígnios autônomos. Responderá por dois crimes de homicídio em concurso formal impróprio (penas somadas).

3.4. REGRAS DE FIXAÇÃO DA PENA

3.4.1. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO

No **concurso formal próprio**, o juiz aplica uma só pena, se idênticas as penas dos crimes, ou a maior, quando não idênticas, aumentada **de 1/6 até a metade (sistema da exasperação)**.

Obs.: se a soma das penas é mais benéfica ao réu, o sistema da exasperação deve ser substituído pelo da cumulação (sistema do cúmulo material benéfico). Ou seja, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do concurso material deste Código.

Este é o **concurso material benéfico**.

3.4.2. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

No concurso formal impróprio (ou imperfeito), **as penas são somadas**, pois, a exemplo do concurso material, o **agente atua com desígnios autônomos (sistema da cumulação)**.

A pena é aplicada como se se tratasse de concurso material (art. 70, *caput*, segunda parte, do CP).

Segundo o STJ, a **expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual**. O dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o.

No entanto, o CESPE/CEBRASPE (TRF 5ª) já entendeu como **incorreta** a seguinte alternativa: “*Ocorre concurso formal imperfeito quando há dolo em relação ao delito desejado e dolo eventual no tocante aos outros resultados da mesma ação, situação em que o agente deve ser apenado pelo sistema de cúmulo material*”.

4. CRIME CONTINUADO OU CONTINUIDADE DELITIVA

4.1. CONCEITO

Continuidade delitiva é uma ficção jurídica para fins de política criminal.

O juiz, ao invés de aplicar as penas correspondentes aos vários crimes praticados em continuidade, por ficção jurídica, **para fins da pena, considera como se um só crime fosse praticado pelo agente, majorando a sua pena**.

Trata-se de um instituto que nasceu para beneficiar o agente.

No crime continuado, o sujeito, por meio de mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica mais de um crime da mesma espécie, sendo que estes crimes guardam entre si uma relação, em que seja possível deduzir que um deles seja continuidade do outro, pois foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

É possível aplicar o crime continuado aos crimes omissivos próprios.

Diante disso, deverá ser **aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas**, aumentada, em qualquer caso, **de 1/6 a 2/3**.

Além disso, o sujeito comete os crimes com a denominada **homogeneidade subjetiva**, o sujeito deve perceber o crime com uma ligação com o crime que o antecedeu, devendo ser guiado pela mesma unidade de propósito. Esta posição não é pacífica, mas **encontra entendimento no Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que é necessária a homogeneidade subjetiva para configurar-se a continuidade delitiva**.



Por conta de ser imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva – *mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução* – e de ordem subjetiva – *unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos* – é que **se afirma ter o STJ adotado a teoria mista**.

4.2. ESPÉCIES DE CRIME CONTINUADO

São espécies de crime continuado:

- **crime continuado genérico (art. 71, CP)**
- **crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, CP)**

4.2.1. CRIME CONTINUADO GENÉRICO

Ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie (**do mesmo tipo penal**) e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3.

São requisitos do crime continuado genérico:

- **pluralidade de condutas**
- **pluralidade de crimes da mesma espécie**
- **mesmas condições de tempo, de lugar e a mesma maneira de execução**
- **outras circunstâncias semelhantes**

Segundo o STF e STJ, para haver a continuidade delitiva, os “crimes da mesma espécie” devem ser previstos no **mesmo tipo penal**, protegendo o mesmo bem jurídico.

ATENÇÃO: no caso de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A) e sonegação previdenciária (art. 337-A), apesar de não estarem no mesmo tipo, mas por protegerem o mesmo bem jurídico, o STJ admite a continuidade delitiva.

Atente-se que **extorsão e roubo não admitem continuidade delitiva**, pois não estão no mesmo tipo penal. Roubo e latrocínio também não admitem, porque o primeiro ofende o patrimônio e o segundo, o patrimônio e a vida da vítima (STJ).

Furto simples e furto qualificado, todavia, admitem a continuidade delitiva, mesmo que as formas do furto não sejam as mesmas.

Para haver continuidade delitiva exige-se um elo de continuidade. Isso significa que **a pluralidade de condutas deve seguir as mesmas condições de tempo, de lugar e a mesma maneira de execução**:

- **Mesmas condições de tempo:** as infrações devem ter as mesmas condições de tempo. Segundo a jurisprudência, são aquelas que **se distanciam uma da outra em até 30 dias**. Nos crimes contra a ordem tributária, os tribunais admitem continuidade delitiva com intervalo temporal de até 7 anos, a depender do fato gerador.
- **Mesmas condições de lugar:** os delitos têm de ser cometidos na mesma comarca ou em comarcas vizinhas/contíguas.
- **Mesma maneira de execução:** a execução não deve ser absolutamente idêntica, basta que guardem uma semelhança do *modus operandi*.
- **Outras circunstâncias semelhantes**

No crime continuado genérico, o juiz leva em conta uma só pena, se idênticas, ou a maior, se não idênticas, em qualquer dos casos **aumentando-a de 1/6 a 2/3 (sistema da exasperação)**.

Este aumento varia **de acordo com o número de infrações praticadas**.



4.2.2. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO

O crime continuado específico está previsto no art. 71, parágrafo único, do CP, estabelecendo que, nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, **aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo**, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Os requisitos do crime continuado específico são os mesmos do art. 71, *caput*, com alguns requisitos especializantes:

- pluralidade de condutas;
- pluralidade de crimes da mesma espécie;
- mesmas condições de tempo, de lugar e a mesma maneira de execução;
- **crimes têm de ser dolosos;**
- **as vítimas devem ser diferentes;**
- **com violência ou grave ameaça à pessoa.**

É possível inclusive nos **crimes contra a vida**. Houve superação da súmula 605 do STF, porque a redação do parágrafo único do artigo 71 adveio da reforma do CP de 1984, posterior à edição da súmula.

Presentes essas três especializantes, incidirá o art. 71, parágrafo único.

No crime continuado específico, também se aplica o sistema da exasperação, porém a pena será **aumentada de 1/6 até 3x (triplo)**. É o mesmo sistema do *caput*, com aumento diverso.

Nesta espécie de crime continuado, deve ser observado o **cúmulo material benéfico** (art. 70, parágrafo único, do CP), ou seja, se a soma das penas for mais benéfica que o aumento, é ela que será utilizada.

4.3. SÚMULA 711 DO STF

Caso o agente pratique, por exemplo, cinco furtos em continuidade delitiva (isto é, prevalecendo-se das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução) ele responderá por um só furto, com a pena majorada. Se, no meio da continuidade delitiva, vem uma lei que aumenta a pena do crime, como o agente responde por um só furto, qual lei que regerá o caso (a antiga, mais benéfica, a vigente ou ambas)?

Nos termos da Súmula 711 do STF, aplica-se a última lei penal, ainda que mais grave: **A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.**

Veja que se aplica o mesmo raciocínio ao crime permanente. Ambos sofrerão a incidência da última lei, mesmo que mais gravosa.

4.4. SÚMULA 723 DO STF

Segundo a Súmula 723, **não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a um ano.**

Este raciocínio vale para o concurso formal e crime continuado, é a mesma ideia do concurso material.

4.5. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA

No dia 1, os agentes praticam um roubo em passageiros de um ônibus, havendo um concurso formal. No dia 2 de outubro, esses assaltantes roubam os passageiros de outro ônibus, prevalecendo as mesmas condições de local, tempo etc. Repare que cada um dos dois roubos praticados configura concurso formal e eles estão em continuidade delitiva. Serão aplicados ambos os concursos?



Segundo o STJ, **é necessário aplicar apenas 1 aumento, que é referente à continuidade delitiva. Isto é, deverá aplicar a pena de 1/6, relativo à continuidade, considerando como se fosse cometido apenas um crime.** Em outras palavras, quando há concurso formal e crime continuado ao mesmo tempo, só persiste o crime continuado, desfazendo-se o concurso formal, para evitar *bis in idem*. Posição de Luiz Flávio Gomes e do STJ.

4.6. CONTINUIDADE DELITIVA E HOMICÍDIO DOLOSO

É possível continuidade delitiva no homicídio doloso? De acordo com a Súmula 605 do STF, não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida.

Cuidado, todavia, pois a Súmula é anterior ao processo de reforma do CP/1984, quando foi acrescentado ao art. 71 o seu parágrafo único, autorizando a continuidade nos delitos praticados com violência contra a pessoa (gênero, que tem como espécie o homicídio).

Veja que a Súmula 605 não foi cancelada. Contudo, **ela está evidentemente superada**, inclusive para o STF.

4.7. CRIME CONTINUADO E MULTA

O art. 72 do CP estabelece que, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Dois posicionamentos:

- a) Em razão da omissão em relação aos crimes continuados, adota-se a interpretação mais favorável ao réu (pena de multa exasperada para a continuidade delitiva).
- b) O crime continuado é uma espécie de concurso de crimes, tanto que a previsão está no artigo 72, após o artigo 71. Aplica-se o artigo 72 aos crimes continuados. Esta posição foi adotada em prova de concurso de 1ª fase.

5. QUESTÕES COMPLEMENTARES

5.1. CONCURSO DE CRIMES E JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

No caso de concurso de crimes, **a fixação da competência do JECRIM leva em conta a soma das penas máximas cominadas, no caso de concurso material.**

Sendo concurso formal próprio, haverá a exasperação da pena.

Nesse caso, deverá ser observado se a soma ou a exasperação ultrapassam o limite de 2 anos, hipótese em que não será do JECRIM a competência.

5.2. CONCURSO DE CRIMES E LEI 12.403/11

A Lei 12.403/11 é conhecida como a nova lei de prisões.

O delegado de polícia pode arbitrar fiança para infrações penais com penas máximas cominadas de até 4 anos de reclusão.

Ademais, existe um patamar mínimo para que haja prisão preventiva, devendo a pena máxima superior a 4 anos.

A importância é discutir se, no caso de concurso de crimes, o delegado deve exasperar ou não.

A conclusão é de que **tanto para a interpretação de prisão preventiva quanto para o arbitramento de fiança pelo delegado de polícia, é necessário considerar o concurso de crimes.**



CAPÍTULO 20 — TEORIA GERAL DA PENA: MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. INTRODUÇÃO

A medida de segurança é uma espécie de sanção penal. É a forma com que o Estado reage contra a violação da norma proibitiva por agente não imputável.

Trata-se de mais uma sanção penal, ao lado da pena, utilizada pelo Estado na resposta à violação da norma penal, pressupondo agente não imputável ou semi-imputável.

O CP adotou o sistema vicariante, e não do duplo binário: não se admite a aplicação conjunta de pena e medida de segurança.

Obs.: Durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o fato de ter sido imposta ao réu, em outra ação penal, medida de segurança referente a fato diverso **não impõe a conversão da pena privativa de liberdade que está sendo executada em medida de segurança**. No caso, evidencia-se que cada reprimenda imposta corresponde a um fato distinto. Portanto, não há que se falar em ofensa ao sistema vicariante, porquanto a medida de segurança refere-se a um fato específico e a aplicação da pena privativa de liberdade correlaciona-se a outro fato e delito (Inf. 579, STJ).

2. FINALIDADES

A finalidade essencial da medida de segurança é preventiva, pois visa impedir que o sujeito volte a praticar fato definido como crime, pois, apesar de inimputável, ele apresenta alto grau de periculosidade.

A medida de segurança não está preocupada em punir o agente pelo crime cometido no passado, tampouco preocupada com a culpabilidade do agente. Está preocupada, principalmente, com o futuro, com a periculosidade do agente.

3. ESPÉCIES DE MEDIDA DE SEGURANÇA

São espécies de medidas de segurança previstas no art. 96 do CP:

- **medidas de segurança detentiva:** é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado. Aplica-se a crimes apenados com reclusão.
- **medidas de segurança restritiva:** é o tratamento ambulatorial. Aplica-se a crimes apenados com detenção, salvo se a periculosidade do agente justificar que ele seja submetido a uma internação.

Segundo o STJ, **o inimputável submetido à medida de segurança de internação em hospital de custódia não pode cumprir medida de segurança no estabelecimento prisional comum, sob a justificativa de que não há vagas ou recursos**. Ou seja, o sujeito não pode ser punido pela incompetência do Estado.

4. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA DE SEGURANÇA

São pressupostos da medida de segurança:

- **prática de fato previsto como crime/contravenção:** fato típico e ilícito, mas não culpável.
- **periculosidade do agente:** é a personalidade de certos indivíduos, militando serem possuidores de maior ou menor inclinação para o crime. O agente poderá ser inimputável ou semi-imputável:
 - **inimputável:** haverá a absolvição do indivíduo, por meio da sentença absolutória imprópria, impondo-se a medida de segurança.
 - **semi-imputável:** o indivíduo deverá ser condenado. O fato de ser semi-imputável impõe a redução da pena de 1/3 a 2/3, mas é possível que, caso se mostre necessário, o juiz



imponha, em vez da redução da pena, a medida de segurança. **Para o semi-imputável há uma condenação.**

Essa periculosidade pode se externar através de doença mental (inimputável) ou de perturbação mental (semi-imputável). No caso de doença mental, haverá a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança; no caso da perturbação mental, haverá a condenação, com pena reduzida ou com medida de segurança (a ser escolhida pelo juiz). Trata-se do **sistema vicariante**.

Segundo Zaffaroni, no sistema vicariante, há substitutividade, passando a medida a ocupar o lugar da pena em certos casos, isto é, a medida pode vicariar (substituir) a pena. Dessa forma, às vezes o homem é tratado como pessoa com certa culpabilidade e, às vezes, como alguém não culpável, mas perigoso. A substituição ou “vicarização” não tem lugar quando se trata de incapazes psíquicos, aos quais somente se aplicam medidas de segurança.

A medida de segurança decorrente de condenação para o semi-imputável gerará reincidência. Caso seja fruto de absolvição imprópria, não gerará reincidência.

5. DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA

De acordo com o art. 97, § 1º, do CP, a medida de segurança tem **prazo mínimo**, que **varia de 1 a 3 anos**, e será por **tempo indeterminado**, ou seja, não tem prazo máximo.

Nesse prazo mínimo, é possível a detração.

Nos Tribunais Superiores, prevalece a inconstitucionalidade da indeterminação do prazo máximo, violando a proibição da prisão perpétua:

- **STF:** sugere um prazo máximo de 30 anos. O mesmo previsto para as penas privativas de liberdade.
- **STJ:** sugere um **prazo igual ao da pena máxima abstratamente cominada pelo crime**. O STJ, inclusive, editou a Súmula 527, dizendo que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. **Ex.:** se passados 10 anos da medida de segurança aplicada pelo cometimento do crime de roubo o sujeito apresentar o mesmo grau de periculosidade, a sanção penal não poderá se estender. Será necessário ajuizar ação de interdição na esfera cível.

6. PERÍCIA MÉDICA

A perícia médica se realiza **após o término do prazo mínimo** (1 a 3 anos). E se não for constatada a cessação da periculosidade, a perícia **deve ser realizada de ano em ano**.

Veja que as novas perícias, a serem realizadas anualmente, podem ser antecipadas pelo Juiz da execução penal, por expressa previsão do dispositivo. Todavia, elas jamais poderão ser adiadas para depois de um ano.

O art. 43 da LEP admite que médico particular acompanhe a execução da medida.

Havendo divergência entre as opiniões do perito oficial e a do médico particular, diz o parágrafo único que **o juiz poderá ficar com uma ou com outra, a depender da que o convencer**. Ele pode, inclusive, determinar a realização de outra.

Em nenhum momento a lei estabelece que o laudo oficial deverá prevalecer. **A decisão cabe ao juiz da execução.**

7. DESINTERNAÇÃO OU LIBERAÇÃO CONDICIONAL

Essa liberação é **sempre condicional**, eis que averiguada a cessação da periculosidade, deve ser determinada a desinternação (se internado) ou a liberação (se tratamento ambulatorial) do agente pelo período de 1 ano.



Se dentro de 1 ano, o agente pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade, a medida de segurança é restabelecida.

Este fato **não precisa ser típico, podendo ser fato atípico**, desde que indique a persistência de sua periculosidade (ex.: furto de uso, autolesão etc.).

Determina-se a desinternação ou liberação a título de ensaio. Isso significa que durante um ano ele fica sob observação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores **têm admitido a desinternação progressiva**, consistente na passagem da internação para o tratamento ambulatorial antes da definitiva liberação do agente. Neste caso, antes de conseguir a desinternação, o agente passa para o tratamento ambulatorial para somente depois receber a liberação.

8. REINTERNAÇÃO DO AGENTE

Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, o juiz pode determinar a internação se esta se mostrar necessária para fins curativos.

Estando o agente em tratamento ambulatorial e sobrevindo fato indicativo da necessidade de internação, o juiz poderá determiná-la, caso a providência seja necessária para fins curativos.

Não se trata de regressão-sanção, eis que não há natureza punitiva. O agente não está sendo punido e migrando para o regime fechado. **A finalidade é curativa.** No caso, o tratamento mostra-se insuficiente para a anomalia mental, que para fins curativos exige a internação.

9. CONVERSÃO DA PENA EM MEDIDA DE SEGURANÇA

Na hipótese de **superveniência da doença mental durante a execução da pena**, o agente é condenado enquanto era imputável, surgindo a anomalia psíquica durante o cumprimento da pena.

Em razão disso, a **pena será convertida em medida de segurança**.

Quando isso ocorre, há duas consequências diversas:

- **Anomalia passageira:** o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. A medida de segurança imposta é **reversível**. O tempo da internação é computado como cumprimento de pena. **Deve observar a pena imposta**, eis que o tempo de internação não ultrapassará a pena imposta na sentença.
- **Anomalia irreversível:** quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do ministério público, da defensoria pública ou da autoridade administrativa, **poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança**. A medida de segurança imposta é **irreversível**. A internação **não é computada** como pena, ou seja, a pena é substituída por medida de segurança. Segundo o STJ, **a medida de segurança não poderá ultrapassar o período da pena imposta na sentença penal condenatória**.

Se persistir a periculosidade do agente após essa medida de segurança já cumprida, deverá haver a busca da interdição do indivíduo no juízo cível.

Nesse caso, ainda que decorrido o prazo máximo da pena abstratamente fixada para o delito, constatando-se a manutenção da periculosidade, deve-se buscar perante o **juízo cível** a interdição do agente (figurando o MP como parte legítima), demonstrando-se a necessidade da internação extrapenal, como forma de proteger o paciente e a sociedade (art. 1.767 do CC e art. 9º da Lei 10.216/06).

10. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E MEDIDA DE SEGURANÇA

A medida de segurança, por ter caráter de sanção penal, poderá ter extinta a sua punibilidade.



Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Portanto, poderá haver a prescrição da pretensão punitiva assim como a prescrição da pretensão executória.

Na sentença, quando absolutória imprópria, não há fixação de prazo máximo, mas apenas mínimo. Diante disso, existem 3 correntes sobre o assunto:

- **1ª C:** entende que não se aplica a prescrição da pretensão executória em sede de medida de segurança.
- **2ª C:** segundo o STJ, a prescrição da pretensão executória é possível, calculando-se a prescrição com base na pena máxima cominada ao delito. Se a pena máxima é de 4 anos, a prescrição nesse caso será de 8 anos. Considera-se a pena máxima, eis que seria o máximo de tempo em que poderia o sujeito cumprir a medida de segurança. Ou seja, basta pegar a pena máxima abstratamente cominada ao delito para calcular a prescrição.
- **3ª C:** a prescrição da pretensão executória é regulada pela duração máxima da medida de segurança, que seria de 30 anos.

Devido à adoção da segunda corrente, o STJ editou a súmula 527, estabelecendo que o tempo de duração da medida de segurança **não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado**. Isso porque, nessa hipótese, o magistrado aplica a medida de segurança diretamente (absolvição imprópria). Por ser absolutória, a sentença que aplica a medida de segurança não interrompe o curso do prazo prescricional.

No caso do réu semi-imputável, a sentença é condenatória, ou seja, o juiz aplica uma pena, com a causa de redução prevista no parágrafo único do art. 26 do CP e depois substitui a pena privativa de liberdade por medida de segurança (art. 98), caso constate que o réu necessita de especial tratamento curativo.

Logo, existe uma pena concretamente aplicada, que será utilizada no cálculo da prescrição.

11. MEDIDA DE SEGURANÇA PREVENTIVA

Existe medida de segurança provisória ou preventiva?

Antes da Lei 12.403/2011, não existia medida de segurança preventiva. O magistrado, se imprescindível, decretava a prisão preventiva. Após a lei, admite-se medida de segurança como medida cautelar.

O art. 319 do CPP estabelece como medida cautelar diversa da prisão a internação provisória do acusado desde que preenchidos os seguintes requisitos:

- crimes praticados com violência ou grave ameaça;
- peritos concluírem ser o agente inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e;
- houver risco de reiteração.



CAPÍTULO 21 — TEORIA GERAL DA PENA: EFEITOS DA CONDENAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Os efeitos da condenação podem ser:

- **efeitos penais:** dividem-se em:
 - **principal:** é a execução forçada da pena imposta;
 - **secundários:** é a reincidência, a interrupção da prescrição, revogação do sursis, etc.
- **efeitos extrapenais:** podem ser:
 - **extrapenais genéricos:** previstos no art. 91 do CP.
 - **extrapenais específicos:** previstos no art. 92 do CP.

Os efeitos extrapenais permanecem mesmo nos casos de *abolitio criminis* e de anistia, enquanto que os efeitos penais desaparecem, nessas hipóteses.

2. EFEITOS EXTRAPENAIIS

2.1. EFEITOS EXTRAPENAIIS GENÉRICOS

Os efeitos extrapenais genéricos estão previsto nos art. 91 do CP e se aplicam a todas as condenações:

- **Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime:** a sentença penal é um título executivo. A Lei 11.719/08 estabeleceu que o juiz pode fixar um mínimo de indenização para a vítima. Esta lei mostrou-se mais gravosa ao réu, razão pela qual a jurisprudência só se aplica após a sua entrada em vigor. Todavia, segundo o STJ, esta indenização depende de pedido de vítima. Se o juiz fixar esta indenização de ofício, haveria uma violação ao contraditório, ampla defesa e ao princípio da congruência. Em provas, considerar que a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito automático da sentença penal condenatória.
- **Confisco em favor da União dos instrumentos do crime:** não é qualquer instrumento que se perde, pois fica ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, desde que esses instrumentos cujo alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. **Ex.:** João quer matar José e para tanto compra um revólver na feira. Imediatamente depois João é preso. Ele responderá apenas por homicídio, visto que o porte foi exclusivamente para cometer o homicídio. Nesse caso, João vai perder a arma, pois o porte daquele instrumento por si só constitui fato ilícito. Por outro lado, se João entrar na casa do seu chefe e furtar a arma para cometer o crime contra José, não haverá a perda da arma do seu chefe em favor da União, desde que a arma estivesse em condições legais.
- **Confisco em favor da União do produto do crime ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso:** proveito é aquilo que o sujeito angariou pela prática criminosa, o valor. O produto do crime é a coisa adquirida diretamente com o crime, bem como a coisa adquirida. Ressalte-se que o direito de boa-fé e do lesado fica ressalvado.

2.2. EFEITOS EXTRAPENAIIS ESPECÍFICOS

Os efeitos extrapenais específicos estão previstos nos artigos 91-A (inovação da Lei 13.964/19) e 92 do CP.

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei **comine** pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, **poderá** ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.



§ 1º Para efeito da perda prevista no **caput** deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Destaques:

1. Como o caput diz que a perda dos bens pode ser decretada, temos que não se trata de efeito automático, mas que deve ser motivadamente declarado na sentença;
2. A norma presume a ocorrência de fraude quando bens são transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal;
3. O juiz não pode decretar de ofício a perda do artigo 91-A, devendo ter sido requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada;
4. A decretação da perda na sentença não pode ser genérica. O magistrado deve declarar o valor da diferença apurada e **especificar** os bens cuja perda for decretada.

Os efeitos extrapenais específicos do artigo 92 **não são automáticos**, de modo que o juiz deverá declarar na sentença **motivadamente**:

- perda de cargo, função pública ou mandato eletivo;
- incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela;
- inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como instrumento para a prática de crime doloso

→ Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo

Nesse caso, é necessário separar em:

- **efeitos de natureza administrativa**
- **efeitos de natureza política**

Os **efeitos de natureza administrativa** abrangem crimes praticados por servidores. Para haver perda do cargo ou da função pública, deverá o servidor:

- praticar um crime com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública e ser condenado a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano; ou
- ser condenado a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos.

Se o juiz substituir a pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direito, o servidor não perderá o cargo.

Com relação aos **efeitos de natureza política**, a CF, em seu art. 15, inciso III, estabelece que **é consequência de toda a sentença penal condenatória a suspensão dos direitos políticos**. Sendo assim, o mandato eletivo seria perdido, mas em relação aos congressistas a CF é dúbia, devendo ser aplicado também aos parlamentares estaduais.

O art. 55 da CF traz as seguintes hipóteses de perda do mandato político, sendo que duas delas merecem destaque:

- **perda ou suspensão dos direitos políticos.**



- **sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.**

O §3º assevera que a perda será declarada **pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político** representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

Já o §2º aduz que a perda do mandato, no caso de sentença penal condenatória transitada em julgado, será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, **por maioria absoluta**, mediante **provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional**, assegurada ampla defesa.

Na Ação Penal 470, vulgo Mensalão, o STF entendeu que a suspensão dos direitos políticos decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado. E, portanto, a perda dos mandatos seria decorrência dessa sentença. Caberia então à respectiva Casa, tão somente, declarar a perda.

Todavia, a Corte adotou um novo entendimento. Na Ação Penal 565, **o Supremo Tribunal Federal decidiu que compete à Casa Legislativa deliberar a respeito da perda do mandato parlamentar condenado**. Segundo o STF, seria possível que um sujeito que tivesse seus direitos políticos suspensos continuasse o exercício do seu mandato eletivo.

Em relação aos parlamentares estaduais e distritais, por força do art. 27 da Constituição Federal, todas essas disposições se aplicam.

No que tange aos **parlamentares municipais**, a sentença penal condenatória gera a perda dos direitos políticos e, conseqüentemente, a **perda automática do mandato**. Nesse caso, há um efeito automático que é a suspensão dos direitos políticos, razão pela qual o juiz deverá dizer na sentença, enquanto o presidente da Câmara dos Vereadores apenas declara a suspensão.

→ **Incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela**

A lei estabelece que haverá o efeito extrapenal específico de incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela quando o agente for condenado por:

- crime doloso
- pena de reclusão
- praticado contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado

A Lei nº 13.715/2018 alterou a redação do inciso II do art. 92 do CP. A redação anterior do inciso II falava em “pátrio poder” e foi substituída por “poder familiar”. Neste aspecto, a redação foi alterada apenas para atualizar a expressão utilizada pelo Código Civil de 2002, não tendo ocorrido uma mudança substancial.

Entretanto, acrescentou na redação do referido inciso a expressão “outrem igualmente titular do mesmo poder familiar”, ou seja, se o agente comete crime doloso contra uma pessoa e esta vítima divide com o agente o poder familiar em relação a uma criança ou adolescente, poderá o agente perder o poder familiar sobre a criança ou adolescente.

Acrescentou, ainda, as expressões “filha” e “outro descendente”, o que significa que se o agente, por algum motivo, for titular do poder familiar sobre neto/bisneto e cometer crime contra seus descendentes, poderá perder o poder familiar. **ATENÇÃO:** A situação não será tão comum, pois ocorrerá apenas quando o agente exercer o poder familiar sobre seus descendentes.

Já o termo “filha” foi incluído de forma desnecessária, pois estava abrangido pela expressão “filho”, uma vez que o texto legal não exige a flexão de gênero das palavras, salvo se houver alguma limitação expressa.

Existe uma discussão sobre a extensão dessa incapacidade para o poder familiar. Isto é, se isto se estenderia a todos os filhos ou somente ao filho que foi vítima.

1ª Corrente: entende que a presente consequência da condenação incide sobre a relação entre o condenado e a vítima, não alcançando outros filhos (Guilherme Nucci).

2ª Corrente: essa incapacidade pode ser estendida para alcançar outros filhos, pupilos ou curatelados, além da vítima do crime. Não seria razoável decretar a perda do poder familiar somente em relação à filha de



dez anos de idade estuprada pelo pai, aguardando fosse igual delito praticado contra as outras filhas mais jovens, para que só então se privasse o genitor desse direito (Rogério Sanches).

A segunda corrente ganha força com o advento da Lei 12.962/14 que, alterando o ECA, anuncia em seu art. 23, §2º que **a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha.**

Exemplo: Imagine que o pai abusou sexualmente de sua filha, menor de 14 anos, tendo outros dois filhos, sendo mais velhos. Nesse caso, não haveria porque decretar a incapacidade do pátrio poder em relação aos demais. No entanto, se o pai tivesse ainda outras filhas menores, seria prudente que fosse estendido aos demais irmãos.

Obs.: A prova do MP de Goiás considerou correta a 1ª corrente, ou seja, o juiz deveria, de forma fundamentada, por se tratar de crime cometido com abuso do poder familiar, decretar a incapacidade para o exercício do pátrio poder em relação ao filho que sofreu o abuso, **ainda que houvesse outros filhos de idade menor do que a criança abusada.**

Sendo vítima do delito em questão, não podendo fazê-lo em relação às demais, que não foram vítimas do crime. Trata-se de **efeito secundário da sentença penal condenatória**. Cuidado, pois este efeito, que é extrapenal, não tem nada a ver com a suspensão do poder familiar do direito civil, que é preventiva.

→ **Inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso**

A própria lei estabelece que haverá a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

O Código Penal não fala em veículo automotor, se estendendo àquele que se utiliza de um navio, por exemplo.

É **indispensável** que a incidência da inabilitação para dirigir veículo se dê no caso em que o agente **utilizou do veículo como meio para a prática de crime doloso**. **Ex.:** um ex-Deputado foi preso por dirigir embriagado e matar duas pessoas. Acabou denunciado por homicídio doloso e, se condenado, poderá acabar inabilitado para dirigir veículo.

3. EFEITOS DA CONDENAÇÃO NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

3.1. LEI DE TORTURA

A Lei de Tortura estabelece que a condenação **acarretará a perda do cargo, emprego ou função, e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada como efeito automático da condenação**, não precisando ser motivadamente declarada na sentença, conforme entendimento do STJ.

3.2. LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Na Lei de Organização Criminosa também há um efeito parecido e **automático**. O §6º do art. 2º da Lei 12.850/13 estabelece que **a condenação de funcionário público implicará a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função pública ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena.**

3.3. LEI DE LAVAGEM

Na Lei de Lavagem também há alguns efeitos da condenação específicos.

3.4. LEI DE RACISMO (LEI 7.716/89)

A Lei de Racismo também traz efeitos extrapenais específicos em seu art. 16.



Esta lei estabelece que **é efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.** Aqui, **o efeito não é automático**, devendo ser devidamente declarado na sentença (motivado), nos termos do art. 18.

Quando o legislador dispõe expressamente sobre a incidência dos efeitos extrapenais da condenação, significa que ele quer que haja motivação declarada em sentença. Nos demais casos em que silencia, há incidência automática.

3.5. LEI DE FALÊNCIA

Se o sujeito for condenado a crime falimentar, ficará inabilitado para o exercício de atividade empresarial, bem como impedido de exercer cargo, conselho de administração, diretoria ou gerência de sociedades empresárias.

Esses efeitos **não são automáticos**.



CAPÍTULO 22 — TEORIA GERAL DA PENA: REABILITAÇÃO

1. CONCEITO

Reabilitação é uma medida de natureza criminal, que objetiva garantir ao outrora condenado o **sigilo sobre o processo e sobre a condenação**.

Outra finalidade ou consequência da reabilitação é a **suspensão de determinados efeitos extrapenais (art. 92, CP)**.

2. EFEITOS

A finalidade é fazer com que o indivíduo retorne à sociedade, a fim de apagar o seu passado. No entanto, a LEP traz medidas muito mais benéficas ao condenado.

Nos termos do dispositivo acima, a reabilitação tem a finalidade de:

- **Assegurar o sigilo da condenação:** de acordo com o art. 202 da LEP, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, **salvo** para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.
Para Rogério Greco, a reabilitação não tem mais utilidade em relação a assegurar o sigilo da condenação, eis que a própria LEP já o garante, sem precisar aguardar o transcurso do prazo de 2 anos.
- **Suspender efeitos extrapenais específicos da condenação (art. 92 do CP):** os efeitos específicos são perda do cargo, incapacidade para o exercício do poder familiar e a inabilitação para dirigir veículo. O art. 93, parágrafo único, assevera que nas situações dos incisos I (perda de cargo, função público ou mandato eletivo) e II (incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela), a **reabilitação é parcial, vedando-se a reintegração na situação anterior**. Isto é, aquele que está incapacitado para o exercício do poder familiar poderá voltar a exercer o poder familiar, mas não mais sobre aquela vítima, e sim sobre os outros filhos, curatelados ou tutelados. Aquele que perde cargo, emprego ou função pública pode prestar outro concurso e rezar para passar. Em outras palavras, **a reabilitação somente é total no caso do inciso III (reabilitação para dirigir veículo)**.

3. REQUISITOS DA REABILITAÇÃO

Os requisitos da reabilitação estão previstos no art. 94 do CP:

- **transcurso do período de 2 anos desde o cumprimento ou a extinção da pena:** computando-se o período de prova do sursis e do livramento condicional, caso não revogados.
- **domicílio do condenado no país pelo período de 2 anos.**
- **bom comportamento público e privado do condenado.**
- **ressarcimento do dano causado pelo crime ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, assim como a renúncia do ressarcimento pela vítima ou a novação da dívida.**

4. REVOGAÇÃO DA REABILITAÇÃO

Esta reabilitação poderá ser revogada, de ofício ou a requerimento do MP.

Ocorrerá a revogação da reabilitação quando o condenado ou reabilitado **for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa**.

Obs.: É possível reabilitação no caso de medida de segurança, principalmente ao semi-imputável que é condenado (ele é condenado e pode sofrer os efeitos específicos da condenação).



Em síntese, são **requisitos** para a revogação da reabilitação são:

- **condenado reabilitado**
- **condenado reincidente**
- **pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, desde que a pena que não seja de multa.**

5. COMPETÊNCIA

No estudo da reabilitação prevista no CPP, devem ser analisados apenas os dispositivos processuais penais.

O pedido é feito ao juiz da condenação (art. 743 do CPP), e não para o juiz da execução. Isso porque não há mais execução da pena.

Diante disso, a reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de **2 anos após a extinção ou término do cumprimento da pena**, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que já tenha residido durante aquele tempo, a fim de que possa ser aferido o seu bom comportamento público e privado em tais locais.

6. RECURSO

Da decisão que:

- **nega a reabilitação cabe apelação**, conforme art. 593, inciso III, do CPP;
- **concede a reabilitação caberá apelação e recurso de ofício**, nos termos do art. 746 do CPP.

Em relação ao reexame necessário, há questionamentos doutrinários acerca da constitucionalidade do dispositivo legal.

7. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES

Havendo pluralidade de condenações, a reabilitação só pode ser requerida **após o transcurso do período de 2 anos a partir do cumprimento da última sanção penal.**

Enquanto estiver cumprindo sanção não poderá pedir a reabilitação.

8. REABILITAÇÃO X REINCIDÊNCIA

A reabilitação não impede a reincidência de crime futuro.

A medida de reabilitação **não rescinde a condenação**, apenas a torna sigilosa. Logo, todos os seus efeitos penais permanecem, dentre eles a reincidência.



CAPÍTULO 23 — AÇÃO PENAL

1. CONCEITO

Ação penal é o direito de pedir ao Estado a tutela jurisdicional.

2. CARACTERÍSTICAS

O direito de ação possui as seguintes características:

- **direito público:** é um direito do Estado. Legitima a atuação do direito material, que é o direito penal. Para aplicar o direito penal, é necessário que haja um processo, porém o que dá início ao processo é a ação, a qual legitima a atuação do Estado, no exercício do direito de punir.
- **direito subjetivo:** possui um titular específico, que é, via de regra, o Ministério Público. Sendo de ação privada, será a vítima ou seu representante legal.
- **direito abstrato:** independe da existência do direito material.
- **direito autônomo:** independe da procedência do pedido ou da improcedência da pretensão punitiva.

3. CONDIÇÕES DA AÇÃO

As condições da ação podem ser divididas em:

- **genéricas:** estão em todas as ações penais.
- **específicas:** estão em algumas ações penais.

3.1. CONDIÇÕES GENÉRICAS

- **possibilidade jurídica do pedido:** o provimento pleiteado encontra amparo no ordenamento jurídico. O fato deve encontrar guarida no âmbito do direito processual penal, ou seja, não sendo possível o pedido, não haverá essa condição.
- **legitimidade *ad causam*:** é a legitimidade para a causa. A legitimidade ativa, via de regra, é do Ministério Público. Sendo privada, será da vítima. A legitimidade passiva é, normalmente, de uma pessoa natural, podendo ser pessoa jurídica eventualmente nos crimes ambientais.
- **interesse de agir:** esta condição poderá se desmembrar em:
 - **Utilidade:** o autor tem interesse na demanda quando esta possa lhe trazer alguma utilidade, que é aferida por meio da necessidade do provimento jurisdicional e de sua adequação.
 - **necessidade:** sempre estará presente, pois não se pode aplicar a pena diretamente, sendo indispensável que se dê por meio do processo.
 - **adequação:** eleição da via adequada.
- **justa causa:** é um lastro probatório mínimo. É o denominado *fumus boni iuris*.

3.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As condições específicas estão presentes em determinadas ações penais, destacando, dentre outras:

- representação da vítima
- requisição do Ministro da Justiça



4. CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO PENAL

A ação penal poderá ser:

- **de iniciativa pública:** quem promove é o MP, podendo ser:
 - **condicionada à:**
 - **representação da vítima:** manifesta o desejo de que o acusado seja condenado.
 - **requisição do Ministro da Justiça:** é uma autorização para que haja o processo.
Em ambos os casos não há vinculação da necessidade de oferecer a denúncia.
 - **incondicionada:** não há qualquer exigência para haver início da ação penal.
- **de iniciativa privada:** neste caso, será subdividida em :
 - **exclusivamente privada**
 - **personalíssima**
 - **subsidiária da pública**

No silêncio da lei, a ação será pública incondicionada. Vale lembrar que, no caso de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça, não há vinculação do Ministério Público, que pode promover, por exemplo, o arquivamento do inquérito policial.

4.1. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA

Será o MP o titular da ação penal pública incondicionada.

Esta ação é orientada pelos seguintes princípios:

- **oficialidade:** o MP é o órgão oficial.
- **obrigatoriedade (legalidade processual):** o MP, caso estejam presentes as condições da ação, é obrigado a agir (oferecer denúncia), salvo no caso da transação penal oferecida nos crime de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima cominada não ultrapassa dois anos.
- **indisponibilidade:** o MP não pode desistir da ação penal, tampouco desistir de um recurso por ele interposto. Mas ele poderá renunciar a interposição do recurso, ou seja, deixar de recorrer. O MP pode requerer a absolvição, mas não desistir. Uma mitigação desse princípio é a suspensão condicional do processo prevista na Lei 9.099/95; a denúncia é oferecida, mas em seguida há requerimento para suspender o processo quando a pena mínima do crime cometido não ultrapassa um ano.
- **intranscendência:** a ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime.
- **indivisibilidade ou divisibilidade:** a doutrina não é pacífica em dizer qual princípio prevalece. Sendo indivisibilidade, o MP teria que oferecer a denúncia contra todos os envolvidos. Para o princípio da divisibilidade, o MP não estaria obrigado a oferecer denúncia em face de todos os investigados. Prevalece a ideia da divisibilidade, visto que o *parquet* pode oferecer denúncia em relação a um, promover o arquivamento em relação a outro, requisitar novas diligências em relação ao terceiro, não havendo qualquer violação ao direito penal do fato.

4.2. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA

É necessário a prévia manifestação de vontade do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. A titularidade continua sendo do MP, que tem natureza jurídica de **condição específica de procedibilidade**.

A vítima faz a representação, enquanto o Ministro da Justiça faz uma requisição.

4.2.1. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO

O ofendido se manifesta no sentido de que **deseja dar início** ao processo penal. A única exigência é de que esta manifestação **se dê por escrito**, seja perante o delegado, membro do MP ou juiz.



A vítima deixa claro que quer a condenação do indivíduo.

Além disso, basta que haja uma **manifestação inequívoca de vontade** de querer ver o autor do crime processado criminalmente.

Edílson Bonfim estabelece que a **simples circunstância de que o ofendido se dirija à delegacia**, a fim de apresentar os fatos criminosos já seria suficiente para configurar o exercício da representação, eis que manifesta, inequivocamente, o desejo de responsabilizar criminalmente o investigado.

São **legitimados** a oferecer a representação:

- **vítima maior de 18 anos:** a própria vítima.
- **vítima menor de 18 anos:** representante legal da vítima.
- **interesses colidentes entre menor de 18 anos e seus representantes legais:** se os interesse entre o representante legal e a vítima forem conflitantes, o juiz nomeará um curador especial. No entanto, este curador não está obrigado a oferecer a representação, fazendo um juízo de conveniência e oportunidade em representar ou não pelo crime.
- **vítima morta ou declarada ausente:** nesse caso, o direito de representar passa a ser do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (CADI), **nesta ordem**.

Rogério Sanches entende que apesar de o CP falar em cônjuge, poderá estender o direito de representação ao companheiro. Samer Agi entende pela não aplicação, pois seria caso de analogia *in malam partem*.

A **retratação** da representação é plenamente admissível até **o oferecimento da denúncia**, e não o recebimento.

A **retratação da retratação** da representação também é possível, desde que se dê **até o último dia do prazo decadencial**. Este prazo decadencial é, via de regra, de **6 meses**, contados do dia em que tomar conhecimento acerca do autor do fato criminoso.

Caso a vítima ofereça representação **contra apenas um dos autores do delito**, o MP **poderá processar os demais**, pois a representação tem relação ao fato, e não em relação ao autor. Trata-se do fenômeno da **extensibilidade da denúncia**. Ou seja, a representação não se dá em face deste ou daquele autor, mas sim em relação **ao fato**, conforme explica Norberto Avena.

ii. Requisição do Ministro da Justiça

Trata-se de uma condição específica de procedibilidade.

As hipóteses estão previstas no Código Penal:

- **crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil:** o juízo político é feito pelo Ministro da Justiça.
- **crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro**
- **crime contra a honra de presidente da república**

Observa-se que a literalidade do texto legal faz constatar que a requisição do Ministro da Justiça não poderia ocorrer nos crimes contra a honra de chefe de estado estrangeiro. Isso porque chefe de governo não se confunde com chefe de estado. O CP fala somente em chefe de governo.

No caso de requisição do Ministro da Justiça, não há prazo decadencial, **podendo exercer esta requisição dentro do prazo prescricional**.

A lei **não fala sobre a retratação da requisição do Ministro da Justiça**, visto que esta requisição tem natureza de autorização, pois não vincula o membro do MP, podendo, inclusive, promover o arquivamento.

Mirabete entende que não é possível retratação da requisição do Ministro da Justiça, enquanto Nucci entende que é possível.

Samer Agi concorda com Nucci, pois, como se trata de um ato político, a situação política poderá se alterar, deixando de ser necessário que haja a requisição, hipótese em que haveria a retratação.

4.3. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA

O titular é o ofendido ou seu representante legal, caso a vítima seja menor de 18 anos.



Trata-se de uma verdadeira **substituição processual**. No caso, a vítima age em nome próprio, mas defendendo direito alheio, que é o direito de punir do Estado.

Há 3 espécies de ação penal de iniciativa privada:

- exclusivamente privada
- personalíssima
- subsidiária da pública

4.3.1. AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA

A ação penal exclusivamente privada deve ser exercida por meio de queixa-crime.

Vigoram aqui os **princípios** da:

- **oportunidade e da conveniência:** a vítima não é obrigada a oferecer a queixa-crime.
- **disponibilidade:** a vítima pode desistir da ação penal já em curso. Ex.: perdão judicial, que deve ser aceito.
- **indivisibilidade:** a vítima não pode escolher o réu, processando todos ou nenhum deles.
- **intranscendência:** a ação não pode ser oferecida em face de pessoa que não cometeu o delito.

Quanto à legitimidade, quem promove a ação será a vítima, caso seja maior de 18 anos, ou seu representante legal, caso seja menor de 18 anos. Sendo vítima morta ou ausente, o legitimado será o CADI, nesta ordem. A queixa-crime proposta por um dele afasta o direito dos demais de promover a ação penal.

Segundo o STJ, é **possível a condenação em honorários advocatícios em caso de ação penal privada**.

Na ação penal privada, o MP age como fiscal da lei, **podendo aditar a queixa-crime em relação aos aspectos formais**.

Em aspectos **materiais**, o **MP não poderia aditar a queixa**, a fim de incluir um agente, por exemplo. Há entendimento em sentido diverso.

Norberto Avena explica que **o MP deve velar pela indivisibilidade**, caso em que se for percebido violação a este princípio, o MP deverá requerer ao juiz que o querelante seja instado a se manifestar, ou aditando a queixa-crime, a fim de incluir o autor que estava de fora, ou ainda que seja reconhecida a renúncia em relação ao direito de ação.

O STF já entendeu que não oferecida a queixa-crime contra todos os supostos autores ou partícipes da prática delituosa, há afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, a implicar renúncia tácita ao direito de querela, cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal.

O prazo decadencial para ingressar com a ação penal privada é de **6 meses**, a contar do conhecimento da autoria.

Todavia, há **exceções**:

- **crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento:** o prazo se inicia do trânsito em julgado da sentença que anula o casamento.
- **crime de violação de direito autoral:**
 - será de 30 dias para oferecimento da queixa-crime, a contar da homologação do laudo pericial.
 - será de 8 dias, caso o autor do crime tenha sido preso em flagrante.

Existe uma discussão se o prazo decadencial cessa quando o sujeito oferece a denúncia ou queixa perante juízo incompetente.

O STF decidiu no sentido de que **cessaria**. No entanto, há uma distinção:

- se o sujeito promove ação penal perante **juízo relativamente incompetente**, haverá cessação do prazo decadencial, interrompendo a prescrição.
- Se o sujeito promove ação penal perante **juízo absolutamente incompetente**, não poderá ser cessado o prazo prescricional.



Segundo o STJ (03/2016), **está pacificado** na Corte que o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade **absolutamente** incompetente, **é ato absolutamente nulo**, não produzindo efeito como marco interruptivo da prescrição.

O próprio STJ também entende que, em se tratando de **incompetência relativa**, o exame da prescrição da pretensão punitiva deve considerar o recebimento da denúncia realizado pelo juízo incompetente, e não a convalidação posterior do Juízo que detém competência territorial, uma vez que este último ato possui natureza declarativa, prestando-se unicamente a confirmar a validade do primeiro. Em outros termos: **pelo princípio da convalidação, o recebimento da denúncia por parte de juízo territorialmente incompetente tem o condão de interromper o prazo prescricional.**

4.3.2. AÇÃO PENAL PRIVADA PERSONALÍSSIMA

Na ação penal privada personalíssima, o direito de agir é atribuído única e exclusivamente à vítima, de forma que se o ofendido morre, haverá extinção da punibilidade.

Sendo incapaz o ofendido, aguarda-se a cessação da sua incapacidade, a fim de que se possa oferecer a queixa crime.

O direito de agir é atribuído à vítima com exclusividade.

O único crime que se admite esta ação penal é o crime do art. 236 do CP, que é o delito de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento.

4.3.3. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

Ocorre nos casos em que o MP se mostra inerte, não oferecendo denúncia no prazo legal. E outras palavras, esgotado o prazo, o MP não promoveu o arquivamento do inquérito policial, não requereu novas diligências e não ofereceu denúncia. A partir desse momento, a vítima e seus representantes terão prazo de seis meses para oferecer a queixa-crime subsidiária.

A ação penal privada subsidiária da pública se faz presente em crimes originariamente de ação penal pública, situação em que esta não foi intentada no prazo legal pelo MP.

É denominada também de **ação penal secundária**, conforme a doutrina. Diante de uma circunstância, altera-se a legitimidade, ou especificidade, da ação penal.

Nesse caso, só caberá se o MP estiver inerte, caso o MP tenha pedido diligências, promovido o arquivamento do IP, etc., não será possível essa ação.

O prazo para intentar a ação penal privada subsidiária da pública é de **6 meses, contado do esgotamento do prazo de oferecimento da denúncia pelo MP.**

Esgotando o prazo, não haverá extinção da punibilidade pela decadência.

Com relação à ação penal privada subsidiária da pública, os poderes do MP são maiores, eis que poderá:

- **repudiar a queixa:** deverá, neste caso, oferecer **denúncia substitutiva**.
- **aditar a queixa:** poderá incluir novos autores ou novos fatos.
- **intervir em todas as etapas do processo:** seja oferecendo provas, interpondo recursos, quando necessário, etc.
- **havendo desídia do querelante:** o MP retoma a titularidade da ação penal, não ocorrendo a preempção.

5. INSTITUTOS QUE ENSEJAM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS CRIMES PERSEGUIDOS MEDIANTE AÇÃO PENAL PRIVADA

São institutos que ensejam extinção da punibilidade da ação penal privada:

- **decadência**



- **renúncia:** antes da ação penal, exaltando o princípio da oportunidade. Pode ser expressa ou tácita. A renúncia se estende aos demais, pelo princípio da indivisibilidade. Mas se a vítima renunciar, não prejudicará as demais.
- **perdão:** poderá ser oferecido durante o processo, decorre do princípio da disponibilidade. É imprescindível que o perdão seja aceito, sendo um ato bilateral (prazo de três dias para o aceite).
- **perempção:** é uma sanção ao querelante que está sendo desidioso. Trata-se de aplicação do princípio da disponibilidade. São hipóteses previstas no art. 60 do CPP:
 - iniciada a ação, o querelante deixar de promover o andamento do processo **durante 30 dias seguidos;**
 - falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, ninguém comparece em juízo, para prosseguir no processo, **dentro do prazo de 60 dias**, qualquer das pessoas do CADI;
 - querelante deixar de comparecer, **sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;**
 - sendo o **querelante pessoa jurídica, esta se extingue sem deixar sucessor.**

Obs.: Em relação aos crimes de calúnia e injúria, o art. 520 do CPP prevê uma audiência de conciliação antes do recebimento da queixa crime, hipótese em que o juiz ouvirá as partes separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Segundo o STF, neste caso, se o indivíduo não comparecer, **não haverá perempção**, pois não seria ele obrigado a comparecer à audiência de conciliação, quando não quer conciliar.

A doutrina estabelece que nas alegações finais deve ser possível perceber que o querelante quer a condenação do querelado. Não havendo esta conclusão, haverá perempção.

6. AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A HONRA

Com relação à ação penal nos crimes contra a honra, a regra é de que os crimes contra a honra são de **natureza privada**.

Havendo **lesão física, injúria ou lesão corporal**, a **ação penal será pública incondicionada**, em razão da lesão corporal.

A doutrina pondera que, com a Lei 9.099/95, a ação passaria a ser pública condicionada, já que lesão corporal leve é condicionada à representação. Para Samer Agi, a ação deve continuar sendo incondicionada, visto que o STF se manifestou acerca do assunto quanto ao crime de estupro, nos termos da Súmula 608 – “no crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada”. Esse entendimento do STF não foi alterado, mesmo com a Lei 9.099/95 que dispõe que se a lesão corporal for leve, a ação penal pública é condicionada a representação.

No caso de **delito contra a honra ser praticado contra funcionário público no exercício de suas funções**, a **ação penal é pública condicionada à representação**.

Segundo o STF, pela Súmula 714, é **concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido**, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Se o servidor optar por uma das vias, não poderá mais propor a outra via. Haveria uma preclusão lógica.

Sendo contra o Presidente da República ou contra o Chefe de Governo estrangeiro, a ação penal é pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.

O crime de injúria de caráter racial será **condicionada à representação**.



CAPÍTULO 24 — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA: DOS CRIMES CONTRA A VIDA

A Parte Especial do Código Penal contempla a maior parte das figuras definidas como crime no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, a abordagem não é exaustiva, vez que a legislação extravagante também tipifica importantes condutas delituosas.

Conforme se observa, a preocupação inicial do legislador está voltada à tipificação dos crimes contra a pessoa, colocando o ser humano em posição de destaque na tutela penal. Nota-se, ainda, que a pessoa é protegida desde a concepção, isto é, antes mesmo do nascimento.

O direito à vida é formalmente e materialmente constitucional (art. 5º, *caput*, CF). Porém, é relativo, podendo sofrer restrições, pois nenhum direito ou garantia individual tem caráter absoluto. Alguns exemplos de mitigação ao direito à vida previstos no ordenamento são a pena de morte em período de guerra declarada (5º, inc. XLVII, CF), a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, inc. II, CP), as hipóteses de aborto legal ou permitido (art. 128 do CP), dentre outros.

Importa ressaltar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os **crimes dolosos contra a vida**, consumados ou tentados (art. 5º, inc. XXXVIII, “d”, da CF).

Eis o rol dos crimes contra a vida previstos no Código Penal:

- Homicídio (art. 121)
- Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação (art. 122)
- Infanticídio (art. 123)
- Aborto (arts. 124 a 128)

Devemos ainda destacar que, dos quatro crimes acima mencionados, apenas o homicídio apresenta as formas dolosa e culposa. Os demais somente são praticados com dolo (direto ou eventual). No caso do homicídio culposo, a competência para julgar é do juízo singular.

1. ART. 121. HOMICÍDIO

Figura central dos crimes contra a vida, trata-se da conduta de matar alguém. Crime bicomum, já que não se exige qualidade especial, quer do agente, quer da vítima e material, isto é, tem um resultado naturalístico, o qual precisa ser alcançado para a consumação. É crime de forma livre, pois pode ser praticado por qualquer meio. Em regra, comissivo, mas poderá também ocorrer por omissão. Pode ser classificado ainda como instantâneo, já que se esgota com a ocorrência do resultado, porém de efeito permanente. É um crime de dano, pois o elemento subjetivo busca ofender o bem jurídico tutelado (a vida) e não somente colocá-lo em perigo.

O homicídio é conceituado como a eliminação da vida humana extrauterina. Se a supressão da vida for intrauterina, haverá aborto. Iniciado o trabalho de parto, a hipótese será de homicídio ou infanticídio, a depender do caso. Considera-se iniciado o trabalho de parto com a dilatação do colo do útero e as contrações expulsórias, nos partos naturais, e com a incisão no abdômen feita pelo médico, nos casos de parto cirúrgico (cesariana).

Tradicionalmente, considera-se o início da vida extrauterina com a verificação de processo respiratório autônomo, passível de constatação por prova pericial (docimasias respiratórias). Todavia, há quem entenda de modo diverso. Certo é que a respiração é a prova por excelência da existência de vida, mas não é a única, já que a vida pode se manifestar por movimentos circulatórios e pulsações do coração, por exemplo.²¹

Quando a vítima do homicídio, tentado ou consumado, é o Presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do STF, e o crime tem motivação política, incidirá o autor no art. 29 da Lei nº 7.170/83 (Crimes contra a Segurança Nacional). Aplica-se, portanto, o princípio da especialidade.

²¹BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2**. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 54.



Vale ressaltar que o genocídio, tipificado pela Lei nº 2.889/56, consiste na conduta de matar indivíduos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Assim, não é crime contra a vida, mas sim contra a humanidade.

No homicídio doloso, o agente atua imbuído do denominado *animus necandi ou occidendi*. Admite-se o dolo eventual, quando o agente não quer o resultado morte, mas assume o risco de produzi-lo.

Questão sempre debatida diz respeito ao homicídio praticado na direção de veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica. Nessa situação, pode-se caracterizar dolo eventual ou culpa consciente, a depender do caso concreto. A tendência jurisprudencial tem sido afastar qualquer consideração apriorística sobre dolo eventual no caso de homicídios praticados por indivíduos que ingeriram bebida alcoólica. Há que se ponderar as circunstâncias da hipótese em análise, uma vez que podem haver sensíveis diferenças quanto à substância ingerida, a quantidade, e a própria conduta do agente.

A consumação do homicídio ocorre com a morte, verificada pela cessação da atividade encefálica (art. 3º, *caput*, Lei nº 9.434/97).

A prova da materialidade, por sua vez, é feita por meio de exame necroscópico, o qual atesta a morte e suas causas.

É admissível a tentativa (no latim, *conatus*), exceto quanto ao homicídio culposo, vez que os delitos culposos são incompatíveis com a forma tentada.

A tentativa de homicídio pode ser branca ou incruenta, quando a vítima não é atingida, ou ainda vermelha ou cruenta, quando a vítima sofre ferimentos. Exemplo: indivíduo encontra um desafeto e, com a arma de fogo municiada, efetua disparos em direção ao inimigo, com intenção de matar. Os disparos atingem o inimigo, mas esse não vem a falecer, pois recebeu atendimento médico que evitou a morte. Tem-se, portanto, a tentativa cruenta. Por sua vez, se o indivíduo efetua os disparos e não atinge a vítima, por erro de pontaria, tem-se uma tentativa branca.

O homicídio será hediondo quando qualificado (art. 121, §2º, CP) ou se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente (art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90). Extermínio é a chacina, a eliminação da vida pelo fato da vítima pertencer a determinado grupo ou classe social, a exemplo de pessoas em situação de rua, prostitutas, homossexuais ou moradores de determinadas comunidades. A ação revela impessoalidade, isto é, a vítima não é escolhida por suas características individuais, mas sim por pertencer ou ser membro de um grupo que compartilha das mesmas condições.

A figura básica do homicídio, descrita no *caput* do art. 121, não tem natureza hedionda e tem pena cominada em abstrato de 6 a 20 anos de reclusão.

1.2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

No art. 121, § 1º, do CP, temos a previsão do homicídio privilegiado como causa especial de diminuição de pena (minorante). Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Apesar do dispositivo legal trazer a expressão “o juiz pode reduzir a pena”, entende-se não se tratar de uma faculdade, mas sim de imposição legal, de direito subjetivo caso o acusado preencha os requisitos previstos em lei e o Conselho de Sentença reconheça a causa de diminuição de pena.

Note-se que a conduta continua típica, ilícita e praticada por agente culpável. A estrutura do crime permanece intacta. Todavia, o legislador considera que os motivos do crime merecem uma reprovabilidade menor, de sorte a se reduzir a pena na terceira fase da dosimetria. Tal figura privilegiada, por certo, não se reveste de caráter hediondo, segundo entendimento já consolidado na doutrina e na jurisprudência.

Importante frisar que o privilégio é tese defensiva, a ser apresentada durante os debates no plenário do júri. A matéria será quesitada antes das qualificadoras e, uma vez reconhecida a minorante



pelo Conselho de Sentença, o juiz deverá reduzir a pena. Trata-se de direito subjetivo do acusado e não mera liberalidade do juiz presidente, por força do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, CF).

Por estar a privilegiadora relacionada à motivação do agente, isto é, aos motivos determinantes do crime, apresenta caráter subjetivo ou pessoal, portanto incomunicável aos coautores ou partícipes, nos termos do art. 30 do CP, segundo o qual “*Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime*”.

O art. 121, §1º, traz três hipóteses de homicídio privilegiado:

- a) **Relevante valor social:** se dá quando o interesse é de toda a coletividade. Ex.: matar o traidor da pátria, ou matar o estuprador de diversas crianças no bairro.
- b) **Relevante valor moral:** ocorre quando há um interesse individual, em regra envolvendo sentimento de misericórdia ou compaixão. Ex.: homicídio eutanásico.

Quanto à eutanásia, importante destacar não ser admitida no direito brasileiro a causa supralegal de exclusão da ilicitude fundada no consentimento do ofendido, vez que a vida é direito indisponível. Dessa forma, ainda que a vítima, doente em estado terminal, manifeste em declaração de última vontade seu consentimento com a eutanásia, isto é, com a abreviação da própria vida, estará caracterizado o homicídio. Todavia, considerando que o autor do crime age por sentimento de piedade, em razão do sofrimento da vítima que padece de doença ou mal incurável, poderá ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena.

A eutanásia em sentido estrito é aquela praticada por um agir (modo comissivo), com a eliminação da vida de pessoa portadora de doença grave ou sem prognóstico de recuperação. Já a ortotanásia é a eutanásia por omissão, moral ou terapêutica. Por exemplo, quando o médico deixa de adotar as providências para prolongar a vida do doente terminal.

- c) **Homicídio emocional:** o sujeito ativo reage **logo após** injusta provocação da vítima, sob o domínio de violenta emoção.
São requisitos: **domínio de violenta emoção** (não basta a influência, que é atenuante genérica prevista no art. 65, inc. III, “c”, do CP; deve ser a emoção que retira por completo a capacidade de agir refletidamente); **reação imediata** (não pode ocorrer horas ou dias após); **injusta provocação da vítima** (apta a gerar repulsa e indignação, de acordo com um consenso geral).

Importa lembrar que a emoção não afasta a responsabilização penal, conforme dispõe o art. 28, inc. I, do CP. Porém, tem o condão de privilegiar o crime de homicídio.

1.3. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO OU HÍBRIDO

É pacífico o entendimento sobre a possibilidade de homicídio privilegiado – qualificado, a um só tempo, desde que a qualificadora tenha natureza objetiva. **Exemplo:** matou valendo-se de meio cruel (múltiplos golpes de faca), mas agiu logo após a injusta provocação da vítima, sob o domínio de violenta emoção.

Considerando a orientação contida no art. 67 do CP, segundo a qual devem preponderar os motivos determinantes do crime, o homicídio privilegiado-qualificado não é hediondo. Assim sendo, de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o chamado homicídio privilegiado-qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras, de natureza subjetiva, com qualificadoras de natureza objetiva, não é considerado crime hediondo.

Importa distinguir, então, as qualificadoras objetivas das subjetivas.



As qualificadoras objetivas, materiais ou reais são aquelas que se materializam no plano fático, que podem ser constatadas pelo trabalho pericial e que aparecerão numa fotografia da cena do crime. Estão, portanto, relacionadas aos meios e modos de execução do crime. São as qualificadoras dos incisos III, IV e VI do § 2º do art. 121, com exceção da traição, já que nesse último caso tem-se a quebra de uma relação de confiança preexistente entre as partes e, portanto, de natureza subjetiva. Quanto ao inciso VI, que contempla o **feminicídio**, a jurisprudência do STJ tem o considerado como **qualificadora de índole objetiva**, compatível, assim, com a motivação torpe. Não se desconhece a existência de entendimento doutrinário em sentido diverso. Porém, para fins de prova objetiva, o candidato deverá seguir a posição do STJ.²²

As qualificadoras subjetivas, por seu turno, estão relacionadas aos aspectos volitivos do agente, isto é, a motivação do crime. Estão descritas nos incisos I, II, V e VII do § 2º do art. 121.

1.4. HOMICÍDIO QUALIFICADO

As hipóteses qualificadoras do homicídio estão dispostas no § 2º do art. 121. Tornam o crime hediondo, isto é, submetido aos rigores da Lei nº 8.072/90, que veda a concessão de graça, anistia, indulto e fiança. Ademais, as qualificadoras aumentam os patamares de pena em abstrato, que passam a ser de 12 a 30 anos de reclusão. Enquanto os motivos sociais ou morais privilegiam o delito, as motivações imorais ou antissociais o qualificam.

Em síntese, temos o seguinte panorama das qualificadoras:

Incisos I e II: motivos do crime (subjetivas; incompatíveis com o privilégio)

Incisos III e IV: meios e modos de execução (objetivas, exceto traição)

Inciso V: conexão (especial finalidade do agente; subjetiva, incompatível com o privilégio)

Inciso VI: feminicídio (contra mulher, por razões e condição do sexo feminino ou em contexto de violência doméstica e/ou familiar; objetiva, segundo o STJ)

Inciso VII: contra integrantes dos órgãos de segurança pública ou pessoas a eles vinculadas por casamento, união estável ou parentesco (subjetiva, incompatível com o privilégio).

Vejamos as principais características de cada uma das qualificadoras.

INCISO I — Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe

O legislador se valeu, na redação do dispositivo legal, de fórmula casuística (mediante paga ou promessa de recompensa), seguida de fórmula genérica, que admite interpretação analógica tendo por base os exemplos anteriormente apresentados.

²²PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE.

COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018).

Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).



Tem-se a figura típica do homicídio mercenário, praticado por cupidez, ambição imoderada. A paga corresponde ao recebimento prévio, enquanto a promessa de recompensa contempla a expectativa futura de pagamento pela execução do homicídio.

Trata-se de crime bilateral ou de concurso necessário, já que há, no mínimo, um mandante e um executor (sicário, mercenário, matador de aluguel).

Importante notar que a qualificadora NÃO se aplica automaticamente ao mandante, por se tratar de circunstância de caráter subjetivo (art. 30 do CP: “não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”).²³

O motivo torpe é aquele indigno, vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável, que atinge profundamente o sentimento ético-social da coletividade.

A vingança e o ciúmes não necessariamente caracterizam torpeza. É preciso analisar as circunstâncias do caso concreto.

INCISO II – Motivo fútil

É o motivo banal, insignificante, desproporcional, de pouca importância, que revela egoísmo ou mesquinhez. Não se confunde com o motivo torpe. Um motivo não pode ser simultaneamente torpe e fútil, vez que não há identidade entre as expressões.

A ausência de motivo ou o seu desconhecimento não pode ser taxado de fútil.

Ciúmes e embriaguez não necessariamente são motivos fúteis, sendo necessário o exame da hipótese fática.

Uma importante divergência doutrinária e jurisprudencial reside em saber se há compatibilidade entre o motivo fútil e o dolo eventual.

Para a primeira corrente, seriam compatíveis. O fato de o réu ter assumido o risco de produzir o resultado morte, aspecto caracterizador do dolo eventual, não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil, uma vez que o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta, mostrando-se, em princípio, compatíveis entre si (STJ. 5ª Turma. REsp 912.904/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06/03/2012).

Já a segunda corrente considera a qualificadora do motivo fútil incompatível com o dolo eventual, tendo em vista a ausência do elemento volitivo (STJ. 6ª Turma. HC 307.617-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/4/2016. Info 583). Para os adeptos dessa corrente, é preciso diferenciar a voluntariedade e a intenção criminosa. A voluntariedade está presente em todas as ações delitivas. Já a intenção criminosa, que está voltada às consequências da ação lesivas ao direito, não está presente nos crimes culposos e nos cometidos com dolo indireto.

Vale destacar que, segundo entendimento jurisprudencial, a incidência da qualificadora do motivo fútil exige uma reação desproporcional do agente a uma ação ou omissão da vítima. Não existindo nenhum comportamento prévio do ofendido, a despertar a reação egoísta ou mesquinha do autor, não há que se falar em futilidade. Confira-se:

Não incide a qualificadora de motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), na hipótese de homicídio supostamente praticado por agente que disputava ‘racha’, quando o veículo por ele conduzido -

²³ PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. MOTIVO TORPE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. MANDANTE. COMUNICABILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante a paga ou a promessa de recompensa seja circunstância accidental do delito de homicídio, de caráter pessoal e, portanto, incomunicável automaticamente a coautores do homicídio, não há óbice a que tal circunstância se comunique entre o mandante e o executor do crime, caso o motivo que levou o mandante a empreitar o óbito alheio seja torpe, desprezível ou repugnante.

2. Na espécie, o recorrido teria prometido recompensa ao executor, a fim de, com a morte da vítima, poder usufruir vantagens no cargo que exercia na Prefeitura Municipal de Fênix.

3. Recurso especial provido, para reconhecer as apontadas violações dos arts. 30 e 121, § 2º, I, ambos do Código Penal, e restaurar a decisão de pronúncia, restabelecendo a qualificadora do motivo torpe, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

(REsp 1209852/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)



em razão de choque com outro automóvel também participante do 'racha' - tenha atingido o veículo da vítima, terceiro estranho à disputa automobilística. Motivo fútil corresponde a uma reação desproporcional do agente a uma ação ou omissão da vítima. No caso de 'racha', tendo em conta que a vítima (acidente automobilístico) era um terceiro, estranho à disputa, não é possível considerar a presença da qualificadora de motivo fútil, tendo em vista que não houve uma reação do agente a uma ação ou omissão da vítima. (STJ. 6ª Turma. HC 307.617-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/4/2016. Info 583).

INCISO III – Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum

Verifica-se que o CP se valeu de fórmula casuística, exemplificando com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, e arremata com uma expressão genérica (ou outro meio insidioso ou cruel).

O meio insidioso é aquele traiçoeiro, sorrateiro, enganador, que envolve fraude, sabotagem. Exemplo: bebida com veneno, sabotagem em automóvel. No caso do veneno, para a caracterização da qualificadora do meio insidioso, é preciso que seja ministrado dissimuladamente, isto é, sem conhecimento da vítima. Se o veneno for administrado de forma forçada ou com conhecimento da vítima, poderá se caracterizar, em tese, o meio cruel, se o propósito for causar intenso ou desnecessário sofrimento. A consequência prática, para fins de fixação da pena, é a mesma.

O emprego de fogo e explosivo podem constituir meio cruel ou meio de que pode resultar perigo comum, a depender das circunstâncias. Exemplos de explosivos: bomba caseira, coquetel Molotov.

A asfixia, por sua vez, consiste em obstar a função respiratória. Poderá ser mecânica (afogamento, enforcamento) ou tóxica (gás asfixiante).

A tortura, conceituada pelo Decreto nº 40/91, que promulgou a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes é entendida como

qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.

Importa distinguir o homicídio qualificado pela tortura do crime de tortura com resultado morte, tipificado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.455/97. No caso do homicídio qualificado pela tortura, o agente atua com dolo de matar (direto ou eventual). A tortura é o meio empregado, que provoca intenso ou desnecessário sofrimento físico ou mental. A competência para julgar é do Tribunal do Júri. Já no caso da tortura com resultado morte, tem-se um exemplo de crime preterdoloso (dolo no antecedente e culpa no consequente, a morte). A competência é do juízo singular. A conclusão, portanto, é que a diferença reside na análise do elemento subjetivo (dolo), que se revela pelas circunstâncias que estão em torno do crime. Se a intenção for a todo momento a de provocar a morte e se escolhe o meio especialmente cruel, tem-se o homicídio qualificado pela tortura. No entanto, se o objetivo era torturar para obter alguma informação ou castigar, não sendo a intenção matar, mas ocorrendo a morte por culpa, o crime será o tipificado na lei de tortura. Em ambos os casos, o crime será hediondo, já que a tortura é crime equiparado a hediondo pela CF (art. 5º, inc. XLIII, CF).

O meio cruel é aquele que causa intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, que revela ausência de piedade, sadismo, um martírio. A quantidade (reiteração) de golpes é um indicativo do meio cruel.

O meio de que possa resultar perigo comum é aquele que pode atingir um número indeterminado de outras pessoas, além da vítima. Exemplo: disparos feitos em festa ou em via pública.

INCISO IV — À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido

O inciso IV retrata os modos qualificadores do homicídio. O crime é praticado de forma a dificultar ou impedir a reação defensiva da vítima. A lei se utiliza de alguns exemplos (traição, emboscada e dissimulação), seguidos de uma fórmula genérica que admite interpretação analógica.

É uma qualificadora muito frequente nas denúncias. Quando o disparo é efetuado pelas costas, ou quando a vítima é absolutamente surpreendida em sua casa ou local de trabalho, em que o ataque se mostra inesperado, tem-se a possibilidade de enquadramento no inciso IV.

A traição pode ser física (tiro pelas costas) ou moral (atrair para um abismo). O agente se vale da confiança da vítima e atua de modo sorrateiro. É um **crime próprio ou especial**, pois só pode ser cometido por pessoa que tem a confiança da vítima.

A emboscada revela-se na tocaia. O agente se oculta para surpreender. Na emboscada, que é sempre premeditada, o autor aguarda escondido a passagem da vítima desprevenida.

A dissimulação, por sua vez, é a atuação disfarçada, o modo de agir hipócrita, que ilude. Exemplo: demonstração de falsa amizade.

O recurso que dificulta ou impossibilita a defesa deve ter por parâmetro a traição, a emboscada ou a dissimulação. Isto é, deve guardar similitude de natureza. O exemplo mais frequente é a surpresa, o ataque inesperado, do qual a vítima não desconfia e não prevê.

INCISO V – Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime

Os fins qualificadores do homicídio têm natureza subjetiva, relacionados à motivação do agente. Observa-se o atuar com um especial fim de agir, já que o homicídio é praticado para garantir a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Há, portanto, a conexão, a ligação entre dois ou mais crimes.

Para a caracterização da qualificadora é indiferente que o homicídio ocorra antes ou depois do crime que se pretende assegurar. Não é preciso que o crime conexo venha de fato a ocorrer, bastando apenas a intenção de praticá-lo.

Duas espécies de conexão podem ser verificadas. A conexão **teleológica** ocorre quando o homicídio é praticado para assegurar a execução de outro crime. **Exemplo:** matar um segurança para em seguida matar ou sequestrar um empresário. Na conexão **sequencial** ou **consequencial**, o homicídio é cometido posteriormente ao crime. **Exemplo:** matar a testemunha do crime anterior.

INCISO VI – Feminicídio. Homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino ou em contexto de violência doméstica ou familiar.

O homicídio por motivação de gênero foi incorporado ao Código Penal pela Lei nº 13.104/15. É o crime discriminatório, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino ou em contexto de violência doméstica ou familiar.

De plano, importa distinguir feminicídio de feminicídio. Matar uma mulher não necessariamente será feminicídio se não houver um contexto de violência doméstica ou familiar ou, ainda, um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Exemplo: matar a ex-empregadora por ter sido demitido por justa causa, matar uma mulher num contexto de briga de vizinhos, briga de trânsito ou disputa de terras. Em princípio, não se caracteriza feminicídio, já que a motivação não está relacionada ao sexo da vítima, embora outras qualificadoras possam ser cogitadas a depender das peculiaridades do caso.

O autor do feminicídio poderá ser homem ou mulher, já que não há óbice à aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) a relações entre duas mulheres, desde que presente uma desigualdade entre as partes, isto é, uma relação que envolva subordinação, vulnerabilidade ou submissão em um dos polos. Inclusive, o art. 5º, parágrafo único, da Lei Maria da Penha expressamente dispõe que as relações

peçoais enunciadas no dispositivo legal independem de orientação sexual, a significar que o diploma pode ser aplicado a relações homoafetivas entre mulheres.

A vítima do feminicídio é necessariamente do sexo feminino. Nesse ponto, porém, convém destacar que a doutrina e jurisprudência têm caminhado para reconhecer a possibilidade do transexual feminino ser também vítima do crime.

O transexual é o indivíduo que sofre uma dicotomia físico-psíquica, possuindo um sexo físico distinto de sua conformação sexual psicológica. Nessa situação, a cirurgia de mudança de sexo (transgenitalização) pode se apresentar como um modo necessário para a adequação dos estados físico e psíquico. O transexual comporta-se perante a sociedade como se enxerga psicologicamente, ou seja, com os atributos do sexo oposto ao de seu nascimento.

O nome social é a identificação pela qual os transexuais são chamados cotidianamente, em contraste com o nome oficialmente registrado, que não reflete sua identidade de gênero.

Sobre a possibilidade do transexual feminino ser vítima de feminicídio existem duas correntes. A primeira não admite tal possibilidade, ainda que tenha havido a cirurgia de transgenitalização. Sustentam seus defensores que a cirurgia altera somente o aspecto físico e estético, e não a genética. A outra corrente admite que, se o transexual tiver feito a cirurgia de mudança de sexo de forma definitiva e a retificação de seu registro civil, deve ter o tratamento dispensado de acordo com a sua nova característica física, vez que a psicológica já o colocava nessa posição. Dessa forma, considerando que o transexual tem o psiquismo voltado para o gênero feminino e que tenha realizado a cirurgia de mudança de órgãos genitais, bem como a alteração em seu registro civil para fazer constar mulher, poderá ser abrangido pela proteção especial do feminicídio.

Deve-se notar que, se o objetivo da qualificadora é proteger o polo mais fraco da relação afetiva ou social, seja ela biologicamente mulher ou juridicamente mulher, a corrente que entende possível o transexual ser vítima de feminicídio tende a prevalecer.

Vale lembrar que a jurisprudência já pacificou o entendimento sobre a possibilidade da alteração do registro civil, mesmo que o transexual não tenha se submetido à cirurgia de transgenitalização. Consequentemente, à luz dos direitos fundamentais corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, infere-se que o direito dos transexuais à retificação do sexo no registro civil não pode ficar condicionado à exigência de realização do procedimento cirúrgico, para muitos inatingível do ponto de vista financeiro ou mesmo inviável do ponto de vista médico.²⁴

Conforme já ressaltado, o feminicídio é o crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino ou em contexto de violência doméstica ou familiar.

O conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher está no art. 5º da Lei Maria da Penha, **sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.**

Assim, o feminicídio fundado em violência doméstica é uma norma penal em branco imprópria heterovitelinária, já que é necessário recorrer ao art. 5º da Lei 11.340/06 para completar o sentido do preceito e permitir a sua correta aplicação.

Além do feminicídio ser uma qualificadora do crime de homicídio, o Código Penal prevê no art. 121, § 7º, causas de aumento de pena específicas, de 1/3 até a metade, se o crime for praticado:

- I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
- II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;
- III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;
- IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

²⁴ Nesse sentido, REsp 1626739/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 01/08/2017.

Por certo, tais circunstâncias devem ingressar na esfera de conhecimento do agente, sob pena de se consagrar a indesejável responsabilidade penal objetiva.

O inciso IV merece especial atenção. Na hipótese do feminicídio ter sido praticado em descumprimento a medida protetiva de urgência (proibição de contato e aproximação, por exemplo), previamente estabelecida e da qual o agressor já havia sido intimado, responderá o agente também pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06?

Os Tribunais Superiores ainda não se manifestaram sobre o assunto, porém, a melhor interpretação deve ser no sentido de que o crime do art. 24-A do CP, como crime-meio, é absorvido pela conduta mais grave, o feminicídio. Fazer incidir o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e também o inciso IV do § 7º do art. 121 do CP representaria punir duas vezes o agente pelo mesmo fato (*bis in idem*), o que é vedado.

Tema importante diz respeito à natureza do feminicídio como qualificadora.

A doutrina diverge, havendo aqueles que defendem a natureza subjetiva (Rogério Sanches Cunha), enquanto outros a natureza objetiva (Nucci).

Porém, a jurisprudência do STJ tem reconhecido o feminicídio como qualificadora de índole objetiva, compatível com o motivo torpe. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. BIS IN IDEM COM O MOTIVO TORPE. AUSENTE. QUALIFICADORAS COM NATUREZAS DIVERSAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)

2. Nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente. Assim, não há se falar em ocorrência de *bis in idem* no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, porquanto, a primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 440.945/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

INCISO VII – Contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

A qualificadora ora em comento encontra justificativa na gravidade da conduta, atentatória à estrutura do Estado Democrático de Direito.

Trata-se de norma penal em branco de fundo constitucional, já que é preciso completar o conteúdo com as disposições dos artigos 142 e 144 da CF.

No art. 142 estão listadas as Forças Armadas, isto é, Marinha, Exército e Aeronáutica. Já o art. 144 traz o rol dos órgãos incumbidos da segurança pública, a saber, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Cíveis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais federal, estaduais e distrital.²⁵ As guardas municipais também se incluem no rol, conforme art. 144, § 8º, CF, assim como os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública.

Convém destacar que a preocupação do legislador, ao instituir a qualificadora, foi com a função pública exercida e não propriamente com a pessoa atingida. Se o indivíduo está afastado das funções, exonerado ou aposentado, não incidirá o autor do crime na qualificadora. É preciso, ademais, que

²⁵ As Polícias Penais, criadas pela EC 104/2019, são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabendo a elas a segurança dos estabelecimentos penais. O objetivo dessa mudança foi valorizar os agentes penitenciários, conferindo-lhes os direitos inerentes à carreira policial, e permitindo uma melhor estruturação da agora Polícia Penal.

o crime esteja relacionado ao exercício funcional. Um indivíduo que mata um policial militar, fora de serviço, em razão de uma discussão de trânsito, não incidirá na figura qualificada do inc. VII.

1.5. HOMICÍDIO CULPOSO

O art. 121, § 3º, do CP, prevê pena de detenção, de um a três anos, quando o homicídio é culposo.

A culpa é elemento normativo do tipo, a ser verificada por meio de um juízo de valor.

No homicídio culposo, o desvalor do resultado é idêntico ao do homicídio doloso. O que é substancialmente menor é o desvalor da conduta, já que a morte advém de uma escolha equivocada quanto à forma de agir, por imprudência, negligência ou imperícia, e não de um intento deliberado para produzir a morte.

Assim, no crime culposo observa-se a violação a um dever objetivo de cuidado.

A imprudência é a culpa positiva, representada por um agir. A negligência é culpa negativa, um deixar de fazer. A imperícia, por sua vez, é a culpa profissional, ligada ao exercício de arte, ofício ou profissão.

Importante destacar que a competência para julgar o homicídio culposo é do juízo singular e não do Tribunal do Júri.

Não há tentativa de homicídio culposo. Com efeito, o crime culposo não é compatível com a tentativa (exceção feita à culpa imprópria, na qual o agente age dolosamente, mas em erro). Na tentativa há dolo idêntico ao da consumação do crime, mas o autor não atinge o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Já no crime culposo não há dolo.

Na hipótese de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor aplica-se o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), por força do princípio da especialidade.

O § 4º do art. 121 estabelece causa de aumento de pena de 1/3 para o homicídio culposo se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

O instituto do **perdão judicial** é aplicável ao homicídio culposo, conforme dispõe o art. 121, § 5º: “Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”.

Trata-se de incidência prática do **princípio da infração bagatelar imprópria**. Tem-se um fato típico, ilícito e culpável. Porém, a punibilidade é afastada, pois o Estado entende desnecessária a aplicação de pena àquele indivíduo que praticou o fato criminoso, já que as consequências do crime exercem a função retributiva da pena.

O perdão judicial é causa de extinção da punibilidade, previsto no rol do art. 107, inc. IX, do CP. Importante lembrar, ainda, da Súmula 18 do STJ: “A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.” Não há condenação, nem absolvição. O magistrado limita-se a declarar a extinção da punibilidade.

Para a concessão do perdão judicial é preciso criteriosa avaliação do caso concreto, para se verificar as condições pessoais dos envolvidos. Segundo o STJ, é necessário vínculo de parentesco ou afinidade entre agente e vítima.

Em caso de concurso formal de crimes, o perdão judicial concedido para um deles não necessariamente deverá abranger o outro. O fato de os delitos terem sido cometidos em concurso formal não autoriza a extensão dos efeitos do perdão judicial concedido para um dos crimes, se não restou comprovada, quanto ao outro, a existência do liame subjetivo entre o infrator e a vítima fatal. Exemplo: indivíduo dirigindo seu veículo imprudentemente causa a morte de sua noiva e de um colega de trabalho, a quem deu carona. O fato de ter sido concedido perdão judicial em relação à morte da noiva não significará

a extinção da punibilidade no que tange ao homicídio culposo do colega, com quem o agente não tinha vínculo de parentesco ou afinidade.²⁶

Por fim, cabe destacar que não se aplica o arrependimento posterior ao homicídio culposo, conforme entendimento do STJ, já que o instituto previsto no art. 16 do CP requer a prática de crime de natureza patrimonial ou de efeitos patrimoniais, o que não se verifica na hipótese de delito contra a vida.²⁷

Admite-se o acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) somente na hipótese de homicídio culposo. Segundo a doutrina, os crimes incompatíveis com o acordo são aqueles cuja violência está na conduta, e não no resultado.²⁸

QUESTÕES

1- (CEBRASPE – TJPR – 2019) A respeito de crimes contra a pessoa, é correto afirmar que

A responderá pela prática de crime contra a vida o agente que anuncia produtos ou métodos abortivos.

B responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção penal.

C o crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime.

D o agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio, haja vista a vítima ser mulher.

2- (CEBRASPE – DPDF – 2019) Assinale certo ou errado

A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito:

Letra C está correta. Os incisos III e IV do § 2º do art. 121 contemplam as qualificadoras quanto aos meios e modos de execução do homicídio. Nos dois casos, a lei se utiliza de alguns exemplos, seguidos de uma fórmula genérica que admite interpretação analógica, nos moldes dos paradigmas anteriormente listados.

A letra A está errada, pois o delito seria, em tese, contra a paz pública, o de incitação ao crime, previsto no art. 286 do CP.

A letra B também está errada, pois o art. 121, § 2º, inc. V, não contempla a contravenção penal, mas somente crime, não se admitindo analogia *in malam partem*.

Por fim, a letra D está errada vez que a motivação do crime não está ligada a razões ou condições do sexo feminino, não se podendo cogitar de feminicídio.

2. Gabarito:

Letra C está correta. Os incisos III e IV do § 2º do art. 121 contemplam as qualificadoras quanto aos meios e modos de execução do homicídio. Nos dois casos, a lei se utiliza de alguns exemplos,

²⁶STJ. 6ª Turma. REsp 1444699-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 1/6/2017 (Informativo 606).

²⁷ Não se aplica o instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP) para o homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) mesmo que tenha sido realizada composição civil entre o autor do crime a família da vítima. Para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP é indispensável que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. STJ. 6ª Turma. REsp 1.561.276-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/6/2016 (Info 590).

²⁸CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume único. Parte Especial**. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 45.



seguidos de uma fórmula genérica que admite interpretação analógica, nos moldes dos paradigmas anteriormente listados.

A letra A está errada, pois o delito seria, em tese, contra a paz pública, o de incitação ao crime, previsto no art. 286 do CP.

A letra B também está errada, pois o art. 121, § 2º, inc. V, não contempla a contravenção penal, mas somente crime, não se admitindo analogia *in malam partem*.

Por fim, a letra D está errada vez que a motivação do crime não está ligada a razões ou condições do sexo feminino, não se podendo cogitar de feminicídio.

2. ART. 122. INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO A SUICÍDIO OU A AUTOMUTILAÇÃO (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.968/19)

O tipo penal sofreu completa reformulação com o advento da Lei nº 13.968/19, com vigência a partir de 26 de dezembro de 2019 (não houve *vacatio legis*).

Importa notar que um mesmo dispositivo legal passou a prever comportamentos claramente distintos. No mesmo tipo há a previsão de crime doloso contra a vida e de natureza diversa. Com efeito, na hipótese de automutilação, a tutela se dirige à integridade física alheia, de maneira que a conduta estaria melhor alocada no capítulo das lesões corporais. É criticável também que ambas as condutas tenham a mesma reprovação penal, embora uma seja nitidamente mais grave do que a outra. Diante da natureza diversa dos delitos, a participação em suicídio continua a ser da competência do Tribunal do Júri, ao passo que a participação na automutilação, por não ser crime doloso contra a vida, será julgada pelo magistrado singular, perante o Juizado Especial Criminal. Admitida a transação penal, fica prejudicado o acordo de não persecução penal (art. 28-A, § 2º, inc. I, CPP).

A principal mudança foi a inclusão, no preceito primário, da participação em automutilação. Antes, só havia a previsão da participação em suicídio, condicionada a punição do agente à produção de resultado lesão grave/gravíssima ou morte.

Suicídio é a destruição deliberada da própria vida. Deve ser voluntária. Não se fala em consentimento da vítima.

Não se punia nem se pune atualmente a tentativa de se matar. A norma penal tutela a vida alheia, não aceitando que o agente dê a ideia, reforce o projeto ou forneça algum auxílio material para que um terceiro se mate.

Automutilação é a conduta de causar lesões em si próprio.

Pelo princípio da alteridade, o qual veda a punição de condutas que não ultrapassem o âmbito de disponibilidade do agente, a autolesão, por si só, não é punida. Assim como o suicídio não é punido, o que o legislador veda é o induzimento, a instigação ou o auxílio material a alguém para que se mutila.

A participação no suicídio ou automutilação pode ser moral (nas modalidades induzir e instigar) ou material (na modalidade auxiliar). Induzir significa incutir a ideia, até então inexistente. Instigar consiste em reforçar o propósito preexistente. Por sua vez, auxiliar é concorrer materialmente, com o empréstimo da arma, por exemplo.

Por se tratar de um tipo misto alternativo, de conduta múltipla ou de conteúdo variado, se praticados mais de um dos verbos, no mesmo contexto fático, haverá a prática de crime único do art. 122.

O CP é expresso, no art. 146, §3º, inc. II, no sentido de que não há constrangimento ilegal na coação feita para impedir o suicídio.

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (crime comum). O sujeito passivo, no entanto, deve ter um mínimo de capacidade de resistência e de discernimento. Do contrário, haverá lesão corporal ou homicídio. Nesse sentido já se posicionava a doutrina e, com o advento da Lei nº 13.968/19, passou a constar expressamente do texto legal, nos parágrafos 6º e 7º:

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código.

§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código.

A idade de 14 anos foi eleita pelo legislador para definir, segundo um critério biológico, a menoridade da vítima para fins de afastamento da incidência penal no art. 122. Assim como nos crimes contra a dignidade sexual, a lei despreza por completo o consentimento e a capacidade de resistência dos menores de 14 anos.

Exige-se que a conduta seja dirigida a uma ou a várias pessoas determinadas. Isso porque o induzimento genérico não é apto a ensejar o crime. Dessa forma, uma obra literária que aborde o suicídio não é capaz de incriminar o autor do livro nas penas do art. 122.

Não há modalidade culposa do crime. A ação penal é pública incondicionada.

A Lei nº 13.968/19 também alterou o **preceito secundário do tipo penal**, prevendo a sanção de 6 meses a 2 anos de reclusão para a figura do *caput*.

A maior modificação, nesse âmbito, foi a **não previsão de condicionamento da punição à existência de resultado naturalístico**. Anteriormente à Lei nº 13.968/19, havia a necessidade da produção do resultado lesão grave/gravíssima ou morte para a punição.

Atualmente, a ocorrência dos resultados naturalísticos lesão grave/gravíssima ou morte tornará o crime qualificado, isto é, com novos patamares mínimo e máximo de pena abstratamente cominados, conforme previsão dos parágrafos 1º e 2º do art. 122.

Ademais, as causas de aumento de pena foram ampliadas:

§ 3º A pena é duplicada:

I – se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil;

II – se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.

O texto legal passa a prever os motivos torpe e fútil. As outras hipóteses já constavam da redação anterior.

O motivo egoístico é aquele em relação ao qual somente o agente irá se beneficiar. Exemplo: instigar um concorrente à mesma vaga de emprego a se suicidar. As definições quanto à motivação torpe e fútil foram tratadas no estudo do crime de homicídio.

Quanto ao inc. II, utiliza-se como parâmetro a idade entre 14 e 18 anos incompletos quanto à vítima menor. A diminuição da capacidade de resistência pode ser verificada no acometimento por doenças psiquiátricas, a exemplo da depressão.

Os parágrafos 4º e 5º contemplam novas majorantes de pena:

§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.

§ 5º Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual.

Vale observar que a conduta praticada por meio da *internet* ou rede social deve se voltar a pessoas determinadas.

A criminalização busca atingir condutas extremamente danosas a adolescentes e crianças, em que se instiga ou induz ao suicídio e à automutilação por meio de desafios ou jogos macabros, veiculados em grupos ou redes virtuais.

Por fim, destacamos algumas práticas - felizmente em desuso - citadas pela doutrina e que podem tipificar a conduta descrita no art. 122 do CP.

No **duelo americano**, há duas pessoas e duas armas, e apenas uma delas está municiada. Combinam de tirar a sorte para escolher a arma e logo após disparar contra a própria cabeça. A pessoa que sobreviver ao duelo responderá pelo crime do art. 122.

Na **roleta russa** a situação é semelhante, pois há uma única munição na arma, que vai passando de mão em mão. Cada pessoa aperta o gatilho, até que chega o momento em que o projétil é disparado na cabeça da vítima. Os sobreviventes responderão pelo crime do art. 122.

No **ambicídio**, ou **pacto de morte**, duas pessoas combinam de tirar a vida conjuntamente. Caso não dê certo e um deles sobreviva, responderá por induzimento ao suicídio. É importante notar que, se apenas um deles praticar o ato executório que levará à morte (acionamento de uma torneira de gás, por exemplo), e sobreviver, responderá pelo homicídio.

3. ART. 123. INFANTICÍDIO

O infanticídio consiste na conduta de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. O preceito secundário traz pena de detenção, de dois a seis anos.

O infanticídio é, portanto, uma forma privilegiada de homicídio, vez que pune de forma mais branda a mãe que, fragilizada pelo puerpério, mata o próprio filho.

Trata-se de crime bипróprio, vez que somente pode ser praticado pela genitora, em desfavor do filho. Admite coautoria e participação (art. 30 do CP). Pode ocorrer por omissão (deixar de amamentar, por exemplo), já que a mãe tem o dever legal de agir para impedir o resultado (art. 13, § 2º, *a*, do CP). É também crime material, de dano, plurissubsistente, instantâneo e doloso.

Pode ser praticado durante o parto ou logo após. Antes do início do trabalho de parto, o crime é de aborto. A expressão “logo após”, como elemento normativo do tipo, será avaliada em cada caso concreto.

O parto tem início com a dilatação do colo do útero, seguida das contrações expulsórias, no caso do parto natural, e com a incisão feita pelo cirurgião, nos partos cesáreos.

O estado puerperal é definido como o conjunto de alterações físicas e psíquicas em decorrência das circunstâncias relacionadas ao parto. Não é necessária perícia médica para constatação do estado puerperal, por ser um efeito normal e inerente ao parto, segundo posição que prevalece.

Não se confunde o estado puerperal com imputabilidade ou semi-imputabilidade, nada obstante o estado puerperal altere a saúde mental da mulher.²⁹

O crime somente pode ser praticado na forma dolosa (dolo direto ou eventual), diante da inexistência de previsão quanto à modalidade culposa. Também não se mostra possível a punição a título de homicídio culposo, conforme doutrina majoritária.³⁰ Para a tipificação da conduta não se exige especial fim de agir (elemento subjetivo especial do tipo), bastando a influência do estado puerperal.

Se a mãe, sob influência do estado puerperal, mata outra criança, acreditando se tratar de seu filho, responderá pelo infanticídio, nos moldes do art. 20, § 3º, do CP (erro quanto à pessoa).

4. ARTS. 124 A 128. ABORTO

²⁹Nesse sentido, considerando que o legislador considerou a mulher imputável para fins de aplicação do art. 123, confira-se Masson, Cleber. Direito Penal. Parte Especial. Vol. 2. 10 ed. São Paulo: Gen Método, 2017, p. 79. Em sentido diverso, considerando que a hipótese é de semi-imputabilidade, tratada pelo legislador como tipo especial, tem-se o entendimento de Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13ed. São Paulo: RT, 2013, p.665.

³⁰No sentido de que a conduta deverá ser punida como homicídio culposo, confira-se Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Vol. 2. 17 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 177.

O aborto consiste na interrupção da gravidez, com a morte do fruto da concepção. Considera-se o início da gravidez com a fecundação e, nos termos da legislação vigente, haverá aborto em qualquer fase da evolução fetal.

Com o início do trabalho de parto (natural ou por cirurgia) haverá homicídio ou infanticídio, a depender do sujeito ativo, e não aborto.

São duas as espécies de aborto:

Aborto criminoso: interrupção dolosa da gravidez. Tratado nos artigos 124 a 127 do CP.

Aborto legal ou permitido: feito de forma voluntária e com amparo legal, conforme previsão do art. 128 do CP.

O aborto ilícito ou criminoso está tipificado nos artigos 124 a 127 do CP.

No **art. 124 do CP** tem-se o aborto provocado pela própria gestante (autoaborto) ou com seu consentimento. São, portanto, duas condutas por meio das quais a própria gestante interrompe sua gravidez, provocando a morte do feto. Nessa modalidade, tem-se crime de mão própria, vez que somente a gestante poderá praticar. Admite-se a participação, em atividades acessórias, a exemplo do instigar, induzir ou auxiliar. Se o terceiro, porém, pratica atos executórios do aborto, responderá pela figura do art. 126 do CP, vez que se observa, na presente hipótese, uma exceção à teoria unitária ou monista quanto ao concurso de agentes (art. 29 do CP). O tipo do art. 124 não admite coautoria. Exemplo: casal de namorados que engravida e decide pelo aborto. O rapaz que leva a namorada à clínica clandestina, contrata e paga pelos serviços incide na figura do art. 126 do CP, ao passo que a mulher, consentindo com a prática abortiva, incorre no crime previsto no art. 124 do CP.

O **art. 125 do CP** contempla o aborto sem o consentimento da gestante, apenado de forma mais grave, com reclusão de três a dez anos. Conforme anteriormente explicado, se houver consentimento, a figura será a do art. 124 do CP.

Para a tipificação da conduta, não é preciso o emprego de violência, grave ameaça ou fraude. É suficiente que a gestante desconheça que nela está sendo praticado o aborto.

Por sua vez, no **art. 126 do CP** pune-se a conduta do terceiro que provoca aborto com o consentimento da gestante. Consoante exposto acima, trata-se de exceção à teoria monista quanto ao concurso de agentes, adotada como regra pelo Código Penal, já que o terceiro não será coautor do crime estabelecido no art. 124 do CP. Tem-se aqui a aplicação da **teoria pluralista ou da cumplicidade do delito distinto**. Importa destacar que o aborto consentido (art. 124, segunda figura) e o aborto consensual (art. 126) são crimes de concurso necessário, pois exigem a presença de duas pessoas, no mínimo.

O crime de aborto, em todas as suas formas, somente é praticado a título doloso. Não há previsão de aborto culposo, restando, nesse caso, eventual reparação de danos na esfera cível.

O dolo pode ser direto ou eventual. O indivíduo que mata uma mulher, sabendo da gravidez, responde, em concurso formal, pelos crimes de homicídio e aborto, já que, quanto à morte do feto, verificou-se, no mínimo, o dolo eventual. Por outro lado, se o agente tinha a intenção de lesionar a mulher, cuja gravidez era nítida, e sobrevém o aborto, o crime será de lesão corporal gravíssima, nos termos do art. 129, § 2º, inc. V, do CP.

O crime é material, exigindo-se a morte do feto ou embrião para a consumação do delito. Será possível, assim, a tentativa, desde que, utilizados meios idôneos e eficazes, a morte do feto não sobrevenha por circunstâncias alheias à vontade do agente. A hipótese é de crime impossível (art. 17 do CP) quando se realiza manobra abortiva e o feto já estava morto.

A ação penal, assim como em todos os demais crimes contra a vida, é pública incondicionada.

Art. 127. Figuras majoradas do aborto

O dispositivo prevê que as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, sobrevém a morte.

Nota-se, assim, impropriedade técnica do legislador, ao utilizar a epígrafe “formas qualificadas.” O dispositivo traz, em verdade, **causas de aumento de pena**, que incidem na terceira fase da dosimetria.

Art. 128. Aborto legal ou permitido

Apesar do legislador ter usado a expressão “Não se pune o aborto praticado por médico”, em verdade o CP arrola causas especiais de exclusão da ilicitude. Assim, tecnicamente, seria mais adequado o emprego da expressão “não há crime”.

São duas as hipóteses:

a) Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado aborto necessário ou terapêutico, previsto no inciso I.

b) No caso de gravidez resultante de estupro. Trata-se do aborto humanitário, sentimental, ético ou piedoso, elencado no inciso II. Não há limitação temporal para a realização do aborto nesse caso. A prova da ocorrência do estupro, bem como o consentimento da gestante, devem ser cabais.

Além das hipóteses legalmente previstas de aborto permitido, há que se destacar a exceção criada pela jurisprudência do STF, no julgamento da ADPF 54/DF.

Conforme decidiu a Suprema Corte, a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta atípica. Assim, por força de interpretação jurisprudencial, realizar aborto de feto com anencefalia não é crime. Uma vez confirmado o diagnóstico, bem como a irreversibilidade da situação, não é necessária a prévia autorização judicial para a interrupção voluntária da gravidez. Note-se que a decisão tomada na ADPF 54/DF restringe-se aos casos de anencefalia. É certo que existem outras doenças e síndromes graves, incapacitantes da sobrevivência fora do útero materno. Todavia, para esses outros casos, mostra-se necessária a prévia autorização judicial para a interrupção da gravidez.

Ainda, convém destacar a decisão da 1ª Turma do STF no julgamento do HC 124306/RJ, relator originário Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 29/11/2016 (Info 849), no qual se decidiu, como questão subjacente ao pedido de liberdade de dois médicos presos em flagrante pela realização de aborto com consentimento da gestante, que não haveria crime quando a interrupção voluntária da gravidez ocorresse no primeiro trimestre de gestação.

O critério dos três primeiros meses de gravidez, utilizado pelo STF no caso concreto citado, encontra respaldo em estudos médico-científicos, no sentido de que, nessa fase inicial da gestação, o córtex cerebral, responsável pelo desenvolvimento de sentimentos e racionalidade, ainda não foi formado, nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno. Assim, não há qualquer possibilidade do embrião subsistir fora do corpo da mãe antes de completado o primeiro trimestre de sua formação. Com base nessas premissas científicas, diversos países adotaram o entendimento de que a interrupção voluntária da gestação não deve ser criminalizada, desde que feita no primeiro trimestre da gestação. É o caso da Alemanha, Bélgica, França e Uruguai.

Por certo que se trata de assunto polêmico, que envolve posicionamentos de cunho religioso, moral e filosófico acerca do marco inicial da vida e da possibilidade de sua interrupção.

Importa considerar que a decisão em comento não tem efeito *erga omnes*, já que tomada em análise de *habeas corpus*, pela 1ª Turma do STF. Portanto, não se mostra correto afirmar, de modo peremptório, que o aborto feito com o consentimento da gestante no primeiro trimestre de gestação foi descriminalizado pelo STF.

A discussão sobre a criminalização ou não do aborto nos três primeiros meses da gestação foi feita com o escopo de se analisar se seria cabível a manutenção da prisão preventiva dos médicos. O STF não determinou o trancamento da ação penal. O *habeas corpus* foi concedido apenas para que fosse afastada a prisão preventiva dos acusados.³¹

³¹ Fonte: Dizer o Direito. <https://www.dizerodireito.com.br/2016/12/a-interruptao-da-gravidez-no-primeiro.html>



QUESTÕES

1- (CEBRASPE – DPE RN- 2015) Dalva, em período gestacional, foi informada de que seu bebê sofria de anencefalia, diagnóstico confirmado por laudos médicos. Após ter certeza da irreversibilidade da situação, Dalva, mesmo sem estar correndo risco de morte, pediu aos médicos que interrompessem sua gravidez, o que foi feito logo em seguida. Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência do STF, a interrupção da gravidez

- a) deve ser interpretada como conduta atípica e, portanto, não criminosa.
- b) deveria ter sido autorizada pela justiça para não configurar crime.
- c) é isenta de punição por ter ocorrido em situação de aborto necessário.
- d) configurou crime de aborto praticado por Dalva.
- e) configurou crime de aborto praticado pelos médicos com consentimento da gestante.

Gabarito: A, conforme decisão tomada na ADPF 54/DF.



CAPÍTULO 25 — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA: DAS LESÕES CORPORAIS

1. ART. 129. LESÃO CORPORAL

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A lei criminaliza a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. A tutela penal abrange qualquer dano do ponto de vista anatômico, fisiológico ou psíquico, praticado sem intenção de matar (*animus necandi*).

As lesões podem ser dolosas (*animus laedendi*) ou culposas.

Para a tipificação da conduta, é necessária a produção de dano no corpo da vítima, interno ou externo, abrangendo também as alterações psíquicas.

A dor, por si só, não caracteriza lesão corporal, assim como o eritema (vermelhidão, decorrente da vasodilatação dos capilares sanguíneos, após um tapa ou bofetada) também não caracteriza o crime.

A autolesão **não é punida** (princípio da alteridade), a menos que viole outro bem jurídico tutelado, a exemplo do que ocorre na fraude para recebimento de seguro, tipificada no art. 171, § 2º, V, CP, em que o agente lesa a própria integridade física ou saúde com o fim de obter o valor de seguro ou indenização.

As lesões corporais de natureza leve e as culposas (art. 129, *caput*, e § 6º do CP) são crimes de ação penal pública condicionada à representação (art. 88 da Lei nº 9.099/95). Tem-se, assim, o prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados do conhecimento da autoria delitiva, para se promover a representação, que é uma condição de procedibilidade da ação penal. As demais espécies de lesão corporal são processadas mediante ação penal pública incondicionada.

A tentativa é possível nas lesões dolosas, especialmente se o crime for plurissubsistente. Incabível o *conatus* na lesão culposa e na lesão seguida de morte (crime preterdoloso).

Importa diferenciar a tentativa de lesão corporal da contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP). A diferença reside no dolo. Na contravenção, o dolo é de agredir, sem lesionar, a exemplo do empurrão. As vias de fato não atingem a integridade física da vítima.

As lesões corporais dolosas, praticadas com *animus laedendi ou nocendi*, podem ser:

- Leves (art. 129, *caput*). Infração de menor potencial ofensivo. Submetida à ação penal pública condicionada à representação.

- Graves (art. 129, § 1º)

- Gravíssimas (art. 129, § 2º)

- Seguidas de morte (art. 129, § 3º). Crime preterdoloso.

- Em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §§ 9º e 10). Não necessariamente contra a mulher; a vítima também poderá ser homem.

Os parágrafos 11 e 12 do art. 129 estabelecem majorantes (causas de aumento de pena), incidentes na terceira fase da dosimetria, para as hipóteses de lesões corporais praticadas nas condições do § 9º contra pessoa com deficiência (§ 10) e quando praticadas contra policiais ou integrantes dos órgãos de segurança pública ou seus familiares, independentemente da natureza da lesão (§ 12), desde que no exercício da função ou em decorrência dela.

As lesões leves do art. 129, *caput*, são obtidas por exclusão. Se não se enquadrar nas hipóteses dos resultados previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 129 será considerada lesão leve.

A lesão corporal é crime bicomum, visto que qualquer pessoa pode figurar nos polos ativo e passivo; material, já que possui resultado naturalístico, necessário para a consumação; de dano; comissivo ou omissivo; instantâneo; de forma livre.

Há previsão legal de crime de lesão corporal de natureza hedionda. Trata-se da lesão corporal gravíssima ou seguida de morte contra integrantes de órgãos de segurança pública (art. 1º, inciso

I-A, da Lei nº 8.072/90). São os agentes dispostos nos artigos 142 e 144 da CF, componentes das Forças Armadas(Exército, Marinha, Aeronáutica), e demais órgãos incumbidos da segurança pública, tais como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícia Penal, e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Afasta-se, portanto, o parentesco por afinidade (sogros, cunhados), incluindo-se, por certo, o filho adotivo, já que a ordem constitucional e civil proíbe qualquer distinção entre os filhos.

Lesões corporais leves

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Conforme já ressaltado, a lesão será leve por exclusão (quando não se caracterizar uma forma mais grave).

A ação penal é pública condicionada à representação (prazo decadencial de 6 meses a partir do conhecimento da autoria), submetida ao rito da Lei nº 9.099/95, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

Nessa modalidade de lesão, admite-se o consentimento do ofendido como causa supralegal (ou extralegal) de exclusão da ilicitude. Dentro de certos limites, as pessoas podem dispor de sua integridade física em práticas do cotidiano que são socialmente adequadas e permitidas, tais como em esportes que envolvam contato físico intenso, lutas, tatuagens, brincos, *piercings* e outros adereços corporais. O consentimento deve ser expresso (oral ou escrito); livre (sem coação ou ameaça); respeitar os bons costumes (aquilo que é socialmente aceito); ser manifestado previamente à prática do ato; e deve se verificar a capacidade do ofendido em consentir (maior de idade e no uso e gozo das faculdades mentais).

O consentimento do ofendido não é admitido nos demais tipos de lesão (grave, gravíssima e seguida de morte)

Lesões corporais graves

§ 1º Se resulta:

I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto;

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

A lesão grave se caracteriza como infração de médio potencial ofensivo, autorizando a suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 89 da Lei nº 9.099/95, caso preenchidos os demais requisitos legais.

No inciso I temos exemplo de crime a prazo, o qual depende do implemento de uma condição futura para a correta tipificação. Somente se verifica a lesão de natureza grave após o transcurso do prazo de 30 dias, previsto em lei.

Nos termos do art. 168, § 2º, do CPP, há necessidade de um exame pericial inicial e outro complementar, decorrido o prazo de 30 dias, para fins de prova da materialidade do crime.

O termo *ocupações habituais* engloba qualquer atividade do cotidiano (caminhar, estudar, praticar esportes), e não necessariamente o trabalho. A ocupação não precisa ser lucrativa. A aferição é objetiva, com fundamento em laudo médico, não sendo suficiente a percepção subjetiva da vítima sobre a sua própria incapacidade.

Na hipótese do inciso II, o perigo de vida deve ser concreto, comprovado por laudo médico pericial, não bastando a mera impressão subjetiva do indivíduo ou do magistrado.

Quanto ao inciso III, debilidade é a diminuição da capacidade funcional, duradoura, de recuperação incerta. O membro, sentido ou função continua a existir, porém funcionalmente reduzido.



A jurisprudência do STJ já se manifestou quanto à perda de dentes. Poderá caracterizar lesão grave, a depender da comprovação pericial acerca da debilidade permanente da função mastigatória. Há necessidade, portanto, de laudo. Se a lesão se enquadrar apenas em questões estéticas, será, em tese, considerada leve. Não se cogita de lesão gravíssima, pois não há que se falar em deformidade permanente.³²

Na hipótese de órgãos duplos (rins, pulmões, olhos), a perda de um deles caracteriza lesão grave pela debilidade permanente de sentido ou função. A ausência de ambos configura lesão gravíssima pela perda ou inutilização.

Por fim, quanto ao inciso IV, aceleração de parto é sinônimo de parto prematuro, precoce, antes do termo normal definido pela medicina. É necessário que o agente saiba da gravidez da vítima. Na hipótese da criança nascer morta em razão das lesões sofridas pela mãe, o crime será de lesão corporal gravíssima, diante do aborto. E se a criança nasce com vida e falece horas ou dias após, como consequência das lesões na mãe? A doutrina não é unânime, havendo quem entenda se tratar de lesão corporal gravíssima, pelo aborto (posição majoritária) e aqueles que vislumbram, inclusive, ser hipótese de concurso de crimes, verificando-se a lesão corporal grave pela aceleração do parto, em relação à mãe, e homicídio em relação à criança, conforme já decidido pelo STJ.³³

Lesões gravíssimas

§ 2º Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incurável;

III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

³² A lesão corporal que provoca na vítima a perda de dois dentes tem natureza grave (art. 129, § 1º, III, do CP), e não gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP). STJ. 6ª Turma. REsp 1.620.158-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2016 (Info 590).

³³ "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. LESÃO CORPORAL GRAVE COM ADIANTAMENTO DE PARTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO. AGRESSÕES A GRÁVIDA COM MORTE DE NEONATO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- Esta Corte possui entendimento no sentido de que o trancamento de ação penal é medida excepcional que se mostra possível apenas nos casos em que se puder verificar, de plano, a total ausência de provas sobre autoria e materialidade, a atipicidade da conduta, ou diante da ocorrência de uma causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica nos autos.

- Não ocorre *bis in idem* na imputação de lesão corporal com adiantamento de parto e homicídio no caso em que o paciente, com intuito de matar seu filho, golpeia a barriga da mãe "justamente no lado esquerdo onde, segundo o exame de ultra-som realizado, era o local onde encontrava-se a cabeça do feto".

- Hipótese de concurso formal imperfeito, ou seja, aquele pelo qual se praticam, com desígnios autônomos, dois ou mais crimes mediante uma só ação ou omissão.

- Na ação descrita como praticada pelo paciente é possível se identificar o suposto dolo de matar, resultado possível tanto no delito de aborto, quanto no de homicídio - ambos crimes contra a vida.

- Devido ao fato de a criança ter nascido com vida - condição que, caso se mantivesse, resultaria no delito de tentativa de aborto - mas falecido em seguida em decorrência das agressões, deve-se adequar o tipo para o crime de homicídio consumado.

- Não se verifica falha patente na tipificação da conduta do paciente, apta a ensejar o trancamento da ação penal, de modo que a questão deve ser submetida ao veredicto do Tribunal do Júri.

Ordem não conhecida." HC 85.298/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 27/02/2014.



Note-se, inicialmente, que a denominação lesões gravíssimas não é feita pelo legislador. Todavia, já se encontra consagrada na doutrina e na jurisprudência, diante da necessidade de se diferenciar as figuras dos parágrafos 1º e 2º.

No inciso I, a incapacidade permanente, isto é, que se protraí no tempo, sem possibilidade de se fixar um termo final, relaciona-se ao exercício de atividade laborativa remunerada.

Quanto ao inciso II, a enfermidade incurável é aquela ainda não eficazmente combatida pela medicina à época do crime.

No que tange ao inciso III, diferencia-se da lesão grave por não mais se ter qualquer funcionalidade do membro, sentido ou função. O sentido ou função cessam e o membro ou órgão é completamente extraído, amputado.

No inciso IV, tem-se a lesão estética que provoca extremo desconforto. Vale pontuar que a qualificadora deformidade permanente **não é afastada por posterior cirurgia plástica reparadora que elimine ou minimize a alteração provocada na vítima**. Isso porque o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação, não o afetando providências posteriores, notadamente quando não usuais (pelo risco ou pelo custo, como cirurgia plástica ou de tratamentos prolongados, dolorosos ou geradores do risco de vida) e promovidas a critério exclusivo da vítima. (STJ. 6ª Turma. HC 306.677-RJ, Rel. Min. Ericson Maranhão [Desembargador convocado do TJ-SP], Rel. para acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/5/2015. Info 562).

Por fim, no inciso V, tem-se o aborto, isto é, a morte no útero materno do fruto da concepção. O crime é **preterdoloso** nesse caso, pois há dolo em relação às lesões corporais na mãe e culpa quanto ao aborto. Se a morte do feto for proposital, haverá concurso formal impróprio de crimes (lesão corporal e aborto). Por certo, a gravidez deve ser de conhecimento do agente. Caso a condição seja desconhecida, haverá erro de tipo, com o afastamento do dolo e da lesão qualificada.

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

A hipótese é de crime preterdoloso ou preterintencional, conforme explicitado pelo legislador ao exigir que o agente não tenha desejado o resultado morte, nem assumido o risco de produzi-lo. O delito, dado o seu caráter híbrido (dolo no antecedente e culpa no consequente), não admite a forma tentada.

Lesão corporal dolosa privilegiada

§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Tem-se aqui uma causa de diminuição de pena, aplicável apenas às lesões dolosas, sejam elas leves, graves, gravíssimas ou seguidas de morte. Sobre as caracterização do privilégio, remetemos o leitor às considerações feitas no estudo do homicídio privilegiado.

1.2. SUBSTITUIÇÃO DE PENA

O art. 129, § 5º, prevê a **lesão leve** privilegiada, com a substituição da pena privativa de liberdade por multa, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima ou, ainda, na hipótese de lesões recíprocas (duas pessoas injustamente se agridem, o que não se confunde com a legítima defesa).

Lesão corporal culposa



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



§ 6º Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano

A lesão corporal culposa é a ofensa à integridade física de outrem por negligência, imprudência ou imperícia (culpa como elemento normativo do tipo penal).

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo e de ação penal pública condicionada à representação. A homologação da composição civil dos danos acarreta renúncia ao direito de representação e consequente extinção da punibilidade.

A intensidade da lesão culposa é irrelevante para fins de tipificação, já que a conduta é culposa em si, independentemente do resultado produzido. A gravidade da lesão culposa poderá ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena, nas consequências do crime.

Vale lembrar que se a lesão culposa for praticada na direção de veículo automotor, por força do princípio da especialidade, aplica-se o art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

1.3. AUMENTO DE PENA (LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA)

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.

§ 8º - Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.

Assim como no homicídio culposo, a lesão corporal culposa será majorada de 1/3 (na terceira fase da dosimetria), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante e, ainda, na hipótese de crime praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

1.4. PERDÃO JUDICIAL

Nos termos do § 8º, admite-se o perdão judicial no caso de **lesão corporal culposa**, nas mesmas circunstâncias em que se admite o instituto no homicídio culposo. O STJ entende que, para aplicar o perdão judicial, é preciso uma das seguintes situações: vítima tenha relação de parentesco com o agente do crime; vítima tenha relação de afeto com o agente do crime; agente do crime tenha sofrido sequelas físicas.

Assim, não é toda e qualquer situação que envolva a prática de uma lesão culposa que vai ensejar o perdão judicial como causa extintiva da punibilidade e aplicação do princípio da bagatela imprópria. Se a lesão corporal for dolosa, não caberá perdão judicial.

1.5. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos

O § 9º somente se aplica às lesões leves. Se as lesões forem graves, gravíssimas ou seguidas de morte, incidirá a majorante de 1/3 prevista no § 10. Da mesma forma, haverá aumento de pena se o crime for cometido contra pessoa com deficiência (§ 11).

O sujeito passivo pode ser homem (pai, filho, esposo, companheiro, irmão)

Busca-se tutelar de modo mais eficaz o convívio pacífico na unidade doméstica.

No caso de lesões leves, a ação continua sendo condicionada à representação se o sujeito passivo for homem. Se mulher, por força da Súmula 542 do STJ, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica é pública incondicionada.



CAPÍTULO 26 — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA: DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE

Neste capítulo serão tratados os crimes de perigo, que prescindem da efetiva ocorrência do dano. É suficiente para a consumação a exposição do bem jurídico a uma probabilidade de dano. Os crimes de perigo podem ser subdivididos em:

- Crime de perigo concreto: é indispensável que se comprove a situação de perigo na hipótese fática. Ex.: crime de perigo de vida (art. 132 do CP).

- Crime de perigo abstrato (presumido, *juris et de jure*): é desnecessário que se comprove a situação de perigo. Há presunção absoluta de que determinadas condutas acarretam perigo a bens jurídicos. Ex.: art. 130 do CP (perigo de contágio venéreo).

1. ART. 130. PERIGO DE CONTÁGIO VENÉREO

Segundo o art. 130, é crime expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a **contágio de moléstia venérea**, de que sabe ou deve saber que está contaminado. A pena é de detenção, de 3 meses a 1 ano, **ou** multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cabendo transação penal e suspensão condicional do processo (institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/90).

O dispositivo sofre críticas, já que o avanço da medicina e as facilidades atuais de cura, por meio de antibióticos, tornam despicinda a criminalização autônoma do perigo de transmissão de doença.

O bem jurídico tutelado é a incolumidade física e a saúde da pessoa. O sujeito ativo pode ser qualquer um, homem ou mulher, desde que esteja contaminado com moléstia venérea.

É necessário o efetivo contato físico entre autor e vítima. Não é um crime de forma livre, sendo imprescindível a existência de relações sexuais ou ato libidinoso capaz de transmitir a doença venérea. Não haverá o delito se o perigo de contágio for oriundo de qualquer outro tipo de ação, como a ingestão de alimentos, amamentação ou uso de utensílios domésticos.

Tem-se, ainda, uma norma penal em branco, já que é preciso completar o preceito primário quanto às moléstias venéreas. Com efeito, são as doenças assim definidas pelo Ministério da Saúde, como a sífilis e a gonorreia. Vale pontuar que a AIDS não se adequa ao conceito, pois não se transmite apenas pelo contato sexual. Nesse caso, o crime será de tentativa de lesão corporal de natureza gravíssima, por se tratar de uma enfermidade incurável ou, para outros, seria hipótese de homicídio tentado.

Se o indivíduo sabe que está contaminado, o dolo é direto. Se o indivíduo deveria saber, tem-se dolo eventual (entendimento majoritário da doutrina). Supondo que uma pessoa saiba que o parceiro tem a moléstia venérea e, ainda assim, consinta que o agente pratique o ato sexual sem o uso de preservativo, o crime ocorrerá da mesma forma, pois se trata de um bem indisponível (integridade física, saúde). Portanto, o consentimento é ineficaz para ilidir a prática delitiva.

Se é intenção do agente transmitir a moléstia e não apenas expor a vítima ao perigo de contágio, o dolo não é mais de perigo, e sim dolo de dano, já que o sujeito pretende alcançar o resultado, caracterizando-se a forma qualificada do §1º, cuja pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. O delito passa a ser de médio potencial ofensivo, admitindo a suspensão condicional do processo (ou *sursis* processual), nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

A ação penal é pública condicionada à representação (§2º). O intuito é proteger a intimidade, a vida privada da vítima, a fim de não expor o risco que correu. Assim, evita-se o *strepitus judicii*, isto é, o constrangimento, o vexame provocado pelo processo.

Se o agente quer efetivamente transmitir a doença e consegue contaminar a vítima, produzindo o resultado danoso à saúde, estaremos diante de uma lesão corporal, podendo ser de natureza grave, gravíssima ou até mesmo seguida de morte.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, não é preciso comprovar que a pessoa foi submetida a uma situação de risco, bastando que se comprove a prática do ato sexual, ainda que a vítima



não tenha sido contaminada. Trata-se de crime formal, que prescinde do resultado naturalístico para a consumação.

Há uma presunção do perigo, mas se ficar demonstrado que, por meio do ato sexual, a vítima não foi posta em perigo em momento algum, pois era impossível o seu contágio, não haverá o crime, a conduta será atípica. **Exemplo:** o agente usou preservativo. Nesse caso, o sujeito não agiu com dolo direto e nem com dolo eventual.

2. ART. 131. PERIGO DE CONTÁGIO DE MOLÉSTIA GRAVE

Segundo o art. 131, é crime a conduta de praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. A pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95).

O tipo exige especial fim de agir. É o elemento subjetivo especial do tipo, a tendência interna transcendente, extraída da expressão com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado.

Não é necessário que o ato seja sexual, podendo ser qualquer meio apto a produzir o contágio.

O bem jurídico tutelado é incolumidade física e a saúde.

O sujeito ativo do crime é pessoa contaminada pela moléstia.

O sujeito passivo poderá ser qualquer pessoa que não tenha a doença, pois, do contrário, haverá crime impossível. Exemplos de moléstia grave: febre amarela, tuberculose, poliomielite.

O crime é punido a título de dolo. Há um dolo direto de dano, com o especial fim de agir de transmitir a doença. Não se admite o dolo eventual, diante da exigência do dolo específico.

A consumação se dá com a prática do ato perigoso, ainda que não ocorra a transmissão da moléstia grave. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada. Os crimes em que há a tendência interna transcendente (especial fim de agir) são crimes formais.

Se o contágio ocorrer e resultar lesão corporal leve, esta ficará absorvida pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave (delito mais grave).

Por outro lado, se ocorrer uma lesão corporal gravíssima, ou se resultar em morte, o sujeito responderá pela lesão corporal de natureza gravíssima ou pela lesão corporal seguida de morte (homicídio preterdoloso), eis que haverá a consunção (o crime de perigo será absorvido pelo crime de dano).

A tentativa é possível, se houver uma conduta plurissubsistente (*iter criminis* pode ser fracionado).

O art. 131 não traz nenhuma disposição em sentido contrário, motivo pelo qual a ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 132. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM

Segundo o art. 132, é crime a conduta de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente (prestes a ocorrer). Trata-se de um crime de perigo concreto. Busca-se proteger a vida e a saúde humana contra determinadas situações especiais, procurando prevenir, por exemplo, acidentes de trabalho, já que muitos empregadores agem com omissão, descaso, expondo operários a grave risco, para redução de custos com técnicas ou materiais.

A pena é de detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Assim, a hipótese é de infração de menor potencial ofensivo e expressamente subsidiária (residualidade). O art. 132 só será utilizado como *soldado de reserva*, caso não se verifique o dolo de praticar uma conduta mais grave. Se o indivíduo tem a intenção de lesionar ou matar pessoa específica, não incidirá no crime do art. 132 do CP. Responderá pela lesão corporal ou homicídio.

O parágrafo único estabelece que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em



estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. A ideia é proteger, em especial, os trabalhadores rurais, conhecidos como boias-frias, muitas vezes levados às lavouras em veículos improvisados, sem qualquer segurança.

Qualquer pessoa poderá praticar a figura típica, sendo crime comum. Já o polo passivo deve se formar por pessoa ou pessoas determinadas. Se a infração coloca em risco um número indeterminado de indivíduos, o sujeito ativo responde por crime de perigo comum (art. 250 e seguintes do CP).

O crime deve ser doloso (dolo direto ou eventual). O dolo é de perigo e não de dano. O sujeito quer ou assume o risco de expor a vida ou a saúde de outrem a uma situação de perigo concreto. Se a intenção é de provocar um mal, o crime será de lesão corporal ou homicídio.

A consumação se dá quando há o efetivo risco. Se da conduta perigosa sobrevier a morte da vítima, o agente responderá pelo homicídio culposo.

A tentativa é admissível quando o crime for comissivo, embora de difícil configuração prática.

É indiferente eventual consentimento da vítima, por se tratar de proteção a bens jurídicos indisponíveis.

Diante da inexistência de qualquer ressalva no texto legal, a ação é pública incondicionada.

4. ART. 133. ABANDONO DE INCAPAZ

Conforme o art. 133, é crime a conduta de abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena é de detenção, de 6 meses a 3 anos. É uma infração de médio potencial ofensivo, cabendo suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95). Permite também o ANPP (art. 28-A do CPP).

O crime é próprio, pois o sujeito ativo deve ter a vítima sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Não necessariamente o sujeito passivo será um menor, podendo ser um idoso, pessoa com deficiência, alcoólatra doentio, um enfermo, uma pessoa com transtornos psiquiátricos ou com uma incapacidade transitória. Não se cuida somente de incapacidade civil, mas sim de natureza real.

Abandonar significa deixar ao desamparo. É indiferente se o abandono é temporário ou definitivo. O agente viola um dever de assistência que lhe incumbe.

O §1º estabelece que, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão, de 1 a 5 anos. Ainda caberá suspensão condicional do processo.

Todavia, resultando em morte o abandono de incapaz, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos.

Em qualquer uma dessas qualificadoras, haverá um crime preterdoloso, isto é, dolo quanto ao abandono, culpa quanto ao consequente, visto que o agente não tinha a intenção de causar a morte ou a lesão grave.

O §3º prevê que as penas serão aumentadas de 1/3:

- Se o abandono ocorre em lugar ermo;
- Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima;
- Se a vítima é maior de 60 anos ;

O rol é taxativo, não se admitindo a analogia *in malam partem*.

O crime exige um dolo de perigo, ou seja, a vontade e consciência de expor a vítima a perigo por meio do abandono. Não há exigência de especial fim de agir.

O dolo de dano altera a natureza da infração penal, pois se o sujeito abandonar a criança para que ela morra, o dolo será de matar, e a hipótese passa a ser de homicídio ou infanticídio.

Não há previsão legal da forma culposa.

A consumação se dá no exato momento do abandono efetivo, colocando o incapaz em uma situação de risco concreto, real, ainda que momentâneo.



Caso tenha sido praticado mediante ação, admite-se a tentativa do crime. Na forma omissiva não há que se falar em *conatus*.

A ação penal é pública incondicionada.

Por fim, importa ressaltar a existência de dispositivos específicos, na legislação extravagante, no caso do abandono de idosos (art. 98 da Lei nº 10.741/03) e pessoa com deficiência (art. 90 da Lei nº 13.146/15) em hospitais, casas de saúde, entidades de acolhimento ou similares.

5. ART. 134. EXPOSIÇÃO OU ABANDONO DE RECÉM-NASCIDO

Segundo o art. 134, é crime a conduta de expor ou abandonar **recém-nascido**, para ocultar desonra própria. A pena será de detenção, de 6 meses a 2 anos.

Observa-se nesta figura uma forma privilegiada de abandono de incapaz. Há um especial fim de agir, pois o sujeito age para ocultar desonra própria.

O bem jurídico protegido é a incolumidade física e a saúde do recém-nascido.

O termo *desonra* está relacionado a questões sexuais, considerando a época de elaboração do Código Penal. Trata-se de gravidez mantida em segredo, indesejada, advinda de estupro, incesto, relação extraconjugal, etc.

Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, em razão da pena cominada em abstrato. A consumação se dá com o abandono efetivo, que cria risco concreto, ainda que momentâneo.

Se do abandono do recém-nascido resulta lesão corporal de natureza grave, a pena passa a ser de detenção, de 1 a 3 anos. Se ocorre a morte, por conta do abandono, a pena será de detenção de 2 a 6 anos. Em qualquer um desses casos, o crime será preterdoloso (dolo quanto ao abandono, culpa quanto ao resultado lesão grave ou morte).

O crime é próprio ou especial. Cezar Roberto Bitencourt sustenta que somente a mãe poderá ser o sujeito ativo do crime.³⁴ No entanto, majoritariamente, entende-se que não só a mãe, mas também o pai poderá ser sujeito ativo do crime em apreço, pois ambos podem abandonar o recém-nascido para ocultar desonra própria. **Exemplo:** sujeito casado que abandona o recém-nascido para que não se descubra a gravidez da amante.

O sujeito passivo é o recém-nascido, compreendido como o indivíduo com poucos dias de vida, até a queda do cordão umbilical.

O crime é doloso, exigindo-se o elemento subjetivo específico do tipo, ou seja, o fim de ocultar desonra própria. Se o marido abandona o recém-nascido adulterino de sua esposa (filho resultante do adultério da mulher), não pratica o crime do art. 134, pois não age para ocultar desonra própria, mas sim para ocultar desonra alheia. Ou seja, o indivíduo comete o crime mais grave do art. 133 (abandono de incapaz).

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 135. OMISSÃO DE SOCORRO

Nos termos do art. 135, é crime deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.

A pena é de detenção, de 1 a 6 meses, **ou** multa. É uma infração de menor potencial ofensivo. Admitida a transação penal, fica inviabilizado o ANPP (art. 28-A do CPP).

Trata-se de crime omissivo puro ou próprio, pois o tipo penal já descreve a abstenção penalmente relevante (*deixar de prestar ou não pedir*). Como crime omissivo próprio, é também de mera

³⁴Bitencourt, Cezar Roberto. *Tratado de Direito Penal. Parte Especial*. Vol. 2. 17 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 304.



conduta, ao qual não se atribui resultado algum, bem como é incompatível com a tentativa, por ser unissubsistente, que não admite fracionamento do *iter criminis*.

Protege-se a vida e a saúde do ser humano. O fundamento para a tipificação da conduta reside no dever de solidariedade social, um princípio moral erigido à condição de dever jurídico. Esse é um dever imposto a todos, e não um dever jurídico específico. Portanto, qualquer um poderá incidir na omissão de socorro (crime comum). Diante de uma situação em que várias pessoas podem ajudar alguém, mas elas omitem o socorro, cada uma pratica o crime, não se falando em coautoria. Se uma pessoa ajudar a vítima, nenhuma das outras cometerá o crime, pois a assistência de uma desobriga as demais (entendimento majoritário).

O sujeito passivo será criança abandonada ou extraviada (idade inferior a 12 anos), o inválido ou ferido desamparado, ou aquele que se achar em grave e iminente perigo. O rol é taxativo.

Não há crime quando se deixa de prestar assistência a uma pessoa nitidamente morta.

O parágrafo único estabelece que a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave/gravíssima e será triplicada se resultar a morte. Ainda que tenha resultado morte, a infração continuará sendo de menor potencial ofensivo, mas a pena é majorada.

Se a morte do periclitante for inevitável, responderá o agente pela omissão do comportamento devido, na forma majorada, apesar de este não ter a capacidade de evitar o resultado danoso?

Não responderá, na medida em que a atuação do omitente não evitaria o resultado. Exige-se para a incidência da majorante que se prove no caso concreto que a conduta omitida seria capaz de impedir o resultado mais gravoso. Exemplo: se a morte da vítima se deu por lesões no cérebro, cuja assistência prestada jamais impediria a superveniência do evento letal, não há como atribuir esse resultado ao agente.

A omissão deverá ser dolosa, não havendo previsão de conduta culposa.

Convém ressaltar que no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) a omissão de socorro poderá caracterizar majorante do crime ou até mesmo delito autônomo.

Há também previsão específica quanto à omissão de socorro ao idoso, nos moldes do art. 97 da Lei nº 10.741/03.

A ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 135-A. CONDICIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL

Este tipo penal busca combater condutas abusivas em hospitais particulares. Segundo a doutrina, trata-se de uma espécie *sui generis* de omissão de socorro condicionada.

Segundo o art. 135-A, é crime a conduta de exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial. A pena é de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

A previsão é alvo de críticas, considerando o caráter fragmentário, subsidiário, do Direito Penal. Muitos doutrinadores entendem que tais situações já são solucionadas no juízo cível, diante das previsões constantes no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Somente poderá ser sujeito ativo do crime os administradores, gestores, gerentes ou encarregados de departamento de hospital particular, os quais possuem poder de decisão. Servidor de hospital público não pode exigir garantia, pois, nesse caso, a hipótese será de concussão (art. 316 do CP).

Prevalece o entendimento no sentido de que a conduta se tipifica com a exigência da garantia ou do preenchimento dos formulários, não havendo necessidade da dupla obrigação para o enquadramento legal. Ambas as situações representam entrave e procrastinação no atendimento emergencial.

O tipo contempla a situação emergencial, que não se confunde com a urgência, que se revela de menor gravidade e imediatidade do que a emergência. Pelo princípio da legalidade estrita, se a



indevida exigência ocorrer em hipótese de urgência, pode-se cogitar da incidência no art. 135 do CP (omissão de socorro).³⁵

O crime é praticado de forma dolosa, ficando afastada eventual adequação típica de condutas negligentes.

A consumação ocorre com a exigência indevida, condicionando o atendimento emergencial à prestação de uma garantia ou ao preenchimento de um formulário. É crime de perigo concreto, devendo ser provada a situação emergencial e que ela não foi atendida.

A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave/gravíssima e até o triplo se resulta a morte da vítima.

Diante da ausência de dispositivo legal em sentido contrário, a ação penal é pública incondicionada.

8. ART. 136. MAUS-TRATOS

Nos termos do art. 136, configura o crime de maus-tratos a conduta de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.

A pena será de detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e a transação penal, eis que se trata de infração de menor potencial ofensivo.

O crime é próprio, pois somente pode ser cometido por aquele que tenha autoridade, guarda ou vigilância em relação à vítima, por uma relação de direito público ou privado. A babá ou o empregado doméstico podem ser sujeitos ativos do crime, por serem contratados para cuidar de pessoa incapaz de fazê-lo por si própria.

Há discussão doutrinária sobre a possibilidade de prática do crime em face do enteado. Prevalece a corrente que, considerando a legalidade estrita, não admite a figura típica nessa hipótese, pois o agente não tem poder correicional ou familiar sobre o enteado.

Tem-se um tipo de ação múltipla ou conteúdo variado, já que o verbo expor está associado a três condutas possíveis: privar de alimentação ou cuidados indispensáveis, sujeitar a trabalho excessivo ou inadequado ou, ainda, abusar de meios de correção ou disciplina.

A consumação se dá no momento em que o agente cria o perigo real. Deve ser demonstrada a situação concreta para fins de tipificação.

No caso da privação de cuidados ou alimentos, é necessária a habitualidade, a reiteração do comportamento, por se entender que uma única conduta não gera perigo à incolumidade física.

Se não se verificar que houve a exposição a perigo real, ainda que seja vexatória a punição, não há que se falar em crime de maus-tratos. **Exemplo:** mãe que raspa os cabelos da filha não comete o crime de maus-tratos, pois não houve perigo à vida ou à saúde nesse caso.

Atente-se que os maus-tratos não se confundem com o crime de tortura, previsto no art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455/95. Isso porque, no caso da tortura, a vítima deverá ser submetida a **intenso** sofrimento físico ou mental. No crime de maus-tratos basta a exposição a situação de perigo à saúde ou à vida. A intenção do agente pode ser a disciplina, mas abusa desse poder.

Segundo o §1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão, de 1 a 4 anos. Se resulta a morte, a pena será de reclusão, de 4 a 12 anos. São hipóteses qualificadas do crime, preterdolosas, vez que haverá o dolo quanto aos maus-tratos, mas culpa quanto às lesões graves/gravíssimas ou a morte. As lesões leves são absorvidas pela figura básica.

Se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos, haverá o aumento de 1/3 da pena na terceira fase da dosimetria.

³⁵ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Parte Especial. Volume Único.** 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 172.

Os maus-tratos praticados contra maiores de 60 anos estão tipificados no art. 99 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 27 — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA: DA RIXA

1. ART. 137. RIXA

Configura o crime a conduta de participar de rixa, **salvo para separar os contendores**. A pena é de detenção, de 15 dias a 2 meses, **ou** multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal. Admitida a transação pena, resta inviabilizado o acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

Rixa é uma briga entre ao menos três pessoas, em que cada um age por sua própria conta, não havendo grupos determinados. É acompanhada de vias de fato ou violências físicas recíprocas. Pode haver emprego de armas ou não.

Segundo a doutrina, quando o CP não faz referência expressa ao número exato de pessoas para a tipificação da conduta, entende-se que a lei prevê a necessidade de, ao menos, três indivíduos. Tem-se, assim, um crime de concurso necessário, computando-se inimputáveis ou pessoas não identificadas para se alcançar o número mínimo de três rixosos.

Não há rixa quando ocorre apenas a altercação verbal, ofensas ou trocas de xingamentos. A rixa pressupõe o contato físico, agressões, vias de fato.

O bem jurídico tutelado é a incolumidade física ou mental da pessoa humana.

O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer indivíduo. O agente, na rixa, **será sujeito ativo e passivo simultaneamente, em virtude das agressões recíprocas**. Por isso, diz-se a rixa um crime de condutas contrapostas.

A participação na rixa pode ser material ou moral. No último caso, tem-se a conduta do indivíduo que incentiva, motiva ou instiga moralmente os demais a brigarem.

A participação poderá ocorrer desde o início da briga, normalmente não pré-ordenada, ou o sujeito poderá aderir à rixa ao longo de sua ocorrência.

É necessária uma conduta dolosa. Há, aqui, o dolo de perigo, que é a vontade consciente de tomar parte na briga.

O crime de rixa se consuma no momento em que tem início o conflito, **sendo um crime de perigo presumido ou abstrato**, não sendo necessário comprovar nenhum resultado naturalístico (dano, perigo concreto), isto é, que o efetivo risco à incolumidade física ou mental ocorreu.

Trata-se de um crime unissubsistente, motivo pelo qual prevalece o entendimento de que o crime de rixa **não admite tentativa**, quando se tratar da rixa subitânea ou de improviso, isto é, a que acontece instantaneamente, de inopino, sem prévio ajuste. Por exemplo, as que ocorrem em bares, festas, estádios de futebol. **A doutrina aponta ser possível a tentativa na rixa preordenada ou premeditada**, ou seja, quando há um prévio acordo entre os indivíduos.³⁶

Há legítima defesa na rixa? Via de regra, não se admite a excludente de ilicitude em caso de rixa, pois um dos requisitos da legítima defesa é a reação a uma agressão injusta. No caso da rixa, todos os envolvidos estão se agredindo injustamente. Não há agressor e agredido. Todos são agressores. Porém, a doutrina traz uma exceção, possibilitando a legítima defesa na rixa quando essa tiver um padrão, mas um dos rixosos o ultrapassa. **Exemplo:** a briga é de socos e chutes, mas um dos indivíduos pega uma arma de fogo. Logo após, sofre uma pedrada de um outro participante, que buscava se defender do disparo de arma. Haverá legítima defesa nesse caso.

1.1. QUALIFICADORA

Se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave/gravíssima, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. É a hipótese de **rixas qualificadas**, prevista no

³⁶ MASSON, Cleber. **Direito Penal. Parte Especial. Vol. 2.** 10. ed. São Paulo: Método, 2017, p. 189.



parágrafo único, que continuará sendo infração de menor potencial ofensivo, cabendo transação penal e suspensão condicional do processo.

Existem alguns sistemas que vão justificar a punição dos rixosos nesses casos:

Sistema da solidariedade absoluta: todos os participantes da rixa vão responder também pelo resultado lesão corporal grave/gravíssima ou homicídio, ainda que não tenham sido os provocadores diretos do resultado mais gravoso.

Sistema da cumplicidade corresponsiva: havendo morte ou lesão grave/gravíssima, e não sendo possível apurar quem foi o autor, todos responderão pelo resultado. No entanto, a pena será a média da sanção do autor e do partícipe. Nesse sistema, há uma pena atenuada para aqueles que participaram da rixa, mas não causaram o resultado agravador.

Sistema da autonomia: a rixa é punida por si mesma, independentemente do resultado agravador. Caso tenha ocorrido, haverá qualificação do delito. Pelo resultado agravador, só responderá aquele que o praticou. **Exemplo:** João, José, Carlos e Antônio participaram de uma rixa. Antônio morreu. Os outros 3 respondem por rixa qualificada. Mas se João foi quem matou Antônio, responderá por rixa qualificada e pelo homicídio.

Há uma autonomia em relação aos crimes, de sorte que somente o indivíduo que provocar o resultado morte responderá em concurso pela rixa qualificada e homicídio. **Esse é o sistema adotado pelo CP.**

Parcela da doutrina identifica na rixa qualificada um resquício de responsabilidade penal objetiva em nosso ordenamento, pois todos os contendores, inclusive o que restou lesionado, responderão pelo crime agravado, ainda que não se identifique o real autor da lesão grave ou morte.

Se houver vários homicídios ou indivíduos lesionados, a rixa qualificada será uma só. A quantidade de mortes poderá ser valorada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria.

Caso o agente tenha participado da rixa, mas deixou o local antes da ocorrência do resultado morte, ou seja, **se a morte ocorreu posteriormente à saída desse indivíduo, responderá pela rixa qualificada.** Isso porque a participação anterior deu condições para que o evento morte ou lesão corporal grave viesse a ocorrer.

Por outro lado, se o indivíduo ingressa na rixa após a morte, não responderá pela forma qualificada, eis que não contribuiu para que o desfecho tivesse ocorrido.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 28 — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA: DOS CRIMES CONTRA A HONRA

São três os delitos tratados neste capítulo: calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140). Importa recordar que há previsão de crimes contra a honra em leis especiais, a exemplo do Código Penal Militar, Lei de Segurança Nacional e Código Eleitoral. Assim sendo, o Código Penal tem natureza subsidiária por ser lei geral. Prevalece o princípio da especialidade.

A honra é direito fundamental, consagrado pelo texto constitucional, no art. 5º, inc. X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

A doutrina conceitua a honra como o conjunto de qualidades físicas, morais e intelectuais de um ser humano, que o fazem merecedor de respeito no meio social e promovem sua autoestima. A ofensa à honra produz dor psíquica, abalo moral.

1. CLASSIFICAÇÃO DA HONRA

Honra objetiva: visão que a sociedade tem acerca das qualidades físicas, morais e intelectuais de determinada pessoa. Reputação social. Julgamento que as pessoas fazem de alguém.

Honra subjetiva: sentimento pessoal acerca das próprias qualidades físicas, morais e intelectuais. Juízo individual (autoestima). Divide-se em honra-dignidade (qualidades morais) e honra-decoro (qualidades físicas e intelectuais).

Honra comum: refere-se à pessoa, independentemente das suas atividades. **Exemplo:** chamar alguém de idiota, gordo, safado, ofende a honra comum.

Honra especial: também chamada de honra profissional, relaciona-se às atividades exercidas pela vítima. **Exemplo:** chamar um motorista de barbeiro, ou um médico de carniceiro, ofende a honra especial.

2. ART. 138. CALÚNIA

Descreve o art. 138: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.” A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos e multa.

O crime de calúnia ataca a **honra objetiva** (conceito que a sociedade tem sobre o indivíduo). Consiste na atribuição a alguém **de fato** definido em lei como **crime**, sabendo da inocência da pessoa. A imputação falsa é elementar do tipo penal.

A imputação deve ser de um fato específico, verossímil e determinado. Não basta chamar de ladrão ou esturpador. Deve-se ter a narrativa completa do falso fato criminoso (data, local, modo de execução). **Se a imputação é verdadeira, o fato é atípico, pois o tipo penal não busca proteger a honra de criminosos.**

Por ofender a honra objetiva, a consumação da calúnia ocorre quando a imputação falsa chega ao conhecimento de terceira pessoa (basta uma), mesmo que antes da própria vítima do crime. O crime é formal, consumando-se independentemente do dano à reputação.

A imputação deve ser de **crime**. Não abrange contravenção penal, considerando o princípio da legalidade estrita. Quando a imputação falsa for de contravenção, haverá difamação (art. 139 do CP).

A calúnia também é chamada de difamação qualificada.

A falsidade da imputação pode recair sobre o fato (que não ocorreu) ou a autoria criminosa (vítima da calúnia não praticou o crime).

A calúnia verbal não admite tentativa. Já na forma escrita, é possível o *conatus* (carta extraviada, por exemplo).

Importa distinguir a calúnia da denúncia caluniosa (art. 339 do CP): no caso da denúncia caluniosa, o agente, além de imputar falsamente o crime a alguém, **leva essa informação ao**



conhecimento de autoridade pública, movimentando o aparato estatal de persecução. Quanto à ação penal, em regra, quanto à calúnia, é privada. Já na denúncia caluniosa, por se tratar de crime contra a administração da justiça, a ação penal é pública incondicionada, uma vez que este crime possui gravidade substancialmente maior.

No art. 138, § 1º, verifica-se a conduta equiparada. Na mesma pena do *caput* incorre quem propala ou divulga a falsa imputação. Propalar significa relatar verbalmente. Divulgar consiste em relatar por qualquer outro meio. A punição se justifica por se ampliar a potencialidade lesiva do crime.

No art. 138, § 2º, encontra-se previsão importante, no sentido de ser punível a calúnia contra os mortos. Não há regra semelhante quanto aos demais crimes contra a honra. Tutela à memória da boa reputação. Serão vítimas o cônjuge e os familiares do morto.

A exceção da verdade é tratada no art. 138, § 3º. É o meio de defesa de que se vale o indivíduo que está sendo acusado da prática do crime de calúnia. Poderá provar que o que está relatando não é um fato falso e sim uma imputação de crime verdadeira.

A falsidade da imputação é presumida. Porém, trata-se de presunção relativa (*juris tantum*), vez que admite prova em contrário. Assim, o acusado de calúnia pode provar a veracidade do fato criminoso imputado.

A tipificação da calúnia destina-se a tutelar ataques ilícitos à honra de pessoas de bem, e não para acobertar criminosos.

A *exceptio veritatis* deve ser apresentada na primeira oportunidade em que a defesa se manifestar nos autos e a regra é a sua admissibilidade. Apenas em três situações não será admitida: (i) fato imputado constitui crime de ação penal privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; (ii) se o fato é imputado contra Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; (iii) o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Nessas hipóteses não há que se fazer prova da verdade da imputação, esta será considerada sempre falsa.

3. ART. 139. DIFAMAÇÃO

Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, é crime que atinge a honra objetiva, assim como a calúnia. É infração de menor potencial ofensivo, vez que a pena é de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

A imputação é de fato específico que macula a reputação da vítima, pouco importando se verdadeiro ou falso.

Diversamente do que ocorre no crime de calúnia, na difamação a exceção da verdade só é admitida em uma única hipótese, de ofensa irrogada a funcionário público no exercício das funções, visto que surge o interesse da Administração Pública em saber se aquela acusação que macula a honra do servidor público é verdadeira ou falsa. Nesse caso, há um interesse público na lisura e bom exercício das funções pelos seus servidores.

Exemplo: A, em uma conversa entre amigos, diz que o servidor público B sempre trabalha embriagado em sua repartição. B ingressa com a queixa-crime por difamação. A poderá se valer da exceção da verdade, a fim de provar que B trabalha embriagado. O fundamento da *exceptio veritatis* é o interesse maior na fiscalização dos agentes públicos.

A consumação da difamação ocorre quando terceira pessoa, ainda que única, toma conhecimento da ofensa dirigida à vítima.

3.1. EXCEÇÃO DA NOTORIEDADE

O art. 566 do CPP traz essa possibilidade de defesa. Trata-se de oportunidade que se confere ao réu de provar que o fato imputado é de domínio público. É admitida tanto na **calúnia** quanto na **difamação, já que ambas tutelam a honra objetiva. Se o fato já é de domínio público, não há um atentado à honra, já que esta já estaria previamente maculada.**



4. ART. 140. INJÚRIA

Dispõe o art. 140: “*injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.*” A pena é de 1 a 6 meses ou multa. É, também, infração de menor potencial ofensivo.

Injuriar significa ofender, insultar, atribuir qualidade negativa. O ataque se dá à **honra subjetiva**. Não há imputação de fato. Basta a ofensa à dignidade ou decoro por xingamento ou atribuição de qualidade negativa.

O *bullying* (intimidação sistemática), previsto na Lei nº 13.185/15, pode caracterizar injúria, na medida em que o indivíduo que pratica o *bullying* por muitas vezes se vale de insultos pessoais, da atribuição de um apelido ou qualidade negativa.

Como atinge a honra subjetiva, a consumação da injúria ocorrerá quando a ofensa chega ao conhecimento da vítima, de forma imediata ou mediata. É possível a **tentativa** quando manifestada por escrito.

É **incompatível com a exceção da verdade**, justamente porque atinge a honra subjetiva, isto é, o conceito que pessoa faz sobre si, não se tratando da imputação de fato específico. Pode ser que o indivíduo possua inúmeras qualidades negativas mas, ainda assim, o conceito que faz sobre si é excelente, e vice-versa.

O art. 140, § 1º, prevê o perdão judicial, causa extintiva da punibilidade, nos moldes do art. 107, IX, do CP e na Súmula 18 do STJ (“A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório”).

Ainda que presente um fato típico e ilícito, praticado por agente culpável, não se mostra necessária a punição. Hipóteses: quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria (semelhança ao crime cometido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima); no caso de retorsão imediata, que consiste em outra injúria (revide). Tão logo ofendida, a vítima também ataca a honra do seu agressor.

No art. 140, § 2º, há a previsão da injúria real, praticada por meio de violência ou vias de fato aviltantes. Tem-se a agressão física capaz de envergonhar, humilhar, causar vexame público. Não há dolo de machucar, lesionar. **Exemplos:** atirar fezes ou urina, cuspir, rasgar a roupa.

Art. 140, § 3º. Injúria qualificada: quando a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência. A pena passa a ser de **reclusão**. O STF já se pronunciou no sentido de que a previsão de tal pena não fere a proporcionalidade, em respeito à tutela mais eficaz da dignidade da pessoa.

A ofensa deve ser dirigida a pessoa ou pessoas individualizadas.

Importante: a injúria de cunho racial não se confunde com racismo.

O **crime de racismo** está previsto em lei especial, Lei nº 7.716/89. Consiste em **manifestações generalizadas ou indiscriminadas** de segregação racial. O crime é de ação penal pública incondicionada, inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLII, CF), mas não é hediondo.

Já a injúria qualificada (de cunho racial ou não) é crime de **ação penal pública condicionada à representação** (art. 145, parágrafo único, CP), além de ser afiançável e prescritível.

Vale ressaltar que o STF, por meio de sua 1ª Turma, no julgamento dos Embargos de Declaração em Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 983.531/DF, reconheceu a **equiparação dos crimes de injúria racial e racismo e, por conseguinte, a imprescritibilidade e inafiançabilidade daquele.**

Na ocasião, o STF ratificou a decisão proferida pelo STJ, que reconheceu **não ser taxativo o rol dos crimes previstos na Lei nº 7.716/1989**, encontrando-se presentes o preconceito e a intolerância na conduta tipificada como injúria racial.

Trata-se do episódio em que um jornalista chamou um colega de profissão de “negro de alma branca” e que “não conseguiu revelar nenhum atributo para fazer tanto sucesso, além de ser negro e de origem humilde”. As publicações foram feitas, pela *internet*, em 2009.

O caso levou o Ministério Público do Distrito Federal a apresentar denúncia por racismo. Em primeira instância, o juiz tipificou o crime como injúria racial e declarou extinta a punibilidade, por entender que era prescritível. O caso foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.

Em 2015, o autor do fato foi condenado pela 6ª Turma do STJ, a qual concluiu que injúrias raciais são imprescritíveis, por representarem mais um delito no cenário do racismo. O réu, por sua vez, apresentou recurso ao STF, que rejeitou os embargos, criando o seu primeiro precedente nesse sentido.

De acordo com tal entendimento, em relação ao crime de injúria racial, é possível a realização de investigação, oferecimento de denúncia, condenação e execução de pena, independentemente da ocorrência dos prazos de prescrição previstos no art. 109 do CP.

Importa distinguir a injúria do desacato: se a ofensa é feita na presença do funcionário público, no exercício da função ou em razão dela, o crime é de desacato (art. 331 do CP). Na injúria, a ofensa não é feita na presença do funcionário (pode ser por telefone, mensagem, imprensa), mas está relacionada às funções exercidas.

Injúria cometida pela internet: essa circunstância, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal (art. 109 da CF). Em regra, a competência será da Justiça Estadual, ainda que utilizadas redes sociais sediadas no exterior.

O art. 142 traz causas especiais de exclusão da ilicitude (entendimento majoritário) em relação à injúria e à difamação, a saber: a ofensa irrogada em juízo, na discussão a causa, pela parte ou seu procurador (imunidade judiciária), a crítica literária, artística ou científica, ausente o propósito de ofender a honra alheia, e o conceito desfavorável emitido por funcionário público (imunidade funcional).

A retratação é possível nas hipóteses de calúnia e difamação de ação penal privada. Por haver a imputação de fato específico ofensivo à honra objetiva, há interesse da vítima na retratação, embora não seja necessária a sua concordância, observando-se o disposto no parágrafo único do art. 143. Deve o ofensor se desculpar, afastando do conhecimento público o que anteriormente afirmou. Consiste em causa de extinção da punibilidade (art. 107, inc. VI, CP).

A retratação tem natureza subjetiva, não se comunicando aos querelados que não se retrataram. Deve ser total, cabal, incondicional. É unilateral, isto é, não necessita de aceitação do ofendido. Deve ser anterior à prolação da sentença ou acórdão condenatório.

Consoante o art. 144, se, de referências, alusões ou frases, infere-se calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido **pode pedir explicações em juízo**. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.

A parte final do dispositivo deve ser interpretada de acordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se pode obrigar o requerido a dar as explicações pretendidas, nem prejudicá-lo de qualquer forma, sem o respeito ao devido processo legal.

Assim, o pedido de explicações terá natureza preparatória e explicativa. É **facultativo**, não sendo capaz de interromper o prazo decadencial de 6 (seis) meses.

Algumas considerações finais acerca dos crimes tratados nesse capítulo.

Todos os crimes contra a honra definidos no CP, à exceção da injúria qualificada (art. 140, §3º) encaixam-se no conceito de infração de menor potencial ofensivo, com a consequente aplicação da Lei nº 9.099/90.

São todos classificados como crimes comuns, de forma livre, formais (não dependem de resultado naturalístico), instantâneos.

Como regra geral, a ação penal é privada (somente se procede mediante queixa). **Exceções:** art. 145, *caput*, parte final; art. 145, parágrafo único, 1ª e 2ª partes.

Súmula 714 do STF: Ação penal privada concorrente (muito cobrada em provas de concurso).

“É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções”.



Manifesta-se o interesse coletivo na apuração dos fatos imputados a servidor público no exercício de suas funções.

QUESTÕES

1- (CEBRASPE – TJSC -2019) Com relação a crimes contra a honra, assinale a opção correta.

A O crime de calúnia se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da imputação falsa contra si.

B Calúnia contra indivíduo falecido não se enquadra como crime contra a honra.

C A exceção da verdade é admitida em caso de delito de difamação contra funcionário público no exercício de suas funções.

D A retratação cabal do agente da calúnia ou da difamação após o recebimento da ação penal é causa de diminuição de pena.

E O delito de injúria racial se processa mediante ação penal pública incondicionada.

Gabarito: C



CAPÍTULO 29 — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA: CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

1. ART. 146. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

O crime consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência (violência imprópria), a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

O fundamento constitucional para a tutela penal reside no art. 5º, inc. II, da CF, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

A tipificação da conduta pode se dar quando a vítima é obrigada, compelida, a fazer algo ou quando a vítima é constrangida a deixar de fazer algo.

O verbo constranger, núcleo do tipo, significa retirar a liberdade de autodeterminação. É uma coação ilegal à liberdade moral ou psíquica.

O comportamento deve ser certo e determinado.

O constrangimento deve ser ilegal. Não há crime quando o constrangimento objetiva impedir uma ação criminosa. Os meios de execução são três: violência (força física), grave ameaça (violência moral, apta a intimidar, amedrontar) e a violência imprópria (qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima).

Se o comportamento da vítima puder ser exigido por ação judicial, o crime será o do art. 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões). **Exemplo:** cobrança de dívida pelos próprios meios.

O crime é de forma livre e material, isto é, depende de resultado naturalístico para a consumação. É instantâneo. A tentativa é possível.

O delito é também **subsidiário (residual)**. Deve ser verificado se o constrangimento é meio de execução de crime mais grave, hipótese em que restará absorvido. Exemplo: para a prática do estupro, o agente obriga a vítima, mediante grave ameaça, a retirar as roupas. O constrangimento ilegal, nesse caso, compõe o *iter criminis* do delito contra a dignidade sexual e será por este, mais grave, absorvido.

No **Estatuto do Idoso** há previsão específica para aquele que coage, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração (art. 107 da Lei nº 10.741/03). Na **Lei de Abuso de Autoridade** (Lei nº 13.869/19) há diversos tipos especiais de constrangimento ilegal, os quais irão prevalecer diante das disposições genéricas do CP.

Ainda, o Código arrola causas especiais de **exclusão de ilicitude** (posição majoritária):

§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo:

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida;

II - a coação exercida para impedir suicídio.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 147. AMEAÇA

Descreve o art. 147: “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.” A pena cominada é de detenção, de um a seis meses, ou multa. Nos termos do parágrafo único, somente se procede mediante representação (ação penal pública condicionada).

O mal deve ser sério, verossímil e iminente. Não necessariamente o mal grave prometido se caracteriza como crime.



O crime é comum. A vítima deve ser pessoa certa e determinada, capaz de compreender o mal prenunciado.

A ameaça pode ser direta, indireta, implícita (exemplo: quando o indivíduo apresenta ou exhibe uma faca; simula que vai disparar arma de fogo) ou condicional (exemplo: se você não casar comigo, eu te mato).

Não é necessário que a ameaça se dê na presença da vítima, bastando que chegue ao seu conhecimento.

A consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, não sendo preciso que se concretize. Portanto, o crime é formal ou de consumação antecipada (prescinde do resultado naturalístico). É também crime de forma livre, que pode ser praticado por palavras, gestos, escritos ou qualquer meio simbólico.

Vale lembrar do caráter subsidiário ou residual. Se a ameaça for meio para a prática de outro crime, será absorvida.

3. ART. 148. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO

No art. 148 temos a seguinte descrição típica: privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. A pena é de reclusão, de um a três anos. Assim, a hipótese é de crime de **médio potencial ofensivo**, admitindo suspensão condicional do processo. Se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, será possível o acordo de não persecução penal, nos moldes do art. 28-A do CPP.

O sequestro ou cárcere privado será qualificado, passando a ter pena de **reclusão, de 2 a 5 anos**, nos seguintes casos:

- Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos.
- Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital.
- Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias.
- Se o crime é praticado contra menor de 18 anos.
- Se o crime é praticado com fins libidinosos.

O §2º estabelece que, se do sequestro ou cárcere privado resultar à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, **grave sofrimento físico ou moral, a pena será de reclusão, de 2 a 8 anos**. É uma modalidade qualificada do crime.

O bem jurídico tutelado é a liberdade de locomoção.

O sujeito ativo é qualquer pessoa (crime comum).

É preciso distinguir o sequestro do cárcere privado, apesar de ambos terem o mesmo tratamento penal.

O sequestro é gênero. Há privação da liberdade, mas sem confinamento. **Exemplo:** a pessoa está sequestrada em um sítio, mas tem liberdade de andar pela propriedade. Já o cárcere privado é espécie de sequestro. Há um confinamento, estando a pessoa dentro de um cômodo, como quarto, sala, banheiro, sem possibilidade de deslocamento.

O tempo durante o qual a vítima sofre a privação da liberdade não interfere na tipificação da conduta. Se o período for superior a 15 dias, estará caracterizada a forma qualificada do crime.

A voluntariedade é o dolo. Não é preciso uma finalidade especial(dolo específico). Se o indivíduo sequestrar para obter uma vantagem indevida, o crime será a extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP).

O crime se consuma no momento em que se cerceia a liberdade de locomoção da vítima.

Trata-se de **crime permanente**, isto é, a consumação se protraí no tempo. Diante disso, permite-se a aplicação de lei penal mais gravosa enquanto não houver a cessação da permanência (libertação da vítima). Permite-se, também, a prisão em flagrante a qualquer tempo.



No caso do sequestro qualificado para fins libidinosos, há a substituição da figura do antigo crime sexual de rapto (artigos 219 e 220 do CP, revogados). Não houve a *abolitio criminis*, e sim a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica. A conduta continua sendo criminosa, apesar da revogação do tipo penal, vez que prevista em dispositivo diverso.

O professor Rogério Sanches Cunha ensina que o rapto era um crime de iniciativa privada, enquanto o sequestro é crime de ação penal pública incondicionada. A lei que revogou o crime de rapto é de 2005 (Lei nº 11.106/05). Supondo que o agente tenha cometido o crime antes da lei que alterou o tipo formal, a inicial acusatória deverá se dar por queixa-crime (ação penal privada) ou por denúncia (ação penal pública incondicionada)?

Segundo Sanches, **não poderá haver o oferecimento da denúncia, e sim de ação penal privada**. Isso porque, ao tempo do crime, somente se procedia mediante queixa. A nova lei tem repercussão penal, pois não admite o permite perdão do ofendido, renúncia, decadência e perempção, institutos que não têm aplicação na ação penal pública.³⁷

Conforme dispõe o § 2º, a pena será de 2 a 8 anos se da privação resultar maus-tratos, gerando grave sofrimento físico ou moral (figura qualificada do crime).

Haverá o **crime de tortura**, previsto na Lei nº 9.455/97 se o agente pratica o sequestro ou cárcere privado com o objetivo de:

- Obter uma informação, confissão ou declaração da vítima, seja por ela ou por uma terceira pessoa;
- Provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa;
- Fazer discriminação racial ou religiosa.

Se houver o sequestro ou cárcere privado para fins políticos ou para a obtenção de fundos, destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas, ou por inconformismo político, figurando como vítimas Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara ou Presidente do STF, haverá crime contra a segurança nacional (Lei nº 7170/83).

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 149. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

Segundo o art. 149, é crime a conduta de **reduzir alguém a condição análoga à de escravo**, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.

A pena será de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

O §1º estabelece que nas mesmas penas incorre quem (condutas equiparadas):

- Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

- Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

Por sua vez, o §2º prevê que a pena é **umentada de metade**, se o crime é cometido contra criança ou adolescente, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

A doutrina nomeia esse crime de **plágio**, pois há a sujeição de uma pessoa ao poder de outra, a objetificação do ser humano. Daí a repugnância da infração penal.

Trata-se de crime contra a liberdade individual e a competência para o julgamento é objeto de divergências na doutrina e na jurisprudência.

³⁷ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Parte Especial. Volume Único**. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, pp. 228-229.

Tradicionalmente, compreendia-se que, se o crime atingisse a **organização do trabalho** seria, em regra, da competência Justiça Federal, visto que os princípios basilares sobre os quais o trabalho se estrutura são atingidos, malferindo o direito de vários indivíduos ou de uma categoria (art. 109, inc. VI, da CF).

Por outro lado, quando apenas uma pessoa é atingida em sua liberdade individual, o crime seria, em regra, da competência da Justiça Estadual.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, abstratamente, não se pode considerar a redução a condição análoga à de escravo como crime que atinge a organização do trabalho. Se somente um trabalhador é atingido, não haveria ofensa à organização do trabalho, motivo pelo qual a competência seria da Justiça Estadual.

Por outro lado, em julgados mais recentes, a Corte reiterou o entendimento de que a competência sempre será da Justiça Federal (RE 541.627/PA e RE 459.510/MT), considerando que a topografia do crime no CP, isto é, o posicionamento no capítulo dos crimes contra a liberdade individual não seria fator preponderante para a fixação da competência. Esse deve ser o entendimento adotado para provas de concurso.

Por se tratar de um **crime de ação vinculada**, deve ser praticado por meio de uma das condutas descritas no tipo. Quando o tipo penal descreve o *modus operandi*, tem-se um crime de ação vinculada. Confira-se: submeter a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitar a condições degradantes de trabalho, restringir, por qualquer meio, a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, manter vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

Trata-se de um **tipo misto alternativo**, de conteúdo múltiplo ou variado, motivo pelo qual se o indivíduo incidir em mais de uma conduta, no mesmo contexto, terá praticado um único crime, devendo ser levada em conta a variedade de comportamentos na primeira fase dosimetria da pena, nas circunstâncias do crime.

Se o meio utilizado para praticar o crime for o sequestro, este ficará absorvido pelo crime de redução a condição análoga à de escravo, que é mais grave.

Não é necessário que ocorra violência, grave ameaça, maus-tratos, ou que o sujeito passivo experimente sofrimento. O eventual consentimento da vítima é irrelevante, por se tratar de bem jurídico indisponível.

A consumação se dá quando o indivíduo é reduzido a condição análoga à de escravo por meio de uma das formas previstas no tipo penal.

O crime é permanente, ou seja, a qualquer momento é possível a prisão em flagrante, visto que a consumação se prolonga no tempo. Será possível a incidência da lei mais gravosa superveniente, caso não tenha cessado a permanência. É possível a tentativa.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 149-A. TRÁFICO DE PESSOAS

Trata-se de figura introduzida pela Lei nº 13.344/16, a qual revogou os artigos 231 e 231-A do CP. Eis a redação do dispositivo legal:

Art. 149-A Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:

- I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
- II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;
- III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;
- IV - adoção ilegal; ou
- V - exploração sexual.

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.



§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se:

I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las;

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;

III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou

IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.

§ 2º A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar organização criminosa.

Conforme se nota, a tutela penal não se restringe a aspectos ou fins sexuais, estendendo-se a outras finalidades específicas, elencadas no artigo em análise.

Trata-se de tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado. Algumas figuras são crimes permanentes (acolher, alojar, etc.). A prática de mais de um verbo no mesmo contexto fático ensejará crime único.

O tráfico internacional de pessoas, quando a vítima é enviada para fora do Brasil, configura causa de aumento de pena.

O crime é bicomum, ou seja, pode ser praticado por qualquer sujeito ativo. Se for servidor público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, há causa de aumento de pena (majorante que incidirá na terceira fase da dosimetria).

O bem jurídico tutelado pela norma é a liberdade pessoal, quanto ao próprio corpo, a liberdade de locomoção e de trabalho, bem como o respeito ao estado de filiação e à liberdade sexual.

As principais vítimas desse crime são crianças, adolescentes e mulheres.

Trata-se, ademais, de crime formal. As finalidades específicas pretendidas pelo agente (especial fim de agir ou tendência interna transcendente) não precisam se concretizar para a consumação do crime, bastando o dolo. Caso sejam alcançadas, teremos exaurimento, respondendo o agente por dois ou mais crimes, em concurso material.

O consentimento do ofendido, em regra, não exclui o crime, quando se tratar de vítimas em situação de vulnerabilidade social ou econômica.

A atribuição para investigar o delito é da Polícia Civil, salvo de houver transnacionalização (exportação da vítima), quando a atribuição passa a ser da Polícia Federal.

Há possibilidade de colaboração premiada, ação controlada, infiltração de agentes e demais meios de obtenção de prova previstos na Lei do Crime Organizado (Lei nº 12.850/13).

Crime de ação penal pública incondicionada.

6. DOS CRIMES CONTRA A INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO

6.1. ART. 150. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Estabelece o art. 150 ser crime a conduta de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. A pena é de detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Sendo possível a transação penal, afasta-se o ANPP.

Protege-se a tranquilidade doméstica (intimidade, segurança e vida privada). A inviolabilidade domiciliar é direito fundamental, nos termos do art. 5º, inc. XI, da CF:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



O consentimento do morador, explícito ou implícito, torna o fato atípico. Incompatível com o dolo eventual. Não se admite a forma culposa.

O crime é comum (praticado por qualquer pessoa), permanente (consumação se prolonga no tempo), de mera conduta (não prescreve resultado naturalístico). É também tipo misto alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado ou plurinuclear (a prática dos dois verbos no mesmo contexto fático enseja figura criminosa única). Haverá o crime quando o proprietário (locador) adentrar a residência alugada sem o consentimento do inquilino.

Na hipótese de residência familiar e colidência de manifestações sobre a autorização para ingresso no domicílio, deverá prevalecer a vontade dos pais, ainda que o imóvel pertença ao filho menor.

No caso de habitação coletiva, em que há regime de igualdade entre os moradores, em que um deles quer receber alguém, mas o outro não o quer, prevalece a decisão daquele que proibiu o ingresso, motivo pelo qual, se o terceiro ingressar, praticará o crime de violação de domicílio.

O § 1º contempla a forma qualificada. Se o crime é cometido durante a noite, em lugar ermo (deserto, sem habitantes), com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas, a pena passa a ser de detenção, de 6 meses a 2 anos, além do crime correspondente à violência. Ainda que qualificado, continua sendo delito de menor potencial ofensivo.

O § 2º foi revogado pela Lei nº 13.869/19. Assim, a violação de domicílio cometida com abuso de autoridade está tipificada no art. 22 da lei especial.

No § 3º verifica-se uma norma penal permissiva, pois traz rol de excludentes de ilicitude. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

- Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência.
- A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

O §3º vai ao encontro da Constituição Federal, estabelecendo que a casa é inviolável, salvo para prestar socorro, casos de calamidade, situações de flagrante delito, ou durante o dia por ordem judicial. Se estivermos diante dessas circunstâncias não haverá crime de violação de domicílio.

O § 4º, por sua vez, é norma penal explicativa: estabelece que a expressão "casa" compreende qualquer compartimento habitado; aposento ocupado de habitação coletiva (quarto do hotel, caso esteja ocupado);compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (o STJ entendeu que gabinete de delegado de polícia é um lugar privativo, ainda que esteja dentro de repartição pública, de forma que o ingresso contra a vontade do delegado configura crime de violação de domicílio). A enumeração é exemplificativa. Quanto às dependências da casa, tem-se a garagem, jardim, quintal, desde que não aberto ao público.

No § 5º também se observa norma penal explicativa, pois dispõe sobre o que não se compreende na expressão "casa": hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do inciso II do parágrafo anterior; taverna, casa de jogos e outras do mesmo gênero.

O crime de violação de domicílio é subsidiário, pois pode ser crime-meio para a prática de outro mais grave, como um furto ou roubo.

A ação penal é pública incondicionada.

7. DOS CRIMES CONTRA A INVOLABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA

7.1. ART. 151. VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA

O tipo previsto no art. 151 foi tacitamente revogado pelo art. 40 da Lei nº 6.538/78, que trata dos delitos contra o serviço postal e contra o serviço de telegrama. Deve prevalecer, assim, o princípio da especialidade.

Segundo o art. 40 da Lei nº 6.538/78, há crime na conduta de devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. A pena é de detenção, até 6 meses, ou pagamento não excedente a 20 dias-multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

Qualquer pessoa pode praticar o crime (comum). O sujeito passivo é o remetente e também o destinatário. É um crime de dupla subjetividade passiva.

O marido que indevidamente lê a correspondência de sua esposa, ou o contrário, não pratica o crime de violação de correspondência. Segundo a doutrina majoritária, a comunhão de interesses no matrimônio afasta o delito.

Se os pais acessam a correspondência dos filhos, a ocorrência de crime dependerá da existência ou do poder familiar. Se o filho estiver sujeito à autoridade parental, não haverá crime. Mas caso não haja essa autoridade, o fato será típico.

Se a correspondência estiver aberta, plenamente acessível a qualquer um, não haverá crime.

Algumas hipóteses legais de autorização para a devassa de correspondência:

Lei de Falências: autoriza a abertura, pelo administrador judicial, de correspondências endereçadas ao falido, desde que haja interesse da massa presente na situação.

Diretor de estabelecimento prisional: pode devassar a correspondência de presos, de forma motivada (suspeita da prática de crimes, por exemplo).

CPP: a autoridade judicial ou policial poderá apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; (art. 240, § 1º, f, CPP).

Curador: tem direito ao conhecimento da correspondência endereçada ao interessado absolutamente incapaz. Esse entendimento deve ser adequado ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Tutores e pais: têm direito de acesso às correspondências endereçadas aos tutelados ou aos filhos, no exercício do poder familiar.

7.1.1. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime de violação de correspondência é um **crime material** (exige resultado naturalístico), consumando-se no momento em que o agente toma conhecimento do conteúdo da correspondência.

Não basta abrir ou rasgar o envelope. Deve-se ter acesso ao conteúdo. Se o indivíduo, por circunstâncias alheias a sua vontade, é impedido de ler o teor da correspondência, **haverá tentativa**.

O crime de sonegação ou destruição de correspondência estava originariamente no §1º, inciso I, do art. 151, **mas também foi revogado pela Lei nº 6.538/78**.

Estabelece o art. 40, §1º, da Lei nº 6.538/78 que incorre nas mesmas penas quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, para sonegá-la ou destruí-la, no todo ou em parte.

Sonegar significa ocultar e destruir é o mesmo que inutilizar.

A doutrina majoritária entende se tratar de **delito formal**. Basta que o sujeito se apossa, com a intenção de sonegar ou destruir a correspondência, ainda que não tenha acesso ao conteúdo.

O art. 151, §1º, inciso II, traz o crime de violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica, estabelecendo que incorrerá nas mesmas penas do *caput* quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas.

Nesse caso, o agente (crime comum) toma conhecimento da comunicação, de forma lícita, mas, após, transmite a outrem ou utiliza indevidamente a informação. Não há conflito com a previsão do art. 10 da Lei nº 9.296/96, que trata das interceptações de comunicação telefônica, informática ou telemática.



Conforme o inciso III, incorre nas mesmas penas quem impede a comunicação ou a conversação referidas no inciso II (terceiras pessoas).

No inciso IV, tem-se que incorre nas mesmas penas quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.

O § 2º estabelece causa de aumento de pena, de 1/2 (metade), se houver dano para outrem.

Já o § 3º prevê que, se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, a pena será de detenção, de 1 a 3 anos. É um crime qualificado de médio potencial ofensivo, pois não admite suspensão condicional do processo. É possível o ANPP.

O § 4º estabelece que nos casos do art. 151 **somente se procede mediante representação**, salvo nos casos do § 1º, IV, e do § 3º, nos quais a ação penal será pública incondicionada.

Portanto, a regra é de que a ação é penal pública condicionada à representação. Para o art. 40 da Lei nº 6.538/78, os crimes são de ação penal pública incondicionada.

7.2. ART. 152. CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL

O art. 152 prevê a seguinte figura típica: abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena de detenção, de 3 meses a 2 anos. É crime de menor potencial ofensivo.

O crime é próprio, pois o sujeito ativo deverá ser sócio ou empregado, ou seja, deverá ter a característica, pois do contrário incidirá nas penas do artigo anterior. A correspondência tratada no dispositivo tem natureza comercial.

A conduta é punida apenas dolosamente.

O parágrafo único prevê a ação penal condicionada à representação.

O **crime é próprio**, pois o sujeito ativo deverá ser sócio ou empregado, ou seja, deverá ter a característica, pois do contrário incidirá nas penas do artigo anterior.

8. DOS CRIMES CONTRA A INVOLABILIDADE DOS SEGREDOS

8.1. ART. 153. DIVULGAÇÃO DE SEGREDOS

“Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.” É infração de menor potencial ofensivo.

O bem jurídico tutelado é a inviolabilidade do segredo e, por consequência, a privacidade e a intimidade.

O crime é próprio, pois quem divulga o segredo é o destinatário ou detentor do documento particular ou de correspondência confidencial.

Quanto ao objeto material do crime, tem-se os documentos escritos, correspondências, que contenham conteúdo sigiloso. Portanto, a figura do art. 153 não trata de conteúdo secreto revelado apenas verbalmente.

O tipo não exige que a divulgação produza dano, aferindo-se apenas a potencialidade de causar dano. É **crime de perigo concreto**, bastando a conduta, somada à demonstração de que havia potencialidade de causar o dano.

Ademais, o crime é formal, pois com a divulgação do segredo a um número indeterminado de pessoas já estará consumado.

A expressão sem justa causa, contida na descrição típica, é elemento normativo, que será avaliada pelo magistrado no caso concreto.



O §1-A estabelece que constitui crime a conduta de divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública.

Esta figura é mais grave, pois está divulgando informações sigilosas da Administração pública, assim definidas em lei. Trata-se de norma penal em branco, pois demanda complemento normativo.

É infração de médio potencial ofensivo, pois admite suspensão condicional do processo, mas não admite transação.

O crime somente se procede mediante representação, exceto quando resultar prejuízo para a Administração Pública, hipótese em que a ação penal será incondicionada.

8.2. ART. 154. VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL

Dispõe o art. 154 “ser criminosa a conduta de revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação do segredo possa produzir dano a outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.” É infração de menor potencial ofensivo.

O crime é próprio, pois o sujeito ativo é aquele que tomou conhecimento do segredo por exercer função, ministério, ofício ou profissão (na esfera privada; no âmbito público, as figuras típicas estão previstas nos artigos 325 e 326 do CP). Essa revelação deverá se dar sem justa causa, pois se houver justa causa o fato é atípico.

Se houver consentimento com a divulgação do segredo, o fato também será atípico.

O crime é **formal**, bastando a divulgação do segredo. Não é preciso que quem tenha o seu segredo revelado sofra qualquer dano.

Conforme dispõe o art. 269 do CP, o médico tem obrigação, sob pena de crime, de comunicar à autoridade moléstia grave de que tenha tomado conhecimento no exercício da profissão. Nesse caso, ainda que na relação paciente e médico vigore o sigilo, prevalece o interesse público e deverá o profissional de saúde notificar a moléstia, respondendo penalmente pela omissão.

O crime somente se procede mediante representação.

8.3. ART. 154-A. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO

Nos termos do art. 154-A, pune-se a invasão de dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança ou instalação de vulnerabilidades. A pena cominada é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Trata-se do tipo penal criado pela Lei nº 12.737/12, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, atriz que teve seu computador pessoal invadido em maio de 2012 e vários fotos íntimas subtraídas. Também é chamado de crime de intrusão informática.

Importa lembrar que a Lei nº 12.965/14 constitui o marco civil da *internet*, definindo princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores no Brasil.

O bem jurídico tutelado pela norma é a liberdade individual (inviolabilidade dos segredos). O crime é bicomum, não se exigindo características especiais do agente ou da vítima.

O objeto material é dispositivo informático **alheio**, conectado ou não à rede computadores. Assim, incluem-se no conceito *notebooks*, *tablets*, placas de vídeo, processadores de computadores, *smartphones*, teclados, *webcam*, impressoras, monitores, *pen drives*, HDs e CDs.

O elemento subjetivo é o dolo, acrescido de especial fim de agir (“com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”). Não basta, portanto, devassar dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Ausente as finalidades especiais, a conduta é atípica.



O crime é formal, pois se consuma independentemente de se alcançar a finalidade pretendida.

O § 1º prevê conduta equiparada, pois na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no *caput*.

Conforme dispõe o § 2º, aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico.

Para a consumação do crime não é necessário que o indivíduo tenha o objetivo de obter vantagem econômica, mas se a prática do crime gera prejuízo, haverá uma causa de aumento de pena.

O § 3º estabelece forma qualificada. O § 4º estabelece majorante aplicável à hipótese do § 3º.

No § 5º há previsão de causa de aumento de pena, incidente na terceira fase da dosimetria, de um terço à metade, se o crime for praticado contra:

I - Presidente da República, governadores e prefeitos;

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

A competência, em regra, é da Justiça Estadual. É irrelevante o fato de ter sido cometido o crime pela *internet*. O crime praticado pela rede mundial de computadores não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.

Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. É o que dispõe o art. 154-B.

CAPÍTULO 30 — DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: DO FURTO

1. ART. 155. FURTO

A figura penal do furto consiste em subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. A pena é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Tutela-se a propriedade e a posse legítimas.

O patrimônio é bem jurídico disponível. Por isso, o consentimento do ofendido, antes ou durante a subtração, torna o fato atípico. Depois da subtração o consentimento é ineficaz.

Ser humano não é coisa alheia móvel. Logo, não poderá ser furtado. O crime será de sequestro (art. 148 do CP), extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP) ou subtração de incapaz (art. 249 do CP).

A subtração de cadáver é conduta prevista no art. 211 do CP, pois se trata de coisa fora do comércio, salvo se ostentar valor econômico e estiver na posse legítima de pessoa física ou jurídica (cadáver pertencente a uma Faculdade de Medicina ou a um museu, por exemplo).

Não há furto nos casos de *res nullius* (coisas que nunca tiveram dono) ou *res derelicta* (coisas abandonadas), conceitos dispostos no art. 1.263 do Código Civil.

O furto de gado é chamado de abigeato.

Subtração de talão de cheques em branco e cartão magnético bancário: entende a doutrina que não haverá crime de furto, vez que desprovidos de valor econômico. Eventual utilização indevida desses objetos caracteriza, a princípio, estelionato (art. 171).

O elemento subjetivo no furto é o dolo (*animus furandi*), acompanhado do especial fim de agir, consistente na vontade de assenhoreamento definitivo da coisa alheia móvel (*animus rem sibi habendi*). Para a caracterização do crime, é imprescindível que o agente se aposses da coisa e passe a se comportar como se fosse seu legítimo proprietário.

Nesse sentido, o credor que subtrai bens do devedor para se ressarcir de dívida não paga não comete furto e sim exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 CP).

No direito brasileiro, o chamado furto de uso não é conduta típica, por ausência do *animus rem sibi habendi*. A agente quer usar a coisa momentaneamente, sem dela se apropriar. Não haverá crime, mas pode haver repercussões na esfera cível.

O furto de uso, como conduta atípica, tem os seguintes requisitos: subtração de coisa alheia móvel infungível, intenção de utilizar apenas momentaneamente, seguida da restituição íntegra ao possuidor originário.

Importa ressaltar que, no caso do roubo, não se cogita de atipicidade quando praticado com o fim de uso, pois o delito é pluriofensivo, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

1.2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA (CAUSA DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE)

A abordagem dos crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça exige o estudo do princípio da insignificância como causa extralegal de exclusão da tipicidade material.

A terminologia foi cunhada por Claus Roxin. Klaus Tiedemann chama de princípio de bagatela. As expressões são sinônimas.

Para a compreensão do princípio, é preciso recordar que a tipicidade penal é composta pelos aspectos formal e material. A tipicidade formal corresponde ao juízo de subsunção do fato da vida à norma jurídica. Já a tipicidade material corresponde à lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

Algumas condutas, formalmente, amoldam-se a um tipo penal. Porém, materialmente não apresentam relevância concreta. Afasta-se, assim, a tipicidade, pois o bem jurídico tutelado não chegou a ser lesado, ofendido, ou posto em perigo. O princípio da bagatela afasta a tipicidade material.



O princípio da insignificância não tem previsão legal no Brasil. Todavia, é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência.

1.3. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO

A análise é casuística, não havendo possibilidade de se estabelecer critérios pré-definidos para o reconhecimento da insignificância.

Para o STF, os requisitos ou vetores para a aplicação do princípio são:

Periculosidade ausente

Reprovação reduzida

Ofensividade mínima

Lesão inexpressiva

Note-se que são conceitos abertos, que permitem ampla margem de interpretação pelo aplicador da norma.

A insignificância é considerada fator de política criminal e sempre levará em conta as peculiaridades do caso concreto.

O valor do objeto material não é o único parâmetro a ser aferido. As condições pessoais do agente e da vítima devem ser analisadas.

Em regra, não se aplica a insignificância ao reincidente, portador de maus antecedentes e ao criminoso habitual. Todavia, alguns doutrinadores pontuam críticas nesse aspecto. Por se tratar de causa que afasta a tipicidade material, não seria o caso de se analisar o perfil subjetivo do agente. A análise repousa sobre a conduta, interessa o fato praticado em si e não quem o praticou. Tem-se, assim, um resquício do direito penal do autor. Por outro lado, a aplicação do princípio não pode fomentar a prática reiterada de pequenos furtos, como meio de vida. A última corrente tem prevalecido.

Conforme ressaltado, o perfil da vítima deve ser avaliado. As condições econômicas, se o bem tinha valor sentimental e eventuais consequências do crime devem ser ponderadas. Exemplo: furto de botijão de gás, avaliado em R\$ 130,00. Quando o crime atinge uma grande distribuidora, em tese seria possível o reconhecimento da bagatela. Todavia, se o mesmo botijão é subtraído de uma família que trabalha com venda informal de marmitas, o furto não será insignificante, pois inviabilizará o sustento. A situação em concreto é que vai ditar a melhor solução a ser adotada.

Não há valor máximo (teto) a ser considerado. Como regra, aplica-se a insignificância a valores que não ultrapassem 10% do salário mínimo vigente à época do fato.

O princípio pode ser aplicado a atos infracionais, crimes ambientais, ao descaminho e aos crimes tributários.

Não se aplica a insignificância:

- Crimes hediondos e equiparados
- Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
- Uso de entorpecentes (art. 28 Lei nº 11.343/06)
- Crimes contra a fé pública (moeda falsa, por exemplo)
- Crimes contra a Administração Pública (Súmula 599 do STJ, regra geral)
- Contrabando (natureza ilícita da mercadoria importada ou exportada)
- Violência doméstica ou familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha)

O furto famélico não é hipótese de incidência da bagatela. Trata-se da situação comprovada de extrema penúria. Não há crime pela incidência da excludente de ilicitude consistente no estado de necessidade (art. 24 do CP)



1.4. TEORIAS ACERCA DA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES DE FURTO E ROUBO

A preocupação acerca do momento consumativo dos crimes contra o patrimônio remonta ao direito romano. Ao longo da história, diferentes teorias foram elaboradas. Verifica-se na doutrina alguma divergência quanto à nomenclatura. De qualquer sorte, as principais correntes são:

Concrectatio: consta do Digesto, a compilação das leis romanas. Entende-se que o mero contato da mão com a coisa já torna o crime consumado. Todavia, foi superada, vez que o simples tocar em um objeto não revela o dolo de subtração.

Apprehensio: a consumação ocorre com a apreensão da coisa.

Amotio: formulada por Francesco Carrara, é a teoria mais aceita na atualidade. Preconiza que a consumação ocorre com a apreensão e inversão da posse do bem; o indivíduo, além de segurar a coisa, retira-a da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por um brevíssimo espaço de tempo. É a **teoria adotada pelo STF e STJ. Alguns doutrinadores identificam a teoria da *amotio* como sinônimo de *apprehensio*.**

Ablatio: defende-se que para a consumação não basta a apreensão da coisa, sendo necessário o transporte a outro lugar; o indivíduo deve ter o proveito seguro, assenhorar-se e comportar-se como dono; privilegia o caráter material dos crimes patrimoniais, que dependem do resultado naturalístico, no sentido de que o objeto furtado possa ser transportado de modo seguro.

Em que pese parcela da doutrina tradicional adotar a teoria da *ablatio*, atualmente prevalece o entendimento de que não é necessário o transporte, sequer a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando que tenha ocorrido a inversão da posse. Ainda que o indivíduo seja perseguido, se houve a inversão da posse, o crime estará consumado. É o entendimento que se extrai da **Súmula 582 do STJ**:

consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.
Mutatis mutandis, a súmula aplica-se ao crime furto.

No contexto do crime de furto, convém ressaltar ainda a **Súmula 567 do STJ**, segundo a qual sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

A jurisprudência rechaçou o argumento defensivo muito utilizado no sentido de que o furto ocorrido em estabelecimento com sistema de vigilância era crime impossível, uma vez que o agente estava sendo monitorado e, a qualquer momento, seria possível interromper o *iter criminis* e, conseqüentemente, o crime jamais restaria consumado.

Ante ao imbróglio doutrinário e jurisprudencial, o STJ edita a súmula em análise, já que há situações em que o furto poderá se consumir, visto que nenhum sistema de vigilância é completamente perfeito e apto a evitar todas as situações que se desenvolvem, além de serem uma forma de desestímulo a essas práticas delitivas que são corriqueiras. A elaboração desta súmula envolve questões acerca de política criminal.

Ademais, os agentes de segurança não podem fazer a abordagem do consumidor enquanto no interior da loja, já que ele pode, a qualquer tempo, decidir pagar pela mercadoria, ainda que inicialmente a sua conduta não revele tal intenção.

1.5. REPOUSO NOTURNO

A pena do furto aumenta-se de um terço se é praticado durante o repouso noturno. Trata-se de causa de aumento de pena ou majorante, com incidência na terceira fase da dosimetria.



Entende-se por repouso noturno o intervalo entre o recolhimento para o descanso e o despertar. Variável de acordo com os costumes locais. Não basta ser noite. Exemplo: 20h00 nas grandes cidades é horário de plena atividade e não pode ser considerado como de repouso noturno. Assim, a incidência da majorante vai depender do prudente arbítrio do magistrado, pois não há um parâmetro fixo.

O objetivo de legislador é apenar com maior gravidade aquele indivíduo que se vale da menor vigilância que está sendo exercida sobre os bens, a maior vulnerabilidade, sendo maiores as possibilidades de êxito do agente. Todavia, a vítima não necessariamente precisa estar dormindo ou repousando.

É indiferente se a casa é habitada ou não, comércio ou via pública. A majorante irá incidir.

Historicamente, prevalecia o entendimento jurisprudencial no sentido de que a causa de aumento somente se aplicava ao furto simples (art. 155, caput), em razão da localização topográfica do repouso noturno (logo abaixo do furto simples e antes do qualificado), bem como em razão das formas qualificadas já terem suas penas aumentadas nos patamares mínimo e máximo.

Porém, mais recentemente, o **STJ mudou o entendimento**. Entendeu-se que, diante da possibilidade de reconhecimento do privilégio (§ 2º) ao furto qualificado (§ 4º), não haveria óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena (§ 1º) ao furto simples (*caput*).

Há críticas a esse posicionamento, no sentido de que se aplica o privilégio às figuras qualificadas em uma interpretação *in bonam partem*, que favorece o acusado, ao passo que ao aplicar uma majorante, estar-se-ia adotando um posicionamento *in malam partem*, uma analogia prejudicial ao réu. Não obstante, prevalece no STJ o entendimento segundo o qual aplica-se a majorante do furto noturno às hipóteses qualificadas do §4º.

1.6. FURTO PRIVILEGIADO

Segundo o § 2º do art. 155, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Dessa forma, são dois os requisitos cumulativos para o reconhecimento do privilégio no furto: primariedade do agente (não reincidente) e pequeno valor da coisa furtada.

O pequeno valor é aquele que não excede a um salário mínimo vigente na data do fato. Há necessidade, assim, de auto de avaliação econômica, direta ou indireta. O pequeno valor não se confunde com o pequeno prejuízo, nem com o que é insignificante e, assim, um indiferente penal.

Se presente ambos os requisitos legais, o juiz **deve** aplicar o privilégio. Trata-se de direito subjetivo do acusado.

1.7. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO (HÍBRIDO)

É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Esse é o enunciado da Súmula 511 do STJ, que trata da possibilidade de coexistência entre o privilégio (de índole subjetiva) com as qualificadoras do furto, desde que estas sejam objetivas.

Qualificadoras objetivas, materiais ou reais são aquelas que estão relacionadas ao modo de execução, tempo, lugar do crime e instrumentos utilizados. São qualificadoras que se concretizam no mundo dos fatos e que podem ser constatadas na cena do crime.

Já as qualificadoras subjetivas ou pessoais dizem respeito à pessoa do agente, a aspectos subjetivos.

No caso do furto, todas as qualificadoras previstas no § 4º do art. 155 são de ordem objetiva, **com a única exceção do abuso de confiança (inc. II)**. O abuso de confiança se equipara à traição. Como exemplo, podemos citar o furto cometido pelo empregado de muitos anos de uma casa ou empresa.



Se o funcionário não sofre vigilância, tem total acesso aos bens de seu empregador e subtrai, ainda que a coisa tenha valor inferior a um salário mínimo, não poderá ser beneficiado pelo privilégio.

O §3º dispõe que se equipara à coisa móvel a energia elétrica, ou ainda qualquer outra energia capaz de ter valor econômico. Trata-se de uma cláusula de equiparação.

E quanto ao sinal de TV a cabo? Pode ser equiparado à energia elétrica nas hipóteses em que há captação clandestina?

Para o STJ, a conduta de furto de sinal de TV à cabo se subsume à conduta descrita no art. 155, § 3º, do CP. Considera que deve ser ampliado o rol do item 56 da Exposição de Motivos do Código Penal para abranger formas de energia ali não dispostas, considerando a revolução tecnológica a que o mundo vem sendo submetido nas últimas décadas.

Já o **STF** tem precedentes no sentido da atipicidade da conduta, por entender que o sinal de TV a cabo não se equipara à energia elétrica. Ademais, o direito penal não admite analogia *in malam partem*.

Diante da divergência jurisprudencial, é importante observar o enunciado da questão de prova. Veja:

(CESPE/CEBRASPE) *Considere que João, por vários meses, tenha captado sinal de televisão a cabo por meio de ligação clandestina e que, em razão dessa ligação, considerável valor econômico tenha deixado de ser transferido à prestadora do serviço. Nessa situação hipotética, considerando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, João praticou o crime de furto de energia.*

O gabarito do item é correto, pois o examinador, de forma expressa, mencionou que a resposta deveria ser dada de acordo como entendimento do STJ.

Ainda segundo o STJ, no caso de furto de energia elétrica mediante fraude, o adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade. O furto de energia elétrica não pode receber o mesmo tratamento dado ao inadimplemento tributário, de modo que o pagamento do débito antes do recebimento da denúncia não configura causa extintiva de punibilidade, mas causa de redução de pena relativa arrependimento posterior (art. 16 do CP). Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público, no caso de fornecimento de energia elétrica, prestado por concessionária, é de tarifa ou preço público, não possuindo caráter tributário (Informativo 645).

Adulterar o sistema de medição da energia elétrica para pagar menos que o devido configura estelionato e não furto. A alteração do sistema de aferição, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que o real consumo de energia elétrica configura estelionato. Exemplo: as fases “A” e “B” do medidor foram isoladas por um material transparente, que permitia a alteração do relógio fazendo com que fosse registrada menos energia do que a consumida. Esse foi o entendimento consagrado pelo STJ (Informativo 648).

1.8. FURTO QUALIFICADO

São as hipóteses estabelecidas nos incisos I a IV do § 4º, §§ 4º-A, 5º, 6º e 7º

§ 4º, inc. I. Destruição ou rompimento de obstáculo.

A destruição ou rompimento deverá ser sobre uma coisa exterior ao bem que se pretende subtrair (fechaduras, portas, janelas, cadeados).

Se a violência for aplicada contra a coisa pretendida, ou seja, sobre o próprio objeto, não incidirá a qualificadora. **Exemplo:** Se João, para subtrair a bolsa que está dentro do veículo, quebra o vidro e leva a bolsa, haverá furto qualificado pelo rompimento do obstáculo. Por outro lado, se João quebra o vidro para levar o próprio carro, o **furto será, em princípio, simples**.

Por certo que a situação do exemplo acima enseja controvérsia, pois o furto de um acessório ou objeto que esteja dentro do automóvel receberá uma reprimenda maior do que a subtração do próprio veículo, caso o agente quebre o vidro para acessar o interior.



A Terceira Seção STJ, apesar de haver precedentes divergentes no âmbito das turmas, pacificou o entendimento de que a subtração de objeto localizado no interior do veículo automotor mediante rompimento de obstáculo – quebra do vidro – qualifica o furto.

Vale lembrar que a violência contra a coisa poderá ser promovida antes, durante ou após a subtração, mas desde que antes da consumação do delito. Se a destruição for posterior, haverá furto em concurso com o crime de dano.

No caso de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o entendimento prevalente no STF é no sentido da incompatibilidade com a aplicação do **princípio da insignificância**.

Segundo o STJ, na falta de peritos oficiais na comarca, é válido o **laudo pericial que reconheça a qualificadora do furto** referente ao rompimento de obstáculo elaborado por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior, ainda que sejam policiais. A perícia é essencial, uma vez que se trata de crime não- transeunte, isto é, que deixa vestígios.

Com efeito, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP **está condicionada à comprovação do rompimento de obstáculo por laudo pericial**, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios, hipótese na qual a prova testemunhal poderá lhe suprir a falta. A confissão, por si só, não afasta a imprescindibilidade do laudo.

§ 4º, inc. II, primeira parte. Abuso de confiança.

O abuso de confiança é circunstância subjetiva, revelando uma periculosidade do agente que quebra uma relação preexistente de lealdade com a vítima.

Exige-se que o autor do crime tenha um vínculo especial com o ofendido. Não basta que seja empregado da vítima para se considerar que houve abuso de confiança. É preciso que haja a quebra da expectativa da **lealdade** que se esperava. **Exemplo:** se o empregado da empresa furta R\$ 500,00 do caixa, não necessariamente haverá abuso de confiança, caso estivesse sob constante monitoração ou vigilância. Por outro lado, se a empregado tinha a chave do cofre, acesso às contas e movimentações financeiras da empresa e facilidades por ser funcionário de confiança, estará caracterizada a qualificadora. Na hipótese de uma diarista que não tinha as chaves da casa, nem acesso a todos os cômodos, que era vigiada por sistema de câmeras, dentre outras circunstâncias que demonstrem a preocupação com a segurança do local, não há que falar na qualificadora, já que não existia o vínculo de lealdade e confiança entre as partes, de modo a deixar o crime mais reprovável.

Importa estabelecer a diferença entre o furto praticado com abuso de confiança e a apropriação indébita (art. 168 do CP). No **furto qualificado**, o agente se apossa da coisa ilícitamente. O indivíduo não tem a posse da coisa, mas apenas o contato. O dolo de subtração é concomitante ao apossamento. Já na **apropriação indébita**, a pessoa recebe a posse de forma legítima, para depois deliberar sobre o assenhoreamento indevido. A conduta nasce lícita, mas posteriormente passa a ser ilícita. O dolo é superveniente.

Segundo o STJ, é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o furto é qualificado pelo abuso de confiança.

§ 4º, inc. II, segunda parte. Fraude.

O crime de furto poderá ser qualificado quando cometido mediante fraude.

Não se confunde com o estelionato (art. 171 do CP), eis que, no furto, a fraude é utilizada para diminuir a vigilância da vítima sobre bem. A vítima não sabe que o bem sairá da sua esfera de posse. No estelionato, o sujeito ludibria a vítima para que ela, espontaneamente, entregue a coisa. A fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima.

§ 4º, inc. II, terceira parte. Escalada.

A escalada é a utilização de uma via anormal para ingresso no local em que se encontra a coisa a ser subtraída, podendo haver uma penetração subterrânea.

O que se exige é um **esforço fora do comum**. Se o muro é baixo, de fácil transposição por qualquer pessoa, não haverá o furto qualificado pela escalada.

Em regra, é preciso perícia para atestar que o sujeito precisou despender um esforço fora do comum para acessar o objeto a ser subtraído. Todavia, havendo filmagens, é possível haver o

reconhecimento da qualificadora. De acordo com o STJ, **ainda que não tenha sido realizado exame pericial, pode ser reconhecida a presença da qualificadora de escalada do crime de furto na hipótese em que a dinâmica delitiva tenha sido registrada por meio de sistema de monitoramento com câmeras de segurança e a materialidade do crime qualificado possa ser comprovada por meio das filmagens e também por fotos e testemunhos.**

O STF entende que não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado mediante escalada, diante do significativo grau de reprovabilidade do *modus operandi*.

§ 4º, inc. II, quarta parte. Destreza.

O agente, por meio de uma peculiar habilidade, pratica o crime sem que a vítima perceba que foi subtraída.

A jurisprudência condiciona a aplicação da qualificadora da destreza ao caso em que a vítima traga a coisa junto ao próprio corpo. Crime bastante comum em aglomerações urbanas, em ruas de comércio popular, em que existem pessoas altamente especializadas nesse tipo conduta criminosa (batedores de carteira).

§ 4º, inc. III. Emprego de chave falsa.

O professor Damásio de Jesus entende que chave falsa é todo o instrumento, com ou sem a forma de chave, que se destina a abrir fechaduras. Poderá, assim, ser um arame, grampo, prego, chave mixa, etc.

§ 4º, inc. IV. Concurso de pessoas.

É qualificadora objetiva.

Pode ser o concurso com um inimputável, hipótese em que vai incidir também o art. 244-B do ECA.

É inadmissível aplicar ao furto qualificado pelo concurso de pessoas a majorante do roubo, por trazer um patamar de aumento menor. Esse entendimento está consolidado na Súmula 442 do STJ.

§4º-A. Emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

Trata-se de qualificadora introduzida no CP pela Lei nº 13.654/18, publicada em 24 de abril de 2018. A vigência se deu na data da publicação, diante da não previsão de *vacatio legis*.

A pena passa a ser de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (pena equivalente ao crime de roubo).

É uma forma especial de rompimento de obstáculo. Perigo comum é aquele experimentado por um número indeterminado de pessoas.

O objetivo da norma é prevenir e punir de maneira específica a prática de crimes de explosão de caixas eletrônicos, uma vez que são delitos que causam pavor na população, expõem a vida, a integridade física e o patrimônio das pessoas a risco, mesmo ocorrendo nas madrugadas. Trata-se, sem dúvidas, de conduta de maior gravidade e reprovabilidade.

Antes do advento da Lei nº 13.654/18 eram imputados, em concurso formal impróprio, conforme entendimento majoritário, capitaneado por membros do MP, os crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e de explosão majorada (em razão do intuito de obter vantagem pecuniária). Além disso, caso as circunstâncias permitissem, crimes de associação criminosa ou organização criminosa.

Assim, como a pena mínima resultante do concurso de crimes era de 6 anos, a nova previsão legal revela-se mais benéfica, ao prever pena mínima de 4 anos (*novatio legis in melius*).

O agente condenado pelo crime de furto qualificado em concurso formal impróprio com a explosão majorada **pode ser beneficiado pela retroatividade benéfica da nova qualificadora, eis que, nos termos do art. 2º do CP**, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. No mesmo sentido, convém lembrar da Súmula 611 do STF: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.”

Portanto, a lei nova mais benigna sempre retroagirá em benefício do acusado, mesmo que já esteja cumprindo pena, após o trânsito em julgado. A competência para fazer essa análise caberá ao juízo das execuções penais.



A Lei nº 13.964/19, o Pacote Anticrime, modificou a Lei nº 8.072/90 para tornar **hedionda** a figura do roubo qualificado pelo emprego de explosivos. Por se tratar de uma lei nova mais severa, só tem aplicação aos fatos ocorridos após a entrada em vigência, o que ocorreu em 23/01/2020.

§ 5º Furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

O §5º mantém a pena máxima de 8 anos, mas fixa a pena mínima em 3 anos.

Neste caso, após furtar o veículo, o sujeito o **leva para outro Estado ou outro país**.

Se o indivíduo consegue subtrair, mas é detido antes de ultrapassar a fronteira, responderá pela modalidade simples ou pelas qualificadoras do §4º, mas não pelo crime de furto qualificado ora em comento. É necessário haver a transposição efetiva das fronteiras.

Perceba que o §5º não menciona o Distrito Federal, não se admitindo a analogia *in malam partem*. Todavia, há quem entenda em sentido diverso. Vale lembrar que a mesma omissão legislativa existia quanto ao crime de dano, e foi recentemente suprida pela Lei nº 13.531/17.

§ 6º. Furto de semovente domesticável de produção.

Semovente é animal. Existem três espécies de semoventes: animais selvagens, animais domesticados (ou domesticáveis) e animais domésticos.

Semovente domesticável de produção é o animal que foi domesticado ou que pode ser domesticado para ser utilizado como rebanho ou produção. Em regra, incluem-se no conceito os bovinos, ovinos, suínos, caprinos etc.

O legislador, contudo, não fez restrições. Dessa forma, ingressam no conceito de semovente domesticável de produção animais diversos, a exemplo de cães, gatos e aves, desde que tenham finalidade de produção, é dizer, sejam idôneos a gerar algum retorno econômico ao seu titular, como se dá na criação de filhotes destinados à venda.

Não ingressam na proteção do dispositivo legal os animais selvagens, como leão, tigre, girafa, elefante e os animais domésticos que não sejam voltados à produção.

Segundo o §6º, haverá furto qualificado, ensejando pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, **ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração**.

Assim, o § 6º pune mais gravosamente o **abigeato**, nome dado pela doutrina para o **furto de gado**. Vale lembrar que o abigeato abrange não apenas o furto de bovinos, mas também de outros animais domesticáveis, como caprinos e suínos. O agente que pratica abigeato é chamado de abigeator.

Não se pode confundir o **abigeato** com o **abactio**, que consiste no roubo de bovinos, ou seja, na subtração mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

A causa de aumento de pena de 1/3 para o furto durante o repouso noturno é aplicada ao furto de semovente domesticável de produção, eis que se trata de circunstância objetiva.

Da mesma forma, admite-se que haja incidência do furto qualificado-privilegiado (furto híbrido) no caso de o furto de semovente domesticável de produção, desde que estejam preenchidos os requisitos do § 2º, ou seja, o agente seja primário e a coisa seja de pequeno valor. Como dito, a qualificadora é de natureza objetiva.

Se o agente subtrair semovente domesticável de produção praticando, ainda, alguma das condutas previstas no § 4º do art. 155 do CP, será possível a cumulação dos §§ 4º e 6º do art. 155. É o que acontece, por exemplo, no caso do agente que, mediante o rompimento cerca do curral, furta uma vaca (art. 155, § 4º, I c/c § 6º). Nessa hipótese teremos um furto duplamente qualificado.

A pena em abstrato será a prevista no § 4º do art. 155 (de 2 a 8 anos) e a qualificadora descrita no § 6º será utilizada pelo magistrado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

§ 7º. Subtração de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

A pena será de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. O indivíduo não está se utilizando do explosivo ou do artefato análogo para a subtração, mas subtrai acessórios que isoladamente

possibilitem a fabricação do explosivo. Essa conduta, por si só, já será um tipo penal. É autônoma e independe da posterior utilização dos explosivos.

Parcela da doutrina entende ser possível a incidência das figuras do §4º-A e 7º ao mesmo caso. Rogério Sanches Cunha admite a possibilidade de **concurso de crimes** entre o furto do explosivo (de uma empresa especializada) e o posterior furto (de caixa eletrônico ou cofre) com a utilização do mesmo explosivo. Condutas distintas, que atingem patrimônios diversos e que, portanto, não se podem confundir. Não haveria *bis in idem*, já que os bens jurídicos tutelados das vítimas são diversos, isto é, patrimônios distintos sendo atingidos.

1.8. ART. 156. FURTO DE COISA COMUM

Segundo o art. 156, constitui crime de furto de coisa comum a conduta de subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. É crime de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal. Admitida a transação penal, resta inviável o acordo de não persecução penal.

O §1º estabelece que **somente se procede mediante representação**.

Tem-se, aqui, um tipo menos grave de furto, em que se tutela não a propriedade alheia, mas sim a comum, isto é, pertencente a várias pessoas, inclusive o próprio sujeito ativo. O crime é próprio, já que somente pode ser praticado pelo condômino, coerdeiro ou sócio.

O bem visado pelo agente deve estar na posse de uma terceira pessoa, outro coerdeiro, outro sócio ou outro condômino. Se o bem estiver na posse daquele que, em tese, subtraiu, o delito será de apropriação indébita (art. 168 do CP).

Por sua vez, o §2º estabelece que **não é punível a subtração de coisa comum fungível**, cujo valor não excede a quota a que tem direito o agente. Há aqui uma **causa excludente de ilicitude especial**, já que o legislador estabeleceu a impunibilidade da subtração, e não do agente. É necessário que estejam presentes os dois requisitos: a coisa comum deve ser fungível e o valor da subtração não pode exceder a quota a que o sujeito ativo teria direito. Coisa fungível é aquela que pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade.

QUESTÕES

(CEBRASPE – Delegado PF – 2018) Sílvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares, com o propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Sílvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Sílvio furtar o objeto sem que fosse notado.

Gabarito: ERRADO. Conforme a Súmula 567 do STJ, a existência do sistema de monitoramento eletrônico, por si só, não torna o crime de furto impossível.



CAPÍTULO 31 — DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: DO ROUBO E DA EXTORSÃO

O art. 157 estabelece: “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.”

O roubo é crime complexo, resultante da fusão de outros delitos, a saber, furto e lesão ou furto e ameaça. É também pluriofensivo, na medida em que tutela mais de um bem jurídico: patrimônio, integridade física ou liberdade individual.

Classifica-se como crime bicomum, não se exigindo qualidade especial do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Pode ser praticado de forma livre, é instantâneo, de dano, e unissubjetivo, como regra.

O elemento subjetivo é o dolo, somado ao especial fim de agir, o *animus rem sibi habendi*, isto é, o fim de assenhoreamento definitivo da coisa. Para a tipificação da conduta, é essencial verificar que o indivíduo se apossa ilicitamente do bem e passa a se comportar como se dono fosse.

Não se aplica o princípio da insignificância ao roubo, diante da pluriofensividade, revelada no emprego da violência e da grave ameaça. O desvalor da ação é elevado.

Não há previsão de roubo privilegiado.

A figura do *caput* do art. 157 é chamada de roubo próprio. Pode ser praticado mediante grave ameaça, também chamada de violência moral ou *vis compulsiva*. Trata-se da promessa de mal grave, por gestos, palavras ou símbolos. O potencial intimidatório da ameaça deve ser verificado no caso concreto. O porte simulado de arma, a arma defeituosa inapta a disparos e simulacro de arma de fogo (arma de brinquedo) caracterizam a elementar grave ameaça, mas não são aptos a majorar o delito.

A violência própria, por sua vez, é a *vis corporalis* ou *vis absoluta*. Consiste no emprego de **força física sobre a vítima**. **Exemplo:** lesão corporal ou vias de fato, para paralisar ou dificultar os movimentos.

Neste ponto, surge o questionamento: a trombada caracteriza furto ou roubo? A hipótese concreta deve ser analisada, pois há divergência doutrinária.

É necessário analisar o caso, não sendo possível afirmar, *a priori*, que a trombada caracterize um crime ou outro.

Em geral, o contato físico para distração, sem ofensa à integridade corporal, caracteriza o furto. Exemplo: crime ocorrido em multidões, shows, ônibus, etc. Já o contato físico intenso ou violento para eliminar ou reduzir a defesa caracteriza o **roubo**.

Por fim o roubo próprio pode ser praticado mediante violência imprópria, entendida como sendo qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. É o **meio ardiloso ou subreptício**. **Exemplo:** drogar ou embriagar completamente a vítima, para então lhe subtrair os bens (golpe “Boa noite, Cinderela”).

No §1º do art. 157 temos a figura do roubo impróprio, por aproximação ou por equiparação. Assim, na mesma pena do *caput* incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Há uma diferença marcante entre o roubo próprio e o impróprio.

Na forma do *caput*, a grave ameaça ou a **violência, que pode ser própria ou imprópria**, é empregada **antes ou durante** a subtração.

Já no roubo impróprio (§ 1º), a grave ameaça ou a **violência (somente própria)** é empregada **posteriormente** à subtração. A grave ameaça ou a violência são utilizadas para o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou terceiro.

Portanto, o roubo impróprio **não admite a violência imprópria** (qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência), por incompatibilidade e ausência de previsão legal.

É possível a tentativa de roubo impróprio? Há divergência doutrinária. Prevalece o entendimento de que **não é possível**, já que o crime se consuma com o emprego da violência, após o



agente se tornar o possuidor da coisa (**primeiro se apodera do bem e depois emprega a violência**). Essa é a posição do STJ e de Damásio de Jesus. Mirabete, por sua vez, entende ser possível o *conatus*, quando o agente, depois de se apoderar da coisa, tenta empregar violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

1. CONSUMAÇÃO DO ROUBO PRÓPRIO

Segundo o posicionamento tradicional da doutrina, o roubo é crime eminentemente **material**, dependendo da produção de resultado naturalístico para a consumação. Assim, somente estaria consumado com a retirada do bem da esfera da vigilância da vítima e sua livre disponibilidade pelo agente, ainda que por breve período de tempo.

Esse entendimento, contudo, foi superado pela jurisprudência. A posição atual dos Tribunais Superiores é pela adoção da teoria da *amotio*, bastando a inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica e desviada do bem pelo seu autor, a teor do que dispõe a **Súmula 582 do STJ**: “consoma-se o crime de roubo **com a inversão** da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.”

Portanto, com a adoção da teoria da *amotio*, o crime de roubo passa a ter feições de crime formal (não depende de resultado material naturalístico), já que basta o emprego da violência ou grave ameaça, com a consequente inversão da posse do bem, ainda que não se opere a retirada da esfera de vigilância da vítima.

2. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, AGRAVADO OU MAJORADO (ROUBO PRÓPRIO OU IMPRÓPRIO)

Art. 157, § 2º, CP: a pena aumenta-se de um terço até metade na terceira fase da dosimetria.

É tecnicamente errado se falar em roubo qualificado diante das circunstâncias do §2º, uma vez que se tratam de causas de aumento de pena. O roubo não é qualificado, mas circunstanciado ou majorado.

Art. 157, § 2º, inc. I: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma. Tal majorante foi REVOGADA pela Lei nº 13.654/18.

Prevalecia a orientação de se tratar de arma em sentido amplo, abrangendo tanto as armas de fogo (revólver, pistola, espingarda, metralhadora, fuzil) quanto as armas brancas, isto é, aquelas que não se encaixam no conceito de arma de fogo. A arma branca pode ser *própria* (produzida para ataque e defesa) ou *imprópria* (produzida sem finalidade específica de ataque e defesa, como um martelo, por exemplo). Ambas as hipóteses ensejavam a incidência do aumento de pena.

A Lei nº 13.654/18 introduziu no CP o § 2º-A, nos termos do qual a pena aumenta-se da fração fixa de 2/3 (dois terços) no seguinte caso:

Inc. I: se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

NOVATIO LEGIS IN MELLIUS: a Lei nº 13.654/18 se mostrou benéfica, ou seja, ao restringir a causa de aumento de pena ao emprego de arma de fogo, deve a lei penal retroagir para retirar a majorante relativa a todos os roubos cometidos com objetos outros que não armas de fogo em sentido estrito cometidos até 22/01/2020. Em 23/01/2020, com a vigência da Lei nº 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime, foi restaurada a majorante do roubo com emprego de arma branca no inc. VII do § 2º.

Comentários mais detalhados sobre o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo serão feitos logo abaixo.

Art. 157, § 2º, inc. II: se há o concurso de duas ou mais pessoas.

Cuida-se de exemplo de **crime acidentalmente coletivo**, que pode ser cometido por um único agente, não sendo hipótese de concurso necessário, mas a pluralidade de pessoas acarreta a majoração da pena na terceira fase da dosimetria.

Aplica-se a majorante ainda que o comparsa seja **inimputável** ou **desconhecido** (não identificado).

Se o roubo é cometido em concurso com **menor de idade**, deve ser imputado também o crime do art. 244-B do ECA. A hipótese será de concurso formal (uma só ação, dois crimes). Não é necessário investigar se o menor foi, de fato, corrompido pelo maior, basta a simples presença do menor no contexto da prática delitiva, independentemente do seu passado infracional. A corrupção de menores é crime formal, nos termos da Súmula 500 do STJ.

Art. 157, § 2º, inc. III: se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

Busca-se dar maior proteção às pessoas que trabalham com transporte de valores alheios. Não incidirá a majorante se o transportador for o proprietário dos bens.

A hipótese abarca o transporte de dinheiro ou qualquer outro bem de cunho econômico, inclusive contra os Correios. Com efeito, o STJ considerou possível a aplicação da majorante quando a vítima transportava cosméticos de expressivo valor econômico e liquidez (RESP 1.309.966/RJ).

Essa circunstância deve ser de conhecimento do agente, sob pena de responsabilização penal objetiva.

O crime tem dupla subjetividade passiva: tanto o proprietário dos valores, bem como aquele que os transportava serão vítimas da conduta delitiva.

Para fins de tipificação da conduta, o serviço de transporte pode decorrer de ofício (funcionário de empresa) ou ocasionalmente. É indiferente se o transporte ocorre em uma mesma localidade ou entre locais ou cidades distantes.

Art. 157, § 2º, inc. IV: se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

A intenção do legislador é punir de forma mais grave o indivíduo que transporta o veículo para outro estado ou para fora do Brasil, dificultando a localização e recuperação do bem e facilitando o comércio ilícito. A majorante incide, assim, a um resultado posterior à subtração (transporte do bem para outro estado ou exterior).

O conceito de veículo automotor está no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro. É o veículo movido a motor de propulsão que circule por seus próprios meios (carro, moto, caminhão, ônibus). Compreende também o ônibus elétrico que não circule sobre trilhos.

Para a incidência da majorante não basta a simples intenção do agente de levar o veículo para outro estado/exterior, devendo haver a efetiva transposição a fronteira.

Art. 157, § 2º, inc. V: se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

A vítima é mantida em poder do agente para a consumação do crime ou sucesso da fuga. **Exemplo:** indivíduo que aborda um motorista de táxi/aplicativo objetivando subtrair o veículo e passa a transitar pela cidade por cerca de 20 ou 30 minutos, até chegar ao ponto em que decide abandonar o motorista e seguir no carro sozinho. A restrição da liberdade foi apenas uma etapa para garantir a consumação do crime.

A restrição deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, por tempo superior ao necessário à execução do roubo.

Importa destacar que se trata de restrição e não privação da liberdade. Nesta última hipótese, configura-se o crime de sequestro ou cárcere privado.

A Lei nº 13.964/19 modificou o texto da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) e passou a prever essa modalidade de roubo majorado como crime hediondo. Por se tratar de *novatio legis in pejus*, somente vai se aplicar aos delitos cometidos a partir de 23/01/2020.

Art. 157, § 2º, inc. VI: se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

Aplicam-se, no geral, os mesmos comentários feitos quanto à qualificadora do furto, com a diferença de que aqui a subtração se dá mediante violência ou grave ameaça à pessoa.



Não há, necessariamente, o emprego posterior do explosivo. A subtração das substâncias ou de seus acessórios já tipifica a conduta.

Art. 157, § 2º, inc. VII: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

Conforme já mencionado anteriormente, a causa de aumento pelo emprego de arma branca foi restabelecida pela Lei nº 13.964/19, o Pacote Anticrime. Vai se aplicar aos fatos praticados após a sua vigência. Arma branca é todo objeto que, embora não tenha sido fabricado com finalidade bélica, é capaz de intimidar e ferir, a exemplo das ferramentas em geral.

Art. 157, § 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Algumas observações importantes merecem atenção sobre o roubo cometido com arma de fogo.

A arma deve ser efetivamente empregada, exibida à vítima. O ofendido deve ser capaz de ver que está sendo empregada uma arma. Se o indivíduo faz a abordagem pelas costas e encosta um cano, mas a vítima não tem condições de detalhar o objeto utilizado, é possível a capitulação da conduta no crime de roubo, pela grave ameaça exercida, mas não será majorado pelo emprego de arma de fogo, já que não foi possível fazer a prova de que o instrumento utilizado era, efetivamente, uma arma de fogo.

A simulação do porte de arma (gesto por baixo das vestes) e a arma de brinquedo caracterizam a elementar da grave ameaça, mas não autorizam a incidência da causa de aumento de pena. A Súmula 174 do STJ foi cancelada.

Na hipótese de concurso de agentes e apenas um deles emprega a arma: por se tratar de circunstância de caráter objetivo, comunica-se a **todos** os coautores e partícipes (artigos 29 e 30 do CP), por força da adoção da teoria unitária ou monista quanto ao concurso de agentes.

Quanto ao simulacro de arma de fogo não apreendido, o ônus da prova no sentido de que não se tratava de uma arma real é da defesa. Incidirá a majorante se o simulacro não for apreendido e a defesa não for capaz de fazer prova em contrário ao que está sendo alegado. Prevalecerá a impressão, o relato da vítima de que foi ameaçada por uma arma de fogo.

Segundo o STF, é desnecessária a apreensão e perícia da arma, podendo seu potencial lesivo ser comprovado por outros meios.

Caso a arma de fogo seja apreendida e constatada a sua ineficácia absoluta, isto é, inaptidão completa para efetuar disparos, afasta-se a majorante. Todavia, se a ineficácia é apenas relativa (a arma tem um defeito, mas, por vezes, dispara) prevalece o entendimento da incidência da causa de aumento de pena.

A arma desmuniada enseja debate. Não há entendimento consolidado sobre o tema. Julgados recentes do STJ tem afastado a incidência da majorante, por considerar que, no momento da prática do crime, a arma desmuniada equivale à arma totalmente inapta a efetuar disparos. A razão de ser da causa de aumento de pena é o potencial lesivo da arma. Inexistindo, afasta-se a majorante.³⁸

³⁸PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ARMA DESMUNICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a utilização de arma inidônea, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena, que está vinculado ao potencial lesivo do instrumento, quando não puder ser considerado diante de ineficácia para a realização de disparos, por encontrar-se desmuniada.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1721936/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



Vale pontuar que não há crime autônomo de porte de arma (art. 14 ou 16 da Lei nº 10.826/03), se somente houver prova do emprego da arma de fogo no exato momento da subtração patrimonial, pela aplicação do **princípio da consunção (absorção)**, uma vez que o porte funciona como crime-meio para a prática do roubo, que é o crime-fim.

Inc. II: se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

A previsão legal é semelhante à qualificadora do furto. Aqui, tem-se uma causa de aumento de pena para o roubo. O aumento se dá em patamar fixo de 2/3 na terceira fase da dosimetria. **Exemplo:** indivíduos invadem um estabelecimento comercial durante o dia, subjugam as pessoas presentes mediante grave ameaça e colocam explosivos para abrir um cofre. Imputa-se o crime de roubo com pena majorada em dois terços.

Importa ressaltar ainda que, embora o referido pacote tenha tornado também hedionda a figura do furto qualificado pelo emprego de explosivos ou artefatos análogos, não procedeu da mesma forma quanto ao roubo majorado pelo mesmo motivo. Sem dúvidas, tal lapso legislativo gera perplexidades. Não será possível considerar o roubo hediondo nessa hipótese, sob pena de violação ao princípio da legalidade, bem como por ser vedada a analogia *in malam partem* no Direito Penal.

Art. 157, § 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Tal previsão foi inserida pela Lei nº 13.964/19. Trata-se de majorante, que incidirá na terceira fase da dosimetria.

Conforme dispõe o art. 2º, inc. II, do Decreto nº 9.847/19, são de uso restrito as armas de fogo automáticas e semiautomáticas ou de repetição que sejam: a) não portáteis; b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules.

São de uso proibido, por sua vez, nos termos do art. 2º, inc. III, do mesmo decreto: a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária; ou b) as armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos. Exemplos: armas em forma de caneta ou bengala.

A causa de aumento aplica-se tão somente às armas de fogo de uso restrito ou proibido. Não se cogita da aplicação quando se tratar de arma de uso permitido, nem mesmo se teve suas características originais modificadas ou numeração raspada.

Vale lembrar que a Lei nº 13.964/19, o Pacote Anticrime, modificou a Lei nº 8.072/90 para prever como hediondos quaisquer crimes de roubo praticados com arma de fogo, sejam de uso permitido, restrito ou proibido (§ 2º-A e § 2º-B).

3. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

O art. 68, parágrafo único, do CP dispõe que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal superior.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte superior, o uso de arma desmunicada, no delito de roubo, caracteriza o emprego da grave ameaça, mas não pode ser utilizada como causa de aumento - art. 157, § 2º, I, do CP. Precedente.

3. Agravamento regimental improvido.

(AgRg no AREsp 722.298/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, o magistrado pode desprezar uma ou mais causas de aumento.

Vale recordar o teor da Súmula 443 do STJ, segundo a qual o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Com a entrada em vigor das novas majorantes estabelecidas no § 2º-A e § 2º-B, há quem entenda pela possibilidade de flexibilização da regra estabelecida na Súmula 443. Segundo defende o prof. Rogério Sanches Cunha, caso um roubo seja cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo de uso restrito, poderia o magistrado tanto aplicar somente o aumento do dobro relativo à arma, como também poderia fazer incidir o incremento de 1/3 a ½ pelo concurso de agentes.³⁹

Quanto aos percentuais de aumento de pena para o roubo circunstanciado do § 2º, para concursos do Ministério Público e Magistratura pode-se adotar as seguintes frações: uma causa, 1/3; duas causas, 2/5; três causas, ½.

4. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO

No art. 157, §3º, temos o roubo qualificado pelo resultado lesão grave ou pela morte. Note-se a alteração nos patamares das penas em abstrato.

A Lei nº 13.654/18 desmembrou o referido § 3º em dois incisos.

No inc. I está previsto o resultado lesão corporal grave (compreende também a gravíssima, §§ 1º e 2º do art. 129), com pena de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa. Anteriormente à Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) essa figura não tinha natureza hedionda, passando a ter em 23/01/2020.

Já no inc. II temos o roubo com resultado morte, o latrocínio, cuja pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. Também crime hediondo.

Não se aplicam as causas de aumento de pena do § 2º, uma vez que os patamares de fixação da pena já são mais graves.

Tratando-se de crime qualificado pelo resultado, estará consumado com a produção de lesão grave/gravíssima na vítima, ainda que a subtração não se aperfeiçoe.

Os crimes qualificados pelo resultado não são, necessariamente, preterdolosos (dolo no antecedente e culpa no consequente). Pode haver dolo no consequente, no resultado. Inclusive, a fim de verificar a tentativa no caso do roubo qualificado pela lesão grave, é necessário se verificar o dolo quanto à produção da lesão corporal grave.

4.1. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, INC. II)

Trata-se de crime complexo (fusão de roubo e homicídio) e pluriofensivo (ofensa ao patrimônio e vida). É hediondo, seja consumado ou tentado. É crime contra o patrimônio, pois a ofensa à vida é meio para a subtração patrimonial.

A competência é do juízo singular (e não do Tribunal do Júri), conforme Súmula 603 do STF.

Para a caracterização do latrocínio é essencial que o agente empregue dolosamente a violência contra a vítima e exista relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte. **Exemplo:** se o indivíduo é contratado para tirar a vida de um desafeto do mandante e, após a consumação do crime de homicídio, decide furtar os pertences pessoais da vítima, não é hipótese de latrocínio. O dolo de subtrair é subsequente à intenção de matar. Haverá concurso de crimes, pois não há que se falar em relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte. O crime foi de homicídio e, posteriormente, sobreveio o dolo de subtrair. O concurso será de homicídio e furto. As vítimas do furto serão os herdeiros do falecido.

³⁹ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial**. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 327.



Ademais, a violência empregada no latrocínio deve ser dolosa. **Exemplo:** se o indivíduo ingressa em estabelecimento comercial com uma arma de fogo e resolve, para intimidar os clientes, efetuar um disparo na parede. O projétil ricocheteia e acaba atingindo um dos clientes, provocando sua morte. Aqui, configura-se a prática de latrocínio, visto que o indivíduo teve o dolo de efetuar o disparo. Havendo dolo na prática da violência para intimidar ou amedrontar as vítimas, responderá o sujeito pelo resultado, doloso ou culposo, que advier dessa violência, empregada dolosamente.

Assim sendo, a violência empregada no latrocínio é sempre dolosa. O resultado morte pode advir de dolo ou culpa.

O latrocínio será **consumado** quando:

- Subtração consumada e morte consumada.
- Subtração tentada e morte consumada (Súmula 610 STF).

Por sua vez, temos latrocínio **tentado** quando:

- Subtração tentada e morte tentada.
- Subtração consumada e morte tentada.

Latrocínio e pluralidade de mortes: será crime único se o roubo é voltado contra um único patrimônio, embora mais de uma vítima seja morta. Magistrado poderá aumentar a pena na primeira fase (art. 59, consequências do crime – primeira fase da dosimetria da pena). Este é o entendimento do STF; STJ tem julgados em sentido diverso.

Mais de um patrimônio atingido: concurso formal impróprio (art. 70, parte final, CP). A hipótese é de desígnios autônomos. Aplica-se, portanto, o concurso material (somatório das penas).

Concurso de agentes: se o roubo é praticado em concurso de pessoas e somente um dos coautores provoca a morte, o latrocínio consumado é imputado a todos os envolvidos (art. 29 do CP, teoria unitária ou monista quanto ao concurso de pessoas). **Exemplo:** dois indivíduos ingressam em agência bancária com a intenção de subtrair valores, um deles armado. Entretanto, no momento da fuga, um dos agentes, por receio de ser abordado, efetua disparo e mata um cliente do banco. Neste caso, o latrocínio consumado também será imputado ao indivíduo que já havia conseguido empreender fuga no momento do disparo efetuado pelo seu comparsa. Ao praticar o roubo em concurso de agentes, assumiu o risco do resultado morte, ainda que não a tenha praticado.

Segundo o STJ, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os crimes de roubo e latrocínio, por não serem delitos da mesma espécie (embora sejam do mesmo gênero). Haverá concurso material de crimes.

QUESTÕES

1- (MPSC – 2019) Assinale Verdadeiro ou Falso

QUESTÃO: () Conforme jurisprudência dominante no STJ, nos crimes de furto e roubo (arts. 155 e 157 do CP) a consumação do fato típico somente ocorre com a posse mansa e pacífica, o que não se verifica no caso de perseguição imediata do agente e recuperação da coisa subtraída.

GABARITO: FALSO

QUESTÃO: () No crime contra o patrimônio em que a coisa é subtraída e a violência é praticada com a intenção de matar a vítima, sem que esta chegue a morrer, a conduta é tipificada como tentativa de latrocínio, e não como roubo consumado, nem como latrocínio consumado (art. 157 do CP), conforme definido pela jurisprudência dominante no STJ.

GABARITO: VERDADEIRO



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



2- (CEBRASPE – TJPR – 2019 adaptada) Múcio, com o objetivo de ter a posse de um carro, abordou Cláudia, que dirigia devagar na saída de um estacionamento. Ao surpreendê-la, ele fez sinal para que ela parasse e, após Cláudia sair do veículo, Múcio a colocou, com violência, dentro do porta-malas, para impedir que ela se comunicasse com policiais que estavam próximos ao local. Horas depois do crime, Múcio liberou a vítima em local ermo. Nessa situação hipotética, a conduta de Múcio o sujeita a responder pelo crime de

A extorsão mediante sequestro.

B roubo em concurso material com sequestro.

C extorsão qualificada mediante a restrição da liberdade da vítima.

D roubo circunstanciado, pelo agente ter mantido a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade

Gabarito: D

3- (CEBRASPE- PCGO -2017) Álvaro e Samuel assaltaram um banco utilizando arma de fogo. Sem ter ferido ninguém, Álvaro conseguiu fugir. Samuel, nervoso por ter ficado para trás, atirou para cima e acabou atingindo uma cliente, que faleceu. Dias depois, enquanto caminhava sozinho pela rua, Álvaro encontrou um dos funcionários do banco e, tendo sido por ele reconhecido como um dos assaltantes, matou-o e escondeu seu corpo. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A) Álvaro cometeu os crimes de roubo qualificado e homicídio simples.

B) Samuel cometeu os crimes de roubo simples e homicídio culposo.

C) Álvaro cometeu os crimes de roubo e homicídio qualificados.

D) Álvaro cometeu o crime de homicídio qualificado e será responsabilizado pelo resultado morte ocorrido durante o roubo.

E) Álvaro e Samuel cometeram o crime de roubo qualificado pelo resultado morte.

Gabarito: D

5. ART. 158. EXTORSÃO

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.”

A extorsão é, por certo, crime contra o patrimônio. **Quando qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, será crime hediondo (art. 158, §§ 2º e 3º).**

Trata-se de crime pluriofensivo, pois tutela o patrimônio e a integridade física e/ou a liberdade.

Constranger significa retirar a capacidade de autodeterminação, em virtude da violência ou da grave ameaça.

O crime de extorsão é classificado como formal, pois independe do resultado naturalístico para a sua consumação, e instantâneo, de consumação antecipada ou de resultado cortado (Súmula 96 do STJ). Assim, o delito se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida. Se obtida a vantagem, constituirá mero exaurimento.

Diferenciação entre roubo e extorsão: é preciso analisar os verbos núcleos do tipo e as circunstâncias fáticas. Ambos são crimes contra o patrimônio, cometidos com violência ou grave ameaça.

Na extorsão, a própria vítima, coagida, entrega o bem. Já no roubo, a coisa pode ser entregue ou subtraída. Assim, se a coisa é subtraída, sempre haverá roubo. Já na extorsão, **é imprescindível a colaboração da vítima**. No roubo, a coisa subtraída é móvel. Já na extorsão, a vantagem econômica indevida poderá estar relacionada a bem imóvel.

Exemplos de extorsão: falsos sequestros com exigência de resgate; grave ameaça exercida para o fornecimento de senha bancária para saques.



Segundo o STF, não é possível se reconhecer continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão, pois não são crimes de mesma espécie, embora seja do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio).

Art. 158, § 1º: causas de aumento de pena

Incidem na terceira fase da dosimetria.

Crime cometido por duas ou mais pessoas: necessariamente coautoria. Para a caracterização da majorante, é preciso que os comparsas pratiquem atos executórios. Não é necessário que sejam os coautores imputáveis ou que todos sejam identificados.

Crime cometido com emprego de arma: prevalece o entendimento de se tratar de arma em sentido amplo. O simulacro de arma de fogo não se presta para a incidência da majorante.

Art. 158, § 2º: extorsão qualificada

Remete ao roubo qualificado (§ 3º).

Com resultado lesão grave/gravíssima ou morte, causado a título de dolo ou culpa. Crime hediondo, nas duas formas, conforme previsão introduzida pela Lei nº 13.964/19.

Art. 158, § 3º: extorsão mediante restrição de liberdade da vítima.

Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. É crime hediondo (Lei nº 13.654/19).

Trata-se de hipótese de extorsão qualificada, em que os patamares de pena, mínimo e máximo, são alterados.

É o crime conhecido como *sequestro-relâmpago* ou *saidinha de banco*. A restrição de liberdade da vítima se dá por um lapso temporal suficiente para a obtenção de senha bancária e efetuar saques.

Tem-se um crime remetido, pois se reporta às penas previstas em outro dispositivo legal, qual seja, as do art. 159, §§ 2º e 3º, CP.

Não se confunde com a extorsão mediante sequestro, prevista no art. 159 do CP.

No presente caso, não há privação, mas somente restrição da liberdade da vítima. A privação é aquela que se dá por um lapso temporal bastante considerável. Exemplo: quando a vítima é mantida confinada dentro de um mesmo local, privada de contato exterior.

QUESTÕES

1- (CESPE Delegado - BA/2016) A extorsão é considerada pelo STJ como crime material, pois se consuma no momento da obtenção da vantagem indevida.

Gabarito: ERRADO.

6. ART. 159. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

O art. 159 prevê: “sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena: reclusão, de oito a quinze anos.”

O crime é hediondo em todas as suas formas.

É classificado como crime complexo, pois resulta da junção da extorsão (art. 158 do CP) com o sequestro (art. 148 do CP).

Sequestrar significa privar da liberdade de locomoção por tempo relevante.

O tipo estabelece um especial fim de agir, consistente na obtenção, para si ou para outrem, de qualquer vantagem. Apesar de não haver referência expressa à natureza da vantagem, prevalece o entendimento de que deve ter caráter econômico e indevido, visto se tratar de crime contra o patrimônio.



Ademais, temos hipótese de crime formal, que se consuma com a privação da liberdade da vítima, independentemente da efetiva obtenção da vantagem. Caso recebido o preço do resgate, haverá mero exaurimento. Tem por característica, também, ser crime permanente, já que a consumação se prolonga ao longo do tempo, enquanto perdurar a privação da liberdade da vítima.

Formas qualificadas: art. 159, §§ 1º a 3º (também hediondas).

§ 1º – Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.

A nomenclatura “bando ou quadrilha” está em desuso, devido à alteração do art. 288 do CP. É a hipótese, portanto, de associação criminosa.

§ 2º – Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave.

§ 3º – Se resulta a morte.

Concurso de qualificadoras: o magistrado deve se utilizar da mais grave para qualificar o crime (alteração nos patamares mínimo e máximo da pena) e a outra como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.

Art. 159, § 4º. Colaboração premiada como causa especial de diminuição de pena.

Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços. Não pode ser aplicada por delegados de polícia ou pelo MP, mas somente pelo magistrado.

Por se tratar de tema afeto à individualização da pena, o reconhecimento é exclusivo do Judiciário, incidindo na terceira fase da dosimetria.

Segundo o STJ, quando as informações do agente forem eficazes para a libertação da vítima (com a integridade física preservada), a causa de diminuição de pena é de incidência obrigatória, passando a ser direito subjetivo do acusado.

7. ART. 160. EXTORSÃO INDIRETA

De acordo com o art. 160, configura extorsão indireta a conduta de exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro.

A pena é de reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Cabe suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

O tipo busca coibir atos torpes de credores (agiotas, especialmente) em face de devedores.

Trata-se de um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois o agente poderá praticá-lo por meio da exigência ou recebimento. Se incidir nos dois verbos, no mesmo contexto fático, haverá crime único.

A exigência é a solicitação em tom de ameaça. No que tange ao receber, parte do próprio sujeito passivo a iniciativa de oferecer a garantia.

Nas duas condutas é preciso que o sujeito ativo esteja abusando da situação em que se encontra a vítima. Diante disso, o sujeito ativo exige da pessoa algum documento que possa dar causa à instauração de processo criminal contra essa pessoa ou contra um terceiro. Há dolo de aproveitamento, isto é, abuso da situação de dificuldade, vulnerabilidade da vítima. O crime é comum.

A consumação dependerá do núcleo do tipo. Na modalidade *exigir*, o crime é formal, bastando a simples exigência para sua consumação. Já no núcleo *receber* é crime material, consumando-se no momento em que o sujeito ativo recebe o documento que pode dar origem ao processo criminal. Se, depois de obter o documento, o agente efetivamente dá início ao procedimento criminal do qual sabe ser a vítima inocente, há concurso material do crime de extorsão indireta com denúncia caluniosa (art. 399 do CP).

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 32 — DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: DA USURPAÇÃO

1. ART. 161. ALTERAÇÃO DE LIMITES

Segundo o art. 161, configura o crime de alteração de limites a conduta de suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. A pena é de detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, sujeita ao rito do Juizado Especial Criminal, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

O sujeito ativo é o proprietário, possuidor ou futuro comprador do imóvel vizinho. O crime exige que o sujeito venha a suprimir ou deslocar tapume ou outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se de parte ou do todo da coisa imóvel alheia. **Exemplo:** vizinho que invade o terreno do outro, alterando a linha divisória do terreno.

O sujeito passivo é proprietário ou possuidor cujas áreas vizinhas sejam alteradas em razão da conduta criminosa do sujeito ativo.

O crime é cometido somente na forma dolosa, consistente na vontade de suprimir ou de deslocar o tapume ou sinal indicativo de linha divisória, devendo ter a finalidade de apropriar-se no todo ou em parte da coisa imóvel alheia (especial fim de agir).

O crime é de consumação antecipada, ou seja, é formal. Com a mera supressão ou deslocamento da linha divisória já estará consumado, ainda que o sujeito não consiga efetivamente se apoderar da coisa imóvel alheia.

Art. 161, §1º, inc. I. Usurpação de águas

Segundo o art. 161, § 1º, inciso I, na mesma pena do *caput* incorre quem desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias.

O crime é **comum**, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não necessariamente o vizinho. Criminaliza-se o impedimento de uso da água.

O sujeito passivo é o proprietário ou possuidor da água que foi desviada ou represada.

As águas são parte do solo (art. 79 do Código Civil), por essa razão são equiparadas a bens imóveis.

Se a água é canalizada, passa a ser de propriedade da empresa concessionária de serviço público. Se a água ingressa em reservatório particular, passa a pertencer ao dono do reservatório. Assim, se, após a canalização ou mantida em reservatório particular, a água for subtraída, não haverá o crime de usurpação de água, mas sim furto (art. 155 do CP).

O crime é formal, consumando-se quando há o desvio ou represamento da água alheia, independentemente de um real proveito por quem represou ou desviou.

Art. 161, § 1º, inc. II. Esbulho possessório

Na mesma pena do *caput* incorre quem invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. A pena será de detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

Trata-se de crime de concurso necessário, pois deve haver pelo menos 3 pessoas. É indiferente se o crime é praticado na zona urbana ou rural.

Qualquer pessoa poderá ser o sujeito ativo do crime (é comum). O sujeito passivo é quem detém a posse legítima ou a propriedade do imóvel que sofre a invasão.

O delito se consuma no momento da invasão, que consiste no ingresso à força, independentemente do titular ficar privado da posse. Isto é, a partir do momento que os invasores ingressam à força na propriedade, ainda que sejam repelidos imediatamente e ainda que o titular não fique privado da posse, o crime já estará consumado. Portanto, é crime formal.

Havendo o esbulho, se houver a alteração de limites (crime-meio), esta ficará absorvida, pois é etapa necessária do esbulho cometido. Incide o princípio da consunção ou absorção.

Se o sujeito ativo se utiliza da violência (§2º), haverá concurso material do esbulho possessório com qualquer dos delitos contra a pessoa.

Nos termos do § 3º, a ação penal, **se a propriedade é particular, e não há emprego de violência**, será privada (somente se procede mediante queixa).

Por outro lado, sendo o esbulho cometido em propriedade pública, o crime será de ação penal pública incondicionada. Da mesma forma, será de **ação penal pública incondicionada** caso o crime de esbulho seja em propriedade particular e o delito se dê por meio de violência.

Invasão de propriedades rurais para fins de reforma agrária. Há crime de esbulho possessório? Há duas correntes sobre o tema.

Para a primeira linha de pensamento, não há crime, por se tratar de movimento social destinado a pressionar as autoridades pela reforma agrária. Importa em prática de ilícito civil e pode resultar na prática de outros delitos, como furtos e roubos, mas não o esbulho possessório, **por ausência de dolo**. Nesse sentido, há precedentes do STJ e decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski no HC 91.616/RS (2007).

Para a segunda corrente, há crime, mesmo quando se trata de propriedade alegadamente improdutiva, pois se trata de atividade à margem da lei, com emprego arbitrário da força. A reforma agrária não pode ser pressionada pela prática de atos ilícitos. Nesse sentido, ADI 2.213/DF, Informativo 262, rel. Min. Celso de Mello.

2. ART. 162. SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS

O art. 162 diz que constitui o crime a conduta de suprimir ou alterar, **indevidamente**, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. A pena é de detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. A infração é de **médio potencial ofensivo**, não cabe transação penal, mas sim a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O crime é comum, podendo qualquer pessoa praticar, exceto o proprietário. Na tipo penal há referência expressa a *gado alheio*. Os semoventes são considerados coisas móveis para fins penais. Nesse sentido, o possuidor pode praticar o crime. Por sua vez, a sujeito passivo é o proprietário do gado ou do rebanho.

Para que haja a configuração do crime, não basta que ocorra a supressão ou a alteração, **sendo necessário que essa supressão ou alteração da marca seja indevida**. O elemento normativo do tipo será valorado pelo magistrado para fazer a subsunção da conduta ao tipo penal.

Se o agente furta o animal e faz a alteração ou supressão da marca, haverá a **absorção do crime em estudo pelo furto qualificado**, com base no princípio da consunção. Em outras palavras, o crime de supressão ou alteração de marca ficará absorvido pelo crime de furto qualificado de semovente domesticável de produção (crime-fim, previsto no art. 155, §6º, CP). Assim, é necessário estar atento para verificar se não houve a prática de crime mais grave. Se o objetivo for de assenhoreamento definitivo, o crime é de furto qualificado.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 33 — DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: DO DANO

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017)

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima.

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

O bem jurídico protegido pelo art. 163 do CP é patrimônio das pessoas físicas e jurídicas (propriedade e posse).

A proteção se volta à coisa alheia. É atípica a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa própria.

A hipótese é de tipo misto alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado, que pode ser praticado das seguintes formas:

- Destruir: extinção física total da coisa. **Exemplo:** demolição de um prédio.

- Inutilizar: tornar uma coisa imprestável aos fins a que se destina, não necessariamente destruindo-a. **Exemplo:** retirada de uma peça essencial ao funcionamento.

- Deteriorar: estragar ou corromper parcialmente um bem, com diminuição da utilidade ou valor. **Exemplo:** riscar um carro.

O crime é de forma livre e bicomum. Somente pode ser praticado na forma dolosa. Não há dano culposo previsto no Código Penal, salvo na hipótese de crimes ambientais (Lei nº 9.605/98).

Não é necessária a intenção de lucro, nem qualquer outro dolo específico (posição majoritária).

Ademais, o crime é material, isto é, a consumação ocorre quando efetivamente se destrói, inutiliza ou deteriora a coisa alheia. Trata-se também de crime não-transeunte, que deixa vestígios, marcas de existência. Daí decorre a necessidade de prova pericial da materialidade, nos moldes do art. 158 do CPP ("Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado").

É possível a tentativa (*conatus*). **Exemplo:** deseja quebrar um objeto, dirige-se a ele com um pedaço de ferro, mas é impedido.

No caso do dano simples (art. 163, *caput*, CP), a **ação penal é privada**, ensejando a aplicação da Lei 9.099/95 (art. 167 do CP).

1. DOCUMENTOS PÚBLICOS PODEM SER OBJETO MATERIAL DO CRIME DE DANO?

Será necessário analisar o caso concreto, a fim de averiguar a existência de um crime específico. Haverá crime de dano se o propósito for de afetar o patrimônio da vítima.

Se ocorre a inutilização de documento que prova fato juridicamente relevante, o crime será o do art. 305 do CP (supressão de documento).

Por outro lado, se a conduta for praticada por advogado ou procurador, o crime será o do art. 356 do CP (sonegação de papel ou objeto de valor probatório).

A inutilização de edital ou de sinal corresponde ao crime do art. 336 do CP (inutilização de edital ou de sinal).



A inutilização, total ou parcial, de livro oficial, processo ou documento é tipificada no art. 337 do CP (subtração ou inutilização de livro ou documento).

A **pichação** é tipificada no art. 65 da Lei nº 9.605/98 (crimes ambientais), quando se tratar de edificações ou monumentos urbanos. Se a pichação se der em edificação rural ou bens móveis, o crime será o do art. 163 do CP, na modalidade deteriorar.

2. FIGURAS QUALIFICADAS DO DANO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I A IV

Por se tratar de qualificadora, os limites das penas são alterados em abstrato. O preceito secundário estabelece pena de detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência. O crime passa a ser de médio potencial ofensivo, com possibilidade de *sursis* processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) e acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

Inc. I: com violência à pessoa ou grave ameaça.

A violência se volta contra pessoa e não contra a coisa. Há pluriofensividade da conduta. A violência deve ser anterior ou concomitante ao dano; é um meio para o agente danificar a coisa. Se posterior a violência, poderá haver concurso de crimes (dano e lesão corporal), já que a lei impõe o concurso material obrigatório nesse caso. A ameaça, quando anterior ou concomitante, é absorvida pelo dano qualificado. Se posterior, haverá concurso de dano e ameaça. A ação penal é pública incondicionada.

Inc. II: com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave.

Nessa hipótese temos caso de subsidiariedade expressa, pois o emprego de explosivo pode ser meio de execução de um delito mais grave, como o homicídio. **Exemplo:** indivíduo explode um carro com o objetivo de matar quem está no interior. Não incorrerá no dano qualificado, uma vez que a explosão do veículo foi o meio para a prática do homicídio. Sendo assim, o crime de dano restará absorvido pelo crime doloso contra a vida, o crime-fim. A análise do dolo do agente é fundamental.

O emprego de substância explosiva que qualifica o dano deve ser anterior ou concomitante à prática do crime.

Diferença em relação aos crimes de incêndio (art. 250 do CP) e explosão (art. 251 do CP): no crime de dano, o agente se limita a ofender o patrimônio alheio. No incêndio e na explosão cria-se perigo comum a um número indeterminado de pessoas. No caso do dano qualificado, a intenção do agente é ofender o patrimônio específico daquela vítima, não gerando perigo a outras pessoas.

A ação penal é pública incondicionada.

Inc. III: contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos (redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017).

Antes do advento da Lei nº 13.531/17 o dispositivo legal não fazia menção ao Distrito Federal, às autarquias, empresas públicas, fundações públicas e permissionárias de serviços públicos. Assim, não poderia ser considerado qualificado o dano cometido contra o patrimônio distrital, segundo entendimento que, por fim, após longa discussão, prevaleceu no STJ, diante dos princípios da estrita legalidade e da vedação à analogia *in malam partem* em Direito Penal. Diante da omissão legislativa, o crime de dano contra o patrimônio do DF era processado mediante ação penal privada (com todas as implicações daí decorrentes). Portanto, para os fatos praticados antes da vigência da Lei nº 13.531/17, não se pode considerar o dano contra o DF qualificado, por se tratar de *novatio legis in pejus*, a qual não retroage.

O fundamento da qualificadora reside na tutela do interesse coletivo na preservação dos bens públicos, como os meios de transporte coletivos, presídios, delegacias, hospitais.

Segundo o STF, em regra, é inaplicável o princípio da insignificância. Há precedente do STJ em sentido diverso, em hipótese de lençol rasgado por interno do sistema prisional para improvisar um varal, a fim de secar suas roupas (HC 245.457/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).



3. DANO À CELA OU INSTALAÇÃO DE PRESÍDIO COM FINALIDADE DE FUGA

Segundo o STJ, como o objetivo é a liberdade, ausente o dolo específico de deteriorar o patrimônio (*animus nocendi*), não se caracteriza o crime de dano qualificado.

Inc. IV: por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima.

A punição mais exacerbada se justifica no individualismo excessivo e desprezo aos bens alheios de valores mais altos. O motivo egoístico equivale ao torpe. O prejuízo considerável será verificado no caso concreto, a depender não só do valor do bem, mas sobretudo da situação econômico-financeira da vítima. Nesse caso, a ação penal é privada (art. 167 CP).

4. ART. 164. INTRODUÇÃO OU ABANDONO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE ALHEIA

Segundo o art. 164, constitui crime introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. A pena será de detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo. Cabe transação penal e suspensão condicional do processo.

O sujeito ativo é qualquer pessoa. O sujeito passivo é o proprietário ou possuidor de imóvel que sofre prejuízo.

O crime é de ação múltipla(introduzir ou deixar). Basta um animal para configurar o crime, desde que resulte prejuízo. É o que ocorre, por exemplo, na pastagem indevida.

Se houver o consentimento do proprietário ou possuidor, o fato será atípico.

O crime é material, consumando-se no momento em que há o prejuízo.

Somente se procede mediante queixa (art. 167 do CP).

5. ART. 165. DANO EM COISA DE VALOR ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO OU HISTÓRICO

O dispositivo em comento foi tacitamente revogado pela Lei nº 9.605/98, já que esta, no art. 62, inciso I, dispõe que é crime a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. A pena é de reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Na lei especial, o dano culposo é punido.

6. ART. 166. ALTERAÇÃO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO

Este dispositivo também foi revogado pela Lei de Crimes Ambientais, em seu art. 63. Segundo a Lei nº 9.605/98, constitui crime a conduta de alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. A pena é de reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Cabe suspensão condicional do processo, mas não cabe transação penal.

7. ART. 167. AÇÃO PENAL

A ação penal, em todo o capítulo de dano, conforme o art. 167, será da seguinte forma:

Dano simples (art. 163, *caput*) ou dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima (art. 163, parágrafo único, inc. IV): ação penal privada.

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia (art. 164): ação penal privada.

Demais infrações: ação penal pública incondicionada.



CAPÍTULO 34 — DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

1. ART. 168. APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Nos termos do art. 168, *caput*, é crime apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. A pena é de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Apropriar-se significa tomar como própria coisa alheia. Na apropriação indébita, a vítima voluntariamente entrega coisa móvel ao agente e este, após se encontrar na posse ou detenção da coisa, inverte seu ânimo, passando a se comportar como dono. Há, portanto, uma situação de **quebra de confiança**. O crime é material.

Segundo o STJ, é possível a apropriação indébita de coisas fungíveis (que podem ser substituídas por outras da mesma espécie, qualidade e quantidade).

Requisitos para a tipicidade da conduta: entrega voluntária do bem pela vítima, posse ou detenção desvigiada, boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem e modificação posterior no comportamento do agente.

O elemento subjetivo é o dolo. Não se admite a modalidade culposa.

Importa fazer a distinção quanto ao estelionato (art. 171 do CP), considerando o momento em que desponta o dolo.

Na apropriação indébita, o dolo é subsequente ou sucessivo, vez que o sujeito recebe a coisa de boa-fé. Já No estelionato o dolo é antecedente ou *ab initio*. O fim de se apropriar da coisa já estava presente antes mesmo da posse ou detenção da coisa. Em ambos os delitos, a entrega do objeto pela vítima é voluntária.

É possível a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

No Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) há, no art. 102, modalidade especial de apropriação indébita. Confira-se: “Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.”

O parágrafo 1º do art. 168 estabelece que a pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: I - em depósito necessário; II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Conforme dispõe o art. 170 do CP, em todas as hipóteses de apropriação indébita é aplicável o **privilegio** como causa especial de diminuição de pena, nos moldes do art. 155, § 2º, do CP (“se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”).

2. ART. 168-A. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA

Dispõe o art. 168-A: “Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Cabível o acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).”

De plano, nota-se que o tipo não trata de apropriação. O verbo nuclear é *deixar de repassar*. Vale anotar que o STF já afirmou a constitucionalidade do dispositivo em comento.

Severas críticas são feitas à alocação do tipo penal no capítulo que trata da apropriação indébita. A doutrina aponta que seria mais adequada a previsão na Lei nº 8.212/91 (Seguridade Social) ou na Lei nº 8.137/90 (Crimes contra a Ordem Tributária) ou no título referente aos crimes contra a Administração Pública.



O sujeito ativo é a pessoa que tem o dever legal de repassar à previdência social a contribuição recolhida. Em regra, é o empregador. O sujeito passivo é a previdência social, bem como os segurados lesados.

Enquanto na apropriação indébita exige-se prévia posse ou detenção e comportamento posterior de legítimo dono, na figura do art. 168-A é dispensável o locupletamento do agente com as quantias das contribuições previdenciárias, bastando que não sejam repassadas aos cofres públicos. Assim sendo, a conduta do art. 168-A não é a de se locupletar, enriquecer ou se apropriar das contribuições não repassadas, mas sim o simples fato de deixar de repassar. Portanto, tem-se conduta omissiva. O crime é omissivo próprio ou puro, pois o tipo descreve um comportamento negativo, um deixar de fazer. A omissão já está contida no tipo penal.

Segundo o entendimento jurisprudencial pacificado, para a configuração do delito não é necessário um fim específico (*animus rem sibi habendi*), bastando a vontade livre e consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados.

Ademais, a hipótese é de norma penal em branco homogênea, vez que deve ser complementada pela legislação previdenciária quanto ao prazo e forma de recolhimento das contribuições que foram descontadas dos contribuintes e não repassadas aos cofres públicos.

A competência, em regra, é da Justiça Federal. Exceção feita ao art. 149 § 1º, da CF, quando se tratar de contribuições do regime previdenciário próprio dos Estados, Distrito Federal e municípios. Nesses casos, a competência passa a ser da Justiça Estadual.

Aspecto importante diz respeito à necessidade de conclusão do procedimento administrativo relativo à existência, exigibilidade e valor da contribuição previdenciária como condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Conclui-se, assim, que o crime tem natureza material. Não há que se falar em denúncia pelo crime de apropriação indébita previdenciária se não concluído o procedimento administrativo prévio. O momento consumativo corresponde à data de constituição definitiva do crédito tributário, com o exaurimento da via administrativa.

Logo, a hipótese é de rejeição da denúncia se não houver condição de procedibilidade. Da mesma forma, inquérito policial não pode ser instaurado pela autoridade policial. Esse é o entendimento adotado pelo STJ e STF, com fundamento no art. 142 do CTN, o qual estabelece que a competência para lançamento de tributo é da autoridade administrativa. Nesse exato sentido, o enunciado da Súmula Vinculante 24.

Prevalece o entendimento de não ser possível a tentativa, por se tratar de crime omissivo.

O parágrafo 1º prevê as formas equiparadas. Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

- I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;
- II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;
- III – pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

O parágrafo 2º, por seu turno, prevê a extinção de punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Todavia, segundo entendimento jurisprudencial do STJ e do STF, interpretando a legislação superveniente (Leis nº 10.684/03 e 12.832/11), o adimplemento do débito tributário, a qualquer tempo, até mesmo após o trânsito em julgado, é causa de extinção da punibilidade.

O parágrafo § 3º estabelece hipótese de perdão judicial e privilégio. Contudo, diante da orientação jurisprudencial acima destacada, a previsão tornou-se pouco aplicada.

Por derradeiro, o parágrafo 4º, introduzido pela Lei nº 13.606/18, estabelece que a faculdade prevista no § 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor,

inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

O valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda.

E quanto ao princípio da insignificância? É possível a aplicação ao delito previsto no art. 168-A do CP? A questão é um tanto polêmica. Ao que parece, a tendência jurisprudencial é no sentido de não ser possível a exclusão da tipicidade material, conforme se observa do recente julgado abaixo transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõem o Supremo Tribunal Federal entendem ser inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária, tendo em vista a elevada reprovabilidade dessas condutas, que atentam contra bem jurídico de caráter supraindividual e contribuem para agravar o quadro deficitário da Previdência Social.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior concluiu que não é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, independentemente do valor do ilícito, pois esses tipos penais protegem a própria subsistência da Previdência Social, de modo que é elevado o grau de reprovabilidade da conduta do agente que atenta contra este bem jurídico supraindividual.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1783334/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 02/12/2019). Grifou-se.

3. ART. 169. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA

Segundo o art. 169, apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza redundam em pena de detenção, de um mês a um ano, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

O crime é comum. A coisa não chega às mãos do agente por ato da vítima, mas sim por erro, caso fortuito ou força da natureza, a justificar a punição mais branda.

O parágrafo único prevê condutas equiparadas (na mesma pena incorre):

Apropriação de tesouro: I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

Apropriação de coisa achada: II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Nessa situação, temos um crime classificado pela doutrina como de conduta híbrida ou mista, vez que o tipo penal incriminador prevê uma ação, a apropriação de coisa alheia perdida, seguida de uma omissão, consistente na não restituição ao dono ou à autoridade competente no prazo de 15 dias.

Por haver a previsão de um prazo legal para a restituição, temos, também, um crime a prazo, já que a consumação exige o prévio transcurso do lapso de 15 dias.

4. ART. 170. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRIVILEGIADA

Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, § 2º, do CP, que contempla o furto privilegiado. Assim, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o



juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.



CAPÍTULO 35 — DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES

1. ART. 171. ESTELIONATO

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. Esta é a definição legal do delito de estelionato.

A etimologia da palavra nos revela que *stellio*, em latim, significa camaleão. Assim, o crime patrimonial que é cometido mediante fraude, dissimulação e meios enganosos é tipificado no art. 171.

O crime pode ser praticado mediante artifício, isto é, a fraude material ou ardil, consistente na fraude moral (conversa enganosa).

O crime é bicomum, não se exigindo característica especial do agente ou da vítima.

Prevalece o entendimento de que a vantagem ilícita deve ter natureza econômica, vez que o estelionato é crime contra o patrimônio.

A fraude em certames de interesse público não é hipótese de estelionato, mas sim do crime previsto no art. 311-A do CP. Antes do advento da Lei nº 12.550/11, o STF entendeu que a “cola eletrônica” não se amoldava ao tipo do estelionato, nem da falsidade ideológica, razão pela qual a conduta era considerada atípica.

A consumação do estelionato depende da **lesão patrimonial** e do **prejuízo** à vítima. Trata-se de crime de **duplo resultado**, material e instantâneo.

Vale destacar que não é exigido, para a configuração do crime, que a vítima estivesse de boa-fé. Em verdade, em muitos casos, o ofendido é ludibriado justamente em razão de sua ganância.

É frequente haver relação entre o estelionato e a falsidade documental. Exemplo: sujeito que falsifica um documento (público ou particular) e depois se vale do escrito para ludibriar, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio. Em tese, estariam caracterizados dois crimes (art. 171 e art. 297 ou 298 do CP). Porém, prevalece o entendimento de que o estelionato absorve a falsidade documental, por força da Súmula 17 do STJ: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.” Observa-se o estelionato como crime-fim e a falsidade como crime-meio. Assim, aplicável o princípio da consunção.

O § 1º prevê o estelionato privilegiado, fazendo remissão ao disposto no art. 155, § 2º, do CP, já comentado.

No § 2º temos a previsão das condutas assemelhadas. Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria: I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria.

O rol é taxativo.

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria: II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias.

Apesar da semelhança, é preciso verificar que, no inc. I, o indivíduo vende coisa alheia (móvel ou imóvel) como se fosse própria. Já no inc. II, a venda recai sobre coisa própria, porém com ônus, sobre o qual silencia.

Defraudação de penhor: III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado.

Deve haver prévio contrato pignoratício. O devedor, que é mantido na posse da coisa penhorada, é o sujeito ativo do crime.

Fraude na entrega de coisa: IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém.



Se a fraude se der no exercício de atividade comercial, a conduta passa a ser a prevista no art. 175 do CP.

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro: V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro.

O indivíduo que se autolesiona com o objetivo de receber indenização ou seguro poderá responder por esse tipo, não se configurando o delito de lesão corporal.

É necessária a existência prévia de um contrato de seguro em vigor (voluntário ou obrigatório).

O sujeito ativo é o segurado e o sujeito passivo é a seguradora.

Trata-se da **única forma de estelionato em que se tem consumação antecipada. É crime formal**, ou seja, estará consumado no momento em que o agente se autolesiona, ou agrava as consequências da lesão ou da doença, independentemente da obtenção da indenização, que consiste mero exaurimento.

É preciso o dolo, acrescido do especial fim de agir (elemento subjetivo específico), verificado no intuito de haver indenização ou valor de seguro.

Fraude no pagamento por meio de cheque: VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

O sujeito ativo é o emitente do cheque. É o titular da conta que, já imbuído do dolo, ao emitir a cártula, tem conhecimento de fato que irá impedir o recebimento do valor pelo tomador do cheque. O sujeito passivo é qualquer pessoa.

Se um indivíduo se utilizar do cheque para enganar terceiros, falsificando a assinatura do titular da conta, responderá pelo delito de estelionato propriamente dito (art. 171, *caput*) e não por essa figura.

Exemplos de condutas que se amoldam ao inc. VI: saque integral dos valores da conta, sustação do cheque, encerramento da conta.

Se a fraude é empregada antes da emissão da cártula, o crime é o do *caput* (estelionato simples).

Ressalta-se que cheque é ordem de pagamento à vista, motivo pelo qual, se o cheque foi emitido pós-datado, desnatura-se a essência do cheque, não sendo possível a prática desse crime. Isso porque o indivíduo não emitiu o cheque sem fundos, e sim com a condição de que fosse apresentado em data futura.

Para fins de tipificação, deve estar presente o especial fim de agir (não expresso no tipo), consistente na intenção de fraudar (*animus lucri faciendi*). Nesse sentido, observa-se o teor da **Súmula 246 do STF**: “Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos.”

Na modalidade de estelionato em comento, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia obsta a instauração da ação penal, conforme leitura a *contrario sensu* da **Súmula 554 do Supremo Tribunal Federal**. Com efeito, a súmula estabelece que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal.

Parcela da doutrina entende que o enunciado sumular, anterior à reformulação da Parte Geral do Código Penal em 1984, perdeu a eficácia, diante do instituto do arrependimento posterior (art. 16 CP). Contudo, o STF continua aplicando a Súmula 554, sob o argumento de que não se cuida de arrependimento posterior, mas sim falta de justa causa para a ação penal (ausência de fraude).

Por seu turno, a Súmula 521 do STF estabelece que o foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, **é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Exemplo:** Samer emitiu um cheque em Porto Alegre/RS, mas o tomador resolve sacar a cártula em Canoas/RS. Nesse caso, será a comarca de Canoas o foro competente para julgamento do crime.

A emissão de cheque sem fundos para pagamento de obrigações naturais (dívidas de jogos, por exemplo) é **conduta atípica**. O art. 814, *caput*, 1ª parte, do Código Civil estabelece que as dívidas de aposta ou de jogo não obrigam o pagamento.

1.1. REPARAÇÃO DO DANO E ESTELIONATO

A Súmula 554 do STF estabelece que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. A leitura do enunciado, *a contrario sensu*, indica que se o pagamento da cártula ocorre antes do recebimento da denúncia, não há condição de procedibilidade para a ação penal. É preciso ter cuidado, pois tal entendimento só se aplica ao estelionato previsto no art. 171, § 2º, inciso VI, do CP, não sendo, portanto, cabível tal raciocínio nas outras hipóteses do crime.

Para as demais formas de estelionato, a reparação do dano **antes do recebimento da denúncia** enseja a aplicação do art. 16 do CP (arrependimento posterior), como causa de diminuição de pena.

A reparação do dano antes da sentença atrai a aplicação do art. 65, inc. III, alínea b, parte final, do CP, isto é, uma atenuante genérica.

Por fim, a reparação após a sentença não surte efeito.

Segundo a jurisprudência, a conduta do agente que emite cheque que chegou ilicitamente ao seu poder configura o ilícito previsto no *caput* do art. 171 do CP, e não em seu § 2º, VI. Assim, tipificada a conduta como estelionato na sua forma fundamental, o fato de ter ressarcido o prejuízo à vítima antes do recebimento da denúncia não impede a ação penal, não havendo falar, pois, em incidência do disposto na Súmula 554 do STF, que se restringe ao estelionato na modalidade de emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, prevista no art. 171, § 2º, VI, do CP.

Art. 171, §3º . Estelionato circunstanciado ou majorado.

A pena aumenta-se de um terço se o crime, em qualquer uma das formas, é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Logo, aplica-se a majorante aos casos que envolvam a entidade autárquica previdenciária (INSS).

Em relação ao estelionato previdenciário, há uma discussão sobre ser crime instantâneo de efeitos permanentes ou crime permanente. A relevância reside na definição do início do prazo prescricional, eis que no crime permanente a consumação se protraí no tempo, enquanto não cessada a permanência.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato vai iniciar a sua contagem da consumação do crime, visto que se adota a teoria do resultado. Essa é a razão pela qual se faz imprescindível saber, no caso concreto, se o crime se consumou (crime instantâneo) ou se o crime tem a sua consumação postergada no tempo (crime permanente).

É ainda necessário destacar **duas situações em que o estelionato previdenciário poderá ocorrer**:

a) O benefício é fraudulento na origem, ou seja, é criado sem qualquer observância dos requisitos legais (“benefício fantasma”).

b) O benefício é devido na origem, mas alguém está utilizando o cartão do beneficiário indevidamente.

Segundo o STF, no caso em que o benefício já **nasce viciado**, haverá crime instantâneo ou permanente, a depender de quem o comete. Se o crime é praticado por um terceiro, que não será o beneficiário do valor da previdência, para este terceiro o crime é instantâneo de efeitos permanentes. No entanto, para o agente que se beneficia diretamente da fraude, o crime é permanente, pois todo mês recebe os valores indevidos.

Se alguém se vale do cartão previdenciário de outrem que faleceu (benefício criado de forma legal), recebendo os valores indevidamente após a morte, o crime será instantâneo, ainda que faça



saques mensais do benefício. Nessa hipótese, segundo o STJ, a continuidade delitiva é aplicável ao estelionato previdenciário, praticado por aquele que, após a morte do beneficiário, passa a receber mensalmente o benefício em seu lugar, mediante a utilização de cartão magnético do falecido. Ou seja, cada vez que o indivíduo vai até a agência promover o saque comete um novo crime de estelionato previdenciário, em continuidade delitiva. O crime não é permanente, e sim instantâneo.

Art. 171, §4º. Estelionato contra idoso.

A pena aplica-se em dobro quando o crime é cometido contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.

A causa de aumento de pena aplica-se a todas as modalidades de estelionato. Tutela-se a maior fragilidade e vulnerabilidade dos idosos, que frequentemente são vítimas de golpes e fraudes.

§ 5º. Ação penal para o estelionato.

A Lei nº 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime, passou a prever, como regra geral, que somente se procede mediante representação nos casos de estelionato, salvo se a vítima for:

- I - a Administração Pública, direta ou indireta;
- II - criança ou adolescente;
- III - pessoa com deficiência mental; ou
- IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.

A doutrina tece algumas críticas, em especial no que tange aos incisos II e III, vez que a vítima do estelionato deve ter capacidade para ser enganada. No caso das crianças ou das pessoas com deficiência, o crime, regra geral, será aquele previsto no art. 173 do CP (abuso de incapazes).

2. ART. 172. DUPLICATA SIMULADA

Segundo o art. 172 do CP, configura o crime de duplicata simulada a conduta de emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.

A pena é de detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Não admite suspensão condicional do processo e nem transação penal (elevado potencial ofensivo). Porém, cabível o acordo de não persecução penal.

Nos termos do parágrafo único, nas mesmas penas de detenção, de 2 a 4 anos, e multa, incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas.

O crime somente pode ser praticado por quem emite o título falso. Tem-se, assim, um crime próprio ou especial. O sujeito passivo é aquele que aceita de boa-fé a duplicata, ou ainda o tomador.

O momento consumativo é controverso na doutrina. Uma parcela sustenta que a consumação ocorre no momento em que o título é colocado em circulação (posição do prof. Damásio de Jesus). Porém, há quem entenda que o crime se consuma com a criação ou emissão do título, visto que a lei não exige a circulação (Cleber Masson).

No entanto, não há dúvidas de que o crime é formal (de resultado cortado ou de consumação antecipada), bastando a potencialidade do dano.

A ação penal é pública incondicionada, com as ressalvas do art. 182 do CP (escusas processuais ou relativas).

3. ART. 173. ABUSO DE INCAPAZES

Configura o crime de abuso de incapazes a conduta de abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro.



A pena é de reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. É infração de maior potencial ofensivo, que permite o acordo de não persecução penal.

O tipo penal apresenta duas figuras:

Abusar: aproveitar-se ou prevalecer-se de determinada condição (tirar vantagem).

Induzir: fazer nascer a ideia na mente de outrem.

O tipo não exige artifício ou ardil, dispensando também a efetiva lesão patrimonial. Bastará a potencialidade lesiva. É suficiente para a consumação que o agente induza à prática de algum ato que possa produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Por essa razão, o crime é formal.

Atos nulos, como a venda de imóvel por absolutamente incapaz, por não produzirem qualquer efeito jurídico, não caracterizam o crime. Porém, se o ato for anulável, tipifica-se a conduta.

O crime pode ser praticado por qualquer pessoa (crime comum). Existe discussão sobre a possibilidade de o menor emancipado ser vítima do delito. Apesar de alguns entendimentos diversos, o *nomen iuris* do crime é abuso de incapaz. O menor emancipado não é incapaz, motivo pelo qual não pode ser sujeito passivo do crime, em que pese o tipo penal exija apenas que se trate de menor.

O crime somente pode ser cometido a título doloso, consistente na vontade de abusar para conseguir a prática de um ato indevido que cause prejuízo ao incapaz ou a outra pessoa. Há, portanto, um especial fim de agir, um elemento subjetivo do tipo (dolo específico), consistente no intuito de proveito próprio ou alheio.

O crime se consuma no instante em que a vítima pratica o ato a que foi induzida, independentemente da obtenção efetiva do proveito pelo sujeito ativo ou de prejuízo ao incapaz ou a terceira pessoa (crime formal). Alcançando o agente essas circunstâncias, haverá exaurimento da infração penal.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 174. INDUZIMENTO À ESPECULAÇÃO

Segundo o art. 174, constitui crime abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruínosa. A pena para o crime é de reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. É infração de médio potencial ofensivo, cabendo suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

Busca-se tutelar o patrimônio da pessoa ingênua, inexperiente ou crédula. Dispensa o uso de ardil ou artifício, no que se distingue, portanto, do estelionato.

O crime é comum, formal, cuja consumação independe do efetivo prejuízo à vítima.

A ação é pública incondicionada, salvo hipóteses do art. 182 do CP (representação como condição de procedibilidade da ação penal).

5. ART. 175. FRAUDE NO COMÉRCIO

Configura crime de fraude no comércio a conduta de enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor: I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; II - entregando uma mercadoria por outra. A pena é de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Permite a transação penal e a suspensão condicional do processo.

É crime próprio, uma vez que o indivíduo deve estar no exercício da atividade comercial. Vale lembrar que atividade comercial pressupõe continuidade, profissionalização e habitualidade. Portanto, aquele que faz uma única venda não realiza atividade comercial, em que pese tenha realizado um ato comercial.

Há quem defenda ter sido a previsão do CP revogada pelas Leis nº 8.078/90 e 8.137/90, já ambas possuem dispositivos semelhantes. Todavia, deve-se considerar que a lei posterior só revoga a anterior quando dispuser inteiramente sobre a matéria nela contida, o que não é o caso.



A presente figura é muito semelhante ao estelionato, aplicando-se o princípio da especialidade, pois o crime é cometido no âmbito da atividade comercial.

As vítimas são pessoas certas e determinadas, que devem ser efetivamente prejudicadas. O crime tem natureza material, consumando-se no momento em que o ofendido é enganado, comprando a coisa, com a tradição da mercadoria.

O **§1º** prevê forma qualificada na conduta de alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, ou vender pedra falsa por verdadeira, ou vender, como precioso, metal de outra qualidade. O tipo é claramente destinado a joalheiros, ourives e comerciante de joias. A pena passa a ser de reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

O **§2º** estabelece que se aplica o disposto no art. 155, § 2º (privilegio). Sendo o sujeito primário e a coisa de pequeno valor, poderá o juiz reduzir a pena de 1/3 a 2/3, substituir a pena de reclusão pela de detenção, ou aplicar apenas a pena de multa.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 176. OUTRAS FRAUDES

Segundo o art. 176, configura crime tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. A pena é de detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. É crime de menor potencial ofensivo, da competência do Juizado Especial Criminal. Comporta a aplicação dos institutos despenalizantes previstos na Lei nº 9.099/95. Uma vez admitida a transação penal, resta inviável o acordo de não persecução penal.

O tipo contempla, assim, serviços que, regra geral, são prestados sem a exigência de prévio pagamento.

O parágrafo único prevê que somente se procede mediante representação e que o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, ou seja, a depender da situação, será possível o perdão judicial.

Atente-se ao fato de que, se o sujeito dispõe de recursos, mas não quer pagar tais comodidades, não haverá o crime, e sim um calote, ilícito civil, pois a elementar não resta preenchida. É o caso da “pendura”, tradição nos cursos de Direito. Porém, a depender da hipótese e do ardis utilizado, a conduta poderá se enquadrar no art. 171 do CP.

7. ART. 177. FRAUDES E ABUSOS NA FUNDAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE POR AÇÕES

O art. 177 criminaliza a conduta de promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo.

A pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Trata-se de infração de médio potencial ofensivo, cabendo suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

Conforme se observa do preceito secundário, o crime é subsidiário. É preciso verificar se a conduta não se amolda a uma das figuras da Lei nº 1.521/51, que trata dos crimes contra a economia popular.

O delito é formal. Não é necessário, como pressuposto da consumação, qualquer resultado lesivo aos acionistas.

No parágrafo 1º estão dispostos nove incisos que retratam as figuras equiparadas, nas quais há fraudes e abusos na administração de sociedades por ações (e não na sua fundação). Recomenda-se a leitura dos incisos. Os crimes são próprios (somente podem ser cometidos pelo diretor, gerente, ou fiscal de sociedade por ações, liquidante ou representante da sociedade anônima estrangeira autorizada a



funcionar no país). São também tipos expressamente subsidiários (somente se não constituir crime contra a economia popular).

O parágrafo 2º estabelece que incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembleia geral. O crime é próprio, pois só o acionista pode praticar. A negociação do voto pode consistir em compra, venda ou qualquer outro tipo de acordo cuja finalidade seja a obtenção de vantagem indevida.

A ação penal, como regra, é pública incondicionada, com as ressalvas do art. 182 do CP.

8. ART. 178. EMISSÃO IRREGULAR DE CONHECIMENTO DE DEPÓSITO OU WARRANT

O art. 178 estabelece como crime emitir conhecimento de depósito ou *warrant*, em desacordo com disposição legal. A pena cominada é de reclusão, de um a quatro anos, e multa. É infração de médio potencial ofensivo, cabendo o *sursis* processual e o acordo de não persecução penal.

Trata-se de delito de pouca incidência na prática. O objetivo é tutelar o patrimônio representado pelos títulos de crédito e, de forma indireta, a fé pública na veracidade das cártulas.

O crime é comum.

Para melhor compreensão dos aspectos penais, é importante recordar algumas noções do direito empresarial.

Quando um indivíduo deixa uma mercadoria no armazém geral são emitidos dois títulos de crédito: o conhecimento de depósito, que representa a própria mercadoria depositada, servindo como prova de sua guarda e conservação. Quem detém o título é o proprietário da mercadoria, podendo aliená-la com a entrega da cártula; e o *warrant*, que é uma garantia real em relação às mercadorias depositadas. Quem tem o *warrant* poderá instituir penhor sobre os bens.

Assim, o conhecimento de depósito permite fazer circular a propriedade da mercadoria e o *warrant* permite colocar esses bens em garantia.

Tem-se, ainda, uma norma penal em branco, vez que é preciso saber quais são as determinações legais para emitir os títulos de crédito. O Decreto nº 1.102/1903 completa o sentido do dispositivo em comento.

O crime se consuma independentemente do resultado ou prejuízo gerado. Tem, portanto, natureza formal.

A ação penal é pública incondicionada.

9. ART. 179. FRAUDE À EXECUÇÃO

Segundo o art. 179, constitui crime a conduta de fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. É, assim, criminalizado o comportamento daquele que, dolosamente, deseja frustrar o pagamento devido aos seus credores.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, cabendo suspensão condicional do processo e transação penal.

O sujeito ativo somente poderá ser o próprio devedor, não comerciante. Tem-se, assim, um crime próprio.

É um delito de ação múltipla, sendo possível fraudar a execução alienando, desviando, destruindo, danificando bens ou simulando dívidas. Havendo a prática de mais de um verbo no mesmo contexto fático, por ser tratar de tipo misto alternativo ou de conteúdo variado, o crime será único.

Segundo entendimento que prevalece, é indispensável um processo civil em andamento para a cobrança da dívida. Não é necessária a citação do devedor, bastando a prova de que tinha conhecimento do trâmite da ação.

A consumação ocorre com a fraude, ou seja, pela alienação, desvio, destruição, dano aos bens ou simulação de dívidas. Há possibilidade de tentativa.



Nos termos do parágrafo único, a ação penal é privada, em regra. Exceção: quando o crime é praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou Município, por força do art. 24 ,§ 2º, CPP.



CAPÍTULO 36 — DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: DA RECEPÇÃO

Segundo o art. 180, constitui crime de receptação a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

A pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Trata-se de infração de médio potencial ofensivo, admitindo suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa (crime comum).

O tipo penal exige um especial fim de agir, pois é necessário que a conduta se dê em proveito próprio ou alheio. Se o indivíduo age para simplesmente auxiliar o autor do delito antecedente (crime anterior à receptação), e não há proveito algum para esse indivíduo ou para outrem, o crime não é de receptação e sim de favorecimento real (art. 349 do CP).

Os verbos adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar caracterizam a receptação própria. Já o núcleo influir tipifica a receptação imprópria.

Segundo o STF, apesar de o tipo penal não ser expresso, é necessário que a coisa, objeto de receptação, seja móvel.

Não é preciso que a coisa seja genuína, bem como pode ser proveniente da infração de forma indireta. **Exemplo:** João roubou um carro. Se José compra o carro de João comete receptação. No entanto, é possível que João tenha trocado o carro roubado por uma moto. José, sabendo que João roubou um carro, e o trocou pela moto, ainda assim resolve comprá-la. Nesse caso, também estará configurada a receptação.

Se alguém recebe um bem de boa-fé, mas, tempos depois, passa a conhecer a procedência ilícita, haverá o crime de receptação? Entende-se que não, pois o dolo deve preceder a conduta, ou ao menos ser concomitante a ela. A conduta, nesse exemplo, é atípica.

O delito é classificado como acessório ou parasitário, vez que reclama a prática de um crime anterior. Todavia, não é necessário um prévio ajuste entre o autor do crime antecedente e o receptor.

O dispositivo não menciona contravenção penal e nem mesmo ato infracional. Segundo entendimento que prevalece, a palavra *crime* deve ser interpretada restritivamente. Se a coisa é produto de contravenção penal, não se caracteriza o delito do art. 180, considerando a vedação à analogia *in malam partem*.

Todavia, entende-se que haverá receptação quando a coisa é produto de ato infracional.

A tipificação independe de prévia condenação pelo delito precedente, bastando que se comprove a existência do crime. Não se exige, ademais, que o crime seja contra o patrimônio.

O crime de receptação própria é material, consumando-se no momento em que a coisa ingressa na esfera de disponibilidade do agente. Na modalidade imprópria, o delito é formal, bastando a influência ao terceiro de boa-fé.

A doutrina majoritária entende que é admissível a tentativa na forma própria. Na imprópria, que consiste na influência, não se admite a tentativa.

Segundo o STJ, é atípica a conduta de receber folhas de cheques em branco furtadas ou roubadas. Para a Corte, o talonário de cheque não tem valor econômico por si só, motivo pelo qual não há que se falar em receptação.

A incidência do princípio da insignificância na receptação é controversa. Embora exista precedente do STJ, o STF entende que o delito traz consigo vários outros crimes, inclusive mais graves, fomentando a prática de roubos e furtos.

O §1º traz a forma qualificada da receptação, estabelecendo a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou



industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Aqui, há um **crime próprio**, pois somente pode ser praticado por quem exerce atividade comercial ou industrial.

A pena é de reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. O crime é de elevado potencial ofensivo, razão pela qual não comporta os institutos despenalizantes da Lei nº 9.099/95. Também não se aplica o princípio da insignificância.

O STF já decidiu que a forma qualificada é constitucional, não se cogitando de violação ao princípio da proporcionalidade.

O crime é próprio, vez que somente pode ser praticado por quem exerce atividade comercial ou industrial.

A expressão deve saber está relacionada ao dolo eventual. Assim, tanto o indivíduo que sabe, como aquele que deveria saber da procedência ilícita, respondem igualmente pelo delito na forma qualificada.

O §2º equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Trata-se de uma norma penal explicativa, no sentido de delimitar e aclarar o alcance da disposição precedente.

O §3º contempla a hipótese da receptação culposa. *Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso*. Nessa situação, o indivíduo tem condições de agir com maior diligência antes de adquirir o produto, mas assim não o faz.

A pena é de detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. A infração é de menor potencial ofensivo, permitindo suspensão condicional do processo e transação penal.

As condições para se aferir a conduta culposa não são cumulativas.

Segundo o §4º, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Preserva-se a autonomia da receptação, ainda que seja um crime parasitário. Existindo o crime precedente, haverá punição pela receptação, ainda que não se conheça o autor do crime precedente ou que ele não seja punível por qualquer razão. Não haverá receptação quando o crime precedente não existir ou quanto houver alguma causa que exclua a tipicidade.

Ainda que não se saiba quem praticou o crime antecedente, adquirida a coisa de origem ilícita, haverá receptação.

O §5º estabelece que, na hipótese do §3º (receptação culposa), se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena (perdão judicial). A benesse é aplicável somente na hipótese de receptação culposa.

Já na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155, ou seja, se o indivíduo for primário e a coisa for de pequeno valor, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 a 2/3 (privilegio), substituir a pena de reclusão pela detenção ou ainda aplicar apenas a pena de multa.

É possível a receptação **qualificada-privilegiada**? Há divergência. Prevalece o entendimento quanto à possibilidade, considerando-se a posição topográfica dos parágrafos (o § 5º é posterior ao § 2º).

O §6º dispõe que a pena prevista no *caput* do art. 180 será aplicada em dobro quando se tratar de bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Perceba que apenas a receptação simples terá sua pena dobrada.

A ação penal para todas as formas é pública incondicionada, com as ressalvas do art. 182 do CP.

1. ART. 180-A. RECEPTAÇÃO DE ANIMAL

A Lei nº 13.330/2016 acrescentou o art. 180-A ao Código Penal, criando uma nova espécie de receptação envolvendo animais.



Segundo o art. 180-A, configura o crime de receptação de animal a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. A pena é de 2 a 5 anos e multa.

O crime é comum, isto é, pode ser praticado por qualquer pessoa, exceto o proprietário do animal ou o autor do delito antecedente.

O tipo penal traz elemento subjetivo especial (tendência interna transcendente, dolo específico ou especial fim de agir), tendo em vista que exige “a finalidade de produção ou de comercialização”.

O elemento subjetivo geral, o dolo propriamente dito, consiste na expressão “deve saber ser produto de crime”. Segundo STF e STJ, abrange tanto o dolo eventual como o dolo direto.

O objeto material do delito é o semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes.

O crime é material, consumando-se quando a coisa se integra à esfera de disponibilidade do agente.

Novatio legis in melius: o objetivo declarado da Lei nº 13.330/2016 foi o de punir de maneira específica quem pratica receptação de semoventes domesticáveis de produção. Contudo, ao inserir o art. 180-A do CP, o legislador diminuiu a pena para essa conduta.

Antes da Lei nº 13.330/2016, se o indivíduo praticasse a conduta descrita atualmente no art. 180-A do CP, ele não respondia pela receptação simples do art. 180, *caput*, do CP, e sim pela receptação qualificada prevista no § 1º do art. 180. Isso porque o art. 180-A do CP prevê que a conduta deve ter sido praticada “com a finalidade de produção ou de comercialização”, exigência esta que não está descrita no *caput* do art. 180, mas que está prevista no § 1º do art. 180 (“no exercício de atividade comercial ou industrial”).

Em outras palavras, antes da Lei nº 13.330/2016, a conduta era punida com a pena de 3 a 8 anos (§1º do art. 180 do CP). Após a lei, a conduta passou a ter pena de 2 a 5 anos (art. 180-A do CP).

Dessa forma, a Lei nº 13.330/16 deverá retroagir para beneficiar pessoas que tenham sido condenadas pelo art. 180, § 1º, do CP nos casos de receptação de animais destinados a produção ou comercialização.



CAPÍTULO 37 — DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Nos termos do **art. 181**, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:

- I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;
- II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

São as chamadas imunidades penais absolutas ou materiais, que importam em total isenção da pena. Entende-se que o direito penal não deve se imiscuir em assuntos familiares. O crime permanece íntegro (é fato típico, ilícito e praticado por agente culpável). Porém, a punibilidade resta afastada. Remanescem, todavia, os efeitos civis do ilícito, como a obrigação de reparar o dano.

A redação do inciso II é inadequada, pois refere-se a uma distinção não mais existente em nossa ordem jurídica atual, em parentesco legítimo ou ilegítimo.

O rol é taxativo. Todavia, os que vivem em união estável também podem invocar a imunidade material, considerando a proteção constitucional conferida ao instituto, inclusive às uniões entre pessoas de mesmo sexo.

O **art. 182**, por seu turno, estabelece que somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:

- I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado
- II - de irmão, legítimo ou ilegítimo;
- III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.

São as imunidades (ou escusas) relativas ou processuais, que não isentam de pena, mas transformam a ação penal pública incondicionada em condicionada à representação (condição de procedibilidade). O rol também é taxativo.

Ressalta-se que o texto do CP encontra-se em desacordo com a ordem civil e constitucional, ao fazer menção a irmão legítimo ou ilegítimo. Não há qualquer distinção entre os irmãos. O mais acertado seria mencionar irmão, bilateral ou não.

Quanto ao tio e sobrinho, para a incidência da imunidade é preciso que tenham residência comum, isto é, vivam sob um mesmo teto, de forma duradoura.

O **art. 183** é deveras importante, pois trata das exceções. Prevê que não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:

- I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa;
- II - ao estranho que participa do crime.
- III - se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

QUESTÕES

1- (CEBRASPE-TJBA-2019) Com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue os itens que se seguem, com base no entendimento jurisprudencial.

- I. A existência de sistema de vigilância por monitoramento, por impossibilitar a consumação do delito de furto, é suficiente para tornar impossível a configuração desse tipo de crime.
- II. A presença de circunstância qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva no delito de furto não afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio, se estiverem presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva.
- III. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniada na perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo.



IV. No delito de estelionato na modalidade fraude mediante o pagamento em cheque, a realização do pagamento do valor relativo ao título até o recebimento da denúncia impede o prosseguimento da ação penal.

Estão certos apenas os itens

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

Gabarito: C



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



CAPÍTULO 38 — DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL

O fundamento constitucional da tutela à propriedade intelectual reside no art. 5º, inc. IX, CF, segundo o qual

é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”; também no inc. XXVII, que estabelece “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

Ainda no âmbito constitucional, o art. 216 prevê proteção às obras artísticas, científicas, literárias e invenções em geral, os reconhecendo como bens incorpóreos, porém com valor econômico.

1. ART. 184. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos acarreta pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Comporta os benefícios da Lei nº 9.099/95, tais como a transação penal e a suspensão condicional do processo.

Tem-se uma norma penal em branco homogênea, vez que é preciso recorrer à legislação específica para delimitar o significado de direitos de autor. A Lei nº 9.610/98 dispõe sobre os direitos autorais.

Direitos de autor são bens móveis. Podem ser patrimoniais ou morais.

Os direitos patrimoniais podem ser exemplificados pela gravação, extração de cópias, adaptação de obras. Há exploração comercial e econômica da obra intelectual. Podem ser negociados a qualquer tempo. Os herdeiros poderão fruir e dispor da obra pelo prazo de 70 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 9.610/98.

Já os direitos morais estão relacionados à paternidade da obra, conservação, integridade. São direitos insuscetíveis de alienação, imprescritíveis e irrenunciáveis. São transmitidos pela via sucessória.

Há ainda os direitos conexos, relativos aos intérpretes, executantes, produtores e empresas de radiodifusão.

A jurisprudência tem entendido que na falsificação ou imitação grosseiras não há violação ao direito de autor. Trata-se de uma hipótese de crime impossível (art. 17 do CP).

O núcleo do tipo do *caput* é violar, que significa transgredir, infringir, ofender.

O crime pode ser praticado de forma livre. Exemplo: reprodução não autorizada de livros por fotocópias, comercialização de originais sem autorização do autor, plágio (assinar como sua obra alheia).

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é crime comum. Já o sujeito passivo é o autor da obra. Caso falecido, será o herdeiro(s). Se o direito autoral foi passado a uma pessoa jurídica, será ela o sujeito passivo.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não se pune a forma culposa. O *caput* não exige especial fim de agir.

O crime é classificado como formal, pois prescinde de resultado naturalístico. Não é necessário o prejuízo à vítima, nem que o agente aufera lucro.

A Lei nº 9.610/98, nos artigos 46 a 48, estabelece limitações aos direitos autorais. Nessas hipóteses, não haverá tipicidade da conduta. **Exemplo:** paráfrases e paródias.

As figuras qualificadas estão previstas no art. 184, §§ 1º, 2º e 3º. Exigem um especial fim de agir, qual seja, o intuito de lucro direto ou indireto. Porém, os crimes continuam sendo formais. Não é necessária para a consumação a efetiva obtenção do lucro ou proveito patrimonial.

§1º: se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. A pena é de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Crime de elevado potencial ofensivo.

§2º: na mesma pena do § 1º (reclusão de 2 a 4 anos, e multa) incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

Na modalidade expor à venda, o crime é permanente (a consumação se prolonga no tempo).

§3º: se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente, a pena será de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

Nessa hipótese, o legislador previu as mais diferentes formas de prática do crime, em especial por meio da rede mundial de computadores.

§4º: o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610/98, nos arts. 46 a 48, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.

Assim sendo, não há crime quando a cópia é uma única, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.

Apesar do art. 184, §4º, prever que não serão punidas as condutas previstas no §§1º, 2º e 3º, é preciso também estender esse benefício ao indivíduo que praticar a conduta do *caput*. Se a figura qualificada não é punida, com maior razão não devem ser punidas as condutas que se amoldarem ao *caput*.

Súmula 502 do STJ: “Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.”

O enunciado consolidou o entendimento de que não é possível se invocar o princípio da adequação social em relação à conduta de expor à venda CDs e DVDs falsificados. Apesar de ser prática costumeira no país, entende-se que somente a lei pode determinar a *abolitio criminis*. O costume não derroga a lei penal.

Súmula 574 do STJ:

Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem.

Segundo o STJ, é dispensável que haja o exame pericial de todos os objetos apreendidos para fins de comprovação da materialidade. Também é dispensável a identificação pormenorizada de todos os autores que tiveram seu direito violado.

A ação penal é tratada no art. 186 do CP.

2. ART. 185. USURPAÇÃO DE NOME OU PSEUDÔNIMO ALHEIO

Revogado pela Lei nº 10.695/2003.



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



3. ART. 186. AÇÃO PENAL

A ação penal irá variar de acordo com o crime:

Violação de direito autoral na modalidade simples (sem intuito de lucro): ação penal privada (mediante queixa).

Violação de direito autoral nas modalidades qualificadas (§§1º e 2º): ação penal pública incondicionada.

Violação de direito autoral em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público: ação penal pública incondicionada.

Violação de direito autoral para oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite (§3º): ação penal pública condicionada à representação.



CAPÍTULO 39 — DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL: DOS CRIMES CONTRA O PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

Artigos 187 a 191 revogados pela Lei nº 9.279/96 (Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial).

CAPÍTULO 40 — DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL: DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Artigos 192 a 195 revogados pela Lei nº 9.279/96 (Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial).

CAPÍTULO 41 — DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL: DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Artigo 196 revogado pela Lei nº 9.279/96 (Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial).



CAPÍTULO 42 — DOS CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O bem jurídico tutelado é a organização do trabalho, bem comum de todos. As condutas previstas no CP envolvem **violência ou fraude**, que visam atrapalhar o desempenho do trabalho no âmbito geral. Não é qualquer conduta atentatória à organização do trabalho que interessará ao direito penal.

Segundo os Tribunais Superiores, não havendo lesão ao direito dos trabalhadores de forma coletiva, com impacto social relevante, ou ofensa aos órgãos que lhes preservam, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Com efeito, a competência federal não alcança os delitos que atingem somente direitos individuais, de determinado grupo de trabalhadores, e não a categoria como um todo. A competência será da Justiça Estadual quando a conduta vulnerar um trabalhador ou grupo de trabalhadores tão somente na esfera de liberdade individual.

1. ART. 197. ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE TRABALHO

O art. 197 dispõe que constitui atentado contra a liberdade do trabalho a conduta de constranger alguém, mediante **violência ou grave ameaça**:

I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias.

A pena é de detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. É obrigatório o concurso material de crimes em caso de violência (lesão corporal, por exemplo).

II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de greve ou paralisação de atividade econômica.

A pena é de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Trata-se também de infração de menor potencial ofensivo.

Quando as condutas forem praticadas com violência ou grave ameaça não será possível o acordo de não persecução penal.

O tipo tutela a liberdade na escolha profissional.

O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige qualidade especial do agente.

A consumação ocorre quando a vítima cede ao constrangimento, fazendo ou deixando de fazer aquilo que o constrangedor exige. Trata-se de um **crime material**, não bastando o constrangimento. Há que se ter o resultado naturalístico. O crime é também permanente, uma vez que a consumação prolonga-se no tempo. É viável a tentativa.

No caso do inc. II, greve é o abandono coletivo do trabalho, sinônimo de greve. O crime consiste em emprego de violência para coagir a participar do movimento paralisista. Não se confunde com a participação voluntária em greve, seguida do uso de violência, tipificada no art. 200 do CP.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 198. ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE CONTRATO DE TRABALHO E BOICOTAGEM VIOLENTA

Segundo o art. 198, configura o crime a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. A pena é de detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Havendo o emprego de violência ou grave ameaça, não será possível o acordo de não persecução penal.

Trata-se de crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa.

Tem-se um exemplo de norma penal em branco, vez que o conceito de contrato de trabalho está na CLT.

Há duas condutas no dispositivo legal. A primeira consiste em constranger a celebrar contrato de trabalho (atentado contra a liberdade de trabalho). A segunda é o constrangimento a não fornecer ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial agrícola (boicotagem violenta).

Segundo entendimento majoritário, tratando-se de crimes diversos, embora previstos no mesmo dispositivo, configuram um **tipo misto cumulativo**. Isso porque, se o agente constrange alguém a celebrar o contrato de trabalho e constrange outra pessoa ou a mesma pessoa a não fornecer determinado produto a outrem, haverá a prática de dois crimes, em concurso.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 199. ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional acarreta pena de detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

A conduta é de constranger alguém a se filiar ou se desfilial de sindicato ou associação profissional. O direito à livre associação é garantido constitucionalmente e engloba o direito de não se associar.

O crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. A consumação ocorre quando há efetivamente o constrangimento, fazendo com que o indivíduo participe ou deixe de participar do sindicato ou associação. Ou seja, quando a vítima cede, o crime se consuma. Assim, o crime é material, pois requer o resultado naturalístico. A tentativa (*conatus*) é admissível.

O crime é praticado a título doloso e não se exige especial fim de agir.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 200. PARALISAÇÃO DE TRABALHO, SEGUIDA DE VIOLÊNCIA OU PERTURBAÇÃO DA ORDEM

Segundo art. 200, haverá crime com a conduta de participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra coisa. Conforme dispõe o parágrafo único, para que se considere coletivo o abandono de trabalho é indispensável o concurso de, pelo menos, três empregados. Tem-se, no parágrafo, uma norma penal explicativa, já que esclarece o que se entende por abandono coletivo.

Dessa forma, admite-se que seja feita a greve, mas não se permite a prática de violência contra pessoa ou coisa. Inclusive, o direito pacífico de greve é assegurado constitucionalmente, no art. 9º, *caput*, da CF.

A pena é de detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência (concurso material obrigatório). É infração de menor potencial ofensivo. Se cometido com violência, não admite o acordo de não persecução penal.

O crime é plurissubjetivo ou de concurso necessário, vez que se exige o quantitativo mínimo de três empregados.

A suspensão do trabalho, em inglês *lock out*, ocorre quando o **empregador** figura como autor do delito. Neste caso, a doutrina majoritária entende que a suspensão também deve ser coletiva.

A ação penal é pública incondicionada e a competência, em regra, é da Justiça Federal.



5. ART. 201. PARALISAÇÃO DE TRABALHO DE INTERESSE COLETIVO

Segundo o art. 201, configura crime a conduta de participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Também é infração de menor potencial ofensivo. A pena é mais gravosa em relação aos tipos anteriores, pois a interrupção é de uma obra pública, atingindo número maior de pessoas.

O sujeito ativo é o empregado, no caso de abandono coletivo (greve), ou o **empregador**, no caso da suspensão coletiva ou *lock out*. O sujeito passivo será a coletividade (crime vago).

Não importa se a greve é pacífica ou não. Basta o abandono coletivo de trabalho e a interrupção da obra pública, não se exigindo a violência à coisa ou a pessoa.

O crime é praticado a título doloso e não se exige especial fim de agir.

A competência é, como regra, da Justiça Federal.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 202. INVASÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL OU AGRÍCOLA. SABOTAGEM.

Constitui crime invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. A pena é de reclusão, de um a três anos, e multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Trata-se de tipo misto cumulativo, já que na mesma disposição legal encontram-se duas figuras delitivas diferentes (invadir ou ocupar; danificar), as quais podem ser praticadas em concurso.

O crime é comum. Somente pode ser praticado na modalidade dolosa. Há o especial fim de agir, consistente na finalidade de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Não se pune a forma culposa.

Se o indivíduo invade ou ocupa o estabelecimento, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, estará consumado o delito. Se efetivamente impede ou embaraça, há exaurimento do crime. Dessa forma, o delito é formal.

A ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 203. FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA

Segundo o art. 203, constitui crime a conduta de frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. A pena é de detenção de 1 ano a 2 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. É infração de menor potencial ofensivo, de concurso material necessário quando há violência.

Tem-se uma norma penal em branco homogênea, cujo complemento será dado pela legislação trabalhista. É também crime de ação múltipla ou conteúdo variado.

O **§ 1º** prevê que nas mesmas penas incorre quem (condutas equiparadas):

I. Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida;

No caso do inc. I há elemento subjetivo do tipo, consistente no fim de impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida.

II. Impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais.

O **§ 2º** estabelece que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Com a incidência da causa de

aumento de pena, a infração deixa de ser de menor potencial ofensivo. A doutrina critica o rol das pessoas presumidas como mais vulneráveis e sugere que seria mais adequado permitir ao magistrado avaliar, no caso concreto, se há vulnerabilidade ou não..

O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa. O sujeito passivo é o trabalhador prejudicado.
A ação penal é pública incondicionada.

8. ART. 204. FRUSTRAÇÃO DE LEI SOBRE A NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO

Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. A pena é de detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. É infração de menor potencial ofensivo.

Parte da doutrina entende que o dispositivo em questão **não foi recepcionado pela CF/88**, pois esta garante a igualdade entre o brasileiro e o estrangeiro residente no país, motivo pelo qual não caberia conferir maior proteção à nacionalização do trabalho.

De qualquer sorte, o intuito da norma é proteger o interesse do trabalhador brasileiro contra os avanços de estrangeiros no mercado do trabalho.

O crime é comum.

A ação penal é pública incondicionada.

9. ART. 205. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

Segundo o art. 205, constitui crime a conduta de exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa. A pena é de detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo. Exemplo: advogado suspenso por decisão administrativa da OAB.

Trata-se de **crime habitual**, pois o núcleo estabelece *exercer atividade*, pressupondo-se a reiteração da conduta. Dessa forma, não é cabível a tentativa do crime. Trata-se também de um crime próprio, somente podendo praticar o sujeito impedido por decisão administrativa.

É crime de mera conduta. O tipo não descreve resultado naturalístico.

O professor Rogério Sanches Cunha faz o seguinte questionamento: **o médico impedido de exercer a profissão, após ter cancelada pelo CRM a sua inscrição, pratica o delito de exercício de atividade com infração de decisão administrativa ou o exercício ilegal da medicina (art. 282 do CP)?**

O STF entende que o médico pratica o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa (art. 205 do CP), eis que se trata de uma **norma específica**. Isso porque o médico tem, por uma decisão do CRM, o impedimento de exercício da atividade.⁴⁰

O crime é praticado na forma dolosa e não se exige qualquer finalidade especial.

A ação penal é pública incondicionada.

10. ART. 206. ALICIAMENTO PARA O FIM DE EMIGRAÇÃO

Segundo o art. 206, recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro, acarreta pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. Cabe suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

Emigrar significa sair do país. Não é preciso levar a vítima efetivamente para o território estrangeiro. Esse é apenas o especial fim de agir. Se recrutar a vítima com essa finalidade, o delito já estará consumado. Trata-se de um crime formal.

O que se tutela é o interesse do Estado na permanência de trabalhadores brasileiros no território nacional.

⁴⁰ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial**. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 499.



O crime é comum, já que pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é o Estado, mas os trabalhadores recrutados poderão figurar como vítimas também.

O crime é praticado dolosamente. No entanto, é preciso o especial fim de agir, que é a intenção de levar a vítima para o estrangeiro.

Há discussão acerca da quantidade mínima de trabalhadores para a tipificação da conduta. A doutrina diverge. Prevalece o entendimento de que seriam no mínimo três trabalhadores, vez que o CP, quando se contenta com o número mínimo de dois, o fez expressamente.

A ação penal é pública incondicionada.

11. ART. 207. ALICIAMENTO DE TRABALHADORES DE UM LOCAL PARA OUTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL

Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional é o crime descrito pelo art. 207, cuja pena é de detenção de um a três anos, e multa.

Não há o intuito de emigração, mas sim levar trabalhadores de uma localidade para outra dentro do território nacional. O objetivo da norma é evitar o despovoamento de uma região e o consequente inchaço populacional de outra. Deve haver equilíbrio entre as regiões do território, coibindo-se o deslocamento em massa de trabalhadores.

Trata-se de infração de médio potencial ofensivo, pois admite suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

O crime é formal, pois independe que o agente consiga levar os trabalhadores para outra localidade do território nacional.

Segundo o §1º, incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de origem.

Por seu turno, o §2º traz causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, caso a vítima seja menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena, portadora de deficiência física ou mental.

A questão quanto à quantidade mínima de trabalhadores, abordada no comentário ao dispositivo anterior, também tem lugar no art. 207. Prevalece o entendimento quanto ao número mínimo de três trabalhadores.

O crime se consuma no momento do recrutamento, ainda que não haja o efetivo transporte do trabalhador ao local pretendido. Portanto, o delito é formal. No caso do §1º (figuras equiparadas), o crime se consuma no momento em que o agente nega ao trabalhador o recurso para obter o retorno à sua origem.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 43 — DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS: DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO

A liberdade de consciência e de crença é garantida constitucionalmente, conforme art. 5º, inc. VI, CF. É livre o exercício de cultos religiosos, bem como é assegurada a proteção aos locais onde são realizados.

1. ART. 208. ULTRAJE A CULTO E IMPEDIMENTO OU PERTURBAÇÃO DE ATO A ELE RELATIVO

Segundo o art. 208, constitui crime escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. A pena é de detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, que admite suspensão condicional do processo e transação penal.

O crime é comum. Na primeira conduta, escarnecer de alguém publicamente, verifica-se o crime praticado contra uma pessoa determinada. Nas demais formas (impedir ou perturbar; vilipendiar), o sujeito passivo é a coletividade religiosa.

Escarnecer significa zombar, ridicularizar. Não se confunde com a injúria qualificada, prevista no art. 140, § 3º, do CP, na qual se atribui qualidade negativa a pessoa em razão de sua crença religiosa.

O parágrafo único estabelece que, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3. Trata-se de causa de aumento de pena que incide na terceira fase da dosimetria, sem prejuízo da pena correspondente à violência. A doutrina entende que a majorante tem lugar quando a violência é empregada contra **pessoa** e também contra **coisa**, pois o tipo penal não faz essa distinção.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 209. IMPEDIMENTO OU PERTURBAÇÃO DE CERIMÔNIA FUNERÁRIA

Nos termos do art. 209, há crime na conduta de impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. A pena é de detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cabendo transação penal e suspensão condicional do processo.

O parágrafo único estabelece que, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da pena correspondente (concurso material de crimes).

O crime é comum. O sujeito passivo é a coletividade, sendo representada pela família, amigos e pessoas que tinham alguma relação com o falecido.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 210. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA

O art. 210 prevê crime na conduta de violar ou profanar sepultura ou urna funerária. A pena é de reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. É infração de médio potencial ofensivo, cabendo *sursis* processual e acordo de não persecução penal.

O bem jurídico tutelado é o respeito aos mortos.

O crime é comum. Qualquer pessoa pode praticar, inclusive os familiares do falecido. O sujeito passivo é a coletividade, amigos e parentes do morto.

Violar significa abrir, quebrar, devassar. Profanar é ofender, desrespeitar.

É possível haver concurso formal de crimes, caso o ato de profanação se traduza em calúnia contra o morto. Conforme já estudado, na esfera dos crimes contra a honra, o único passível de configuração contra os mortos é a calúnia.



Caso haja furto, ou seja, se o indivíduo quer subtrair algum bem móvel de dentro da sepultura, o delito ora em comento ficará absorvido, eis que se trata de crime-meio.

Na hipótese em que o agente viola sepultura com a finalidade de subtrair ou destruir o cadáver, aplica-se o princípio da consunção, caracterizando-se o crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

Segundo a doutrina, a sepultura vazia ou o monumento à memória de alguém, que não contenham partes de um cadáver, não poderão ser objeto material do crime.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 211. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele é crime punido com reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Trata-se de infração de médio potencial ofensivo, cabendo suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

A tutela penal se volta ao sentimento de respeito aos mortos.

O cadáver é coisa fora do comércio, logo, não pode ser objeto de furto, exceto nos casos em que tenha valor econômico, por estar afetado ao patrimônio de determinada pessoa jurídica, como um museu, instituto de pesquisas ou faculdade de medicina.

Não podem ser objeto do crime em comento esqueletos, cinzas e múmias.

O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por familiares do morto. O sujeito passivo é a coletividade, bem como parentes do falecido.

Não se perquire o especial fim de agir. Ademais, não se pode invocar a autodefesa para justificar a prática do crime. Se a intenção é impedir a apuração de um crime de homicídio, o agente incorrerá em concurso material de delitos.

Entende a doutrina ser necessário analisar a hipótese em concreto mas, em princípio, não se mostra possível o concurso da fraude processual com a ocultação, destruição ou subtração do cadáver. Se o objetivo do indivíduo era alterar cena de crime e, para isso, destruiu o cadáver, um dos crimes restará absorvido pelo outro e, por certo, o crime de ocultação de cadáver vai prevalecer, por ser mais grave.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 212. VILIPÊNDIO A CADÁVER

Segundo o art. 212, haverá crime quando o agente vilipendiar cadáver ou suas cinzas. A pena é de detenção, de 1 a 3 anos, e multa. A infração é de médio potencial ofensivo. Caberá suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

O crime é comum, isto é, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por parentes do morto. O sujeito passivo é a coletividade, em especial os familiares do falecido.

Vilipendiar é sinônimo de desprezar, desdenhar, aviltar, rebaixar. O crime é de execução livre, nas mais variadas formas. Exemplo: colocar o cadáver em posições ofensivas, escarrar, urinar ou jogar objetos no cadáver.

O crime se consuma com a prática do ato de aviltamento, o que pode ocorrer também por gestos ou palavras.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 44 — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

A lei protege o direito de escolha ao parceiro sexual. Quando tal direito é violado, o Estado deve intervir. No presente capítulo, são tipificadas as seguintes condutas:

- Estupro (art. 213)
- Violação sexual mediante fraude, também chamado de estelionato sexual (art. 215)
- Importunação sexual (art. 215-A, introduzido pela Lei nº 13.718/18)
- Assédio sexual (art. 216-A)

A Lei nº 13.718/18 promoveu importantes alterações nos crimes contra a dignidade sexual, que serão abordadas ao longo do presente estudo.

1. ART. 213. ESTUPRO

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena é de reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. Nos §§ 1º e 2º estão previstas as formas qualificadas:

§ 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

O estupro é **crime hediondo em todas as formas**, simples ou qualificado, tentado ou consumado. É, assim, insuscetível de graça, anistia, indulto e fiança.

Constranger é o verbo núcleo do tipo e significa retirar a liberdade de autodeterminação de alguém.

O constrangimento pode ser para a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso, de gravidade assemelhada à cópula vaginal.

Não houve *abolitio criminis* em relação ao atentado violento ao pudor, previsto, até 2009, no art. 214 do CP. Em observância ao princípio da continuidade típico-normativa, o fato continua sendo criminoso, porém tratado em tipo penal diverso. Assim, o atual art. 213 representa a junção do crime de estupro e do atentado violento ao pudor (antiga figura do art. 214 do CP).

A conjunção carnal é a cópula vaginal. Já os atos libidinosos são aqueles revestidos de conotação sexual, como o sexo oral, anal, beijo lascivo e o toque nas partes íntimas.

As lesões leves e as vias de fato são absorvidas pelo estupro. As lesões graves, gravíssimas e a morte qualificam o crime.

Em relação ao constrangimento para a conjunção carnal, a relação deve ser, necessariamente, heterossexual (pessoas de sexos biológicos opostos; não se trata de orientação sexual, mas de uma questão biológica). Mulher também pode ser sujeito ativo de estupro, como mandante ou auxiliando na execução.

Quanto à prática de ato libidinoso (praticar ou permitir que com ele se pratique), a situação pode envolver pessoas de mesmo sexo biológico ou distintos. Não é necessário o contato físico erótico entre estuprador e vítima, desde que o sujeito passivo tenha envolvimento no ato. Exemplo: sujeito que ordena a outro, mediante grave ameaça, que toque em suas próprias partes íntimas (automasturbação).

O crime é bicomum. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo ou passivo.

Se o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima à conjunção carnal e também a outro ato libidinoso, como sexo anal, quantos crimes comete?

Segundo entendem os Tribunais Superiores, trata-se de crime único, pois o art. 213 do CP constitui um tipo misto alternativo. Assim sendo, a pluralidade de comportamentos não acarreta o concurso

de crimes, mas poderá ser valorada de maneira negativa pelo magistrado na dosimetria da pena (art. 59 do CP).

O crime é praticado somente na forma dolosa, não se exigindo nenhuma finalidade específica. O delito é material e é perfeitamente compatível com a forma tentada quando, iniciada a execução do ato, este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A depender da idade da vítima, três situações distintas podem se apresentar:

- a) Vítima com idade igual ou superior a 18 anos: estupro simples (art. 213, *caput*).
- b) Vítima maior de 14 e menor de 18 anos: estupro qualificado (art. 213, § 1º, parte final).
- c) Vítima menor de 14 anos: estupro de vulnerável (art. 217-A, *caput*).

Pessoa com idade igual ou superior a 14 anos, ausente outra causa de vulnerabilidade, pode praticar consensualmente conjunção carnal ou outro ato libidinoso.

Rogério Sanches Cunha aborda a questão do *stealthing* (dissimulação), conduta que corresponde à retirada do preservativo durante o ato sexual, sem o consentimento do parceiro, que assentira com a prática condicionada ao uso da proteção.

A criminalização da conduta passa pela análise das peculiaridades do caso concreto. Caso o indivíduo retire a proteção e encontre resistência do parceiro na continuidade do ato sexual, valendo-se então do emprego de violência ou grave ameaça, estará caracterizado o estupro. Todavia, se a retirada é sorrateira e o parceiro ou parceira não percebe, poderá se configurar o tipo do art. 215 do CP, o estelionato sexual.⁴¹

A ação penal é pública incondicionada em todos os casos de estupro, nos termos do art. 225, com a redação dada pela Lei nº 13.718/18, superando-se definitivamente o debate a respeito da eficácia da Súmula 608 do STF: “No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.”

2. ART. 214. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR

Revogado pela Lei nº 12.015/2009

3. ART. 215. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE

O art. 215 estabelece como crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena é de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Nos termos do parágrafo único, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

O delito ora em comento é comumente chamado de *estelionato sexual*, uma vez que são empregados meios fraudulentos para a prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A vítima é levada a erro e, assim, não expressa o seu consentimento quanto à relação sexual, que é obtida por meio enganoso.

O crime somente pode ser praticado na forma dolosa. Se houver o consentimento válido da vítima, a conduta típica restará afastada.

O crime é bicomum, visto que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo. Quando a vítima é menor de 14 anos, a tutela penal se dá no âmbito do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).

O tipo prevê “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”, diferentemente do estupro, em que a fórmula legal é “praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.

⁴¹ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial.** 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 522-523.



Conclui-se, assim, que no caso do art. 215 do CP o agente necessariamente pratica o ato sexual com a vítima. Não haverá o crime nas hipóteses em que a vítima é obrigada a praticar o ato libidinoso em si mesma (automasturbação, por exemplo) ou venha a praticar no agente (sexo oral, por exemplo).

A fraude ou meio similar engana, retira ou diminui a liberdade de escolha. **Exemplo:** embriaguez incompleta, sedação ou anestesia incompleta, falso médico que se vale da suposta profissão para realizar exames íntimos, falsos rituais de cura espiritual, etc.

É importante notar que não há violência ou grave ameaça. Há vício no consentimento. A vítima tem capacidade de escolha, porém é ludibriada.

Se a embriaguez, sedação ou coma retirar por completo o discernimento da vítima, o crime será de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), ante a incapacidade da vítima em manifestar consentimento.

A doutrina entende ser possível a prostituta (o) ser vítima da violação sexual mediante fraude. Se o cliente, após combinar o programa e uma vez realizado o ato, foge sem pagar a quantia previamente acertada, a prostituta foi vítima do crime, vez que a falsa promessa de pagamento caracterizou-se em fraude para a prática sexual.

O crime é material. Consuma-se com realização da conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A tentativa é admissível.

A ação penal é pública incondicionada, por força do art. 225, com a redação dada pela Lei nº 13.718/18.

4. ART. 215-A. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

O art. 215-A foi introduzido no CP pela Lei nº 13.718/18. A conduta consiste em praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

É crime de médio potencial ofensivo. Admite a suspensão condicional do processo, uma vez preenchidos os requisitos legais do art. 89 da Lei nº 9.099/95, e também o acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

O tipo penal em comento surge no contexto em que certas práticas com caráter libidinoso e para satisfação da lascívia estavam tuteladas de forma deficiente pelo ordenamento jurídico, visto que não havia um meio termo entre o estupro, o estupro de vulnerável e a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, prevista no art. 61 da LCP. **Exemplo:** sujeito que, no transporte coletivo, para satisfazer a própria lascívia, se masturba e ejacula em passageira. O fato não podia ser enquadrado como estupro (art. 213 do CP), considerando a ausência de violência ou grave ameaça. Também não podia ser classificado como violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP), tendo em vista que o ato libidinoso não foi praticado com a vítima. Diante disso, a conduta era punida como contravenção penal, prevista no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Com o advento da Lei nº 13.718/2018, o fato passa a ser tipificado como importunação sexual, delito do art. 215-A do CP, com uma punição mais consentânea à gravidade em abstrato.

As condutas que se amoldam ao novo tipo penal não apresentam a mesma reprovabilidade de uma conjunção carnal, sexo anal ou oral, praticados em contexto violento, mas também não poderiam continuar subtuteladas como contravenção penal.

O art. 61 do Decreto-lei nº 3.688/41 (importunação ofensiva ao pudor) foi expressamente revogado pelo art. 215-A do CP. Aplica-se, na hipótese, o princípio da continuidade normativo-típica. Todavia, tratando-se de *novatio legis in pejus*, não poderá retroagir para alcançar situações ocorridas antes da vigência da Lei nº 13.718/18.

O crime é bicomum. É preciso atentar para a majorante estabelecida no art. 226, inc. II, do CP.



Seria possível a vítima do crime ser menor de 14 anos? Há possibilidade de desclassificação do estupro de vulnerável para a conduta do art. 215-A, nos casos de atos libidinosos menos graves, como o toque furtivo sobre as roupas?

Até o presente momento, o STJ não admite a desclassificação comentada, ao argumento de que deve ser observado o princípio da especialidade (art. 217-A do CP). No entanto, alguns ministros já manifestaram intenção de debater mais a fundo a possibilidade.

O núcleo do tipo penal é o verbo praticar, que significa fazer, realizar, um ato libidinoso (ação com propósito lascivo). Exemplo: masturbação e ejaculação, toque nas partes íntimas sobre as roupas, fricção dos órgãos genitais no corpo de outrem (também chamada de *frotteurismo*, palavra de origem francesa, que significa tocar e se esfregar em uma pessoa sem seu consentimento). O dispositivo exige que o ato libidinoso seja praticado contra pessoa ou grupo de pessoas específico. Se o ato não for direcionado a pessoa determinada, tem-se, em princípio, o crime de ato obsceno, previsto no art. 233 do CP.

Apesar de ser mais frequente em ambientes públicos, em que há aglomeração e contato físico entre pessoas, o crime também pode ser praticado em locais fechados, como o interior de uma residência.

Ademais, o tipo apresenta subsidiariedade expressa, conforme se vê no preceito secundário (*se o ato não constitui crime mais grave*). Se há constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, o crime é de estupro (art. 213 do CP).

O delito é material, consumando-se com a prática do ato libidinoso. A importunação envolve um profundo desconforto, mal estar.

Exige-se um elemento subjetivo específico, consistente no objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Não há previsão de modalidade culposa.

A tentativa, em tese, é possível. Isso porque se trata de crime plurissubsistente. Porém, de difícil verificação na prática.

Convém lembrar que delito plurissubsistente é aquele cuja execução pode ser fracionada em vários atos.

A ação penal é pública incondicionada (art. 225 do CP).

5. ART. 216. ATENTADO AO PUDOR MEDIANTE FRAUDE

Revogado pela Lei nº 12.105/09

6. ART. 216-A. ASSÉDIO SEXUAL

O art. 216-A tipifica a conduta de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parcela da doutrina entende desnecessária a criminalização, pois o assédio pode ser satisfatoriamente tutelado pelo Direito Civil, do Trabalho e Administrativo.

A Organização Mundial do Trabalho (OIT) define o assédio sexual como insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, desde que sejam uma condição para manter o emprego, influenciar nas promoções, prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar.

O bem jurídico tutelado é a liberdade sexual e o exercício do trabalho em condições dignas, desprovidas de constrangimentos e humilhações.

O verbo núcleo do tipo é constranger. Todavia, a redação do tipo legal é criticada, pois no crime de assédio não há emprego de violência ou grave ameaça. Conforme já estudado, constranger, para fins penais, significa compelir, retirar a liberdade de autodeterminação. Exige-se o dissenso, isto é, o comportamento contra a própria vontade.



Observa-se da redação do dispositivo que o legislador também não mencionou constranger a quem. Ora, a conduta de constranger corresponde necessariamente a um determinado comportamento. Para o professor Cleber Masson, o tipo do art. 216-A deve ser entendido como uma modalidade específica de constrangimento ilegal, sem violência ou grave ameaça à pessoa. A conduta deve ser compreendida como molestar, perturbar, intimidar. Exemplos: promoção funcional condicionada à satisfação sexual do superior hierárquico; ameaça de demissão caso não pratique atos libidinosos com o chefe.⁴²

Deve haver relação entre o constrangimento e o exercício laboral. Assédio fora do ambiente de trabalho, desvinculado da posição de hierarquia ou ascendência, não tipifica a conduta.

O crime é bipróprio ou especial, pois somente pode ser cometido por superior hierárquico da vítima ou por quem tenha ascendência sobre ela, seja a relação de direito público ou privado. Haverá assédio na relação entre patrão e empregada doméstica.

Não são relevantes o sexo e a orientação sexual (pode haver uma relação homossexual de assédio).

A vantagem ou favorecimento sexual pode ser para o próprio agente ou para outrem.

Segundo o entendimento tradicional da doutrina e da jurisprudência, para que se configure o assédio, é imprescindível haver hierarquia ou ascendência do autor do crime em relação à vítima, no âmbito do exercício de emprego, cargo ou função. Assim, não se cogitava de assédio sexual na relação entre professores e alunos, ou na relação entre líderes religiosos e seus fiéis, pois ausente hierarquia derivada do exercício de emprego, cargo ou função.

Todavia, em 2019, o STJ julgou ser possível inserir no tipo do assédio sexual a conduta do professor que, no ambiente da sala de aula, aproxima-se de aluna e, com o objetivo de obter vantagem sexual, toca partes do corpo da moça. Consideraram os ministros que a ascendência do docente sobre os alunos é inerente ao exercício da profissão, já que o professor pode interferir diretamente na avaliação, atribuição de notas e na aprovação dos discentes.⁴³

O elemento subjetivo é o dolo, acrescido do especial fim de agir, caracterizado pelo intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.

O crime é formal. Consuma-se com o constrangimento, independentemente da realização do ato desejado pelo superior hierárquico.

Se a vítima tiver menos de 14 anos, ou for vulnerável (pessoa com deficiência ou doença mental incapacitantes), a doutrina indica ser a hipótese de estupro de vulnerável, tentado ou consumado, a depender da situação fática concreta. Não se cogita de assédio sexual em face de vulneráveis.

Nos termos do § 2º, a pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.

A ação penal é pública incondicionada.

⁴² MASSON, Cleber. Direito Penal. **Parte Especial. Vol. 3.** São Paulo: Gen Método, 2017, pp. 49-50

⁴³ REsp 1.759.135/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/08/2019.



CAPÍTULO 45 — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL

1. ART. 216-B. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL

A Lei nº 13.772/18 introduziu no CP o art. 216-B, segundo o qual é crime produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Comina-se pena de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. É infração de menor potencial ofensivo, cabendo os institutos da Lei nº 9.099/95. Admitida a transação penal, torna-se inviável o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inc. I, do CPP.

O tipo soluciona a punição a indivíduos que registram a prática de atos sexuais entre terceiros sem consentimento ou autorização. Antes da Lei nº 13.772/18 não havia punição, no âmbito penal, para aquelas pessoas que instalavam câmeras ou outros dispositivos para captar cenas de nudez ou de caráter sexual em banheiros públicos ou privados, hotéis ou cômodos alugados.

O bem jurídico protegido é a intimidade sexual. O crime é bicomum. Porém, se há envolvimento de criança ou adolescente, prevalece o princípio da especialidade, aplicando-se as disposições do ECA (art. 240 ou 241-C da Lei nº 8.069/90, a depender do caso).

O elemento subjetivo é o dolo. Não se exige especial fim de agir. Não se admite modalidade culposa.

A cena registrada deve ter sido praticada em caráter íntimo e privado. Se o agente filma um casal mantendo relações sexuais em uma praça ou parque, em local aberto ao público, não haverá o crime, pois as partes abriram mão de sua intimidade. Inclusive, os indivíduos que praticam atos libidinosos em público poderão responder pela figura do art. 233 do CP (ato obsceno). Se há autorização de todos os envolvidos, o fato é atípico, salvo na hipótese de envolvimento de criança ou adolescente, situação na qual se configura o crime do art. 240 do ECA.

A tentativa é, em tese, possível. Isso porque se trata de crime plurissubsistente (a execução pode ser fracionada em vários atos). Seria a hipótese de instalação oculta do dispositivo pelo agente com o fim de registro, e, apesar do funcionamento da câmera, a vítima percebe a tempo e desliga o aparelho.

Se o agente faz o registro indevido e posteriormente divulga a cena, deve responder pelos crimes dos artigos 216-B e 218-C em concurso material? É necessário investigar o dolo do agente. Se, inicialmente, o indivíduo faz o registro para a satisfação da própria lascívia e, tempos depois, resolve divulgar a cena, é possível se cogitar do concurso de crimes, diante dos contextos fáticos distintos. Por outro lado, se o registro já é feito com o intuito de divulgação, ou são feitos de forma simultânea (transmissão ao vivo ou *streaming*), a aplicação do princípio da consunção mostra-se mais adequada, sendo o registro, menos grave, absorvido pela conduta do art. 218-C do CP, mais gravosa. Nesse exato sentido tem-se o posicionamento do prof. Rogério Sanches Cunha.⁴⁴

O parágrafo único prevê conduta equiparada. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.

Assim, temos que, no *caput*, a cena registrada é verdadeira. Já no parágrafo único, a fotografia, vídeo ou áudio não é verdadeiro. Foi feita uma montagem, ou seja, foram acrescentados elementos que não ocorreram na realidade. **Exemplo:** o agente pega imagem de uma modelo nua e, por meio do programa de computador, troca o rosto da modelo pelo da vítima.⁴⁵

⁴⁴ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial.** 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 540-541.

⁴⁵ Fonte: Dizer o Direito. Acesso e disponibilidade em: <https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/lei-137722018-crime-de-registro-nao.html>



Tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa. Trata-se, portanto, de crime bicomum.

O elemento subjetivo é o dolo. Não se exige especial fim de agir (vingança ou qualquer outra motivação especial). Não se admite modalidade culposa.

O crime se consuma ainda que o agente tenha feito a montagem com o intuito apenas de diversão, ou seja, com a intenção de brincar com a vítima.

A Lei nº 13.772/2018 entrou em vigor na data de sua publicação, em 20/12/2018. Por se tratar de *novatio legis in pejus*, não se aplica a fatos ocorridos antes de sua vigência. Assim, os atos praticados antes de 20/12/2018 não poderão ser punidos com base no art. 216-B do CP.

A ação penal é pública incondicionada, nos termos do art. 225 do CP.



CAPÍTULO 46 — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL

Vulneráveis são os indivíduos em situação de fragilidade, em razão da idade ou outra condição médica ou psicológica. São aqueles que, biologicamente, não têm capacidade para compreender o que seja ou quais as consequências de um ato sexual, por estarem em condição de saúde ou psíquica que não permita saber ou discernir.

A lei despreza, por completo, o consentimento dos vulneráveis. Não há vontade penalmente relevante.

Dessa forma, a vulnerabilidade tem natureza objetiva e não comporta a discussão sobre presunção relativa ou absoluta. A partir de provada idade inferior a 14 anos, ou de laudo médico que ateste a doença, a incapacidade de discernir, não há que falar em consentimento, visto que a análise é objetiva.

Os tipos penais que tutelam os vulneráveis no CP são os seguintes:

- Estupro de vulnerável (art. 217-A).
- Corrupção de menores (art. 218). Não se confunde com a previsão do art. 244-B do ECA.
- Satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A).
- Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável (art. 218-B).
- Divulgação de cena de estupro, de estupro de vulnerável, de sexo ou pornografia (art. 218-C).

1. ART. 217. SEDUÇÃO

Revogado pela Lei nº 11.106/2005.

2. ART. 217-A. ESTUPRO DE VULNERÁVEL

O *caput* do art. 217-A tem a seguinte redação: *ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos*. A pena é de reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. O critério etário foi o adotado pelo legislador. Não se utiliza mais a expressão presunção de violência. Em seu lugar, passa a existir o conceito de vulnerabilidade.

A Súmula 593 do STJ já deixava clara a concepção objetiva da vulnerabilidade, ao estabelecer que "o crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente."

O § 1º, primeira parte, estabelece que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no *caput* com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato.

A enfermidade ou doença podem ser permanentes ou temporárias, congênitas ou adquiridas, desde que retirem completamente a capacidade de consentir. Nesses casos, há necessidade de laudo médico pericial para atestar o grau de comprometimento do indivíduo. O critério adotado pelo legislador foi o sistema biopsicológico.

É preciso compatibilizar a previsão legal com a Lei nº 13.146/15, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de sorte a se resguardar o direito à gestão da vida sexual de tais indivíduos. O Código Penal não pretende tolher o exercício da liberdade sexual por pessoas com graus leves e moderados de deficiência e



que possuem capacidade de discernimento e compreensão. O que a lei penal veda é o abuso. Daí a importância do laudo médico, para atestar o grau de deficiência da vítima.⁴⁶

O § 1º, parte final, prevê a prática do crime também contra aquele que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Nesse caso, a interpretação da cláusula genérica deve se dar em sentido amplo, abrangendo qualquer motivo que retire a capacidade de resistir ao ato sexual. Exemplos: coma profundo, sedação, anestesia geral. O agente pode tanto provocar a situação, como se aproveitar de quadro já existente.

Nos parágrafos 3º e 4º temos as formas qualificadas pelo resultado (crime preterdoloso). No primeiro caso, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena passa a ser de reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. Se resulta morte, a reclusão será de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

O estupro de vulnerável é hediondo em todas as suas formas. Aplicam-se os rigores da Lei nº 8.072/90, seja o crime tentado ou consumado.

Não se exige a violência ou grave ameaça como meio de execução. A vulnerabilidade já afasta a capacidade de consentimento.

O § 5º, introduzido pela Lei nº 13.718/18, estabelece que as penas previstas no *caput* e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Assim, observa-se que o enunciado sumular do STJ foi introduzido, com algumas modificações, no texto legal. Segundo a doutrina, a interpretação do §5º deve ser restrita quando se cuidar do portador de enfermidade ou deficiência mental, para a devida compatibilização com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos moldes já explicitados.

É importante distinguir o estupro de vulnerável da violação sexual mediante fraude, prevista no art. 215 do CP.

No estupro de vulnerável, a vítima está totalmente privada de sua capacidade de resistência. Exemplo: vítima completamente sedada, embriagada ou drogada.

Já na violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP), também chamado de estelionato sexual, a vítima tinha presente a sua capacidade de resistência, mas foi enganada. Exemplo: exames ginecológicos com sedação ou anestesia parcial, falsos rituais de cura espiritual.

A ação penal, para todas as figuras do art. 217-A, será pública incondicionada.

3. ART. 218. CORRUPÇÃO DE MENORES

O art. 218 estabelece ser crime induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem. A pena cominada é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Apesar do *nomen iuris*, esta figura não se confunde com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais popularmente conhecido como corrupção de menores (embora não seja usada essa nomenclatura na Lei nº 8.069/90). A previsão da lei especial não tem qualquer cunho sexual e é aplicada a indivíduo maior de idade que cometa crime em concurso com menor de idade, independentemente da natureza da conduta criminosa.

Diante dessa situação, a doutrina sugere que o *nomen iuris* mais adequado ao tipo penal em comento seria “*mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outrem*”.

Percebe-se que a mediação pressupõe um triângulo constituído pelo mediador (sujeito ativo), a vítima (menor de 14 anos induzida) e o destinatário da atividade criminosa do mediador.

Consuma-se o crime com o comportamento erótico do menor de 14 anos para satisfazer a lascívia de outrem. Exemplo: indivíduo que induz menor de 14 anos a dançar nu para um terceiro. Ainda

⁴⁶A Lei nº 13.146 de 2015, em seu art. 6º, dispõe que “A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: II – exercer direitos sexuais e reprodutivos”. O artigo 8º do mesmo diploma preceitua que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à dignidade, entre outros.

que nenhum interesse sexual tenha sido despertado no terceiro, com o comportamento do vulnerável o crime já estará caracterizado. Tem-se, assim, um crime material, que exige o resultado naturalístico para a consumação. Não confundir com o art. 244-B do ECA, que é formal, nos termos da Súmula 500 do STJ.

A satisfação da lascívia, na presente hipótese, deve se dar por atividades contemplativas (contemplação passiva). Se houver contato físico, o crime poderá ser o do art. 217-A do CP.

Há certa semelhança com o tipo do art. 227 do CP (mediação para servir à lascívia de outrem). A diferença se dá quanto à idade da vítima.

O verbo núcleo do tipo é induzir, isto é, criar na mente de alguém menor de 14 anos a vontade de satisfazer a lascívia alheia.

A conduta deve atingir menores de 14 anos determinados. Se forem indeterminados, o crime será de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, estabelecido no art. 218-B do CP.

Uma parcela da doutrina, a exemplo do professor Guilherme de Souza Nucci, entende ser o tipo desnecessário, pois seria uma exceção pluralística à teoria monista quanto ao concurso de agentes. Para o referido doutrinador, a conduta consiste em participação moral no estupro de vulnerável, já que se induz o menor a um comportamento erotizado.⁴⁷

O crime é comum. O sujeito ativo é também chamado de proxeneta (mediador da lascívia alheia). Ressalte-se que proxeneta é diferente de cafetão ou rufião, conceitos que serão estudados oportunamente.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 218-A. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE

Segundo o art. 218-A,

praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, é crime, com pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

O bem jurídico tutelado é a dignidade sexual do menor de 14 anos, que deve ter um desenvolvimento moral sadio.

Não há envolvimento corporal do vulnerável com qualquer pessoa. O menor limita-se a presenciar a conjunção ou outro ato libidinoso, despertando, com isso, a lascívia do sujeito ativo ou de terceiros.

Trata-se de tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado (se praticar na presença ou induzir a presenciar, em relação à mesma vítima, no mesmo contexto fático, haverá crime único).

Segundo uma parcela da doutrina, não é necessária a presença física do menor no ambiente. Basta que a relação sexual seja presenciada ou assistida, ainda que por meios tecnológicos. Outra corrente entende que, por meios virtuais, o crime seria o previsto no art. 241-D do ECA.

O tipo exige especial fim de agir, consistente na intenção de satisfazer lascívia própria ou de outrem.

O crime é formal, pois se consuma quando o menor presencia a prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso. O crime não exige habitualidade, nem a efetiva satisfação sexual da pessoa envolvida.

A ação penal é pública incondicionada.

⁴⁷NUCCI, Guilherme de Souza. **Código Penal Comentado**. São Paulo: RT, 2010, p. 933.



5. ART. 218-B. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL

Nos termos do art. 218-B, *submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone* é crime punido com reclusão, de (quatro) a 10 (dez) anos.

O tipo é misto-alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado, pois prevê condutas praticadas contra vítimas que ainda não foram inseridas na prostituição, nos casos dos verbos *submeter, induzir, atrair ou facilitar* e, nos casos dos núcleos *impedir ou dificultar*, as vítimas são os indivíduos já prostituídos, isto é, que exercem o comércio sexual habitualmente.

O art. 244-A do ECA foi revogado tacitamente pelo art. 218-B.

A prostituição é definida como comércio sexual exercido com habitualidade. Pressupõe contato físico. Em nosso sistema penal, a prostituição, por si só, quando praticada por pessoa maior e capaz, não é crime. Pune-se a exploração da prostituição e o envolvimento de menores. No caso da exploração de adultos, o crime é o do art. 228 do CP.

O tipo penal abrange também condutas que não dependem de contato físico para a satisfação sexual. Exemplo: shows eróticos, disque-sexo.

O crime é comum. Deve-se atentar para a majorante do art. 226, inc. II, do CP, isto é, crime praticado por ascendente, padrasto ou madrastra, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Nesses casos, a pena aumenta-se da metade na terceira fase da dosimetria. O sujeito passivo é a pessoa menor de 18 anos, homem ou mulher, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. A doutrina destaca que, se menor de 14 anos, a hipótese poderá ser de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

Segundo o STJ, nos termos do art. 218-B do Código Penal, são punidos tanto aquele que capta a vítima, inserindo-a na prostituição ou outra forma de exploração sexual (*caput*), como também o cliente do menor prostituído ou sexualmente explorado (§ 1º). HC 371.633/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 19/03/2019 (Info 645).

Em outras palavras, este tipo penal incrimina:

a) o proxeneta, este punido pelo *caput* do art. 218-B;

b) e também o cliente da prostituição do menor, sancionado pelo § 1º do art. 218-B. O cliente pode ser punido de forma autônoma, ou seja, mesmo que não haja um proxeneta.

Ainda que o próprio cliente tenha negociado o programa sem intermediários, haverá o crime. Basta que o agente, mediante pagamento, convença a vítima, dessa faixa etária, a praticar com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso. (STJ. 6ª Turma. REsp 1490891/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17/04/2018).

Considere que João, maior de idade, conheceu Pedro, de 16 anos, em uma praça e ofereceu R\$ 50,00 e mais um lanche para que o adolescente fizesse sexo com ele no seu apartamento. Pedro, garoto muito pobre, aceitou e João praticou ato libidinoso com o adolescente em troca de dinheiro. Essa situação se repetiu por mais sete vezes, todas elas envolvendo sexo em troca de dinheiro. Os pais de Pedro descobriram o fato e o Ministério Público denunciou João pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, inc. I, do CP em continuidade delitiva (art. 71).

A defesa do acusado poderia ter sucesso se conseguisse provar que o adolescente de 16 anos já tinha discernimento para a prática do ato sexual e, portanto, não era vulnerável?

O tema é polêmico, mas o STJ respondeu que sim. Segundo decidiu a Corte, a vulnerabilidade no caso do art. 218-B do CP é relativa. Assim, diferentemente do que ocorre nos artigos 217-A, 218 e 218-A do Código Penal, nos quais o legislador presumiu de forma absoluta a vulnerabilidade dos menores de 14 anos, no art. 218-B não basta aferir a idade da vítima, devendo-se averiguar se o menor de 18 (dezoito) anos ou a pessoa enferma ou doente mental, não tem, de fato, o necessário discernimento

para a prática do ato, ou por outra causa não pode oferecer resistência (STJ. 5ª Turma. HC 371.633/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 19/03/2019. Info 645).

O STJ, apesar de ter fixado a tese acima exposta, em abstrato, considerou que, no caso concreto, o adolescente se entregou à prostituição em razão de sua péssima situação econômica, motivo pelo qual a sua imaturidade, em função da idade, associada à sua situação financeira, o tornaram vulnerável. Em outras palavras, a defesa não conseguiu afastar a presunção relativa e o rapaz foi considerado vulnerável, razão pela qual caracterizou-se o crime.

Por fim, a defesa ponderou que não houve continuidade delitiva, ao argumento de que o crime do art. 218-B só se consuma com a reiteração de atos, ou seja, não haveria o delito se o ato sexual fosse praticado só uma vez. Logo, se o tipo penal exige obrigatoriamente pluralidade de atos, não se pode falar em punição maior pela continuidade delitiva já que a reiteração é algo que sempre deve existir. A tese, todavia, não foi acolhida pelo STJ. Para a Corte, o crime se consuma mesmo que haja apenas uma relação sexual. O tipo penal não exige habitualidade. Basta um único contato consciente com o adolescente submetido à prostituição para que se configure o crime.⁴⁸

A prostituta pode ser sujeito passivo deste crime? Sim, nas modalidades impedir ou dificultar que abandone a prostituição.

O crime pode ser instantâneo, nos verbos *submeter*, *induzir*, *atrair* ou *facilitar*. Será permanente nas modalidades *impedir* e *dificultar*.

Estabelece o §1º que, se o delito é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

O §2º, por seu turno, estabelece que incorre nas mesmas penas de reclusão, de 4 a 10 anos (figuras equiparadas):

I. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo;

Vale lembrar que, se o indivíduo praticar qualquer ato sexual com menor de 14 anos, haverá estupro de vulnerável. Por outro lado, se o agente se vale do adolescente maior de 14 anos e menor de 18 anos, já inserido na prostituição, para a prática de ato sexual, incidirá nas mesmas penas do *caput*.

II. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.

Segundo o §3º, na hipótese do inciso II do § 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

O art. 218-B, em todas as suas modalidades, é catalogado como crime hediondo.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 218-C. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE SEXO OU PORNOGRAFIA

Eis a redação do tipo penal:

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática –, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.

O crime foi acrescido ao CP pela Lei nº 13.718/18. Apesar da previsão do art. 154-A (invasão de dispositivo informático), este dispositivo se mostrava insuficiente para tutelar outras formas de

⁴⁸ Fonte: Dizer o Direito. Acesso e disponibilidade em:

<https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2019/06/info-645-stj-1.pdf>



exposição da intimidade que passaram a existir com o crescente avanço tecnológico. Na atualidade, é comum o compartilhamento de dados contendo conteúdo pornográfico, como a troca de “nudes” e cenas de sexo em aplicativos de conversas, salas de bate-papo virtuais e redes sociais.

Trata-se de crime de médio potencial ofensivo. Admite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O art. 218-C contém nove verbos núcleos do tipo. É misto –alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado. A prática de mais de uma conduta, no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, caracteriza crime único.

Ademais, o crime é comum (pode ser praticado por qualquer pessoa). O agente que divulgou o vídeo não necessariamente é o mesmo indivíduo que participou ou filmou o ato. Se for a mesma pessoa, poderá haver concurso de crimes. **Exemplo:** imagine que o indivíduo praticou o estupro e filmou o ato. Em seguida, ele divulgou o vídeo na *internet*. Neste caso, ele terá praticado dois delitos em concurso material: estupro e o crime do art. 218-C do CP.

Nos casos de vítima menor de 18 anos, a subsunção pode se dar nos artigos 241 ou 241-A do ECA, mais graves. Se a conduta consiste em vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual com cena envolvendo criança ou adolescente, o crime é o do art. 241 do ECA, punido com reclusão de quatro a oito anos. Tratando-se das demais condutas envolvendo menores de idade, o crime é o do art. 241-A, punido com reclusão de três a seis anos.

O art. 218-C apresenta subsidiariedade expressa, ou seja, é preciso verificar se o fato não constitui tipo mais grave. Pode ser praticado por qualquer meio (de forma livre).

O objeto material pode ser fotografia, vídeo ou outros registros audiovisuais. Não se exige especial fim de agir ou objetivo de lucro.

A consumação ocorre no momento em que o agente pratica qualquer dos verbos descritos, ou seja, oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende, expõe à venda, distribui, publica ou divulga. A tentativa é possível, pois se trata de crime plurissubsistente.

O § 1º dispõe que a pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Pune-se de maneira mais grave o indivíduo que quebra uma relação de confiança, em relações como o casamento, união estável ou namoro. Não se inserem nesta definição relações casuais, sem maior vínculo entre o agente e a vítima, situações que se subsumem à forma básica do *caput*. Quanto ao fim de vingança ou humilhação, tem-se o chamado *revenge porn*, a vingança ou humilhação ocorrida, em geral, após o fim de relacionamento amoroso. A parte inconformada com o término divulga registros da intimidade do casal. Nesse caso, poderá se cogitar da incidência da causa de aumento a relações casuais, desde que constatada a intenção de vingança.

No § 2º há previsão de excludente de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no *caput* deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos. Nessa hipótese, não há o dolo do agente em provocar qualquer prejuízo, de humilhar ou expor a vítima a constrangimento.

Por fim, vale notar que **não se trata** de crime hediondo.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 47 — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: DO RAPTO

Artigos 219 A 222 revogados pela Lei nº 11.106/2005

CAPÍTULO 48 — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigos 223 e 224 revogados pela Lei nº 12.015/2009

1. ART. 225. AÇÃO PENAL

Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. A redação foi dada pela Lei nº 13.718/2018. Antes, a regra era a ação penal condicionada à representação, sendo incondicionada apenas quando a vítima fosse menor de 18 anos ou pessoa vulnerável (Lei nº 12.015/2009).

Conforme se nota, o legislador não primou pela melhor técnica na redação atual do art. 225. Isso porque, como regra em nosso CP, quando a lei nada diz, a ação é pública incondicionada. A lei é expressa nas ações públicas condicionadas à representação e nas ações penais privadas. Como a ação penal passou a ser pública incondicionada em todos os crimes contra a dignidade sexual, bastaria ter revogado o art. 225 do CP.

Com isso, supera-se o debate a respeito da eficácia da Súmula 608 do STF: “No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.”

Alguns doutrinadores tecem críticas à nova previsão legal, vez que ignora o *strepitus iudicii*, isto é, constrangimento gerado pelo processo. Retira-se da vítima maior e capaz a possibilidade de optar por não expor e reviver fatos relativos à sua intimidade.

Por se tratar de tratar de matéria de processo penal, mas com reflexos penais evidentes, a inovação não pode retroagir, pois é desfavorável aos acusados.

2. ART. 226. AUMENTO DE PENA

O aumento previsto no art. 226 é aplicável aos crimes dos Capítulos I e II, isto é, aos artigos 213, 215, 215-A, 216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218- C.

I – de quarta parte (1/4), se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

III - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado:

Estupro coletivo:

a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes;

Forma de concurso de pessoas, já existente no inciso I e cuja única diferença é a fração de aumento. Seria um deslize do legislador? A doutrina entende ser plenamente possível compatibilizar ambos os dispositivos. O inc. I é aplicável a todos os delitos dos capítulos I e II. Já o inciso IV é específico para o crime de estupro, inclusive o de vulnerável.

Estupro corretivo:

b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.



Abrange, em regra, crimes contra mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. O estuprador age a pretexto de “corrigir” a orientação sexual da vítima. Por óbvio que a motivação é das mais reprováveis, pautada por ódio e preconceito.

O prof. Sanches Cunha explica que se tratada violência usada como um castigo pela negação da mulher à masculinidade do homem.⁴⁹

A Lei nº 13.718/2018 entrou em vigor na data de sua publicação, em 25/09/2018. Como se trata de lei penal mais gravosa (*novatio legis in pejus*), não retroage, não alcançando fatos praticados antes da sua vigência.

A regra de irretroatividade vale, inclusive, para as ações penais. Assim, por exemplo, se, em 24/09/2018, o agente cometeu contra uma mulher maior de 18 anos um assédio sexual (art. 216-A do CP), a ação penal continua sendo pública condicionada à representação.

QUESTÕES

1- (CEBRASPE – MPPI - 2019) A respeito de crimes contra a dignidade sexual, assinale a opção correta.

A Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, é relevante, na avaliação da atipicidade da conduta, averiguar a existência de relacionamento amoroso entre a vítima e o agente.

B O STJ pacificou o entendimento de que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eventual consentimento da vítima afasta a tipicidade do estupro de vulnerável.

C Em regra, o crime de importunação sexual pode ter como agente passivo pessoa vulnerável, dados a especificidade da conduta e seu caráter de crime não subsidiário.

D Caracteriza o crime de assédio sexual a conduta de médico ginecologista que, durante atendimento, pratica ato libidinoso contra paciente, aproveitando-se do consentimento dado por ela para a realização de exame ginecológico.

E Em se tratando de crime de estupro em que a vítima seja maior de dezoito anos de idade e plenamente capaz, a ação penal é pública incondicionada, ainda que não tenha ocorrido violência real na prática do crime.

2- (CEBRASPE – TJPR – 2019) Julgue os itens a seguir, relativos a delitos de natureza sexual.

I Praticar, em local público, ato libidinoso contra alguém e sem o seu consentimento caracteriza contravenção penal tipificada como importunação ofensiva ao pudor.

II Praticar conjunção carnal com o parceiro na presença de menor de catorze anos de idade, a fim de satisfazer a própria lascívia, configura, a princípio, o tipo penal específico denominado satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

III Praticar ato obsceno em praça pública, ainda que sem a intenção de ultrajar alguém específico, configura crime de importunação sexual, que, por equiparação, é considerado hediondo.

IV Divulgar na Internet fotografias de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, como meio de vingança pelo término de relacionamento, configura crime específico previsto no ECA, o que afasta a incidência do novo tipo penal previsto no art. 218-C do Código Penal.

Estão certos apenas os itens

A I e III.

B I e IV.

C II e III.

D II e IV.

3- (CEBRASPE – TJSC – 2019 adaptada) Um indivíduo poderá responder criminalmente por violação sexual mediante fraude, caso pratique *frotteurismo* contra uma mulher em uma parada de ônibus coletivo lotada, sem o consentimento dela.

⁴⁹ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial.** 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 577.



4- (CEBRASPE – TJSC – 2019 adaptada) Tanto ao agente, maior e capaz, que praticar o crime de estupro coletivo quanto ao agente, maior e capaz, que praticar o crime de estupro corretivo será aplicada a mesma majorante de pena in abstrato.

GABARITO

1. E
2. D
3. ERRADO
4. CORRETO



CAPÍTULO 49 — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA O FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

1. ART. 227. MEDIAÇÃO PARA SERVIR A LASCÍVIA DE OUTREM

O tipo penal prevê como criminoso a conduta de induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. A pena é de reclusão, de um a três anos.

O crime é chamado de lenocínio principal, isto é, dar assistência à libidinagem de outrem ou dela tirar proveito. As figuras do *caput* e dos parágrafos estão relacionadas aos mediadores da exploração sexual.

A prostituição é apenas uma das formas de exploração sexual. Existem outras, como o turismo sexual, a pornografia e o tráfico para fins libidinosos.

O crime é de médio potencial ofensivo. Comporta a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal, desde que não haja violência ou grave ameaça.

A conduta punível é a de induzir alguém a satisfazer a lascívia de pessoa determinada. Do contrário, se a vítima é induzida a satisfazer a lascívia de um número indeterminado de pessoas, haverá o crime de favorecimento da prostituição (art. 228 do CP).

A satisfação pode ser dar mediante qualquer atividade de cunho sexual, incluindo a mera contemplação passiva. É um crime de ação livre, não necessariamente habitual.

Uma parcela minoritária da doutrina entende que a conduta deveria ser abolida do ordenamento, já que a questão é de âmbito moral. A liberdade sexual, exercida sem violência ou grave ameaça, não deve ser tutelada pelo Estado quando se tratar de pessoas maiores e capazes que exercem livremente a sua vontade.

O tipo penal traz apenas o verbo induzir (fazer nascer a ideia). Não contempla o verbo instigar (reforçar a vontade já existente) que será, a princípio, atípico.

O crime é comum. Não exige nenhuma característica especial do sujeito ativo.

A conduta somente é praticada a título de dolo, este entendido como a vontade livre e consciente de induzir a vítima a satisfazer a lascívia de pessoa determinada. Há uma finalidade pessoal, que é busca da satisfação da lascívia de outrem.

A consumação ocorre com a prática do ato que importa satisfação da lascívia da outra pessoa, independentemente dessa pessoa se considerar satisfeita com o ato ou não. O crime é material ou causal.

Os parágrafos contemplam as qualificadoras.

O § 1º estabelece que, se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, a pena passa a ser de reclusão, de dois a cinco anos. Vale lembrar que, se a vítima tem menos de 14 anos, a figura é a descrita no art. 218 do CP.

No § 2º tem-se que, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena passa a ser de reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à violência (concurso material obrigatório).

Por fim, no § 3º, se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. É o chamado lenocínio mercenário ou questuário. Não é preciso que haja habitualidade. Não se confunde com o rufianismo, previsto no art. 230, no qual a vítima exerce a prostituição, havendo a exploração de forma habitual. Na hipótese ora em comento, a pessoa explorada não exerce atividade de comércio sexual, nem se exige habitualidade.

A ação penal é pública incondicionada.



2. ART. 228. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

No art. 228, temos a conduta de induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. A pena cominada é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Na figura do art. 227 do CP, anteriormente estudada, a vítima não era prostituída. No tipo legal em destaque, a vítima vai praticar o comércio sexual com habitualidade. Ocorrerá, portanto, a prostituição ou outra forma de exploração, como o turismo para fins libidinosos.

O crime é comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Nos termos do § 1º, se o agente é ascendente, padrasto, madrastra, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, haverá forma qualificada do crime, com pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, desde maior de 18 anos, plenamente capaz. Conforme já visto, vítima menor de 18 anos ou que apresente característica de vulnerabilidade, por enfermidade ou doença mental, que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, torna o agente incurso no art. 218-B do CP, crime hediondo.

A prostituição é o comércio sexual exercido com habitualidade.

O Brasil adotou o sistema abolicionista, segundo o qual a prostituição, por si só, não constitui crime ou contravenção, fazendo parte do livre arbítrio individual, da liberdade de disposição do corpo para fins sexuais. Não é punido quem exerce a prostituição, mas se pune quem a favorece (art. 228), contribui para sua manutenção, intermediando encontros (art. 229) ou dela se aproveita materialmente (art. 230). O que se pune é a exploração ou estímulo, para evitar a proliferação desenfreada.

O art. 228 do CP comina penas ao favorecimento da prostituição, isto é, ao comércio sexual habitual com contato físico entre as partes envolvidas, bem como qualquer outra forma de exploração sexual que não depende de contato físico, a exemplo de shows eróticos.

A exploração sexual é elemento normativo do tipo, isto é, de índole cultural, devendo seu conceito ser obtido pelo intérprete a depender do momento em que se vive, da situação daquela comunidade, dentre outros aspectos históricos e regionais envolvidos. Ressalte-se que o Poder Público faz vistas grossas a estabelecimentos de exploração sexual de pessoas maiores, sendo conhecidos em todas as cidades os locais onde tais práticas ocorrem.

O tipo é misto alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado. Os verbos são:

- Induzir: dar a ideia, inspirar;
- Atrair: aliciar ou seduzir;
- Facilitar: simplificar o acesso;

Nesses três casos, a vítima **ainda não** se dedica à prostituição.

- Impedir: vedar ou obstar;
- Dificultar: tornar mais oneroso, criar obstáculos.

Nesses últimos dois casos a pessoa já se encontra no comércio sexual habitual. A conduta punida será a do indivíduo que impede ou dificulta que o sujeito prostituído abandone a prostituição.

O § 2º contempla forma qualificada, com pena de reclusão de 4 a 10 anos, quando o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Por certo, não se deixará de aplicar a pena correspondente à violência. Haverá, assim, concurso de crimes.

Por fim, o art. 228, § 3º, estabelece que, se há finalidade de lucro, aplica-se também a pena de multa. Não se exige a efetiva obtenção da vantagem econômica, basta a intenção de recebê-la.

A ação penal é pública incondicionada



3. ART. 229. CASA DE PROSTITUIÇÃO

Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Esta é a conduta criminosa definida como casa de prostituição, de elevado potencial ofensivo. A pena é de reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Não são cabíveis os benefícios da Lei nº 9.099/95, porém admite-se o acordo de não persecução penal. Alguns autores atribuem ao delito o *nomen juris* “estabelecimento para exploração sexual”.⁵⁰

O verbo núcleo do tipo é “manter” e, assim, exige um comportamento costumeiro. A doutrina entende que, além de ser **crime habitual, é também permanente**, já que enquanto se mantém o estabelecimento para exploração sexual o delito está sendo consumado. A habitualidade é incompatível com a tentativa.

Incluem-se no tipo penal os bordéis, casa de tolerância, “inferninhos”, “zonas”, casas de *strip-tease*, clube das mulheres. Porém, o nome utilizado não é relevante, mas sim a atividade exercida.

Conforme se extrai da leitura do dispositivo, é indiferente que o proprietário compareça ao local, desde que mantenha a estabelecimento destinado ao fim de exploração sexual.

O sujeito ativo é qualquer pessoa, sendo crime comum. Tem-se a figura do proxeneta, o intermediário para relações sexuais alheias.

O sujeito passivo é a pessoa explorada sexualmente e, em segundo plano, a coletividade.

O elemento subjetivo é o dolo. A intenção de lucrar (*animus lucrandi*) é irrelevante para fins de tipicidade. Poderá ser valorada na fixação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP.

Não se cogita de atipicidade material, pela aplicação do princípio da adequação social, sob o argumento de que são atividades toleradas socialmente, praticadas em estabelecimentos conhecidos de toda a população. O costume não revoga o tipo penal. Cabe somente ao legislador o papel de revogar ou modificar a lei penal em vigor, isto é, a *abolitio criminis* só ocorre por força de lei (STF, HC 104.467/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Informativo 615).

Embora polêmico, segundo entendimento mais recente do STJ, o estabelecimento que não se volta exclusivamente à prática de mercancia sexual, tampouco envolve menores de idade ou do qual se comprove retirada de proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, não dá origem a fato típico a ser punido na seara penal.⁵¹

A exploração sexual é elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal.

Dessa forma, crime é manter pessoa em condição de explorada, obrigada, coagida, não raro em más condições, ou mesmo em condição análoga à de escravidão, impondo-lhe a prática de sexo sem liberdade de escolha, ou seja, **com tolhimento de sua liberdade sexual e em violação de sua dignidade sexual**.

⁵⁰CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume único. Parte Especial**. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 583.

⁵¹Exemplo fornecido no Informativo Comentado pelo Dizer o Direito: João era proprietário de um bar e restaurante denominado “Tesouro”. O agente, pretendendo aumentar a clientela e auferir maiores lucros, convidou mulheres de cidades próximas para se prostituírem no local. Para tanto, acertou com elas que forneceria hospedagem e alimentação em troca da realização de programas sexuais com clientes do estabelecimento. Conforme ficou combinado, quando os clientes chegassem ao local as garotas os convenceriam a pagar bebidas, que eram vendidas por doses e em valores superiores ao de mercado. Em seguida, essas mulheres acertariam com os clientes a realização de programa sexual num dos quartos do local, mediante o pagamento de valor ao dono do estabelecimento. Ao fim, a mulher ficaria com o valor correspondente ao programa enquanto o denunciado ganharia com a venda das bebidas e com o aluguel dos quartos. Por tal conduta, João foi denunciado nas penas do art. 229 do CP. Segundo decidiu o STJ, a conduta de João é atípica. Fonte: Dizer o Direito. Acesso e disponibilidade em: <https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2018/11/info-631-stj.pdf>

Nesse sentido, o bem jurídico tutelado não é a moral pública mas sim a dignidade sexual como, aliás, o é em todos os crimes constantes do Título VI da Parte Especial do Código Penal, dentre os quais, o do artigo 229. E o sujeito passivo do delito não é a sociedade mas sim a pessoa explorada, vítima da exploração sexual. Assim, se não se trata de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual, tampouco há notícia de envolvimento de menores de idade, nem comprovação de que o recorrido tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara penal. (REsp 1.683.375-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018, noticiado no Informativo 631).

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 230. RUFIANISMO

O art. 230 prevê como criminosa a conduta de tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. A pena é de reclusão, de um a quatro anos, e multa. É crime de médio potencial ofensivo, sendo possível a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O tipo exige que o sujeito seja sustentado pela prostituição (rufião ou cafetão). A exploração é material, econômica, daquilo que a pessoa prostituída auferir, e não do corpo.

O sujeito ativo é qualquer pessoa (crime comum).

Para a caracterização do crime, é necessário que haja habitualidade, ou seja, deve haver reiteração de comportamento, constituindo-se em crime habitual.

Embora a prostituição em si não seja ilícita, o Estado não tolera a conduta daqueles que se mantêm à custa de quem se prostitui.

O crime é material, consumando-se com o proveito obtido em decorrência da prostituição alheia.

Espécies de rufianismo

Segundo a doutrina, o rufianismo poderá ser ativo ou passivo:

a) Rufianismo ativo: é aquele no qual o indivíduo tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros. **Exemplo:** cafetão.

b) Rufianismo passivo: tem-se quando o indivíduo tira proveito da prostituição alheia, fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. **Exemplo:** gigolô.

Há quem sustente a inconstitucionalidade do dispositivo na forma básica (*caput*), vez que a questão, de cunho eminentemente moral, está relacionada à liberdade sexual de indivíduos maiores e capazes, não devendo ser punida pelo Direito Penal.

Nos termos do § 1º, se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrastra, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância a pena passa a ser de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa (forma qualificada).

Por sua vez, o § 2º prevê que, se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima a pena será de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência (curso obrigatório de crimes).

É importante estabelecer a diferença do crime de mediação para satisfazer a lascívia de outrem com o fim de lucro (art. 227, §3º, do CP) e rufianismo (art. 230).

O ponto em comum é que ambos são espécies de **lenocínio questuário ou mercenário**, em que há o desejo de obter vantagem econômica pela atividade sexual de terceira pessoa.

No **rufianismo**, a pessoa explorada exerce a prostituição, e sua configuração reclama habitualidade, pois o agente tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros (rufianismo ativo) ou fazendo-se sustentar (rufianismo passivo), no todo ou em parte, por quem a exerça.

Já na **mediação para servir a lascívia de outrem** a pessoa explorada não se prostitui, e o delito é instantâneo (não requer habitualidade, uma única conduta já perfaz o crime). Em outras palavras, para sua consumação basta um único ato de induzir alguém a satisfazer a lascívia alheia.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ARTS. 231 E 231-A. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERNO PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

Revogados pela Lei nº 13.344/16, que introduziu no Código Penal o art. 149-A (tráfico de pessoas). Não houve *abolitio criminis*. As condutas continuam sendo punidas, porém em dispositivo diverso, aplicando-se ao caso o princípio da continuidade normativo-típica.

6. ART. 232-A. PROMOÇÃO DE MIGRAÇÃO ILEGAL

Segundo o art. 232-A, promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro é crime apenado com reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

O tipo penal foi introduzido no CP pela Lei nº 13.445/17, a qual instituiu a Lei de Migração e revogou o Estatuto do Estrangeiro.

A localização topográfica do artigo no CP é alvo de muitas críticas e está, nitidamente, equivocada, pois o crime de promoção de migração ilegal **não tem conotação sexual** e não se confunde, de forma alguma, com o tráfico de pessoas para exploração sexual, que antes da Lei nº 13.344/16 fazia parte do mesmo Capítulo.

A conduta ora em estudo consiste em viabilizar a entrada no território brasileiro de estrangeiro que não cumpre os requisitos legais estabelecidos na própria Lei de Migração.

O crime é comum (pode ser cometido por qualquer pessoa).

A Lei de Migração tem como um dos seus princípios a não criminalização do migrante ilegal (art. 3º, inciso III, da Lei nº 13.445/17). A punição se dirige ao indivíduo que promove a migração de terceiro, com intuito de obter vantagem econômica.

O sujeito passivo é o Estado, o qual deve ter controle sobre o trânsito de estrangeiros no país.

O tipo contém a finalidade especial de obter vantagem econômica. Não haverá crime se alguém tiver o intuito de auxiliar pessoa que pretende ingressar ilegalmente no território nacional ou em país estrangeiro.

É compatível com a tentativa.

No § 1º há previsão de figura equiparada. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro.

O § 2º estabelece causa de aumento de pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se:

I - o crime é cometido com violência; ou

II - a vítima é submetida a condição desumana ou degradante.

Nesse último caso, o legislador está atento, sobretudo, às condições de transporte e moradia a que os migrantes se submetem.

Por fim, o § 3º prevê que a pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas, a exemplo do tráfico de pessoas e a falsificação de documentos.

A ação penal é pública incondicionada. A competência é da Justiça Federal.



CAPÍTULO 50 — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

1. ART. 233. ATO OBSCENO

Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público acarreta pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, que comporta os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

O ato obsceno é aquele dotado de sexualidade, idôneo a ferir o sentimento de pudor, não aceito socialmente. Exemplos: exibir os órgãos genitais, andar nu em locais públicos.

O simples verbalizar, utilização de palavras de baixo calão ou de cunho sexual não tipificam a conduta, já que o verbo núcleo do tipo é praticar, exigindo-se um agir.

O bem jurídico tutelado é o pudor público, a moral coletiva. A prática do ato não se dirige a uma pessoa específica. Nesse último caso, poderá haver a importunação sexual, descrita no art. 215-A do CP.

Qualquer pessoa poderá ser sujeito ativo do crime.

O costume não revoga a lei penal, mas o que se considera ato obsceno tem mudado ao longo dos anos. Assim, ato obsceno é elemento normativo do tipo, que comporta interpretação pelo magistrado, a depender dos costumes locais, da aceitação cultural de determinada conduta, o que pode se modificar, inclusive, ao longo do tempo.

É importante diferenciar os seguintes conceitos:

Lugar público: é aquele lugar que é acessível por qualquer pessoa. **Exemplo:** rua, praça, etc.

Lugar aberto ao público: é o lugar em que o público pode frequentar, ainda que se trate de um número indeterminado de pessoas. Não significa livre acesso, mas um indeterminado número de pessoas poderá frequentar, desde que observe a forma adequada. **Exemplo:** cinema, restaurante, teatro, hotel, etc.

Lugar exposto ao público: o local não é aberto, mas o público consegue ver o que lá acontece. **Exemplo:** garagem com um portão que permite ver o que se passa dentro, casa com janelas de vidro.

O delito somente se verifica na modalidade dolosa. Consuma-se com a prática do ato obsceno, sendo um **crime de mera conduta (ou simples atividade)**. O tipo penal descreve o comportamento ilícito, sem a previsão de qualquer resultado naturalístico.

A ação é pública incondicionada.

2. ART. 234. ESCRITO OU OBJETO OBSCENO

Nos termos do art. 234, fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno é crime apenado com detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. O parágrafo único estabelece condutas equiparadas. Incorre na mesma pena quem:

I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo;

II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

III - realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cabendo transação penal e suspensão condicional do processo.

A previsão revela-se um tanto inadequada e curiosa para os dias atuais, visto que as possibilidades de tipificação são inúmeras. Devido às mudanças na sociedade frente à liberdade de



expressão, o tipo penal não encontra muita aplicação prática. A tipificação depende de ofensa à moralidade pública. Há, assim, um descompasso entre a letra da lei e a realidade dos dias de hoje.

A conduta de expor à venda é crime permanente, já que a conduta se prolonga no tempo.

Objeto obsceno é elemento normativo do tipo, que comporta interpretação, a depender da época e dos costumes sociais.

O crime é comum, doloso, formal, de perigo abstrato (basta a potencialidade de ofensa à moralidade pública), não requer resultado naturalístico.

É indispensável a presença de dois elementos especiais subjetivos: a finalidade de comércio, de distribuição ou de exposição pública, bem como o propósito de ofender a moral pública.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 51 — DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: DISPOSIÇÕES GERAIS

1. ART. 234-A. AUMENTO DE PENA

Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada:

I – (VETADO)

II – (VETADO)

III - de metade a 2/3 (dois terços), se do crime resulta gravidez; (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)

As duas majorantes, incidentes na terceira fase da dosimetria, aplicam-se a todos os crimes do Título VI.

Quanto ao inc. III, que trata da gravidez, Rogério Sanches Cunha entende que, cuidando-se de consequência da infração penal, não necessita ser alcançada pelo dolo (vontade consciente) do agente.⁵²

No caso do inc. IV, idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei nº 10.741/03. O conceito de pessoa com deficiência, por sua vez, é dado pelo art. 2º da Lei nº 13.146/15.

Art. 234-B. SEGREDO DE JUSTIÇA

Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça.

A publicidade, regra quando se trata dos atos processuais, pode ser mitigada em nome da intimidade das vítimas.

⁵²CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume único. Parte Especial**. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 604



CAPÍTULO 52 — DOS CRIMES CONTRA A FAMÍLIA: DOS CRIMES CONTRA O CASAMENTO

1. ART. 235. BIGAMIA

Contrair alguém, sendo casado, novo casamento é crime punido com reclusão, de dois a seis anos. Não é possível a aplicação da Lei nº 9.099/95, mas se admite o acordo de não persecução penal.

Tutela-se a organização da família e o casamento monogâmico.

Na figura do *caput*, somente a pessoa já casada pode ser sujeito ativo. Tem-se, assim, um crime próprio e também de concurso necessário, já que são necessárias duas pessoas para a execução do delito.

O tipo menciona a bigamia, mas por certo a poligamia também está abrangida (interpretação extensiva).

Trata-se de crime de forma vinculada, vez que somente pode ser praticado quando se contrai novo casamento, segundo as formalidades da lei civil.

A separação judicial não impede a caracterização do delito, pois a dissolução do vínculo, segundo a lei brasileira, ocorre somente com a morte ou o divórcio.

A união estável não configura o crime de bigamia, assim como o casamento contraído apenas no âmbito religioso.

Um dos cônjuges pode ser inimputável ou ignorar o impedimento do outro.

O crime também se caracteriza se um indivíduo, casado com alguém do sexo oposto, contrai novo matrimônio homoafetivo, diante da plena possibilidade de celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo (ADPF 132)

É hipótese de bigamia se o casamento anterior foi realizado no exterior.

No § 1º é prevista a forma privilegiada. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de um a três anos.

Assim, se uma pessoa solteira, viúva ou divorciada se casa com alguém já casado, tendo ciência dessa condição, incidirá nas penas do § 1º. O contraente já casado, por sua vez, responderá pela figura do *caput*. Há uma exceção pluralística à teoria monista ou unitária quanto ao concurso de agentes, estabelecida no art. 29 do CP.

O § 2º prevê que, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Trata-se de causa de exclusão da tipicidade.

Enquanto a validade do primeiro casamento não é decidida no juízo competente, o processo penal deverá permanecer suspenso, por se tratar de uma questão prejudicial externa obrigatória.

O elemento subjetivo é o dolo. Não se admite a forma culposa. O crime independe de finalidade específica.

O crime de bigamia necessariamente é precedido por uma declaração falsa do agente a respeito do seu estado civil, motivo pelo qual, no momento de se habilitar para o casamento, deverá dizer que é solteiro. Nesse caso, o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) fica absorvido pelo crime de bigamia, por força do princípio da consunção. Nesse caso, a falsidade ideológica é crime-meio para alcançar o crime-fim.

A consumação do delito ocorre quando é declarado perfeito o segundo casamento, com a manifestação de vontade dos nubentes, dispensando-se a lavratura de termo. A doutrina diverge quanto à possibilidade do *conatus*.

A ação penal é pública incondicionada.

Há uma importante ressalva quanto ao prazo prescricional, que não terá início a partir da consumação do crime, mas apenas a partir da data em que se torna conhecida a bigamia, nos termos do art. 111, inciso IV, do CP.



2. ART. 236. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento

O art. 236 estabelece como crime contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. A pena é de detenção, de seis meses a dois anos. É infração de menor potencial ofensivo. Cabe transação penal e suspensão condicional do processo. Uma vez realizada a transação, torna-se inviável o acordo de não persecução penal.

O crime é comum. Considera-se possível que os dois contraentes pratiquem o delito simultaneamente, enganando um ao outro (dolo bilateral).

Tem-se clara hipótese de norma penal em branco homogênea, pois é necessário recorrer ao Código Civil, que elenca as hipóteses de erro essencial e impedimentos matrimoniais.

Erro essencial

De acordo com o art. 1.557 do Código Civil, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado;

O erro que foi ocultado traz a insuportabilidade da vida em comum.

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal;

Exemplo: a mulher descobriu que o cônjuge havia sido condenado por estupro de vulnerável.

III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência;

Exemplos: impotência *coeundi*

Impedimentos:

O art. 1521 do Código Civil traz o rol dos **impedimentos matrimoniais** (dirimentes absolutos ou públicos; causas de nulidade).

Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II - os afins em linha reta;

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V - o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas; (nessa situação, caracteriza-se a bigamia– art. 235, CP)

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.

O crime é material ou causal: consuma-se com o casamento.

Não se admite a modalidade culposa.

Incompatível com a tentativa (*conatus*), vez que a tipificação legal está condicionada à anulação ou declaração de nulidade do casamento.

Conforme prevê o parágrafo único, a ação penal depende de **queixa do contraente enganado** e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Trata-se do **único exemplo de ação penal privada personalíssima, isto é, que não se transmite aos sucessores. Ademais**, a sentença civil de nulidade ou anulação do casamento tem a natureza jurídica de condição de procedibilidade da ação penal.

3. ART. 237. CONHECIMENTO PRÉVIO DE IMPEDIMENTO

Nos termos do art. 237, contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta é crime apenado com detenção, de três meses a um ano. É infração de menor potencial ofensivo, sendo aplicáveis os benefícios da Lei nº 9.099/95.

Não se pode contrair o casamento sendo casado, hipótese em que há bigamia. Não se pode contrair casamento por meio de engano ou fraude, pois há a caracterização da figura do art. 236 do CP.

No crime ora em estudo, **não há engano, não há fraude e o impedimento não é casamento anterior**. Mesmo assim, a pessoa contrai casamento, conhecendo a existência de impedimento que causa a nulidade absoluta.

Qualquer pessoa poderá praticar esse crime (crime comum), inclusive os dois cônjuges em coautoria. Ambos sabem que não podem casar por conta de um motivo e mesmo assim se casam.

Não existe fraude ou ocultação para com o outro. É suficiente que um dos nubentes saiba da existência do impedimento.

É caso de norma penal em branco homogênea, vez que os impedimentos matrimoniais estão arrolados no art. 1521 do Código Civil.

O crime só é praticado a título doloso, não se exigindo nenhuma finalidade específica.

Além disso, o delito é material, consumando-se com o casamento, após o assentimento dos nubentes.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 238. SIMULAÇÃO DE AUTORIDADE PARA CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO

O crime previsto no art. 238 consiste em atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento. A pena é de detenção, de um a três anos, **se o fato não constitui crime mais grave**. Cabível a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

A autoridade para a celebração de casamentos é a Justiça de Paz, estabelecida no art. 98, inc. II, da CF.

Trata-se de um **crime expressamente subsidiário**. Por exemplo, se o indivíduo atribui-se falsamente a autoridade e cobra quantia dos noivos para a celebração do casamento, haverá estelionato.

O sujeito ativo é qualquer pessoa.

Falsamente é elemento normativo do tipo.

Haverá a consumação no **momento em que a pessoa atribui a si a autoridade e essa é falsa**, ainda que o matrimônio não venha a ocorrer. O crime é formal, ou de consumação antecipada, pois prescinde da realização do casamento.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 239. SIMULAÇÃO DE CASAMENTO

Nos termos do art. 239, simular casamento mediante engano de outra pessoa é crime com pena de detenção, de um a três anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. A infração é de médio potencial ofensivo, cabendo suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

O agente simula um casamento para enganar outra pessoa, podendo ser o nubente ou um terceiro (pais, por exemplo). O sujeito ativo do crime é um dos contraentes, mas Mirabete sustenta que o magistrado ou o oficial de registro civil também podem simular um casamento, enganando os próprios nubentes.

Engano é elemento normativo do tipo, isto é, comporta interpretação pelo magistrado na situação concreta.

O crime se consuma quando há a cerimônia fraudulenta, simulada. O crime é formal. Não se exige especial fim de agir.



Conforme se extrai do preceito secundário, é também hipótese de subsidiariedade expressa.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 240. ADULTÉRIO

Revogado pela Lei nº 11.106/2005

Ocorreu a *abolitio criminis*, isto é, a supressão da figura criminosa do ordenamento.

CAPÍTULO 53 — DOS CRIMES CONTRA A FAMÍLIA: DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO

1. ART. 241. REGISTRO DE NASCIMENTO INEXISTENTE

Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente é crime, cuja pena é de reclusão, de dois a seis anos. Não é aplicável a Lei nº 9.099/95, porém admite-se o acordo de não persecução penal.

Tutela-se o estado de filiação e também a fé pública relativa aos documentos do registro civil.

Observa-se uma modalidade especial de falsidade ideológica (art. 299 do CP).

O nascimento não ocorreu ou o feto nasceu morto. Pelo conteúdo do documento ser falso, trata-se de um falso moral, ideal ou ideológico.

O crime é comum. A consumação se dá com a inscrição do nascimento inexistente. Há que se ter um resultado naturalístico, pois se trata de crime material. Não se exige especial fim de agir. O sujeito passivo é o Estado.

A Lei de Registros Públicos, Lei nº 6.015/73, estabelece nos artigos 50 e 54 a exigência que todo nascimento ocorrido no território nacional seja comunicado e registrado no livro próprio.

Importante: a prescrição da pretensão punitiva somente começa a ser contada a partir da data em que se torna conhecido o registro de nascimento inexistente, nos termos do art. 111, inc. IV, do CP.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 242. PARTO SUPOSTO. SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DE DIREITO INERENTE AO ESTADO CIVIL DE RECÉM-NASCIDO

Segundo o art. 242, dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil é crime, cuja pena é de reclusão, de dois a seis anos.

A tutela penal dirige-se ao estado de filiação e à fé pública. A sanção cominada não permite a aplicação da Lei nº 9.099/95. Há possibilidade do acordo de não persecução penal.

O tipo contempla quatro condutas diferentes (tipo misto alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado):

a) **Dar parto alheio como próprio:** atribuir para si a maternidade de filho alheio, não originário do próprio ventre. Não se faz necessário o registro civil. A simulação de gravidez, por si só, não configura o delito. O crime é próprio ou especial, pois só mulher pode cometer.

b) **Registrar como seu o filho de outrem:** diferentemente da figura do art. 241, o nascimento ocorreu. Porém, o agente faz constar do registro civil uma situação inexistente. É a prática conhecida como “adoção à brasileira”. Trata-se de uma modalidade especial de falsidade ideológica. A tese de defesa mais comumente invocada é o erro de proibição, previsto no art. 21 do CP, pelo desconhecimento do caráter ilícito da conduta. O crime é comum. Pode ser praticado por homem ou por mulher.

c) **Ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil:** esconder para evitar o registro do recém-nascido. Crime comum.

d) **Substituir recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil:** trocar um recém-nascido por outro (troca de bebês). Não se exige o registro civil (pode ocorrer antes ou depois do registro). Crime comum.

No parágrafo único há previsão da figura privilegiada, se o crime é praticado por motivo de **reconhecida nobreza, isto é, que revela altruísmo, generosidade e caridade**. É aplicável às duas primeiras

formas do crime, mais comum na adoção à brasileira. Segundo parcela da doutrina é, em tese, incompatível com as duas últimas figuras, devido à maior reprovabilidade.⁵³

O magistrado escolherá a medida que melhor se adequa à situação fática, podendo conceder o perdão judicial, como causa extintiva da punibilidade (art. 107, inciso IX, do CP) ou aplicar a pena reduzida, a depender das circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do acusado.

A ação penal é pública incondicionada, mas o prazo prescricional, na conduta de registrar como seu o filho de outrem, somente começará a fluir no momento em que o fato se tornar conhecido.

3. ART. 243. SONEGAÇÃO DE ESTADO DE FILIAÇÃO

Nos termos do art. 243, deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil é crime que acarreta pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa. Cuida-se de delito de médio potencial ofensivo, que permite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Exige um especial fim de agir, verificado no intuito de prejudicar direito inerente ao estado civil. **Exemplo:** atribuir filiação diversa para alijar um indivíduo de seu direito de herança.

Se o crime é cometido com motivação diversa da descrita (prejudicar direito inerente ao estado civil), não haverá a incidência no artigo em comento.

O crime é comum. Pode ser praticado pelos próprios pais, mas também em relação ao filho alheio. Pode se dar por ação ou omissão.

Para a consumação, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico, o efetivo prejuízo. Assim, tem-se um crime formal, de consumação antecipada. Basta que se revele a intenção especial do agente, dispensando-se a sua concretização.

A ação penal é pública incondicionada.

⁵³MASSON, Cleber. Direito Penal. **Parte Especial. Vol. 3.** São Paulo: Gen Método, 2017, pp. 192.



CAPÍTULO 54 — DOS CRIMES CONTRA A FAMÍLIA: DOS CRIMES CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR

1. ART. 244. ABANDONO MATERIAL

Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Eis o crime de abandono material, apenado com detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no país.

A tutela penal dirige-se à assistência familiar, à manutenção da dignidade da família e também à garantia de subsistência entre seus membros. A pena cominada admite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O crime é próprio, pois depende de qualidade especial do sujeito ativo. Somente poderá ser praticado por quem tenha o dever de garantir a subsistência da vítima, ou por quem tenha o dever de socorrer o gravemente enfermo.

A omissão da assistência já consuma o crime, pois é omissivo próprio ou puro.

Se o agente cometer o crime contra os pais ou avós, ou seja, contra duas ou mais pessoas, o **delito será único**, visto que o bem jurídico tutelado é a família. A quantidade de vítimas deverá ser valorada pelo magistrado na individualização da pena, na primeira fase da dosimetria, no que tange às circunstâncias judiciais.

“Sem justa causa” é o elemento normativo do tipo, a ser interpretado e sopesado pelo magistrado no caso concreto.

O verbo núcleo do tipo, deixar, evidencia se tratar de crime omissivo próprio ou puro. Assim, como regra, é incompatível com a tentativa, exceto quanto à figura equiparada do parágrafo único. **Exemplo:** indivíduo que pede demissão do emprego para que não sejam descontados em sua folha de pagamento os valores da pensão alimentícia.

Na primeira figura, quando se deixa de prover a subsistência, não é necessária prévia ação judicial de alimentos para a caracterização do crime.

O parágrafo único trata das figuras equiparadas. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.

Segundo a doutrina, é inviável a analogia *in malam partem*: não se cogita de abandono material em união estável, já que o tipo penal refere-se a cônjuge.⁵⁴

Vale lembrar que há previsões na lei especial quando se tratar de idoso (art. 98 da Lei nº 10.741/03) e pessoa com deficiência (art. 90 da Lei nº 13.146/15).

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 245. ENTREGA DE FILHO MENOR A PESSOA INIDÔNEA

O tipo penal do art. 245 consiste em entregar filho menor de 18 (dezoito) anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. A pena é de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. É infração de menor potencial ofensivo, admitindo a transação penal e a suspensão condicional do processo.

O crime é próprio, vez que somente pode ser praticado pelo pai ou mãe. Sujeito passivo será o filho, menor de 18 anos.

⁵⁴ MASSON, Cleber. Direito Penal. **Parte Especial. Vol. 3.** São Paulo: Gen Método, 2017, pp. 199.



A conduta prevê a exposição a perigo material, isto é, a possibilidade do filho sofrer algum dano físico, ou a perigo moral, consistente na possibilidade do filho sofrer um dano psíquico na companhia daquela pessoa.

O crime é de perigo concreto, sendo necessária a efetiva comprovação da situação de perigo material ou moral à vítima. Pode ser praticado de forma livre.

No § 1º há figura qualificada. A pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão se o agente pratica o delito para obter lucro, ou se o menor é enviado para o exterior. Conforme o § 2º, incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro. Rogério Sanches lembra que a parte final dos §§ 1º e §2º estão tacitamente revogadas pelos artigos 238 e 239 do ECA⁵⁵.

Com efeito, segundo o art. 239 da Lei nº 8.069/90, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro é crime apenado com reclusão de 4 a 6 anos, e multa. Assim, a previsão do ECA é mais gravosa e deve prevalecer, em homenagem ao princípio da especialidade.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 246. ABANDONO INTELECTUAL

Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar é crime punido com detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

O fundamento constitucional para a tutela penal está no art. 205 da CF. É preciso velar pela adequada formação do filho em idade escolar.

Trata-se de delito de menor potencial ofensivo, sendo cabíveis os institutos da Lei nº 9.099/95.

É crime omissivo próprio ou puro, já que o verbo núcleo do tipo é “deixar”, isto é, um não fazer.

“Sem justa causa” é elemento normativo do tipo. Comporta interpretação e valoração no caso concreto.

O crime só se configura se deixar de prover à instrução primária (fundamental) do filho em idade escolar.

Somente os pais poderão deixar de prover à instrução primária do filho. Logo, cuida-se de crime próprio ou especial. Em verdade, é mais acertado se falar em crime bipróprio, pois no polo ativo estão os pais, e serão vítimas os próprios filhos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), alterada pela Lei nº 12.796/13, dispõe que a educação básica e gratuita começa dos 4 até os 17 anos de idade. Por isso, dos 4 aos 17 anos os jovens se encontram em idade escolar.

O art. 6º da Lei nº 9.394/96 estabelece que os pais e responsáveis são **obrigados** a efetuar matrícula da criança a partir dos 4 anos de idade.

O crime se consuma a partir do momento em que a omissão ocorre e o menor fica em casa, não sendo enviado à escola. O tempo que o menor fica afastado da instituição de ensino será valorado no caso concreto. Por certo, a situação deverá se prolongar por um tempo juridicamente relevante para a caracterização da infração penal.

É preciso verificar se havia a intenção de não matricular o menor na escola ao longo de um semestre ou ano. Se a ausência de matrícula se dá por problemas eventuais, falta de escola próxima de casa ou falta de vagas em escola pública no município, ou outras questões que também demandam o ajuizamento de uma ação para se conseguir a matrícula, não haverá crime.

Por se tratar de crime omissivo, não admite tentativa.

⁵⁵ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial.** 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 636.



A ação penal é pública incondicionada.

O ensino domiciliar (homeschooling) é conduta típica?

As pessoas que discordam das diretrizes de educação do país, das linhas adotadas, ou por questão de segurança, ou condições financeiras, optam por ensinar e educar os filhos em casa cometem o crime de abandono intelectual?

A discussão é mais presente na Europa e nos Estados Unidos.

No Brasil, o ensino domiciliar não é permitido. As crianças a partir de 4 anos de idade devem ser necessariamente matriculadas em instituição de ensino.

Sobre a tipificação da conduta, a doutrina diverge.⁵⁶ A legislação brasileira não prevê, nem regulamenta o ensino domiciliar. O STF já se manifestou, na esfera cível, contrário ao ensino domiciliar, por não haver fiscalização do Poder Público quanto à frequência às aulas, nem quanto à avaliação do desempenho do aluno. Segundo a Corte, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais, especialmente o art. 208, § 3º, da CF/88 (RE 888.815/RS, Informativo 915).⁵⁷

4. ART. 247. ABANDONO MORAL

O *nomen iuris* abandono moral foi dado pela doutrina e recebeu aceitação pela jurisprudência, para fins de diferenciação da figura precedente, que trata do abandono intelectual. Assim, há crime na conduta de permitir alguém que menor de 18(dezoito anos), sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância:

- I - frequente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida;
- II - frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza;
- III - resida ou trabalhe em casa de prostituição;
- IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública.

A pena prevista é de detenção, de um a três meses, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo e, por isso, comporta os institutos despenalizantes na Lei nº 9.099/95.

O crime é próprio ou especial, pois somente pode ser praticado pelo titular do poder familiar ou por quem, de qualquer modo, seja responsável pela guarda ou vigilância do menor. Sujeito passivo é o menor de 18 anos.

Nota-se que o legislador se utiliza de diversos elementos normativos do tipo penal, dependentes de juízo de valor pelo magistrado no caso concreto. Exemplo: o conceito de casa mal-afamada vai depender dos costumes, da época e da sociedade.

A hipótese do inciso IV não se confunde com a contravenção penal de mendicância, que foi revogada.

Trata-se de crime de condutas conjugadas. Assim, se o agente incidir em mais de uma hipótese, ainda que contra a mesma vítima, responderá pelos crimes em concurso material ou formal impróprio, a depender da situação. Não é tipo misto-alternativo.

Na modalidade “frequentar”, o crime exige habitualidade. Não é compatível com a tentativa, portanto.

Na forma “conviver”, deve-se verificar um tempo juridicamente relevante. Classifica-se, portanto, como crime permanente, já que a consumação se protraí no tempo.

⁵⁶ No sentido da atipicidade da conduta, confira-se artigo de autoria do professor Damásio de Jesus, disponível em <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/educacao-domiciliar-constitui-crime/5439>

⁵⁷ Há projeto de lei, do Senado Federal, PLS 28/2018, ainda em tramitação, no sentido de alterar o Código Penal, para estabelecer que o crime de deixar de prover à instrução primária de filho em idade escolar não ocorrerá se os pais ou responsáveis ofertarem aos filhos educação domiciliar.

Em todos os casos, o crime é formal ou de consumação antecipada, uma vez que independe de resultado naturalístico.

É também classificado como crime de perigo concreto (posição majoritária), havendo necessidade de comprovação da real exposição do menor à possibilidade de dano à sua formação moral.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 55 —DOS CRIMES CONTRA A FAMÍLIA: DOS CRIMES CONTRA O PÁTRIO PODER, TUTELA OU CURATELA

1. ART. 248. INDUZIMENTO A FUGA, ENTREGA ARBITRÁRIA OU SONEGAÇÃO DE INCAPAZES

A figura descrita no art. 248 é a seguinte: induzir menor de dezoito anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de dezoito anos ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. A pena é de detenção, de um mês a um ano, ou multa.

A tutela penal volta-se à manutenção do poder familiar. Pátrio poder é uma nomenclatura já desatualizada, utilizando-se, em seu lugar, poder familiar.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Uma vez admitida a transação penal, resta inviável o acordo de não persecução penal.

Qualquer pessoa poderá praticar esse crime, inclusive os pais, caso estejam destituídos ou com o poder familiar suspenso. O sujeito passivo é o pai, mãe, tutor ou curador e, em segundo plano, o menor de 18 anos ou interdito.

É importante destacar que não incide no delito em apreço, mas sim no art. 359 do CP (desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito), o indivíduo, pai ou mãe, que retém o filho menor por prazo superior ao acordado quanto à visitação.

Há três condutas que caracterizam a figura criminosa:

- Induzir menor de 18 anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial;

Para a tipificação, é necessário que haja o efetivo desaparecimento do menor. Induzir significa despertar, fazer nascer a ideia de fugir.

- Confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de dezoito anos ou interdito;

É a entrega arbitrária, que ocorre quando alguém tem o menor momentaneamente sob sua responsabilidade (na escola, por exemplo) e o entrega a terceiro, sem ordem de quem legitimamente tem o poder familiar.

- Deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame.

Nesse caso, trata-se de um crime omissivo, revelado pelo verbo “deixar”. Não admite a tentativa. “Sem justa causa” é elemento normativo do tipo.

O crime somente pode ser praticado na forma dolosa e não exige especial fim de agir.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 249. SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES

Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial é crime, cuja pena é de detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não constitui elemento de outro crime.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, mas com subsidiariedade expressa (“soldado de reserva”). Ou seja, há necessidade de se verificar se o dolo não se dirige à prática de crime mais grave, como na hipótese de extorsão mediante sequestro.

É um crime comum, já que qualquer pessoa poderá praticar a infração penal.

O delito se consuma com a retirada do incapaz da esfera de proteção do pai, mãe, tutor ou curador. Segundo entendimento majoritário, é permanente. Por se tratar de delito plurissubsistente, é compatível com a tentativa.



No § 1º há a advertência no sentido de que o fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Conforme já ressaltado, a expressão pátrio poder deve ser entendida como poder familiar.

O § 2º traz a possibilidade de perdão judicial. No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus-tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar pena.

A ação penal é pública incondicionada.

Deve prevalecer, em homenagem ao princípio da especialidade, a previsão contida no art. 237 do ECA, quando a conduta consistir em subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Note-se que, no tipo previsto na lei específica, há o especial fim de agir.

CAPÍTULO 56 — DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA: DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

1. ART. 250. INCÊNDIO

Nos termos do art. 250, constitui crime causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A pena é de reclusão, de três a seis anos, e multa.

A tutela penal se volta à proteção da incolumidade pública.

Crime de perigo comum é aquele em que um número indeterminado de pessoas é exposto a perigo, havendo, no dizer de Nelson Hungria, uma indeterminação do alvo.

Incêndio, segundo o professor Cleber Masson, é o fogo com labaredas de grandes proporções, originado pela combustão de qualquer matéria, cujo poder de destruição e de causar prejuízos se revelem idôneos no caso concreto.⁵⁸

O laudo pericial é indispensável para a constatação da elementar do tipo, isto é, se o fogo atinge labaredas de grandes proporções e se pessoas indeterminadas foram expostas a perigo.

O crime é comum ou geral, já que pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade. É, assim, crime vago. É indiferente se o incêndio ocorre em coisa própria ou alheia.

A tipificação da conduta dispensa finalidade específica, ou seja, o agente não precisa estar imbuído de especial motivação. Se o incêndio se der por motivação política, o delito passa a ser o previsto no art. 20 da Lei nº 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional).

O crime é material ou causal, exigindo para a consumação a ocorrência de resultado naturalístico.

Note-se que o perigo deve ser concreto, isto é, o bem jurídico tutelado, a incolumidade pública, deve ser exposta a risco efetivo.

Hipóteses em que haverá concursos de crimes:

Se o indivíduo praticar um incêndio com a intenção de receber valor da seguradora, a doutrina entende que, nesse caso, haverá concurso formal entre o crime de perigo comum e o crime de estelionato contra a seguradora, já que são delitos autônomos que protegem **bens jurídicos distintos** (incolumidade pública e interesse financeiro da seguradora).

O mesmo raciocínio se faz presente quando há intenção homicida. Se alguém provoca um incêndio para matar outrem, responderá pelo crime de incêndio em concurso formal com o crime de homicídio. A depender do caso concreto, porém, ensejará a aplicação do princípio da consunção. Deve-se verificar se no caso do incêndio houve a exposição de um número indeterminado de pessoas a perigo concreto.

O §1º prevê majorantes. As penas são aumentadas de 1/3, na terceira fase da dosimetria da pena:

- Se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;
- Se o incêndio é em casa habitada ou destinada a habitação;
- Se o incêndio é em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura;
- Se o incêndio é em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo; (não há relevância se o veículo não estiver ocupado no momento do crime)
- Se o incêndio é em estação ferroviária ou aeródromo; (rol taxativo, que não inclui portos ou rodoviárias)
- Se o incêndio é em estaleiro, fábrica ou oficina;
- Se o incêndio é em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;

⁵⁸MASSON, Cleber. Direito Penal. **Parte Especial. Vol. 3.** São Paulo: Gen Método, 2017, pp. 238.



- Se o incêndio é em poço petrolífero ou galeria de mineração;

- Se o incêndio é em lavoura, pastagem, mata ou floresta (**não há conflito com o art. 41 da Lei nº 9.605/98, na hipótese de mata ou floresta, pois a tipificação da conduta na lei especial requer a não ocorrência do perigo comum**).

O § 2º prevê a forma culposa do crime, caso em que a pena será de 6 meses a 2 anos. Não se aplicam as majorantes do § 1º.

Se o sujeito causa o incêndio de forma culposa e tem condições de evitá-lo, mas não o faz, não responderá pelo incêndio culposamente, e sim pelo incêndio doloso. **Exemplo:** João deu início culposamente ao incêndio. Todavia, era possível fazer cessar o fogo, porém não o fez. Com a sua conduta teria o dever de evitar o resultado que criou, motivo pelo qual responderá pelo crime doloso, na forma omissiva imprópria.

Forma majorada pelo resultado:

Segundo o art. 258 do CP, se do crime doloso de perigo comum resultar:

- Lesão corporal de natureza grave: a pena será aumentada da 1/2 (metade);
- Morte: a pena será aplicada em dobro.

São hipóteses de crime preterdoloso.

Sendo o crime culposo, se resultar em:

- Lesão corporal: a pena será aumentada da 1/2 (metade);
- Morte: a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3 (um terço).

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 251. EXPLOSÃO

O art. 251 prevê como crime a conduta de expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. A pena é reclusão, de três a seis anos, e multa. Não é possível a aplicação da Lei nº 9.099/95, porém é viável o acordo de não persecução penal (desde que não incidente a majorante do § 2º).

O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública.

O núcleo do tipo é o verbo expor, colocando em perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas.

O tipo penal incrimina a explosão, o arremesso e a simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Assim, é prescindível a efetiva detonação do explosivo.

O crime é comum, já que pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade, tratando-se de crime vago.

O caput tipifica condutas que seriam atos preparatórios. Ou seja, mesmo que haja arremesso de engenho de dinamite ou a simples colocação de engenho ou de substância de efeitos análogos haverá crime.

O elemento subjetivo é dolo, sendo desnecessária finalidade específica.

Tem-se um delito material, que apresenta consequência no mundo dos fatos, e de perigo concreto. O perigo não é presumido, devendo ser demonstrado.

Se a explosão não gera perigo a um número indeterminado de pessoas, poderá restar caracterizado o tipo do art. 163, parágrafo único, inc. II (dano qualificado pelo emprego de substância explosiva).

Por se tratar de crime não transeunte, isto é, que deixa vestígios materiais, é indispensável a realização de perícia, como prova da materialidade. A prova testemunhal substitui o exame de corpo de delito na hipótese de desaparecimento dos vestígios, conforme os artigos 158 e 167 do CPP).

No § 1º há previsão de pena mais branda se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos (explosão privilegiada). A reclusão passa a ser de um a quatro anos, e multa. O crime é de médio potencial ofensivo e admite a suspensão condicional do processo. O legislador faz a



diferenciação devido ao poder destrutivo do dinamite e, conseqüentemente, maior reprovabilidade da conduta. A aferição do dinamite ou substância de efeitos análogos depende de prova técnica pericial, que não pode ser suprida pela prova testemunhal, por exemplo.

No § 2º são elencadas causas de aumento de pena, de um terço, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no nº II do mesmo parágrafo.

Há previsão de **modalidade culposa**, no § 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; nos demais casos, é de detenção, de três meses a um ano.

A explosão decorre de imprudência, negligência ou imperícia. O resultado é indesejado, mas objetivamente previsível. Exemplo: armazenamento inadequado de fogos de artifício. A explosão culposa é infração de menor potencial ofensivo, que tramitará conforme o procedimento da Lei nº 9.099/95.

Aplicam-se, ainda, as formas majoradas descritas no art. 258.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 252. USO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE

O art. 252 estabelece: expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. A pena cominada é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Assim como nos crimes de incêndio (art. 250) e explosão (art. 251), o núcleo do tipo é o verbo “expor”, isto é, colocar em perigo um número indeterminado de pessoas. É, portanto, crime de perigo comum.

Tem como característica também ser crime de forma vinculada, já que o meio de execução consiste na utilização de gás tóxico ou asfixiante.

Gás tóxico é aquele venenoso e asfixiante é o mesmo que sufocante. Não precisam ser mortíferos. Não se confundem com a fumaça ou vapor, que possam causar incômodo. Para esse último caso, há previsão no art. 38 da Lei das Contravenções Penais, que prevê: “provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém.” A distinção reside na gravidade da conduta. A contravenção só molesta, não expõe a risco a vida ou integridade física.

O delito é comum, pois não exige nenhuma característica especial do agente, e o sujeito passivo é a coletividade, sendo crime vago, portanto.

Trata-se de crime material e de perigo concreto, isto é, o uso do gás tóxico ou asfixiante deve, comprovadamente, expor a perigo um número indeterminado de pessoas. Há necessidade de perícia para se atestar a materialidade delitiva.

Parte da doutrina defende que o dispositivo em comento foi parcialmente revogado pelo art. 54 da Lei de Crimes Ambientais, o qual estabelece: “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.

Deve ser feita, assim, a compatibilização dos diplomas legais. Aquele que expõe a perigo a vida e a integridade física de outrem mediante o uso de gás tóxico ou asfixiante incorre nas penas previstas no dispositivo da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). Entretanto, permanece em vigor o artigo do CP quando houver a exposição a perigo, pelo uso de gás tóxico ou asfixiante, do patrimônio alheio, que não é tutelado pela Lei nº 9.605/98.

Há previsão de modalidade culposa no parágrafo único, apenas com detenção, de três meses a um ano.

Também se aplicam as formas majoradas do art. 258 do CP.

A ação penal é pública incondicionada.



4. ART. 253. FABRICO, FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO POSSE OU TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS OU GÁS TÓXICO, OU ASFIXIANTE

Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Essa é a conduta típica prevista no art. 253, punida com detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Admite-se a aplicação da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado. A prática de mais de um dos verbos, no mesmo contexto fático, enseja crime único.

O art. 16, parágrafo único, inc. III, do Estatuto do Desarmamento revogou tacitamente o dispositivo em comento com relação à **substância ou engenho explosivo**. Quanto aos demais produtos, isto é, gás tóxico ou asfixiante, ou ainda para o material destinado a sua fabricação, continua sendo aplicado o tipo do art. 253 do CP.

Trata-se de crime de perigo abstrato ou presumido, ou seja, prescinde da comprovação do efetivo perigo à coletividade (posição majoritária).

Há elemento normativo do tipo na expressão “sem licença da autoridade.” É, assim, norma penal em branco heterogênea, vez que exige um complemento.

O crime é formal, de consumação antecipada ou resultado cortado. Não se exige que o dano seja causado. O delito se consuma quando o sujeito fabrica, fornece, adquire, possui ou transporta o gás tóxico ou asfixiante.

Aplicam-se as formas majoradas do art. 258 do CP.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 254. INUNDAÇÃO

Segundo o art. 254, é crime causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A pena é de reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de seis meses a dois anos, no caso de culpa. A forma dolosa admite o acordo de não persecução penal. Já a inundação culposa é infração de menor potencial ofensivo.

Qualquer pessoa pode praticar essa infração (crime comum). O sujeito passivo é a coletividade (crime vago).

A inundação se caracteriza quando ocorre extravasamento de águas, o desvio de onde deveria permanecer, natural ou artificialmente. Como consequência, há a submersão de um local, atingindo a incolumidade pública.

O crime é material e de perigo concreto. Consuma-se no momento em que, após causar a inundação, são expostos a perigo efetivo e comprovado a vida, integridade física ou patrimônio de pessoas não individualizadas.

Aplica-se o art. 258 do CP (formas majoradas pelo resultado).

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 255. PERIGO DE INUNDAÇÃO

Nos termos do art. 255, remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação é crime punido com reclusão, de um a três anos, e multa. É possível a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O crime é comum, pois qualquer pessoa poderá praticar a infração, inclusive o proprietário do prédio. O sujeito passivo é a coletividade.



Tem-se um exemplo de crime obstáculo, já que se pune um ato preparatório da inundação (art. 254) de forma autônoma.

A figura não admite tentativa e prescinde da inundação para que reste configurada.

O crime é formal e de perigo concreto.

Somente pode ser praticado na forma dolosa. Não se exige especial fim de agir.

Se a inundação efetivamente ocorre, sem que o agente tenha desejado ou assumido o risco, responderá em concurso formal com o art. 254, na forma culposa.

A ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 256. DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO

Segundo o art. 256, causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem é conduta punida com reclusão, de um a quatro anos, e multa. Admite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal. No parágrafo único, há previsão da **modalidade culposa**, com pena de detenção, de seis meses a um ano, infração de menor potencial ofensivo, atraindo a incidência da Lei nº 9.099/95.

Qualquer pessoa poderá praticar essa infração (crime comum). Mas é preciso expor efetivamente a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, motivo pelo qual se trata de crime de perigo concreto.

Desabamento é a derrubada de obras produzidas pela ação humana. Já o desmoronamento é fazer vir abaixo partes do solo.

A simples queda de materiais isolados não basta para a configuração do delito, segundo o entendimento jurisprudencial.

O crime é material. A consumação ocorre com o desabamento ou desmoronamento, desde que causem perigo comum.

Importante distinguir a presente figura da contravenção prevista no art. 29 da LCP: “Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa.” Há subsidiariedade expressa da contravenção, visto que não há exposição de pessoas indeterminadas a perigo.

Aplica-se o disposto no art. 258 do CP.

A ação penal é pública incondicionada.

8. ART. 257. SUBTRAÇÃO, OCULTAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO

O art. 257 prevê como crime a conduta de subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. A pena é de reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Não é possível a aplicação da Lei nº 9.099/95, mas é viável o acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

Trata-se de tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado. A prática de mais de um verbo, no mesmo contexto fático, enseja crime único.

O crime é comum, já qualquer pessoa poderá praticar essa infração, inclusive o proprietário dos objetos destinados a salvamento. O sujeito passivo é a coletividade (crime vago).

O objeto material do delito poderá ser extintor, corda, medicamento, bastando que haja uma situação de urgência e que o sujeito oculte o objeto necessário.

Entende a doutrina ser possível empregar a analogia para outras situações não contempladas no tipo penal, desde que guardem similitude com as condutas expressas no artigo.

O crime é de perigo abstrato ou presumido, dispensando a comprovação do perigo concreto ou prova do dano. A tentativa é admissível.

Não há previsão de crime culposos neste caso. Aplica-se o art. 258 do CP (forma majorada pelo resultado) apenas em relação ao crime doloso de perigo comum, desde que resulte:



- Lesão corporal de natureza grave: a pena será aumentada da 1/2 (metade).
 - Morte: a pena será aplicada em dobro.
- A ação penal é pública incondicionada.

9. ART. 258. FORMAS QUALIFICADAS DE CRIME DE PERIGO COMUM

Na verdade, o dispositivo prevê causas de aumento de pena e não qualificadoras. Tecnicamente, revela-se mais acertado falar em formas majoradas de crime de perigo comum.

Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. Há crime preterdoloso, isto é, dolo no antecedente e culpa no consequente (resultado).

No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço. Há culpa no antecedente e no consequente.

Vale ressaltar que, se de apenas uma conduta relativa a um crime de perigo comum decorra lesão corporal ou morte de mais de uma pessoa, não haverá concurso de crimes.

10. ART. 259. DIFUSÃO DE DOENÇA OU PRAGA

O tipo penal foi revogado tacitamente pelo art. 61 da Lei de Crimes Ambientais.

Nos termos da Lei nº 9.605/98, é crime ambiental a conduta de disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. A pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Não se admite a forma culposa na lei especial.



CAPÍTULO 57 — DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA: DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

1. ART. 260. PERIGO DE DESASTRE FERROVIÁRIO

O crime previsto no art. 260 é o de impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, por meio das seguintes condutas:

I - destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra-de-arte ou instalação;

II - colocando obstáculo na linha;

III - transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia;

IV - praticando outro ato de que possa resultar desastre.

Apenas é reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Assim, não se mostra possível aplicar a Lei nº 9.099/95. Porém, à figura do *caput*, é viável o acordo de não persecução penal.

Obras de arte, referidas no inc. I, são construções como túneis, viadutos, pontes, destinadas à passagem de veículos.

No caso do inc. IV, *outro fato de que possa resultar desastre* é uma fórmula genérica, que autoriza a analogia *intra legem*. Porém, o dispositivo é criticável, dada a sua amplitude, com possível ofensa à necessidade de que os tipos penais sejam claros e determinados (taxatividade da lei penal).

O perigo de desastre deve ser efetivamente comprovado, motivo pelo qual se trata de **crime de perigo concreto**.

O crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por funcionários da empresa ferroviária. O sujeito passivo é a coletividade (crime vago).

É também classificado como crime formal ou de consumação antecipada, não se exigindo o resultado naturalístico para a sua consumação.

No § 1º observa-se a forma qualificada, quando de fato resulta o **desastre ferroviário**. A pena passa a ser de reclusão, de quatro a doze anos e multa. Trata-se de delito preterdoloso, que não admite tentativa.

Já o § 2º prevê a forma culposa. O agente causa o desastre por ter agido com negligência, imprudência ou imperícia. A pena será de detenção, de seis meses a dois anos, isto é, uma infração de menor potencial ofensivo.

Por fim, o § 3º traz norma penal explicativa. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Assim, o tipo inclui trens, bondes, metrô, teleféricos, sejam públicos ou particulares.

Segundo o art. 263, se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, **no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte**, aplica-se o disposto no art. 258 do CP (majorantes).

Questão discutida pela doutrina e jurisprudência diz respeito ao “surfe de trem”, praticado por sujeitos que se arriscam sobre os vagões em movimento. Há crime?

Prevalece o entendimento de não ser típica a conduta, já que surfista de trem limita-se a expor a perigo sua própria vida. Não há dolo de criar a situação de perigo de desastre ferroviário que vá atingir um sem número de pessoas.

Para os que defendem a tipicidade, o indivíduo, ao se equilibrar nos vagões, prejudica o sistema de acionamento das portas, impedindo o regular funcionamento dos trens, colocando em risco inúmeras pessoas, incidindo na conduta do art. 260, inc. IV, do CP.

Sem dúvidas, o caso concreto indicará a melhor solução, verificando-se as circunstâncias em que foi praticada a conduta, o dolo do agente, e se houve a exposição efetiva das pessoas a perigo.



A competência é da Justiça Estadual, ainda que a linha férrea seja da União, pois o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública (STJ, Informativo 551)⁵⁹.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 261. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL OU AÉREO

Nos termos do art. 261, expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea é crime apenado com reclusão, de dois a cinco anos. Admite-se o acordo de não persecução penal, conforme o art. 28-A do CPP.

Qualquer pessoa pode praticar o delito, inclusive o proprietário. Ademais, é crime vago, tendo a coletividade como sujeito passivo. Tutela-se a incolumidade pública.

Caso o sujeito queira promover a queda da aeronave para matar alguém, a doutrina entende que há **concurso formal impróprio** entre o crime em tela e o homicídio, já que, além do dolo de matar o passageiro específico, outras pessoas também foram submetidas a uma situação de perigo concreto.

O tipo é misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado, que pode ser praticado nas formas expor, praticar, impedir e dificultar. O crime é de forma livre, pois não há nenhuma vinculação ou modo específico de incorrer nas sanções.

O crime é de perigo concreto, exigindo a efetiva demonstração de colocação da incolumidade pública em situação de risco.

Não se perquire a finalidade específica da conduta. Porém, quando há intuito de obtenção de vantagem econômica, aplica-se multa, conforme indicação do § 2º.

Quanto ao momento consumativo, o crime é formal, pois independe do efetivo prejuízo à navegação marítima, fluvial ou aérea, desde que haja o perigo a um número indeterminado de pessoas.

Segundo o art. 263, se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no art. 258 do CP (forma majorada).

Conforme o § 1º, se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave, a pena será de reclusão, de quatro a doze anos. A forma qualificada é preterdolosa (culpa quanto ao resultado danoso).

A modalidade culposa está prevista no § 3º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, tem-se pena de detenção, de seis meses a dois anos. A infração será de menor potencial ofensivo.

O art. 35 do Decreto-lei nº 3.688/41 prevê como contravenção penal o abuso na prática da aviação, consistente em entregar-se na prática da aviação, a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em que a lei o permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim. Nesse caso, a conduta é praticada por piloto, com conhecimentos técnicos, o que diminui a possibilidade de riscos à incolumidade pública. Se o agente pratica tais comportamentos sem possuir conhecimento e técnica para tanto, surgindo perigo à coletividade, estará configurado o tipo do art. 261 do CP.

A competência é da Justiça Federal, como regra (art. 109, inc. IX, da CF).

A ação penal é pública incondicionada.

⁵⁹“Em princípio, compete à Justiça Estadual (e não à Justiça Federal) processar e julgar suposto crime de perigo de desastre ferroviário qualificado pelo resultado lesão corporal e morte (art. 260, IV, § 2º, c/c art. 263 do CP) ocorrido por ocasião de descarrilamento de trem em malha ferroviária da União. Isso porque, aparentemente, esse fato não gerou qualquer ofensa direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF).” STJ. 6ª Turma. RHC 50.054-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 4/11/2014 (Info 551).



3. ART. 262. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE

Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento é crime punido com detenção, de um a dois anos. É possível a transação penal e a suspensão condicional do processo (Lei nº 9.099/95).

No tipo penal anterior havia uma referência específica aos meios de transporte (ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo). O art. 262 contempla aqueles não abrangidos pelo art. 261, o rodoviário e o lacustre, por exemplo. Tem, assim, caráter residual ou subsidiário.

O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, no que se refere à segurança dos meios de transporte público.

O tipo abrange o serviço prestado pelo Poder Público ou por particulares, por concessão e, ainda, todas as atividades realizadas em prol da coletividade, como no caso do transporte escolar e ônibus fretados, ainda que particulares. Por outro lado, não abrange o serviço prestado por carros de passeio particulares.

Os núcleos do tipo são expor, impedir e dificultar. É tipo misto alternativo ou de conteúdo variado. Se praticado mais de um verbo em um mesmo contexto fático, o crime é único.

O delito se classifica, quanto aos sujeitos, em comum e vago.

Consuma-se independentemente da ocorrência de desastre, sendo assim formal. Exemplo: indivíduo que adapta seu veículo para o uso a gás em casa, de forma amadora.

O crime é de perigo concreto, exigindo a efetiva demonstração do perigo causado à incolumidade pública.

Se o sujeito tinha a intenção de matar passageiro determinado, responderá pelos crimes em concurso formal impróprio, uma vez presentes desígnios autônomos.

O § 1º estabelece que se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de dois a cinco anos. É a forma qualificada e preterdolosa.

No caso de culpa, se ocorre desastre, a pena será detenção, de três meses a um ano, nos moldes do § 2º, também infração de menor potencial ofensivo.

Segundo o art. 263, se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, **no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal** ou **morte**, aplica-se o disposto no art. 258 (forma majorada).

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 263. FORMA QUALIFICADA

Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no art. 258, o qual prevê: se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço.

Na verdade, o dispositivo prevê causas de aumento de pena e não qualificadoras. Tecnicamente, revela-se mais acertado falar em formas majoradas de crime.

5. ART. 264. ARREMESSO DE PROJÉTIL

Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar é conduta punida com detenção, de um a seis meses. Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo, desde que não haja o resultado morte (parágrafo único).

O tipo contempla qualquer meio de transporte coletivo de pessoas ou coisas (cargas em geral). Exemplos: ônibus, navios, aviões e helicópteros. Todavia, não abrange veículos particulares utilizados para fins privados, ainda que se encontrem várias pessoas em seu interior.



É elementar do tipo que o veículo esteja em movimento. Se estiver parado, o crime será de dano (art. 163 do CP).

O arremesso pode ser feito com as próprias mãos ou mediante a utilização de instrumento (estilingue, catapulta).

Incluem-se no conceito de projétil as pedras, pedaços de vidro ou madeira, peças de metal, isto é, objetos grandes e sólidos. Não podem ser assim considerados ovos, tomates, e outros incapazes de ofender a incolumidade pública. Prevalece o entendimento que somente integram o conceito de projétil objetos sólidos. Minoritariamente, há quem sustente que líquidos, a exemplo dos ácidos, poderiam se enquadrar também no conceito de projétil.

Se o projétil for munição de arma de fogo, o crime será aquele previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 (princípio da especialidade).

O crime é subsidiário, residual. É necessário analisar se a intenção do agente não era a de praticar crime mais grave.

O delito é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Quanto à consumação, é formal. É de perigo abstrato, já que independe da efetiva produção de resultado naturalístico.

Se o indivíduo tem a intenção de atingir uma pessoa determinada com o projétil, ao arremessar uma pedra, por exemplo, responderá pelos crimes em concurso formal caso existam desígnios autônomos (além do dolo de ferir, também tiver a intenção de expor a perigo a incolumidade pública).

Nos termos do parágrafo único, se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; se resulta morte, a pena é a do art. 121, § 3º (homicídio culposo), aumentada de um terço.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 265. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

Nos termos do art. 265, atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública acarreta pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O legislador se vale da interpretação analógica ou *intra legem*. Utiliza-se de fórmula casuística (*atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor*), seguida de uma fórmula genérica (*ou qualquer outro de utilidade pública*). Assim, o rol não é taxativo.

No caso do serviço de telefonia há um tipo específico, previsto no art. 266 do CP.

Atentar significa atrapalhar, ofender, importunar ou colocar em risco. Busca-se evitar danos e cortes indesejáveis no abastecimento. Exemplos: destruição dos meios de produção, captação (usinas, represas) ou de distribuição (postes, fios, encanamento).

O crime é comum e o sujeito passivo é a coletividade.

O movimento de greve não configura o crime do art. 265, pois se trata de exercício de um direito constitucional.

O tipo não exige a demonstração do efetivo perigo, motivo pelo qual o crime é de perigo abstrato ou presumido.

O parágrafo único estabelece que a pena será aumentada de um terço até a metade, se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços.

Quando se tratar de impedir ou dificultar o funcionamento de instalação nuclear ou o transporte de material dessa natureza, aplica-se a lei especial, nos termos do art. 27 da Lei nº 6.453/77.

A competência, em regra, é da Justiça Estadual, salvo quando houver interesse da União (energia elétrica, por exemplo, conforme art. 21, XII, b, da CF).

A ação penal é pública incondicionada.



7. ART. 266. INTERRUPTÃO OU PERTURBAÇÃO DE SERVIÇO TELEGRÁFICO, TELEFÔNICO, INFORMÁTICO, TELEMÁTICO OU DE INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento é crime apenado com detenção, de um a três anos, e multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Qualquer pessoa pode praticar o crime, inclusive aquela que executa o serviço. O crime é vago, pois o sujeito passivo é a coletividade.

Percebe-se que o tipo penal não exige a comprovação do efetivo perigo ao bem jurídico tutelado (perigo abstrato), dispensando a efetiva ocorrência do dano para a consumação (formal).

O perigo deve expor pessoas indeterminadas. Se a conduta atingir pessoas específicas, o crime será o do art. 151, § 1º, III, do CP.

Admite a tentativa.

A instalação clandestina de aparelhos de telecomunicação caracteriza o crime do art. 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4.117/62). Exemplo: rádios –pirata.

Conforme dispõe o § 1º, incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento.

Importante notar a redação do § 2º, pois se aplicam em dobro as penas se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Trata-se de causa especial de aumento de pena, justificada pela maior reprovabilidade da conduta praticada em tempo de instabilidade social. Incidirá, por certo, na terceira fase da dosimetria.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 58 — DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA: DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

1. ART. 267. EPIDEMIA

Segundo o art. 267, causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, é crime punido com reclusão, de dez a quinze anos. Não se aplica a Lei nº 9.099/95, nem é possível o acordo de não persecução penal.

O bem jurídico tutelado é a saúde pública, entendida como a preservação de condições saudáveis de subsistência e desenvolvimento da coletividade.

Germe patogênico é o organismo capaz de produzir moléstia infectocontagiosa, nociva à saúde, como vírus, bactérias, fungos e bacilos. O núcleo do tipo é causar, isto é, produzir, dar origem, propagar os microorganismos.

Epidemia é o surto de uma doença, que tem caráter transitório, atacando simultaneamente um número indeterminado de indivíduos de certa localidade. **Exemplo:** epidemia de febre amarela em Minas Gerais. Outros exemplos: poliomielite, influenza, raiva, Covid-19, esta última, por ter alcançado proporções mundiais, é chamada de pandemia.

A propagação poderá ocorrer das mais diferentes formas, inclusive por omissão, quando o indivíduo, contaminado, deixa de tomar as precauções necessárias para evitar a difusão da doença.

O crime é material e de perigo concreto, motivo pelo qual é necessário que várias pessoas sejam infectadas em razão da conduta do agente. Não se exige especial fim de agir.

Somente a difusão de doença humana tipifica a conduta. Se a moléstia atinge plantas ou animais, prevalece a disposição da lei especial (art. 61 da Lei nº 9.605/98).

O delito é compatível com a tentativa, como na hipótese de apenas uma pessoa ser contaminada.

Nos termos do § 1º, se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Trata-se de forma majorada. Basta uma única morte. **A Lei nº 8.072/90 consagra a epidemia dolosa com resultado morte como crime hediondo.**

No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos. Assim, se não houver morte, será infração de menor potencial ofensivo.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 268. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA

O art. 268 prevê como criminosa a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de detenção, de um mês a um ano, e multa. Cuida-se de delito de menor potencial ofensivo, da competência do Juizado Especial Criminal.

Tem-se um exemplo de norma penal em branco, observada a expressão *determinação do poder público*. O preceito primário depende de complemento, que poderá ser outra lei ou ato administrativo (decreto, regulamento).

Exemplos: a Lei nº 7649/88 impõe o cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, a fim de garantir a segurança das coletas e dos que receberão o sangue doado.

Além disso, segundo a jurisprudência, a reutilização de agulhas hipodérmicas em hospital caracteriza o delito em comento. O indivíduo que reaproveita materiais descartáveis e que podem causar infecções ou propagação de doenças incidirá nessa figura penal.

O crime é comum, uma vez que não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, e vago, pois tutela a saúde pública. O sujeito passivo é a coletividade.



O elemento subjetivo é o dolo, prescindindo de finalidade específica. Não se admite a forma culposa.

O crime se consuma no momento em que há a violação à determinação do Poder Público, seja por lei ou ato administrativo, desde que revestida de compulsoriedade. O crime é formal ou de consumação antecipada, pois não é necessário o resultado naturalístico. O fato de desobedecer a determinação já caracteriza a figura consumada. Admite-se a tentativa.

O tipo não exige a efetiva demonstração de perigo. É um **crime de perigo abstrato** (presumido). Não se observando as normas administrativas, a coletividade estará exposta a risco.

Nos termos do parágrafo único, a pena é aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Tais profissionais tem o dever de evitar a introdução ou propagação de doença, em razão do cargo ou função exercida, daí resultando uma maior reprovabilidade no caso de inobservância.

Segundo o art. 285, aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no art. 267 (epidemia). No caso do art. 268, ora em estudo, vai se aplicar a forma majorada prevista na primeira parte do art. 258, já que não há previsão de modalidade culposa do crime.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 269. OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇA

Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória é crime punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

O crime é **próprio**, pois o tipo penal exige que seja o autor médico, mas admite concurso de pessoas, como na hipótese do enfermeiro ou terceiros que participam do delito. O sujeito passivo é a coletividade.

O verbo núcleo do tipo é *deixar*, que representa um não fazer. Assim, é um crime omissivo próprio ou puro, pois a omissão está descrita expressamente no tipo penal.

É também classificado como crime de mera conduta ou simples atividade, pois o simples *deixar* já caracteriza a figura consumada.

A hipótese é de norma penal em branco, pois o rol das doenças de comunicação obrigatória é feito pelas autoridades sanitárias, em atendimento ao interesse público, considerando a possibilidade de contágio. **Exemplos:** Lei nº 6.259/75 e Portaria 1.100/96 do Ministério da Saúde, que tratam da dengue, rubéola, hepatite, dentre outras doenças contagiosas.

O crime é de **perigo presumido ou abstrato**.

Não há incompatibilidade da figura penal em estudo com o sigilo profissional imposto pelo art. 154 do CP. É sabido que o prontuário médico é um documento sigiloso, porém, quando se trata de doença de notificação compulsória, o médico, ao comunicar às autoridades que está diante de um quadro infeccioso grave e que deve ser notificado, está no estrito cumprimento de um dever legal. O crime de violação de segredo profissional somente se caracteriza quando a revelação do estado de saúde se dá sem justa causa, elemento normativo do tipo a ser aferido no caso concreto.

Tratando-se de crime omissivo puro, não é compatível com a tentativa. Não há fracionamento do *iter criminis*.

Há incidência de causas de aumento de pena, pois o art. 285 determina a aplicação do art. 258.

A ação penal é pública incondicionada.



4. ART. 270. ENVENENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OU DE SUBSTÂNCIA ALIMENTÍCIA OU MEDICINAL

Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo é crime apenado com reclusão, de dez a quinze anos.

Apesar da pena cominada ser alta, o crime foi retirado do rol dos hediondos. É compatível com a prisão temporária.

Segundo a doutrina majoritária, não há incompatibilidade com o art. 54 da Lei nº 9.605/98, que se volta a punir a poluição de qualquer natureza. A figura descrita no CP tem potencialidade lesiva muito maior.

Qualquer pessoa pode praticar o crime, não se exigindo nenhuma característica especial. O sujeito passivo é a coletividade.

Água potável é aquela destinada ao consumo humano, de forma direta ou indireta (preparo de alimentos). Veneno é a substância apta a intoxicar o organismo, com a alteração das funções biológicas normais.

Trata-se de um **crime de perigo comum**. Isso significa que a substância envenenada deverá estar posta à disposição de um número indeterminado de pessoas, ainda que seja de uso particular. Exemplo: águas estocadas em caixa d'água de uma escola ou indústria, que servirá para o consumo de inúmeros estudantes ou operários, ou que será utilizada para a produção de determinado alimento.

O tipo penal não exige a demonstração do efetivo perigo, motivo pelo qual constitui **crime de perigo abstrato**.

Se o envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal direcionar-se a pessoa determinada, com intenção de matar, a hipótese é de homicídio, tentado ou consumado. Se a conduta colocar em perigo pessoa determinada, tem-se o crime do art. 132 do CP.

Se a água não era potável, ou se a substância alimentícia ou medicinal já estava contaminada, é o caso de crime impossível, por impropriedade absoluta do objeto.

O crime é formal, de consumação antecipada ou resultado cortado, pois prescinde da provocação de dano ou da efetiva ingestão da água ou substância alimentícia ou medicinal.

No § 1º está descrita a figura equiparada. Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada. O sujeito ativo é terceira pessoa, diversa da responsável pelo envenenamento.

Aquele que efetua o envenenamento não pode incidir na figura equiparada. Se envenena e depois entrega a consumo, tem-se um desdobramento da conduta principal, que será absorvido, pelo princípio da consunção.

Na modalidade ter em depósito é crime permanente, eis que a consumação se prolonga no tempo.

A modalidade culposa está prevista no § 2º, punida com detenção, de seis meses a dois anos. O envenenamento se dá por imprudência, negligência ou imperícia. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, com a possibilidade de aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do art. 285, aplicam-se as causas de aumento de pena previstas no art. 258, na terceira fase da dosimetria.

A ação penal é pública incondicionada

5. ART. 271. CORRUPÇÃO OU POLUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

Segundo o art. 271, corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde é conduta punida com reclusão, de dois a cinco anos.



Apesar da similitude, este tipo não se confunde, por óbvio, com aquele do art. 270, que é mais grave, pois pode produzir danos mais amplos à coletividade. Envenenar é mais grave do que corromper ou poluir.

Cogita-se de um conflito aparente de normas penais entre o dispositivo em estudo e a Lei nº 9.605/98. Luiz Régis Prado e Rogério Sanches Cunha entendem que houve a ab-rogação do crime em comento pela Lei dos Crimes Ambientais, em seu art. 54⁶⁰.

Já Cleber Masson entende que não houve revogação do tipo do CP. Defende que aplicação da lei especial pressupõe a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, nos moldes do art. 54, § 2º, inc. III, da Lei nº 9.605/98. Se essa interrupção não ocorrer, mas ainda assim a água for corrompida ou poluída, restando imprópria para consumo ou nociva à saúde, incidirá a figura do art. 271 do CP. Assim, a Lei nº 9.605/98 tem um *plus* especializante.⁶¹

O STJ tem julgado no sentido da primeira corrente, conforme se observa do HC 178423/GO:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. POLUIÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO OU DANO A FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CORRUPÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. AB-ROGAÇÃO PELA LEI Nº 9.605/98. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA NO DELITO DE DANO E DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE NO CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. **O tipo penal, posterior, específico e mais brando, do art. 54 da Lei nº 9.605/98 engloba completamente a conduta tipificada no art.**

271 do Código Penal, provocando a ab-rogação do delito de corrupção ou poluição de água potável.

II. Para a caracterização do tipo citado, mister a ocorrência de efetiva lesão ou perigo de dano, concreto, real e presente, à saúde humana, à flora ou à fauna.

III. Mostra-se inepta a denúncia que carece de comprovação da possibilidade de danos à saúde humana pelo suposto fato de a paciente de ter deixado, em data específica, que seu rebanho bebesse em dique que abastece cidade, pela ausência de conclusão técnica sobre a salubridade da água.

IV. A mera descrição de dano a floresta de preservação permanente é insuficiente para a configuração do delito do art. 38, caput, da Lei nº 9.605/98, sendo necessária a demonstração de indícios mínimos de autoria.

V. A simples descrição do dano ambiental e conseqüente atribuição da responsabilidade à proprietária do imóvel rural, quanto mais se recentemente adquirido, consiste em responsabilização penal objetiva, inadmissível no ordenamento jurídico.

VI. Ausentes da denúncia os elementos mínimos de autoria e materialidade, cabível o trancamento da ação penal.

VII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. (HC 178.423/GO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Grifou-se.

6. ART. 272. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

O art. 272 prevê como crime corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. A pena prevista é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. É crime de elevado potencial ofensivo, salvo na modalidade culposa, prevista no § 2º.

⁶⁰CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 706.

⁶¹MASSON, Cleber. Direito Penal. **Parte Especial. Vol. 3.** São Paulo: Gen Método, 2017, p. 335.



O tipo penal exige que a conduta torne a substância ou produto alimentício nocivo à saúde ou reduza o seu valor nutritivo. Trata-se da prova da materialidade do crime, sendo imprescindível o **exame pericial. O crime é de perigo concreto**, sendo necessário demonstrar, por prova técnica, que houve a perda dos nutrientes ou a nocividade à saúde.

A doutrina aponta **violação ao princípio da proporcionalidade**, pois se pune da mesma forma condutas distintas (tornar nociva; reduzir o valor nutritivo) e com gravidades diversas. Tornar o produto nocivo à saúde é muito mais grave do que reduzir seu valor nutritivo.

Qualquer pessoa pode praticar o crime (comum). O sujeito passivo é a coletividade. Admite-se a prática por omissão.

O crime é formal, pois prescinde de resultado naturalístico para a consumação. A tentativa é possível. Não se exige especial fim de agir.

O § 1º estabelece que está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico.

Por seu turno, o § 1º-A prevê que incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado. Trata-se de conduta equiparada. O sujeito ativo não foi o responsável pela falsificação. Algumas modalidades são crimes permanentes, como ter em depósito e expor à venda.

Conforme o § 2º, se o crime é culposos, a pena passa a ser de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Há que se atentar ao aumento de pena. Segundo o art. 285, aplica-se o disposto no art. 258 do CP.

À míngua de disposição diversa em sentido contrário, a ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 273. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS

Segundo o art. 273, falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é crime punido com reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

O tipo penal trata de condutas ligadas ao poder de polícia da Administração Pública, aos órgãos de vigilância sanitária, ao poder de fiscalizar os produtos de interesse da saúde pública. Considerando a seletividade do direito penal, no que tange à escolha dos bens jurídicos tutelados, entendeu-se que essas práticas são demasiado graves, por expor a incolumidade de um sem número de pessoas a risco, não sendo a tutela apenas no âmbito administrativo suficiente. O direito penal, como *ultima ratio*, também é chamado a intervir nessas situações.

O crime é hediondo, exceto na modalidade culposa. Aplicam-se, assim, os rigores da Lei nº 8.072/90.

O § 1º estabelece que nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. É o crime praticado pelo **vendedor**, e não por quem fabricou o produto falsificado.

Por sua vez, o § 1º-A traz norma penal explicativa. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.

Saneantes são os produtos destinados à higienização e limpeza, como desinfetantes, águas sanitárias. Os de uso em diagnóstico são aqueles produtos empregados por laboratórios para se aferir a presença de determinada substância ou patologia em exame de urina, fezes, sangue, materiais biológicos, etc. Os cosméticos são destinados ao embelezamento, para fins meramente estéticos.



Parte da doutrina critica a equiparação de cosméticos e saneantes a medicamentos, valendo-se do princípio da proporcionalidade. A ofensa à saúde pública é bem menor no caso dos cosméticos e saneantes.

O tipo é misto alternativo, já que o crime pode ser praticado de diferentes formas. São quatro os verbos nucleares do *caput*: falsificar (conferir aparência enganadora), corromper (deteriorar), adulterar (modificar para pior) ou alterar (modificar de qualquer forma)⁶².

A prática de mais de um dos núcleos no mesmo contexto fático ensejará crime único.

O crime é comum, uma vez que não exige nenhuma característica especial do seu sujeito ativo, e também vago, pois a coletividade é o sujeito passivo.

O elemento subjetivo é o dolo, e prescinde de finalidade específica. Há a previsão do tipo culposos, hipótese em que não será crime hediondo.

O delito é formal, de consumação antecipada ou resultado cortado, pois não exige o resultado naturalístico para a consumação. É crime de perigo abstrato.

O § 1º-B trata dos produtos equiparados a falsificados, isto é, as condições os tornam potencialmente perigosos para a população. Assim sendo, se o produto for vendido nas condições listadas nos incisos do § 1º-B, a pessoa que vendeu será punida como se o artigo fosse falsificado. Há uma presunção de que comercializar produtos terapêuticos ou medicinais nas condições do § 1º-B é tão perigoso quanto vender produtos falsificados. Eis o rol legal:

- I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
- II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;
- III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;
- IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;
- V - de procedência ignorada;
- VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

A incriminação numa das condutas previstas no art. 273, § 1º-B (figuras equiparadas), não impede a responsabilização também no âmbito administrativo.

Em 2015, **o STJ decidiu que é inconstitucional a pena (preceito secundário) do art. 273, § 1º-B, V, do CP (produto de procedência ignorada)**. Em substituição a ela, deve-se aplicar a pena prevista no *caput* do art. 33 da Lei 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão (Informativo 559). Considerou-se a desproporcionalidade da punição do art. 273, de 10 a 15 anos de reclusão, comparando-a a outras condutas mais graves, como o estupro de vulnerável e a extorsão mediante sequestro.⁶³

Ainda segundo o STJ, se o agente criou farmácia de fachada para vender produtos falsificados destinados a fins terapêuticos ou medicinais, deverá responder pelo delito do art. 273 do CP (e não por este crime em concurso com tráfico de drogas), ainda que fique demonstrado que também mantinha em depósito e vendia alguns medicamentos e substâncias consideradas psicotrópicas no Brasil por estarem na Portaria SVS/MS nº 344/1998.

⁶²CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 711.

⁶³Sobre o tema, importantes as considerações do professor Márcio André Lopes Cavalcante, publicadas no portal *Dizer o Direito*. Confira-se: “Essa decisão vale apenas para o inciso V do § 1º-B do art. 273 ou também para os demais incisos? O caso concreto apreciado pelo STJ envolvia um habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo inciso V. Assim, no dispositivo do acórdão, menciona-se apenas este inciso. No entanto, pela leitura dos votos dos Ministros, percebe-se que eles trataram do tema de forma genérica, abrangendo todo o § 1º-B. Logo, minha opinião pessoal é no sentido de que essa decisão vale para todos os incisos do § 1º-B. O que o STF entende a respeito? O Plenário do STF ainda não se manifestou sobre o tema. No entanto, existem precedentes da Corte em sentido contrário ao que decidiu o STJ, ou seja, acórdãos sustentando que o § 1º-B do art. 273 é CONSTITUCIONAL (RE 829226 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/02/2015; RE 844152 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/12/2014). Para fins de concurso, você deve estar atento para o modo como a pergunta será formulada. Se indagar a posição do STJ, é pela inconstitucionalidade. Se perguntarem sobre o STF, este possui precedentes sustentando que o art. 273, § 1º-B, do CP é constitucional. Caso o enunciado não diga qual dos dois entendimentos está sendo exigido, assinala a posição STJ porque esta foi divulgada em Informativo e é mais conhecida”. Conteúdo extraído do Informativo Esquemático nº 559 do STJ, disponível em <https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2015/05/info-559-stj.pdf>

Assim, mesmo tendo sido encontradas algumas substâncias classificadas como drogas, o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 ficará absorvido pelo delito do art. 273 do CP, que possui maior abrangência. Aplica-se aqui o princípio da consunção (Informativo 590).

Para a configuração do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º B, inc. I, não se exige perícia, bastando a ausência de registro na ANVISA, obrigatório na hipótese de insumos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. (STJ. 5ª Turma. HC 177.972-BA, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 28/8/2012).

Aplicáveis as causas especiais de aumento de pena, nos termos dos artigos 285 e 258 do CP.

Não se aplica o princípio da insignificância ao delito em tela, ainda que de pequeno valor o produto terapêutico ou medicinal falsificado ou corrompido. Há, por certo, incompatibilidade da insignificância com o bem jurídico tutelado, que é a saúde pública.

A modalidade culposa encontra-se no § 2º, apenada com detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. É infração de médio potencial ofensivo, sendo cabível o *sursis* processual.

A competência é, em regra da Justiça Estadual, salvo quando o medicamento for de procedência internacional. Exemplo: anabolizantes sem o devido registro na Anvisa trazidos do Paraguai, a evidenciar a transnacionalidade da conduta (Informativo 467 do STJ).

A ação penal é pública incondicionada.

8. ART. 274. EMPREGO DE PROCESSO PROIBIDO OU DE SUBSTÂNCIA NÃO PERMITIDA

Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Este é o delito tipificado pelo art. 274, com pena de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Admite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Há uma clara preocupação do legislador em cuidar para que os produtos destinados a consumo de um número indeterminado de pessoas não tenham entre seus componentes substâncias tóxicas aptas a provocar malefícios à saúde, alergias, intolerâncias, entre outras reações indesejáveis.

No conceito de produto destinado a consumo se incluem roupas, calçados, brinquedos, itens de higiene. Devem ter por destinatários a coletividade.

Observa-se uma norma penal em branco, sendo necessário um complemento pela legislação sanitária (leis, decretos ou regulamentos).

O crime é comum, não exige nenhuma característica especial do sujeito ativo, e é vago, vez que o sujeito passivo é a coletividade.

Ademais, o crime é formal, prescinde de resultado naturalístico, e de perigo abstrato. Não se exige especial fim de agir.

É aplicável o aumento de pena previsto no art. 285, na forma do art. 258.

A ação penal é pública incondicionada.

9. ART. 275. INVÓLUCRO OU RECIPIENTE COM FALSA INDICAÇÃO

Segundo o art. 275, é crime inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. A pena é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Assim, é cabível a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Inculcar significa fazer crer, apregoar, dar a entender, demonstrar. O indivíduo faz constar no invólucro (rótulo, pacote) ou recipiente (frasco, pote, embalagem) a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo. A informação é falsa.

Qualquer pessoa pode cometer o crime. Já o sujeito passivo é a coletividade e, eventualmente, a vítima atingida no caso concreto.



O crime se consuma quando há a falsa indicação, não havendo a necessidade de disponibilização do produto ao consumidor, ou que tenha havido aquisição. O delito é, portanto, formal. Prescinde da superveniência do resultado naturalístico. A tentativa é possível.

Não se confunde com o tipo do art. 66 da Lei nº 8.078/90(CDC), segundo o qual é crime fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Se a conduta recai sobre gêneros alimentícios, terapêuticos ou medicinais, aplica-se o art. 275do CP, que é específico quanto aos produtos que estão sujeitos à sua incidência. Nos demais casos, aplica-se o CDC o qual, inclusive, prevê modalidade culposa.

A ação penal é pública incondicionada.

10. ART. 276. PRODUTO OU SUBSTÂNCIA NAS CONDIÇÕES DOS DOIS ARTIGOS ANTERIORES

Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos artigos 274 e 275 acarreta pena de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Trata-se de infração de médio potencial ofensivo, cabendo *sursis* processual e o acordo de não persecução penal.

A hipótese é de crime remetido, vez que a definição típica remete a outros dispositivos penais, que passam a integrá-lo.

O crime é comum. É mais frequentemente praticado por comerciantes. Quanto ao sujeito passivo, o crime é vago, pois atinge a coletividade.

É ainda tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado. A prática de mais de um verbo em um mesmo contexto fático enseja delito único.

Na modalidade *ter em depósito* o crime é permanente. Nesse caso, exige-se o especial fim de agir, consistente em ter em depósito para o fim de vender.

O crime é formal e de perigo abstrato.

Aplica-se o aumento de pena, nos termos dos artigos 285 e 258.

A ação penal é pública incondicionada.

11. ART. 277. SUBSTÂNCIA DESTINADA À FALSIFICAÇÃO

Conforme dispõe o art. 277, vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais é crime apenado com reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. É cabível a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O tipo penal trata de substâncias que serão acrescidas a produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, para lhes alterar ou falsificar. **Exemplo:** adicionar determinada substância conservante para ocultar a deterioração de um alimento.

Trata-se de crime comum e vago.

A previsão legal abrange somente as substâncias. Não inclui aparelhos ou petrechos que serão utilizados, eventualmente, para falsificar produtos alimentícios.

O tipo é misto alternativo, já que o crime pode ser praticado de diferentes formas (vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder). A prática de mais de um dos verbos, no mesmo contexto fático, tipifica um único crime.

Ademais, tem-se um exemplo de crime obstáculo, com a incriminação autônoma de comportamentos que representam atos preparatórios dos crimes previstos nos artigos 272 e 273 do CP. Ainda que o indivíduo não consiga efetivamente falsificar os produtos, quando tem em depósito a substância destinada a falsificar, já incorrerá em conduta criminoso. Ou seja, ainda que não complete o seu objetivo final (falsificar), o ato preparatório já é punido, dada a sua gravidade.



O crime é formal, não exige o resultado naturalístico, e de perigo abstrato, já que o legislador presume o risco à saúde pública.

Não admite tentativa, nem modalidade culposa. Aplica-se o art. 285, na forma do art. 258 (causas de aumento de pena).

A ação penal é pública incondicionada.

12. ART. 278. OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE PÚBLICA

Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal é crime apenado com detenção, de um a três anos, e multa. É possível a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Quando a substância tem natureza alimentícia ou medicinal, a hipótese será dos crimes dos artigos 272 e 273. No tipo penal em estudo incluem-se, por exemplo, papéis, tintas, cigarros, brinquedos. Quando se tratar de substância entorpecente, assim definida em lista elaborada pelo Poder Executivo, o crime será o do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão do princípio da especialidade.

O crime é comum e vago.

Substância nociva é aquela que causa algum tipo de prejuízo a quem a consome. A nocividade deve ser inerente à coisa, e não decorrente do uso inadequado.

É também um crime de perigo comum (o perigo atinge um número indeterminado de pessoas). Quanto à consumação, é formal, pois prescinde do resultado naturalístico.

Masson defende ser o delito de perigo concreto, havendo a necessidade de efetivamente se demonstrar que aquele produto apresenta nocividade à saúde.⁶⁴ Já Sanches entende ser de perigo abstrato.⁶⁵

A modalidade culposa está prevista no parágrafo único, punida com detenção, de dois meses a um ano.

Aplicam-se as causas de aumento de pena do art. 285.

Não havendo previsão legal em sentido diverso, a ação penal é pública incondicionada.

13. ART. 279. SUBSTÂNCIA AVARIADA

O dispositivo foi revogado, expressamente, pelo art. 23 da Lei nº 8.137, de 27.12.1990, que define os crimes contra as relações de consumo.

A previsão incriminadora consta do art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90. Confira-se:

Art. 7º Constitui crime contra as relações de consumo:

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à quinta parte.

14. ART. 280. MEDICAMENTO EM DESACORDO COM RECEITA MÉDICA

Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica é delito punido com detenção, de um a três anos, ou multa. Admite o *sursis* processual e o acordo de não persecução penal.

Substância medicinal é o produto destinado a servir como medicamento, para prevenção ou cura de determinada doença.

⁶⁴MASSON, Cleber. Direito Penal. **Parte Especial**. Vol. 3. São Paulo: Gen Método, 2017, p. 369.

⁶⁵CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume Único**. Parte Especial. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 723.

A expressão *em desacordo com receita médica* é elemento normativo do tipo, a ser valorada no caso concreto. Deve haver uma contrariedade ou incongruência com a prescrição do médico.

Não haverá crime no caso de contrariedade à receita emitida por outro profissional da área de saúde, como dentistas, já que o tipo penal trata da receita médica e é vedada a analogia *in malam partem* no direito penal.

E se o medicamento entregue em lugar do prescrito for mais benéfico ao paciente? Ainda assim haverá crime? A doutrina diverge.

Os que defendem a atipicidade o fazem por entender que a saúde pública não foi vulnerada. Por outro lado, a corrente que aponta a incriminação ressalta que não se pode tolerar arbitrariedades na entrega de medicamentos. Prevalece a segunda corrente.

O crime é de perigo abstrato, pois o legislador presume o risco à saúde pública.

Não é necessário que o sujeito ativo seja o farmacêutico, o crime não é próprio. Quanto ao sujeito passivo, trata-se de crime vago.

A consumação ocorre com a entrega do medicamento, sem a observância estrita ao que estava prescrito na receita médica, gerando a presunção absoluta de perigo, independentemente da situação concreta ao paciente. Não se perquire o especial fim de agir. A tentativa é possível.

Não há crime quando se trata da entrega de medicamentos similares ou genéricos, visto que possuem o mesmo princípio ativo. O crime não se caracteriza, pois não se trata de receitar uma marca ou nome comercial, mas sim uma substância.

A modalidade culposa está descrita no parágrafo único. O medicamento é fornecido em desacordo com a receita por negligência, imprudência ou imperícia. Será punida com detenção, de dois meses a um ano.

Incidem as majorantes nos termos dos artigos 285 e 258.

A ação penal é pública incondicionada.

15. ART. 281. COMÉRCIO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA

O dispositivo foi revogado pela Lei nº 6.368/76, a qual foi sucedida pela Lei nº 11.343/06.

16. ART. 282. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA

Nos termos do art. 282, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites é conduta punida com detenção, de seis meses a dois anos. Conforme o parágrafo único, se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. A pena cominada permite a aplicação da Lei nº 9.099/95.

Segundo a CF, a regra é a liberdade ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações que a lei exigir.

O tipo penal pode ser dividido em duas partes.

O exercício da profissão sem autorização legal é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Pode-se exemplificar com o estudante de medicina ou odontologia que, mesmo não concluída a graduação, começa a atender pacientes.

Já o **exercício excedendo os limites legais** é crime próprio, pois o sujeito já é médico, dentista ou farmacêutico, mas excede os limites legais.

Em ambos os casos, o sujeito passivo é a coletividade.

O verbo núcleo do tipo é exercer, exigindo-se a habitualidade atos reiterados, repetidos. Assim, por se tratar de crime habitual, não admite tentativa. Uma única atuação irregular não caracterizará o tipo penal.

O médico, dentista ou farmacêutico que continua exercendo sua profissão, **mesmo após ter sido suspenso por uma decisão judicial**, não incorre no crime ora comentado, mas sim no art. 359 do CP



(desobediência a ordem judicial). Se a desobediência for a uma suspensão administrativa (CRM), incidirá no art. 205 do CP (exercício de atividade com infração de decisão administrativa).

O rol do art. 282 é taxativo, não se estendendo a médicos veterinários, enfermeiros, massagistas ou parteiras. Deve-se atentar para a vedação à analogia *in malam partem* no direito penal.

O crime é formal, pois prescinde de resultado naturalístico, bastando o exercício habitual da profissão de maneira ilegal ou excedendo seus limites para a consumação. Não se perquire especial fim de agir. Se houver intenção de lucro, aplica-se também a pena de multa.

Não haverá crime quanto aos atos praticados em situação de emergência, na falta de profissionais habilitados ou situação de calamidade, já que caracterizado o estado de necessidade com excludente de ilicitude (art. 24 do CP).

A falsificação de diploma universitário para o exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica é absorvida pelo tipo em estudo, pois funciona como crime meio. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção.

Segundo decidiu o STJ, o exercício da acupuntura **não configura** o delito previsto no art. 282 do CP (exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica).

É cediço que o tipo penal descrito no **art. 282 é norma penal em branco** e, por isso, deve ser complementado por lei ou ato normativo em geral, que discrimine e detalhe as atividades exclusivas de médico, dentista ou farmacêutico.

Segundo doutrina, a complementação do art. 282 há de ser buscada na legislação federal que regulamenta as profissões de médico, dentista ou farmacêutico. Dispõem sobre o exercício da medicina a Lei nº 3.268/57, de 20.09.57 e o Decreto nº 20.931, de 11.01.32. Das referidas normas federais, observa-se que não há menção ao exercício da acupuntura.

Assim, o STJ reconheceu que não há regulamentação da prática da acupuntura, sendo da União a competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício das profissões, consoante previsto no art. 22, XVI, da CF (RMS 11.272-RJ, Segunda Turma, DJ 4/6/2001). Assim, ausente complementação da norma penal em branco, o fato é atípico (RHC 66.641-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 3/3/2016, DJe 10/3/2016).

Segundo o art. 285, aplica-se o disposto no art. 258 (causas de aumento de pena).

A ação penal é pública incondicionada.

17. ART. 283. CHARLATANISMO

Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível caracteriza crime, punido com detenção, de três meses a um ano, e multa. É infração de menor potencial ofensivo, sendo cabíveis a transação penal e o *sursis* processual.

O charlatão é o sujeito que sabe que nenhum efeito curativo pode ter o tratamento que inculca ou anuncia. É o sujeito insincero, que divulga terapêutica absolutamente ineficaz. É o estelionatário da medicina, que age com má-fé. O termo advém da expressão italiana *charlare*, que significa falar besteiras, falar à toa, propagar algo que não corresponde à realidade.

O sujeito ativo deve ter a ciência de que o meio que está divulgando é ineficaz. O tipo exige a má-fé. Do contrário, não haverá o dolo que a infração penal exige.

O crime é instantâneo e comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por médico.

É também tipo misto alternativo, que pode ser praticado nas formas de inculcar ou anunciar. Inculcar significa apregoar, sugerir. Anunciar é o mesmo que divulgar, noticiar, o que pode ser feito pelos mais diversos meios.

É importante pontuar a diferença entre o charlatanismo e o exercício ilegal da medicina. No exercício ilegal da medicina (art. 282) existe habitualidade e, em regra, o indivíduo que o pratica não é médico, a não ser na modalidade de excesso aos limites da profissão. O sujeito não é apto para o exercício profissional, não concluiu a faculdade ou possui um saber meramente prático.



No charlatanismo, o agente, que pode ser médico ou não, tem ciência da ineficácia do tratamento que aconselha ou aplica, mas ainda assim o apregoa, em regra para enriquecer valendo-se da aflição alheia.

Há quem sustente a possibilidade de concurso de crimes entre o charlatanismo e o estelionato. Os delitos guardam semelhanças, já que envolvem fraude, mas o charlatanismo não é crime contra o patrimônio, mas sim contra a saúde pública. Se o charlatão obtém vantagem ilícita em proveito próprio ou alheio, incidirá nas duas figuras. Porém, para provas da Defensoria Pública, é preferível adotar o entendimento de que o charlatanismo é absorvido pelo estelionato, quando o agente é movido pelo intuito de lucro.

Não há modalidade culposa do crime.

Aplicam-se as majorantes de pena à forma dolosa, nos moldes dos artigos 285 e 258.

A ação penal é pública incondicionada.

18. ART. 284. CURANDEIRISMO

Exercer o curandeirismo:

I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;

II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;

III - fazendo diagnósticos;

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único - Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, aplicáveis, assim, a transação penal e a suspensão condicional do processo.

O núcleo “exercer” pressupõe habitualidade, reiteração de comportamento, motivo pelo qual é **crime habitual**. Assim, é também incompatível com o *conatus*.

É também crime de forma vinculada, visto que a forma de praticá-lo está descrita nos três incisos.

Qualquer pessoa poderá ser sujeito ativo, não se exige qualidade especial. O sujeito passivo é a coletividade.

O crime é de perigo abstrato ou presumido. Não há necessidade de demonstrar a situação de perigo concreta à saúde pública.

O crime é praticado apenas a título doloso e não se verifica o especial fim de agir.

Os atos inerentes a rituais religiosos, a exemplo de passes e bênçãos, são considerados manifestações de fé e não se encaixam no tipo penal do art. 284.

No curandeirismo, o sujeito não se passa por profissional de saúde. A conduta consiste em promover a cura por métodos sem nenhum embasamento científico.

Ao contrário do charlatão, que é verdadeiro estelionatário da medicina, o curandeiro acredita ser capaz de curar por meio de métodos mágicos ou sobrenaturais.

É possível a incidência de causa de aumento de pena, nos moldes do art. 285.

A ação penal é pública incondicionada.

19. ART. 285. FORMA QUALIFICADA

Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste Capítulo, salvo quanto ao definido no art. 267.

Assim, excetuando-se a epidemia, todos os demais crimes podem ter as penas incrementadas nos moldes do art. 258 do CP, nas formas dolosas ou culposas.



Conforme já ressaltado anteriormente, o aumento da pena se dá na terceira fase da dosimetria, de modo que parte da doutrina considera tecnicamente equivocada a referência a forma qualificada.



CAPÍTULO 59 — DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA

O presente título trata dos crimes que provocam inquietação, desassossego, na comunidade.

São todos crimes obstáculo: incrimina-se de forma autônoma condutas que, em princípio, representariam atos preparatórios de outros delitos. O legislador age de forma antecipada, para preservar a paz pública.

Se a motivação do agente for política, aplica-se a Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83).

1. ART. 286. INCITAÇÃO AO CRIME

Incitar, publicamente, a prática de crime acarreta pena de detenção, de três a seis meses, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, sendo cabível a aplicação dos institutos despenalizantes da Lei nº 9.099/95.

O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade.

Incitar significa induzir, estimular a prática de determinado crime. **Não abrange as contravenções, nem atos imorais.** É preciso que a incitação atinja número indeterminado de pessoas. O termo *publicamente* é elementar do tipo penal.

A consumação ocorre quando a incitação é dirigida à coletividade de indivíduos. Trata-se de **crime formal e de perigo abstrato**. O legislador presume de forma absoluta que esta conduta, por si só, traz gravames à tranquilidade social.

Nota-se, assim, uma exceção à regra prevista no art. 31 do CP, segundo a qual “o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.” Criminaliza-se a instigação à prática de um crime, ainda que não ocorra o resultado naturalístico.

O tipo não exige a efetiva prática do crime incitado. Basta o incentivo público à realização.

Se o instigado praticar o crime, eventualmente o instigador poderá praticar o crime cometido pelo incitado na qualidade de partícipe. Responderá pelo art. 286 do CP também, em concurso formal.

A incitação deve se relacionar a crime específico, determinado. Não se admite a incitação genérica.

Em 2014, ocorreu caso de repercussão nacional envolvendo a prática, em tese, do delito previsto no art. 286 do CP. Naquela época, o então Deputado Federal Jair Bolsonaro, durante uma discussão no plenário da Câmara, afirmou que a também Deputada Federal Maria do Rosário “não merecia ser estuprada”. No dia seguinte, em entrevista concedida em seu gabinete ao jornal Zero Hora, Bolsonaro reiterou as declarações, dizendo que Maria do Rosário “não merece ser estuprada por ser muito ruim, muito feia, não faz meu gênero”. E acrescentou que, se fosse estuprador, “não iria estuprá-la porque ela não merece”.

O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra o parlamentar afirmando que ele, ao fazer essas declarações, teria incitado a prática do crime de estupro (art. 213 do CP), incorrendo, portanto, no delito do art. 286. Além disso, a Deputada ajuizou queixa-crime sob a alegação de que teria sido vítima de injúria (art. 140 do CP).

A defesa argumentou que o parlamentar não cometeu qualquer crime com seu comentário, considerando estar acobertado pela imunidade material prevista no art. 53 da CF/88. Todavia, a denúncia e a queixa-crime foram recebidas pelo STF e estão em fase de instrução.

A imunidade parlamentar material (art. 53 da CF/88) protege os Deputados Federais e Senadores, qualquer que seja o âmbito espacial (local) em que exerçam a liberdade de opinião. No entanto, para isso é necessário que as suas declarações tenham conexão com o desempenho da função legislativa

ou tenham sido proferidas em razão dela. Para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser consideradas como relacionadas ao exercício do mandato, elas devem ter, ainda de forma mínima, um teor político. Palavras e opiniões meramente pessoais, sem relação com o debate democrático de fatos ou ideias não possuem vínculo com o exercício das funções de um parlamentar e, portanto, não estão protegidas pela imunidade material. No caso concreto, as palavras do Deputado Federal dizendo que a parlamentar não merecia ser estuprada porque seria muito feia não são declarações que possuem relação com o exercício do mandato e, por essa razão, não estão amparadas pela imunidade material. (STF. 1ª Turma. Inq 3932/DF e Pet 5243/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/6/2016. Informativo 831).

Vale ressaltar que ainda não há condenação. As ações penais estão em curso no STF, em fase de instrução (AP 1007 e 1008).

Importante destacar, ainda, que o STF não se manifestou sobre um dos argumentos do denunciado, qual seja, o de que ele teria apenas se defendido de prévias agressões verbais praticadas pela Deputada (retorsão imediata ou reação a injusta provocação). A Corte afirmou que essa alegação somente será apreciada ao final do processo, após a instrução.

2. ART. 287. APOLOGIA DE CRIME OU CRIMINOSO

Nos termos do art. 287, fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime é conduta punida com detenção, de três a seis meses, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

Fazer apologia significa elogiar, enaltecer, louvar, exaltar de forma pública.

Não abrange as contravenções penais, nem atos imorais. A ideia é que nenhum ato criminoso ou pessoa condenada seja exaltado ou enaltificado, a fim de incitar a prática de delitos. Entende-se que nenhum crime, ou seu autor, possam ser publicamente elogiados.

O crime elogiado deve ser um fato passado. Se fato futuro, há quem sustente haver incitação ao crime (art. 286).

É indiferente se a pessoa envolvida no crime é autora, coautora ou partícipe. Além disso, não precisa ter sido condenada ou mesmo denunciada.

A apologia deve ser pública, de modo a alcançar número indeterminado de pessoas.

É importante diferenciar a incitação ao crime da apologia de crime ou criminoso.

Na incitação, há estímulo claro e direto à prática de crime determinado. Em regra, refere-se a atos futuros. Na apologia, o estímulo é indireto, por meio do elogio a um crime ou criminoso.

O crime é comum e o sujeito passivo é a coletividade.

O elemento subjetivo é dolo, prescindindo-se de qualquer finalidade específica. Não se admite a modalidade culposa.

O delito é também classificado como formal e de perigo abstrato (não é necessária a prova de que houve, de fato, perturbação da ordem pública).

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 288. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Segundo o art. 288, associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes é conduta apenada com reclusão, de 1 a 3 anos. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

A redação atual do dispositivo foi dada pela Lei nº 12.850/2013, conhecida como Lei das Organizações Criminosas, a qual promoveu modificações no Código Penal e alterou o tipo da associação criminosa, que antes era chamada de quadrilha (área urbana) ou bando (área rural). Essa dicotomia deixou de existir e o número de integrantes para a caracterização da associação criminosa passou a ser menor (três).



Conforme dispõe o parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é **armada ou se houver a participação de criança ou adolescente**. Dessa maneira, não se imputa o art. 244-B do ECA em concurso, já que há uma causa de aumento específica quando a associação criminosa também é composta por criança ou adolescente, sob pena de *bis in idem*.

O tipo penal tutela a paz pública. O crime é comum e vago (coletividade como sujeito passivo).

Além disso, o crime é plurissubjetivo ou de concurso necessário. Se não há a reunião de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crime, não haverá a perfeita adequação típica. Em regra, há um líder ou chefe, cuja existência não é indispensável. Os integrantes não precisam se conhecer todos mutuamente, assim como não precisam se reunir fisicamente. Para o acordo, pode haver qualquer tipo de comunicação, inclusive por intermediários. Atualmente, as maiores interações se dão por meio de aparelho celular, aplicativos de conversas, pelas mais variadas formas que não exigem contato pessoal.

Incluem-se no número de três os inimputáveis (qualquer causa de inimizabilidade) ou os agentes ainda não identificados. Basta que apenas um dos integrantes seja maior de 18 anos e imputável. Se um dos três é inimputável, o tipo é majorado, nos termos do parágrafo único (participação de criança ou adolescente).

A modificação legislativa revelou-se mais gravosa (*novatio legis in pejus*): bastam três pessoas para a caracterização da associação criminosa, enquanto para a quadrilha ou bando eram necessários ao menos quatro indivíduos.

O verbo núcleo do tipo é associar. Significa reunir-se para o fim específico de cometer crimes. **Não abrange contravenções penais. Os crimes devem ser dolosos.**

O vínculo associativo deve ser **estável e permanente** característica que o diferencia do concurso de agentes. Tem-se um ajuste duradouro para a prática de crimes indeterminados, de igual natureza ou não.

Ausente a estabilidade e a permanência não há que se falar em caracterização do crime de associação criminosa, mas sim em concurso de agentes.

O crime é também classificado como formal, consumando-se com a associação estável e permanente, ainda que nenhum delito seja efetivamente praticado.

Não é necessária organização definida, hierarquia entre os membros ou repartição de funções. Em relação à organização criminosa, prevista na legislação especial, a associação criminosa do art. 288 tem estrutura mais rudimentar, menos elaborada.

O crime é de perigo abstrato, isto é, a simples associação dos indivíduos já abala a paz social, ainda que nenhum crime seja praticado por este grupo. É também delito permanente, pois a consumação se prolonga no tempo. É possível a prisão em flagrante a qualquer momento.

Conforme já ressaltado, é um exemplo de crime obstáculo. Incrimina-se, de forma autônoma, atos representativos da preparação de outros delitos.

É incompatível com a tentativa (*conatus*). Não é possível fracionar o *iter criminis*. Presentes a estabilidade e a permanência, o crime estará consumado. Caso contrário, a conduta será atípica.

O delito é autônomo, pois prescinde de crime anterior ou posterior. A associação criminosa, antiga quadrilha, pode ser punida de forma autônoma, não sendo preciso que haja denúncia também pelo crimes que foram eventualmente praticados pelo grupo, planejados ou tentados.

Se o fim da associação é a prática de crimes hediondos e equiparados, aplica-se o art. 8º da Lei nº 8.072/90.⁶⁶

⁶⁶Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.



A regra é a competência da Justiça Estadual. Exemplos de competência da Justiça Federal: associação criminosa para a prática de peculato contra a Previdência Social ou grupo que se vale da utilização de documentos falsos para a supressão de tributos federais

Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, na denúncia, é possível a descrição genérica das condutas praticadas individualmente por cada integrante, bastando a demonstração do vínculo associativo de pelo menos três pessoas. Não é preciso que a descrição do que cada um faz no âmbito da associação criminosa seja pormenorizada.

Importa distinguir a associação criminosa da organização criminosa (Lei nº 12.850/13).

A organização necessita do número mínimo de quatro pessoas. A estrutura é mais sofisticada. Destina-se à prática de infrações graves, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional. São verdadeiras estruturas ilícitas de poder, que seguem um modelo empresarial de gestão. São extremamente organizadas, com diferentes setores, repartições de funções, hierarquia claramente estabelecida, de maneira que esse modelo torna as organizações criminosas difíceis de serem investigadas e desbaratadas, porque o nível de organização é bastante elaborado. Exemplos: facções criminosas como PCC e Comando Vermelho.

Por sua vez, a associação criminosa contenta-se com uma organização rudimentar. Não é preciso que haja a figura do líder ou chefe, a repartição fixa e determinada de funções, a hierarquia é flexibilizada e se exige um número de participantes menor, já que se contenta com três pessoas.

A associação para o tráfico de drogas é tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Não é crime hediondo. Exige-se apenas duas pessoas para a caracterização.⁶⁷

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 288-A. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA

Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código acarreta pena de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.

Qualquer pessoa poderá praticar o crime (comum). É plurissubjetivo ou de concurso necessário, de condutas paralelas (os sujeitos se auxiliam mutuamente, com objetivo comum).

O texto legal é silente quanto ao número mínimo de pessoas que devem figurar no grupo criminoso, havendo duas correntes. A primeira, no sentido de que se aplica o art. 288, exigindo-se três ou mais pessoas. Já para os adeptos da segunda corrente, o número mínimo de integrantes deve ser o mesmo previsto na Lei nº 12.850/13, ou seja, quatro indivíduos. Prevalece o entendimento de que bastam três pessoas para a caracterização do tipo do art. 288-A, pois a técnica legislativa adotada no CP é no sentido de explicitar o número de pessoas diferente de três.

Parcela da doutrina questiona a constitucionalidade do tipo penal, por ser extremamente aberto, não contendo as definições do que sejam organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, gerando, assim, insegurança jurídica e violando o princípio da taxatividade da lei penal.

Ademais, as condutas já estavam tuteladas por outros dispositivos legais, tal qual o art. 288e a Lei nº 12.850/13.

A doutrina conceitua a **organização paramilitar** como aquela desvinculada do Estado, armada e com estrutura semelhante às organizações militares. Utiliza táticas e técnicas militares e policiais, de **forma clandestina**, com motivação ilícita. Tal tipo de agrupamento é vedado pela CF (art. 5º, XVII, CF), tendo em vista o monopólio do Estado quanto ao uso do poder coercitivo.

⁶⁷Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.



A **milícia particular**, por sua vez, corresponde ao grupo de civis ou militares fora da função, armado, com pretensa função de restaurar a ordem e a segurança em comunidades dominadas pela criminalidade, em face da ineficiência do Poder Público. Ocorre, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Verdadeiro poder paralelo exercido onde o Estado não alcança, e que inclusive coage para a colaboração financeira, mediante violência e ameaça.

Grupo e esquadrão são agrupamentos de extermínio, matadores, que buscam eliminar pessoas rotuladas como nocivas, inconvenientes ou perigosas. São justiceiros que aplicam penas ao seu bel prazer e senso próprio de justiça.

O tipo é misto alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado, já que previstos os verbos constituir, organizar, integrar, manter ou custear. A prática de mais de uma conduta, no mesmo contexto fático, enseja crime único.

A união deve ser estável e permanente. Se assim não for, a hipótese será de concurso de pessoas. O crime de milícia privada se consuma no momento em que é constituída a associação, ou seja, no momento de convergência dos indivíduos para formar a associação. É, assim, um crime formal e de perigo abstrato.

Tem por característica ser crime é permanente, visto que a consumação se protraí no tempo, e independe da prática de qualquer infração penal.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 60 — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

A fé pública consiste na crença ou convicção geral na autenticidade e valor dos documentos e atos prescritos para as relações coletivas.⁶⁸

Os delitos previstos neste título são chamados de crimes de falso, embora existam outros crimes dessa natureza no CP. Observa-se que lesam os interesses patrimoniais dos indivíduos, o interesse público na segurança das relações jurídicas, o privilégio monetário do Estado e os meios de prova.

São requisitos dos crimes de falso: o dolo (não há crime de falso culposos), a imitação da verdade (pode ser na forma de alteração, não necessariamente uma cópia), e o dano potencial (não precisa ser efetivo, nem patrimonial; deve ser idôneo a ludibriar).

Os crimes podem apresentar três espécies de falsidade: material, ideológica ou pessoal.

A falsidade material (ou externa) é aquela que incide materialmente sobre a coisa. Apresenta-se como contrafação (falsificação, criação de documento falso), alteração (inserção de palavras em um contrato) ou supressão (retirada de informações de um documento). Exemplos: artigos 297 e 298 do CP (falsificação de documento público e particular), a fabricação de uma CNH em casa.

Já na **falsidade ideológica** temos um documento verdadeiro, mas com conteúdo falso. Não há veracidade intelectual. Ocorre uma simulação. Exemplo: indivíduo casado se declara solteiro perante o tabelião ao lavrar uma escritura. Está presente nos artigos 299, 300 e 301 do CP.

Por sua vez, a **falsidade pessoal** relaciona-se à qualificação da pessoa física, à identidade civil. O sujeito atribui-se dados falsos, conforme se vê nas condutas descritas nos artigos 307 a 309 do CP. Exemplo: pessoa que se apresenta nome falso perante a autoridade policial para ocultar antecedentes criminais ou mandado de prisão em aberto contra si.

1. ART. 289. MOEDA FALSA

Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro é crime punido com reclusão, de três a doze anos, e multa. É possível o acordo de não persecução penal, nos moldes do art. 28-A do CPP.

A proteção penal dirige-se à confiança no sistema de emissão e circulação da moeda. O objeto material do crime é a moeda metálica ou o papel-moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro.

O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa (crime comum), salvo no caso do §3º. O sujeito passivo é a coletividade (crime vago).

A falsificação deve ser idônea, bem feita, com aptidão para enganar (*imitatio veri*). Ou seja, deve ser convincente. A falsificação grosseira poderá configurar o crime de estelionato, conforme Súmula 73 do STJ: *“A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual.”*

Entende a jurisprudência pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime em tela, sendo irrelevante o número de cédulas, seu valor ou o número de pessoas eventualmente lesadas. Segundo o STF, a fé pública é bem intangível e que corresponde à confiança que a população deposita em sua moeda, não se tratando, assim, da simples análise do valor material nela representado.⁶⁹

O crime é formal, consumando-se no momento da contrafação, independentemente da circulação da moeda falsa. Não exige, tampouco, dano a terceiro. Os eventuais prejuízos a terceiros podem ser considerados na dosimetria. Admite-se a tentativa.

Como se trata de crime transeunte, que deixa vestígios, exige-se a prova pericial como prova da materialidade delitiva (art. 158 CPP).

⁶⁸ MASSON, Cleber. Direito Penal. **Parte Especial**. Vol. 3. São Paulo: Gen Método, 2017, p. 447.

⁶⁹ HC 96153/MG, Informativo 548.



O § 1º estabelece que nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Trata-se de tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado, já que diferentes verbos que podem caracterizar a conduta criminosa. O delito é formal e de perigo, consumando-se independentemente da obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros, assim como a figura do *caput*.

No § 2º, por sua vez, prevê: quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Cuida-se da forma privilegiada, infração de menor potencial ofensivo.

Segundo o STJ, a diferenciação no apenamento para as modalidades dos §§ 1º e 2º não ofende o princípio da proporcionalidade.

A figura do §2º é substancialmente menos grave, porque nessa situação, o indivíduo, por exemplo, um comerciante, recebe de boa-fé a moeda falsa, em pagamento de um produto ou serviço. Ao constatar a falsidade, para não ficar no prejuízo, introduz de volta à circulação a moeda recebida. Com efeito, a intenção do agente não é lesar a fé pública, mas simplesmente evitar o desfalque econômico.

Nos termos do § 3º, é punido com reclusão, de três a quinze anos, e multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II - de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

A conduta do § 3º, chamada de falsificação funcional, é crime próprio, uma vez que exige qualidade especial do sujeito ativo. É também mais grave, considerando as funções exercidas pelos indivíduos descritos.

Por fim, no § 4º, tem-se que nas mesmas penas do § 3º incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada. Nessa hipótese, autorizou-se apenas a emissão da moeda, mas não a sua circulação, a qual depende do estudo de diversos fatores. O crime é comum.

A competência para processar e julgar o crime de moeda falsa é da Justiça Federal e a ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 290. CRIMES ASSIMILADOS AO DE MOEDA FALSA

Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros; suprimir, em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização; restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização é delito punido com reclusão, de dois a oito anos, e multa. Nos termos do parágrafo único, o máximo da reclusão é elevado a doze anos e multa, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo. Admite-se o acordo de não persecução penal, conforme o art. 28-A do CPP.

São três as condutas delituosas previstas, relacionadas ao papel-moeda, que consistem em fraudes para a revalidação de cédulas já imprestáveis ou recolhidas para inutilização.

O crime é comum, salvo no caso do parágrafo único, em que a pena máxima do crime é elevada por ter sido cometido por funcionário público que trabalha na repartição. O sujeito passivo é a coletividade.

A falsificação deve ser bem feita, convincente, pois se for grosseira poderá haver o crime de estelionato, conforme Súmula 73 do STJ.

A consumação ocorre no momento em que a cédula é formada, segundo os primeiros dois núcleos, ou no momento em que ela é restituída à circulação. Não se exige dano ou prejuízo.

Ação penal é pública incondicionada. A competência é da Justiça Federal.



3. ART. 291. PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA

Nos termos do art. 291, é crime fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. A pena é de reclusão, de dois a seis anos, e multa.

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo é o Estado, pois é quem produz as moedas.

O tipo é misto alternativo. A prática de mais de um dos verbos no mesmo contexto fático enseja crime único.

Segundo o STJ, para a tipificação do crime do art. 291 do CP basta que o agente detenha a posse de petrechos destinados à falsificação de moeda, sendo prescindível que o maquinário seja de uso exclusivo para esse fim. Entendeu a Corte que a expressão “especialmente destinado” não diz respeito a uma característica intrínseca ou inerente do objeto. Se assim fosse, só o maquinário exclusivamente voltado para a fabricação ou falsificação de moedas consubstanciaria o crime, o que implicaria a absoluta inviabilidade de sua consumação (crime impossível), pois nem mesmo o maquinário e insumos utilizados pela Casa de Moeda são direcionados exclusivamente para a fabricação de moeda. A dicção legal está relacionada ao uso que o agente pretende dar ao objeto, ou seja, a consumação depende da análise do elemento subjetivo do tipo (dolo), de modo que, se o agente detém a posse de impressora, ainda que manufaturada visando ao uso doméstico, mas com o propósito de a utilizar precipuamente para contrafação de moeda, incorre no referido crime. (STJ. 6ª Turma. REsp 1.758.958-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/09/2018. Informativo 633).

Se uma pessoa é surpreendida com os petrechos para falsificação, mas a moeda falsa já foi elaborada, o crime em estudo restará absorvido pela figura do art. 289.

Ação penal é pública incondicionada. A competência é da Justiça Federal.

4. ART. 292. EMISSÃO DE TÍTULO AO PORTADOR SEM PERMISSÃO LEGAL

Segundo o art. 292, emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago é delito punido com detenção, de um a seis meses, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

O tipo penal tutela da fé pública, no que tange à confiança da população na emissão do título ao portador.

Títulos de crédito são aqueles definidos no art. 887 do Código Civil. A hipótese é, assim, de norma penal em branco homogênea, que necessita de complemento legislativo, com o fim de saber quais títulos podem circular ao portador ou sem indicação da pessoa a quem deva ser pago. É necessário conhecer quais títulos podem ser emitidos nessa condição.

Emitir significa colocar em circulação.

O elemento subjetivo é dolo, não reclamando finalidade específica. Não se admite a forma culposa.

O crime é formal. Dispensa resultado naturalístico e que seja causado prejuízo efetivo.

Nos termos do parágrafo único, quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção, de quinze dias a três meses, ou multa. Trata-se da forma privilegiada.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 293. FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS

Dispõe o art. 293:

Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:



- I – selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;
 - II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;
 - III - vale postal; (*revogado pelo art. 36 da Lei 6538/78; que dispõe sobre os serviços postais*)
 - IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;
 - V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;
 - VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município;
- Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

A hipótese contempla a falsidade material.

O inciso III não tem aplicação, pois foi revogado pelo art. 36 da Lei nº 6.538/78, que dispõe sobre os serviços postais. É uma lei posterior ao Código Penal, que prevalece em homenagem ao princípio da especialidade.

O bem jurídico tutelado é a fé pública, confiança e legitimidade dos papéis públicos, com especial relevância no âmbito social, para as negociações e atividades relacionadas à arrecadação do Estado.

O verbo núcleo do tipo é falsificar, isto é, reproduzir, imitar ou modificar. Cria-se um papel público ou modifica-se um verdadeiro.

Tem-se um crime comum ou geral, que pode ser praticado por qualquer pessoa, não se exigindo nenhuma característica especial do sujeito ativo. Vale notar que o art. 295 prevê causa de aumento de pena de 1/6 na hipótese do crime ser praticado por funcionário público que se vale de sua condição. O sujeito passivo é o Estado.

Na hipótese de falsificação grosseira, isto é, sem idoneidade para enganar, sendo perceptível por qualquer indivíduo, a conduta torna-se atípica, incapaz de lesionar a fé pública (crime impossível, art. 17 do CP).

O rol dos papéis públicos é taxativo.

O crime é formal, pois a falsificação já expõe o bem jurídico tutelado a perigo, não sendo necessário que o documento alcance a finalidade pretendida pelo agente. Consuma-se independentemente de resultado naturalístico.

O § 1º estabelece a figura equiparada:

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

- I – usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este *artigo*;
- II – importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;
- III – importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria:
 - a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;
 - b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. (norma penal em branco homogênea)

No caso do inciso I, o sujeito ativo é diverso do falsário, isto é, daquele que falsificou o papel. Se o falsário, além de produzir, também usa o documento, caracteriza-se o *post factum* impunível. Havendo o desdobramento, não haverá a punição pelos dois crimes. Ocorrerá a consunção e o falsário responderá nos termos do caput.

No inciso III verifica-se um especial fim de agir. Não basta o dolo, pois o indivíduo deve utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. O crime é próprio, já que só pode ser praticado por aquele que está no exercício comercial ou



industrial. A alínea b é norma penal em branco homogênea, na medida em que é necessário recorrer a complemento legislativo para perquirir quais são os produtos e mercadorias cujo selo oficial é obrigatório.

No § 2º incrimina-se a conduta de suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. A pena é de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Deve haver uma alteração material no documento para esconder o carimbo ou sinal de que o papel estava inutilizado. O especial fim de agir consiste em tornar os papéis novamente utilizáveis. O crime é de médio potencial ofensivo, cabível a suspensão condicional do processo (*sursis processual*).

Por sua vez, o § 3º estabelece que incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Embora não seja o falsário, quem utiliza o documento alterado também incidirá nas mesmas penas.

Não é possível incidir nas figuras dos §§ 2º e 3º simultaneamente. Aplica-se, portanto, a consunção. Se aquele que suprime é também aquele que usa, a conduta de quem usa será absorvida pelo fato de ter também suprimido o carimbo ou sinal do papel.

Nos moldes do § 4º, quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Trata-se da figura privilegiada, semelhante à previsão que consta do art. 289. O indivíduo, de boa-fé, recebe o papel falsificado e, para não ficar no prejuízo, põe o documento em circulação. Pelo fato de agir com menor reprovabilidade, o legislador comina pena de detenção. É crime de menor potencial ofensivo, da competência dos Juizados Especiais.

O § 5º diz equiparar-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Trata-se de norma penal explicativa.

Quando se tratar de falsificação ou alteração de nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo a operação tributável, o crime será aquele descrito no art. 1º, inc. III, da Lei nº 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária). A lei especial prevalece sobre norma geral. O crime contra a ordem tributária é material, de maneira que para a sua consumação é necessária a supressão ou redução do tributo. Portanto, diferente dos crimes contra a fé pública, no qual basta a falsificação do papel para a consumação, ainda que nenhum resultado naturalístico seja atingido.

A competência, em regra, é da Justiça Estadual, salvo se a emissão do papel incumbir à União, suas empresas públicas ou autarquias (art. 109, IV, CF).

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 294. PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO

Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior é delito punido com reclusão, de um a três anos, e multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Qualquer pessoa pode cometer o crime. O sujeito passivo é a coletividade e o Estado.

Segundo entendimento jurisprudencial, se o sujeito tem os objetos para falsificação e efetivamente falsifica, responderá apenas pelo delito do art. 293, ficando o art. 294 absorvido. A hipótese é de consunção.

O tipo incrimina atos preparatórios. Por isso, é chamado de crime obstáculo. É também misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado (cinco núcleos distintos). No mesmo contexto fático, a prática de mais de um dos verbos tipifica crime único.

O crime é formal, pois independe de resultado naturalístico para a consumação. Não há previsão de forma culposa.



Nas modalidades “possuir” e “guardar” o crime é permanente, ou seja, a consumação se prolonga o tempo.

Trata-se, ainda, de crime não transeunte, pois deixa vestígios.

A ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 295. FORMA MAJORADA

Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

A disposição se aplica aos artigos 293 e 294. Para a incidência da causa especial de aumento de pena, é indispensável que o funcionário público se valha das facilidades proporcionadas pelo cargo.



CAPÍTULO 61 — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA: DA FALSIDADE DOCUMENTAL

1. ART. 296. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO

Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Selo e sinal público não são propriamente documentos, mas sim objetos cuja utilidade é conferir autenticação, origem ou legitimidade a um documento e somente após a sua utilização é que passam a integrá-lo.

Não se confundem com selo destinado a controle tributário ou à arrecadação de tributos. Este tipo penal trata de selos identificadores de origem, de legitimidade, relacionados às funções, aos órgãos da Administração Pública.

Não há referência no tipo penal ao Distrito Federal, visto que o Código Penal é anterior à criação do DF. Considerando a omissão legislativa e a taxatividade da lei penal, é inviável a analogia *in malam partem*.

O crime é comum, não se exigindo qualidade específica do sujeito ativo. Se o agente é funcionário público e pratica o delito valendo-se das facilidades proporcionadas pelo cargo, a pena será aumentada de um sexto na terceira fase da dosimetria, nos termos do § 2º. O sujeito passivo é o Estado, de forma imediata, e a pessoa física ou jurídica prejudicada, mediamente.

A consumação se dá no momento em que o indivíduo pratica qualquer das condutas descritas, sendo dispensada a ocorrência do dano, motivo pelo qual se trata de crime formal ou de resultado cortado. A tentativa é possível.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 297. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro é crime apenado com reclusão, de dois a seis anos, e multa. Admite-se o acordo de não persecução penal.

O tipo contempla a falsidade material, vez que a forma, o aspecto exterior do documento é alterada, total ou parcialmente.

Documento, para fins penais, é conceituado como o escrito elaborado por pessoa determinada, representativo de uma declaração de vontade ou da existência de fato, direito ou obrigação, dotado de relevância jurídica e com eficácia probatória.

Documento público, por sua vez, é aquele criado por funcionário público, nacional ou estrangeiro, no desempenho de suas atividades, em conformidade com as formalidades previstas em lei

A cópia autenticada de documento particular extraída por tabelião não é documento público.



O crime é comum. Se o agente é funcionário público, o § 1º prevê causa de aumento de pena de sexta parte. O sujeito passivo é o Estado.

O § 2º traz o rol dos documentos públicos por equiparação. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

Os verbos núcleos do tipo são falsificar e alterar.

Falsificar significa fabricar um documento até então inexistente. É a contrafação. Pode ser total ou parcial. O documento nasce por ação do falsário.

Alterar consiste em modificar um documento já existente e verdadeiro. Exemplo: mudar a data de validade de um passaporte verdadeiro.

A falsificação grosseira, sem potencialidade lesiva, sem idoneidade para ludibriar, torna atípica a conduta, diante da caracterização do crime impossível (art. 17 do CP).

O crime é formal ou de consumação antecipada: não há necessidade de resultado naturalístico, nem que o documento seja utilizado. É também crime instantâneo e não-transeunte, pois deixa vestígios materiais. Mostra-se indispensável o exame pericial de corpo de delito (exame documentoscópico), direto ou indireto, para se verificar se o documento foi de fato forjado, alterado, nos moldes do art. 158 do CPP.

Em regra, a competência será da Justiça Estadual, porém será da Justiça Federal em caso de documentos emitidos por órgãos federais, como na hipótese do passaporte (emitido pela Polícia Federal).

Importante ressaltar que o critério para a fixação da competência é definido pela autoridade que emite o documento, não importando a autoridade a quem foi o documento apresentado. Para o crime de falsificação de CNH, a competência será da Justiça Estadual. Nos termos da Súmula 62 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, atribuído a empresa privada. Conforme a Súmula 104, também do STJ, compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.

No § 3º é prevista a figura equiparada. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:

I – na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;

II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III – em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

Nota-se que o §3º faz uma ampliação do rol dos documentos públicos por equiparação, apresentando situações que envolvem, em especial, a Previdência Social.

Os núcleos do tipo são inserir (colocar, introduzir) e fazer inserir (criar condições para que terceiro introduza ou coloque). Dessa forma, tem-se um documento verdadeiro, mas a informação nele inserida é falsa.

Logo, conclui-se que a hipótese é de falsidade ideológica, de inverdade intelectual, inserida de forma tecnicamente inadequada em dispositivo que trata de falsidade material.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 298. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro é crime punido com reclusão, de um a cinco anos, e multa. No parágrafo único, consta que, para fins do disposto no *caput*, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. A pena cominada admite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.



A diferença em relação ao tipo do art. 297 reside na natureza do documento, que é particular, e na pena menor cominada em abstrato.

O conceito de documento particular para fins penais é obtido por exclusão. O que não é público será particular, inclusive o documento público nulo.

No mais, o tipo reúne as mesmas características do art. 297, a saber: não admite forma culposa, é comum, o sujeito passivo é o Estado, formal, não –transeunte e, por isso, é necessário o exame pericial para a comprovação da materialidade e da potencialidade lesiva.

A falsificação grosseira torna a conduta atípica (crime impossível).

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 299. FALSIDADE IDEOLÓGICA

Segundo o art. 299, omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante é conduta punida com reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Nos termos do parágrafo único, se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Na figura do *caput*, é permitida a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal é admitido tanto para o *caput* quanto para o parágrafo único.

A falsidade ora tratada é a ideológica ou intelectual. O documento é **formalmente verdadeiro**, mas seu conteúdo é divergente da realidade. É também chamado de **falso moral ou falso ideal**.

O objeto material é o documento público ou particular. Quando o documento é público, pelo preceito secundário, a pena é maior.

Os verbos núcleos do tipo são **omitir, inserir e fazer inserir**.

Omitir significa um não fazer. O crime é omissivo próprio ou puro. A lei já descreve um deixar de fazer. Exemplo: deixar de mencionar um gravame em contrato de compra e venda de imóvel.

Inserir é a conduta do próprio agente que introduz, coloca, uma ideia ou informação falsa no documento.

Por sua vez, fazer inserir consiste em criar as condições para que terceiros introduzam as informações falsas.

Nos dois últimos casos, as condutas são comissivas, pois demandam o agir, o fazer.

A declaração falsa de insuficiência de recursos feita em processo judicial para fins de obtenção do benefício da gratuidade da justiça (art. 98 CPC) tipifica o crime?

Para os Tribunais Superiores, não há tipicidade penal, pois a declaração passível de averiguação posterior não constitui documento para fins penais. O pedido pode ser impugnado, inclusive, pela parte adversa.

As petições em geral, em processos administrativos ou judiciais, não se amoldam ao conceito de documento para fins penais. Assim, não há falsidade ideológica com a inserção e dados inverídicos em pedido judicial, pois as alegações serão debatidas em juízo.

E na hipótese do papel assinado em branco e cujo conteúdo é preenchido por terceiro, contra a vontade de quem o assinou? O terceiro pratica falsidade ideológica? Se o papel chegou às mãos do terceiro de forma legítima, tem-se a falsidade ideológica. Se, todavia, o papel foi obtido de forma ilícita (furto, roubo), o crime será de falsificação de documento (art. 297 ou 298, conforme se trate de documento público ou particular). Exemplo: cheque em branco preenchido por terceiro contra a vontade do titular com o fim de prejudicar, de provocar lesão patrimonial. Se o cheque chega às mãos do terceiro



de forma legítima, restará configurada a falsidade ideológica. Se, por outro lado, o papel foi obtido de forma ilícita, por furto ou roubo, o crime será o de falsificação em decorrência da contrafação, isto é, o sujeito produz materialmente algo que não corresponde à realidade.

O crime é formal, consumando-se com a prática da ação ou da omissão, dispensando resultado naturalístico. Na forma omissiva, não admite tentativa.

Para fins de fixação de competência, leva-se em conta o local da falsificação, sendo indiferente o lugar onde se produziu o resultado.

O delito não deixa vestígios materiais, vez que o documento é materialmente verdadeiro. A perícia é desnecessária. A falsidade intelectual será comprovada por outros meios de prova.

Conforme se observa da leitura do parágrafo único, há majorante de pena de um sexto quando o crime é cometido por funcionário público, prevalecendo-se da função e também na hipótese da falsificação ou alteração recair sobre assentamento de registro civil. Nesse último caso, tutela-se os direitos da personalidade, alguns indisponíveis, como o estado de filiação.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 300. FALSO RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA

Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja é crime punido com reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Trata-se de crime de médio potencial ofensivo, com possibilidade de suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal.

No presente caso, apresenta-se um tipo especial de falsidade ideológica, praticado no exercício da função pública de autenticação de documentos públicos e privados. É o falso intelectual praticado pelo funcionário público no desempenho da função.

O verbo núcleo do tipo é reconhecer, isto é, afirmar que pertence a determinada pessoa firma ou letra que não corresponde, em verdade. A falsidade está relacionada à assinatura ou letra e não ao teor do documento.

Tem-se um crime próprio, que somente pode ser cometido pelo servidor dotado de fé pública, como os tabeliães e agentes consulares. O local da prática do crime, se dentro ou fora da repartição pública, é irrelevante.

Na hipótese em que o reconhecimento é feito por particular, que se passa por tabelião, falsificando a assinatura do agente público, o crime será o do art. 297 ou 298 (falsificação de documento público ou particular).

Quando aquele que falsifica também submete o documento à autenticação e o funcionário público tem conhecimento da falsidade, o particular pratica o art. 297 ou 298 e o funcionário público o art. 300.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não se admite a modalidade culposa.

O crime é formal, isto é, a consumação independe de dano eventualmente causado pelo falso reconhecimento de firma ou letra.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 301. CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE FALSO

Segundo o art. 301, é crime atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. A pena é de detenção, de dois meses a um ano. É uma infração de menor potencial ofensivo, sendo cabíveis os institutos despenalizantes da Lei nº 9.099/95.

Atestado é o documento que traz em si o testemunho de um fato ou circunstância da qual o signatário tem conhecimento pessoal.



Já na **certidão**, o funcionário, no exercício de suas atribuições, afirma a verdade de um fato ou circunstância contida em documento público, ou seja, o signatário não tem conhecimento pessoal.

Trata-se, assim, de uma modalidade especial de falsidade ideológica.

A expressão **ou qualquer outra vantagem** deve ser interpretada de maneira restritiva, considerando-se a natureza pública do proveito.

Exemplo de conduta que se amolda ao tipo do art. 301 é a emissão de certidão de antecedentes criminais negativa em favor de sujeito reincidente.

O crime é próprio, somente pode ser praticado por quem ocupa função pública. Porém, não se exige que esteja no exercício. Basta que se valha das facilidades proporcionadas pelo cargo.

A expressão **falsamente** é elemento normativo do tipo, que vai comportar interpretação pelo magistrado no caso concreto.

Para fins de tipificação da conduta, o atestado ou certidão devem ser **originários**.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não se admite a forma culposa, por ausência de previsão legal.

Ademais, trata-se de crime formal, isto é, não depende do resultado naturalístico para a sua consumação, que se dá de forma antecipada.

No § 1º, diferentemente do *caput*, pune-se a **falsidade material** de atestado ou certidão. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem é crime apenado com detenção, de três meses a dois anos. É um delito autônomo, considerado comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. A falsidade tratada é material.

Por fim, no § 2º, se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.

A ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 302. FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO

Nos termos do art. 302, dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso acarreta pena de detenção, de um mês a um ano. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa, conforme previsão do parágrafo único. Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo, que atrai a aplicação da Lei nº 9.099/95.

O verbo núcleo do tipo é dar, que corresponde a fornecer, entregar ou produzir. Não é relevante a finalidade do atestado. A conduta é criminalizada em razão de se atestar um fato não correspondente à realidade. As informações podem ser total ou parcialmente falsas. Exemplo: médico que atesta que alguém em perfeita saúde encontra-se doente.

Quando o atestado falso destina-se à prática de outro crime mais grave, como o estelionato, o falso restará absorvido.

O crime é próprio ou especial, pois somente o médico pode praticá-lo. Não se admite interpretação ampliativa. Portanto, o tipo não abrange dentistas, psicólogos, fisioterapeutas. Nos casos de profissionais outros, haverá falsidade ideológica, nos termos do art. 299, o qual, inclusive, tem pena mais elevada.

O crime em estudo admite coautoria e participação.

O beneficiário do atestado falso que o utiliza, ciente da sua origem, comete o crime do art. 304 do CP (uso de documento falso).

O delito é formal ou de consumação antecipada: o crime se consuma no momento em que o atestado falso é entregue, independentemente de utilização posterior ou da finalidade do uso ou das consequências posteriores.

Vale observar que os crimes contra a fé pública são todos, como regra, formais, não sendo necessário o resultado naturalístico para a consumação, pois a conduta já expõe o bem jurídico a perigo.

Se o médico é servidor público e solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem para emitir o atestado falso, o crime será o de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CP.

O delito somente é praticado na forma dolosa. Não há crime se houve um equívoco quanto ao diagnóstico, pois não se pune a forma culposa. **Exemplo:** se o médico atesta uma doença por erro de diagnóstico, por culpa, a conduta é atípica.

A ação penal é pública incondicionada.

8. ART. 303. REPRODUÇÃO OU ADULTERAÇÃO DE SELO OU PEÇA FILATÉLICA

O dispositivo foi revogado tacitamente pelo art. 39 da Lei nº 6.538/78, lei específica, posterior ao Código Penal, que trata dos serviços postais.

9. ART. 304. USO DE DOCUMENTO FALSO

Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302 acarreta a mesma pena cominada à falsificação ou à alteração.

Observa-se um crime ou tipo remetido, já que a descrição remete aos artigos 297 a 302. Para tipificar corretamente o uso de documento falso deve-se recorrer, necessariamente às condutas mencionadas.

O crime de uso poderá, assim, ser de menor, médio ou elevado potencial ofensivo, a depender da natureza do documento falsificado.

A pena do usuário do documento falso é idêntica à pena do falsário. Ambas as condutas são consideradas igualmente graves e, por isso, merecem a mesma reprimenda.

Tem-se, ainda, exemplo de crime parasitário, de fusão ou acessório: exige-se a prática de crime anterior, não existindo de forma autônoma. A conduta do usuário vai depender que outra pessoa tenha, anteriormente, falsificado ou alterado o documento.

A doutrina também classifica o tipo do art. 304 como norma penal em branco ao avesso, já que é necessário completar o preceito secundário da norma penal. Conforme ressaltado, as penas são estabelecidas em outros tipos penais.

O crime é comum (pode ser praticado por qualquer indivíduo) e formal, consumando-se com a utilização do documento, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou proveito.

A tipicidade requer seja o documento apto a ludibriar. A falsificação grosseira, perceptível de plano, afasta o crime, em razão da ausência de potencial lesivo na conduta. A hipótese será de crime impossível (art. 17 do CP).

Cópias sem autenticação **não** ingressam no conceito de documento para fins de incidência na figura do art. 304, CP.

A posse ou o porte do documento falso não são criminalizados. É preciso que o agente faça uso, com objetivo de atingir efeitos jurídicos, para que o crime se configure. **Exemplo:** indivíduo que portando carteira de identidade falsa não comete crime. A conduta criminalizada é a de fazer uso da documentação, isto é, apresentar o documento para produzir algum efeito jurídico a partir da utilização desse documento.

Discute-se a tipicidade da conduta quando se trata da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Há quem sustente ser crime o simples porte do documento falso visto que para dirigir é obrigatório trazer consigo o documento (art. 159, § 1º, do CTB). O indivíduo estaria, assim, usando e não simplesmente portando a CNH. Assim, o delito resta configurado independentemente do indivíduo ser obrigado a exibir o documento.

Todavia, em recente julgado, o STJ adotou entendimento em sentido diverso. Decidiu a Corte que a configuração do delito previsto no art. 304 do CP pressupõe tanto a efetiva utilização do documento, *sponte* própria, quanto que o documento falso seja apresentado como autêntico. Nessa linha de raciocínio, "o encontro casual do documento falso em poder de alguém (como ocorre por ocasião de



uma revista policial) não é suficiente para configurar o tipo penal, pois o núcleo é claro: 'fazer uso'" (in Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal comentado - 15. ed.rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015). Precedente: CC 128.923/SE, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015.

Dessa forma, se o investigado, em abordagem de rotina, afirma ao agente da Polícia Rodoviária Federal não possuir Carteira Nacional de Habilitação, identificando-se por meio de Carteira de Identidade, e, logo em seguida, o policial avista, em sua carteira aberta, documento similar à CNH que o investigado lhe entrega, admitindo tratar-se de documento falso, não há como se reconhecer na conduta, *a priori*, o elemento de vontade (de fazer uso de documento falso) necessário à caracterização do delito do art. 304 do CP, situação em que a apresentação do documento falso à autoridade policial federal não tem o condão de deslocar a competência para o julgamento da ação penal para a Justiça Federal. (CC 148.592/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017).

A partir do raciocínio desenvolvido no julgado acima citado, conclui-se que apresentação de documento falso por exigência de autoridade pública tipifica o crime, pois o indivíduo tem a faculdade de dizer que não estava portando o documento e, assim, não incidiria na figura criminosa. A partir do momento que se exhibe o documento falso, o crime estará configurado, ainda que essa exibição não seja espontânea e sim por determinação de um agente público.

O uso de documento falso, para encobrir antecedentes criminais, é amparado pela garantia à não autoincriminação?

Segundo o STF, a autodefesa não é ilimitada. Não se pode valer de meios ilícitos para a satisfação de interesses pessoais. Logo, o uso de documento falso não se legitima pelo argumento da autodefesa.

O falsário que usa o documento que ele próprio falsificou não pratica dois crimes. O uso é *post factum* impune, que resta absorvido pela falsificação.

A competência para processar e julgar o crime é, em regra, da Justiça Estadual.

Nos termos da Súmula 546 do STJ, a competência para processar e julgar o crime **de uso** de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi **apresentado** o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.

Atenção! Note que, para os crime que envolvem a **falsificação** do documento, a fixação da competência considera a qualificação do órgão expedidor.

Para o STJ, no caso do crime de **uso** de documento falso, **a qualificação do órgão expedidor do documento público é irrelevante para determinar a competência**. No uso de documento falso, o critério a ser utilizado para definir a competência é analisar a natureza do órgão ou da entidade a quem o documento foi apresentado, considerando que são estes quem efetivamente sofrem os prejuízos em seus bens ou serviços. Assim, se o documento falso é apresentado perante um órgão ou entidade federal, a vítima é este órgão ou entidade que teve seu serviço ludibriado.

Portanto:

Competência para julgar a FALSIFICAÇÃO do documento: definida em razão do órgão expedidor.

Competência para julgar o USO do documento falso: definida em razão do órgão a quem é apresentado.

A Súmula 200 do STJ estabelece que o Juízo Federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou.

Com efeito, o uso de passaporte falso visa ludibriar a Polícia Federal e o controle de imigração, órgãos ligados à Justiça Federal, portanto, a competência para julgar o crime é da Justiça Federal do local onde o delito se consumou, isto é, onde o passaporte falso foi apresentado.

A ação penal é pública incondicionada.



10. ART. 305. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO

Segundo o art. 305, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor é delito punido com reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular. Admite-se a suspensão condicional do processo no caso do documento particular e, em ambos os casos, o acordo de não persecução penal.

Note-se que não há falsificação no tipo em comento. Por esse motivo, a doutrina critica a alocação inadequada no capítulo que cuida das falsidades documentais. Isto porque não haverá falso, mas sim a destruição, supressão ou ocultação do documento.

O tipo é misto alternativo, pois prevê três núcleos distintos, a saber, destruir, suprimir e ocultar.

Destruir significa eliminar, com a utilização de fogo, por exemplo. Suprimir é fazer desaparecer, sem destruir. Ocorre quando o indivíduo rabisca, utiliza tinta, tornando o documento ilegível. Por sua vez, ocultar é o mesmo que esconder.

O documento deve ser verdadeiro, público ou particular.

A conduta não se tipifica se já se tratar de cópia, certidão, traslado ou cópia autenticada, pois poderá ser feito um novo documento, a partir do original. A destruição, supressão ou ocultação é de algo que não pode ser reproduzido.

A expressão *de que não podia dispor* é elemento normativo do tipo. Se o teor do documento não prejudica terceiros, somente afetando a quem dele dispôs, não há crime (princípio da alteridade).

O crime é comum ou geral, pois pode ser praticado por qualquer pessoa.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, com especial fim de agir, consistente em benefício próprio ou de outrem e em prejuízo alheio. O proveito pode ser de qualquer natureza, não necessariamente patrimonial.

Tem-se, ainda, um crime formal ou de consumação antecipada, já que independe da efetiva obtenção da vantagem ou da causação de prejuízo. Na modalidade ocultar, o delito é permanente. A tentativa é possível.

A sonegação de papel ou objeto com valor probatório praticada por advogado ou procurador atrai a aplicação do art. 356 do CP, por força do princípio da especialidade.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 62 — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA: DE OUTRAS FALSIDADES

1. ART. 306. FALSIFICAÇÃO DO SINAL EMPREGADO NO CONTRASTE DE METAL PRECIOSO OU NA FISCALIZAÇÃO ALFANDEGÁRIA, OU PARA OUTROS FINS

O tipo do art. 306 consiste em falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem. A pena é de reclusão, de dois a seis anos, e multa. Admite o acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

Marca ou sinal é aquilo que serve de alerta, possibilitando reconhecer ou conhecer algo. O contraste de metal precioso é marca feita no metal, indicador de peso e quilate. A marca de fiscalização alfandegária é a representação gráfica utilizada, a fim de demonstrar que uma mercadoria foi liberada ou passou por um controle de entrada ou saída do país.

O crime é comum (pode ser praticado por qualquer pessoa) e formal (prescinde de resultado naturalístico para a consumação).

É praticado apenas a título doloso. Não exige especial fim de agir por parte do sujeito ativo.

O parágrafo único contempla a forma privilegiada. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, a pena passa a ser reclusão ou detenção, de um a três anos, e multa. Dessa forma, o magistrado poderá optar pela pena de detenção, que é sensivelmente mais branda.

A ação penal é pública incondicionada.

2. FALSA IDENTIDADE

2.1. ART. 307.

Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, acarreta pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

Conforme se extrai do preceito secundário, o tipo é expressamente subsidiário. É preciso analisar se o fato não constitui elemento de crime mais grave, como o estelionato e outras fraudes, por exemplo.

O crime em comento trata da falsidade pessoal, isto é, aquela que recai sobre a identidade civil.

O objeto material é a identidade, que consiste no conjunto de características próprias de determinada pessoa, capazes de identificá-la e individualizá-la em sociedade. Assim sendo, o agente se atribui ou atribui a terceiro dados pessoais falsos. Tanto podem ser os dados de outra pessoa existente, como uma identidade fictícia. É prática relativamente comum para ocultar antecedentes criminais.

Importante estabelecer a diferença entre a falsa identidade (art. 307) e uso de documento falso (art. 304). Na conduta do art. 307, a atribuição de falsa identidade se dá sem a utilização ou apresentação de documento falso. Exemplo: indivíduo que se apresenta na delegacia com outro nome que não o seu, mas não mostra o RG.

Se for apresentado documento falso, o crime será o do art. 304. Exemplo: indivíduo que apresenta RG com foto e informações de outra pessoa, fazendo-se passar por ela.

O elemento subjetivo é o dolo, acrescido do especial fim de agir, consistente em obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. O proveito pode ser econômico ou de qualquer outra natureza.



Pratica o crime do art. 307 o sujeito que atribui a si próprio falsa identidade para ocultar antecedentes criminais ou para evitar uma prisão?

Para o STF, sim. A autodefesa encontra limites e não permite que se ofenda a fé pública.

No mesmo sentido, tem-se a **Súmula 522 do STJ**: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

A consumação ocorre no momento em que a identidade falsa é atribuída a si ou a terceiro, ainda que o proveito pretendido não seja alcançado. O crime é formal.

A ação penal é pública incondicionada.

2.2. ART. 308.

“Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro” é crime punido com detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Admite-se a transação penal e a suspensão condicional do processo. A subsidiariedade está expressa, sendo necessário verificar se a intenção não era praticar crime mais grave, como o estelionato.

O delito trata da falsidade pessoal. O indivíduo se apodera de documento verdadeiro pertencente a outra pessoa e o utiliza, atribuindo-o como próprio. Há crime, também, quando cede (entrega) a outrem, para que o utilize, o documento próprio ou de terceiro.

O crime é formal, pois independe de resultado naturalístico para a sua consumação. É também comum ou geral, pois qualquer pessoa pode praticar. O sujeito passivo é o Estado.

O exame pericial pode se revelar necessário, para se verificar a autenticidade do documento utilizado ou cedido. Se o documento for falso, o crime será o do art. 304 do CP.

A ação penal é pública incondicionada.

3. FRAUDE DE LEI SOBRE ESTRANGEIRO

3.1. ART. 309.

Segundo o art. 309, “usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu” é delito punido com detenção, de um a três anos, e multa. Admite-se o *sursis* processual e o acordo de não persecução penal.

Observa-se que, no *caput*, temos crime próprio ou especial, pois somente o estrangeiro pode praticar.

Já no parágrafo único, que prevê pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa àquele que atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional, o delito é comum ou geral e praticado de forma livre.

O elemento subjetivo é o dolo, acompanhado de especial fim de agir, consistente no intuito de entrar ou permanecer no território nacional. Se não estiver caracterizada a intenção específica, a tipificação penal não se aperfeiçoa. Não há forma culposa do crime.

A consumação ocorre com o efetivo uso do nome pelo estrangeiro, não sendo relevante se a finalidade vem a ser ou não alcançada. O delito é formal.

Se o documento empregado for falso, o crime em comento resta absorvido pelo art. 304. A hipótese é de consunção, pois o crime mais grave absorve o menos grave.

A competência é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso X, da CF.

A ação penal é pública incondicionada.



3.2. ART. 310.

“Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens” é conduta punida com detenção, de seis meses a três anos, e multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O *nomen iuris* geralmente dado a este crime é *falsidade em prejuízo da nacionalização de sociedade*.

O bem jurídico tutelado é segurança e identidade das pessoas envolvidas em negócios no país.

Trata-se de norma penal em branco homogênea, pois é necessário um complemento legislativo, revelado na expressão “*nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou posse de tais bens*”. Exemplo: art. 222 da CF, ao dispor que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

Trata-se de crime de concurso necessário. Com efeito, para a configuração do delito é necessário que determinado indivíduo se passe por proprietário para encobrir o verdadeiro dono, que é o estrangeiro, já que este não poderia sê-lo.

O crime é formal, de consumação antecipada, e não se exige finalidade específica. Eventual intuito de lucro pode ser valorado na dosimetria da pena (art. 59 do CP).

A competência é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, CF.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 311. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A conduta criminosa prevista no art. 311 consiste em *adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento*. A pena é de reclusão, de três a seis anos, e multa. Admite-se o acordo de não persecução penal.

O bem jurídico tutelado é a fé pública, no aspecto relativo à proteção da propriedade e da segurança no registro e identificação do automóvel. É importante que se tutele a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor.

A adulteração pode ser no chassi (estrutura de aço sobre a qual se monta a carroceria do veículo) ou nos sinais identificadores colocados no motor, câmbio, ou placas.

O conceito de veículo automotor é extraído do Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). Trata-se do veículo a motor de propulsão que circula por seus próprios meios. Não se incluem os veículos que circulam sobre trilhos, como trens.

O tipo é misto alternativo ou de conteúdo variado, diante da presença de dois verbos nucleares, adulterar ou remarcar. O tipo **não** abrange a conduta de ocultar nem suprimir. Dessa forma, se o número do chassi for inteiramente suprimido e não houver nova remarcação, **não estará configurado** o crime, por ser vedada a analogia *in malam partem*.

Discute-se a conduta consistente na colocação de fita adesiva na placa do veículo, para evitar multas ou burlar o rodízio de veículos. Enquadra-se no art. 311 do CP ou seria mera infração administrativa?

Para o STF, a conduta é típica, pois a frustração dos meios legítimos de fiscalização de trânsito macula a fé pública (RHC 116.371/DF). No caso concreto apreciado, o réu argumentou que colocou uma fita isolante preta na placa de seu veículo, modificando o último número, apenas para poder circular com o carro burlando o rodízio de veículos que existia na cidade. Com base nisso, a defesa apresentou duas teses: a falsidade era grosseira (percebida a olho nu); e não houve dolo de praticar o delito, mas apenas o de burlar o rodízio, configurando, portanto, mera irregularidade administrativa.



A Corte não aceitou os argumentos, afirmando que o bem jurídico protegido pela norma penal foi atingido. Assentou que o tipo penal não exige elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica. No entanto, mesmo que se considere que a vontade do agente foi apenas essa, tal conduta tinha por objetivo frustrar a fiscalização, ou seja, os meios legítimos de controle do trânsito, incidindo, portanto, no crime. Além disso, o simples fato de ter sido utilizada fita isolante para fazer a alteração não significa dizer que a falsidade seja grosseira. Isso porque em muitos casos como esse, a adulteração somente é percebida se a placa for analisada de perto, podendo o agente de trânsito ser enganado se o veículo estiver em movimento.⁷⁰

Em provas discursivas, é importante destacar a existência de divergência e que parcela da doutrina entende que a adulteração ou remarcação de número de chassi ou de sinal identificador de veículo automotor deve se revestir de **permanência**, pois somente dessa forma é cabível reconhecer a lesão à fé pública. Se a mudança é temporária e, principalmente, facilmente perceptível por qualquer pessoa, a exemplo do que se verifica na colocação de fitas adesivas nas placas de veículos para livrar-se de multas de trânsito, do pagamento de pedágio, dos radares e da restrição de circulação em dias e horários determinados, não há que se falar em adulteração ou remarcação.

O crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Ainda, é formal, pois independe de resultado naturalístico para a consumação.

Por ser crime não-transeunte, isto é, que deixa vestígios, é necessária a perícia, nos termos do art. 158 do CPP.

O elemento subjetivo é o dolo, independentemente de finalidade específica.

No § 1º está prevista causa de aumento de pena de um terço aplicável ao funcionário público que comete o crime no exercício da função. Incide na terceira fase da dosimetria.

Já o § 2º estabelece que incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Observa-se, assim, a participação material do servidor público, que é o indivíduo propiciador dos meios para registrar o veículo que está com seus sinais nitidamente adulterados. Neste caso, o crime é próprio, pois só pode ser praticado pelo servidor público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo por trabalhar em órgão competente para esse fim. O conceito de funcionário público para fins penais é extraído do art. 327 do CP.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 311-A. FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO

A figura típica descrita no art. 311-A é a seguinte:

Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:

I - concurso público;

II - avaliação ou exame públicos;

III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

IV - exame ou processo seletivo previstos em lei:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 3º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público.

⁷⁰Fonte: Dizer o Direito. Acesso e disponibilidade: <https://www.dizerodireito.com.br/2013/09/se-o-agente-coloca-uma-fita-isolante.html>



O dispositivo ora em análise foi incluído pela Lei nº 12.550/2011, atendendo à necessidade de se tipificar de forma específica essas condutas, que não encontravam perfeita adequação em outros artigos do CP.

Antes do advento do crime em estudo, o STF não considerava típica a conduta da cola eletrônica (candidato que se utiliza de comunicador para estabelecer contato com alguém que já estivesse de posse do gabarito das questões). Esse comportamento não se enquadrava perfeitamente em nenhum tipo do Código Penal, a exemplo do estelionato ou da falsidade ideológica. E, diante da vedação à analogia *in malam partem*, a conduta sofria reprimenda somente nos âmbitos administrativo e cível, mas não no penal.

Para alguns doutrinadores, o direito penal não deveria incidir nesse tipo de situação, já que é a *ultima ratio*. Os demais ramos do ordenamento seriam suficientes para tutelar atos que se revelam moralmente reprováveis.

A abrangência do tipo é para todo e qualquer certame ou concurso de interesse público, não necessariamente de natureza pública. É preciso garantir a credibilidade e transparência dos processos seletivos (vestibular para ingresso em universidade privada, por exemplo). Dessa forma, o crime se caracteriza inclusive quando a fraude se dá no âmbito de instituição privada (faculdade ou universidade).

O tipo é misto alternativo ou de conteúdo variado. A prática de mais de um dos verbos no mesmo contexto fático enseja crime único.

Conteúdo sigiloso é elemento normativo do tipo. Trata-se de informação secreta ao público em geral, cuja divulgação coloca em risco a credibilidade do concurso. A expressão *indevidamente* também é elemento normativo do tipo e será valorada no caso concreto.

O crime é comum ou geral, pois pode ser praticado por qualquer indivíduo. Se praticado por funcionário público, há causa de aumento de pena, conforme o § 3º.

Admite-se apenas a forma dolosa, acrescida do especial fim de agir, revelado nas expressões “com o fim de beneficiar a si ou a outrem” ou “com o fim de comprometer a credibilidade do certame”.

O §2º prevê a figura qualificada quando, da ação ou omissão, resulta em dano para a Administração Pública. Logo, a consumação da figura do art. 311-A **não exige dano** à Administração (crime formal ou de consumação antecipada). Basta que seja constatada a especial finalidade de agir. Uma vez produzido o prejuízo, a pena passa a ser mais elevada.

É compatível com a tentativa, sendo possível o fracionamento do *iter criminis*.

A competência, em regra, é da Justiça Estadual. Quando afetar direitos e interesses da União, a competência será da Justiça Federal.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 63 — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Alguns conceitos são importantes para o início do presente estudo.

Crimes funcionais próprios: são aqueles em que, se não houver a qualidade de funcionário público, a conduta se torna um indiferente penal. Exemplo: prevaricação (art. 319).

Crimes funcionais impróprios: quando há o desaparecimento da qualidade especial de servidor público, o delito é desclassificado para outro tipo penal. **Exemplo:** peculato-furto (art. 312). Caso não haja a condição de funcionário público, haverá o crime de furto (art. 155).

O particular pode praticar crime funcional (próprio ou impróprio) contra a Administração Pública? **Sim**, pois nos termos do art. 30 do CP, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. A condição de funcionário público, por ser elementar dos crimes funcionais, **comunica-se aos particulares que tiverem concorrido para o fato**. Por certo, a elementar deve ser de conhecimento do particular (*extraneus*), sob pena de se consagrar responsabilização penal objetiva. Portanto, o particular que pratica o crime juntamente com o servidor público, sabendo desta condição pessoal, poderá ser coautor ou partícipe do crime funcional.

O conceito de funcionário público para fins penais está disposto no art. 327 do CP. É aquele indivíduo que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O art. 327 é, assim, uma norma penal explicativa ou interpretativa. Inserem-se no conceito de funcionário público os jurados, quando no desempenho da função.

O § 1º do art. 327 contempla as figuras equiparadas. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

Exemplos de empresas prestadoras de serviço conveniadas são as Santas Casas de Misericórdia. Entidades paraestatais são as empresas do “Sistema S” (SESI, SESC, SENAI). Exemplos de pessoas contratadas para exercer atividade típica da Administração Pública são os funcionários de hospitais particulares e médicos contratados para atenderem pelo Sistema Único de Saúde.

Segundo recentemente decidiu o STF, o diretor de organização social pode ser considerado funcionário público por equiparação para fins penais. Isso porque as organizações sociais que celebram contratos de gestão com o Poder Público devem ser consideradas “entidades paraestatais”, nos termos do art. 327, § 1º do CP. (STF. 1ª Turma. HC 138484/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/9/2018. Informativo 915).

Agentes políticos, tais como os membros do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública também se inserem no conceito de funcionário público, para fins penais.

Função pública é diferente de *munus público*. Não se inserem no conceito do art. 327 do CP aqueles que exercem *munus público*, como os tutores, curadores, inventariantes e o defensor dativo (não integrante da Defensoria Pública).

Nos crimes previstos na Lei nº 8.666/93 (Licitações) não se aplica o art. 327 do CP e sim a regra específica do art. 84, §§ 1º e 2º, da lei especial.

Vale ressaltar que, segundo o § 4º do art. 33 do CP, para que o condenado por crime contra a Administração Pública tenha direito à progressão de regime prisional é necessário que faça a reparação do dano causado, ou a devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. O STF decidiu que essa previsão é constitucional. No entanto, deve ser permitido que o sentenciado faça o parcelamento do valor da dívida, em especial quando se tratar de valores vultuosos (Informativo 772).

Quanto ao princípio da insignificância, como causa que afasta a tipicidade material da conduta, a orientação que prevalece é no sentido de não ser aplicável aos crimes contra a Administração Pública, em razão de não se tutelar apenas o aspecto patrimonial, mas sobretudo a moralidade administrativa, que não é quantificável em termos financeiros. A exceção é quanto ao delito de descaminho, previsto no art. 334 do CP, que possui peculiaridades, a serem estudadas oportunamente.

Nesse sentido, o STJ editou a Súmula 599, segundo a qual o “princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.”

Não se desconhece, porém, a existência de julgados em sentido diverso, inclusive no âmbito do próprio STJ. Com efeito, foi reconhecida a insignificância na conduta de danificar um cone de trânsito avaliado em vinte reais.⁷¹

No STF, há julgados admitindo a aplicação do princípio mesmo em outras hipóteses além do descaminho, como foi o caso do HC 107370, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/04/2011 e do HC 112388, Rel. p/ Acórdão Min. Cezar Peluso, julgado em 21/08/2012. Segundo o entendimento que prevalece no STF, a prática de crime contra a Administração Pública, por si só, não inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, devendo haver uma análise do caso concreto para se examinar se incide ou não o referido postulado. Exemplo: na situação de apropriação de folhas de papel, canetas ou outros objetos de pequeno valor, o STF tem relativizado a aplicação do princípio da insignificância.

A seguir, nos artigos 312 a 326, serão estudados os crimes funcionais, isto é, aqueles praticados por funcionário público contra a Administração.

⁷¹PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. INUTILIZAÇÃO DE UM CONE. IDOSO COM 83 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. PRIMÁRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 599/STJ. JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A subsidiariedade do direito penal não permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano. A falta de interesse estatal pelo reflexo social da conduta, por irrelevante dado à esfera de direitos da vítima, torna inaceitável a intervenção estatal-criminal.

2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. A despeito do teor do enunciado sumular n. 599, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, as peculiaridades do caso concreto - réu primário, com 83 anos na época dos fatos e avaria de um cone avaliado em menos de R\$ 20,00, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente à época dos fatos - justificam a mitigação da referida súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante da inexpressiva lesão jurídica provocada.

3. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento da ação penal n. 2.14.0003057-8, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Gravataí/RS.

(RHC 85.272/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018). Grifou-se.



CAPÍTULO 64 — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

1. ART. 312. PECULATO

“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio” é conduta punida com reclusão, de dois a doze anos, e multa. Admite o acordo de não persecução penal.

O termo peculato vem do latim *pecus*, que significa não só gado, mas também moeda, como em pecúnia e pecuniário.

O crime é próprio, somente pode ser praticado por funcionário público. Porém, é possível o concurso de agentes com o particular, desde que este conheça a condição de funcionário público do comparsa (elementar).⁷²

O sujeito passivo é o Estado. No caso do bem pertencente a particular, o proprietário também será vítima.

1.2. MODALIDADES DE PECULATO

Peculato-apropriação: agente se apodera de coisa que tem sob sua posse legítima.

Exemplo: escrivão de polícia encarregado de receber os valores pagos a título de fiança na delegacia e que se apropria das quantias.

Peculato-desvio: agente confere destinação diversa à coisa. É também chamado de malversação.

Peculato-furto: ou impróprio. É aquele descrito no §1º. Aplica-se a mesma pena de reclusão, de 2 a 12 anos, e multa, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, **valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário**. Exemplo: no caso da situação hipotética das fianças que são recebidas pelo escrivão de polícia, se o policial investigador, que não é o responsável por essa função, entra na sala do colega e subtrai os valores, tipifica-se a figura do § 1º. O investigador se valeu da facilidade de acesso à sala do escrivão.

A prestação de serviços não é equiparada a bem móvel para fins de tipicidade do peculato. Veda-se a analogia *in malam partem*.

O crime se consuma, na primeira modalidade, quando há a apropriação do dinheiro, valor ou bem móvel, dispondo do objeto material como se dono fosse. No caso do peculato-desvio, tem-se crime formal para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. Na modalidade peculato-desvio, não se discute o deslocamento de verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro particular em posse do Estado. Assim, a consumação do crime não depende da prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiro.⁷³

Assim, é dispensável a obtenção de lucro pelo agente em qualquer caso.⁷⁴

Segundo o STJ, o administrador que desconta valores da folha de pagamento dos servidores públicos para quitação de empréstimo consignado e não os repassa a instituição financeira pratica peculato-desvio, sendo desnecessária a demonstração de obtenção de proveito próprio ou alheio,

⁷² Jurisprudência em Teses STJ (ed. 57). Tese 9: A elementar do crime de peculato se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao serviço público.

⁷³ Fonte: Dizer o Direito. Acesso e disponibilidade: <https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2020/03/info-664-stj.pdf>

⁷⁴ Jurisprudência em Teses STJ (ed. 57). Tese 11: A consumação do crime de peculato-desvio (art. 312, caput, 2ª parte, do CP) ocorre no momento em que o funcionário efetivamente desvia o dinheiro, valor ou outro bem móvel, em proveito próprio ou de terceiro, ainda que não obtenha a vantagem indevida.

bastando a mera vontade de realizar o núcleo do tipo. (STJ. Corte Especial. APn 814-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 06/11/2019. Informativo 664.

No caso do peculato impróprio (ou peculato furto), a consumação ocorre com a subtração da coisa, dispensando-se a posse mansa e pacífica, na mesma linha doutrinária do crime de furto (teoria da *amotio*).⁷⁵

Em regra, não se admite a aplicação do princípio da insignificância.

E quanto ao peculato de uso? Há crime se o agente tem a intenção de restituir o objeto material à Administração Pública?

A doutrina se divide. Há quem sustente ser conduta típica, ainda que a intenção seja de restituir o bem móvel subtraído, apropriado ou desviado. Não se perquire, ainda, se a conduta foi vantajosa para a Administração. Se a moralidade administrativa foi ofendida, sempre haverá crime.

Todavia, prevalece o entendimento de não ser crime. Segundo o STF, é atípico o peculato de uso relacionado ao uso momentâneo de coisa infungível, sem a intenção de se apropriar, seguida da restituição integral. Poderá caracterizar improbidade administrativa. Porém, haverá peculato no caso de bens fungíveis, como o dinheiro.

No § 2º está previsto o **peculato culposo**. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena será de detenção, de três meses a um ano.

Nesse caso, há o concurso não intencional de funcionário público, por ação ou omissão, para a apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou bem móvel pertencente ao Estado ou sob sua guarda, por terceira pessoa, que pode ser tanto funcionário público (*intraneus*) ou particular (*extraneus*). É a conduta do servidor *relaxado, desatento, relapso, desidioso*.

Para a tipificação, deve existir a prática de conduta dolosa por terceiro, que se aproveita da facilidade gerada culposamente pelo funcionário público. A conduta do terceiro é sempre dolosa. Quem age culposamente é o servidor público que, por imprudência, negligência ou imperícia, cria uma facilidade para a conduta dolosa do *intraneus* ou *extraneus*.

Nos moldes do **§ 3º, no caso do peculato culposo, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.**

Se o servidor que age culposamente faz a reparação do dano antes do trânsito em julgado da sentença, terá extinta a sua punibilidade. Se a reparação se der após o trânsito, terá a pena reduzida à metade. A reparação do dano deve ser completa e não exclui eventual sanção administrativa.

A competência será da Justiça Federal sempre que houver afetação de bens ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas.

A ação penal, em todas as modalidades de peculato, é pública incondicionada.

QUESTÕES

1- (Juiz Federal TRF2 2017) O particular que auxilia materialmente a prática de crime de peculato-desvio por seu amigo, que sabe ser servidor, responderá por apropriação indébita, tendo em vista lhe faltar a qualidade de funcionário público.

2- (CESPE- CEBRASPE 2018) É causa de extinção da punibilidade a reparação de dano decorrente de peculato culposo por funcionário público, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória.

GABARITO

1. Gabarito: item errado, pois a elementar servidor do crime de peculato se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao serviço público, desde que conheçam a referida condição.

2. Gabarito: item correto, nos exatos termos do § 3º do art. 312 do CP.

⁷⁵ Importa registrar que, para o prof. Cleber Masson, na obra já citada anteriormente, o crime de peculato é material em suas três formas.



2. ART. 313. PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM

Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem é a conduta tipificada no art. 313. A pena cominada é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Trata-se do crime chamado de “peculato-estelionato”: o funcionário público se aproveita do erro alheio. A vítima tem uma falsa percepção da realidade.

Apesar do nome, trata-se de modalidade especial de apropriação de coisa havida por erro (art. 169, 1ª parte, CP). Exemplo: particular dirige-se a uma repartição para pagar determinado tributo supostamente atrasado. O funcionário percebe que o valor já estava pago, porém silencia e se apropria do valor. O erro da vítima deve ser espontâneo, pois, se foi provocado pelo funcionário, a conduta típica será diversa (estelionato).

O sujeito ativo é o funcionário público, nos moldes do art. 327 do CP. Caso seja ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, sofrerá aumento de pena da terça parte, na terceira fase da dosimetria, conforme previsão do § 2º do art. 327.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 313-A. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Segundo dispõe o art. 313-A,

inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano é crime apenado com reclusão, de dois a doze anos, e multa. Permite o acordo de não persecução penal.

Tem-se o chamado “peculato eletrônico”, introduzido pela Lei nº 9.983/2000.

O objetivo principal da nova legislação foi tutelar o patrimônio e a saúde financeira da Previdência Social.

Em verdade, a figura não guarda semelhança com os tipos precedentes. Mas, em razão da localização topográfica no Código, é também chamada de peculato.

O tipo é misto alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado: a conduta pode ser de **inserir, facilitar, alterar** ou **excluir**. A prática de mais de um desses verbos no mesmo contexto fático enseja crime único.

O crime é próprio. Exige-se que seja praticado pelo funcionário público autorizado ao acesso a dados restritos.

O elemento subjetivo é o dolo, acrescido de especial fim de agir, consistente no *fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano*. Não se admite a prática culposa.

O delito é formal, vez que prescinde do resultado naturalístico para a consumação. Não é necessária a obtenção de vantagem indevida e dano a outrem.

Segundo o STJ, o crime é instantâneo. Uma vez realizada a inserção ou alteração dos dados, o crime já estará consumado.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 313-B. MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

“Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente” é crime punido com detenção, de três meses a



dois anos, e multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. São cabíveis os benefícios despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

É também modalidade do chamado “peculato eletrônico”, introduzido pela Lei nº 9.983/2000. Busca-se proteger a integridade dos sistemas de informações e programas de informática.

Trata-se de normal penal em branco, que exige complementação para identificar os sistemas de informações ou programa de informática.

Nos termos do parágrafo único, as penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado. Dessa forma, o dano não é requisito para a configuração do crime. A consumação é antecipada (crime formal). O aumento de pena aplica-se no caso de exaurimento (dano efetivo à Administração).

O tipo é misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado. Os verbos modificar e alterar não são sinônimos para fins penais. Modificar significa uma transformação radical, na essência. Já a alteração é menos profunda, pois a mudança não desnatura por completo as informações.

O funcionário público é o sujeito ativo do crime, sendo possível a participação do particular, desde que conhecedor da condição do comparsa.

O delito é praticado somente na forma dolosa.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 314. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO

“Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente” é crime apenado com reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave. É possível a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal. Percebe-se também que o preceito secundário apresenta subsidiariedade expressa. Necessário verificar, portanto, se a conduta não se enquadra nas hipóteses dos artigos 305 e 356 do CP (mais específicos).

O tipo é misto alternativo. Extraviar significa fazer que não chegue ao destino real. Sonegar é o mesmo que ocultar, esconder. Inutilizar, por seu turno, é tornar imprestável, total ou parcialmente.

O sujeito ativo é o funcionário público, conforme descrito no art. 327 do CP.

A destruição pode ser total ou parcial, desde que haja comprometimento de parte essencial.

O delito é punido apenas dolosamente. Não se exige especial fim de agir.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 315. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS

Nos termos do art. 315, *dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei* é crime punido com detenção, de um a três meses, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo. Admitida a transação penal, fica inviabilizado o acordo de não persecução penal.

O tipo penal tutela o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF. Nesse caso, os recursos não são apropriados pelo servidor público em benefício próprio ou de outrem. As verbas são destinadas no âmbito da Administração, mas para uma finalidade diferente daquela prevista em lei. O objetivo é evitar o emprego arbitrário das verbas públicas.

Observa-se uma norma penal em branco homogênea, já que a destinação das verbas deve ser estabelecida em lei.

O tipo em comento não se aplica aos prefeitos. Por força do princípio da especialidade, incide o Decreto-Lei nº 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos (art. 1º, in. III).

Não se deve confundir o crime em estudo com o peculato-desvio. No tipo do art. 315, as verbas ou rendas públicas são desviadas em favor da própria Administração Pública. Os recursos devem



ser aplicados regularmente, de acordo com destinação legal prévia. No caso do crime previsto no art. 312, o bem móvel, público ou particular, é desviado em proveito próprio ou de terceiro.

O elemento subjetivo é dolo, prescindindo de finalidade específica. Não se admite a modalidade culposa.

O crime é material: consuma-se com a aplicação das verbas em finalidade diversa da legalmente prevista. É irrelevante a comprovação de efetivo prejuízo à Administração Pública.

A competência, em regra, é da Justiça Estadual.

A ação penal é pública incondicionada

7. ART. 316. CONCUSSÃO

A conduta tipificada no art. 316 consiste em *exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida*. Comina-se pena de reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Admite-se o acordo de não persecução penal.

O preceito secundário foi objeto de recente modificação, pela Lei nº 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime. Antes da lei, o delito era punido com pena de reclusão de 2 a 8 anos, e multa. Discutia-se na doutrina a desproporcionalidade da cominação em abstrato quando comparada ao crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, o qual prevê pena de reclusão de 2 a 12 anos. Dessa forma, um delito menos grave, a corrupção passiva, era punida com mais rigor do que a concussão. Tal incongruência foi então corrigida.

O sujeito ativo é o funcionário público, mas também pode ser aquele indivíduo que ainda não está no exercício da função (nomeado, mas ainda não em exercício) e se vale da função para exigir vantagem indevida. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público (art. 327, § 2º).

O particular pode concorrer para o crime, desde que saiba da condição pessoal do comparsa (art. 30 do CP).

O sujeito passivo é a Administração Pública, mas também o particular que sofreu o constrangimento.

O verbo núcleo do tipo é exigir. Há uma diferença em relação ao simples solicitar. A exigência envolve grave ameaça, há um temor fundado da vítima, uma influência intimidativa. Já a solicitação é mero pedido e está relacionado ao tipo do art. 317 (corrupção passiva).

Dessa forma, podemos resumir que na concussão há exigência, grave ameaça, ao passo que na corrupção passiva ocorre solicitação, pedido que não envolve violência ou grave ameaça.

O crime é formal: não é necessário que o indivíduo obtenha a vantagem para a consumação, bastando que faça a exigência. A entrega da vantagem é mero exaurimento.

A vantagem indevida deve ser de natureza econômica ou patrimonial?

Há quem sustente que sim. Porém, prevalece o entendimento de que pode ser vantagem de qualquer espécie (sexual ou política, por exemplo).

Jurados podem praticar concussão? Sim, nos termos do art. 445 do CPP. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.

Segundo já decidiu o STF, é legítima a utilização da condição pessoal de policial civil como circunstância judicial desfavorável para fins de exasperação da pena-base aplicada a acusado pela prática do crime de concussão. Aquele que está investido de parcela de autoridade pública — como é o caso de um juiz, um membro do Ministério Público ou uma autoridade policial — deve ser avaliado, no desempenho da sua função, com maior rigor do que as demais pessoas não ocupantes de tais cargos (STF. 1ª Turma. HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 16/8/2016. Informativo 835).

A ação penal é pública incondicionada.



8. ART. 316, § 1º. EXCESSO DE EXAÇÃO

Nos termos do § 1º do art. 316, *se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza* incidirá em pena de reclusão, três a oito anos, e multa. Admite-se o acordo de não persecução penal.

A doutrina critica a técnica legislativa. Verifica-se um tipo fundamental previsto em um parágrafo. Com efeito, a conduta ora em comento é autônoma e independente da prevista no *caput* do art. 316.

No presente caso, a exigência ilegal do tributo ou contribuição social se dá em benefício da Administração Pública, ao passo em que na concussão o funcionário público o faz em proveito próprio ou de terceiro.

Só o funcionário público poderá praticar o delito. É crime próprio ou geral. O sujeito passivo é a Administração Pública.

Trata-se de tipo misto alternativo (exigir ou empregar meio vexatório) e uma norma penal em branco homogênea ou em sentido lato, pois necessita de complemento normativo no preceito primário.

A consumação ocorre no momento em que há a cobrança ilícita, ou quando devido o tributo, é empregada a cobrança de maneira irregular. Assim, o delito é material ou causal. Há compatibilidade com a tentativa.

Custas e emolumentos correspondentes aos serviços notariais e de registros podem constituir objeto material do crime de excesso de exação, segundo o STJ e STF.

Conforme o § 2º, se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos a pena será de reclusão, de dois a doze anos, e multa. Trata-se do excesso de exação qualificado.

Uma vez mais, critica-se a técnica legislativa, pois a pena mínima é inferior à figura do § 1º.

O recolhimento é feito ilicitamente em favor da Administração. O desvio ocorre posteriormente, porém antes da incorporação ao patrimônio público. Se a quantia já ingressou nos cofres públicos, resta caracterizado o peculato-desvio (art. 312, *caput*, parte final, do CP).

O tipo tem rara ocorrência na prática nos dias atuais, já que os tributos são recolhidos por meio de instituições financeiras, por guias próprias.

A ação penal em todos os casos é pública incondicionada.

9. ART. 317. CORRUPÇÃO PASSIVA

Nos termos do art. 317, *solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem* é crime punido com reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Permite-se o acordo de não persecução penal. A tutela se volta à moralidade administrativa.

O agente poderá praticar o crime por 3 condutas diferentes:

Solicitar vantagem indevida: a conduta inicial parte do funcionário público, fazendo o pedido. Lembrar da diferença entre solicitação (mero pedido) e exigência (ameaça com potencial intimidador).

Receber vantagem indevida: a conduta inicial parte do particular, que oferece a vantagem.

Aceitar promessa de vantagem indevida: a conduta inicial parte do particular, que faz a promessa da vantagem.

Segundo o §1º, a pena é aumentada de terça parte, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário:

- Retarda qualquer ato de ofício
- Deixa de praticar qualquer ato de ofício



- Pratica ato de ofício infringindo dever funcional

Essa causa de aumento é muito recorrente em provas de concurso. Tais situações não são elementares do *caput*, mas caso se aperfeiçoem, a pena é incrementada na terceira fase da dosimetria.

Configura-se o crime ainda que a vantagem seja entregue ou prometida não diretamente ao funcionário público, mas a um familiar seu (esposa, filhos).

9.1. CLASSIFICAÇÃO DA CORRUPÇÃO PASSIVA

Corrupção imprópria: ocorre quando visa a prática de um ato legítimo. Exemplo: funcionário aceita a vantagem para fazer o ato mais rápido. Em outras palavras, o agente faz o certo, mas de forma mais célere, ou de forma a beneficiar o indivíduo que pagou a vantagem.

Corrupção própria: ocorre quando o agente recebe vantagem para a prática de um ato ilícito. Exemplo: receber vantagem para aprovar projeto lesivo ao meio ambiente.

A consumação do delito se dá no momento em que há solicitação da vantagem, quando a recebe ou quando aceita a promessa de vantagem. O crime é, portanto, formal ou de consumação antecipada.

Importa ressaltar que se observa, no presente caso, uma exceção pluralística à teoria monista quanto ao concurso de agentes (art. 29 do CP).

A regra no direito penal é no sentido de que todo indivíduo que concorre para o crime incide nas suas penas, na medida de sua culpabilidade. É a chamada teoria monista ou unitária, prevista no art. 29 do CP. Todavia, há exceções na parte especial.

Assim, se um funcionário aceita promessa de vantagem feita por particular para praticar determinado ato, em relação ao servidor, o tipo é o do art. 317 (corrupção passiva). Em relação ao particular, este incidirá na corrupção ativa, prevista no art. 333 do CP.

A corrupção passiva independe da ativa na figura “solicitar”. Já nas formas “receber” e “aceitar” a conduta inicial é do particular e se observa a exceção à teoria monista.

Na conduta “solicitar” não há a participação do particular, a iniciativa é do funcionário público. No momento da solicitação, o particular pode ou não atender ao pedido. O particular não comete crime.

Nas formas “receber” e “aceitar”, o particular é quem oferece a vantagem ou faz promessa do proveito ao servidor público. Nessa situação, o particular incide na conduta do art. 333 do CP.

Não se aplica o princípio da insignificância, não importando o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida.

Segundo decidiu o STJ, o crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada.

Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de “ato de ofício”.

A expressão “ato de ofício” aparece apenas no *caput* do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no *caput* do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão “ato de ofício” figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo. (STJ. 6ª Turma. REsp 1.745.410-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acórd. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/10/2018).

No art. 317, § 2º, está prevista a **corrupção passiva privilegiada**. O funcionário age com menor reprovabilidade, cedendo a pedido ou influência de outrem. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.



O crime é material, pois se mostra necessária a produção do resultado naturalístico para a consumação do crime. Diferencia-se da prevaricação (art. 319), na qual o funcionário tem a especial finalidade de satisfazer interesse ou sentimento **pessoal**. Na corrupção passiva privilegiada, o sujeito cede a influência ou pedido de **terceiro**.

A ação penal, em todos os casos, é pública incondicionada.

10. ART. 318. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO

Conforme dispõe o art. 318, facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334) é delito punido com reclusão, de três a oito anos, e multa. Admite-se o acordo de não persecução penal.

É um exemplo de crime remetido. Deve-se complementar o preceito primário do tipo penal com o art. 334 (descaminho) e 334-A (contrabando), ambos do CP.

Ademais, observa-se mais uma hipótese de **exceção à teoria monista ou unitária quanto ao concurso de agentes**. O funcionário público responde pela figura do art. 318, que é mais grave, em razão da sua condição funcional, enquanto o particular incidirá no art. 334 ou 334-A do CP.

Descaminho é a conduta de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de impostos de importação, exportação ou consumo.

Contrabando é a importação ou exportação de mercadoria proibida no país.

Não se admite a modalidade culposa. Não se exige especial fim de agir, basta o dolo.

O crime é formal, pois sua consumação independe do resultado naturalístico. O delito já se consuma com a intenção de facilitar o contrabando ou descaminho, ainda que estes não se aperfeiçoem.

A competência é da Justiça Federal.

A ação penal é pública incondicionada.

11. ART. 319. PREVARICAÇÃO

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal é a figura descrita no art. 319, punida com detenção, de três meses a um ano, e multa. É infração de menor potencial ofensivo.

Trata-se de um **crime funcional próprio**, pois se desaparecer a elementar funcionário público, o delito se transforma em um indiferente penal.

O tipo é misto alternativo, vez que pode ser praticado por mais de uma conduta, a saber, retardar ou deixar de praticar.

A expressão *indevidamente* é elemento normativo do tipo, exigindo análise pelo magistrado no caso concreto.

Exige-se a constatação do especial fim de agir, revelado na expressão *“para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”*. Dessa forma, é **indispensável que haja o dolo específico para configurar o crime**.

Pratica prevaricação o funcionário público que se recusa a cumprir mandado judicial referente a ato de sua atribuição legal. Não se trata de desobediência (art. 330 do CP), vez que esta somente pode ser praticada pelo particular ou por funcionário que receba ordens não relacionadas às suas funções.

O crime é formal. Para a consumação basta a intenção de satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, ainda que o resultado não se concretize.

Difere da corrupção passiva privilegiada, pois não há pedido, nem influência. O funcionário age ilicitamente para atender a sentimento ou interesse pessoal.

A ação penal é pública incondicionada.



12. ART. 319-A. PREVARICAÇÃO IMPRÓPRIA OU NOS PRESÍDIOS

Nos termos do art. 319-A, *deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo* é conduta punida com detenção, de três meses a um ano. Apesar da crítica doutrinária, a infração é de menor potencial ofensivo, sendo aplicáveis os benefícios da Lei nº 9.099/95. Considera-se a pena muito branda à gravidade da conduta, acarretando uma proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado.

Apesar do legislador não ter conferido um *nomen juris* ao crime, é comumente chamado de prevaricação imprópria ou nos presídios. Foi introduzido no CP pela Lei nº 11.466/2007.

O indivíduo custodiado que se achar portando aparelho telefônico ou similar não responde pelo art. 319-A, pois essa previsão se dirige ao diretor de penitenciária ou agente público. Ao preso caberá a atribuição de falta grave no curso da execução penal, com todas as repercussões inerentes (art. 50, inc. VII, da LEP).

É indiferente se tratar de preso provisório ou definitivo.

Trata-se de crime omissivo próprio ou puro, de mera conduta, que se consuma com a abstenção do dever legal, sendo dispensável o efetivo acesso do interno ao aparelho. É, assim, incompatível com o *conatus*.

A ação penal é pública incondicionada.

13. ART. 320. CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA

Diz o art. 320 que haverá crime na conduta de *deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente*. A pena é de detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo.

Só poderá praticar o funcionário público (crime próprio), hierarquicamente superior ao servidor infrator. O sujeito passivo é o Estado.

A pena será aumentada da terça parte quando o autor do crime for ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, nos termos do art. 327, § 2º, do CP.

Se o superior se omite por um sentimento diverso da indulgência, poderá haver outro crime, como o de prevaricação.

O crime apresenta somente a forma dolosa. É omissivo próprio ou puro, sendo assim incompatível com a tentativa.

A ação penal é pública incondicionada.

14. ART. 321. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA

Segundo o art. 321, haverá crime na conduta de *patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário*. A pena é de detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo, cabendo transação penal e suspensão condicional do processo.

Tutela-se a moralidade administrativa. Funcionários públicos não devem, valendo-se do cargo, patrocinar interesse privado em detrimento da Administração Pública.

O sujeito ativo é o funcionário público (crime próprio). Sujeito passivo é o Estado.



Patrocinar significa defender, advogar, pleitear. Não importa se o interesse patrocinado é lícito ou ilícito. Não se exige para a consumação a prática de ato de ofício, nem a obtenção de vantagem. Não se pune a forma culposa.

O parágrafo único estabelece que, se o interesse particular patrocinado perante a administração é ilegítimo, a pena será de detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Continuará sendo infração de menor potencial ofensivo.

A advocacia administrativa não se estende ao funcionário público que patrocina o seu próprio direito.

A Lei nº 8.666/93 tem disposição específica quando se tratar de licitações.

A ação penal é pública incondicionada.

15. ART. 322. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA

Segundo o art. 322, configura violência arbitrária a conduta de *praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la*.

A pena é de detenção, de 6 meses a 3 anos, **além da pena correspondente à violência**. Cabe apenas a suspensão condicional do processo. Cometido com violência, não será possível o acordo de não persecução penal.

Alguns doutrinadores defendem ter sido o tipo revogado pela Lei nº 4.898/65, esta revogada pela Lei nº 13.869/19. Todavia, o STF entende que tal dispositivo **não foi revogado pela Lei de Abuso de Autoridade**.

Segundo Rogério Sanches, quando presente o abuso de autoridade, acompanhado de violência, o art. 322 do CP atuará como soldado de reserva, deixando de incidir quando o fato se subsumir ao disposto na lei especial (Lei nº 13.869/19).⁷⁶

O sujeito ativo é o funcionário público (crime próprio). Sujeito passivo é o Estado (Administração Pública), mas também o indivíduo submetido ao abuso.

Para haver o crime, a violência deve ser arbitrária, motivo pelo qual não abrange a violência aplicada legalmente, como no caso do art. 292 do CPP (resistência à prisão).

O crime se consuma com o emprego da violência. Se causar lesões corporais ou morte, haverá o somatório das penas (cúmulo material).

A ação penal é pública incondicionada.

16. ART. 323. ABANDONO DE FUNÇÃO

Segundo o art. 323, haverá crime na conduta de *abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei*. A pena é de detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo.

É preciso tutelar o regular desenvolvimento das atividades administrativas.

Trata-se de norma penal em branco, sendo necessário verificar os casos que a lei permite o abandono. Ademais, o tipo restringe-se aos cargos públicos. Não configura o crime o abandono de função ou emprego público.

O sujeito ativo é o funcionário ocupante de cargo público (crime próprio).

Sujeito passivo é o Estado, a Administração Pública, prejudicada com a interrupção da atividade.

É necessário que o funcionário público abandone o cargo por um período juridicamente relevante.

⁷⁶ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal. Volume Único. Parte Especial**. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 896.



É possível que o sujeito abandone o cargo sem abandonar o local de trabalho. Basta pensar no caso de um funcionário que permanece no local de trabalho com os braços cruzados, sem fazer absolutamente nada.

Trata-se de um crime omissivo próprio, pois o agente público deixa de fazer o que ele tinha por dever de fazer. Não é cabível a tentativa.

Somente se pune a forma dolosa. A negligência no exercício das funções poderá ser punida no âmbito administrativo.

O §1º estabelece que, se do fato resulta prejuízo público, a pena é de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Trata-se da forma qualificada.

Segundo o §2º, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, a pena será de detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

A faixa de fronteira está definida na CF (art. 20, § 2º. É a extensão de 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres). A punição mais rigorosa está justificada pela necessidade de defesa do território nacional.

A ação penal é pública incondicionada.

17. ART. 324. EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE ANTECIPADO OU PROLONGADO

Segundo o art. 324, configura o crime a conduta de *entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar no exercício de função pública, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso*.

A pena é de detenção, **de 15 dias a 1 mês**, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo.

Sujeito ativo do crime é o funcionário público que antecipa ou prolonga o exercício da função.

É a qualidade do agente, pessoa ligada à Administração Pública, que vai distinguir o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado do crime de usurpação de função pública (art. 328). Isso porque no crime de usurpação de função pública o sujeito é um particular, alheio e sem qualquer ligação com a Administração.

São condutas do tipo:

- Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Nessa hipótese, o sujeito ignora a diplomação, posse, perícia médica.
- Continuar no exercício de função pública, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. No caso, há uma decisão na esfera administrativa que exonerou o sujeito. Se fosse uma decisão judicial, haveria o crime do art. 359 do CP. A comunicação deve se dar por meio oficial. Trata-se de norma penal em branco.

O crime somente é punido na forma dolosa.

A ação penal é pública incondicionada.

18. ART. 325. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL

Constitui o crime de violação de sigilo funcional a conduta de *revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação*. A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

É crime subsidiário expresso. Também é infração de menor potencial ofensivo, cabendo transação penal e suspensão condicional do processo.

O § 1º estabelece que, nas mesmas penas de detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave, incorre quem:



I- permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

O §2º estabelece que, se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem, a pena é de reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. O exaurimento do delito é punido de forma mais gravosa.

O sujeito ativo é o funcionário público (crime próprio). Mesmo o funcionário público aposentado poderá cometer o crime, assim como o funcionário público afastado.

Sujeito passivo é o Estado (Administração Pública) e, eventualmente, o indivíduo lesado.

O delito se consuma quando um terceiro não autorizado toma conhecimento do segredo. Se vai gerar prejuízo ou não, não interessa para a consumação. O crime é formal. Exige-se que o agente tenha ciência do caráter secreto do fato revelado.

A ação penal é pública incondicionada.

19. ART. 326. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE PROPOSTA DE CONCORRÊNCIA

Este artigo foi revogado tacitamente pelo art. 94 da Lei nº 8.666/93, que tipifica a mesma conduta, entretanto, estabelece pena mais grave.

20. ART. 327. FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Nos termos do art. 327, considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Ao início do estudo dos crimes contra a Administração Pública foram feitas as principais observações sobre o conceito penal de funcionário público.

Na classificação, incluem-se os titulares de cargo público efetivo, os empregados públicos (regidos pela CLT), os ocupantes de cargo em comissão (providos sem concurso) e os servidores temporários (contratados sem concurso, por tempo determinado).

QUESTÕES

1- (CEBRASPE – TJSC – 2019) Joaquim, fiscal de vigilância sanitária de determinado município brasileiro, estava licenciado do seu cargo público quando exigiu de Paulo determinada vantagem econômica indevida para si, em função do seu cargo público, a fim de evitar a ação da fiscalização no estabelecimento comercial de Paulo. Nessa situação hipotética, Joaquim praticou o delito de

- a) constrangimento ilegal.
- b) extorsão.
- c) corrupção passiva.
- d) concussão.
- e) excesso de exação.

Gabarito: D



CAPÍTULO 65 — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

São crimes comuns, que podem ser praticados por qualquer pessoa. Não se inserem no rol dos crimes funcionais.

Podem ser cometidos por funcionários públicos, quando não investidos na função pública desempenhada.

Não se aplica a eles o rito especial previsto no CPP.

1. ART. 328. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA

Constitui crime a conduta de *usurpar o exercício de função pública*. A pena é de detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Cabe transação penal e suspensão condicional do processo.

O parágrafo único prevê que, se do fato o agente auferir vantagem, a pena será de reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. É a modalidade qualificada.

Qualquer pessoa pode praticar (crime comum).

Diferentemente do que ocorre no crime de exercício funcional ilegal, o agente não possui qualquer vínculo com a Administração Pública ou, caso possua, suas funções são absolutamente estranhas à função usurpada.

Usurpar significa apoderar-se indevidamente ou exercer de forma ilegítima uma função pública. Para a caracterização do crime, é essencial que o usurpador exerça atos inerentes à função pública. Não basta que o indivíduo se arrogue na função. Deve praticar atos de ofício como se legitimado fosse.

Se o sujeito se limita a se apresentar como funcionário público resta caracterizada a contravenção penal descrita no art. 45 do Dec. Lei nº 3.688/41

Na figura do *caput*, o crime é formal, pois independe de efetivo dano patrimonial à Administração ou a obtenção de qualquer tipo de vantagem.

Já a previsão qualificada do parágrafo único é crime material, pois se exige a obtenção de vantagem.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 329. RESISTÊNCIA

Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio é crime punido com detenção, de dois meses a dois anos. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

A tutela penal se volta à preservação da autoridade e do prestígio da Administração Pública e, via de consequência, o regular desenvolvimento das atividades.

A resistência consiste em forma mais grave de desobediência (art. 330), já que requer a prática de violência ou ameaça. É também chamada de “desobediência belicosa”.

A violência deve ser dirigida à pessoa (funcionário público ou particular que o auxilia). Não se considera a violência dirigida contra objetos. Exemplo: desferir chutes ou socos contra o Oficial de Justiça que tenta realizar a citação.

A violência contra objetos (coisas) poderá caracterizar a ameaça (art. 147 CP) e crime de dano contra o patrimônio público (art. 163 do CP).

A resistência passiva, como a inação, a fuga, a manifestação oral de recalcitrância não tipificam a resistência, mas sim a desobediência. Exemplo: particular que se recusa a abrir a porta para o policial que tem mandado para ingressar.

Ameaça é a promessa de mal injusto e factível, apta a amedrontar o homem médio (comum).



Rogar pragas não caracteriza ameaça, diante da impossibilidade de concretização. Não consiste ameaça dizer que vai representar perante os superiores ou em órgão correicional, uma vez que se trata do direito de petição, constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXIV, CF).

A jurisprudência entende que eventuais crimes de desobediência ou de desacato são absorvidos pelo delito de resistência, que é mais grave, pois podem ser um meio para a prática do crime de resistência. Deverá ser feita a análise no caso concreto.

A violência ou ameaça devem ocorrer durante a prática do ato. Se antes ou depois, poderá caracterizar outros tipos penais, como a lesão corporal.

Age em legítima defesa o funcionário público que se vale de violência moderada contra aquele que resiste violentamente à execução regular de um ato legal (art. 25 do CP). Hipótese de excludente de ilicitude.

É possível que a resistência seja exteriorizada por terceira pessoa, como um amigo ou parente do destinatário da ordem.

Cuspir, lançar urina ou fezes caracteriza desacato, pois o intuito é de ofender, humilhar, e não ofender a integridade física.

O § 1º prevê a forma qualificada. Se o ato, em razão da resistência, não se executa a pena passa a ser de reclusão, de um a três anos. Trata-se de crime de médio potencial ofensivo. O exaurimento do delito é tratado de forma mais gravosa.

Por fim, o § 2º estabelece que as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 330. DESOBEDIÊNCIA

Segundo dispõe o art. 330, *desobedecer a ordem legal de funcionário público* deve ser conduta punida com detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

Não há o emprego de violência ou ameaça, mas desobediência passiva.

Deve haver a notificação pessoal do responsável pelo cumprimento da ordem. Se o indivíduo não sabe que deve cumprir a ordem, não incidirá no crime de desobediência.

O crime se tipifica se houver a intenção deliberada de não cumprir a ordem. O crime é doloso. Não se admite a forma culposa.

Segundo o STJ, o crime de desobediência é subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual. Trata-se de reflexo da subsidiariedade do direito penal, que é a *ultima ratio*.

Não haverá crime se a ordem for materialmente ou formalmente ilegal. Exemplo: um mandado judicial não poderá ser cumprido no período noturno. Assim, se o destinatário da ordem se recusar a cumprir a ordem, não haverá crime.

O crime se consuma com o desatendimento da ordem, o que pode ocorrer por ação ou omissão.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 331. DESACATO

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela é delito punido com detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo.

Dirige-se a proteção ao agente público, no exercício legítimo de seu cargo, contra investidas violentas ou ameaçadoras de particulares.

Recentemente, houve importante discussão quanto à descriminalização do desacato.



Segundo recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os países aderentes do Pacto de San José da Costa Rica devem eliminar de suas leis a figura do desacato, pois o crime representaria uma posição de superioridade do funcionário público perante o particular, que ficaria limitado em sua liberdade de pensamento e expressão.

Embora a 5ª Turma tenha proferido uma decisão isolada nesse sentido em 2016, a 3ª Seção do STJ não acatou tal entendimento e assentou que desacatar funcionário público no exercício da função continua a ser crime, nos termos do art. 331 do CP.

Desacatar é menosprezar a função pública. Ofende-se o funcionário com o objetivo de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa.

O crime é de forma livre, compatível com os mais diversos meios de execução.

A ofensa deve ser proferida na presença do funcionário público. Exemplos: chamar servidores públicos de vagabundos, corruptos, cuspir, fazer gestos obscenos.

O delito é formal, consumando-se quando o funcionário público toma conhecimento do ato humilhante.

A embriaguez, voluntária ou culposa, não afasta a responsabilidade criminal, assim como também a emoção não afasta o crime.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 332. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Esta é a conduta tipificada pelo art. 332, punida com reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Admite o acordo de não persecução penal.

Nos termos do parágrafo único, há causa de aumento de pena se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

O bem jurídico tutelado é o prestígio da Administração Pública

O crime se assemelha ao estelionato, pois o agente ilude e frauda, alegando um prestígio que não tem ou assegurando um êxito que não está ao seu alcance.

O tipo é misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois pode ser praticado mediante solicitar, exigir, cobrar ou obter.

Se o agente realmente possuir influência perante o funcionário público e vier a corrompê-lo, o crime será o de corrupção ativa, previsto no art. 333.

Outros nomes para o crime descritos na doutrina: gabolice mendaz, bazófia ilusória, jactância enganosa.

O crime é praticado apenas na forma dolosa. Não se exige especial fim de agir.

O delito é comum ou geral. O sujeito passivo é o Estado e, de forma mediata, o comprador da influência. Ainda que constatada a torpeza bilateral, isto é, ainda que o comprador da falsa influência objetivasse um fim ilícito, não deixará a condição de vítima.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 333. CORRUPÇÃO ATIVA

Nos termos do art. 333, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício é crime punido com reclusão, de dois a doze anos, e multa. Admite-se o acordo de não persecução penal.

O parágrafo único estabelece causa especial de aumento de pena, de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.



A conduta deste tipo penal é do particular. Se o funcionário público pede a vantagem indevida e o particular dá a vantagem a ele, não haverá crime deste último, pois o tipo fala apenas em “oferecer” ou “prometer”. O particular será vítima da corrupção passiva (art. 317 do CP), uma vez inviável a analogia *in malam partem*. O particular só comete a corrupção ativa se oferece ou promete.

A existência da corrupção ativa independe da corrupção passiva e vice-versa. Há uma relativa independência entre os tipos penais. Conforme já estudado, os tipos representam exceção pluralística à teoria unitária ou monista quanto ao concurso de agentes (art. 29 do CP): corrupção passiva, prevista no art. 317 CP, praticada por funcionário público e corrupção ativa, estabelecida no art. 333 CP, quando praticada por particular.

O tipo é misto alternativo, pois pode ser praticado mediante oferecer ou prometer. É também de forma livre.

Pratica o crime quem entrega quantia ao funcionário público, bem como aquele que deixa sobre a mesa envelope com dinheiro.

O delito é formal: consuma-se com o oferecimento ou a promessa da vantagem, independentemente da aceitação pelo funcionário público.

Exige-se que o oferecimento ou promessa de vantagem sejam anteriores à prática do ato de ofício. Inexiste a corrupção ativa subsequente.

O particular que pede ao funcionário público que “dê um jeitinho” não pratica crime se não há o oferecimento ou promessa de vantagem indevida. Se o funcionário “der o jeitinho”, violando dever funcional, poderá incidir no art. 317, § 2º (“ceder a pedido de outrem” – corrupção passiva privilegiada, pena de detenção), sendo o particular partícipe. Porém, se o funcionário nada faz, a conduta será atípica para ambos.

A “carteirada”, ato do funcionário público consistente na exibição de seu documento funcional a um particular ou outro funcionário público, não caracteriza corrupção ativa, pois não há oferecimento ou promessa de vantagem. Em face do particular, poderá se caracterizar o abuso de autoridade (Lei nº 13.869/19).

Dar, oferecer ou prometer vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação caracteriza o crime do art. 343 do CP (crime contra a administração da justiça), em razão do princípio da especialidade, e não o de corrupção ativa do art. 333.

Segundo decidiu o STJ, o pagamento da diferença do imposto devido, antes do recebimento da denúncia, não extingue a punibilidade pelo crime de corrupção ativa atrelado ao de sonegação fiscal. Exemplo: João, sócio de uma empresa, ofereceu e pagou propina ao fiscal para que pudesse recolher um valor menor de imposto. Assim, em vez de pagar R\$ 400 mil de imposto, João pagou apenas R\$ 100 mil. Os fatos foram descobertos. João praticou, em tese, corrupção ativa (art. 333 do CP) e sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Antes que a denúncia fosse oferecida, João pagou a diferença do imposto devido acrescido de multa, juros e correção monetária. Esse pagamento irá gerar a extinção do crime de sonegação fiscal, mas não da corrupção ativa que deverá ser julgada normalmente. (STJ. 6ª Turma. RHC 95.557-GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/06/2018. Informativo 631).⁷⁷

A ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 334. DESCAMINHO

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria é crime punido com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Admite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O contrabando foi deslocado para o tipo do art. 334-A com a Lei nº 13.008/14 e teve sua pena aumentada.

⁷⁷Fonte: Dizer o Direito. Acesso e disponibilidade: <https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2018/11/info-631-stj.pdf>



Iludir significa ludibriar, enganar, frustrar. Utiliza-se um meio fraudulento para mascarar a realidade.

O objeto material é o tributo não recolhido.

Tem-se uma lei penal em branco homogênea, cujo complemento é fornecido por outra lei definidora dos impostos devidos pela entrada e saída de mercadorias do Brasil.

Nota-se, na presente hipótese, uma exceção à teoria unitária ou monista quanto ao concurso de agentes (art. 29 do CP). Conforme já estudado, o funcionário público que tem a função de impedir a conduta, mas facilita, pratica o crime do art. 318 (facilitação de descaminho, crime mais grave).

O descaminho também é chamado de contrabando impróprio, pois não se trata de mercadoria proibida.

O crime é formal. A consumação se dá com a fraude, no sentido de mascarar a realidade.

É desnecessário o prévio esgotamento da esfera administrativa. Assim, não é necessária a prévia constituição administrativa do débito fiscal para o início da ação penal pelo descaminho. Porém, a decisão administrativa ou judicial favorável ao contribuinte é questão prejudicial externa. Exemplo: anulação do auto de infração suspende o trâmite da ação penal, até que se resolva a questão no âmbito administrativo (art. 93 do CPP).

Aplica-se o princípio da insignificância ao delito em comento, em razão de sua natureza tributária.

Sobre o assunto, convém destacar o Tema 157 do STJ, estabelecido na análise de recursos repetitivos. A Corte fixou em R\$ 20 mil reais o valor máximo para incidência do princípio da insignificância no caso de crimes tributários federais e de descaminho. Anteriormente, o valor máximo considerado era de R\$ 10 mil reais.

A revisão foi necessária, entre outras razões, em virtude de decisões divergentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e do parâmetro fixado pelas Portarias nº 75 e 130 do Ministério da Fazenda.

O crime não admite modalidade culposa

Iludir o imposto incidente sobre o consumo de mercadoria, a exemplo do ICMS, é crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária), em razão do princípio da especialidade.

A Súmula 151 do STJ dispõe que a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens.

No art. 334, § 1º, tem-se o descaminho por equiparação ou assimilação. Recomenda-se a leitura do dispositivo legal.

O § 2º estabelece que equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Por fim, no § 3º, observa-se causa de aumento de pena se o descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Entende o STJ que a majorante se aplica inclusive aos crimes cometidos em voos regulares, e não apenas àqueles de natureza clandestina.

Segundo decidiu o STJ, compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira, permitida pela ANVISA, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação. STJ. Plenário. CC 159.680-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/08/2018. Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta (STJ. 3ª Seção. CC 160.748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2018. Informativo 631).

Cabe ressaltar que eventual pagamento do tributo não é apto a promover a extinção da punibilidade do descaminho.

A ação penal é pública incondicionada.



8. ART. 334-A. CONTRABANDO

Dispõe o art. 334-A do CP:

Importar ou exportar mercadoria proibida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;

II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente;

III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação;

IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira;

V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

A figura do *caput* admite o acordo de não persecução penal.

A conduta ora em comento é mais grave e reprovável que o descaminho, em razão de ser proibida a mercadoria.

O funcionário público que facilita o contrabando incidirá no art. 318 do CP.

O objeto material é a mercadoria, compreendida como qualquer bem móvel suscetível de comercialização. Não precisa ser necessariamente estrangeira. Pode ser de fabricação brasileira, desde que destinada exclusivamente à exportação.

Em regra, não é necessária perícia.

Por força do princípio da especialidade, quando se tratar de drogas, aplica-se o art. 33 da Lei nº 11.343/06 e, quando se tratar de armas, incide o art. 18 da Lei nº 10.826/03.

Quanto ao contrabando, não se aplica o princípio da insignificância, diferentemente do descaminho (art. 334 do CP) em razão da natureza proibida da mercadoria importada ou exportada. O crime em tela não tem natureza tributária.

O delito é formal: independe de resultado naturalístico para a sua consumação.

Não admite modalidade culposa e somente é praticado a título doloso.

A proibição da mercadoria pode ser absoluta ou relativa.

As figuras previstas no § 1º do art. 334 do CP são chamadas de contrabando por assimilação. Recomenda-se a leitura.

O art. 334, § 1º, IV trata de uma forma específica de receptação (art. 180 do CP).

Se a pessoa aceita adquirir, receber ou ocultar, no exercício de atividade comercial ou industrial, uma mercadoria de procedência estrangeira sem os documentos que atestam que ela foi introduzida regularmente ou com documentos falsos, estará fomentando o contrabando. Assim, o inciso pune a pessoa que pratica atividade comercial ou industrial envolvendo mercadoria de procedência estrangeira, que foi trazida para o Brasil de forma clandestina (sem que as autoridades soubessem) ou fraudulenta (enganando as autoridades).



À exemplo do descaminho, há causa de aumento de pena no § 3º em relação aos crimes cometidos em voos e embarcações. Uma parcela da doutrina defende que somente terá incidência ao transporte de natureza clandestina.

Segundo decidiu o STF, configura contrabando (e não descaminho) a conduta de importar, à margem da disciplina legal, arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola.

A importação de arma de pressão está sujeita à autorização prévia da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro e só pode ser feita por colecionadores, atiradores e caçadores registrados no Exército. Além disso, deve se submeter às normas de desembaraço alfandegário previstas no Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados.

Logo, trata-se de mercadoria de proibição relativa, sendo a sua importação fiscalizada não apenas por questões de ordem tributária, mas outros interesses ligados à segurança pública.

Não é possível aplicar o princípio da insignificância mesmo que a arma de ar comprimido importada seja de calibre inferior a 6 mm, já que este postulado é incabível para contrabando (STF. 2ª Turma. HC 131943/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 7/5/2019. Informativo 939).

A competência é da Justiça Federal.

A ação penal é pública incondicionada.

9. ART. 335. IMPEDIMENTO, PERTURBAÇÃO OU FRAUDE DE CONCORRÊNCIA

Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem é delito punido com detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cabendo transação e suspensão condicional do processo.

A doutrina discute se houve a revogação total ou parcial do dispositivo pela Lei de Licitações. No entanto, prevalece o entendimento de que houve uma **revogação parcial**, pois **haverá esse crime quando houver impedimento, perturbação ou fraude em hasta pública**, pois quando houver concorrência pública, aí incidirá o tipo penal da Le nº 8.666/93

Assim sendo, o dispositivo continua em vigor para os crimes cometidos em hasta pública.

Qualquer pessoa pode praticar, sendo crime comum. O Estado é o sujeito passivo.

O elemento subjetivo é o dolo, acrescido do especial fim de agir, que é a vontade de afastar o concorrente de participar desta hasta pública.

Conforme prevê o parágrafo único, incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida. É a chamada abstenção subornada. O delito é próprio, praticado pelo competidor.

A ação penal é pública incondicionada.

10. ART. 336. INUTILIZAÇÃO DE EDITAL OU DE SINAL

Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto é crime apenado com detenção, de um mês a um ano, ou multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cabendo transação e suspensão condicional do processo.

A tutela dirige-se ao regular desenvolvimento das atividades administrativas.

Qualquer pessoa pode praticar o delito, inclusive o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado.

Conspurar significa sujar, sem impedir completamente a leitura.



Não haverá crime se o edital já foi inutilizado ou não tem mais utilidade. Exemplo: edital com prazo vencido.

A ação penal é pública incondicionada.

11. ART. 337. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO

Segundo o art. 337, configura crime subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público. A pena é reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave. Admite-se o acordo de não persecução penal.

Trata-se de crime subsidiário expresso.

Qualquer pessoa pode praticar a conduta. O sujeito passivo é o Estado.

Se o sujeito ativo for advogado, que retirou o processo ou documento e não devolveu, o crime será do art. 356 do CP.

A ação penal é pública incondicionada.

12. ART. 337-A. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

O art. 337-A prevê o seguinte:

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 1º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

§ 2º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

I – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

§ 3º Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R\$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa.

§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social.

A tutela penal volta-se à fonte de custeio da previdência social. A pena cominada permite o acordo de não persecução penal.

Parcela da doutrina critica a alocação no CP, considerando as leis especiais que também tutelam a previdência social.

O crime é próprio, pois somente pode praticá-lo o responsável pelo lançamento das informações que o tipo relaciona. Porém, há decisão do STJ no sentido de considerá-lo comum, podendo figurar como autor qualquer pessoa, inclusive prefeitos. O sujeito passivo é a previdência social.



A perfeita tipificação exige um complemento, sendo uma **norma penal em branco heterogênea**. A Previdência Social deverá indicar as fichas e papéis que devem ser preenchidos, por exemplo.

A doutrina majoritária entende que o delito é omissivo próprio, motivo pelo qual não admite tentativa.

O STJ tem precedente no sentido de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de sonegação previdenciária e de apropriação indébita previdenciária, apesar de serem distintos.

O elemento subjetivo é o dolo de não incluir os dados necessários nos lançamentos. Mais do que o dolo geral, exige-se o elemento subjetivo especial de agir, que é a finalidade de fraudar a previdência social.

O crime se consuma com a redução ou supressão. Nesse caso, apesar do especial fim de agir, o crime é material, já que se exige a efetiva supressão ou redução do valor devido.

A punibilidade resta extinta se o agente:

- Espontaneamente confessa e presta as informações devidas antes do início da execução fiscal.

- Promove o pagamento do tributo ou da contribuição social antes do recebimento da denúncia.

Se o pagamento do valor devido ocorrer após o início da ação penal, ou após o recebimento da denúncia, só incidirá a atenuante genérica do art. 65, III, b, do CP.

A competência é da Justiça Federal, exceto na hipótese do art. 149, § 1º, da CF.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 66 — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

Primeiramente, é necessário conceituar o funcionário público estrangeiro para fins penais.

Segundo o art. 337-D do CP, considera-se **funcionário público estrangeiro**, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.

O parágrafo único diz que se equipara a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

1. ART. 337-B. CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL

O art. 337-B prevê como crime as condutas de *prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional*. A pena estabelecida é de reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. Cabe suspensão condicional do processo e o acordo e não persecução penal.

No parágrafo único, verifica-se que a pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

O objeto jurídico é o regular desenvolvimento das relações comerciais entre o Brasil e demais países.

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, brasileiro ou estrangeiro (crime comum). O sujeito passivo é por uns considerada a administração pública lesada. Outros entendem que é a credibilidade das relações comerciais internacionais. De qualquer sorte, o crime é vago.

Não é necessário que a vantagem seja direta, podendo ser oferecida, prometida ou dada de maneira indireta, implícita.

É crime formal (prometer e oferecer), motivo pelo qual o efetivo recebimento da vantagem é mero exaurimento e não pressuposto da consumação, bastando que a vantagem chegue ao conhecimento do funcionário público estrangeiro. Na modalidade “dar”, o crime é material, só se consumando quando o agente recebe a vantagem.

A tentativa é possível, nas três modalidades. Não se admite a forma culposa. Exige-se, ainda, a finalidade especial de agir, consistente na intenção de ver o ato ser praticado, omitido ou retardado (dolo específico).

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 337-C. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL

Nos termos do art. 337-C, *solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional* é crime punido com reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Admite-se o acordo e não persecução penal.

O parágrafo único dispõe que a pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.

O bem jurídico é o mesmo do artigo anterior, aplicando-se, quanto aos sujeitos, as mesmas disposições.

Ademais, o tipo é idêntico ao previsto no art. 332, com especializantes.



No crime em comento, Fulano chega para Beltrano e diz: “Meu amigo, me dá uma prata aí que eu vou falar com o Pedrinho, que trabalha lá no Consulado do Chile, pra ele adiantar a tua parada.”. Entretanto, o infrator não pretende, efetivamente, fazer o que prometeu. Ele pretende ludibriar o Beltrano, que vai comprar a influência. Se o indivíduo, de fato, possui influência sobre o funcionário público estrangeiro e pretende utilizá-la, não pratica este delito.

O elemento subjetivo também é o dolo, não se admitindo na forma culposa. Há finalidade especial de agir, consistente na intenção de obter a vantagem “*para si ou para outrem*”.

O crime se consuma com a mera solicitação, exigência ou cobrança da vantagem (crime formal). Na modalidade “obter”, o crime é material. A tentativa é admitida.

Há uma causa de aumento de pena (majorante), que incidirá caso o infrator alegue que está pedindo a vantagem, mas que parte dela se destina ao funcionário público que se pretende “comprar”.

A ação penal é pública incondicionada.



CAPÍTULO 67 — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Os crimes contra a administração da Justiça não tutelam apenas a atividade do Poder Judiciário, mas as funções relacionadas à prestação Jurisdicional, inclusive as de natureza policial.

1. ART. 338. REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO

Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso é crime punido com reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

O bem jurídico tutelado é o regular desenvolvimento das atividades da Justiça, bem como a soberania das decisões. Na verdade, quando se fala em soberania das decisões, não se fala, somente, de ato do Judiciário, eis que **o ato administrativo de expulsão é privativo do Presidente da República**.

O sujeito ativo **somente poderá ser o estrangeiro expulso do país**. Doutrina afirma ser um **crime de mão própria**, pois a execução do delito não pode ser delegada a uma terceira pessoa.

A participação é admissível, na modalidade **auxílio**, desde que o comparsa conheça a condição de estrangeiro expulso, nos termos do art. 30 do CP.

Como o núcleo é **reingressar** no território nacional, **pressupõe 3 requisitos**:

- Ter o estrangeiro sido expulso por ato do Presidente da República
- Ter saído do Brasil
- Ter retornado ao Brasil

A doutrina diverge com relação ao momento da entrada no país (reingresso), mas a posição que prevalece é a de que o tipo penal só abrange o território propriamente dito, não abrangendo o território brasileiro por extensão.

É um **crime material**, pois a consumação se dá com o reingresso. É admissível a tentativa.

Pode o agente praticar o crime em estado de necessidade, como é o caso de perseguição política no país de origem, motivo pelo qual constituiria causa de exclusão da ilicitude.

Parcela da doutrina e parte da jurisprudência vêm entendendo que o **crime é permanente**. Logo, caberia prisão em flagrante a qualquer momento, ainda que o agente tenha retornado ao país há cinco anos, por exemplo. Além disso, haveria a aplicação da súmula 711 do STF.

A ação penal é pública incondicionada e a competência da Justiça Federal.

2. ART. 339. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

Nos termos do art. 339, *dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente* acarreta pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Busca-se tutelar o regular desenvolvimento das atividades policiais e administrativas (correlatas à Justiça). Protege-se, subsidiariamente, a honra da pessoa ofendida.

O crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se de crime comum.

O promotor que promover denúncia contra alguém que sabe inocente poderá cometer este crime, pois deu causa à instauração de uma ação penal.

No caso de se imputar fato definido como crime a alguém, gerando a instauração de algum dos procedimentos previstos no tipo penal, o agente somente responderá pela denúncia caluniosa, pois esta absorve o crime de calúnia. Por esse motivo, o tipo em estudo é também chamado de calúnia qualificada.

Segundo o STJ, se, em razão da comunicação falsa de crime, houve a instauração de inquérito policial, sendo a falsidade descoberta durante os atos investigatórios nele realizados, o delito



cometido é o de denúncia caluniosa, previsto no art. 339 do CP. O fato de o indivíduo apontado falsamente como autor do delito inexistente não ter sido indiciado no curso da investigação não é motivo suficiente para desclassificar a conduta para o crime do art. 340 do CP (Informativo 592).

Para a consumação do delito é necessário que a autoridade adote alguma providência, ainda que não instaure o inquérito policial ou qualquer outro procedimento.

A doutrina discute se, para fins de denúncia caluniosa, o Ministério Público deva estar subordinado à conclusão do procedimento ao qual o denunciante injustamente deu causa. A doutrina majoritária entende que sim, estabelecendo que é preciso primeiro concluir que a denúncia era falsa, para após o MP oferecer denúncia pela denúncia caluniosa.

A tentativa é possível quando a queixa ou denúncia é rejeitada, ou então quando a autoridade policial não dá início a qualquer procedimento investigatório, ou ainda quando a denúncia é feita por escrito e este é interceptado antes de chegar ao conhecimento da autoridade.

No caso da instauração de processo penal, é necessário que o agente saiba que o denunciado é inocente, não bastando que ele tenha dúvidas. Nesse caso, se consuma com o recebimento da ação penal

Somente responderá por este crime o agente que der causa à ação de improbidade, imputando a outra pessoa, fato definido também como crime.

Cezar Roberto Bitencourt afirma que, se o agente dá causa à instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, imputando alguém a prática de um crime, não tipifica o delito de denúncia caluniosa, pois a CPI não está dentre os procedimentos previstos na lei penal.

A denúncia caluniosa contra mortos é possível?

Não se pune a denúncia caluniosa contra os mortos, visto que, nesse caso, já estaria extinta a punibilidade em relação ao fato falsamente imputado ao morto.

O crime não se configura se o fato criminoso que o agente imputa à outra pessoa já não é mais considerado crime (houve *abolitio criminis*), ou se já foi extinta a punibilidade.

O elemento subjetivo é o dolo, não admitindo a forma culposa.

A doutrina majoritária entende que não cabe dolo eventual, mas apenas o dolo direto, pois quando a lei diz que o agente deve “*saber que o ofendido é inocente*”, exclui a possibilidade de dolo eventual.

Atente-se que compete à Justiça Federal julgar denúncia caluniosa quando o delito falsamente imputado foi pela Justiça Federal apurado, ou quando o servidor federal foi acusado da prática de um delito funcional.

No termos do § 1º, a pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.

Por fim, conforme o § 2º, a pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 340. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAÇÃO

Segundo o art. 340, *provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado* é delito punido com detenção, de um a seis meses, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo.

Não se confunde com a denúncia caluniosa, pois nesta se imputa a prática de uma infração à alguém, mas sabe-se que não foi o imputado. Na comunicação falsa não há imputação falsa a alguém, mas há a comunicação à autoridade sobre uma infração penal. A comunicação é falsa, provocando a ação da autoridade.

No tipo em estudo, comunica-se um crime que não ocorreu. Vejam que, aqui, o fato não ocorreu. Diversamente do crime anterior, o agente não aponta um culpado, não individualiza um suposto infrator.



O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (crime comum), sendo sujeito passivo o Estado.

Se a comunicação falsa de crime se der perante uma seguradora, poderá se caracterizar o crime de estelionato (art. 171, §2º, V, CP).

A doutrina majoritária entende que a comunicação falsa de crime perante policiais militares não configura o delito em questão, eis que não são autoridade para estes fins, já que instauração de investigação compete à Polícia Judiciária.

O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de comunicar à autoridade a ocorrência falsa de um crime. Parte da doutrina entende, ainda, que deve haver a especial finalidade de agir, consistente na intenção de ver a autoridade agir e praticar algum ato investigatório.

O crime se consuma no momento em que a autoridade, em razão da comunicação falsa, pratica algum ato, não sendo necessária a instauração do inquérito. Admite-se a tentativa.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 341. AUTOACUSAÇÃO FALSA

Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem é crime punido com detenção, de três meses a dois anos, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo.

O crime é comum. Não pratica o crime quem assume sozinho a prática de um crime do qual participou.

O objeto não pode ser contravenção penal. A conduta punida é a de autoacusar-se falsamente, perante a autoridade competente (autoridade policial, Ministério Público ou Judiciário).

Ainda que o motivo seja nobre, como no caso de evitar a punição de um filho, haverá o crime. Comete o crime, por exemplo, aquele que, em sede de interrogatório (policial ou judicial) confessa crime que não cometeu. Se a confissão se deu sob coação, há inexigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpabilidade, logo, não há crime.

O crime se consuma no momento em que a autoridade toma conhecimento da autoacusação falsa, pouco importando se toma qualquer providência. A tentativa é admissível.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 342. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA

Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral acarreta pena de reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Permite-se o acordo de não persecução penal.

O sujeito ativo somente pode ser a testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou o intérprete. Assim, o crime é de mão própria e não admite coautoria, exceto quanto à falsa perícia. O sujeito passivo é o Estado.

O compromisso de dizer a verdade não é elementar do tipo de falso testemunho. Por esta razão, há quem entenda que o informante poderá cometer o crime. Apesar da grande divergência, a doutrina majoritária entende que testemunha sem compromisso de dizer a verdade (informante) comete o crime, visto que CP não distingue testemunha compromissada e não compromissada para fins de aplicação deste tipo penal.

Ademais, a vítima não pode ser sujeito ativo do delito, pois não é testemunha. O ofendido não presta depoimento, e sim declarações.

Se a testemunha proferir falso testemunho com a intenção de não produzir prova contra si, pois a verdade poderia gerar um futuro processo contra ela, também não pratica o crime.

No crime de falsa perícia, cabe tanto a coautoria quanto a participação. Exemplo: perícia feita por dois peritos que, em conluio, decidem elaborar laudo falso.



O tipo objetivo é de ação múltipla (ou plurinuclear), pois pode ser praticado de diferentes formas (fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade).

Ainda que o processo seja anulado por algum vício, parte da doutrina entende que o crime remanesce. Todavia, se o processo for anulado por causa diversa da falsa perícia ou do falso testemunho, de sorte que estes não mais subsistam, não mais estará configurado o delito.

Trata-se de crime formal, que se consuma no momento em que o agente faz a declaração ou perícia falsa, pouco importando se dessa afirmação falsa sobrevém algum resultado.

A tentativa só é admitida, pela maioria da doutrina, no caso de falsa perícia, pois no caso de falso testemunho, em razão da oralidade, não pode haver fracionamento do ato.

Se o falso testemunho tiver sido prestado por uma testemunha ouvida por carta precatória, o órgão competente para processar e julgar será o juízo deprecado.

O § 1º prevê majorante. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Por sua vez, o § 2º prevê uma hipótese de extinção da punibilidade, que ocorrerá caso o agente se retrate da declaração falsa antes da sentença. A doutrina entende que a retratação, para gerar a extinção da punibilidade, deve ocorrer antes da sentença recorrível. Entretanto, tem crescido o entendimento de que a retratação, a qualquer momento, antes do trânsito em julgado, seria causa de extinção da punibilidade.

Também vem crescendo na doutrina o entendimento de que, se o crime foi praticado em concurso (participação ou coautoria), a retratação de um se estende aos demais, comunicando-se. Isso porque o fato deixa de ser punível, e não o autor.

Além disso, a retratação deve ocorrer no processo em que fora prestado o falso testemunho ou falsa perícia, e não no eventual futuro processo que será instaurado para punir o infrator.

A ação penal é pública incondicionada.

6. ART. 343. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA, PERITO, CONTADOR, TRADUTOR OU INTÉRPRETE

Segundo o art. 343, *dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação* é crime punido com reclusão, de três a quatro anos, e multa. Admite-se o acordo de não persecução penal.

Aplica-se aqui o princípio da especialidade em relação ao crime de corrupção ativa.

A doutrina critica o preceito secundário, sob alegação de que haveria uma violação ao princípio da individualização da pena, pois as penas mínima e máxima estão muito próximas.

Qualquer pessoa pode praticar o crime. Se o agente se vale de violência ou de ameaça para coagir o perito ou a testemunha a mentir, haverá o crime de coação no curso do processo.

Caso receba a vantagem indevida, o perito ou testemunha cometerá o crime do art. 342, §1º, ou seja, com a causa de aumento de pena, pois se trata de atuação mediante suborno. Observe que se trata de um caso de exceção pluralista à teoria monista. Isso porque quem paga responde pela corrupção ativa de testemunha, perito, mas quem recebe comete o crime de falso testemunho ou falsa perícia majorado.

Se o perito for oficial, ou seja, funcionário público, o crime será de corrupção ativa do art. 333 do CP.

O elemento subjetivo é o dolo. Além disso, existe o especial fim de agir de obter dos sujeitos processuais um comportamento que se distancie da verdade, mentindo em juízo ou no processo.

O crime é formal, consumando-se com o oferecimento ou a promessa de vantagem. Não é necessário que a testemunha, perito ou intérprete minta. Na conduta de dar vantagem indevida, o crime é material.



Nos termos do parágrafo único, as penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

A ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 344. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

Segundo o art. 344, *usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral* é crime punido com reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Cabível a suspensão condicional do processo. Praticado com violência ou grave ameaça, não se mostra possível o acordo de não persecução penal.

O crime é comum, qualquer pessoa pode praticar, tendo ou não interesse no desfecho do litígio. O sujeito passivo é o Estado.

Segundo entendimento clássico da doutrina, a grave ameaça é elementar do tipo penal e é verificada quando apta a causar temor e intimidação na maioria das pessoas (homem médio).

Para a caracterização do crime, é indispensável que já exista um procedimento em curso.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, acrescido do especial fim de agir, consistente na satisfação do interesse próprio ou alheio.

A consumação ocorre no momento em que empregada a coação, independentemente da efetiva satisfação do interesse buscado pelo agente. Assim, observa-se que o delito é formal.

A tentativa é admitida.

Se da violência resultar ferimentos, haverá o cúmulo material das penas.

A ação penal é pública incondicionada.

8. ART. 345. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite é crime punido com detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

É infração de menor potencial ofensivo, havendo o cúmulo material com o crime de violência.

Tutela-se a administração da justiça, para que os cidadãos não usurpem prerrogativas do Estado.

O crime é comum. Se o sujeito ativo for funcionário público, o crime poderá ser de abuso de autoridade (Lei nº 13869/19). O Estado é o sujeito passivo. Além disso, é delito de forma livre, admitindo ampla liberdade de execução.

Para a doutrina, o crime só se configura quando o agente poderia buscar aquele direito (pretensão) no Poder Judiciário, mas, em vez disso, decide fazer "justiça com as próprias mãos".

Segundo já decidiu o STJ, a prostituta maior de idade e não vulnerável que, considerando estar exercendo pretensão legítima, arranca cordão do pescoço de seu cliente pelo fato de ele não ter pago pelo serviço sexual combinado e praticado consensualmente, pratica o crime de exercício arbitrário das próprias razões e não roubo.

Desse modo, não se pode negar proteção jurídica àquelas (e àqueles) que oferecem serviços de cunho sexual em troca de remuneração, desde que, evidentemente, essa troca de interesses não envolva incapazes, menores de 18 anos e pessoas de algum modo vulneráveis e desde que o ato sexual seja decorrente de livre disposição da vontade dos participantes e não implique violência (não consentida) ou grave ameaça (Informativo 584).



Trata-se de **crime material**, ou seja, para sua consumação, é necessário que a pessoa consiga a satisfação de sua pretensão, fazendo de fato justiça com as próprias mãos. A tentativa é possível.

A ação penal será pública incondicionada se houver violência.

Nos termos do parágrafo único, se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, ou seja, será **ação penal privada**. Tem-se, assim, um exemplo de **ação penal secundária**. Isso porque as circunstâncias do caso concreto fazem variar a modalidade de ação penal a ser ajuizada.

9. ART. 346. SUBTRAÇÃO, SUPRESSÃO OU DANIFICAÇÃO DE COISA PRÓPRIA NO LEGÍTIMO PODER DE TERCEIRO

Segundo o art. 346, *tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção* é crime punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

O *nomen juris* não consta do texto legal, sendo usualmente empregado pela doutrina. Tutela-se a administração da justiça, no que diz respeito ao conteúdo dos acordos de vontade.

Somente o proprietário da coisa poderá praticar o crime (crime próprio). Porém, é possível o concurso de agentes. O sujeito passivo é o Estado.

Cuida-se de tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo ou variado (tirar, suprimir, destruir ou danificar). A prática de mais de um dos verbos, no mesmo contexto fático, enseja crime único.

A consumação ocorre se a coisa for retirada da esfera de terceiro sem o seu consentimento. Caso o terceiro entregue a coisa, não haverá crime.

Alguns doutrinadores consideram o tipo como uma forma especial de exercício arbitrário das próprias razões.

O elemento subjetivo é o dolo.

A ação penal é pública incondicionada.

10. ART. 347. FRAUDE PROCESSUAL

Nos termos do art. 347, *innovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito* é crime punido com detenção, de três meses a dois anos, e multa. É infração de menor potencial ofensivo.

O sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa, inova o estado de coisa, pessoa ou lugar com o fim de enganar juiz ou perito e obter algum tipo de proveito injusto. É o chamado estelionato processual.

Trata-se de **crime formal**, dispensando o efetivo engano. A inovação deve ser idônea a enganar o juiz ou perito, pois, do contrário, haverá crime impossível.

Os objetos materiais do crime estão descritos no tipo, de forma taxativa, sendo descabida a interpretação ampliativa.

O delito pressupõe um processo civil ou administrativo em andamento, salvo quando diz respeito ao processo criminal.

O elemento subjetivo é o dolo, acrescido do especial fim de agir, consistente no fim de induzir a erro juiz ou perito.

O parágrafo único prevê causa especial de aumento de pena. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Exemplo de conduta que se amolda à presente figura típica é a limpeza de manchas de sangue do corpo da vítima ou do local do crime.

A ação penal é pública incondicionada.



11. ART. 348. FAVORECIMENTO PESSOAL

Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão é delito punido com detenção, de um a seis meses, e multa. É infração de menor potencial ofensivo. O § 1º prevê que, se ao crime não é cominada pena de reclusão, a pena daquele que pratica o favorecimento pessoal passa a ser de detenção, de quinze dias a três meses, e multa.

Tutela-se a administração da justiça, a qual não pode ser embaraçada pela atitude daqueles que auxiliam um criminoso, proporcionando-lhe a fuga.

Qualquer pessoa poderá praticar o crime, até mesmo a vítima do fato criminoso anterior. Não se admite o autofavorecimento.

O favorecimento pessoal é um delito acessório, pois pressupõe a prática de um crime anterior sujeito à reclusão. O auxílio deve ser concreto, efetivo. A conduta ora em estudo não abrange a contravenção penal (conduta será atípica).

O delito se consuma no momento em que o auxílio é prestado com êxito. Assim sendo, o crime é material. É compatível com a tentativa.

O § 2º estabelece escusa absolutória. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Por analogia, fundada na inexigibilidade de conduta diversa, a doutrina entende que deve abranger o companheiro.

A ação penal é pública incondicionada.

12. ART. 349. FAVORECIMENTO REAL

Segundo o art. 349, *prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime* acarreta pena de detenção, de um a seis meses, e multa. É infração de menor potencial ofensivo.

Trata-se de **crime subsidiário**. Perceba que, se o auxílio for destinado a tornar seguro o proveito de contravenção, não haverá crime.

Qualquer pessoa poderá praticar o crime. O sujeito passivo é o Estado.

O favorecimento real é um delito acessório, pois pressupõe a prática de um crime anterior. Não se exige a prévia condenação transitada em julgado em relação ao delito anterior.

Enquanto no tipo do art. 348, o favorecimento pessoal, buscava-se a fuga do criminoso, no presente caso presta-se auxílio não diretamente à pessoa que cometeu o crime, mas sim à ocultação do proveito do ilícito.

O elemento subjetivo é o dolo, acrescido do especial fim de agir.

Se o indivíduo praticar o roubo, mas após a consumação ligar para o amigo e pedir para que ele auxilie a guardar a coisa por um valor combinado, haverá a prática do crime de receptação. Perceba que já estava consumado o roubo e o dolo está relacionado à vantagem dada pelo autor do crime antecedente.

Diferentemente, se o indivíduo, antes de efetuar o roubo, avisa o amigo que irá realizar o crime, pedindo para que ele guarde a coisa em sua residência, **o sujeito que auxilia a guarda da coisa responderá pela participação no roubo**, e não por favorecimento real.

Consuma-se o crime com a efetiva prestação do auxílio, independentemente de tornar seguro o proveito do crime. Em outras palavras, trata-se de crime formal.

Atenção! O favorecimento real é crime formal e o favorecimento pessoal é crime material.

O favorecimento real não traz a previsão da escusa absolutória, motivo pelo qual se o agente torna seguro o proveito do crime que o filho, irmão, ascendente ou descendente cometeu, será punido nos rigores legais.

A ação penal é pública incondicionada.



12.1. ART. 349-A

O art. 349-A prevê:

Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. A pena cominada é de detenção, de três meses a um ano.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

A figura foi introduzida no CP pela Lei nº 12.012/2009. A mesma crítica feita quanto ao pouco rigor da pena quanto ao art. 319-A (prevaricação nos presídios, conduta do diretor da penitenciária ou agente público) também merece ser feita para o tipo ora em comento.

O delito é comum. É mais frequentemente praticado por visitantes do sistema prisional (parentes e amigos dos internos). O sujeito passivo é o Estado.

O crime é de mera conduta, consumando-se com a prática de um dos núcleos do tipo (ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar), não interessando se o aparelho que ingressou no estabelecimento prisional chegou ao seu destinatário.

A ação penal é pública incondicionada.

13. ART. 350. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO OU ABUSO DE PODER

Revogado pela Lei nº 13.869/19 (Lei do Abuso de Autoridade).

14. ART. 351. FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA

Segundo o art. 351, *promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva* acarreta pena de detenção, de seis meses a dois anos. Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo.

Nos termos do § 1º, se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de dois a seis anos. Trata-se da forma qualificada.

Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência, nos termos do § 2º.

O § 3º prevê que a pena será de reclusão, de um a quatro anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado. Nessa hipótese, verifica-se um **crime próprio**.

No § 4º, tem-se a previsão da forma culposa. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa. É infração de menor potencial ofensivo. **Também é crime próprio, pois somente pode ser cometido pelo funcionário público que tenha o preso sob custódia.**

Nas modalidades do *caput* e § 1º, o crime é comum.

A facilitação de fuga de adolescente que está regularmente apreendido não configura o crime.

A consumação ocorre quando o preso ou internado obtém êxito na fuga, ainda que por breve período de tempo. O crime é material, exigindo-se que o preso consiga efetivamente fugir.

A ação penal é pública incondicionada.



15. ART. 352. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA

Dispõe o art. 352: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Cometido com violência, não admite o acordo de não persecução penal.

O crime somente poderá ser praticado pelo preso ou pelo internado. É crime próprio.

Consuma-se com a fuga ou com o simples emprego dos meios necessários à fugir, com violência à pessoa. O crime é de atentado, pois se pune a tentativa da mesma forma que o crime consumado.

A fuga sem violência à pessoa não configura crime, podendo ser punida a título de falta grave, conforme previsão do art. 50, inc. II, da LEP.

A ação penal é pública incondicionada.

16. ART. 353. ARREBATAMENTO DE PRESO

Arrebatado preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda é delito punido com reclusão, de um a quatro anos, além da pena correspondente à violência. Admite-se a suspensão condicional do processo. Em razão da violência, não é possível o acordo de não persecução penal.

O crime é comum. O sujeito passivo é o Estado. Proíbe-se a analogia, não se cogitando de crime o arrebatamento de pessoa submetida à medida de segurança para a finalidade de maltratá-la, ou o adolescente.

Arrebatado significa retirar com violência.

O crime se consuma no momento em que o preso custodiado é arrebatado. É formal, pois não se exige que o preso efetivamente seja maltratado.

A tentativa é admissível.

A ação penal é pública incondicionada.

17. ART. 354. MOTIM DE PRESOS

O art. 354 estabelece: *amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão.* A pena é detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

É um crime próprio, pois somente poderá ser cometido por preso. Além disso, é necessária a pluralidade de agentes, sendo um crime de concurso necessário, delito coletivo ou multitudinário.

Não compreende como motim quando a perturbação da ordem ocorre em hospitais de custódia, pois o tipo fala em amotinarem-se os presos e não os submetidos a medida de segurança. Também não haverá motim com a participação de funcionários do estabelecimento prisional.

O crime se consuma quando há infração à ordem ou à disciplina da prisão, com duração por período relevante.

A ação penal é pública incondicionada.

18. ART. 355. PATROCÍNIO INFIEL

Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado é o crime previsto no art. 355, punido com detenção de seis meses a três anos, e multa. Admite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.



Trata-se de crime próprio, pois somente poderá ser praticado pelo advogado ou procurador judicial.

O patrocínio infiel caracteriza-se em juízo. Pode ocorrer por ação ou omissão.

O crime é material, pois somente irá se consumir com a efetiva ocorrência de prejuízo ao patrocinado, ainda que reversível.

PATROCÍNIO SIMULTÂNEO OU TERGIVERSAÇÃO

O parágrafo único do art. 355 estabelece que incorre na pena de detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.

Nesse caso, o tipo não exige prejuízo ao indivíduo patrocinado. Não é necessário que seja idêntico processo, bastando que seja a mesma causa.

A ação penal é pública incondicionada tanto na figura do *caput* quanto do parágrafo único.

19. ART. 356. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO

Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Esta conduta criminosa é punida com detenção, de seis meses a três anos, e multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Trata-se de crime próprio, pois somente poderá ser praticado pelo advogado ou procurador.

Inutilizar significa destruir. Pressupõe uma ação. Já a segunda conduta, deixar de restituir, corresponde a uma omissão.

O elemento subjetivo é o dolo. Não se perquire o especial fim de agir. A conduta culposa não é punida, podendo implicar apenas sanções processuais, como a proibição de retirada dos autos do cartório.

A ação penal é pública incondicionada.

20. ART. 357. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO

Segundo prevê o art. 357, *solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha* é crime apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O parágrafo único estabelece que as penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

Trata-se de crime comum. A condição especial do servidor é o que diferencia o crime de exploração de prestígio do crime de tráfico de influência, pois este último exige a condição especial de servidor público.

É irrelevante se o autor do crime tinha ou não influência sobre as pessoas mencionadas no tipo penal. Se a agente efetivamente estiver em conluio com o servidor público, o crime poderá ser o de corrupção passiva.

A ação penal é pública incondicionada.

21. ART. 358. VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL

Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem é crime punido com



detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. É infração de menor potencial ofensivo.

O crime é comum ou geral. O sujeito passivo é o Estado.

O delito se consuma, na primeira modalidade, no momento em que a arrematação judicial é impedida, perturbada ou fraudada, sendo crime material. Já na segunda forma, afastar ou procurar afastar concorrente, o delito é formal.

A ação penal é pública incondicionada.

22. ART. 359. DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO

Segundo o art. 359, *exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial* é crime punido com detenção, de três meses a dois anos, ou multa. Admite-se a transação penal e a suspensão condicional do processo.

A doutrina majoritária diz se tratar de crime próprio. Deve ser uma pessoa que está privada ou suspensa, por decisão judicial, de exercer uma atividade ou direito, função ou múnus.

Há, nitidamente, um plus especializante em relação ao art. 330 (desobediência geral).

O elemento subjetivo é o dolo. O delito se consuma quando o sujeito contraria a decisão judicial, iniciando o exercício da função, atividade, direito, autoridade ou múnus. É possível a tentativa.

A ação penal é pública incondicionada.

QUESTÕES

1- (CEBRASPE MPPI 2019) Para influenciar promotor de justiça a não oferecer denúncia contra Lúcio, Mário, analista do Ministério Público, solicitou ao provável denunciado a quantia de R\$ 5.000. Lúcio pagou o valor, mas Mário não comentou o assunto com o membro do Ministério Público, e a denúncia foi oferecida regularmente. Nessa situação hipotética, Mário e Lúcio cometeram, respectivamente,

A o crime de tráfico de influência e uma conduta atípica.
B os crimes de tráfico de influência e de corrupção ativa.
C o crime de exploração de prestígio e uma conduta atípica.
D os crimes de exploração de prestígio e de corrupção ativa.
E os crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa.

Gabarito: C



CAPÍTULO 68 — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS

No último capítulo do CP são tratados os crimes contra as finanças públicas. São oito tipos penais, acrescidos ao texto pela Lei nº 10.028/2000. Todos os delitos são praticados apenas a título doloso. Não há previsão da forma culposa.

A tutela penal busca dar efetividade à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 37 da CF.

1. ART. 359-A. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Segundo o art. 359-A, *ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa* é crime punido com reclusão, de um a dois anos.

O parágrafo único contempla as figuras equiparadas. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:

I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.

É infração de menor potencial ofensivo. Tutela-se a regular administração das finanças públicas, em especial o controle legislativo sobre o orçamento.

O crime é próprio, pois somente pode ser praticado pelo agente público com as atribuições descritas no tipo penal. O sujeito passivo será a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios.

Nas modalidades ordenar ou autorizar, o crime só se consuma com a abertura do crédito, pois somente nesta situação é que se observa lesão ao bem jurídico. Na modalidade realizar a operação de crédito, consuma-se com a efetiva celebração da operação de crédito. Todavia, a doutrina é bastante divergente neste ponto.

A ação penal é pública incondicionada.

2. ART. 359-B. INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR

Nos termos do art. 359-B, *ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei* acarreta pena de detenção, de seis meses a dois anos. É infração de menor potencial ofensivo.

Empenho é o ato realizado pela autoridade competente que cria ao Estado a obrigação de pagar. Inscrever despesa que não tenha sido previamente empenhada é crime.

Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro. Só entra aquela dívida já reconhecida pelo Estado como obrigação de pagar, mas que não foi paga até 31 de dezembro.

O crime é de mera conduta, consumando-se quando há a ordem ou autorização expedida pelo agente público para inscrever despesa que não foi empenhada, como resto a pagar.

A ação penal é pública incondicionada.

3. ART. 359-C. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa



é delito apenado com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Cabe suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O crime é próprio, pois somente pode ser praticado por um detentor de mandato, não necessariamente eletivo. É necessário que seja alguém que tenha poder de decisão administrativa sobre aquele ente público que representa. Ex.: Presidente do Tribunal de Justiça, Procurador Geral de Justiça, Defensor Público Geral.

O crime se consuma no momento em que o administrador ordena ou autoriza a assunção de obrigação que não irá pagar nos dois últimos quadrimestres, ou deixa parcela que não tenha contrapartida suficiente em caixa.

Caso interessante envolvendo prefeito, empréstimos consignados e a prática do delito em comento foi julgada pelo STF em 2016.

Diversos servidores municipais tinham empréstimos consignados cujos valores eram descontados da folha de pagamento. O Prefeito ordenou que fosse feita a retenção, mas que tais valores não fossem repassados à instituição e sim gastos com o pagamento de despesas do Município. Isso foi feito no último ano do mandato do Prefeito, quando não havia mais recursos para pagar o banco, o que só foi feito no mandato seguinte.

O STF entendeu que, nesta situação, restou configurada a prática do peculato-desvio, pois o Município era mero depositário dos recursos, que não eram receita pública, e deu destinação diversa a essa quantia (art. 312 do CP), e que o então Prefeito (réu) autorizou a assunção de obrigação, sem pagar a despesa no mesmo exercício e sem deixar receita para a quitação no ano seguinte, **ficando configurada a prática do crime previsto no art. 359-C do Código Penal** (Informativo 826 STF)⁷⁸.

A ação penal é pública incondicionada.

4. ART. 359-D. ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA

Ordenar despesa não autorizada por lei é o crime descrito pelo art. 359-D, punido com reclusão, de um a quatro anos. Admite-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

O crime é próprio, pois necessita de um agente público que tenha atribuição para ordenar a despesa. Ademais, é formal, consumando-se no momento em que é determinada a ordem de despesa, sendo dispensável a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário.

A ação penal é pública incondicionada.

5. ART. 359-E. PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA

Nos termos do art. 359-E, *prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei* é delito punido com detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo.

O crime é próprio, pois praticado pelo gestor que tem a atribuição para realizar a operação de crédito com terceiro.

A consumação ocorre quando a garantia é prestada sem a constituição da contrapartida exigida por lei. Trata-se de crime de perigo concreto.

A ação penal é pública incondicionada.

⁷⁸ Fonte: Dizer o Direito. Acesso e Disponibilidade: <https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/06/info-826-stf.pdf>



6. ART. 359-F. NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

O art. 359-F prevê como crime a conduta de deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. A pena cominada é de detenção, de seis meses a dois anos.

O crime é omissivo, não admitindo tentativa.

Ademais, o crime é próprio, pois praticado por agente público que tenha atribuição para ordenar, autorizar ou promover o cancelamento do montante de restos a pagar.

Se o valor da dívida inscrita não for superior ao determinado em lei, a conduta será atípica. A simples demora no cancelamento, por culpa, não constitui crime.

A ação penal é pública incondicionada.

7. ART. 359-G. AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

Segundo o art. 359-G, *ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura* é crime punido com reclusão, de um a quatro anos. Admite a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Tutela-se a regularidade das contas públicas, evitando o aumento das despesas ao final do mandato, com fins eleitoreiros.

O crime é próprio, pois praticado por agente público que tenha essa atribuição.

Nos núcleos “ordenar” e “autorizar” o crime será formal. No entanto, no núcleo “executar ato que acarrete aumento de despesa”, o crime será material, perfazendo-se com o efetivo aumento de despesa.

A ação penal é pública incondicionada.

8. ART. 359-H. OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO

O art. 359-H prevê como crime *ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia*. A pena cominada é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Cabe suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal.

Tutela-se a regularidade das finanças públicas, de sorte a coibir a emissão de títulos da dívida pública sem o devido controle.

O crime é próprio, praticado por agente público que tenha atribuição para ordenar, autorizar e promover a introdução do título da dívida pública no mercado financeiro.

A ação penal é pública incondicionada.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bitencourt, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal**, 25ª edição, São Paulo: Saraiva, 2019.

Capez, Fernando. **Curso de Direito Penal – parte geral**, 9ª edição, São Paulo: Saraiva, 2005.

Cunha, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal – parte especial**, 8ª edição, Salvador: Juspodivm, 2016.

Cunha, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal – parte geral**, 4ª edição, Salvador: Juspodivm, 2016.

Estefam André. **Direito Penal – parte geral**, 1ª edição, São Paulo: Saraiva, 2010.

Gonçalves, Victor Eduardo Rios; Baltazar Junior, José Paulo. **Legislação Penal Especial**, 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 2016.

Hungria, Nelson; Fragoso, Heleno Claudio. **Comentários ao Código Penal**, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1977.

Mirabete, Julio Fabbrini. **Manual de Direito Penal**, 23ª edição, São Paulo: Atlas, 2006.

